



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون

محاضرات في قانون المرافعات مقارنة بالفقه الإسلامي

الأستاذ الدكتور
أحمد خليفة شرقاوي
أستاذ قانون المرافعات المساعد
كلية الشريعة والقانون
بطنطا

الأستاذ الدكتور
حامد محمد أبو طالب
أستاذ قانون المرافعات
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
وعميدها الأسبق

٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م



مقدمة

الحمد لله .. الحاكم العادل .. القاضى بالقسط يوم الفصل .. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره .. ونسأله أن يبسط لنا الاعتراف بفضله، ويقبض لسان الدعوى .. وأن يحسم مادة الشكوى .. ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشاهد والبشير والناظر .. المنزل عليه قول الله تعالى ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١).

وأشهد أن لا إله إلا الله القاضى بالعدل بين الخصوم ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، الشاهد بالحق على العموم ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بقية الشهود.

أما بعد ...

فهذا موجز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقاً لتعديلاته وأنظمتها الجارية، وقد جاء في شكل محاضرات متتالية مقارنة بالفقه الإسلامي، وهو عندنا الآن بمثابة النواة، التي ندعو الله - عز وجل - أن يمكننا من النسخ حولها، والبناء فوقها، حتى يليق هذا العمل بعظمة هذا الركن العتيق - الأزهر الشريف - ومكانته العلمية في العالم كله ، وذلك على وفق ما يناسب ذاتية الدراسة في كلية الشريعة والقانون وعلومها الأصيلة.

هذا، ولقد جمعنا في هذا المؤلف بين شرح قانون المرافعات وأحكام الفقه الإسلامي، حتى يكون لمؤلفات هذا الصرح العلمي طابعها المتميز، ولبحوثه مذاقها الفريد من حيث التأصيل والمعاصرة ، مع مراعاة الإيجاز الذي لا يخل بحقيقة المقصود من هذه الدراسة؛ تحصيلاً لقواعدها، وإحاطة بفروعها ومسائلها.

والله - سبحانه وتعالى - نسأل أن يغفر لنا زلاتنا ، وأن يبصرنا بعيوبنا ، وأن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن ينفع القارئ الكريم بما يقرأ إنه سميع مجيب.

(١) الآية ٦٥ من سورة النساء .

هذ، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نهمس في أذن القارئ الصديق بقول الله تعالى
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١)

ويحضرنا أن نذكره أيضا بقول الإمام الشافعي رحمه الله .

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي لعاصي

هذا وبالله التوفيق،،،

الأستاذ الدكتور
أحمد خليفة شرقاوي

الأستاذ الدكتور
حامد محمد أبو طالب.

(١) سورة البقرة ، من الآية رقم ٢٨٢.

تمهيد

تختلف نفوس البشر ونزاهتهم ، وتتباين أهواؤهم ورغباتهم ، ولا يستطيع إنسان أن يعيش منفرداً ومنعزلاً عن مجتمعه ، فلا بد من بقائه مع مجتمعه يأخذ منه ويعطي ، ومن ثم ينتج من ذلك اختلاف حتمي في وجهات النظر بين الناس ، مما يؤدي إلى التشاحن والتباغض والتحاقد والتحاسد ، لذا فإن الحاجة ماسة إلى وجود قواعد تبين حقوق الأفراد وواجباتهم ، لتلبي بذلك حاجاتهم ولقد وجدت القوانين الموضوعية ، كالقانون المدني والقانون التجاري وغيرهما ، لتبين حقوق الأفراد ، وكيف تنشأ هذه الحقوق ، وكيف تستعمل ، وكيف تنقضي .

ولكن لا يكفي وجود القوانين الموضوعية التي تبين حقوق الأفراد ، وواجباتهم ، بل لابد من وجود قواعد تبين كيفية حماية هذه الحقوق ، ورد ما يوجه إليها من اعتداءات ، وترسم الطريق لصاحب الحق للحصول على الحماية اللازمة لحقه ، وتحقيقاً لهذه الغاية وجدت قوانين المرافعات المتعاقبة .

تعريف قانون المرافعات :

يطلق " قانون المرافعات " ويراد به علم أو فقه المرافعات ، ويمكن تعريفه بهذا المعنى بأنه : علم يدرس شئون القضاة والتقاضى من أصول وأوضاع ، وعلى ذلك فهذا العلم يهتم بدراسة النظام القضائي ومبادئه ، وقواعد الاختصاص ومشاكله ، وإجراءات التقاضي وعوارضه ، ولا يدخل في هذه الدراسة ما يتعلق بتنفيذ الأحكام أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى ، وإنما تتم دراسة أحكام التنفيذ وطرقه وإجراءاته في مادة مستقلة هي مادة التنفيذ الجبري^(١) .

(١) - تُدرّس مادة " قانون المرافعات " في السنة الثالثة بكلّيات الحقوق بالجامعات المصرية ، وتدرس مادة " التنفيذ " في السنة الرابعة ، أما كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، فتدرّس مادة المرافعات في السنة الرابعة ، ومادة التنفيذ في السنة الخامسة - وهي السنة النهائية - وذلك في ظل نظام الدراسة القديم في هذه الكليات ، وأما في ظل النظام الجديد ، الذي استحدث بشأن تطوير الدراسة في كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فقد أصبحت هاتان المادتان تدرّسان على ذات النسق الجاري في كليات الحقوق ، فتدرّس المرافعات في السنة الثالثة ، والتنفيذ في السنة الرابعة ، حيث أصبحت الدراسة في كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أربع سنوات بدلاً من خمس سنوات .

كما يطلق ذات التعبير " قانون المرافعات " ويراد به مجموعة القواعد التي تنظم التداعي أمام المحاكم ، وقواعد التنفيذ وطرقه ، وبعض الخصومات الأخرى . ويمكن تعريف قانون المرافعات بهذا المعنى بأنه : " مدونة قانونية تحدد اختصاص المحاكم ، وتبين الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم المدنية ، وترسم إجراءات التنفيذ الجبري وطرقه^(١) .

وقانون المرافعات بهذا المعنى لا يشتمل من مادة المرافعات إلا قواعد التداعي أمام المحاكم ، ويشتمل على الإجراءات وبعض قواعد الاختصاص وهو ما ورد في الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ م .

ومن ناحية أخرى فهو يشتمل على الأحكام العامة في التنفيذ وطرقه وإجراءاته ، وقد وردت هذه الأحكام في الكتاب الثاني من القانون سالف البيان تنفرد هذه الأحكام بمدونة خاصة أو تشريع مستقل^(٢) .

وأما الكتاب الثالث والأخير من قانون المرافعات فهو يشتمل على إجراءات وخصومات متنوعة^(٣) .

موضوع قانون المرافعات :

تشتمل دراسة قانون المرافعات على ما يلي :

أولاً : قوانين النظام القضائي :

وهي تشمل القواعد المتعلقة بترتيب الجهاز القضائي وبيان محاكمه وتشكيلاته .

وكذلك القواعد المتعلقة بالقضاة وأعاونهم من حيث شروط تعيينهم^(٤) ،

(١) انظر تعريفات أخرى غير هذا لأستاذنا الدكتور/ عبد الباسط جميعي في مبادئ المرافعات ، ص : ٤ ، وللدكتور / أحمد الصاوي في الوجيز في قانون المرافعات ص : ٦ ، وانظر أيضاً : مبادئ قانون القضاء المدني للدكتور / فتحي والي ، ص ٥ .

(٢) أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ، ص ٧ - ١٠ .

(٣) كمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة .

(٤) المادة الرابعة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ م ، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م ، وقوانين الهيئات القضائية ، حيث =

محاضرات في قانون المرافعات مقارنةً بالفقه الإسلامي

وقواعد ترقيتهم وإعارتهم^(١) ، ونقلهم وحقوقهم^(٢) ، وواجباتهم إلى غير ذلك من القواعد ، كما أنها تنظم عمل أعوان القضاة ، وهم المحامون والكتّاب والمحضرون والمترجمون .

=نصت على أن " يشترط فيمن يعين معاوناً للنياحة العامة وفي سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها في المادة الأولى أن يكون حاصلاً على إجارة الحقوق المنصوص عليها في البند ٣ من المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل ، وذلك بالنسبة إلى الوظائف التي يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون. الجريدة الرسمية ، العدد ١٨ مكرر أ" في ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ م .

(١) المادة " ٦٥ " من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م بإصدار قانون السلطة القضائية ، حيث نصت على أنه " تجوز إعاره القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي ، أو النائب العام بحسب الأحوال ، وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعاره على أربعة سنوات متصلة .

ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية مستبدلة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م ، وقوانين الهيئات القضائية .

(٢) المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م ، وقوانين الهيئات القضائية ، حيث نصت على أن " تستبدل عبارة " سبعة عاماً " بعبارة " ثمان وستين سنة " في كل من المواد " ٦٩ " ، من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م ، بإصدار قانون السلطة القضائية " ١٢٣ " من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م بشأن مجلس الدولة " ٢٩ " من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، والمادة " ١ " من القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٣ الصادر بتعديل بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، وفي تطبيق أحكام المواد " ١٣٠ " من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م بشأن السلطة القضائية " ١٤ ، ٢٤ " من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م .

الجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر " أ " في ٨ مايو ٢٠٠٧ م .

ثانياً : قوانين الاختصاص :

وهي مجموعة القوانين التي تحدد سلطات القضاة ووظائفهم ، وهي على ثلاث فئات : الأولى تبين ولاية كل جهة قضائية — عند تعدد جهات القضاء — كالقواعد التي تبين ولاية جهة القضاء العادي، وجهة القضاء الإداري، وجهات القضاء الأخرى^(١)، والثانية تبين اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية ، والثالثة تبين اختصاص كل محكمة من محاكم الدرجة الواحدة إقليمياً طبقاً للتوزيع الجغرافي أو المحلي .

ثالثاً : قوانين إجراءات التقاضي :

وهي مجموعة القوانين المتعلقة بالإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها في رفع الخصومات إلى القضاء ، ووسائل الدفاع أمام المحاكم ، وما يجب على المحاكم مراعاته عند الفصل في الخصومات ، وكيفية إصدار الأحكام ، وطرق الطعن فيها وكيفية تنفيذها ، وما يثور بشأنها عند تنفيذها من عقبات وطريقة تذليلها . والإجراءات بمعناها العام تشمل الإجراءات التي تتبع أمام جميع المحاكم، سواء كانت محكمة مدنية أم تجارية أم جنائية أم إدارية أم غير ذلك ، وإذا أطلقت هذه الكلمة " الإجراءات " انصرف معناها إلى الإجراءات الواجبة الاتباع أمام المحاكم المدنية والتجارية بخلاف غيرها من المحاكم ، فهي تختص بقوانين تنظم الإجراءات التي تتبع أمامها ، ولكن هذه الإجراءات دائماً تقيّد ولا تطلق ، كالإجراءات الجنائية وهكذا .

ومن الملاحظ أن هذه المجموعات من القوانين (النظام القضائي ، الاختصاص ، الإجراءات) تتصل ببعضها اتصالاً وثيقاً ، فمثلاً تشكيل المحاكم — وهو من قواعد النظام القضائي — يتصل اتصالاً وثيقاً بقواعد اختصاص كل محكمة ، وأيضاً قواعد الاختصاص اللصيقة بالإجراءات ، وذلك لأن قواعد الإجراءات تتضمن الجزاء على مخالفة قواعد الاختصاص^(٢) .

(١) — كما هو شأن جهة القضاء الدستوري وجهة القضاء العسكري وغيرهما من الجهات

الأخرى ، راجع : الدستور المصري الحالي ، الصادر في ٢٠١٤ م .

(٢) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، للدكتور / محمد حامد فهمي ص ٤ ، ٥ ، شرح قانون المرافعات الليبي للدكتور / عبد العزيز عامر ص ٦ ، شرح قانون المرافعات للدكتورين / عبد المنعم الشرقاوي ، عبد الباسط جميعي ص ٦ ، ٧ .

أهمية قانون المرافعات :

لا يكفي تعيين القضاة وتخصيصهم للفصل في المنازعات ، مع إطلاق الحرية لهم في تسيير الخصومات والحكم فيها بغير أوضاع معينة وإطلاق الحرية للخصوم يتخذون ما يريدون من إجراءات ، بل لا مناص لحسن سير القضاء من وجود قواعد مختصرة ميسرة تؤدي إلى سرعة الوصول إلى الحق ، وتوضح إجراءات التقاضي وأشكالها ومواعيدها ، لأن القاضي في بحثه عن الحقيقة بين أقوال الخصوم وادعاءاتهم يقوم بعمل دقيق وخطير ، فلا بد من قواعد ثابتة تحميه من التحكم ، وأيضاً فإن حق الدفاع يتطلب اتباع إجراءات معينة معلومة سلفاً ، ومراعاة مواعيد محددة معلومة ، تحول دون المفاجآت وتحمي الخصوم من اغتيال حقوقهم في غفلة منهم .

ولا شك أن وضع قواعد للإجراءات محدودة مختصرة ميسرة لتؤدي إلى سرعة وصول صاحب الحق إلى حقه من أسهل طريق وفي أقصر وقت وبأقل النفقات ، وهذا هو الهدف والفرص .

ولكن المبالغة في تعقيد الإجراءات وتطويلها ، وتوسيع مواعيدها بحجة السعي إلى توفير الضمانات لتحقيق العدل، يؤدي إلى عكس المطلوب ، فيصعب الطريق، ويطول وقته ، وتتضاعف نفقاته ، ويثقل عبؤه ، وقد قيل " إن العدل البطيء الغالي الثمن إنما هو نوع من الظلم "(١) .

طبيعة قانون المرافعات :

نقصد بطبيعة قانون المرافعات تحديد مكانه بين أقسام القانون ، أي هل : يعتبر من القانون الخاص أم من القانون العام ؟.

إذا نظرنا إلى القواعد التي يشملها قانون المرافعات بمعناه الواسع نجد أن من بين هذه القواعد ما يعتبر من القانون العام ، كالقواعد المتعلقة بالنظام القضائي ،

(١) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / محمد حامد فهمي ص ٥ ، ٦ ، شرح قانون المرافعات للدكتورين / عبد المنعم الشرقاوي ، عبد الباسط جميعي ص ٧ .

محاضرات في قانون المرافعات مقارنة بالفقه الإسلامي

وغالبية قواعد الاختصاص ، ذلك أن هذه القواعد تنظم تكوين واختصاصات السلطة القضائية ، وهي سلطة عامة ، وعلى هذا تعتبر هذه القواعد من القانون العام^(١) .

كذلك نجد القواعد المتعلقة بإجراءات الخصومة ، وهذه تبدل القول فيها ، فبينما كان الفقه القديم يرى أن هذه القواعد من القانون الخاص ، تأسيساً على أن هذه القواعد تتعلق بحقوق ومصالح الأشخاص الخاصة ، فهي تكفل لهم ممارسة حقوقهم الخاصة على قدم المساواة بينهم ، ويؤيد هذا النظر تسمية هذه القواعد بقانون المرافعات المدنية والتجارية ، لكن هذا الاتجاه بدأ في الانحسار واتجه بعض الشراح إلى القول بأن هذه القواعد تعتبر من القانون العام ، بالرغم من أنها ترمي في النهاية إلى حماية مصالح خاصة ، إلا أنها إجراءات لازمة لأداء مرفق القضاء لوظيفته ، فهي قواعد وضعت لأداء سلطة عامة لعملها^(٢) ، وينتهي هذا الفريق من الشراح إلى القول بأن قانون المرافعات فرع من القانون العام .

وتوسط كثير من الشراح^(٣) ورأي أن قانون المرافعات له طبيعة خاصة ، وفي منزلة وسط بين القانون العام والقانون الخاص ، حيث قد جمع هذا القانون بين قواعد من القانون العام وأخرى من القانون الخاص ، كما سبق القول .

(١) يقصد بالقانون العام مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان ، أما القانون الخاص فيقصد به مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات التي لا تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السيادة ، سواء أكانت هذه العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض أم كانت الدولة طرفاً فيها ، ولكن باعتبارها شخصاً اعتبارياً عادياً وليس باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان .

(٢) الدكتور / فتحي والي في مبادئ قانون القضاء المدني ، بند (٤) والدكتورة أمين النمر في قوانين المرافعات ف "٢٢" .

(٣) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص ٢٠ ، الدكتور / محمد العشماوي في قواعد المرافعات ف"٩" الدكتوران / عبد المنعم الشرقاوي وعبد الباسط جميعي في شرح قانون المرافعات ف"٤" ، الدكتور / أحمد الصاوي في الوجيز ف"٧" .

ونحن نؤيد هذا النظر ، ذلك أن قانون المرافعات تضمن قواعد تهم المصلحة العامة ، فتتصل بالقانون العام ، ومن هذه القواعد قواعد النظام القضائي ، وقواعد الاختصاص المتعلق بالولاية ، وقواعد علانية الجلسات وإشهار الأحكام ، وطرق الطعن وإجراءات التنفيذ الجبري .

كما أن قانون المرافعات تضمن قواعد لا تهم غير الخصوم ، فلهم تركها والاتفاق على غيرها ، ومن ثم تتصل هذه القواعد بالقانون الخاص ، ومن أمثلتها: قواعد الاختصاص المحلي وبعض قواعد الإجراءات .

التسميات المختلفة لقانون المرافعات :

تتعدد الموضوعات التي يتناولها قانون المرافعات بمعناه العام على ما سبق القول ، وكان هذا التعدد سبباً في اختلاف المقننين ، وكذلك الفقهاء في الاسم الذي يطلق على مجموعة القواعد القانونية المنظمة لسلطة القضاء وطريقة الالتجاء إليه ، ولا يزال الفقهاء والمقننون حائرين أشد الحيرة في اختيار اسم مناسب لقانون المرافعات^(١) ، والكل يجتهد في اختيار اسم يكون واضح الدلالة على الموضوعات التي ينظمها هذا القانون ، ونلقي نظرة سريعة على بعض هذه التسميات فيما يلي :

أ - : التسميات التشريعية :

يطلق المقنن المصري والسوداني والليبي والعراقي والكويتي على هذه المجموعة من القواعد القانونية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) ، بينما المقننان السوري واللبناني يطلقان عليها (أصول المحاكمات المدنية والتجارية) والمقنن المغربي يطلق عليها (المسطرة المدنية) ، والمقنن التونسي والجزائري والفرنسي والإيطالي يطلقون عليها (قانون الإجراءات المدنية والتجارية)^(٢) .

(١) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات فقرة "٣" .

(٢) وفي المملكة العربية السعودية كان يطلق على مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية " نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ولكن في ١٤/٧/١٣٩٥ هـ صدرت مجموعة قواعد نظم السلطة القضائية وسميت " نظام القضاء " كما كانوا يطلقون على الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم " نظام المرافعات الشرعية" ولكن ألغى هذا النظام وحل محله مجموعة إجراءات جديدة=

ب - التسمية الفقهية :

يطلق بعض الشراح على مجموعة القواعد القانونية المنظمة لسلطة القضاء وطريقة الالتجاء إليه " قانون الإجراءات المدنية والتجارية " وقد انتقدت هذه التسمية على أساس أن الإجراءات موضوع من الموضوعات التي تعالجها هذه المجموعة ، فهو اسم قاصر عن الدلالة على بقية الموضوعات .

وأطلق كثير من الشراح^(١) على هذه المجموعة اسم " قانون المرافعات المدنية والتجارية " وقد انتقد بعض الشراح^(٢) هذه التسمية تأسيساً على قصورها في الدلالة ، ذلك أن المرافعات هي بعض صور الإجراءات ، وإذا كانت كلمة الإجراءات وهي الكل قاصرة في الدلالة فما بالك بالمرافعات وهي الجزء .

وبذلك يرى تسمية هذه المجموعة باسم " قانون القضاء المدني " ولكن هذه التسمية أيضاً منتقدة ، ذلك أن هذه القواعد لا تهتم فقط بالمسائل المدنية ، وإنما تهتم أيضاً بمسائل القانون التجاري وقانون العمل والقانون الزراعي والأحوال الشخصية ، فهو يهتم بعلاقات الأفراد في نطاق القانون الخاص ، ولذلك اقترح تسميته باسم " قانون القضاء الخاص " ولكن هذه التسمية تثير في الذهن — عند

= سميت " نظم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية " ويلاحظ أن السعودية تستعمل كلمة " نظام " محل كلمة " قانون " نفوراً من الكلمة الأخيرة . انظر التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية د / محمد عبد الجواد ف ٧٣ ، وما بعدها ، النظام القضائي في المملكة العربية السعودية د / حامد أبو طالب ص ٢٠ وما بعدها .

(١) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ف ٢ ، الدكتوران عبد المنعم الشرفاوي وعبد الباسط جميعي في شرح قانون المرافعات ف ٧ ، الدكتور أمينة النمر في قوانين المرافعات ص ١١ .

(٢) الدكتور / فتحي والي في مبادئ قانون القضاء المدني ف ٣ .

إطلاقها — تصور نظام القضاء الخاص الذي لا تتولاه الدولة كما هو الحال في التحكيم^(١) .

وعندنا أن أفضل هذه التسميات في الدلالة على الموضوعات التي تعالجها هذه القواعد هو اسم (قانون القضاء المدني) فهو أكثر دلالة من غيره على هذه الموضوعات .

ومع هذا فلا مانع يمنع من استعمال اسم " قانون المرافعات المدنية والتجارية " ذلك أنه من الناحية التشريعية يدل دلالة شاملة على مجموعة القواعد التي يشملها ، فهو يشتمل على المسائل الإجرائية والاختصاص والدعوى ، ولم يعالج التنظيم القضائي ، ومن الناحية الفقهية يمكن توجيه إطلاق هذه الاسم " قانون المرافعات " على هذه الموضوعات على اعتبار أنها تسمية للكل باسم الجزء^(٢) .

علاقة قانون المرافعات بقوانين الإجراءات الأخرى :

تتعدد القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي ، فإلى جانب قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يوجد قانون الإجراءات الجنائية ، وهناك أيضاً إجراءات التقاضي في المنازعات الإدارية ، وإجراءات التقاضي في الضرائب بين الفرد والدولة ، وغير ذلك .

ومع تنوع الإجراءات تبعاً لتنوع القوانين الموضوعية ، إلا أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر الشريعة العامة في شأن التقاضي أياً كان نوعه مدنياً أم جنائياً ، أم إدارياً أم غير ذلك .

ومعنى هذا أن الأصول والمبادئ التي يتضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كحرية الدفاع ، وقواعد مخاصمة القضاة ، ونظام إدارة الجلسات وولاية المحاكم في تصحيح الأحكام وتفسيرها ، هذه المبادئ والأصول واجبة

(١) الوجيز في شرح قانون المرافعات للدكتور / أحمد الصاوي ف٤ .

(٢) انظر : قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ف ٣ ، قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر ص ٩ ، ١٠ ، أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ف٥ ، مبادئ قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ف٣ .

الاحترام عند التقاضي في المسائل المدنية أو الجنائية أو الإدارية أو غيرها ، ما دامت لا تتعارض مع القوانين الموضوعية أو الإجرائية الخاصة بذلك .
وينبغي على كون قانون المرافعات هو الشريعة العامة في التقاضي سواء كان مدنياً أم جنائياً أم إدارياً أم غير ذلك أنه يتعين الرجوع إلى هذا القانون عند ظهور نقص أو إيهام أو غموض في القوانين الإجرائية الأخرى ، وهذا ما نص عليه المقنن المصري صراحة في المادة (٣) من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون مجلس الدولة ، حيث قال " ... وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " (١) .
ومع كون قانون المرافعات هو الشريعة العامة ، إلا أن هذا القانون لا يطبق على الدعاوى الجنائية أو الإدارية إذا كانت القاعدة متعارضة مع القانون الجنائي أو الإداري أو لا تحقق أهدافهما بصورة مرضية (٢) .

خصائص قانون المرافعات :

تتميز قواعد قانون المرافعات — في مجموعها — بأنها قواعد أمرة وشكلية وفورية التطبيق .

أولاً : قواعد أمرة (٣) :

قواعد قانون المرافعات في جملتها قواعد أمرة ؛ لأنها وضعت لتنظيم مرفق عام من مرفق الدولة وهو مرفق القضاء ، ولا يعقل أن يترك للخصوم حق اختيار

(١) وهذا النص ورد بالقوانين السابقة التي كانت تنظم مجلس الدولة أرقام ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ، ٩ لسنة ١٩٤٩ ، و ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ، ٥٥ لسنة ١٩٥٩ . انظر : بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ص ١٥ في هامش ٢ .

(٢) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص : ٢٣ ، الدكتورة أمينة النمر في قوانين المرافعات ف ٢١ ، الدكتور / أحمد مسلم في أصول المرافعات ف ١٢ ، الدكتور / أحمد الصاوي في الوجيز ف ٤ .

(٣) تنقسم القواعد القانونية بحسب قوتها إلى قواعد أمرة وقواعد مقرررة ، القاعدة القانونية الأمرة : هي القاعدة القانونية التي لا يجوز للأشخاص الاتفاق على ما يخالفها ، والقاعدة المقررة أو المفسرة هي القاعدة التي يجوز للأشخاص الاتفاق على ما يخالفها .

الجهة القضائية الي يعرضون عليها نزاعهم ، أو تترك لهم حرية رفع دعاويهم بالطريقة التي تحلو لهم، ومن ثم كانت غالبية قواعد قانون المرافعات قواعد أمرة ، ومن هذه القواعد : القواعد التي تتعلق بالنظام القضائي ، ومعظم قواعد الاختصاص والقواعد التي ينص القانون صراحة على عدم جواز مخالفتها .

ولئن كانت غالبية قواعد قانون المرافعات قواعد أمرة بلا شبهة كما سبق إلا أن هناك قواعد يثور الخلاف على ما إذا كانت تعتبر من القواعد الآمرة^(١) ، أم هي من القواعد المقررة ، ولتحديد ذلك يتعين النظر إلى كل قاعدة على انفراد والبحث في الهدف من وضعها ، والغاية التي قصدها المقتن من ورائها ، فإذا كانت وضعت لتحقيق مصلحة عامة فهي أمرة ، وإن كتبت وضعت لتحقيق مصلحة خاصة فهي مقررة^(٢) .

ثانياً : قواعد شكلية :

قانون المرافعات قانون شكلي^(٣) ، فهو يجمع قواعد — في جملتها قواعد شكلية ؛ لأنها تلزم الأشخاص باتباع إجراءات معينة ، ومراعاة مواعيد محددة عند اللجوء إلى القضاء ، فهي تنظم الإجراءات والأشكال التي يتعين اتخاذها ، وتحدد المواعيد الواجب مراعاتها عند اللجوء للقضاء ، وهذه القواعد قواعد شكلية ؛ لأنها تتعلق بالشكل ولا تتعلق بموضوع الحقوق المطلوب حمايتها . والهدف من هذه الشكلية صيانة حقوق الخصوم من اغتيالها في غفلة منهم ومنع كيد بعضهم لبعض ، فهي تمكن المدعى عليه من تحضير دفاعه ، وتعطي

(١) الدكتور أمينة النمر في قوانين المرافعات ف ١٦ .

(٢) شرح قانون المرافعات للدكتورين / عبد المنعم الشرفاوي ، وعبد الباسط جميعي ف ٦ ، بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ص ٣ ، شرح قانون المرافعات الليبي للدكتور / عبد العزيز عامر ف ٥ .

(٣) القانون الشكلي : هو مجموعة القواعد المنظمة للإجراءات التي تتبع لتطبيق القانون الموضوعي ، والقانون الموضوعي : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية بين الأشخاص ، وتقرر الحقوق والواجبات وتحدد وسائل نشأتها ونطاقها وآثارها .

المدعي فرصة للوقوف على هذا الدفاع والرد عليه وتمكن القاضي من دراسة القضية وتضع حدوداً للقضاة في مباشرة وظائفهم لا يتعدونها ، حتى يكون الخصوم في مأمن من تحكم القضاة .

وإذا كان للشكلية أهميتها كضمانة من ضمانات العدالة ، ينبغي عدم المغالاة فيها حتى لا تتعقد الإجراءات ويصعب الطريق ويطول الوقت وتزداد النفقات ، وتضيع الحقوق لمجرد مخالفات شكلية لا ضرر منها^(١) ، " وذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطية ذلولاً ، لعدل سهل المنال ، مأمون الطريق ، لا يحتفل " بالشكل " ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً أو يرد به باطلاً ، عدل حريص على سد الذرائع الي يتسلل منها المبطلون ، محترفي الكيد ، وتجار الخصومة^(٢) . "

ثالثاً: فورية التطبيق:

قواعد قانون المرافعات فورية التطبيق ، بمعنى أنها عند تغيير هذه القواعد ، فإن القواعد الجديدة تسرى من وقت العمل بها على الدعاوى والإجراءات وأعمال التنفيذ القائمة أمام القضاء دون القواعد القديمة.

والعلة في ذلك أن قواعد المرافعات ، وضعت لتنظيم مرفق القضاء ، وبيان طريقة اللجوء إليه ، والإجراءات المتبعة في ذلك ، فإذا رأى المقنن أن يغير هذه القواعد أو يعدل فيها فلائنه قدر أن القواعد الجديدة أكثر ملائمة وتحقيقاً للعدالة من القواعد القديمة ، مما يستدعي تطبيقها فوراً على الدعاوى القائمة أمام القضاء ، ولأن قواعد المرافعات لا تنظم — كفاعدة — الحقوق الموضوعية للخصوم وأيضاً لا توجد مصلحة — مشروعة — لأحد الخصوم في نظر دعواه وفقاً لإجراءات معينة أو أمام محكمة دون أخرى^(٣) .

(١) الدكتور أحمد الصاوي في الوجيز بند ٩ ، وانظر قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر بند

٤ بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ص ٤ .

(٢) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الجديد ١٣ لسنة ١٩٦٨م

(٣) الدكتور / عبد العزيز بديوي في قواعد المرافعات ص : ٤ ، ٥ .

هذا هو الأصل — فورية تطبيق قواعد المرافعات — وعلى هذا الأصل ترد بعض الاستثناءات نوجز الحديث فيها فيما يلي :

١ - القوانين المعدلة للاختصاص :

استثنى المقنن من فورية التطبيق " القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى (١) .

وعلى ذلك إذا كانت هذه الدعوى لا تزال متداولة أمام المحكمة لم يقلل فيها باب المرافعة الجديدة تطبيق بأثر فوري ، ويجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها وفقاً للقانون الجديد ، وأما إذا كانت الدعوى قد أقفل باب المرافعة فيها ، وحجزت للحكم فإن القانون القديم هو الذي يسرى ، وتظل المحكمة مختصة بهذه الدعوى رغم أن القواعد الجديدة جعلت مثل هذه الدعوى من اختصاص محكمة أخرى ، وسواء كان حجزها للحكم مع الإذن بتقديم مذكرات أو بدونه ؛ لأن حجزها للحكم دليل على أنها قد تهيأت لإصدار الحكم فيها ولو لم تقدم المذكرات المأذون في تقديمها (٢) .

والحكمة من هذا الاستثناء أن الأصوب والأوفق هو أن تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي حققتها ، وسمعت المرافعة فيها حتى تهيأت الدعوى للحكم فيها ، وليس من الصواب في شيء إحالة هذه الدعوى ، وقد بلغت هذه الدرجة إلى محكمة أخرى ، فتعيد الإجراءات من جديد ، مما يطيل أمد الخصومة ويضاعف نفقاتها لمجرد تعديل الاختصاص .

وجدير بالذكر أن هذا الاستثناء لا يسري إذا كانت القواعد الجديدة لم تقتصر على تعديل الاختصاص ، وإنما ألغت محكمة أو جهة قضاء ، ففي هذه الحالة تنفذ

(١) المادة ١ / ١ مرافعات .

(٢) الدكتور / عبد العزيز بديوي في قواعد المرافعات ص ٥ .

القواعد الجديدة بأثر فوري ، وتنتقل الدعوى إلى جهة الاختصاص وفقاً للقواعد الجديدة حتى ولو كانت الدعوى قد أقفل باب المرافعة فيها^(١) .

٢ - مواعيد المرافعات

استثنى المقتن من فورية التطبيق " القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها " المادة ١ / ٢ مرافعات .

وعلى هذا إذا حدث تعديل في القواعد المنظمة للمواعيد^(٢) ، فإن هذا التعديل لا يسرى بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل تاريخ العمل بالقواعد الجديدة ، وإنما يسري بالنسبة لهذا الميعاد القواعد السابقة التي بدأ الميعاد في ظلها^(٣) .

والعبرة ببداية الميعاد وإن كان قد بدأ في ظل القواعد القديمة سرت القواعد القديمة ، وإن لم يبدأ إلا في ظل القواعد الجديدة سرت القواعد الجديدة^(٤) .

وهذا الاستثناء يقصد به القوانين التي تعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات ، وأما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد

(١) الدكتور / عبد العزيز عامر في شرح قانون المرافعات الليبي ص : ١٥ .

(٢) المراد بقواعد المواعيد ، القواعد المنظمة للأجال والمهل ، من حيث قدر الميعاد واحتسابه وبدايته ونهايته ، وامتداد الميعاد وآثاره ، وانظر : قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر ف ٤٤

(٣) فمثلاً إذا كان ميعاد الطعن ستين يوماً ، وبعد بدء الميعاد عدل إلى أربعين يوماً ، فإن الميعاد الذي بدأ يظل محكوماً بالقانون القديم ، ولا ينقضي إلا بانقضاء ستين يوماً كاملة ، وإذا كان الميعاد أربعين يوماً وبعد بدئه عدل إلى ستين فإن هذا الميعاد ينقضي بانقضاء أربعين يوماً ، سواء صدر القانون الجديد قبل انقضاء الميعاد القديم أو بعد انقضائه .

(٤) العبرة في بدء الميعاد باتخاذ الإجراء الذي يبدأ منه حساب الميعاد ، كما حدده القانون الذي بدأ الميعاد في ظله ، مثلاً إذا كان ميعاد الاستئناف لا يجرى إلا من وقت حصول الإعلان ولم يحصل الإعلان إلا بعد العمل بالقانون الجديد ، فإن القانون الجديد هو الذي يحدد مدة الاستئناف ولا عبرة ببداية الحق في الاستئناف .

فإنه لا يسري عليه هذا الاستثناء ، ولو كان الميعاد قد قرره الفقه أو القضاء بغير نص عليه في القانون لأن التعديل بقانون لا يرد إلا على نص موجود^(١) .
والعلة في هذا الاستثناء أنه متى بدأ الميعاد في ظل قانون معين ، فمن الأوفق والأعدل أن يتم الميعاد وفقاً للقانون نفسه ، حتى لا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته ونهايته^(٢) .

٣ - طرق الطعن في الأحكام .

استثنى المقتن من قاعدة فورية سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى ، أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، " القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق " المادة ١ / ٣ مرافعات .
وعلى ذلك فالأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد ، لا يسري عليها القانون الجديد فيما يتعلق بالطعن متى كان هذا القانون ألغى أو أنشأ طريقاً من طرق الطعن ، وإنما يسري عليها القانون القديم الذي صدرت هذه الأحكام في ظله .

والعلة في ذلك هي احترام الحقوق المكتسبة للأشخاص ، ذلك أن إلغاء طريق للطعن في حكم كان قابلاً للطعن وفقاً للقانون الذي صدر في ظله ، يمس حق المحكوم عليه في حرية الحصول على الحماية القضائية ، وأيضاً إنشاء طريق للطعن في حكم كان غير قابل للطعن ، وفقاً للقانون الذي صدر في ظله ، يمس حق المحكوم له في استقرار مركزه القانوني^(٣) .

(١) انظر الطعن رقم ٤٢٩ لسنة ٣٤ ق ، جلسة ٢٣ / ٥ / ١٩٦٨ ، س ١٩ ، ص : ١٠٠٨ .

(٢) شرح قانون المرافعات للدكتور عبد المنعم الشرقاوي ، عبد الباسط جميعي ف ١ .

(٣) انظر قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر ف ٤٦ .

تقسيم : هذا وسوف نقسم الدراسة في هذا المؤلف إلى أربعة أبواب على النحو التالي :

الباب الأول : النظام القضائي، ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء .

الفصل الثاني : ترتيب المحاكم وتشكيلها .

الفصل الثالث : العاملون بالقضاء .

الباب الثاني : نظرية الاختصاص والإحالة، ويشتمل على ستة فصول :

الفصل الأول : الاختصاص الولائي .

الفصل الثاني : الاختصاص النوعي .

الفصل الثالث : الاختصاص القيمي .

الفصل الرابع : الاختصاص المحلي .

الفصل الخامس : مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام .

الفصل السادس : الإحالة .

الباب الثالث : نظرية الدعوى والخصومة القضائية، ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول : الدعوى وطبيعتها القانونية .

الفصل الثاني : شروط قبول الدعوى .

الفصل الثالث : تقسيمات الدعاوى .

الفصل الرابع : دعاوى الحيازة .

الباب الرابع : إجراءات التقاضي، ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول : التقاضي بوسيلة الدعوى .

الفصل الثاني : التقاضي بوسيلة العريضة .

الفصل الثالث : طرق الطعن في الأحكام .

الفصل الأول

المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء

هناك مجموعة من المبادئ والأسس الهامة لا بد من توافرها لأي نظام قضائي عادل ، وذلك لأن هذه المبادئ والأسس تعتبر سوج^(١) متينة تحمي العدالة وضمانات هائلة لحسن سير القضاء ، ولأهمية هذه المبادئ تهتم بها الأمم ، ومن ثم فقد تنص على بعض منها في دساتيرها ، وتورد بعضها في القوانين الخاصة بالهيئة القضائية ، بل قد تتكرر القواعد المقررة لها في أكثر من موضع ، مما يشير إلى اهتمام المقنن بها .

وفيما يلي نتناول هذه المبادئ مخصصين مبحثاً لكل مبدأ وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول استقلال القضاء

مفهوم استقلال القضاء :

وظيفة القضاء فصل الخصومات بين الناس ، والنهوض بهذه الوظيفة على أكمل وجه يستلزم أن يكون القاضي بمنأى عن كل تأثير ، أو تدخل يؤدي إلى ميل ميزان العدالة في يده أو انحرافه في إمساكه بحياد ونزاهة ، ولذلك كان مبدأ استقلال القضاء من أهم المبادئ التي يقوم عليها أي نظام قضائي عادل .

ويقصد باستقلال القضاء أن يكون في مأمن من تدخل غير رجاله فيه ، فلا يجوز للسلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في القضاء أو التأثير عليه ، كما لا يجوز للقضاء أيضاً أن يتدخل في مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وعلى هذا يمتنع على السلطة التشريعية أن تتصدى للفصل في الخصومات بين الناس أو أن تصدر تشريعاً يهدف إلى تحديد وجه الفصل في نزاع معين معروض

(١) سوج جمع سياج، وهو ما أحيط به على الكرم ونحوه من شوك ونحوه ، والجمع أسوجة وسوج بضمين مثل: كتاب وكتب ، لكنه أمكن استقلاً للضمة على الواو . المصباح المنير ٣٤٧/١ طبع الأميرية .

أمام القضاء ، أو تعدل حكم أصدره القضاء في نزاع بعينه ، أو إيقاف تنفيذ حكم معين ، كما يتمتع على السلطة التنفيذية أن تصدر إلى القضاء أية توجيهات أو أوامر فيما يتعلق بوظيفة القضاء ، بل وعليها المعاونة في تنفيذ الأحكام القضائية ، ولو باستعمال القوة عند اللزوم .

كما يعني استقلال القضاء أيضاً أن يكون رجاله أنفسهم آمنين على مقومات حياتهم ، يعيشون في مأمن من تعسف رجال الإدارة أو أفرادها^(١) .

هذا ولقد اهتمت الدساتير المتتالية في مصر بهذا المبدأ ، ولا تجد دستوراً منها أغفل النص عليه ، بل وتكاد العبارة واحدة منذ دستور ١٩٢٣ حتى دستور ٢٠١٤ وقد أورد الأخير هذا النص حيث قال : " القضاء مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات ... " ^(٢) .

وعلى ذلك فالسلطة القضائية في مصر مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وينبغي على ذلك أن المقنن لا يملك سلطة الفصل في الخصومات ، ولا أن يصدر قانوناً يبين فيه وجه الفصل في نزاع معين ، كما لا يملك تعديل حكم أصدره القضاء ، وأيضاً لا تملك السلطة التنفيذية سلطة الفصل في الخصومات ، ولا أن تصدر إلى القضاء أية توجيهات أو أوامر فيما يتعلق بوظيفة القضاء ، كما لا تملك الاعتراض على تنفيذ حكم أصدره القضاء .

ومن ناحية أخرى تلتزم السلطة القضائية بتطبيق القوانين التي يصدرها المقنن ولا تستطيع أن تتدخل في شئون الإدارة أو في أعمال السلطة التنفيذية .

وحماية للقضاة وضماناً لاستقلالهم جعل المقنن التدخل في القضاء لصالح أحد الخصوم أو للإضرار به جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة سواء كان التدخل

(١) التنظيم القضائي الإسلامي د/ حامد أبو طالب ، ص : ٤٥ .

(٢) المادة ١٨٦ من الدستور الحالي ، وقد نصت المادة ١٨٤ منه على أن " التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم ... " راجع الدستور الحالي لسنة ٢٠١٤ المعدل .

بأمر أو طلب أو رجاء أو توصية^(١) ، ومن ثم فليس لأي فرد أن يملّي على قاض ما يحكم به في أية قضية من القضايا ، ولو كان هذا الفرد رئيس المحكمة التابع لها القاضي أو رئيس هيئة قضائية ، ولو كانت أعلى من المحكمة التابع لها القاضي ، أو حتى وزير العدل نفسه باعتباره عضو الوزارة المسئول عن القضاء^(٢) .

ومع هذا فاستقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس استقلالاً كاملاً ، فالسلطة التشريعية تبين القوانين وتطبقها السلطة القضائية ، وتملك الأخيرة الامتناع عن تطبيق قانون يخالف الدستور ، والسلطة التنفيذية تعين القضاة وترقيهم وتنقلهم ، كما أنها تسهم في تنفيذ الأحكام تحت إشراف قاضي التنفيذ^(٣) .

استقلال القضاء في النظام القضائي الإسلامي :

منذ أن فصل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه القضاء عن الولاية ، وخصص لبعض الولايات قضاة ، أصبح القضاة مستقلين عن السلطة التنفيذية ، وأصبحت وظيفة الفصل في الخصومات من اختصاص القضاة ، وظل القضاء في الإسلام مستقلين عن كل مؤثر ، سواء كان من رجال السلطة التنفيذية أو غيرهم من ذوي النفوذ أو الأقارب ، وقد أورد المؤرخون كثيراً من الحوادث التي تشهد بذلك^(٤) .

(١) انظر المادة ١٢٠ عقوبات .

(٢) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / محمد حامد فهمي ف ٢٤ .

(٣) شرح قانون المرافعات للدكتورين عبد المنعم الشرقاوي وعبد الباسط جميعي ف ٩٠ .

(٤) انظر من تفصيل ذلك التنظيم القضائي الإسلامي د / حامد أبو طالب ، ص ٤٥ ، أخبار القضاة لوكيع ١ / ١٠٥ ، ١٠٦ ، تاريخ القضاء في الإسلام للشيخ عرنوس ص : ١٢ ، الولاية والقضاة للكندي ص : ٤٢٧ ، رفع الإصر عن قضاة مصر ١ / ٢١ ، مبادئ التنظيم القضائي في العراق للأستاذ ضياء شيبث خطاب ص ٢٤ .

المبحث الثاني مجانية القضاء

المقصود بهذا المبدأ :

يقصد بمجانية القضاء أن القضاة لا يتناولون أجراً من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم ، وإنما يؤدون مهمتهم لقاء مرتبات تدفعها لهم الدولة شأنهم في ذلك شأن سائر العاملين في الدولة .

فالقضاة في مصر لا يتقاضون أجوراً على قضائهم من الخصوم ، وإنما يحصلون على رواتبهم من خزانة الدولة ، وتحصل الخزانة رسوماً من المتقاضين مقابل التجائهم إلى المحاكم ، ويدفع المدعي هذه الرسوم في البداية ، وإذا كسب الدعوى حكم بالمصروفات على خصمه فيستردّها منه ، وأما إذا خسر المدعي دعواه فإنه يتحمل الرسوم وحده .

وقد نادى بعض الشراح^(١) بتقرير مبدأ مجانية القضاء بكل معنى الكلمة تمكيناً للأشخاص من الحصول على الحماية القانونية ؛ لأنه لا ينبغي أن تكون الأعباء المالية سبباً في نكوص الدولة عن القيام بأخص وظائفها^(٢) .

وأياً ما كان الحال ، فقد قصد بإلزام المدعين بدفع رسوم ، التقليل من الخصومات الكيدية .

وأما الفقير الذي لا يملك مصاريف المطالبة بحقه ، فقد راعاه المقتنن وقرر إعفائه من الرسوم القضائية ، وحتى لا ينتهز الفقراء منحة الإعفاء ويكثر من

(١) الدكتور أمينة النمر في قوانين المرافعات ف ٣١ .

(٢) أخذت المملكة العربية السعودية بهذا المبدأ : مجانية القضاء ، وقررت عدم أخذ رسوم على القضاء في مختلف مستويات التقاضي ، فبابه مفتوح دون أية قيود وبالمجان . انظر : النظام القضائي في المملكة العربية السعودية د/ حامد أبو طالب ، ص ٣٨ ، الموسوعة الحديثة للملكة العربية السعودية ، حسن الفكهاني ، ٣ / ٢٥٢ ، مدى حق ولي الأمر في تنظيم القضاء وتقييده للدكتور عبد الرحمن قاسم ص ٦٦٣ .

الدعاوى بحق وبدون حق ، اشترط القانون للإعفاء من الرسوم إلى جانب ثبوت عجزه عن الدفع ، احتمال كسب الدعوى .

مجانية القضاء في النظام القضائي الإسلامي :

القضاء في الإسلام قضاء مجاني بكل معنى الكلمة ، فالقاضي لا يأخذ أجراً من المتقاضين لقاء الفصل بينهم ، وإنما يحصل على راتبه من بيت مال المسلمين فهو من عمال المسلمين وأجل عمالهم ، وهو قائم بمصالحهم ، فعليهم رزقه ، ومن يعاونه في أداء مهمته .

بل يرى فقهاء المسلمين أن يفرض للقاضي من الراتب ما يجعله يحيا حياة كريمة ، تليق برفعة هذا المنصب العلي والمكان الجلي ، فيفرض للقاضي ما يكفيه ويوسع عليه ، حتى لا يتطلع إلى أموال الخصوم أو غيرهم^(١) .

ولا يتحمل الخصوم أية نفقات في ظل القضاء الإسلامي ، فكل ما يحتاج إليه القاضي للنهوض بمهمته من أدوات كتابية أو غيرها ، فهي أو ثمنها من بيت مال المسلمين ، لكونها لازمة للقيام بمصالحهم^(٢) .

(١) وفي هذا المجال تجد في الفقه الإسلامي قلائد في جبين الدهر ، وقل أن وجود الزمان بمثلها ، فهذا كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حين بعثهما إلى الشام كتب يقول : " .. أن انظروا رجالاً من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم في الرزق ليكون لهم قوة وعليهم حجة " . انظر : روضة القضاء للسمناني ١ / ٨٦ . وهذا كتاب علي بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي واليه على مصر ، كتب يقول : " ... ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيته .. وافسح له في البذل ما يزيل عنه ، وتقل معه حاجته إلى الناس " نص تاريخ القضاء في الإسلام للشيخ عرنوس ص : ١٧ .

(٢) روضة القضاة للسمناني ١ / ٨٧ .

المبحث الثالث تعدد القضاة والقاضي الفرد

المقصود بهذا المبدأ :

يقصد بتعدد القضاة أن تنتظر الخصومة أمام محكمة مشكلة من عدد فرد من القضاة يدرسونها ويحققونها ويفصلون فيها .
وأما نظام القاضي الفرد فيقصد به أن تنتظر الخصومة أمام محكمة مشكلة من قاض واحد ، يقوم بمفرده بدراستها وتحقيقها والفصل فيها .
ولكل واحد من النظامين — تعدد القضاة والقاضي الفرد — مزاياه التي تعتبر بالتالي عيوباً في النظام الآخر .

مزايا تعدد القضاة :

١- نظام تعدد القضاة يمثل ضماناً من ضمانات العدالة ، ذلك أن هذا النظام يعطي الفرصة لدراسة الموضوع دراسة متأنية ومن وجهات نظر متعددة تمكن من إدراك جميع جوانبه ، وبالتالي يصدر الحكم بعد البحث ، والتمحيص أقرب ما يكون إلى الصواب ، بينما في نظام القاضي الفرد لا يدرس الموضوع إلا من وجهة نظر قاضي واحد ، وقد تغيب عنه بعض جوانبه .

٢- تعدد القضاة ينفي احتمال التحيز ، وذلك لأنه إذا أمكن تصور تحيز القاضي لشخص ما ، فلا يتصور تحيز مجموعة من القضاة لذات الشخص ، وكذلك إذا مال أحد القضاة لخصم ، فإن بقية الهيئة ستكون ضده في الرأي ، فضلاً عن أن مراقبة زملائه تمنعه من ذلك ، بخلاف القاضي الفرد ، فلن يختلف معه أحد في الرأي ، ولن يمنعه من تحيزه مراقبة أحد — إذا تصور إمكان التحيز .

٣- تعدد القضاة يسهم في تحقيق استقلال القضاء ، ذلك أن الحكم يصدر باسم الهيئة وينسب إليها مجتمعة ، فلا يعرف ما إذا كان قاضي معين مؤيداً للحكم أو معارضاً له مما يجعل القاضي لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية ، ومن ثم يكون في أمان وحرية في إبداء رأيه .

بخلاف نظام القاضي الفرد ، فالحكم فيه ينسب لقاض معين مما يجعله هدفاً للضغط عليه وإرهابه ، وقد يتأثر بالموثرات الخارجية ويخاف منها فيهتز ميزان العدالة في يده .

مزايا نظام القاضي الفرد :

١- نظام القاضي الفرد يشعر القاضي بمكانته ومسئوليته ، فهو الذي يصدر الحكم ، ويتحمل مسئوليته ، وينسب إليه مما يدعوه إلى الاجتهاد في بحث الموضوع ، والتروي في إصدار الحكم .

بخلاف الحال في نظام تعدد القضاة ، حيث ينسب الحكم إلى هيئة لا إلى فرد ، مما يدعو كل واحد منهم إلى الاعتماد على غيره .

٢- نظام القاضي الفرد يقلل من تكاليف القضاء ويحقق سرعة الفصل في المنازعات ، ذلك أن هذا النظام يمكن من توزيع القضاة ونهوض كل واحد منهم بعدد معقول من القضايا .

بخلاف تعدد القضاة حيث لا يمكن توزيعهم ، وإنما يجتمعون في مكان واحد ، وينهضون جميعاً بعدد محدود من القضايا ، مما يؤدي إلى تراكم القضايا وتأخير الفصل فيها وإطالة مدة التقاضي^(١) .

موقف المقتن المصري من تعدد القضاة والقاضي الفرد:

رأينا أن لكل من النظامين مزاياه وله عيوبه ، ولذلك حاول المقتن المصري الاستفادة من مزايا النظامين مع العمل على تقادي العيوب ، ومن ثم فقد أخذ بنظام تعدد القضاة — كقاعدة — فالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ، تتكون دوائرها جميعاً من عدد فردي من القضاة .

والى جانب هذا جمع المقتن مجموعة من الدعاوى يمكن وصفها بالبسيطة لكونها ضئيلة القيمة أو عديمة التعقيد ، أو لا تحتاج إلى خبرة قانونية عميقة ، أو

(١) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ص ١٨٦ ، المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / محمد حامد فهمي ف ٤٢ ، أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ، ف ٥٨ ، قانون المرافعات للدكتور محمد عبد الخالق عمر ص ١٠٠ .

لا يمس الحكم فيها أصل الحق ، وجعل هذه الدعاوى من اختصاص محكمة مكونة من قاض واحد .

وبذلك يتمكن المقنن المصري من الاستفادة بمزايا النظامين ، فالقضايا البسيطة التي تحتاج إلى سرعة ينظرها قاض فرد ، أما القضايا الكبيرة الخطيرة المعقدة فهي تحتاج إلى خبرة قانونية عميقة ، وهي جديرة بأن تنتظر أمام محكمة مشكلة من عدد من القضاة .

تعدد القضاة والقاضي الفرد في النظام القضائي الإسلامي :

لقد تحدث الفقهاء المسلمون في نظامي تعدد القضاة والقاضي الفرد وانتفقوا على أنه يجوز لولى الأمر أن يعين شخصاً واحداً في بلد واحد يتولى مهمة الفصل بين الناس في الخصومات وهو نظام القاضي الفرد^(١) .

ثم اختلفوا في جواز تعيين عدد من القضاة ، يتولون مجتمعين مهمة الفصل بين الناس في الخصومات^(٢) .

والراجح جواز تعدد القضاة — لا سيما في عصرنا الحاضر — لأن الخلاف في القضاة المجتهدين وقضاة العصر مقلدون ، والقضاء الآن مخصص بالزمان والمكان والنصاب المقدر من المال .

(١) مطالب أولي النهي ٦ / ٤٦٨ .

(٢) المغني لابن قدامة ٩٢/١٠ ، حاشية الدسوقي ١٣٤/٤ ، روضة القضاة للسمناني ٨١/١ ، ٨٢ .

المبحث الرابع المساواة أمام القضاء

المقصود بهذا المبدأ:

يقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء المساواة التامة بين جميع الأشخاص في حماية حقوقهم المشروعة ، وإعطاء كل إنسان الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه ودفع ما يقع عليه من اعتداء ، ويكون هذا الحق مقروا لجميع فرق في ذلك بنى غنى وفقير أو كثير وصغير أو أمير وخفير ، فعلاً تمييز بين الناس في حق اللجوء إلى القضاء بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة فالكل أمام القضاء سواء .

وتنص المادة (٩٧) من الدستور الحالي ٢٠١٤ على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ، والمحاكم الاستثنائية محظورة.

وعلى ذلك فلجميع الأشخاص على السواء الحق في الحماية القانونية لا فرق في استعمال هذا الحق بين شخص وآخر مهما تفاوتت منازلهم ، ولا مختلف اختصاص المحاكم إلا بسبب قيمة الدعوى ، أو نوع النزاع دون النظر. لأشخاص المتقاضين^(١) .

المساواة أمام القضاء في النظام القضائي الإسلامي:

لا يوجد نظام قضائي في العالم اهتم بمبدأ المساواة بمثل ما اهتم به النظام القضائي الاسلامى فقد جعل هذا النظام حق اللجوء إلى القضاء حقاً مكفولاً للجميع

(١) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ، ص ١٨١ ، ١٨٢ ، قوانين المرافعات للدكتورة / أمينة النمر ف ٢٥ ، ٢٦ .

بل وأوجب على القاضى مراعاة هذا المبدأ فى كل شئى حتى ولفظه ومجلسه ودخول الخصوم عليه^(١).

ومن الثابت أن لجميع الأشخاص الحق فى رفع دعاويهم أمام القضاء ويجب على القاضى أن يسمع الدعوى من أى مدع على أى إنسان ، ولا يجوز للقاضى أن يمنع أحدا من اللجوء إلى القضاء حماية الحق له اعتدى عليه سواء كان المدعى عليه غنياً أم فقير ، جليلاً أم حقيراً ، فللسوقة العامى أن يدعى على السلطان القاهرة^(٢) .

وتحدث الفقهاء المسلمون حديثاً طويلاً مفصلاً عن مبدأ المساواة وخلاصة قولهم أن " إطلاقه يعم الصغير والكبير ، والخلفية والرعية والدنى والشريف والأب والابن والمسلم والكافر^(٣) .

-
- (١) معين الحكام للطرابلسي ٢٠ ، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٥ ، السلطة القضائية وأطوارها ص ٤٩ ، رسالة بخط اليد أعدها عبد الصمد عبد الحليم سالم ، لنيل شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي سنة ١٣٥٦ هـ سنة ١٩٣٧ م ، بمكتبة كلية الشريعة برقم ٤٧٤ .
- (٢) نظرية الدعوى د / محمد نعيم عبد السلام ٢ / ٩ ، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٩٢ .
- (٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٥ ، حاشية الدسوقي ٤ / ١٤٢ ، شرح فتح القدير ٧ / ٢٤٧ .

المبحث الخامس

علانية الجلسات (١)

يقصد بمبدأ علانية الجلسات :

أن يتم التحقيق في الدعاوى وإبداء المرافعة فيها في جلسات علنية ، بحيث يكون لكل شخص حق الحضور فيها وأن يتم النطق بالأحكام بصوت مسموع ، وأن يسمح للصحف بنشر تفاصيل المرافعات التي تجرى فيها ، وكذا منطوق الأحكام التي تصدر بشأنها^(٢).

١ - أهمية علانية الجلسات :

يحقق مبدأ علانية الجلسات أهمية خاصة ، حيث يؤدي إلى حسن الأداء لرسالة القضاء من جانب القضاة ، مما يؤكد حيادهم ويعظم نزاهتهم ويحفظ هيبتهم ، حيث يتم التقاضي على رؤوس الأشهاد ، فيكون القاضي أبعد ما يكون عن التهمة بالميل أو التقصير .

كما أن علانية الجلسات تبعث بالثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين ، حيث تكفل لهم حقوق الدفاع المقررة لهم قانوناً ، كما أن علانية الجلسات تطلع الجمهور على مدى اهتمام القضاء بأعمالهم وعنايتهم بها ، ونزاهتهم في أحكامهم ، مما يزيد احترام الجمهور للقضاة ويبعث على الثقة فيهم^(٣)، مما يمتنع معه تحكم القاضي

(١) لمزيد من التفصيل راجع : هيئة القضاة ضمانات لاستقلال القضاء دراسة تأصيلية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دكتور أحمد خليفة شرقاوي ، ٤٠ وما بعدها . ط / دار الفكر العربي ، الاسكندرية ط / الأولى سنة ٢٠١٣ م .

(٢) المرافعات ، د / عبد الحميد أبو هيف ، بند ٧٤٤ ، ص ٥٤٠ .

(٣) الدكتور / محمد حامد فهمي في المرافعات المدنية والتجارية ف ٢٠٠ ، ولمزيد حول هذه المسألة راجع : العدالة الإجرائية في التقاضي " دراسة تحليلية " د / أحمد خليفة شرقاوي ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ، جامعة بنها ، سنة ٢٠١٣ م .

في الخصومة^(١) محل التقاضي .

وتأكيداً على أهمية العلانية في الجلسات القضائية، قرر المقتن في المادة " ١٨٧ " من الدستور المصرى أن : " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ، ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية^(٢) " .

وجاءت المادة " ١٨ " من قانون السلطة القضائية لتؤكد ذات المبدأ ، حيث نص فيها المقتن على أن : " تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية ، مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ، ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية "^(٣) .

كما نص أيضاً على أهمية مبدأ العلانية فى المادة " ١٠١ " من قانون المرافعات الحالى^(٤) ، وجاء فيها : " تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراؤها سراً ، محافظة على النظام العام ، أو مراعاة للآداب ، أو لحرمة الأسرة " ، وعليه فإن الأصل هو العلانية فى التقاضى والمحاكمات إلا ما استثناه المقتن بنص خاص .

٢- حدود مبدأ العلانية :

يلاحظ أن تحقق العلانية لا يعنى بالضرورة السماح لجميع الناس بالدخول فى قاعات الجلسات بالمحاكم ، حيث قد يسبب ذلك ازدحاماً بقاعة الجلسة ، مما يخل بنظامها ، فيؤدى إلى التشويش على القاضى ، أو إثارة الشغب بين الناس فى

(١) المرافعات ، د/محمد حامد فهمى ، بند : ٣٤ ، ص ٣٣ — قوانين المرافعات ، د / أمينة النمر ، بند ٣٢ ، ص ٦٤ ، مبدأ علانية الجلسات فى ضوء قانون الإجراءات الجنائية ، د / محمود عبد ربه القبلاوى .

(٢) وهى تقابل المادة ٥٢ من الإعلان الدستورى المصرى ، الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ ، الذى أعقب ثورة ٢٥ يناير المصرية .

(٣) المادة " ١٨ " من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م .

(٤) قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، والتعديلات الواردة عليه

حضور القاضى ، وهذا يعد إساءة للقضاء وهيئته ، لذا يكون لأعوان القاضى — الشرطة — أن تقصر الدخول فى القاعة على عدد محدود من الجمهور، بحيث يتناسب وحجم القاعة المخصصة لنظر الدعوى أو تجعل الدخول ببطاقات محددة سلفاً — كما هو شأن القضايا الهامة أو الخطرة — ولا يعد هذا خروجاً أو مخالفة لمبدأ العلانية المنصوص عليه قانوناً^(١).

(١) الوسيط ، د/فتحى والى، بند: ٢٧٢ ، ص ٥٢٢ ، مبدأ علانية الجلسات ، د/محمود عبد ربه القبلاوى ، ص : ٢٦ ، ٢٧ ، وإذا كان مبدأ علانية الجلسات يعد من المعايير الدولية فى التقاضى والمحاكمات ، ومن المبادئ القضائية المستقرة فى النظم الوطنية المختلفة ، إلا أنه يجب ألا يتم التستر خلفه سعيًا وراء شهرة أو مباهاة بما يخل بمبدأ المساواة بين الخصوم ، أو يجعل القاضى محطاً للوسائل الإعلامية المختلفة ، مما يؤدى إلى الخروج عن التقاليد المستقرة فى القضاء المصرى وما يتميز به هذا القضاء ، وهو الأمر الذى لا حظته الكافة فى العديد من القضايا المهمة أو ما يسمى بقضايا الرأى العام .

كما أن واقع الحال أظهر كيف أن البث الحر لوقائع الجلسات فى وسائل الإعلام قد أثر سلباً فى كثير من الأحيان على سير المحاكمة ، وعلى حجية الأحكام التى تصدر بشأنها .

ولنا فى ذلك أن نذكر كيف أن سماع القاضى فى قضية "إية جى سمبسون" ، لاعب كرة القدم فى الولايات المتحدة الأمريكية ، الذى اتهم بقتل زوجته وصديقه فى التسعينيات ، وبدخول الكاميرات قاعة الجلسة ، والذى قوبل بانتقاد الأوساط القانونية فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بحسبانه قد أثر على أداء القاضى والمحلفين ، وحول القضية محط أنظار الرأى العام إلى عرض مسرحى ، تنتقى معه هيئة =القضاء ووقاره ؛ ولهذه الأسباب وحفاظاً على هيئة القضاء ، فإن قانون المملكة المتحدة يحظر التقاط الصور فى المحاكم أو رسم صور الأشخاص ، سواء كانوا من القضاة أو المحلفين أو الشهود أو أطراف الخصومة .

ومن هنا يمكن القول بأن مبدأ العلانية مبدأ أصيل فى التقاضى ، ويحقق الرقابة الشعبية على عمل القاضى والسلطة القضائية ، ولا يجوز بحال مخالفته إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، كما هو الشأن فى الحالات التى رأى المكنن أنها تمس النظام العام أو الآداب العامة أو كيان الأسرة .

أما الحد من العلانية عند وجود المسوغ القانونى لذلك فلا يعد مخالفة لهذا المبدأ فى جوهره وأصوله .

انظر : الإعلام وحدود وضوابط مبدأ علانية الجلسات ، مقال بقلم المستشار / عادل ماجد ، جريدة الأهرام فى ٢٠/٨/٢٠١١م

ولا شك أن الوقت الحاضر يشهد على مساوئ البث الإعلامى المباشر لجلسات المحاكمة الخاصة بالرئيس السابق ، والتى تعارف عليها الناس بمحاكمة القرن ، التى أعقبت الثورة المصرية فى ٢٥ يناير ٢٠١١ م ، وكانت أثراً من آثارها ، فهذه القضية خير شاهد على ضرورة منع الإعلام من بث أمثال هذه القضايا ، نظراً لما يترتب على ذلك من أخطار بالغة ، تؤثر حتماً على هيبة القضاء ورجاله ، فضلاً عن إثارة الشغب والفتن والضغائن بين الناس .

وبهذا يمكن القول بأن هيبة القضاء تتحصل بالبعد عن الأضواء ، فكل عمل من شأنه أن يؤثر على سير العدالة يجب منعه ، حفاظاً على هيبة القضاء ونزاهته .

وهذا ما نص عليه العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فى المادة " ١٤ " منه حيث جاء فيه أنه " ... ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعى الآداب العامة ، أو النظام العام ، أو الأمن القومى ، فى مجتمع ديمقراطى ، لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو فى أدنى الحدود التى تراها المحكمة ضرورية ، حين يكون من شأن العلنية فى بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ... " .

فكيف بنا ننادى بالديمقراطية الحق فى الوقت الراهن دون أن نمنع الإعلام من التدخل فى شأن القضاء ، وما يدور فى ساحاته من قضايا ؛ لا سيما فى الظروف الاستثنائية الحالية التى تمر بها الدولة المصرية ، بعد أن ثبت واقعاً بأن الإعلام يؤثر من بعيد أو من قريب على سير العدالة وإنجازها على النحو المعتبر لها قانوناً .

٣ - الأثر المترتب على مخالفة مبدأ علانية الجلسات :

يتضح مما سبق أن النطق بالحكم يجب وأن يتم في جلسة علنية ، وذلك في جميع الأحوال حتى مع حالات الاستثناء من العلانية الواردة بنص القانون ، فإذا خالفت المحكمة ذلك ، فنطقت بالحكم في جلسة سرية ، ولو كانت الدعوى واردة في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانوناً كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً؛ لمخالفته الصريحة لنص القانون ، وبهذا يمكن القول بأن النطق بالحكم يجب أن يكون علانية ولا يقبل الاستثناء لأي سبب بالغاً ما بلغ (١) .

علانية الجلسات في الفقه الإسلامي :

لقد حرص الفقه الإسلامي على إجراء التقاضي والمحاكمة في صورة علانية، ويعد القضاء في المسجد مظهراً من مظاهر علانية التقاضي في الفقه الإسلامي (٢) ، وبالرغم من اختلاف الفقهاء حول استحباب القضاء في المسجد ، باعتباره أعدل المجالس وأقربها إلى تحقيق العدالة القضائية (٣) ، أو كراهية ذلك تنزيهاً للمساجد التي بنيت لأجل الذكر والصلاة (٤) ، إلا أن القضاء قد جرى فيها بغير تكير (٥) ، وفي مختلف القضايا ، وهذا يؤكد على إجراء الجلسات القضائية في أماكن علنية

(١) أصول المرافعات د/أحمد مسلم ، بند ٤٦ ، ص ٤٧ ، قوانين المرافعات د / أمينة النمر، بند ٣٢، ص ٦٥، مبدأ علانية الجلسات، د/ محمود عبد ربه القبلاوى ص ٤١ .

(٢) نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون ، د / عبد الناصر موسى أبو البصل ص : ٣٨٦ ، علانية جلسات التقاضي في المملكة العربية السعودية ، د / ناصر ابن محمد الجوفان ، ص ١٨ .

(٣) كشاف القناع ، للبهوتي ٣١١/٦ ، نظرية الحكم القضائي ، د/عبد الناصر أبو البصل ص ٣٨١ .

(٤) الحاوي الكبير ، للماوردي ٢٠ / ٨٢ .

(٥) شرح فتح القدير ، لابن الهمام ٦ / ٣٧٠ ، الكافي ، لابن عبد البر ، ص ٤٩٩ .

يشهدها جميع من أرادها من الناس ولو لم يكن مسلماً^(١) ، وذلك دفعاً للتهمة عن القاضى لو أنه قضى فى جلسات سرية^(٢) ، فكانت العلانية محققة فى قضاء المسجد ، ولها ثمارها فى حفظ هيبة القاضى ، وتحقيق الرقابة الشعبية على أحكامه وقضائه^(٣) .

كما عرف الفقه الإسلامى علانية التقاضى والقضاء فى غير المسجد من الأماكن البارزة التى يشهدها جميع الناس ، فاستحسنوا لذلك أن يقضى القاضى فى أماكن تجتمع فيها العامة ، ليشهدوا قضاءه وحكمه بين الخصوم^(٤) ، على وجه يحقق تقريب القضاء من الخصوم دون كلفة أو مشقة^(٥) .

نظرة مقارنة :

بالنظر إلى قواعد القانون الوضعى المتعلقة بمبدأ علانية الجلسات يتضح لنا أن هناك اتفاقاً تاماً بين الفقه الإسلامى والقانون الوضعى ، من حيث مقصود هذا المبدأ وحكمة تقريره وأحواله التى تتصل به ، حيث إن كلاهما يسعى بطبيعته إلى تحقيق جودة الأداء فى رسالة القاضى والقضاء ، على نحو يضمن الهيبة للقاضى ويحفظ عليه النزاهة والوقار فى أعماله القضائية ، ليكون بذلك أبعد من المساس به من أى وجه كان^(٦) .

(١) المغنى ومعه الشرح الكبير ، لابن قدامة ١١ / ٣٨٨ .

(٢) تبين الحقائق ، للزيلعى ٤ / ١٧٨ .

(٣) مواهب الجليل ، للحطاب ٦ / ١١٤ ، نظرية الحكم القضائى ، د/ عبد الناصر أبو البصل ، ص ٣٨٧ .

(٤) المجموع ، للنووى ٢٠ / ١٣٢ .

(٥) المغنى ومعه الشرح الكبير ، لابن قدامة ١١ / ٣٨٨ .

(٦) - هيئة القضاة ضماناً لاستقلال القضاء ، د/أحمد خليفة شرفاوي ، ٣٨ وما بعدها .

المبحث السادس حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم

المقصود بهذا المبدأ

يقصد بحصول الإجراءات في مواجهة الخصوم ، أن كل إجراء من إجراءات الخصومة يتخذه أحد الخصوم يجب أن يكون في مواجهة الطرف يتمكن من الرد على خصمه حماية لمصلحته .

ويعطى هذا المبدأ للخصم فرصة للرد على كل طلب بوجه إليه إن كان لديه رد كما يكمل حقه في مناقشة الخصم في دفاعه ، ومن ثم فلا يؤخذ خصم على غرة وهو أمام القضاء .

ومبدأ حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم ، من المبادئ الأساسية في النظام القضائي المصري ، ولذلك يوجب القانون إعلان المدعي عليه بالطلبات الموجهة إليه ، ومنع المدعي من إبداء طلبات جديدة ، أو تحقيق الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى ، في الجلسة التي يتخلف فيها خصمه ، وكذلك منع المدعي عليه من إبداء طلبات في غيبة المدعي ، ويوجب القانون تمكين كل خصم من الاطلاع على الأوراق التي يقدمها خصمه تأييداً لدعواه .

كما يوجب القانون على القاضي أن يمتنع بعد إقفال باب المرافعة عن سماع أي أقوال من أحد طرفي الخصومة في غيبة الطرف الآخر ، ومن قبول أية ورقة لم يتطلع عليها خصمه^(١) .

(١) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور عبد الباسط جميعي ص ١٨٩ وراجع في الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٤٦ ق جلسة ٢٠ / ٤ / ١٩٧٨ س ٢٩ ، ص ١٠٥٣ " لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة ١٦٨ من قانون المرافعات أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ، وإلا كان العمل باطلاً وهذا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أصل من أصول المرافعات ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للطاعة بإيداع مذكرتها بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها .

غير أن هذا المبدأ لا يمنع المحكمة من السير في إجراءات نظر الدعوى بالرغم من غياب المدعي عليه ، متى ثبت علمه بالدعوى بوصول الإعلان الصحيح إليه.

واستثناءً من هذا المبدأ يجيز القانون اتخاذ إجراءات في غير مواجهة الخصوم كاستصدار أمر على عريضة أو أمر أداء^(١)

حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم في النظام القضائي الإسلامي .

الأصل في الفقه الإسلامي أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم ، ولا يجوز للقاضي أن يسير في إجراءات نظر الدعوى مع غيبة أحد الخصوم عن مجلس القضاء ، مع حضوره في البلد وعدم علمه بالدعوى ، ويمتنع على القاضي أن يسمع بينة في غيبة الخصم ، ولا يجوز له أن يصدر حكمه بناءً على هذه البينة ؛ لأن ذلك نوع من القضاء على الغائب^(٢) ، بل لا يجوز للقاضي أن يقرأ كتاب قاض آخر يتضمن شهادة على مدعي عليه إلا بحضوره ، لأن ذلك بمنزلة أداء الشهادة ، فلا بد من حضوره^(٣) .

هذا هو الأصل ، ولكن إذا امتنع المدعي عليه من الحضور أمام القضاء نعتياً ولدداً في الخصومة جاز للقاضي النظر فيها ، حتى وإن ظل المدعي عليه غائباً^(٤)

(١) قوانين المرافعات د / أمينة النمر ف ١٤ .

(٢) شرح فتح القدير ٧ / ٢٨٦ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٩٧ .

(٣) الهداية وشرح العناية عليها ضمن شرح فتح القدير ٧ / ٢٩٣ .

(٤) نظرية الدعوى للدكتور / محمد نعيم عبد السلام ٢ / ٣١ .

المبحث السابع حرية الدفاع والمناقشة

المقصود بهذا المبدأ :

يقصد بهذا المبدأ — حرية الدفاع والمناقشة — إعطاء كل خصم فرصة كافية لإبداء وجهة نظره أمام القضاء فيما قدمه هو أو قدمه خصمه من ادعاءات . ويعتبر هذا المبدأ ضماناً هامة من ضمانات العدالة ذلك أن القاضي إذا تأني في إصدار حكمه ، حتى يسمع كل كلام الخصوم ، فهو أحرى أن يتبين له وجه القضاء .

وهذا المبدأ — حرية الدفاع والمناقشة — أوسع وأشمل من المبدأ السابق — حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم — ويكمّله ، فالأخير يتطلب حضور المدعي عليه أو نائبه ، ليكون على علم بما يتخذ ضده من إجراءات ، بينما الأول — حرية الدفاع — يتطلب إعطاء الخصم بعد حضوره فرصة لإبداء وجهة نظره وأسانيدها .

وتنص المادة "٩٨" من الدستور الحالي ، الصادر في ٢٠١٤ م على أن: " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع وتضمن الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم " .

وتنص المادة ١٠٢ مرافعات على أنه: " يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى ، أو مقتضيات الدفاع فيها ، ويكون المدعي عليه آخر من يتكلم " .

وعلى ذلك يجب على القاضي أن يستمع إلى أقوال الخصوم خلال المرافعة ، ولا يقاطعهم أثناء إبداء طلباتهم أو دفوعهم ، إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى ، أو تجاوزوا حدود الدفاع المقررة ، أو وجه بعضهم لبعض سباً أو طعن بعضهم في حق شخص أجنبي عن الدعوى .

وينبغي على ذلك وجوب إمهال الخصوم للحصول على أوراق أو مستندات تكون منتجة في الدعوى إذا طلب أحدهم ذلك .

ويقتصر حق الخصم في الدفاع والمناقشة على إعطائه الفرصة للكلام وإظهار وجهة نظره وأدلته ، فإن امتنع عن الكلام أو قصر في تقديم أدلته استمرت المحكمة في نظر الدعوى والحكم بما تنتهي إليه .

حرية الدفاع والمناقشة في النظام القضائي الإسلامي :

مبدأ حرية الدفاع والمناقشة بمعناه المتقدم من المبادئ الأساسية الهامة في النظام القضائي الإسلامي ، فكل خصم من الخصوم حق إبداء وجهة نظره أمام القضاء ، والإدلاء بأدلته وأسانيده ، سواء كانت تثبت ما اتجه إليه أو تنفي مزاعم خصمه ، ولا يجوز للقاضي أن يحكم قبل سماع ما يريد أن يقوله كل خصم^(١) .

ويجب على القاضي أن يمهّل الخصم لإحضار بينته إذا ادعى أن معه بينة ، ولكنها غير حاضرة وطلب إمهاله لإحضارها^(٢) .

ويقتصر حق الخصم في الدفاع والمناقشة على إتاحة الفرصة له ليتكلم ويبيد وجهة نظره وأدلته ، فإن هو أصر على عدم الكلام أو قصر في إبداء أدلته أو كان خصمه ألح بحجته ، قضى القاضي وفقاً لما انتهى إليه^(٣) .

والهدف من إمهال الخصم لإحضار البينة هو إحضارها ، فإن أساء خصم استعمال حقه في ذلك واستعمله للتسويق والمماطلة كيداً لخصمه كان للقاضي أن

(١) تطبيقاً لحديث رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالب حين بعثه قاضياً إلى اليمن : " إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان ، فلا تقضي حتى تسمع كلام الآخر ، كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء . انظر : روضة القضاء للسمناني ٢٧٧/١ ، مطالب أولي النهى ٥٠٨ / ٦ .

(٢) المغني لابن قدامة ١٠ / ٢٠١ ، روضة القضاء للسمناني ١ / ٢٩٣ .

(٣) الشرح الكبير للدردير ٤ / ١٥١ ، كشف القناع ٦ / ٣٣٤ .

يفوت عليه غرضه ، ويحكم عليه^(١) .

ولا يجوز للقاضي أن يمنع خصماً من الكلام طالما كان كلامه في الموضوع ،
أما إذا خرج عنه ، أو أساء للخصوم أو للقاضي أو لغيرهم منعه القاضي
وزجره^(٢) .

المبحث الثامن التقاضي على درجتين

المقصود بهذا المبدأ :

يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين — حق الاستئناف — أن كل نزاع يعرض
أمام محكمة أول درجة وبعد الفصل فيه ، يمكن عرضه من جديد على محكمة
أعلى (محكمة الدرجة الثانية) لإعادة نظره والفصل فيه ، وتعرف المحكمة الأولى
بمحكمة أول درجة ، والثانية بمحكمة الدرجة الثانية أو المحكمة الاستئنافية .
بخلاف مبدأ " التقاضي على درجة واحدة " حيث لا يمكن عرض النزاع مرة
ثانية بعد الفصل فيه ، ويقتصر عرضه على محكمة واحدة .
ولكل من النظامين مزاياه التي تعتبر بالتالي عيوباً في النظام الآخر .

مزايا التقاضي على درجتين :

لنظام التقاضي على درجتين مزايا متعددة ، أهمها ما يلي :

أولاً : نظام التقاضي على درجتين يعطي فرصة لتدارك ما قد تقع فيه محكمة
الدرجة الأولى من أخطاء ، أو ما يشوب أحكامها من عيوب ، لا سيما وأن
النصوص كثيراً ما تكون غير قطعية الدلالة على المطلوب ، ومن ثم تختلف فيها
الأفهام ، والقاضي معرض للوقوع في الخطأ ، ولذلك وجب الاحتياط من مثل هذا
الخطأ بتقرير التقاضي على درجتين ، حيث تتكون محكمة الدرجة الثانية من قضاة
أكثر عدداً ، وأوفر خبرة من قضاة محكمة الدرجة الأولى .

(١) حاشية الدسوقي ٤ / ١٥٠ .

(٢) معين الحكام للطرابلسي ص : ٢١ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٤٠ .

ثانياً : هذا النظام يبعث قضاة محاكم الدرجة الأولى على الاهتمام بدراسة الموضوع ، وتدقيق الأسباب ، والتأني في إصدار الأحكام ، لأن القاضي حين يعلم أن حكمه يمكن أن يعاد فيه النظر ، وأن تناقش حيثياته ومنطوقه يهتم بدراسة الموضوع ويدقق الأسباب ، ويتأني في الحكم^(١) .

ثالثاً : نظام التقاضي على درجتين يعطي الخصم فرصة لتعديل مسار دفاعه إذا تبين له أن خصمه كان ألحن بحجته منه ، ولتكلمة ما فاتته من نقص في الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى .

رابعاً : هذا النظام يبعث على الثقة في القضاء والرضا بقراره أياً ما كان ، ذلك أنه إذا حسب الخصم عدد القضاة الذين نظروا قضيته سيجدهم يتراوحون بين أربعة إلى ستة قضاة ، وهذا يبعث الثقة في القضاء ، حيث لا يعقل أن يتواطأ هذا العدد ضده ، وفي الدرجتين ، وفضلاً عن ذلك فهذا العدد يجعله راضياً بالحكم حتى ولو كان ضده^(٢) .

مزاي التقاضي على درجة واحدة :

لنظام التقاضي على درجة واحدة عدد من المزايا أهمها ما يلي :

أولاً : يؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات وتقصير مدة الخصومة ، وتوفير النفقات ، وذلك لأن النزاع سينتهي بصدر الحكم من المحكمة ، ولن تكون هناك فرصة لتجديده مرة ثانية أمام محكمة أخرى مما يؤدي إلى سرعة إنهاء المنازعات ، وتقصير مدة الخصومة وتوفير النفقات .

ثانياً : هذا النظام يبعث الثقة في نفوس الناس في أحكام المحاكم ، ذلك أن عرض النزاع على محكمة ثانية من شأنه أن يزعزع ثقة الناس في الحكم الأول ، لا سيما إذا اختلفت آراء القضاة واتجاهاتهم .

ثالثاً : قصر التقاضي على درجة واحدة يجعل المتقاضين في وضع متكافئ من يقدر منهم على نفقات المحاكم المتعددة ، ومن لا يقدر ، حيث لا يسمح بعرض

(١) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور/عبد الباسط جميعي ص ١٨٤، المرافعات المدنية والتجارية للدكتور محمد حامد فهمي ف ٣٧ ، مبادئ قانون القضاء المدني د / فتحي والي ف ١٣٢ .
(٢) قانون المرافعات للدكتور محمد عبد الخالق عمر ص ٢٩٤ .

النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلى لا يتمكن من الوصول إليها إلا من يقدر على نفقاتها .

وتعرض المنازعات في القضاء المصري على درجتين للتقاضي ، حيث ترفع الدعوى إلى محكمة تفصل فيها أول مرة ، ثم يكون للخصم المقضي عليه حق الطعن في الحكم بالاستئناف إلى محكمة أعلى ، يطرح عليها النزاع لتحكم فيه من جديد .

وإذا كان القانون المصري قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين كقاعدة — إلا أن هناك حالات رجع فيها المقنن بعض الاعتبارات العملية على مقتضى العدل المطلق، ومستلزمات حسن القضاء^(١) ، استثنائها من قاعدة التقاضي على درجتين من ذلك الدعاوى ضئيلة القيمة ، والتي لا تزيد قيمتها عن مبلغ معين ، لا تحتل نفقات العرض على درجتين ، وكذلك الحالات التي يجيز المقنن فيها للخصوم الالتجاء إلى محكمة الدرجة الثانية رأساً دون أن يكون قد سبق عرض النزاع على محكمة الدرجة الأولى ، ومثال ذلك طلب رد قضاة المحكمة الابتدائية الذي يعرض على محكمة الاستئناف^(٢) ، وكذلك الأجور والفوائد والمرتببات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ، يجوز إضافتها للطلب الأصلي أمام محكمة الدرجة الثانية أثناء نظر الاستئناف^(٣) ، وبذلك تكون هذه الطلبات قد اقتصر نظرها على محكمة الدرجة الثانية .

قصر التقاضي على درجتين :

إذا كان التقاضي على درجتين له مزايا متعددة توجب الأخذ به ، إلا أنه ينبغي أن يقتصر التقاضي على هاتين الدرجتين ، فلا يستأنف حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة أعلى ، فلو أطلق حق الطعن في الأحكام ، لأدى ذلك إلى تأييد الخصومات

(١) الدكتور / محمد حامد فهمي في المرافعات المدنية والتجارية ف ٤١ .

(٢) قوانين المرافعات للدكتورة أمين النمر ف ٢٨ .

(٣) المادة ٢٣٥ مرافعات .

وتخليدها ، واستنفاد أموال المتقاضين في مصاريف التقاضي ، وزعزعة المراكز القانونية وعدم استقرارها .

وقصر التقاضي على درجتين لا يتنافى مع جواز الطعن بالتماس إعادة النظر والطعن بالنقض ، وذلك لأن التماس إعادة النظر يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ، ولأن الطعن بالنقض لا يطرح موضوع النزاع أمام محكمة النقض ، ثم إن الطعن بهذين الطريقتين لا يجوز إلا لأسباب معينة ، وفي حالات محددة ولذلك وصفا بأنهما من طرق الطعن غير العادية^(١) .

التقاضي على درجتين في النظام القضائي الإسلامي :

يجوز في الفقه الإسلامي عرض الحكم الصادر من القاضي حتى ولو كان عادلاً عالمياً على قاض آخر^(٢) ، سواء كان هذا العرض بقصد تنفيذ الحكم الصادر

(١) قد يقال أن احتمال الخطأ الذي جعل التقاضي على درجتين لتداركه ، لا يزال قائماً بعد نظر النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية ؛ لأن قضاة الدرجة الثانية قد يخطئون أيضاً ، فمن العدل المطلق تمكين الخصوم من الطعن مرة ثانية ، بل وإطلاقه . والأفضل أن يقف التقاضي عند هذا الحد ، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قد توافر لها من الضمانات ما يجعل وقوعها في الخطأ قليل الاحتمال ، وعلى كل حال فاحتمال وقوع الخطأ في بعض القضايا أقل ضرراً على حسن سير القضاء من فتح باب الطعن في الأحكام إلى ما لا نهاية .

انظر : المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / محمد حامد فهمي ، ف: ٣٩ ، مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور عبد الباسط جميعي ص ١٨٦ .

(٢) وهذا الذي ذكرناه في المتن بالرغم من أن هناك عبارات للفقهاء قد يفهم من إطلاقها عدم جواز عرض الحكم الصادر من القاضي على قاض آخر ، من هذه العبارات قولهم " لا يجوز للقاضي أن ينظر في قضية غيره " معين الحكام للطرابلسي ، ص ٣٠ ، " ليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله " ابن قدامة في المغني ١٠ / ٥٢ ، " حكم القاضي العدل لا يتعقب " الدردير في الشرح الكبير ٤ / ١٥٣ ، " على القاضي ألا يتعرض لقضية أمضاها الأول إلا على وجه التحرير لها إن عرض فيها عارض بوجه خصومة ، فأما على وجه الكشف لها والتعقيب عليها فلا ، وإن سأله الخصم ذلك " الطرابلسي في معين الحكام ص ٣٠ ، ومع هذا فالعبارات المذكورة لا تمنع من عرض أحكام القضاة حتى ولو كانوا معروفين بالعدل على قضاة آخرين ، فهي تمنع القضاة اللاحقين من العرض لأحكام القضاة السابقين من تلقاء أنفسهم ، ولكن يجوز =

من القاضي الأول^(١) ، أو لظهور جوره وحيفه في أحكامه كلها أو بعضها ، أو لأن هذا القاضي لا يصلح للقضاء^(٢) ، أو لأن أحد الخصوم لم يقتنع بالحكم^(٣) .

= عرض أحكام هؤلاء القضاة من الخصوم على قضاة آخرين ، وذلك إذا وقع نزاع حول هذه الأحكام ، أو تبين وجه فسادها (انظر الشرح الكبير للدردير ٤ / ١٥٣ ، الفواكه البدرية لابن الغرس ص ١٥٥ ، معين الحكام للطرابلسي ص ٣٠) .

(١) الفواكه البدرية لابن الغرس ص ٢٣ .

(٢) المغني لابن قدامة ١٠ / ٥٣ .

(٣) يدل على ذلك ما روى عن حنش بن المعتمر عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : " بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأنتهينا إلى قوم قد بنوا زبية " حفرة " للأسد ، بينما هم كذلك يتدافعون ، إذ سقط رجل فتعلق بأخر ، ثم تعلق الرجل بأخر ، حتى صاروا فيها أربعة ، فجرحهم الأسد ، فانتدب له رجل بحرية فقتله ، وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر ، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا ، فأتاهم علي عليه السلام على تفئة ذلك " حين ذلك " فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسول الله ﷺ حي ، إني أقضي فيكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء ، وإلا حجرت بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي ﷺ فيكون هو الذي يقضي بينكم ، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له ، أجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الديو وثلاث الدية ونصف الدية ، والدية كاملة ، فلأول ربع الدية ؛ لأنه هلك من فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث الدية والثالث نصف الدية ، والرابع الدية كاملة ، فأبوا أن يرضوا ، فأتوا النبي ﷺ وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة ، فأجازه رسول الله ﷺ " . رواه الإمام أحمد بلفظ آخر نحو هذا ، وأخرجه البيهقي والبخاري : انظر : نيل الأوطار للشوكاني ٧ / ٨٣ ، ٨٤ .

وهذا يدل على جواز عرض الدعوى مرة ثانية أمام قاض آخر يكون أعلى درجة من القاضي الأول ، وذلك لأن الإمام علي عليه السلام قال للخصوم هنا " إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء ، وإلا حجرت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ﷺ فيكون هو الذي يقضي بينكم " وهذا القول من الإمام علي يشير إلى حق الخصم في عرض دعواه مرة ثانية أمام القاضي الأعلى ، إن لم يرض الخصم بالحكم الصادر في الدعوى .

ويدل على حق الخصم في ذلك سماع رسول الله ﷺ الدعوى منهم مرة ثانية ، رغم علمه ﷺ بسماع الإمام علي لهذه الدعوى ، وإصداره حكماً فيها ، ومع هذا فقد سمع الرسول ﷺ هذه الدعوى مرة ثانية ، نعم لقد أيد رسول الله ﷺ حكم الإمام علي ولم ينقضه ، لكن قد سمع الدعوى مرة ثانية ، مما يؤيد حق الخصوم في عرض النزاع مرة ثانية أمام قاض أعلى ، إذا لم يرضى أحد الخصوم بالحكم .

وإذا أعيد عرض الموضوع مرة ثانية أمام قاض آخر ، فإن كان الحكم الأول صحيحاً وفقاً لما تقتضيه النصوص والإجماع ، فيجب على القاضي الثاني تأييده وتنفيذه ، بل يجب ذلك على جميع من يعرض عليه هذا الحكم بعد ذلك^(١) .

وإن كان الحكم مخالفاً نبحت في المخالفة ، فإن كان مخالفاً لنص في الكتاب أو السنة ، أو مخالفاً للإجماع أو للقياس الجلي (وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع بالأصل) فيجب نقض الحكم ، ولا يصح تنفيذه ، لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه^(٢) .

وأما إذا كان حكم القاضي الأول مخالفاً لاجتهاد مجتهد فلا ينقض القاضي الثاني حكم الأول ، حتى ولو كان القاضي الثاني لا يرى ما ذهب إليه القاضي الأول ، لأن الأول حكم باجتهاده ، والثاني سيحكم باجتهاده ، واجتهاد الثاني كاجتهاد الأول ، في أن كلا منهما يحتمل الخطأ ، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به ، فلا ينقض بما هو دونه درجة ، وهو ما لم يتصل القضاء به^(٣) .

وكذلك ينقض الحكم إذا كان مخالفاً للقواعد الشرعية في نظر الدعوى ، كما لو صدر الحكم من قاض عرف بالجور أو الحكم بالهوى ، أو لا يصلح للقضاء ، لعدم توفر شروط تولى القضاء فيه ، أو صدر الحكم في غير ما يختص به^(٤) .

(١) المغني لابن قدامة ١٠ / ٥٠ ، الهداية ضمن شرح فتح القدير ٧ / ٢٠٠ .

(٢) شرح المحلى على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة ٤ / ٣٠٤ ، الشرح الكبير للدردير ٤ / ١٥٣ .

(٣) المغني لابن قدامة ١٠ / ٥١ ، شرح فتح القدير ٧ / ٣٠٤ .

(٤) المغني لابن قدامة ١٠ / ٥٣ ، الشرح الكبير للدردير ٤ / ١٥٢ ، وانظر تفصيل الموضوع في التنظيم القضائي الإسلامي د / حامد أبو طالب ص ٦١ - ٦٧ .

الفصل الثاني

ترتيب المحاكم وتشكيلها

المبحث الأول

درجات المحاكم (طبقاتها)

تأخذ مصر بمبدأ التقاضي على درجتين — كقاعدة — ولذلك توجد فيها طبقتان من المحاكم، محاكم الدرجة الأولى أو الابتدائية، ومحاكم الدرجة الثانية أو الاستئنافية، ولكل طبقة منهما محاكمها، وفوق هاتين الطبقتين توجد محكمة النقض

أولاً : محاكم الدرجة الأولى :

محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم التي ترفع إليها الدعاوى لأول مرة ، ونظراً لاختلاف الدعاوى بحسب الصعوبة والأهمية ، فقد رأى المقنن أن يحدد محاكم من محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم الجزئية ، تشكل تشكيلاً يتناسب والدعاوى البسيطة السهلة ، وقرر أن تكون هذه المحاكم قريبة من الخصوم ، أما الدعاوى المعقدة وذات القيمة الكبيرة ، فقد حدد لها المقنن محاكم أخرى من محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم الابتدائية (الكلية) وتشكل هذه المحاكم تشكيلاً يتناسب وأهمية الدعاوى التي تنظرها، وعلى ذلك تنتوع محاكم الدرجة الأولى إلى نوعين هما : المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية (الكلية) .

١ - المحاكم الجزئية : المحاكم الجزئية هي أدنى طبقات المحاكم في النظام القضائي المصري ، وهي منتشرة في جميع أنحاء البلاد ، حيث توجد — كقاعدة — محكمة جزئية في كل مركز أو بندر أو قسم ، وذلك حتى تكون قريبة من مكان النزاع ، ومحل إقامة الخصوم .

وتمارس المحكمة الجزئية نشاطها داخل دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية المكاني ، ويكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل^(١) .

(١) المادة ١١ / ١ من قانون السلطة القضائية .

وتتعد المحكمة الجزئية في مقرها المحدد في قرار إنشائها من وزير العدل ، ويجوز أن تتعد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة^(١) . ويجيز القانون لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه – بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية – محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها^(٢) .

وقد أصدر الوزير قرارات بإنشاء محكمتين جزئيتين تجاريتين في القاهرة والإسكندرية ، كما أصدر عدة قرارات بإنشاء محاكم لشئون العمال في القاهرة والإسكندرية ، وبعض المدن الأخرى ، وهذه المحاكم المتخصصة لها اختصاص نوعي محدد بنوع معين من الدعاوى ، ولا يجوز لها نظر غير هذا النوع من الدعاوى ويجوز الدفع أمامها بعدم الاختصاص النوعي ، إذا كانت الدعوى المرفوعة أمامها من غير هذا النوع الذي خصت له ، ذلك أن هذا ليس مجرد تقسيم للعمل مما يدخل في التنظيم الإداري ، كما هو الأمر بالنسبة للدوائر المختصة لنظر نوع معين من الدعاوى^(٣) .

٢ - المحاكم الابتدائية :

هي المحاكم التي تنظر الدعاوى ذات القيمة الكبيرة ، والدعاوى المعقدة لأول مرة ، أي : بصفة مبتدأة ، ومن هنا يطلق عليها عملاً اسم المحاكم الكلية على اعتبار أنها المحاكم صاحبة الاختصاص الكلي الشامل أصلاً^(٤) .

(١) المادة ١١ / ٢ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ١٣ من قانون السلطة القضائية .

(٣) قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ص ١٣٦ ، مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور/ عبد الباسط جميعي ص ٢٠١ ، قانون القضاء المدني للدكتور / محمود هاشم ف ٩٣ .

(٤) أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي في مبادئ المرافعات ص ١٩٨ .

ويكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية^(١) ، كقاعدة ، ويجوز إنشاء محاكم ابتدائية أخرى ، وتعيين دائرة اختصاصها المحلى ، وتعديل هذا الاختصاص بقانون^(٢) ، ولذلك فقد توجد في المحافظة الواحدة أكثر من محكمة كلية ، كما هو الحال في محافظة القاهرة ، حيث قسمت محكماتها الابتدائية إلى محكمتين ، إحداهما سميت بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، والثانية محكمة شمال القاهرة الابتدائية .

ومع هذا " يجوز أن تتعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة" .

ثانياً : محاكم الدرجة الثانية :

ترتيباً على جعل التقاضي على درجتين ، فقد جعل المقنن محاكم تستأنف إليها الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، بمعنى أن محاكم هذه الدرجة لا ترفع أمامها دعاوى مبتدأة — كقاعدة — وتختلف هذه المحاكم بحسب نوع الحكم المستأنف ، فالحكم الصادر من المحكمة الجزئية يقبل الاستئناف ، ينظر أمام المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة من محاكم الدرجة الثانية ، أما الحكم الصادر من محكمة ابتدائية ويقبل الاستئناف فإنه ينظر أمام محكمة الاستئناف ، ولذلك فمحاكم الدرجة الثانية هي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف .

(أ) المحاكم الابتدائية (الكلية) :

للمحاكم الابتدائية في نظامنا القضائي وضعان ، أولهما اعتبارها من محاكم الدرجة الأولى، حيث ترفع إليها الدعاوى المبتدأة، وهو الوضع الذي ذكرناه حالاً ، أما الوضع الثاني للمحاكم الابتدائية ، فهو اعتبارها من محاكم الدرجة الثانية ، حيث ترفع إليها الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية ، ذلك أن المقنن

(١) المادة ٩ / ١ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ١٠ من قانون السلطة القضائية .

تبعاً لتقديره السابق في بساطة الدعاوى الجزئية ، قرر أن يكون استئنافها إلى المحكمة الابتدائية^(١) .

وإذا كان تشكيل المحكمة في الوضعين لا يختلف — كما سيرد — لكن الوصف يجب أن يختلف ، ولذلك يسميها بعض الشراح : المحكمة الكلية الاستئنافية^(٢) .

(ب) محاكم الاستئناف :

وهي محاكم تختص بنظر الطعون المرفوعة في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ، باعتبارها محكمة أول درجة ، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة ثاني درجة ، فلا تستأنف ؛ لأن التقاضي يقف عند درجتين .

وتسمى محكمة الاستئناف هذه — في العمل — محاكم الاستئناف العليا تمييزاً لها عن المحاكم الابتدائية باعتبارها محكمة استئنافية .

ويكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا ، ويجوز أن تتعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف^(٣) .

ويجوز إنشاء محاكم استئناف أخرى ، وتعيين دائرة اختصاصها المحلي وتعديل هذا الاختصاص بقانون^(٤) .

(١) انظر المادة ٤٧ / ٢ مرافعات " وتختص — أي المحاكم الابتدائية — كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .

(٢) الدكتور / أحمد مسلم في أصول المرافعات ، ف ١١٢ ويرى — بحق — أنه لا يمكن أن تسمى بالمحكمة الابتدائية الاستئنافية لأن هذا تناقض لفظي ، ويؤثر تسميتها بالمحكمة الكلية ، حتى تقابل الجزئية من ناحية وليمكن تسميتها بالكلية الاستئنافية من ناحية أخرى ، وحينئذ يقتصر مدلول المحكمة الابتدائية على المحكمة الكلية كمحكمة الدرجة الأولى .

(٣) المادة ٣ من قانون السلطة القضائية .

(٤) المادة ١٠ من قانون السلطة القضائية .

ونظراً لأن بعض محاكم الاستئناف يشمل اختصاصها المكاني أكثر من محافظة ، فقد أجاز المقنن تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الاستئنافية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف^(١) .

محكمة النقض

تأتي محكمة النقض على رأس القضاء العادي ، وهي أعلى من محاكم الدرجة الأولى ، ومحاكم الدرجة الثانية ، ولكنها لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ؛ لأن الطعن أمامها لا يجوز لخطأ متعلق بالوقائع ، وإذا هي نقضت حكماً لخطئه في القانون ، فالأصل أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم^(٢) ، وإذا حكمت المحكمة في الموضوع — في الحالات التي يجوز فيها ذلك — فلا يعدو عملها مجرد تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه ، أما تقدير ثبوت الوقائع فلا رقابة عليه لمحكمة النقض^(٣) .

ووظيفة هذه المحكمة الإشراف على صحة تطبيق القانون أمام المحاكم ، وسلامة تفسيره وتأويله ، وتعمل على توحيد أحكام القضاء^(٤) .

(١) المادة ٦ / ٤ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ٢٦٩ / ٢ مرافعات .

(٣) أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي في مبادئ المرافعات ص ١٩٦ ، الدكتور / محمد حامد فهمي في المرافعات المدنية والتجارية ف ١٤٨ .

(٤) هذا وقد استحدث المقنن نصاباً مالياً لمحكمة النقض ، وقد نص على ذلك في المادة " ٢٤٨ من قانون المرافعات الحالي بأن : " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية :

١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم " مستبدله بمقتضى

المادة الثانية من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧م الصادر بالجريدة الرسمية ، العدد ٢٢

=

مكرر في ٦ يونيه سنة ٢٠٠٧م

والنهوض بهذه المهمة — توحيد تفسير القانون وتطبيقه — يستدعي أن تكون القائمة بهذه المهمة محكمة واحدة ، حتى لا تتعدد الاتجاهات ، ومن ثم كانت محكمة النقض محكمة واحدة ، مقرها مدينة القاهرة^(١) ، وقد أنشئت هذه المحكمة في عام ١٩٣١م^(٢).

هذا، وفي التعديل الحديث قرر المقنن أن: " يُعَيِّن رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، ولمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

(المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م ، استبدلت نصوص فقراتها الثانية والثالثة والرابعة بهذا النص، وذلك بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩م، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الجريدة الرسمية ، العدد ٢٥ مكرر " ب " في ٢٦ يونية سنة ٢٠١٩م).

= ونص أيضاً في المادة " ٢٤٩ " على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي — أي كانت المحكمة التي أصدرته — فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم ، وحاز قوة الأمر المقضي " .

(١) المادة ٢ من قانون السلطة القضائية ، ولم يشر القانون إلى جواز عقدها خارج هذا المقر . الدكتور / عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص ١٤٠ .

(٢) أنشئت محكمة النقض في ٢ مايو سنة ١٩٣١ بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ وسميت هذه المحكمة في قانون إنشائها " محكمة النقض والإبرام " رغم أن لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ رأت حذفها في جميع النصوص التي تتكلم عن النقض في قانون المرافعات وفي سائر القوانين المتعلقة به ، وبررت ذلك بأن المحكمة هي محكمة نقض فقط ، تقبل الطعن فتتقض الحكم ، أو ترفض الطعن وتقف عند هذا الحد ، فليس لها صفة الإبرام ، انظر : مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور عبد الباسط جميعي ص ١٩٤ هامش (١) ، الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور / فتحي والي ف ١٢٣ ، أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ف ١١٥ .

المحكمة الدستورية العليا

أنشأ المقتن المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م؛ لتحل محل المحكمة العليا، التي كانت قد أنشئت بالقانون ٨١ لسنة ١٩٦٩م .
هذا، ولقد أصبحت المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها بموجب الدستور المصري الحالي، الصادر في ٢٠١٤م .

النص الدستوري :

نصت المادة " ١٩١ " من دستور ٢٠١٤م علي أن : " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة " .

كما نصت المادة " ١٩٢ " من ذات الدستور علي اختصاصات هذه المحكمة بقولها : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها .

كما نصت المادة " ١٩٥ " من ذات الدستور أيضا علي إلزامية الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة بقولها :

" تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " .

وعلي هذا: فإن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، فهي لا تتبع جهة القضاء العادي، كما أنها لا تتبع جهة القضاء الإداري، وإنما هي جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

درجات المحاكم في النظام القضائي الإسلامي:

تعدد درجات المحاكم في أي نظام قضائي أو عدم تعددها، يعتمد أساساً على مدى قابلية الأحكام للطعن في هذا النظام، فإن كانت الأحكام قابلة للطعن تتعدد درجات المحاكم، وأما إذا كانت الأحكام لا تقبل الطعن فلا وجود للتعدد.

وقد تحدثنا فيما سبق عن مدى قابلية الأحكام للطعن في الفقه الإسلامي، وحق الخصوم في عرض الحكم الصادر من قاض على قاض آخر.

وخلاصة القول أنه وإن كانت للأحكام حجية واجبة الاحترام من الجميع، ويفترض فيها الصحة، وأنها عنوان الحقيقة، إلا أنه يجوز عرض النزاع مرة ثانية على قاض آخر، لوقوع نزاع في الحكم، أو لظهور جور القاضي الذي أصدره وحيفه في أحكامه كلها أو بعضها، أو لأن القاضي لا يصلح للقضاء، أو لأن أحد الخصوم لم يقتنع بالحكم.

وعلى هذا يمكن القول بأن تعدد درجات المحاكم لا يصطدم وقواعد النظام القضائي الإسلامي، بل هو يساير هذا النظام، وذلك تأسيساً على أن لولي الأمر الحق في تخصيص القضاء، وتقبيده وحقه في ذلك إنما هو ثابت بمقتضى الشرع^(١).

(١) المغني لابن قدامة ١ / ٩٢، شرح فتح القدير ٧ / ٢٥٦، حاشية ابن عابدين ٥ / ٤١٩، مجلة الأحكام الشرعية للقارى ص ٥٩٩، أدب القاضي للماوردي ١ / ١٢٣، القضاء في الإسلام رسالة الدكتور / محمود مفتاح ص ١٩٠.

المبحث الثاني تشكيل المحاكم

تختلف النظم القضائية في تشكيل محاكمها وفقاً للظروف التي تعيشها كل دولة ومن ثم تختار ما يتناسب وأحوالها ، مفاضلة في ذلك بين النظامين المعروفين نظام القاضي الفرد وتعدد القضاة^(١) .

وفي مصرنا الحبيبة حاول المقنن الاستفادة من مزايا كل نظام مع تقاضى عيوبه بقدر الإمكان ، ولذلك أخذ بالنظامين في مجالين مختلفين على الوجه الآتي :

تشكيل محاكم الدرجة الأولى:

يفرق المقنن في تشكيل محاكم الدرجة الأولى بين المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية .

أولاً : تشكيل المحاكم الجزئية :

تشكل المحكمة الجزئية من قاض واحد ، نظراً لكثرة الدعاوى التي ينظرها مع بساطتها وضآلة قيمتها ، والأخذ بنظام القاضي الفرد هنا يتناسب وظروف مصر وجهازها القضائي ، وما يعانيه من عجز في الأعضاء والوسائل والإمكانات ، مع وجود كم هائل من القضايا يتزايد ويتضاعف ويتكاثر .

وكذلك تتشكل محكمة الأمور المستعجلة من قاض فرد لأن الدعاوى المستعجلة في حاجة إلى إجراءات سريعة ومختصرة ، وكذلك تتشكل محكمة التنفيذ من قاض فرد ؛ لأن طبيعة عمل هذه المحكمة وهو الإشراف على عمل التنفيذ ، يتطلب أن يكون المشرف شخصاً واحداً ، حتى يكون الإشراف أكثر فاعلية^(٢) .

(ب) تشكيل المحاكم الابتدائية :

أخذ المقنن المصري في تشكيل المحاكم الابتدائية بمبدأ (تعدد القضاة) فنتشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة ، هم رئيس الدائرة وعضوان ، وقد راعى المقنن أن المحكمة الابتدائية تنتظر الدعاوى كبيرة القيمة، والتي تحتاج إلى خبرة

(١) سبق أن تناولناهما بالتفصيل ، راجع ما سبق .

(٢) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ، ف ١٣٠ .

قضائية عميقة؛ نظراً لأهميتها أو لصعوبتها.

تشكيل محاكم الدرجة الثانية:

(أ) تشكيل المحاكم الابتدائية :

لا يختلف تشكيل المحاكم الابتدائية باعتبارها محكمة درجة ثانية عن تشكيلها باعتبارها محكمة درجة أولى ، وعلى ذلك فهي تشكل من ثلاثة قضاة^(١) هم : رئيس الدائرة وعضوان ؛ نظراً لأن الدعاوى المستأنفة في حاجة إلى الأناسة والتروي ، وتشكيل المحكمة من ثلاثة أدعى إلى تحقيق ذلك .

وتؤلف كل محكمة من المحاكم الابتدائية من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرئاسة المحكمة — إدارياً — أحد مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية ، أو من أية محكمة استئناف أخرى تالية لها في الترتيب^(٢) .

ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد .

وتشتمل كل محكمة ابتدائية على عدد كاف من الدوائر ، يرأس كلٍّ منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها ، ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة^(٣) .

(ب) تشكيل محاكم الاستئناف :

تشكل محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة^(٤) ، يطلق عليهم نظراً لسمو مركزهم لفظ (مستشارين)^(٥) .

(١) المادة (٩) من قانون السلطة القضائية .

(٢) ترتيب محاكم الاستئناف وفقاً للمادة ١/٥٤ من قانون السلطة القضائية ، هو محكمة استئناف قنا ثم أسيوط ثم بني سويف ثم الإسماعيلية ثم المنصورة ثم طنطا ثم الإسكندرية ثم القاهرة .

(٣) الفقرات ٢ ، ٣ ، ٤ من المادة (٩) من قانون السلطة القضائية .

(٤) المادة ٦ / ٢ من قانون السلطة القضائية .

(٥) الدكتور / أحمد مسلم في أصول المرافعات ف ١١٢ .

وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين .

وتشتمل كل محكمة من محاكم الاستئناف على عدد كاف من الدوائر ، يرأس كلاً منها رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد المستشارين ، وتقسم المحكمة إلى دوائر ، وتوزيع العمل بها هو مسئولية الجمعية العمومية للمحكمة ، وهو عمل إداري لا يترتب عليه أي اختصاص نوعي (١) .

تشكيل محكمة النقض:

تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين، وتحتوي هذه المحكمة على نوعين من التشكيلات القضائية هي الدوائر، وهيئتان عامتان:

(أ) تشكيل الدوائر:

توجد بمحكمة النقض دوائر لنظر المواد الجنائية ، ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية ودوائر الأحوال الشخصية ودوائر للمواد الاقتصادية " القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الأخرى .

وتشكل كل دائرة من خمسة مستشارين ، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه ، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها (٢) .

وترتيب وتأليف الدوائر ، وتوزيع القضايا على الدوائر المختصة تختص به الجمعية العامة لمحكمة النقض (٣) .

(١) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص ١٤٠ .

(٢) المادة (٣) من قانون السلطة القضائية .

(٣) الفقرتان أ ، ب من المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية .

(ب) تشكيل الهيئتين :

وفقاً لنص المادة (٤) من قانون السلطة القضائية ، تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة ، إحداهما للمواد الجنائية ، والثانية للمواد المدنية والتجارية ، ومواد الأحوال الشخصية وغيرها .

وتشكل كل هيئة من الهيئتين من أحد عشر مستشاراً ، برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه ، وتختص بالنظر في العدول عن مبدأ قانوني قرره أحكام سابقة صادرة من الدوائر التابعة لذات الهيئة ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خاصة هي أغلبية سبعة أعضاء على الأقل^(١) .

وأما إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قرره أحكام سابقة ، صادرة من دوائر تابعة لهيئة أخرى ، كأن ترى دائرة مدنية العدول عن مبدأ قرره الدوائر الجنائية ، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، كهيئة واحدة تشكل من اثنين وعشرين مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم نوابه ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل^(٢) .

تشكيل المحكمة الدستورية العليا:

النص الدستوري :

نصت المادة " ١٩٣ " من الدستور المصري الحالي الصادر في ٢٠١٤م علي أن: " تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها،

(١) المادة ٤/٢ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ٤/٣ من قانون السلطة القضائية، وانظر قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ص ١٤٠ ، ١٤١ ، الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور / فتحي والي ف ١٣٠ .

ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

كما نصت المادة " ١٩٤ " من ذات الدستور علي أن :

" رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية " .

هذا، ويرأس جلسات المحكمة رئيسها، أو أقدم أعضائها ، وعند خلو منصب الرئيس، أو غيابه، أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.

ويجب أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته .

ويشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا أن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، المنصوص عليها بالمادة (٣٨) من قانون السلطة القضائية ، وفوق ذلك لا تقل سنه عن خمسة وأربعين سنة ميلادية .

ويتم اختيار من يعين عضواً بالمحكمة الدستورية من بين الفئات التالية :

(أ) أعضاء المحكمة الحاليين .

(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل .

(ج) أستاذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية، ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثمان سنوات متصلة على الأقل .

(د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة .

الفصل الثالث

العاملون بالقضاء

نتحدث في هذا الفصل عن الأشخاص الذين تناط بهم أعمال القضاء والقائم بأعمال القضاء أصلاً هم القضاة ، وهناك أشخاص آخرون لا غنى للقضاء عن خدماتهم ، فهم يؤدون خدمات للقضاء على قدر من الأهمية ، وهؤلاء الأشخاص هم أعضاء النيابة ، والكتاب ، والمحضرون ، والخبراء .

وفيما يلي نتحدث عن القضاة في المبحث الأول

ثم عن أعضاء النيابة العامة في المبحث الثاني

ثم عن أعوان القضاء في المبحث الثالث

المبحث الأول

القضاة

القضاة هم أهم العناصر البشرية التي تظهر في العملية القضائية ، وهم مصابيح مضاءة تنير طريق الحق ، وسوج متينة تحبس الظلم وتكبتة ، وهم ملجأ الناس وملاذهم حين تُظلم الدنيا بالظلم ، وكثير منهم قضى نحبه فداءً للحق وكتباً للظلم ، ومنهم من تغلب عليه الظلم وقتله مظلوماً ، فمن هم القضاة ؟ كلمة القضاة كلمة عامة تشمل كل من له ولاية القضاء في الدولة أياً كانت درجته الوظيفية .

ونظراً لما لو وظيفة القضاء من أهمية ، فإن الأنظمة القضائية المختلفة تجتهد في وضع القواعد التي تضمن دخول أفضل العناصر المؤهلة لتولي هذه الوظيفة ، وتقرر لهم من الضمانات ما يجعلهم آمنين على حاضريهم ومستقبلهم ، وما يضمن حسن سير القضاء ، ولذلك سنتحدث عن اختيار القاضي وشروطه في مبحث أول ، ثم عن ضمانات القاضي في مبحث ثان .

المطلب الأول اختيار القاضي وشروطه

نتحدث عن اختيار القاضي في الفرع الأول، ثم نبين شروطه في الفرع الثاني

الفرع الأول اختيار القاضي

يجتهد الفقهاء والمقننون في وضع القواعد التي تكفل وصول أفضل العناصر البشرية لتولي منصب القضاء ، وعموماً يدور اجتهادهم حول الأخذ بأحد نظامين ، هما : نظام انتخاب القاضي ونظام تعيين القاضي .

أولاً : نظام انتخاب القاضي :

يهدف هذا النظام إلى اختيار القاضي عن طريق الانتخاب ، سواء كان انتخاباً عاماً — مباشراً أو غير مباشر — أو كان انتخاباً من هيئات معينة ، وقيل في تأييد هذا النظام أنه يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ، ويؤكد مبدأ الفصل بين السلطات ، ويعتبر الناخبين مصدر السلطات جميعاً ، ومع ذلك فهو نظام مننقد ، فهو يجعل القاضي في حاجة إلى جمهور المتقاضين لانتخابه ، فيعمل على إرضائهم حتى يعيدوا انتخابه فيفقد بذلك استقلاله وأيضاً جمهور الناخبين ، قد لا يختار الشخص الأكثر كفاءة وإنما يختار الشخص الأكثر شعبية أو قرابة أو مداراة لهم^(١) .

ثانياً : نظام تعيين القاضي :

يهدف هذا النظام إلى اختيار القاضي بواسطة السلطة التنفيذية وتعيينه في منصب القضاء ، ذلك أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة تنهض بها عن طريق السلطة القضائية ، فيكون من الطبيعي أن تتولى الحكومة تعيين من يتولى الوظائف العامة ، ومنها الوظيفة القضائية ، ولا شك أن الدولة أقدر على حسن اختيار القضاة من الجمهور .

ولا محل للخوف من قيام الحكومة بتعيين القضاة ، وخضوعهم للحكومة التي

(١) الوسيط للدكتور/فتحي والي ف٩٥، المرافعات المدنية والتجارية للدكتور/ محمد حامد فهمي

عينتهم ، وذلك لأن تعيين الحكومة للقضاة ليس مطلقاً ، وإنما يخضع لتوافر شروط موضوعية حددها القانون إلى جانب النص على الضمانات التي تكفل استقلال القضاة ، وتجعلهم في مأمن من سلطان الحكومة^(١) .

وقد أخذ نظام القضاء المصري بنظام تعيين القضاة عن طريق السلطة التنفيذية، ولكن سلطتها في ذلك ليست مطلقة ، وإنما تخضع لشروط موضوعية يجب توافرها فيمن يعين قاضياً^(٢) .

ويجب على الحكومة أن تراعي تحقق الشروط فيمن تختارهم لمنصب القضاء وأن تبتعد عن المؤثرات السياسية قدر الإمكان ، وأن تتأني بهذا المنصب عن اعتباره مكافأة عن خدمات سابقة ، أو للانتماء للحزب الحاكم أو للعمل في فصول أو منظمات معينة ، وبتعبير آخر يجب أن يكون هذا منصب بعيد عن تطبيق فكرة " أهل الثقة أولى من أهل الخبرة " يكون القضاء بعيداً عن معترك الحياة الحزبية بما تحمله من أخطار يهدد استقلال القضاء^(٣) .

اختيار القاضي^(٤) في التنظيم القضائي الإسلامي :

وظيفة القاضي في الإسلام وظيفة شرعية ، ومنزلة رفيعة ، لا منزلة فوقها من المنازل ، ولا رتبة أوفى منها ، فهي منصب جلي ، ومكان عليّ ، ولذلك فقد أولاهم الفقهاء اهتمامهم ، وتناولوها بالبحث والدراسة العميقة ، وحددوا طريقة

(١) قانون القضاء المدني للدكتور / محمود هاشم ف ١٢٢ ، الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ف ٩٦ .

(٢) قوانين المرافعات للدكتورة أمين النمر ف ٥٨ .

(٣) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص : ٢٠٨ .

(٤) لفظ (قاضي) اسم مدح يقول السمناني في روضة القضاة في هذا المعني : " اختلف الناس في أن اسم القاضي أشرف من الحاكم أم هما سواء ، فمنهم من قال أن اسم القاضي أشرف في اللغة ، ومنهم من قال بالعكس من هذا ، ومنهم من قال هما سيمان ، ولهذا أضافهما الله تعالى إليه على السواء ، ورأيت كثيراً من القضاة يكره أن يخاطب الناس بالحاكم ويأنس بالقاضي " روضة القضاة ١ / ٥١ .

اختيار القاضي ، ووضعوا شروطاً ثقيلة ينبغي توافرها فيمن يكون جديراً بهذا الوصف ، ويتولى منصب القضاء .

وفي اختيار القاضي يأخذ التنظيم القضائي الإسلامي بنظام تعيين القاضي عن طريق ولي الأمر ، ولم يأخذ بنظام الانتخاب عن طريق الرعية ، وذلك لأن القاضي نائب عن ولي الأمر لمصلحة المسلمين ، فضلاً عن أن هذا الطريق يجعل للقاضي حاجة عند الناس ، وقد يعمل على إرضائهم للحصول على هذه الوظيفة ، مما يؤثر على سير العدالة .

ويجوز لولي الأمر في اختياره للقاضي أن يعين شخصاً يعرفه ، ويعلم توافر الشروط فيه ، وأما إذا كان لا يعرفه ، فيكون له أن يعتمد على السؤال عنه ، وجمع المعلومات حوله ، فإن رضى عنه ، وإلا فالأمر منوط به ، وكذلك يجوز لولي الأمر أن يعقد اختباراً لمن يرشح لوظيفة القاضي يتولاه ولي الأمر بنفسه ، أو من ينيبه في ذلك ، وقد اختبر رسول الله ﷺ معاذاً حين بعثه قاضياً على اليمن (١) .

الفرع الثاني

شروط تعيين القاضي

لقد أوردت المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الشروط العامة التي يجب توافرها فيمن يولى القضاء ، وهذه الشروط هي :

الشرط الأول : أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية ، فليس للأجانب ولاية القضاء في مصر ؛ لأن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة ، ولا يجوز أن يكون ممثل الدولة في تولي سلطتها إلا من يتمتع بجنسيتها يستوي أن تكون هذه الجنسية جنسية مصرية أصيلة أم مكتسبة (٢) .

الشرط الثاني : أن يكون كامل الأهلية ، ومن ثم فلا يجوز تعيين فاقد الأهلية أو ناقضها قاضياً .

(١) المغني لابن قدامة ١٠ / ٣٥ ، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٦ .

(٢) الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور / فتحي والي ، ص ٩٧ ، الجنسية للدكتور /

إبراهيم أحمد إبراهيم ص ١٤٥ .

الشرط الثالث : ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم الاستئناف، وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض ، وقد افترض المقنن أن من بلغ هذا الحد من عمره يكون قد بلغ حداً من الوعي ونضوج الفكر وقوة الشخصية يؤهله لتولي هذه المراكز .

الشرط الرابع : أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية ، أو على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من إحدى كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، وذلك بتقدير جيد على الأقل^(١) ، وذلك بناءً على المادة " ٦ " من قرار رئيس الجمهورية^(٢) ، بإصدار القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية ، وبناءً على المادة الثانية من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٦م^(٣) .

(١) انظر : المادة رقم ٣٨ من قانون السلطة القضائية ، حيث نصت على أنه: " يشترط فيمن يعين معاوناً للنياحة العامة وفي سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها في المادة الأولى أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند " ٣ " من المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل ، وذلك بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون " معدلة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ ، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية .

انظر : الجريدة الرسمية ، العدد " ١٨ " مكرر " أ " في ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ م .

(٢) ونصها : " استثناء من حكم البند ٣ من المادة ٣٨ من القانون المرافق يجوز أن يعين معاوناً بالنياحة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء ، أو الإجازة العالية مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون ، والقانون المرافق هو قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م .

(٣) في شأن تطوير الدراسة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٩٦٦م ، ونصت المادة الثانية منه على أن: " تمنح جامعة الأزهر خريجي كلية الشريعة والقانون درجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون ، ويكون لحاملي هذه الدرجة كافة الحقوق المقررة لحاملي درجة الإجازة العالية في الشريعة ، فضلاً عن الحقوق المقررة لحاملي درجة "الليسانس" في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات الجمهورية ... " .

ويجوز تعيين من يحصل على شهادة أجنبية معادلة لإجازة الحقوق ، بشرط أن ينجح في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

الشرط الخامس : ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر يخل بالشرف ، ولو كان قد رد إليه اعتباره ، وتقدير الأمر المخل بالشرف متروك لتقدير من بيده أمر التعيين.

الشرط السادس : أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، فالقضاء منصب جلي ومكان علي ، يجب تنزيهه من ذوي السمعة السيئة والسيرة الذميمة .

الشرط السابع : توافر خبرة سابقة في العمل بالقانون تتناسب مع الدرجة التي سيعين بها قاضياً بالمحكمة الابتدائية أم رئيساً بها ، أو مستشاراً بمحكمة الاستئناف أو مستشاراً بمحكمة النقض ، وقد حددت المواد من ٣٩ - ٤٣ من قانون السلطة القضائية الخبرة المطلوبة لكل درجة من الدرجات الوظيفية السابقة^(١) .

ويكون شغل الوظائف القيادية سواء بالتعيين أم الترقية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاريها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة .

أما بالنسبة لمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض، فيعين بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ، ويرشح الآخر وزير العدل .

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض .

(١) قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ص ٢١٦ ، الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ف ٩٧ .

ويعين رئيس محكمة النقض من بين سبعة من نواب رئيس المحكمة ولمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله^(١).

المطلب الثاني ضمانات القاضي

تهتم الأنظمة القضائية المختلفة بوضع ضمانات تحقق استقلال القاضي وتضمن حيده في اتخاذ القرار .

وقد اهتم نظام القضاء المصري بتقرير هذه الضمانات التي تكفل أن يكون القاضي آمناً في حاضرة مطمئناً على مستقبله ، وتجعله بمنحي من بطش ذوي الأيدي القوية من الخصوم أو غيرهم ، ولذلك وضع المقتن المصري ضمانات تحمي القاضي من الحكومة ، وضمانات تحميه من الخصوم ، وضمانات تحميه من نفسه.

وهذه الضمانات لا يقصد بها مصلحة القضاة أنفسهم بقدر ما يقصد بها مصلحة المتقاضين ، فالقاضي إذا كان في مأمن حكم وهو مطمئن الفؤاد ، ثابت اليد ، فلا يهتز ميزان العدالة في يده ، وفيما يلي نتعرض لبيان هذه الضمانات من خلال الفروع التالية :

(١) راجع: المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية، معدلة بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩م.

الفرع الأول

ضمانات حماية القاضي من الحكومة

وضع المقتن المصري ضمانات لحماية القاضي من تدخل الحكومة ، والتأثير عليه ، وهذه الضمانات هي :

أولاً : عدم القابلية للعزل :

يقصد بذلك عدم جواز عزل القاضي ، أو وقفه عن العمل ، أو إحالته إلى المعاش إلا برضاه ، وفي الحدود التي ينص عليها القانون (١).

ولأهمية هذه الضمانة ، فقد نص عليها الدستور في المادة ١٦٨ " القضاة غير قابلين للعزل " كما نص عليها قانون السلطة القضائية في المادة ٦٧ " رجال القضاء والنيابة العامة — عدا معاوني النيابة — غير قابلين للعزل " .

وهذه ضمانة هامة ، لا سيما بالنسبة لدول العالم الثالث ، والدول حديثة العهد بالديمقراطية ، فكثيراً ما تلجأ حكومات هذه الدول إلى خنق الحريات ، وإسكات الأصوات ، ومن ثم تعد الحكومة يدها لتطول الأحرار ، وكل من يبدو منه استقلال في الرأي، حتى ولو كان قاضياً (٢) .

ولا يعني عدم القابلية للعزل أن القاضي يظل قاضياً طوال حياته ، ومهما أتي من تصرفات لا تليق وهذا المنصب ، بل إن القاضي يخضع كغيره من موظفي الدولة للإحالة للمعاش إذا بلغ السبعين عاماً (٣) ، " لا يجوز أن يبقى في وظيفة أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة ميلادية " .

(١) راجع : هيبه القضاة ضمانة لاستقلال القضاء "دراسة تأصيلية مقارنة" بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، د/ أحمد خليفة شرفاوي ، بحث منشور في مجلة روح القوانين ، جامعة طنطا ، العدد السابع والخمسون ، إصدار يناير ٢٠١٢م ، ص ١١٥٨ وما بعدها .

(٢) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٩٩ .

(٣) المادة ٦٩ / ١ من قانون السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، وقد نص في مادته الأولى على أنه " تستبدل عبارة " سبعين عاماً " بعبارة " ثمان وستين سنة " في كل من المواد " ٦٩ " من القرار بقانون رقم ٤٦

ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة^(١) .

كذلك تجوز إحالة القاضي إلى المعاش إذا لم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمره بعد انقضاء الأجازات المرضية المقررة له في القانون ، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق ، وهنا يحال القاضي إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (المادة ١٩١ / ١ من قانون السلطة القضائية) .

وأيضاً تجوز إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إذا ظهر في أي وقت أنه فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية^(٢) .

وكذلك تجوز الإحالة إلى المعاش ، أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بالنسبة للرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة ، الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متوالين بدرجة أقل من المتوسط^(٣) .

لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية ... " . الجريدة الرسمية ، العدد " ١٨ " مكرر " أ " في ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ ، هذا وقد نص المقتن في المادة ٦٩/٢ من قانون السلطة القضائية على أنه : " ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو ، فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ ، دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة

(١) المادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية .

(٣) المادة ١١٢ من قانون السلطة القضائية

وقرار الإحالة إلى المعاش أو النقل لوظيفة غير قضائية في الحالتين الأخيرتين يكون من اختصاص مجلس تأديب القضاة^(١) المنصوص عليه في المادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية^(٢).

وجدير بالذكر أن الحالات التي يجوز فيها إحالة القاضي إلى المعاش واردة في القانون على سبيل الحصر ، ومن ثم فلا يمكن إحالة أي قاض إلى المعاش إلا إذا انطبقت عليه حالة من الحالات التي ذكرها القانون .

ثانياً : وضع قواعد خاصة لشئون القضاة :

اهتم المقتن المصري بوضع ضمانات خاصة لمختلف الأمور التي تهم القاضي ومن ثم فيشعر القاضي بالاستقرار ، ولا يسعى لإرضاء أحد من القائمين على هذه الأمور ومن ذلك :

١ - راتب القاضي : لقد حرص المقتن على رعاية القاضي ، فقرر له راتباً متميزاً ، وخصه بكادر خاص يختلف عن كادر العاملين المدنيين بالدولة ، حيث لا ينبغي أن تكون المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر ، سبباً في التضيق على القاضي ، فإن ذلك يدعوه إلى التطلع إلى ما في أيدي الخصوم أو غيرهم ، مما يكون له أخطر الأثر على القضاء^(٣).

وتحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بقانون السلطة القضائية ، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ، أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة^(٤).

٢ - ترقية القاضي : ترقية القاضي تتم عن طريق السلطة التنفيذية ، ولو أطلق الأمر لها في ذلك لتمكنت من نفع من يداهنها ويمالئها ، ومن ضرر من يقف لها ويعارضها ، وذلك بترقية الأول وتناسي الثاني ، وبهذا يغدو القاضي الذي يقيم

(١) ويتكون من رئيس محكمة النقض رئيساً ، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ، وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض أعضاء .

(٢) الدكتور / محمود هاشم في قانون القضاء المدني ١ / ١٣٠ .

(٣) قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ١ / ٢٤٤ .

(٤) المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية .

العدالة بين الناس مفتقداً إياها لنفسه ، منشغلاً بما يقع عليه من ظلم بدلاً من رفعه ودفعه عن الآخرين^(١) ، وتقادياً لهذا الوضع فقد نظم المقنن ضوابط لترقية القاضي حتى لا يكون أمر ترقيته خاضعاً لما قد يعتري السلطة من أهواء .

وفي هذا الشأن أوردت المادة "٤٩" من قانون السلطة القضائية الأحكام الخاصة بترقية القضاة ، وتكون الترقية على أساس الأقدمية مع الأهلية ، ويجوز ترقية القاضي للكفاية الممتازة ، ولو لم يحل دوره في الترقية متى أمضي في وظيفته سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة القضاة الذين يرقون لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية بينهم .

ومن جهة أخرى يستفاد من نص المادة "٧٩" من قانون السلطة القضائية أنه يجوز تخطي بعض القضاة في الترقية .

وضمناً لحق القاضي في الترقية إن كان لها وجه ، وعدم تخطيه إن لم يكن له سبب ، يقوم وزير العدل — قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة بثلاثين يوماً على الأقل — بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ، ولم تشملهم الحركة القضائية مع بيان أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق في التظلم^(٢) .

ومن الضمانات أيضاً كون الترقية تتم بقرار من رئيس الجمهورية ، وبشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى^(٣) .

٣- نقل القاضي أو نديه أو إعارته : وضع المقنن ضوابط لنقل القاضي من مكان إلى مكان آخر ، وذلك لأن المحاكم تنتشر في سائر بلاد الجمهورية ، وتختلف هذه البلاد فيما بينها من حيث توافر أسباب المعيشة ، وأحوال البيئة ومدى

(١) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٢٠٠ .

(٢) مبادئ المرافعات للدكتور / عبد الباسط جميعي ص : ٢١٦ .

(٣) المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية .

البعد عن العاصمة ، ولو ترك الأمر مطلقاً بيد السلطة التنفيذية لأمكنها التتكيل بذوي الرأي المستقل من القضاة بنقله إلى المناطق النائية مما يؤثر في استقلال القضاة .
وقد وردت ضوابط النقل و الندب و الإعارة في قانون السلطة القضائية ،
ولذلك نصت المادة ٥٢ منه على أنه : " لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون " ، ثم فصلت المواد "٥٣" وما بعدها قواعد نقل القضاة وندبهم وإعارتهم^(١) .

٤ - **تأديب القاضي** : يخضع القاضي كغيره من العاملين بالدولة للمساءلة عن خطئه ، ولكن نظراً لمكانة القاضي وأهمية وظيفته ، فقد أحاطه المقتن بمجموعة من الضمانات - عند مساءلته - حتى لا يستغل خطأ القاضي ، ويستخدم كوسيلة للتتكيل به وتصفية حسابات قديمة .

(١) هذا وقد نصت المادة رقم " ١٥ " من قانون السلطة القضائية حيث نصت على أنه " تجوز إعاره القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن أربع سنوات متصلة ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية " ، مستبدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ ، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية .
راجع : المادة الثالثة من هذا القانون ، الجريدة الرسمية العدد " ١٨ " مكرر " أ " في ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ ، كما نصت المادة " ٦٦ " من قانون السلطة القضائية ، على أن : " تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها ، أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات ، ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجةها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة ، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته ، وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بسير العمل " ، مستبدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ ، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، راجع : المادة الثالثة من هذا القانون ، الجريدة الرسمية ، العدد " ١٨ " مكرر " أ " في ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ م .

ولذلك جعل المقنن تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من سبعة أشخاص من كبار القضاة ، وهم رئيس محكمة النقض رئيساً ، وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض ، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء ، وعند غياب واحد منهم يحل محله الأقدم من مستشاري محكمته^(١) ، و تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه، أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها .

ويخطر مجلس التأديب بالطلب ، فإذا لم يقر النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب^(٢) ، وتتقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش (المادة ١٠٤ من قانون السلطة القضائية) .

ومحافظة على كرامة القاضي وسمعة القضاء فقد جعل المقنن جلسات المحاكمة التأديبية سرية^(٣) و " يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق " المادة ١٠٧ من قانون السلطة القضائية .

كما حصر المقنن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي في اللوم والعزل^(٤) .

(١) المادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ٩٩ من قانون السلطة القضائية .

(٣) المادة ١٠٦ / ١ من قانون السلطة القضائية .

(٤) المادة ١٠٨ من قانون السلطة القضائية .

٥- **اتهام القاضي ومحاكمته جنائياً** : قد يقع القاضي في الخطأ ، ويرتكب فعلاً يعد جريمة بمقتضى القانون ، وفي ذلك يخضع القاضي للمساءلة الجنائية كمواطن عادي ، ولكن المقنن أحاط القاضي بضمانات حتى في حالة ارتكابه فعلاً يستوجب محاكمته جنائياً وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي :

أ - في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية
ب - وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج عنه بكفالة أو بدونها ، وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .

وتحدد هذه اللجنة مدة الحبس في قرارها بالحبس أو باستمراره ، وتراعى هذه الإجراءات كلما رأت استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة.

ج - وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جنابة أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة ، وبناءً على طلب النائب العام^(١) .

د - واستثناءً من قواعد الاختصاص المكاني تعين اللجنة المنبثقة^(٢) عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وبناءً على طلب النائب العام ، المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنب أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم^(٣) .

هـ - يجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين^(٤) .

(١) الفقرات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، من المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية .

(٢) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٤٦ .

(٣) المادة ٩٥ من قانون السلطة القضائية .

(٤) المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية .

حماية القاضي من الحكومة في النظام القضائي الإسلامي :

لكي ينهض القاضي بواجبه على أحسن وجه ، يجب أن يكون آمناً مطمئناً في حاضره ومستقبله ، ولذلك يجب أن يكون بمنحى من بطش ذوي الأيدي القوية ، مطمئناً على مقومات حياته في الحاضر والمستقبل وعلى هذا الأساس أقيم النظام القضائي الإسلامي .

(أ) راتب القاضي : القاضي عامل من أجل عمال المسلمين ، وهو قائم على مصالحهم ، ومنقطع لخدمتهم ، ومن ثم فنفقته عليهم .

وهذا هو الاتجاه السائد منذ عهد رسول الله ﷺ بل إن الخلفاء الراشدين أوجبوا إجمال العطاء للقاضي والتوسعة عليه ، حتى لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس . وقد منح رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة أربعين أوقية في السنة ، وأعطى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري ستة آلاف درهم وهو على قضاء البصرة وكذلك على بن أبي طالب أعطى شريحاً القاضي خمسمائة درهم (١) .

(ب) حماية القاضي من ذوي السلطة والنفوذ : يجب أن يكون القاضي في مأمن من كيد ذوي السلطة والنفوذ حتى لا يخشى بأسهم ولا يعمل على إرضائهم ، وتحقيق رغباتهم ، بل يجب أن يكون القاضي بعيداً عن كل مؤثر من قريب أو بعيد . وقد تمتع القضاة المسلمون بهذه الحماية بالرغم من عدم النص عليها في الكتب الفقهية . وهذا على بن أبي طالب يكتب لواليه على مصر أن يجعل للقاضي منزلة لديه لا يطمع فيها غيره ، حتى يكون القاضي آمناً من اغتيال رجال السلطة أو النفوذ عند الوالي (٢) .

(١) روضة القضاة للسمناني ١ / ٨٦ ، التراتيب الإدارية للكتاني ١ / ٢٦٤ ، تاريخ القضاء في الإسلام للشيخ / محمود عرنوس ص ١٧ .

(٢) كتب علي بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي واليه على مصر يقول له : " ... اختر للحكم بين الناس بين الناس أفضل رعيته في نفسك ... وافسح له في البذل ما يزيل غلته ، وتقل معه حاجته إلى الناس ، واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك فيأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك . تاريخ القضاء في الإسلام للشيخ / محمود عرنوس ، ص : ١٧ .

ويدل على تمتع القاضي المسلم بهذه الحماية أنه لما اختلف معاوية بن أبي سفيان والي فلسطين من قبل عمر بن الخطاب مع قاضيها عبادة بن الصامت ، فأغلظ معاوية لعبادة في القول ، فقال عبادة لمعاوية : " لا أسألك بأرض واحدة أبداً " وترك فلسطين ورجع إلى المدينة المنورة ، فلما قابله عمر قال له : ما أقدمك ؟ فأخبره بالأمر فقال : ارجع إلى مكانك فبح الله أرضاً لست بها ولا أمثالك ، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك على عبادة ^(١) ، فكان عبادة أمير نفسه .

الفرع الثاني

ضمانات حماية القاضي من الخصوم

لا يكفي لضمان استقلال القاضي وحيدته أن يضع المقنن ضمانات تحمي القاضي من تسلط الحكومة ، بل يجب أيضاً أن يكون القاضي في حماية من عبث المتقاضين أنفسهم ومن كيدهم له ومشاكستهم معه .

وتحقيقاً لذلك وضع المقنن نظاماً خاصاً لمساءلة القاضي أو عضو النيابة ، عند مساءلته عن خطئه في أداء وظيفته أو بسببها ، وأطلق على هذا النظام " مخاصمة القضاة " ولم يجعل المقنن للأفراد من سبيل لمقاضاة القاضي إلا اتباع هذا النظام ، ويمتاز هذا النظام بأن حدد فيه المقنن أسباب المسؤولية وأوردها على وجه الحصر .

ولا يجب اتباع هذا النظام إلا لمساءلة القاضي أو عضو النيابة مدنياً عن خطئه في أداء وظيفته أو بسببها ، ومن ثم فلا محل لتطبيقه لمساءلة القاضي جنائياً أو تأديبياً ، أو مدنياً متى كانت ناشئة عن ارتباطات تعاقدية أو أخطاء تقصيرية خاصة بحياة القاضي العادية ^(٢) .

(١) أسد الغابة في معرفة الصحابة ٣ / ١٦٠ ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢ / ٨٠٧ ، ٨٠٨ ، مبادئ التنظيم القضائي في العراق ، للأستاذ ضياء شيث خطاب ص : ٢٤ .

(٢) د / أمينة النمر في قوانين المرافعات ف ٧٦ ، الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص ٢٨٠ .

وتعتبر مخاصمة القاضي دعوى تعويض ، تقام بطريق خاص ، ويجوز الرجوع على الدولة بما قد يحكم به على القاضي من تعويض ، على أن تقوم الدولة بالرجوع على القاضي بما تكون قد أوفت به وفقاً للقواعد العامة^(١) . ويتبع هذا النظام لمخاصمة القاضي أيّاً كانت درجته أو المحكمة التي يعمل بها ، كما تجوز مخاصمة الدائرة بأكملها عندما ينسب إليها الخطأ ، ولو كانت بمحكمة النقض ، ولكن لا تجوز مخاصمة الهيئتين العامتين مجتمعتين بمحكمة النقض ؛ لأن القول بجواز ذلك يترتب عليه جعل دعوى المخاصمة بدون محكمة تنتظرها^(٢) كما يتبع هذا النظام لمخاصمة أعضاء النيابة العامة^(٣) . وإذا توفى القاضي أو عضو النيابة ، فإنه يمكن توجيه دعوى المخاصمة إلى ورثته .

أحوال قبول دعوى المخاصمة:

لقد أوردت المادة (٤٩٤ مرافعات) أحوال قبول دعوى المخاصمة على وجه الحصر، وهذه الأحوال على النحو التالي :

١- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر، أو خطأ مهني جسيم.

والغش والتدليس والغدر كلها ألفاظ متقاربة المعنى، ولكنها ليست مترادفة كما ذهب البعض^(٤)، وإنما بينها فروق دقيقة^(٥)، وتتفق فيما بينها في أنها وسائل للوصول إلى

(١) قانون القضاء المدني د / محمود هاشم ف ١٥٢ ، الدكتور / أمينة النمر ، المرجع السابق وذات الفقرة .

(٢) بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ص ١٦٤ ، الوسيط للدكتور / فتحي والي ف ١٠٣ .

(٣) المادة ٤٩٤ / ١ مرافعات .

(٤) الدكتور محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ٢٨٦/١ .

(٥) ويقصد بالغش هنا تغيير القاضي للحقيقة عمداً، لتحقيق مصلحة له، أو لأحد الخصوم، أو للإضرار به، كما إذا غيّر القاضي عمداً أقوال أحد الخصوم، أو الشهود، سواء أكان التغيير في الألفاظ أم في المعاني.

غرض واحد، وهو البعد عن العدالة عمداً؛ لتحقيق مصلحة للقاضي، أو لأحد الخصوم أو للإضرار به.

هذا، ويصعب إثبات الغش أو التدليس أو الغدر، لأن إثبات ذلك يستلزم إثبات سوء النية من قبل القاضي، ولذلك نص المقتن لأول مرة في قانون المرافعات السابق على الخطأ المهني الجسيم باعتباره حالة تجوز فيها مخاصمة القاضي.

ويقصد بالخطأ المهني الجسيم:

تجاوز القاضي للصواب بدرجة كبيرة وملحوظة، نتيجة تفريطه في عمله، وتقصيره في أداء واجباته القضائية وانحرافه عن الوجهة المعتبرة لها قانوناً، فهو خطأ ظاهر وواضح، لا يقع فيه قاض إلا إذا كان على درجة كبيرة من الإهمال وعدم الحيطة، كما هو شأن إغفاله لوقائع ثابتة في ملف الدعوى، أو الجهل الفاضح بالمبادئ القانونية الأولية، التي لا ينبغي بحال أن يجهلها مثله^(١).

ولا بد أن يكون الخطأ واضحاً بدرجة كبيرة، بحيث يدل على وقوع إهمال جسيم من قبل القاضي، أو جهل فاضح منه، وأما الخطأ غير الجسيم فلا يعتبر من

وأما التدليس فهو نوع من الغش، ولكن يزيد عليه أن تغيير الحقيقة فيه يكون باستعمال أساليب وطرق احتيالية؛ لتغطية الغش، فمثلاً إذا كلف قاض بكتابة تقرير عن قضية فكتبه محرراً عمداً، بأن وصف مستنداً مقدماً في القضية بغير ما اشتمل عليه المستند، فهذا غش، وكتابة التقرير بخط رديء أو بعبارات غير قاطعة الدلالة عمداً، لتغطية الغش، يجعل الغش تدليساً، لأنه استعمل وسيلة لتغطية الغش وإخفائه، فالمدلس أمعن في الغش من الغاش.

وأما الغدر فنعتقد أن المراد به هنا الحكم بالظلم عمداً للأغراض السابقة، وهو يختلف عن الغش، في أن الأخير تغيير لحقيقة، ومنه يصل القاضي إلى غرضه، وأما الغدر فلا يغير الحقيقة، ومع ذلك يحكم بالظلم عمداً، وقد سماه المقتن غدراً؛ مرجع التسمية هنا لأن هذا الفعل يمثل نقضاً للعهد واليمين الذي أقسمه بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحترم الدستور القانون، ونقض العهد هو إنما هو الغدر ذاته.

ولذلك فالغادر - فيما نعتقد - إنما هو أفجر من الغاش ومن المدلس.

(انظر قانون القضاء المدني للدكتور محمود هاشم ١٥٤/١، الدكتور فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني ف١١١).

(١) الدكتور فتحي والي، الوسيط ف١٠٢، الدكتور عبدالعزيز بديوي، بحوث قواعد المرافعات ص ١٦٥.

أحوال مخاصمة القاضي، كما هو شأن الخطأ في تقدير ثبوت الوقائع، أو في تفسير القانون على نحو معين، ولو كان مخالفاً لإجماع الفقهاء، كما لا يعد خطأ جسيماً أن يجهل القاضي حكماً في القانون لا يعتبر من أسسه أو مبادئه.

٢- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له، أو امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها.

وتتحقق هذه الحالة ببقاء القاضي ممتنعاً عن ذلك بعد إعداره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض، وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.

هذا، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعدار (المادة ٤٩٤/٢ مرافعات).

٣- الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات، كما شأن هو ما نصت عليه المادة (١٧٥) مرافعات، والتي أوجبت إيداع مُسَوِّدَ الحكم المشتملة على أسبابه، موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم، وإلا كان الحكم باطلاً، ويكون المتسبب في البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه.

إجراءات دعوى المخاصمة والمحكمة المختصة بها :

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة (المادة ٤٩٥ / ١ مرافعات) معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ٩٢ ، ١٨ لسنة ١٩٩٩ وقياساً على ذلك إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض^(١) يقدم التقرير إلى كتاب محكمة النقض ، ويجب أن يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً .

(١) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٩٠ .

و ضماناً لجدية الدعوى أوجب المقنن أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها ، وأن تودع مع التقرير الأوراق المؤيدة لها ، وأن يودع عند التقرير مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة .

ثم تبلغ صورة التقرير إلى القاضي المخاصم أو عضو النيابة ، وتخير النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى^(١) ؛ لأن دعاوى المخاصمة من الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة التدخل فيها^(٢) .

ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة ، على أن تكون أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية لتبليغ القاضي المخاصم بالتقرير . (المادة ٤٩٥ مرافعات) .

ونظر دعوى المخاصمة على مرحلتين :

المرحلة الأولى : مرحلة النظر في جواز قبول المخاصمة ، أى : البحث في مدى صحة الإجراءات المطلوبة ، وتوفر أوجه المخاصمة ، ويعقد الاختصاص بها لإحدى دوائر محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة — يعينها رئيس محكمة الاستئناف — ما لم يكن القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض ، فتختص بالفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة^(٣) ، وفي كلتا الحالتين يكون نظرها في غرفة المشورة .

وتحكم المحكمة في جواز المخاصمة بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال ، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى (المادة ٢٩٦ مرافعات)

والحكم في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه ، ولا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير^(٤) .

(١) المادة ٩٢ مرافعات .

(٢) المادة ٨٩ / ٤ مرافعات .

(٣) انظر : بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ، ص ١٦٨ .

(٤) حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٢١ في جلسة ٥ / ٦ / ١٩٥٢ .

وإذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، فإنها تحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمئة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه (المادة ٤٩٩ / ١ مرافعات معدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م) .

وأما إذا حكم بجواز قبول المخاصمة ، حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام المحكمة المختصة وتبدأ مرحلة ثانية ، على أن القاضي المخاصم يصبح غير صالح لنظر الدعوى – التى كانت سبباً في المخاصمة – وذلك من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة " (١) .

المرحلة الثانية : مرحلة النظر في موضوع المخاصمة ، وفيها يزيد المقنن من ضمانات القاضي أو عضو النيابة المخاصم ، ولذلك عقد الاختصاص بها لهيئات تختلف باختلاف درجة القاضي المخاصم ، فإذا كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها فالاختصاص ينعقد لدائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف يحددها الحكم الصادر بجواز قبول المخاصمة .

وأما إذا كان المخاصم مستشاراً في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام ، فإن الاختصاص يكون لدائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم .

وإذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فإن الاختصاص يكون لدوائر المحكمة مجتمعة .

وفي الجلسة المحددة ينظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ، ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم ، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى .

وإذا قضت المحكمة برفض المخاصمة فإنها تحكم أيضاً على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمئة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع

(١) المادة ٤٩٨ مرافعات .

التعويضات إن كان لها وجه، وأما إذا قضت بصحة المخاصمة فإنها تحكم على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه .
ومع هذا إذا كان التصرف الذي تريد أن تبطله المحكمة هو حكم صادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة ، فلا تحكم المحكمة ببطلانه إلا بعد إعلان ذلك الخصم لإبداء أقواله ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم ، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم (١) .

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض (المادة ٥٠٠ مرافعات) ومن ثم إذا كان صادراً من محكمة النقض فإنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق ؛ لأن أحكامها لا تقبل الطعن وفقاً للمادة ٢٧٢ مرافعات .
حماية القاضي من الخصوم في النظام القضائي الإسلامي .

لقد أحاطت الشريعة الإسلامية القاضي بعدة ضمانات تجعله في مأمن من كيد الخصوم وعبثهم ، ومن هذه الضمانات عدم جواز مخاصمة القاضي ، وعدم مسؤوليته عن خطئه .

أ- **عدم جواز مخاصمة القاضي :** يرى فقهاء المسلمين أن القاضي المأمون في أحكامه ، العدل في أحواله البصير بقضائه لا تجوز مخاصمته ، ولا تسمع الدعوى عليه فيما يتعلق بأحكامه ؛ لأن سماعها وإجابة طلب المدعي بمخاصمة القاضي يذهب بمهابة القضاء ، ويجعل القاضي عرضة لكيد الخصوم ، ومن ثم قد يخشى بأسهم ويعمل على إرضائهم انقاء لشرفهم .

ومع هذا إذا ظهر جور القاضي وتسلفه ، واشتهر بالظلم وتظاهرت الشكاية عليه ، نظر ولي الأمر في أمره ، فإن كان حكمه على ما يجب من الصواب نفذ ،

(١) المادة ٤٩٩ مرافعات ، معدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

وإن لم يكن كذلك كأن يعتمد القاضي الخطأ أو الجور عزره ولي الأمر وعزله ،
لظهور خيانتته فيما هو أمين عليه^(١) .

وحماية للقاضي أوجب الفقهاء على ولي الأمر ألا يأخذ بمجرد قول الخصم ،
بل لابد من تقديم البينة ، فإن وجدت ، نظر في الأمر واستدعى القاضي ، وإلا
فيرى بعض الفقهاء عدم إحضار القاضي ؛ لأن في إحضاره وسؤاله مهانة له
وأعداء القاضي كثير .

ويرى بعض آخر من الفقهاء حضور القاضي حتى ولو لم تكن هناك بينة
ويسأل ، فإن اعترف بها وإلا فالقول قوله بلا يمين ؛ لأن قول القاضي مقبول ولو
بعد عزله.

ب- عدم مسئولية القاضي عن خطئه : إذا ظهر أن القاضي قد أخطأ في
حكمه ، وجب إبطال الحكم ورد الحال إلى ما كانت عليه الواقعة متى كان ذلك
ممكناً ، وأما إذا لم يمكن ذلك ، أو أمكن وترتب على ذلك ضرر وجب ضمان ذلك
من بيت مال المسلمين ولا يسأل القاضي عن هذا الضمان .
أما إذا كان القاضي قد حكم بخلاف الحق عمداً وأقر بتعده فعلية الضمان في
ماله^(٢).

الفرع الثالث

ضمانات حماية القاضي من نفسه

القاضي أولاً وأخيراً واحد من البشر ، وفيه الجانبان : الخير والشر ، ومن هنا
تهتم الأنظمة القضائية بوضع الضمانات التي تكفل حماية القاضي من جانب الشر
فيه ، فقد يطغى هذا الجانب ، ويسعى القاضي لتحقيق مصالح لنفسه مستغلاً في
ذلك وضعه الوظيفي كقاضي أو يعمل على تحقيق النفع لنفسه أو لأقاربه ، أو إيقاع
الضرر بعدوه .

(١) معين الحكام للطرابلسي ص : ٣٣ ، ٣٤ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٥٦ .

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤١٨ ، روضة القضاء للسمناني ١ / ١٥٦ ، ١٥٧ .

لذا فقد منع المقتن المصري القاضي من القيام ببعض الأعمال والتصرفات التي من شأنها أن تتعارض مع وظيفة القضاء ، وكذلك منعه من التصدي للقضاء في حالات يغلب على الظن أن القاضي قد يخرج فيها عن حياده فيها .

أولاً : منع القاضي من القيام ببعض الأعمال والتصرفات :

محافظة على سمعة القاضي ، وضماناً لنزاهته وحيدته ، وحفاظاً على استقلاله وكرامته ، وبعداً به عن الشبهات ، منع القاضي من القيام ببعض الأعمال والتصرفات التي من شأنها أن تتعارض مع واجبات وظيفة القضاء وحسن أدائها ، ولذلك :

١- لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته^(١) .

٢- يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ، ويحظر كذلك على القضاء الاشتغال بالعمل السياسي ، فلا يجوز لهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم " المادة ٧٣ من قانون السلطة القضائية " .

٣- لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً ولو بغير أجر ، حتى ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء ، إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وفي حالات مخصوصة.

لذا يستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا كان أحد أطراف النزاع من أقارب القاضي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .

كما لا يجوز ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة إذا كانت طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم ، إلا إذا وافق مجلس القضاء الأعلى ، وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي^(٢) .

(١) ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها (المادة ٧٢ من قانون السلطة القضائية) .

(٢) المادة ٦٣ من قانون السلطة القضائية .

٤- لا يجوز للقاضي أن يكون وكيلاً عن أحد الخصوم في الحضور أو المرافعة ، سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ، حتى ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها القاضي، وإلا كان العمل باطلاً.

ولكن يجوز للقاضي ذلك إذا كان أحد الخصوم يمثلته القاضي قانوناً ، كالقاصر المشمول بولاية القاضي أو وصايته ، أو كان زوجاً للقاضي أو أصلاً له أو فرعاً إلى الدرجة الثانية^(١) " مادة ٨١ مرافعات " .

٥- لا يجوز للقاضي أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه ، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر أعماله في دائرتها ، وإلا كان البيع باطلاً " المادة ٤٨١ مدني " .

٦- لا يجوز للقاضي الذي نظر بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرغة عنها أن يتقدم للمزايدة كمشتري بنفسه أو بطريق تسخير غيره ، وإلا كان البيع باطلاً .

ثانياً : اعتبار القاضي غير صالح لنظر الدعوى :

هناك مجموعة من الحالات يغلب على الظن فيها أن القاضي لن يستطيع التغلب على جانب الشر فيه — كإنسان — ومن ثم قد تضعف نفسه ويخرج عن حياده واستقلاله ، وحماية للقاضي ، وبعداً به عن الشبهات وارتفاعاً به فوق الظنون ودفعاً للحرص عنه ، اعتبره المقنن في هذه الحالات غير صالح لنظر الدعوى ، وممنوعاً من سماعها ، ولو لم يرده أحد الخصوم.

وقد أورد المقنن هذه الحالات على سبيل الحصر ، ومن ثم فلا يجوز التوسع في تفسيرها^(٢) ، ولا القياس عليها^(٣) ، لأنها خلاف الأصل ، وهذه الحالات هي :

(١) الوسيط للدكتور / فتحي والي ف ١٠٤ .

(٢) الدكتور / فتحي والي ، المرجع السابق ف ١٠٥ .

(٣) المرافعات المدنية والتجارية للدكتورين / عبد المنعم الشرقاوي ، فتحي والي ف ١٠٤

هامش "١" .

- ١- إذا كان بين القضاة الذين يجلسون في دائرة واحدة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، وكذلك إذا كان بين ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنهم وبين أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
- وحتى لا يتمكن الخصم سيء النية من تنحية قاض معين عن نظر الدعوى وذلك عن طريق توكيل محام تربطه الصلة المذكورة بذلك القاضي أثناء سير الدعوى ، نص المقتن على أنه : " لا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى " المادة ٧٥ من قانون السلطة القضائية " .
- والحكمة من النص على هذه الحالة المحافظة على حيده القاضي وعدم تأثره بأراء قريبه أو صهره .

- ٢- إذا كان القاضي قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ذلك أن القرابة أو المصاهرة يغلب على الظن فيها أنها تحمل القاضي على الميل مع أحد الخصوم ، وتوافر هذه الحالة حتى بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة ، ويستوي أن يكون القاضي قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو لهما معاً^(١) .

- ٣- إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته (المادة ١٤٦ / ٢) ، ويجب أن تكون الخصومة قائمة وقت رفع الدعوى^(٢) ، أما إذا كانت هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد قيام الدعوى أمام القاضي فإنها لا تكون سبباً لعدم الصلاحية ، حتى لا يتمكن الخصوم من منع القاضي من نظر الدعوى بإثارة خصومة معه أو مع زوجته ، ومع ذلك فالخصومة اللاحقة سبب من أسباب رد

(١) الدكتور / رمزي سيف في الوسيط ف ٤٩ ، الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ١٠٥ .

(٢) الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٢٠٠٠ ق جلسة ٢٦ / ٣ / ١٩٥١ .

القاضي وفقاً للمادة " ١٤٨ " مرافعات ، وكذلك إذا كانت الخصومة قد انتهت قبل قيام الدعوى أمام القاضي ، فلا تعتبر سبباً لعدم الصلاحية ، وإن كان يمكن أن تكون سبباً من أسباب رد القاضي^(١) كما سيأتي بيانه .

٤- إذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية ، أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له ، ذلك أن الوكيل يتصف بالحرص على مصلحة موكله ، والوصي أو القيم يتصف بالعطف على المشمول بالصيانة أو القوامة ، وهذه الصفات لا تتفق وما ينبغي أن يكون عليه القاضي من عدم التحيز والحيدة المطلقة ، والوكالة أو الوصاية أو القوامة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها هي التي تكون قائمة وقت نظر تلك الدعوى ، أما إذا كانت قد انقضت قبل هذا الوقت ، فإنها لا تمنع القاضي من نظر الدعوى^(٢) .

والمقصود بعبارة " مظنونة وراثته له " أن يكون القاضي يمت لأحد الخصوم بسبب من أسباب الإرث ولو وجد من يحجبه عنه أو يحرمه منه ، فقد يزول سبب الحجب أو الحرمان^(٣) ، وذلك لأن للقاضي المظنونة وراثته لشخص مصلحة في تضخيم ثروة هذا الشخص ، أو في استرضائه حتى لا يتعرض للحرمان من الإرث .

٥- إذا كانت للقاضي صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بولي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها ، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى وذلك لأن قرابة القاضي أو مصاهرته بنائب أحد الخصوم أو ممثل الشركة

(١) المرافعات المدنية والتجارية للدكتورين عبد المنعم الشرفاوي، فتحي والي ف ١٠٤ هامش "٢"

(٢) الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٣٢ ق ، جلسة ٢٧ / ١٠ / ١٩٦٦ س ١٧ ص ١٥٩٢ .

(٣) الوسيط للدكتور رمزي سيف ، ف : ٤٩ .

المختصة ، مدعاة لمظنة قد تقوم في ذهن الخصم الآخر في أن تطمئن نفسه إلى الحكم الذي يصدر في الدعوى^(١) .

٦- إذا كان للقاضي أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة ، وذلك لأن وجود مصلحة للقاضي أو لواحد من المذكورين من شأنه أن يخل بحياد القاضي ، ويجب أن تكون المصلحة قائمة بالفعل أثناء الدعوى ، ولا عبرة بوقت نشوئها قبل رفع الدعوى أم بعده^(٢) .

وهذه الحالة تشمل ما قد تقصر عنه سائر الحالات السابقة ، فقد لا تكون الدعوى المطروحة أمام القاضي مقامة من أو على قريبه أو زوجه أو صهره ، ومع ذلك توجد للقاضي أو لواحد من هؤلاء مصلحة محققة من ورائها ، كأن تكون الدعوى مقامة من أحد المساهمين في شركة يساهم فيها القاضي أو واحد من هؤلاء ، ويكون من شأن موضوع الدعوى أن يحقق لأحد من هؤلاء مصلحة وإن كانت غير ظاهرة^(٣) .

٧- إذا كان القاضي قد أفتى أو ترفع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها رأياً ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " المادة ١٤٦ / ٥ مرافعات " .

وذلك لأن القاضي الذي سبق له الإفتاء أو الترفع أو الكتابة في دعوى معينة أو سبق له نظرها بأي وجه من الوجوه ، أو أدى شهادة فيها يكون قد كون رأيه وعقيدته عن الدعوى قبل نظرها ، ومن ثم فقد يحيله ذلك على التمسك برأيه حتى ولو خالف العدالة .

ولا يعتبر موجباً لعدم الصلاحية أن يكون القاضي قد أبدى رأيه في موضوع قانوني يتفق وموضوع الدعوى ، وذلك في مؤلف أو بحث علمي

(١) قواعد المرافعات لمحمد العشماوي والدكتور / عبد الوهاب العشماوي ف ١٦٤ .

(٢) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٥٥ .

(٣) قواعد المرافعات لمحمد العشماوي ، والدكتور / عبد الوهاب العشماوي ف ١١٥ .

مجرد ولو أثناء توليه القضاء ، أو كان قد فصل في عدة دعاوى مشابهة أو أصدر أحكاماً فيها متخذاً اتجاهها قانونياً معيناً .

والمقصود بسبق القاضي لنظر الدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً الذي يفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى ذاتها ، أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً وصحيحاً.

هذا ويجب أن يكون الإفتاء أو الترافع أو الكتابة أو النظر أو أداء الشهادة في نفس الدعوى ، أما إذا كان ذلك في دعوى أخرى فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية وكذلك إذا وجد اختلاف في أي عنصر من عناصر القضية^(١) وغني عن البيان أن عدم الصلاحية ينتفي إذا نص الشارع على أن طريقاً معيناً من طرق الطعن يقدم إلى نفس القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه^(٢) .

(١) نظر القاضي في دعوى النفقة لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة ، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، وبالتالي لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية (الطعن رقم ٤ لسنة ٤٠ أحوال شخصية ، جلسة ١٩٧٢/٥/٢٤ س ٢٣ ص ١٠٠٣) .

واشتراك القاضي في إصدار الحكم ببطلان التنفيذ لا يمنعه من نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ ، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، وبالتالي لا يكون سبباً لعدم الصلاحية (الطعن رقم ٥٠ لسنة ٣٩ ق جلسة ١٩٧٦/٦/١ س ٢٧ ص ١٢٤٧ ")

ولا يبطل الحكم أن يكون أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي أصدرته قد اشترك في نظر استئناف رفع من محكوم عليهم آخرين في نفس الدعوى ؛ لأن الحكم الذي صدر في ذلك الاستئناف ليس من شأنه أن يقيده بشيء وهو يفصل في الاستئناف الأخير " الطعن رقم ٨ لسنة ١١ ق جلسة ١٩٤١/٤/٢٤ " .

(٢) مثل الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي والطعن بالتماس إعادة النظر ، حيث نص القانون على أن ترفع المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وانظر المادة ٢٤٣ مرافعات=

- ٨- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد ، أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحية القاضي للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتتحي عن نظرها (المادة ١٦٥ مرافعات) وذلك لأن وجود خصومة بين القاضي والخصم ، قد يوغر قلب القاضي ويخرجه عن حياده واستقلاله.
- ٩- إذا رفعت على القاضي دعوى المخاصمة وحكم بجواز قبول المخاصمة فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم (المادة ٤٩٨ مرافعات) .

وينبغي الإشارة إلى أن أحوال عدم الصلاحية تتعلق بالنظام العام ، وقد أوجب المقنن امتناع القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يطلب أحد الخصوم رده ، ومن ثم يجوز التمسك بأسباب عدم الصلاحية أو بأحدها لأول مرة أمام محكمة النقض بجميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجب^(١) .

وينبغي على تعلق أحوال عدم الصلاحية بالنظام العام أن يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .

وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى (المادة ١٤٧ مرافعات) .

ثالثاً : رد القاضي :

هناك حالات يحتمل فيها أن القاضي قد يخرج فيها عن حياده ، ومع أن هذا الاحتمال ضعيف إلا أنه قائم وحماية للقاضي ، وتنزيهاً له عن مجرد الشبهات وارتفاعاً بالأحكام عن مواضع الشك والريبة ، أورد المقنن مجموعة من الأسباب ، وأوجب على القاضي أن يتتحي عن نظر الدعوى متى توافر سبب من هذه الأسباب ، فإن لم يفعل كان لكل خصم له مصلحة أن يطلب رد القاضي عن نظر

= حيث نصت علي أن : " يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم .. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم " .

(١) الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٢٤ ق ، جلسة ١٤/٣/١٩٥٥ الطعن رقم ١٣٧١ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٧٩/٦/٢٠ .

الدعوى ، فإن لم ينتج القاضي ، ولم يطلب رده من قبل الخصوم أو أحدهم فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون صحيحاً ، ولا يجوز الطعن فيه لهذا السبب^(١) .
ومن هنا يتضح الفرق بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد في أن أسباب عدم الصلاحية يترتب على وجود واحد منها أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ، ممنوعاً من سماعها ، ولو لم يرده أحد الخصوم كما يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في هذه الحالة ، ولو تم باتفاق الخصوم حتى ولو كان الحكم صادراً من محكمة النقض — كما سبق القول — أما أسباب الرد الآتي ذكرها ، فلا يترتب على مجرد وجود واحد منها منع القاضي من سماع الدعوى ، إلا إذا طلب أحد الخصوم رد القاضي عن الحكم وإذا لم يطلب ذلك فإن القاضي يكون صالحاً لنظر الدعوى ، ويكون حكمه صحيحاً^(٢) .

وقد أورد القانون أسباب الرد في المادة "١٤٨" مرافعات على وجه الحصر ،

ولا يجوز القياس عليها^(٣) وهي :

١- إذا كان للقاضي أو زوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها " المادة ١٤٨ / ١ مرافعات و" المقصود بالتماثل بين الدعويين أن يستند الحكم فيهما إلى نفس المبادئ والقواعد القانونية وعلة الرد في هذه الحالة أن القاضي قد يميل إلى الحكم في الاتجاه الذي يحقق مصلحته أو مصلحة زوجته ، وذلك بإرساء سابقة قضائية يعتمد عليها في دعواه^(٤) .

(١) الوسيط للدكتور/فتحي والي ف١٠٦ ، قانون المرافعات د/محمد عبد الخالق عمر ٢٦١/١ .

(٢) الوسيط للدكتور / رمزي سيف ف ٤٨ .

(٣) الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق على قانون المرافعات ، المادة ١٤٨ تعليق "٢" .

(٤) ولذلك يشترط بعض الشراح أن تكون دعوى القاضي أو زوجته لا تزال قائمة أمام القضاء أما إذا كانت قد انتهت فلا يعد ذلك سبباً للرد ، الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٦٢ .

٢- إذا حدث للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه (المادة ١٤٨ / ١ مرافعات) .
وعلة الرد هنا أن خصومة القاضي أو زوجته لخصم أو لزوجته قد تؤثر على القاضي وتخرجه عن حياده .

ويشترط لتوافر هذه الحالة شرطان ، الأول : أن تكون الخصومة قد نشأت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي^(١) . والثاني : ألا يكون المقصود من رفع الخصومة بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه ، حتى لا يتخذ الخصوم من هذا السبب وسيلة للمشاكسة^(٢) .

٣- إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو لأحد أقارب القاضي أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده (المادة ١٤٨ / ٢ مرافعات) .
وعلة الرد هنا أن الخصومة بين أحد المذكورين وأحد الخصوم أو زوجته قد تؤثر على حياد القاضي .

ويستوي أن تكون الخصومة مقامة قبل رفع الدعوى المطروحة على القاضي أو نشأت بعد رفعها^(٣) ، غاية الأمر أنه إذا كانت الخصومة قد أقيمت بعد رفع الدعوى المطروحة على القاضي ، فيشترط ألا تكون قد أقيمت بقصد رد القاضي .

(١) وأما إذا كانت الخصومة قد نشأت قبل قيام الدعوى المطروحة على القاضي فإن ذلك يعتبر سبباً لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى المطروحة عليه كما قلنا .

(٢) التعليق على قانون المرافعات للدكتور / أحمد أبو الوفا ، المادة ١٤٨ تعليق " ٣ " .

(٣) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ١٠٦ .

٤- إذا كان أحد الخصوم خادماً للقاضي أو كان القاضي اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها (المادة ١٤٨ / ٣ مرافعات) .

وكلمة الخادم تشمل (١) : المربية والطباخ والسائق والبواب والكاتب والسكرتير والمحصل وناظر الزراعة ، ولكن لا تشمل الطبيب أو المهندس أو المقاول أو الحلاق أو المكوجي ، ويقصد باعتبار مؤاكلة أحد الخصوم : تكرار دعوة كل منهما صاحبه للطعام ، وإجابة كل منهما الدعوة عدة مرات ، أما الاجتماع العارض على مائدة غيرهما فلا تعد مؤاكلة ، ومن ثم فلا تعد سبباً للرد . واعتياد المساكنة أن يسكن كل من القاضي والخصم معاً في مسكن واحد على سبيل الاعتياد ، فلا يكفي أن ينزل ليلة في فندق ولو في حجرة واحدة أو يسكن معاً في مبنى واحد ، وكل منهما في شقة مستقلة (٢) .

وقبول الهدية قبيل رفع الدعوى أو بعده يعتبر سبباً للرد ولو لم توافر فيه جريمة الارتشاء ، ويجوز قبول الرد إذا قدمت الهدية لشخص من أقارب القاضي المقيمين معه (٣) .

ولكن رفض الهدية قبيل رفع الدعوى أو بعده لا يعتبر سبباً للرد (٤) ، وعلة الرد في هذه الحالات أنها مظنة وجود ود عميق وصداقة بين القاضي وأحد الخصوم ، مما قد يؤثر على حياد القاضي .

٥ - إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل (المادة ١٤٨ / ٤ مرافعات) .

(١) انظر التعليق على قانون المرافعات للدكتور / أحمد أبو الوفا ، المادة ١٤٨ تعليق " ٥ " .

(٢) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ١٠٦ .

(٣) أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي في مبادئ المرافعات ص ٢٢٧ هامش (١) .

(٤) الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق على قانون المرافعات ، المادة ١٤٨ تعليق (٨) .

لا يكفي لتحقيق هذا السبب مجرد وجود عداوة أو مودة ، بل يجب أن تكون العداوة أو المودة لها تأثير على القاضي ، ويصعب عليه الحكم بغير ميل^(١) . ولكن لا يشترط في العداوة أن تكون شديدة تصل إلى حد الخصومة أمام القضاء أو أن تكون المودة وثيقة تصل إلى حد المؤاكلة أو المساكنة أو قبول الهدايا .

وهذا السبب سبب عام يشمل صوراً كثيرة تفيد العداوة أو المودة ، ولكن القضاء يتشدد في القول بوجودها . ويشترط أن تكون العداوة أو المودة سابقة على رفع الدعوى ، ولا يعتد بهما إذا فتعلهما الخصم افتعالاً بعد رفع الدعوى ليصل إلى رد القاضي عن هذا الطريق^(٢) .

إجراءات التنحي الوجوبي :

إذا توافر سبب من أسباب الرد السابق ذكرها ، وجب على القاضي أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال^(٣) ، بسبب الرد القائم به ، وذلك للإذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة " المادة ١٤٩ مرافعات " والهدف من إخبار المحكمة في غرفة المشورة — وهي ذات الدائرة التي يرأسها القاضي أو يشترك في عضويتها ، منعقدة في جلسة غير علنية — مجرد التداول في جدية سبب التنحي ، والتأكد من توافره ، ومن ثم يؤذن له بالتنحي^(٤) .

(١) وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضي نفسه ، انظر الطعن رقم ٩٠ لسنة ٣٣ ق ، جلسة ٣ / ١٢ / ١٩٦٦ س ١٧ ص ١٩٥٥ .

(٢) قانون المرافعات دكتور/ محمد عبد الخالق عمر ١ / ٢٦٥، الوسيط، د/ رمزي سيف ٥٠.

(٣) تخبر المحكمة في غرفة المشورة إذا كان مستشاراً ، ويخبر رئيس المحكمة الابتدائية إذا كان قاضياً . الدكتور / عبد المنعم الشرقاوي في المرافعات المدنية والتجارية ف ١١٤ ، الدكتور أمينة النمر في قوانين المرافعات ف ٧٥ .

(٤) قانون القضاء المدني للدكتور / محمود هاشم ١ / ١٤٤ .

إجراءات الرد :

إذا توافر سبب من أسباب رد القضية السابق ذكرها ، وجب على القاضي التثني من تلقاء نفسه ، وإذا لم يقم القاضي بهذا الواجب من نفسه ، فالأمر متروك للخصوم ، ولكل واحد منهم يخشي من احتمال انحياز القاضي لقيام سبب من أسباب الرد أن يطلب رد القاضي ، وقد أورد المقنن إجراءات رد القضية بصورة مفصلة في المواد من ١٥١ - ١٦٤ مرافعات ، وذلك على الوجه الآتي :

ميعاد تقديم الطلب :

يجب على طالب الرد أن يقدم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه^(١) ، على اعتبار أن الخصم قد قبل حكمه وتنازل عن رده ؛ لأن رد القاضي شرع لمصلحة طالب الرد ، فله أن يباشره أو يتنازل عنه^(٢) .

وإذا كان الرد في حق قاض ندبته المحكمة للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق كسماع الشهود أو للمعاينة ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد ، وإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلامه بالقرار " المادة ١٥١ / ٢ مرافعات " .

ويجوز تقديم طلب الرد بعد هذه المواعيد ، إذا حدثت أسبابه بعدها أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بأسبابه إلا بعد مضي تلك المواعيد^(٣) .

ولكن لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ولا يقبل ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى الأصلية المنصوص عليه في المادة ١٦٢ من قانون المرافعات^(٤) .

(١) المادة ١٥١ / ١ مرافعات .

(٢) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ص ٢٢٨ .

(٣) المادة ١٥٢ / ١ مرافعات .

(٤) المادة ١٥٢ مرافعات معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

وبذلك سد المقنن الطريق على العابثين بهذا الحق ويعمدون إلى رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها فيطيلون أمد التقاضي ويعرقلون صدور الحكم بعد أن يكون النزاع قد قطع فيه شوطاً طويلاً ، وقد كان ذلك ممكناً قبل التعديل (١) .

طريقة تقديم الطلب :

يقدم طلب الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده (٢) ، يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض في الرد بتوكيل خاص (٣) ، ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب الرد ، وأن تكون من الأسباب التي نص عليها القانون على وجه الحصر ، ويجب أن يتضمن التقرير تعيين طالب الرد ، وتعيين القاضي المطلوب رده (٤) ، كما يجب أن يرفق بالتقرير ما يوجد من الأوراق المؤيدة له (٥) .

و ضمناً لجدية الطلب يوجب القانون على طالب الرد أن يودع عند التقرير ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة (٦) .

وإذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم ، جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

(٢) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٤٣٣ .

(٣) وليس لمحامي الخصم أن ينوب عنه في طلب رد القاضي إلا بتوكيل خاص . انظر الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٢٠ ق ، جلسة ٢٦ / ٣ / ١٩٥١ .

(٤) المرجع السابق وذات الفقرة .

(٥) المادة ١٥٣ / ١ ، ٢ مرافعات .

(٦) المادة ١٥٣ / ٢ معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ .

ويجب على طالب الرد أن يقيد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي ، وإلا سقط الحق فيه (المادة ١٥٤ مرافعات) ، ومن ثم فلا يكفي أن ييادي الخصم رغبته في رد القاضي ويثبت ذلك في محضر الجلسة^(١) ، بل لابد من تأييد الطلب في قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي في الميعاد المذكور .

أثر تقديم الطلب :

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في الطلب^(٢) وقطعاً لأساليب التلاعب بحق رد القضاة أجاز المقنن لرئيس المحكمة أن يندب قاضياً ليجلس بدلاً من القاضي المطلوب رده ، وأن يستمر في نظر الدعوى الأصلية ، كما يأخذ طلب الرد طريقه للفصل فيه دون أن يؤثر على استمرار نظر القضية الأصلية باعتبار القاضي المطلوب رده قد أصبح بعيداً عنها . وبذلك لا يؤثر طلب الرد على سير الدعوى ، ومن ثم لا يتخذ وسيلة للتعطيل وإطالة أمد التقاضي .

وإذا طلب أحد الخصوم رد أحد مستشاري الدائرة التي تنتظر طلب الرد ، فلا يقبل هذا الطلب ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد^(٣) . وإذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه فلا يترتب علي تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنتظر طلب الرد أن تأمر بناءً على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسرى في هذه الحالة حكم المادة ١٦٢ مرافعات^(٤) .

(١) راجع الطعن رقم ١٨٨٧ لسنة ٢٠ ق جلسة ٢٦ / ٣ / ١٩٥١ .

(٢) المادة ١٦٢ مرافعات .

(٣) المادة ١٥٧ / ٨ مرافعات .

(٤) المادة ١٦٢ مكرر من قانون المرافعات .

إجابة القاضي على وقائع الرد وأسبابه :

أوجب المقتن في المادة ١٥٥ مرافعات على قلم كتاب المحكمة أن يرفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة ، مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها ، ويطلع الرئيس والقاضي المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة .

وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه .

وإذا أجاب القاضي واعترف بقيام سبب من أسباب الرد ، أو لم يجب في الميعاد المحدد ، وكانت الأسباب المذكورة في التقرير تصلح قانوناً للرد ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بفتحية القاضي^(١) .

وإذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى ، أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها ، وتتلقى جوابه عنها ، ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع في شأنه الأحكام المقررة " المادة ١٥٨ مرافعات " .

الاختصاص بطلب الرد :

يختلف الاختصاص بنظر طلب رد القضاة بحسب المحكمة التي يتبعها القاضي وعلى ذلك فإذا كان القاضي من قضاة المحكمة الجزئية أو الابتدائية فيختص بنظر طلب الرد إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده

وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف

غير الدائرة التي يكون المستشار المطلوب رده عضواً فيها^(٢) .

(١) المادة ١٥٦ مرافعات .

(٢) المادة ١٥٣ مرافعات .

"ولا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم ، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية"(١).

نظر طلب الرد والحكم فيه :

إذا أجاب القاضي في الميعاد وأنكر أسباب الرد المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة وكانت الأسباب لا تصلح قانوناً للرد ، فإن كان القاضي المطلوب رده أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد(٢) .

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد — وهو رئيس محكمة الاستئناف إن كان القاضي المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية أو مستشاراً بمحكمة الاستئناف أو رئيس محكمة النقض إذا كان المطلوب رده مستشاراً بمحكمة النقض — يتولى هذا الرئيس تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها .

ويقوم قلم كتاب المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد جديدة .

وفي حالة تقديم طلبات رد جديدة قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق فعلى رئيس المحكمة أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد وذلك دون أن تنتظر المحكمة إجابة من القاضي عن وقائع الرد وأسبابه(٣) .

(١) المادة ١٦٤ مرافعات .

(٢) أربعة أيام التالية لاطلاع القاضي على تقرير الرد ، وهذا ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أى بطلان . الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٧١ .

(٣) ١٥٨ مكرر من قانون المرافعات .

وتقوم الدائرة التي تنتظر طلب الرد بتحقيقه في غرفة المشورة وتحكم فيه في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ التقرير ، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد وأقوال الخصوم الآخرين – إن كانوا يريدون إبداء طلبات رد خاصة بهم – كما تسمع ملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى .

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين له^(١) ، ويتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، وذلك على أساس أن خصومة الرد هي خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها وإذا قضت المحكمة برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه فإنها تحكم من تلقاء نفسها^(٢) على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربع مائة جنيه ، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة . وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على وجود عداوة أو مودة بين أحد الخصوم وبين القاضي يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ، فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة آلاف جنيه، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضايا المطلوب ردهم .

ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته^(٣) .

(١) لإحاطة القاضي بضمانات تكفل له الاحترام ، خاصة وأنه في كثير من الحالات يكون توجيه الاستجواب مقصوداً به مجرد الرغبة في إحراج القاضي وتجريحه " المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات .

(٢) الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق على المادة ١٥٩ تعليق " ٢ " .

(٣) المادة ١٥٩ مرافعات معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ ، والقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

وينبغي على الحكم برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه ، أن تعود الخصومة الأصلية – التي وقفت عند تقديم طلب الرد – إلى السريان أمام القاضي الذي طلب رده^(١) ، إلا إذا كان القاضي قد رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص ، فإن هذا يزيل صلاحية هذا القاضي للحكم في الدعوى ويتعين عليه أن يتحى عن نظرها^(٢) كما سبق القول .

وأما إذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد ، فإن القاضي يفقد صلاحيته لنظر الدعوى ، ويتحمل طالب الرد مصاريفه ولا يتحملها القاضي ؛ لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في طلب الرد^(٣) .

الطعن في الحكم :

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية^(٤) ، ذلك أن خصومة الرد هي خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها . وعلى هذا فلا يجوز استئناف الحكم إذا كان صادراً من محكمة لا يجوز الطعن في أحكامها بطريق الاستئناف كمحكمة الاستئناف أو محكمة النقض^(٥) .

(١) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٤٣٤ .

(٢) المادة ١٦٥ مرافعات .

(٣) انظر : الطعن رقم ٩٦٧ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ٥ / ١ / ١٩٧٨ س ٢٩ ص ٩٦ ، ومن هذا الرأي الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٧٢ ، الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق على المادة ١٦٠ تعليق "٢" س ٢٣٣ ، وانظر عكس هذا للدكتور فتحي والي ، حيث يرى أن يلزم القاضي بالمصاريف وفقاً للقواعد العامة ؛ لأن الأمر يتعلق بخصومة قضائية حقيقية . انظر : الوسيط ف ٤٣٤ ، وهامش "١" س ٨٨٧ ومن الرأي الأخير الدكتور رمزي سيف في الوسيط ف ٥٥ والدكتور / محمود هاشم في قانون القضاء المدني ١ / ١٤٨ .

(٤) المادة ١٥٧ مرافعات .

(٥) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ص : ٢٣٢ ، وانظر الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٣٤ ق جلسة ٦ / ٢ / ١٩٦٩ س ٢٠ ص : ٢٦١ .

والحكم في طلب الرد — على كل حال — لا يقبل الطعن إلا من طالب الرد ، ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن يطعن في الحكم بالاستئناف ؛ لأنه ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في طلب الرد ، ولذلك لا يجوز استجوابه ولا توجيه اليمين إليه^(١) ، ولا يحكم عليه بالمصاريف^(٢) ، وقد منحه القانون ضماناً أخرى ، فأجاز له رفع دعوى تعويض على طالب الرد .

وكذلك لا يجوز لخصم طالب الرد في الدعوى الأصلية أن يطعن في الحكم الصادر في طلب الرد ؛ لأن الأمر لا يتعلق بنزاع متفرع عن الدعوى الأصلية حتى يكون له الحق في الطعن في الحكم .

التنازل عن دعوى الرد :

ثار خلاف في الفقه والقضاء حول حق طالب الرد في التنازل عن دعواه ، فذهب قول^(٣) إلى أن دعوى الرد من الدعاوى التي لا يملك رافعها حق التنازل عنها فهي شبيهة بالدعوى العمومية إذا رفعت تعلق بها حق القضاء وحق القاضي المطلوب رده ، وعلى ذلك يتعين السير في إجراءاتها حتى يفصل فيها ، ولو قرر المدعى تنازله عنها ، ولو قبل القاضي المطلوب رده التنازل ؛ لأنه ليس خصماً في الدعوى ، وذلك لأن المصلحة العامة تقتضي أن يحكم في موضوعها صيانة للقضاء من الريب والشبهات .

-
- (١) بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ، ص ١٨٣ .
- (٢) انظر غير هذا : الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٤٣٤ ، وهامش " ١ " ص ٨٨٧ الدكتور / أمينة النمر في الوجيز في قوانين المرافعات ف ٧٤ ، الدكتور / محمود هاشم في قانون القضاء المدني ١ / ٤٨ ، والدكتور / رمزي سيف في الوسيط ف ٥٥ .
- (٣) الدكتور / عبد المنعم الشرقاوي في المرافعات المدنية والتجارية ف " ١١ " ، الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق . انظر : تعليق " ٣ " على المادة ١٥٩ ، وقد استند هذا القول إلى حكيمين أولهما من محكمة الزقازيق الابتدائية في ١٢ يونية سنة ١٩٤٩ منشور بمجلة القضاء السنة ٣١ ص ٦٠١ ، وثانيهما حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية عدد ٢ ص ١٠٣ ، وانظر : حكم محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم ١٤٨ سنة ١٤ ق بتاريخ ١٠/٦/١٩٦٢ ، ذكره الدكتور/محمد كمال أبو الخير في قانون المرافعات ص ٥٠ .

وذهب قول آخر إلى أن للخصم أن يتنازل عن دعواه ؛ لأن رد القاضي حق مقرر للخصم وشرع لمصلحته ، له أن يتمسك به أو يتنازل عنه ، وليس للمحاكم أن تمنع قاضياً من الحكم لقيام سبب من أسباب الرد ، ما لم يكن الخصم صاحب الحق في الرد قد طلبه في ميعاده المناسب له^(١) .

وقد حسم هذا الخلاف بصدور القانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات ، وبمقتضاه أضيفت فقرة جديدة للمادة ١٥٩ يفهم منها جواز تنازل الخصم عن دعوى الرد حيث قالت : " وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " ، كما أضاف القانون المذكور المادة ١٦٢ مكرر تفيد نفس المعنى السابق ، حيث قالت : " إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية ... " .

وبعد تعديل المادة ١٥٩ مرافعات بالقانون ٢٢ لسنة ١٩٩٢ نص المقتنن صراحة على حق طالب الرد في التنازل عن طلبه ، بل وأعفاه من الغرامة إذ تنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى .

وهذه النصوص تؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد ، شأنه في ذلك شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة ١٤٢ / ١ مرافعات ، من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ؛ لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة^(٢) .

(١) من هذا الرأي الدكتور/رمزي سيف في الوسيط ف ٥٤ ، الدكتور / محمود هاشم في قانون القضاء المدني ١٤٦/١ ، الدكتور / محمد كمال أبو الخير في قانون المرافعات ص : ٥٠٢ ، وانظر : حكم محكمة المنصورة الابتدائية في الدعوى رقم ٤٣٦ لسنة ١٩٥٥ ، كلي بتاريخ ١٩٥٥/٩/٢١ ، وحكمها في الدعوى رقم ٦٦٩ ، لسنة ١٩٥٧ بتاريخ ١٩٥٧/١٠/١٩ ذكرهما الدكتور / محمد كمال أبو الخير في المرجع المذكور ، ص ٥٠١ ، ٥٠٣ .

(٢) انظر : الطعن رقم ٩٦٧ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ١٩٧٨/١/٥ ، س ٢٩ ص ١٩٦٧ .

حماية القاضي من نفسه في النظام القضائي الإسلامي :

حماية القاضي من نوازع الشر فيه — كإنسان ، ومحافظة عليه حتى يكون في المكان اللائق به ، منع من بعض التصرفات التي قد تفتح أبواب الشر عليه .
ومن التصرفات التي يمنع منها القاضي : قبول الهدية من الشخص الذي لم يكن يهديه قبل القضاء ، لأن حدوث الإهداء بعد القضاء دليل على استمالته ، حتى يصل المهدي إلى ميل قلب القاضي معه ضد خصمه ، ومن ثم فلا يجوز قبولها كالرشوة^(١) .

ويمتنع القاضي عن البيع والشراء وما في معناهما بنفسه^(٢) ؛ لأن القاضي يعرف فيحابي فيكون في معنى الهدية أو الرشوة .
كما يمنع القاضي من طلب الحوائج من الناس ، كقضاء مصلحة له واستعارة سيارة أو ما إلى ذلك .

ويمنع القاضي من زيارات الناس إلا الذي ولاه ، لأن من دونه رعية^(٣) .
ويمتنع على القاضي أن ينظر دعوى لنفسه أو لزوجه أو أقاربه ولكل من لا تقبل له شهادة على القول الراجح ، وتتنظر دعواه أو دعوى واحد من هؤلاء أمام قاض آخر^(٤) .

كما يمتنع على القاضي أن ينظر دعوى لعدو له ؛ لأن شهادة العدو على عدوه غير مقبولة ، فكذا القضاء ، ويجب عليه أن ينيب غيره إن كان مأذوناً له في الاستتابة^(٥) .

(١) بخلاف ما كان يهديه قبل القضاء ، حيث يقبل القاضي هديته ؛ لأن وجودها قبل القضاء دليل على أنها ليست من أجله

(٢) لما روى أن عمر بن الخطاب كتب إلى القاضي شريح " لا تسار ولا تضار ولا تبع ولا تشتتر في مجلس القضاء .

(٣) معين الحكام للطرابلسي ص : ١٥ ، ١٦ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٦٨ ، ٦٩ .

(٤) الفواكه البدرية لابن العربي ص ١٣٧ ، الأحكام السلطانية للمواردي ص : ٧٥ ، ٧٦ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٩٣ ، ٩٤ .

(٥) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥٧ ، الأحكام السلطانية للمواردي ص ٨٦ .

المبحث الثاني أعضاء النيابة العامة

النص الدستوري :

تنص المادة " ١٨٩ " من الدستور المصري الحالي ، الصادر في ٢٠١٤م علي أن :

" النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله ."

وهذا ما أكدت عليه المادة " ١١٩ " من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م ؛ حيث نصت علي أن: " يُعَيِّنُ النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، ذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله . ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما علي الأقل وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى "

(المادة ١١٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م ، مستبدلة بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩م، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الجريدة الرسمية ، العدد ٢٥ مكرر " ب " في ٢٦ يونية سنة ٢٠١٩م).

وبناء على هذا :

فإن سلطة التصدي لفصل الخصومات وإصدار الأحكام منوطة بالقضاة ، ويعاونهم في النهوض بهذه المهمة مجموعة من الأعوان، يأتي في مقدمتهم أعضاء النيابة العامة، ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم المختلفة — عدا محكمة النقض — النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها . وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين ، وتكون له جميع اختصاصاته^(١) .

ورجال النيابة لا يتبعون السلطة القضائية ، ولكن يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وهم جميعاً تابعون لوزير العدل ، المادة ٢٦ من قانون السلطة القضائية وأما محكمة النقض فتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لديها نيابة عامة مستقلة ، ولها بناء على طلب المحكمة حضور مداوالات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثليها صوت معدود في المداوالات .

هذا، وتؤلف نيابة النقض من مدير يتم اختياره من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل ، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل .

ويكون نقيب مدير نيابة النقض وأعضائها لمدة سنة قابلة للتجديد ، وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى^(٢) . ويكون لدى كل محكمة من محاكم الاستئناف محام عام له جميع حقوق النائب العام واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين ، ولكنه يعمل تحت إشرافه^(٣) .

(١) المادة ٢٣ / ٢٠١ من قانون السلطة القضائية ، معدلة بالقانون ١٣٨ لسنة ١٩٨١ .

(٢) راجع المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٤ .

(٣) أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جمعي في مبادئ المرافعات ص ٢٤٦ وانظر المادة ٢٥ من قانون السلطة القضائية .

صلة النيابة بالقضاء :

لا يعتبر رجال النيابة من رجال القضاء ، وإنما هم من رجال السلطة التنفيذية يمثلونها أمام المحاكم ، ومع هذا فالنيابة تعتبر من الجسم القضائي ، ورجالها من رجال القانون يعملون على تنفيذه^(١) ، ومن هنا جاءت تسميتهم برجال القضاء الواقف ، وسموه كذلك لأنهم يؤدون أعمالهم وهم وقوف وتمييزاً لهم عن القضاة فهم رجال القضاء الجالس ، لأنهم يؤدون أعمالهم وهم جلوس ، ولذلك يحرص المقنن المصري دائماً على أن يجمع بين رجال النيابة ورجال القضاء في أمور كثيرة ، منها وجوب توافر شروط شغل وظيفة القاضي فيمن يعين عضواً بالنيابة ، وتعيين أعضاء النيابة في وظائف القضاء ، ونقل رجال القضاء إلى وظائف النيابة ، وسريان أحكام عدم الصلاحية ، والرد والمخاصمة ، وألا يكون لعضو النيابة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية بالقاضي الذي ينظر الدعوى^(٢) .

ولكن نظراً لطبيعة عملهم وارتباطهم بالسلطة التنفيذية فهم لا يتمتعون بكل مزايا القضاة وضمائنهم ، ومن ثم فضمائنات ترقية رجال النيابة ونقلهم وتأديبهم دون الضمائنات المقررة للقضاة^(٣) ، وهم تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل^(٤) .

والنيابة مستقلة عن المحاكم استقلالاً يكاد يكون تاماً ، فلا تملك المحاكم أن تصدر للنيابة أمراً (مع مراعاة حكم المادة ٩٠ مرافعات)^(٥) ولا أن توجه لوماً

(١) الدكتور / مصطفى كوة في قانون المرافعات الليبي ص ١٧٣ ، ١٧٤ .

(٢) قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر ف ٧٩ .

(٣) قواعد المرافعات لمحمد العشماوي والدكتور عبد الوهاب العشماوي ف ١٣٨ .

(٤) المادة ٢٦ من قانون السلطة القضائية .

(٥) حيث تجيز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، وفي هذه الحالة يكون تدخل النيابة وجوبياً .

للنيابة أو لوحد من أعضائها ، وليس لرؤساء المحاكم إشراف إداري على أقلام النيابة بحاكماتهم ، ومن الجهة الأخرى فليس لأعضاء النيابة أن يتدخلوا في أعمال القضاة ، ولا أن يحضروا مداولاتهم (مع مراعاة حكم المادة ٢٤ / ١ معدلة بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٨١) (١) .

وللنيابة العامة وظيفة أساسية تتعلق بالدعوى الجنائية ، فلها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون خلاف ذلك (٢) ، ولها وظيفة أخرى مدنية ، حيث أجاز لها أو أوجب عليها أن تتدخل في بعض الدعوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتهمنا وظيفتها الأخيرة .

وظيفة النيابة العامة أمام القضاء المدني :

تشارك النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها خصماً أصلياً أو طرفاً منضماً ، فإن هي أقامت الدعوى أمام المحكمة ، تكون خصماً حقيقياً لمن رفعتها عليه ، وتعتبر أنها تعمل بطريق الادعاء ، وتوصف بأنها طرف أصلي في الخصومة ، أما إذا تدخلت في خصومة قائمة بين طرفين لتدلي برأيها اعتبرت أنها تعمل بطريق إبداء الرأي ووصفت بأنها طرف منضم .

(أ) طرف أصلي : للنيابة العامة أن ترفع الدعوى المدنية في الحالات التي

ينص عليها القانون ، ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق (٣) .

ومن ثم ترفع النيابة العامة بعض الدعوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، ومن أمثلة هذه الدعوى ، دعوى حل الجمعيات (المادة ٦٦ مدني)

(١) حيث يكون لنيابة النقص بناءً على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثل النيابة صوت معدود في المداولات . (انظر قواعد المرافعات لأستاذنا المرحوم الدكتور عبد الباسط جميعي ص ٢٤٧ ، قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ١ / ٣٠٩) .

(٢) المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية .

(٣) المادة ٨٧ مرافعات .

ودعاوى شهر الإفلاس (المادة ١٩٦ تجارى) رفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة ، إذا تعلق بالتركة حق لقاصر أو عديم أهلية أو غائب (المادة ٩٥٢ / ٢ من قانون المرافعات ٧٧ لسنة ١٩٤٩) (١)

ب (طرف منظم : أثبت العمل أن القضايا التي تبدي فيها النيابة رأيها قلما يحيد فيها الحكم عن الصحة والحقيقة(٢) ، ولذلك قد يوجب القانون على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم لإبداء الرأي في بعض الحالات ، وقد يجيز لها ذلك في حالات أخرى ، رغبة من المقنن أو المحكمة فى الاستفادة والاستعانة برأي النيابة في الدعوى .

اختلاف دور النيابة العامة في الحالتين :

يختلف دور النيابة العامة باعتبارها طرفاً أصلياً عن دورها باعتبارها طرفاً منضمّاً على الوجه الآتي :

١- إذا كانت طرفاً أصلياً كان لها ما لكل خصم وعليها ما عليه ، فلها أن تعلن الأوراق إلى الخصم وتتلقى الإعلانات عنه ، وهي لها فى هذه الحالة أن تبدي ما تشاء من الطلبات والدفع ، ولها أن تطعن في الأحكام وفقاً للقواعد العامة(٣) . أما إذا كانت النيابة العامة طرفاً منضمّاً فيقتصر دورها على إبداء الرأي في الخصومة القائمة بين طرفيها ، ومن ثم لا تعلن أوراقاً إلى خصم ولا تتلقى إعلانات منه ، وإنما يحال إليها ملف القضية لدراسته ، وتكوين رأي فيه ، وأيضاً لا تقدم طلباً أو دفْعاً لم يقدمه أحد الخصوم ، إلا أن يكون الأمر متعلقاً بالنظام العام

(١) وهي من المواد المعمول بها من القانون المذكور ، طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ .

(٢) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية .

(٣) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور محمد حامد فهمي ف ١٧٦ ، قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ١ / ٣١٦ ، ٣١٧ .

فلها حينئذ أن تنبيه المحكمة إليه ، لأن المحاكم ملزمة بحماية النظام العام ، والحكم من تلقاء نفسها بما يوجبه .

وأما بالنسبة للطعن في الحكم فالقاعدة أن النيابة العامة كطرف منضم لا يجوز لها الطعن في الحكم ، لأن دورها يقتصر على إبداء الرأي ، إلا أن المقنن خرج عن هذه القاعدة وجعل :

١- " للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك " (١)

٢- إذا كانت النيابة العامة طرفاً أصلياً فإنها تأخذ دور المدعى أو المدعى عليه، فإن كانت مدعية كانت أول من يتكلم ، وإذا كانت مدعي عليها كانت آخر من يتكلم (٢) .

بخلاف ما إذا كانت خصماً منضمّاً فإنها تكون آخر من يتكلم .

٣ - إذا كانت النيابة العامة طرفاً أصلياً فهي تؤدي دور الخصم الحقيقي ، ومن ثم لا يجوز ردها ؛ لأن الخصم لا يرد .

(١) المادة ٩٦ مرافعات ، وقد نص القانون على حالات يكون للنيابة العامة حق الطعن في الحكم ولو كانت طرفاً منضمّاً وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية (المواد ٩٠١ ، ٩١٥ ، ١٠٢٥ من قانون المرافعات ٧٧ لسنة ١٩٤٩ الملغي ، وهذه المواد من المواد المعمول بها من القانون المذكور طبقاً لنص المادة الأولى من القانون ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، وانظر أيضاً المادتين ٢ و٣ من القانون رقم ٦٣٨ لسنة ١٩٥٥ والخاص ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ، وانظر كذلك المادة ٢٥٠ مرافعات ، حيث أعطت للنائب العام سلطة الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية - أي كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، وانظر أصول المرافعات للدكتور أحمد مسلم ف ١٤٠ قانون القضاء المدني للدكتور / محمود هاشم ١ / ١٦٤ ، الوسيط للدكتور / مجدي سيف ف ٦٠ .

(٢) قانون المرافعات ، الدكتور / محمد عبد الخالق عمر ١ / ٣١٧ .

بخلاف ما إذا كانت خصماً منضماً فهي بهذه الصفة يجب أن تتوافر فيها الحيدة المطلقة الواجب توافرها في القضاة ؛ لأن دورها بهذا الوصف أقرب إلى الحكم منه إلى الخصم ، ولأنه لا جدال في أن رأيها يكون محل تقدير كبير من المحكمة عند الحكم ، ومن ثم يجوز رد عضو النيابة إذا لم تتوافر فيه الحيدة وكان طرفاً منضماً^(١) .

حالات تدخل النيابة العامة :

قلنا إن المقنن قد يوجب على النيابة أن تتدخل في بعض الدعاوي المدنية ، وقد يجيز لها التدخل في دعاوى أخرى ، وسواء كان التدخل وجوبياً أو جوازياً فقد وردت حالاته في القانون على وجه الحصر ، ومن ثم فلا يجوز القياس عليها ، ونوضح فيما يلي بيان هذه الحالات ثم نتبعها ببيان إجراءات تدخل النيابة العامة ، ذلك على النحو التالي:

حالات التدخل الوجوبي :

فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً:

- ١- الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
- ٢- الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص .
- ٣- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها. " ٨٨ مرافعات "

حالات التدخل الجوازي :

فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجوز للنسبة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:

- ١- الدعاوي الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
- ٢- الدعاوي المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات والصايا المرصدة للبر .
- ٣- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .

(١) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في المرجع السابق ص ٣١٨ ، أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ص ٢٥٠ .

٤- دعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .

٥- الصلح الوافي من الإفلاس .

٦- الدعاوي التي تري النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .

٧- كل حالة أخرى ينص القانون علي جواز تدخلها فيها . " م ٨٩ مرافعات "

إجراءات تدخل النيابة العامة :

أوجبت المادة ٩٣ مرافعات على قلم كتاب المحكمة أن يخبر النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى التي ينص القانون على تدخل النيابة فيها ، سواء كان تدخلها وجوبياً أم جوازياً .

وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة ما تتدخل فيها النيابة العامة فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة ، وقلم الكتاب هو الذي يخطر بها .

ويجوز للنيابة التدخل في الدعوى من تلقاء نفسها متى علمت بها من طريق آخر^(١) ، وإخبار النيابة العامة بهذه الدعاوى إجراء جوهري ومن ثم فإذا أغفل قلم الكتاب إخطار النيابة العامة ولم تتدخل النيابة العامة ترتب على ذلك بطلان الحكم حتى ولو كان تدخلها جوازياً ، إلا أنه إذا كان التدخل لمصلحة خاصة كما هو الحال في هدف المقنن من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة يكون بطلاناً غير متعلق بالنظام العام ، لا يجوز التمسك به إلا للقصر ، ويتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز التصدي به لأول مرة أمام محكمة النقض^(٢).

وإذا تدخلت النيابة العامة فإنها تعطي مهلة — بناءً على رغبتها — لمدة لا تقل عن سبعة أيام لتقديم مذكرة بأقوالها ، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها

(١) قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ١ / ٣٢٣ .

(٢) طعن رقم ٤٤٠ لسنة ٣٦ ق جلسة ١٨ / ٣ / ١٩٧١ س ٢٢ ص ٣٥٩ .

فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم^(١)، و" يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها " المادة ٩٤ مرافعات .

وإذا حضرت النيابة العامة في الجلسة وأبدت أقوالها شفويّاً فتكون ممثلة في الدعوى ، ومع هذا فقد يسر المقنن على أعضاء النيابة العامة التدخل وأعفاهم مما يجب على الخصوم من حضوره واعتبر أن النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها ، ولا يشترط حضورها الجلسة ، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك " (٢) .

وسواء اشترط حضور النيابة أو لم يشترط ، لا يتعين حضورها عند النطق بالحكم (٣).

(١) المادة ٩٣ مرافعات .

(٢) كما هو الحال في المادة ٨٧١ من قانون المرافعات الملغي ، وهي ما زالت سارية بالمادة الأولى من قانون إصدار قانون المرافعات ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، حيث تضمنت المادة حضور أحد أعضاء النيابة .

(٣) المادة ٩١ مرافعات .

المبحث الثالث أعوان القضاء

أعوان القضاء مجموعة من الأشخاص يعاونون القضاة في النهوض بالوظيفة القضائية ويساعدون المتقاضين في الأعمال القضائية ، ويؤدون أعمالاً جوهرية في العملية القضائية ، ويسهمون في حسن سير القضاء .
ويمكن تقسيم هؤلاء الأشخاص إلى طوائف بحسب الأعمال المنوطة بكل طائفة ، فمنهم الكتاب وأمناء السر ، المنوط بهم الأعمال الكتابية ، ومنهم المحضرون المكلفون بتسليم الإعلانات والقيام بإجراءات التنفيذ ، إلى جانب الخبراء والمترجمين والمحامين فهم يؤدون أعمالاً هامة تعين القضاة وتشاركهم في بيان وجه الحق .

وقد نصت المادة ١٣١ من قانون السلطة القضائية على أن " أعوان القضاة هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون "(١)
وفيما يلي نتناول كل طائفة من هذه الطوائف مخصصين مطلباً لكل طائفة .

المطلب الأول الكتاب وأمناء السر

هم طائفة من العاملين بالمحاكم يعاونون رجال القضاء فيما يتعلق بالأعمال الكتابية ، وقد نصت المادة ١٣٥ / ١ على أنه " يعين بمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له ، وعدد كاف من رؤساء الأقسام والكتاب " .

(١) على الرغم من أن النيابة العامة تقدم عوناً مباشراً في العملية القضائية على الوجه سالف الذكر ، إلا أن العرف جرى على ضم أعضاء بالنيابة العامة إلى رجال القضاء ، وأفراد بقية أعوان القضاء بهذا العنوان " أعوان القضاء " وتبعاً لهذا العرف أفردنا الفصل الثاني للحديث عن النيابة العامة والفصل الثالث للحديث عن بقية أعوان القضاء ، وقد صار قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على هذا العرف أيضاً . انظر أصول في المرافعات للدكتور أحمد مسلم ف ١٣٣ حاشية ٢ .

وكتاب المحكمة قسمان : كتاب القسم المدني ويتبعون كبير الكتاب ، ورئيس المحكمة ، وكتاب النيابة أو القلم الجنائي ، ويتبعون رئيس القلم الجنائي ورئيس النيابة بالمحكمة^(١) .

وقد أجازت المادة ١٣٩ من قانون السلطة القضائية تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها في وظائف أمناء سر بالمحاكم والنيابة العامة أقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ، وتشجيعاً للحاصلين على المؤهل المذكور على شغل هذه الوظائف أجاز القانون تعيين من يظهر كفاية ممتازة في عمله في وظيفة معاون نيابة^(٢) .

وتنط بالكتاب مجموعة أعمال منها :

- ١- تلقي الدعاوى وقيدھا في الجدول ، وتقدير الرسوم القضائية ، وتحصيلھا وتحديد مواعيد الجلسات ، وإرسال الأوراق إلى قلم المحضرين لإعلانھا وإبلاغ النيابة العامة بالدعاوي التي تتدخل فيها .
- ٢- الحضور مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات ، وتدوين المحاضر ولا تصح جلسات المحاكم إلا بحضور الكاتب^(٣) ، وكتابة الأحكام والتوقيع عليها وعلى صورھا ولا تستكمل الأحكام شكلھا إلا بتوقيع الكاتب مع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية " المسودة " ووضع الصيغة التنفيذية على الأحكام ، وتسليم الصورة التنفيذية للمحكوم له ، وتوقيعھا وختمھا بخاتم الدولة .
- ٣- حفظ الملفات والوثائق والسجلات بالمحكمة واستخراج الصور والشهادات منها .

(١) المادتان ١٤٧ ، ١٦٤ من قانون السلطة القضائية ، وانظر أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ف ١٣٤ .

(٢) بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بدوي ص ١٤٤ .

(٣) وإلا ترتب على ذلك البطلان وهو يتعلق بالنظام العام . انظر المادة ٣٥ مرافعات .

وقد نظم قانون السلطة القضائية قواعد تعيين الكتاب وترقيتهم وتوزيع الأعمال عليهم في المواد من ١٣٧ - ١٤٧ .

ويلتزم الكتاب بعدم إفشاء أسرار القضايا ، كما يلتزمون بإطلاع من يبيح له القانون أو اللوائح أو التعليمات على القضايا دون غيرهم .

ويلتزمون أيضاً بعدم مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة .

وإلا كان هذا العمل باطلاً ويتعلق البطلان بالنظام العام^(١) .

وغني عن البيان أن الكتاب لا يعتبرون من رجال القضاء ، ولا يتمتعون بحقوقهم وضماناتهم .

المطلب الثاني

المحضرون

وهم موظفون عموميون بالمحاكم يختصون بتسليم الإعلانات القضائية والقيام بأعمال التنفيذ^(٢) ، وقد نصت المادة ١٣٥ / ٢ من قانون السلطة القضائية على أنه: " يعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين " .

ويوجد بالمحكمة الجزئية قلم محضرين يعمل كفرع من قلم المحضرين بالمحكمة الابتدائية ، ولا توجد أقلام محضرين بمحاكم الاستئناف أو بمحكمة النقض^(٣) .

والمحضر قد يكون محضر إعلان يختص بتسليم الإعلانات القضائية ، وقد يكون معاون تنفيذ يختص باتخاذ إجراءات تنفيذ السندات التنفيذية والقيام بالحجوز

(١) الدكتورة أمين النمر في قوانين المرافعات ف ٩٥ ، أستاذنا المرحوم الدكتور / عبد الباسط جميعي في مبادئ المرافعات ص ٢٩٢ ، الدكتور / مصطفى كيرة في قانون المرافعات الليبي ص ١٨١ .

(٢) المادة ٦ مرافعات .

(٣) الوسيط للدكتور / فتحي والي ف ١٣٣ .

محاضرات في قانون المرافعات مقارنة بالفقه الإسلامي

التحفظية ، وقد يجمع المحضر بين الاختصاصين ، وتوزيع العمل بهذا الشكل هو توزيع داخلي للعمل لا يترتب على مخالفته جزاء قانوني من بطلان أو سقوط أو نحو ذلك^(١) .

وقد نظم قانون السلطة القضائية قواعد تعيين المحضرين وترقيتهم ونقلهم وتوزيع الأعمال عليهم في المواد من ١٤٨ - ١٥٥ .

وقد أجازت المادة ٣٩ من قانون السلطة القضائية تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق في وظيفة معاون قضائي بأقلام المحضرين ، وأجازت تعيين من يظهر كفاية ممتازة في وظيفة معاون نيابة إذا استوفى الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة .

والمحضر في أداء وظيفته لا يعتبر وكيلاً عن أحد الخصوم ، وإنما هو مفوض في قبض الدين عند عرضه عليه ، وفي إعطاء المخالصة ، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص " المادة ٢٨٢ مرافعات " .

ولا يجوز للمحضر أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوى الخاصة به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره للدرجة الرابعة ، وإلا كان العمل باطلاً ويتعلق البطلان بالنظام العام^(٢) .

ولا يعتبر المحضر من رجال القضاء ولا يتمتع بضماناتهم .

(١) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ص ٢٩٣ .

(٢) انظر المادة ٢٦ مرافعات .

المطلب الثالث

الترجمان (المترجم) (١)

الترجمان هو المعبر عن حديث بلغة غير لغة المتحدث ويجب أن: " يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين (٢) يعاونون القضاة في التعبير عن أقوال الخصوم أو الشهود باللغة العربية إذا أدلوا بأقوالهم أو شهادتهم بلغة أخرى وذلك لأن " لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحاكم أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون بها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين " (٣) .

وقد بين قانون السلطة القضائية قواعد تعيين المترجمين ونقلهم وترجمتهم في المادة ١٥٧ منه .

ويقوم الترجمان بعمله شفويًا بالجلسة ، أو يترجم مذكرات أو مستندات مكتوبة ويقدم ترجمتها تحريريًا .

ولا يجوز للترجم أن يترجموا أقوالاً أو مذكرات أو مستندات أو غيرها في دعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلاً .

ولا يعتبر الترجمان من رجال القضاء ولا يتمتع بشيء من حقوقهم أو ضماناتهم .

(١) ترجم فلان كلام فلان إذا بينه وأوضحه، وترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم، واسم الفاعل ترجمان وبه لغات أجودها فتح التاء وضم الجيم والثانية ضمهما معاً بجعل التاء تابعة للجيم والثالثة فتحهما بجعل الجيم تابعة للتاء والجمع تراجم " المصباح المنير ١ / ٩١ ، طبع الأميرية سنة ١٩٠٦

(٢) المادة ١٥٦ من قانون السلطة القضائية ، وبالرغم من ذلك فالواقع أن الجهاز القضائي يعاني عجزاً شديداً جداً في المترجمين نتيجة ضعف المرتبات المقررة لهم ، وقد تظاهرت الشكوى من ذلك حيث تخلو غالبية المحاكم من مترجمين ، وقد درجت المحاكم على الاستعانة بترجمان يقدمه أحد الخصوم وحسناً فعلت

(٣) المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية .

المطلب الرابع الخبراء

الخبراء أشخاص ذوو معارف فنية يستعين بهم القضاء في الأمور التي يستلزم تحقيقها هذه المعارف ، كالطب والهندسة والزراعة والخطوط^(١) .

وندب الخبراء جوازي للمحكمة ، فقد تأمر به من تلقاء نفسها كندب خبير لتقدير قيمة الدعوى المنصبة على عقار لم تربط عليه ضريبة ، أو لإجراء معاينة أو لإثبات حالة ، وقد تأمر المحكمة بندب خبير بناءً على طلب الخصوم ، وإذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم^(٢) .

وفيما عدا هذه الحالة فللمحكمة أن تندب خبيراً واحداً أو ثلاثة خبراء من بين المقبولين أمامها ، إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعندئذ يجب على المحكمة أن تبين هذه الظروف في الحكم (المادة ١٣٦ / ٢ من قانون الإثبات) . وعند ندب خبير من غير المقيد بالجدول وجب أن يحلف أمام قاضي الأمور الوقفية — وبغير ضرورة لحضور الخصوم — يميناً أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة ، وإلا كان عمله باطلاً^(٣) ، وهو بطلان مقرر لمصلحة الخصوم وليس متعلقاً بالنظام العام^(٤) .

وينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ، ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديتهم^(٥) قانون الخبرة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون ٦٢٦ لسنة ٩٥٥ ، كما نظم الشارع الاستعانة بالخبراء في قانون الإثبات ٢٥ لسنة ١٩٦٨ .

(١) أستاذنا المرحوم الدكتور / عبد الباسط جميعي في مبادئ المرافعات ص : ٢٩٠ .

(٢) المادة ١٣٦ / ١ من قانون الإثبات

(٣) المادة ١٣٩ من قانون الإثبات

(٤) قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر ف ٩٤ .

(٥) المادة ١٣٤ من قانون السلطة القضائية .

وينقسم الخبراء إلى طائفتين :

- ١- خبراء جدول وهم الخبراء المقبولين أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ، ويطلق عليهم اسم الخبراء الأهليين ، لأنهم ليسوا موظفين .
 - ٢- خبراء وزارة العدل ، وهم موظفون فنيون تابعون للوزارة المذكورة ينهضون بعبء الخبرة أمام المحاكم .
- ويمكن للمحاكم أن تستعين بخبراء خارجيين غير خبراء الجدول وخبراء الوزارة ، وقد يكون الخبير الخارجي موظفاً ، ولكنه ليس من الخبراء المقبولين لدى المحاكم كأستاذة الهندسة والطب وغيرهم ، وقد يكون الخبير الخارجي غير موظف ، وقد أباح المقنن للمحاكم أن تستعين بمن ترى عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني من غير خبراء الجدول وخبراء وزارة العدل .
- ويمكن للخصوم الاستعانة بخبراء خارجيين يقدموا تقارير استشارية ، وقد يكون لتقرير الخبير الاستشاري أثره في ترجيح رأي فني آخر (١) .
- وسواء كان الخبير من خبراء الجدول المقبولين أمام المحاكم ، أم من خبراء وزارة العدل ، أم من غيرهم فرأيه لا يقيد المحكمة (٢) .
- ورغم أن رأي الخبير استشاري لا يقيد المحكمة ، إلا أن لرأيه قيمة أدبية أمام المحكمة وقد يكون محدداً لاتجاهها ، ولذلك يجب أن تتوافر فيه الحيطة المطلقة ، ومن هنا فقد أجاز المقنن رد الخبير متى توافرت حالة من الحالات التي ذكرتها المادة ١٤١ من قانون الإثبات ، وقد جمعت هذه المادة بين بعض أسباب عدم صلاحية القضاة للحكم وبين بعض أسباب ردهم (٣) .
- ولكن " لا يقبل من أحد الخصوم رد الخبير المعين بناءً على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه (٤) " .

(١) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ص ١٩١ .

(٢) المادة ١٥٦ من قانون الإثبات .

(٣) أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ف ١٤٦ حاشية (٢) .

(٤) المادة ١٢٤ من قانون الإثبات .

وقد بين قانون الإثبات إجراءات الخبرة ، وواجبات الخبير وحقوقه ، وأسباب الرد وإجراءاته .

المطلب الخامس

المحامون^(١)

المحامون طائفة من المشتغلين بالقانون ، يسدون النصح للخصوم ، ويصرفون أمورهم القضائية ، ويدافعون عنهم أمام القضاء .

وهم من شركاء القضاء في تحقيق العدالة القضائية، ذلك أن المحامي إذا قام بدوره على الوجه المطلوب يكون عويناً هاماً للقضاء في إظهار وجه الحقيقة في وقت أقصر وبجد أقل ، فهو أبين بالحجة وألحن بها من الخصوم العاديين ، ومن المؤكد أن جانباً كبيراً من حسن سير العدالة ، وتوفيق القضاء في أحكامه يتوقف على قدر ما يبذله المحامون من إخلاص وأمانة في الاضطلاع بعبء مهمتهم^(٢) .

والمحامي عوين للخصم أيضاً ، فهو يساعده بإبداء النصح له ، ويباشر عنه إجراءات الدعوى ، ويدافع عنه باللسان والقلم ، فهو يقدم للخصم معونة جليّة الشأن ، لا يكاد يمكن الاستغناء عنها ، ذلك أنه قلما يستطيع الخصم — ولو كان من رجال القانون — أن يستوفي تحضير قضيته بنفسه ، ويحسن الدفاع فيها ، ويسمح له وقته بأن يباشر إجراءاتها ويحضر بنفسه في كل جلساتها^(٣) .

ورسالة المحامي رسالة سامية تقوم على الدفاع عن الحق وتصرفه ، ومحاربة الظلم وكبته ، والتصدي للطغيان وأهله ، ونجدة المظلوم وإغاثته .

(١) كانت المحاماة معروفة عند العرب قبل الإسلام ، وكانوا يسمون المحامي حجاجاً أو حجيجاً ، فإذا حدث نزاع بين رجلين جاز لأي واحد منهما أن يوكل عنه حجاجاً ، وكان صيغة الوكالة هي أن يقول الموكل لوكيله : وضعت لسانني في فمك لتحتج عني " . الدكتور / مصطفى كامل كيرة في قانون المرافعات الليبي ص ١٨٨ .

(٢) راجع الدستور المصري الحالي لسنة ٢٠١٤م .

(٣) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / محمد حامد فهمي ف ١٨٠ .

و" المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم" (١) .
وللمحاماة مكانة رفيعة يعمل فيها الطامحون من شباب القانون ، ويلوذ بها شيوخ وعلماء الحقوق ، ومن رجالها يختار القضاة كما يختار أعضاء النيابة (٢) .
الحضور عن الخصوم : حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصور على المحامين وحدهم ، فلا يجوز لخصم أن يوكل شخصاً للحضور أمام المحاكم من غير المحامين (٣) .

وقصر حق الحضور عن الخصوم على المحامين ليس عوضاً بالحضور عنهم أمام الجهات القضائية ، وإنما يسرى على غيرها من الجهات التي تتصدى للمنازعات ، كالنيابات ، وهيئات التحكيم ، ودوائر الشرطة واللجان القضائية أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي (٤) .

ومع أن الحضور عن الخصوم مقصور على المحامين وحدهم إلا أن المقنن أجاز " للمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصاً من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة" (٥) .

وقد نصت على ذات الاستثناء أيضاً المادة ٧٢ مرافعات (٦) ، وعلقت المادتان ١٣٢ من قانون السلطة القضائية ٧٢ مرافعات حضور المذكورين على إذن

(١) المادة ١ / ١ من قانون المحاماة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ .

(٢) الدكتور / أحمد مسلم في أصول المرافعات ف ١٤٨ .

(٣) المواد ١٣٢ من قانون السلطة القضائية ٧٢ مرافعات ، ٣ محاماة .

(٤) المادة ٣ من قانون المحاماة .

(٥) المادة ١٣٢ من قانون السلطة القضائية .

(٦) ونصها في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة .

المحكمة وقبلها حضورهم مما يشير إلى سلطة المحكمة في ذلك ، وضرورة موافقتها على هذه الوكالة^(١) .

ويجوز لأحد القضاة أو النائب العام أو أحد وكلائه أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً في الحضور أو المرافعة ، سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة عن ممثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية^(٢) . ولا يجوز لواحد منهم أن يكون وكيلاً عن أي شخص آخر ، سواء أمام المحكمة التي يعملون بها أم أمام أية محكمة أخرى .

الاستعانة بالمحامين : قصر الحضور عن الخصوم أمام جهات القضاء على المحامين لا يعني أن الاستعانة بهم حتماً مقضياً ، ذلك أن الأصل في الاستعانة بالمحامين أمام القضاء المدني اختياري^(٣) ، وليست وجوبية ، فللخصم أن يحضر أمام المحكمة بنفسه إن شاء أو يوكل محامياً أو أكثر^(٤) في الحضور عنه .

ومع هذا فهناك كثير من الخصومات أصبحت الاستعانة فيها بالمحامين واجبة ، ولم يعد للخصم أن يقوم بنفسه ببعض الإجراءات أو يستعين فيها بزوجه أو أقاربه أو أصحابه ، وكذلك حضور بعض الخصومات ، بل يتعين عليه أن يستعين في ذلك بمحام يوكله الخصم وذلك في الحالات الآتية :

١- أمام محكمة النقض " لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض إلا للمحامين المقيدین بجدول المحامين أمام محكمة النقض ، وإلا حكم بعدم قبول الطعن ، ولا يجوز لغير هؤلاء المحامين الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام محكمة النقض (المادة ٤١ من قانون المحاماة) .

(١) الوسيط ، للدكتور / فتحي والي ف ٢٠٠ .

(٢) المادة ٨١ / ٢ مرافعات .

(٣) المادة ١٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية .

(٤) المادة ٧٧ مرافعات " إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل .

كما أوجب قانون المرافعات على كل من الطعن والمذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض^(١) .
كما أوجب قانون المرافعات على كل من الطاعن والمطعون ضده إيداع سند توكيل المحامي الموكل عن كل منهما^(٢) .

والحكمة في ذلك أن محكمة النقض لا تنظر إلا في طعون مبنية على أسباب قانونية بحتة ، فيجب أن يتولى تقديمها والحضور فيها والمرافعة محام حتى لا تكثر الطعون المرفوعة جزافاً بغير سند قانوني^(٣) .

٢- أمام محاكم الاستئناف العليا ، لا يجوز قبول صحيفة الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل .

٣- أمام المحاكم الابتدائية ، لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو الاستئناف أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل^(٤) .

٤- أمام المحاكم الجزئية ، لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين^(٥) .

والحكمة من اشتراط توقيع محام على صحف الاستئناف والدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامي على تحرير هذه الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها ، وبذلك

(١) المادتان ٢٥٣ / ١ ، ٢٦١ مرافعات .

(٢) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور عبد الباسط جميعي ص ٢٥٩ وانظر المادتين ٢٥٥ ، ٢٥٨ مرافعات

(٣) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / عبد المنعم الشرقاوي ف ١٢٤ .

(٤) المادتان ١/٣٧ ، ٥٨ / ٢ من قانون المحاماة .

(٥) الوسيط للدكتور / فتحي والي ف ٢٠٠ وانظر المادة ٥٨ / ٤٠٣ .

تتقطع المنازعات التي تثور بسبب قيام من لا خبرة له بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن (١) .

ويلاحظ أنه بالنسبة لمحكمة النقض يتمتع على الخصم القيام بأي إجراء أمامها بنفسه أو عن طريق شخص آخر غير محام ، بل يتعين أن يكون ذلك عن طريق محام مقبول أمامها، يحضر مع الخصم ، ويترافع عنه ويقدم المذكرات والطلبات .
بخلاف محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية حيث يتمتع على الخصم فقط التوقيع على صحيفة الاستئناف أو الدعوي ، ومن ثم يمكن للخصوم الحضور أمامها بأنفسهم (٢) .

جزاء عدم الاستعانة بمحام :

رتب القانون جزاءً خطيراً لعدم الاستعانة بمحام في المواضع التي أوجب القانون الاستعانة به فيها ، وهذا الجزاء هو البطلان ، وقد نصت على ذلك صراحة المادة ٥٨ / ٥ من قانون المحاماة .

شروط الاشتغال بالمحاماة :

يشترط فيمن يشغل بالمحاماة أمام المحاكم المصرية أن يكون اسمه مقيداً بالجدول العام للمحامين ويجب أن تتوافر الشروط الآتية للقيّد في هذا الجدول العام .
١- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ، وقد أجاز القانون للمحامي من رعايا الدول العربية المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده ، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية ، وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها ، وبشرط المعاملة بالمثل (٣) .

(١) الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٣٥ ق جلسة ٢ / ٥ / ١٩٧٣ سنة ٢٤ ص ٧٠٣ .

(٢) الدكتور فتحي والي في المرجع السابق والفقرة نفسها .

(٣) المادة ٤٢ من قانون المحاماة .

- ٢- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ، وذلك بأن يكون قد بلغ إحدى وعشرين سنة .
- ٣- أن يكون حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية^(١) ، أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر .
- ٤- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنية ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق .
- ٥- ألا يكون عضواً في نقابة مهنية أخرى .
- ٦- أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام قانون المحاماة .
- ٧- ألا يجمع بين المحاماة والأعمال الواردة في المادة (١٤) من قانون المحاماة^(٢) .

(١) ولحاملي درجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر كافة الحقوق المقررة لحاملي درجة " الليسانس في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات الجمهورية بناءً المادة الثانية من القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٦ في شأن تطوير الدراسة في جامعة الأزهر .

(٢) وهي :

- ١- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى . ٢ - منصب الوزارة ٣- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام قانون المحاماة ، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها قانون المحاماة ٤- الاشتغال بالتجارة . ٥- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية . ٦- المناصب الدينية

ويجب أن تتوافر هذه الشروط عند القيد ، ويجب توافرها كذلك لاستمرار القيد^(١) ، وهناك شروط أخرى يجب توافرها للقيد في الجداول المختلفة الآتي بيانها .

جدول المحامين :

للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارسة المهنة ، ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :

- ١- جدول للمحامين تحت التمرين .
- ٢- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية ، وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
- ٣- جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف ، وتعتبر محكمة القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف .
- ٤- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ، وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
- ٥- جدول المحامين غير المشتغلين .

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها^(٢) .

إجراءات القيد بجدول المحامين :

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة نقيب المحامين أو وكيل النقابة في حالة غيابه ، وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً .

(١) المادة ١٣ من قانون المحاماة .

(٢) المادة ١٠ من قانون المحاماة .

ويرفق بطلب القيد الأوراق التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة ١٣ من قانون المحاماة والسابق ذكرها والتي يبينها النظام الداخلي بالنقابة^(١) .
وتتعد اللجنة المذكورة مرة على الأقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضائها ، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة .

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة (المادة ١٧ محاماة) .
تتحقق اللجنة من توافر شروط القيد ، وتصدر قرارها في خلاف ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا رفضت اللجنة قيد الطلب تعين أن يكون قرارها مسبباً ، ويخطر به الطالب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول^(٢) .

وإذا لم تفصل اللجنة في طلب القيد خلال المدة المذكورة ، كان لطالب القيد أن يطعن أمام محكمة استئناف القاهرة^(٣) .

ولطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله .

وإذا رفض التظلم أو كانت مواعيده قد انقضت ، فلطالب القيد أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم ، أو برفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال .

(١) راجع المادة ١٦ من قانون المحاماة .

(٢) المادة ١٨ من قانون المحاماة .

(٣) المادة ١٩ / ٢ من قانون المحاماة .

ولا يجوز تجديد طلب القيد في الحالات السابقة إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد (المادة ١٩ من قانون المحاماة) .

وإذا وافقت اللجنة على قيد اسم الطالب بجدول المحاماة فلا يجوز له أن يزاول مهنة المحاماة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية :

(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون) .

ويحلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة (١) .

المحامي تحت التمرين :

عند تقديم طلب القيد بالجدول العام ويقدم معه طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين ويعرض على لجنة القبول وفقاً للأحكام السابقة (٢) ، حيث يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة ، إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقه الأخرى ، ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (المادة ٢١ محاماة) .

ويجب أن يلتحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة .

وقد ألزم القانون كل محام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يكون من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل (٣) .

(١) المادة ٢٠ من قانون المحاماة .

(٢) المادة ٢٣ من قانون المحاماة .

(٣) وإذا كانت ظروف المحامي المقبول أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف لا تسمح له بقبول أي محام تحت التمرين بمكتبه يجوز لمجلس النقابة الفرعية بناءً على طلب المحامي المذكور أن يقرر إعفائه من ذلك . انظر المادة ٢٩ محاماة .

ويظل المحامي تحت التمرين لمدة سنتين تنقصر إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى^(١) ولكن إذا انقضت أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين ولم يتقدم بطلب لقيده اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسمه من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول^(٢) .

وللمحامي تحت التمرين في السنة الأولى أن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف دعاوى ومستنداتها .

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف دعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري ونحوها^(٣) .

وأما في السنة الثانية فله أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية ، فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة ، وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها .

وكذلك له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجناح ، وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.

(١) المادة ٢٤ محاماة ، معدلة بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ م .

(٢) وللمن استبعد اسمه من الجدول في خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الأربع سنوات أن يطلب قيده اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد ، على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام ، بالإضافة إلى رسم القيد أمام المحاكم الابتدائية وإذا ظل اسمه مستبعداً لمدة سنتين دون أن يطلب إعادة قيده ، فلا يجوز إعادة قيده اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين ، وبعد دفع رسوم القيد من جديد ، ويشترط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين (المادة ٣٠ محاماة) .

(٣) المادة ٢٥ محاماة .

وله الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو المحامي بالإدارة القانونية التي ألحق بها . ويجوز للمحامي تحت التمرين الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر في طلب التأجيل .

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يقدم فتوى كتابية باسمه أو أن يوقع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ^(١) .

ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين (المادة ٢٧ محاماة) .

وقد نص قانون المحاماة على أن: " تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة ويدعي لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحاضرين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبرائهم المتخصصون .

وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين"^(٢) .

المحامي أمام المحاكم الابتدائية :

بعد أن يمضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين السالف ذكرها يطلب المحامي قيده في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين سالف الذكر ، ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها ويرأسها أقدمهم ، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .

(١) المادة ٢٦ محاماة .

(٢) المادة ٢٨ محاماة .

محاضرات في قانون المرافعات مقارنةً بالفقه الإسلامي

وتقدم طلبات القيد إلى اللجنة المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد^(١) وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار^(٢) .
وأجاز القانون قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة^(٣) .

(١) وهذه الشروط هي :

- (أ) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المقررة .
(ب) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها ، ويرفق أيضاً بياناً رسمياً بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
(ج) أن يكون قد وازب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات . انظر المادة ٣١ محاماة .

(٢) المادة ٣٣ محاماة .

- (٣) تعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجدول المحامين الوظائف الفنية في القضاء ، ومجلس الدولة ، والمحكمة الدستورية العليا ، والنيابة العامة ، والنيابة الإدارية ، وإدارة قضايا الحكومة وتدريب القانون في الجامعات .
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة .

وإذا قيد اسم المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية جاز له أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره ، ويكون له الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ، وله أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة .

ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسؤوليته .

وللمحامي المقيم أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها ، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها .

ولا يجوز للمحامي المقيم أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة^(١) .

المحامي أمام محاكم الاستئناف :

يشترط للقيد في جداول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة خمسة سنوات^(٢) ، على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .

ويجوز القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف إذا كان طالب القيد قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات .

ولكن لا يقبل القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاوله الأعمال القانونية النظيرة مدة تزيد عن عشر سنوات .

(١) المادة ٣٤ محاماة .

(٢) ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وتقديم صورة المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي أعدها ، وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها ، وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة . المادة ٣٥ محاماة .

وتقدم طلبات القيد في الجدول المذكور إلى لجنة القبول سائلة الذكر ، ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم ، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .

وعلى اللجنة أن تبلغ قرارها بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن يرفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار (١) .

ومتى قيد المحامي بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف كان له حق الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، وجميع المحاكم عدا محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا كما يكون له إيداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها، والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى (المادة ٢٧ محاماة) .

المحامي أمام محكمة النقض :

يشترط للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :

- ١- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل ، وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة .
- ٢- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية .
- ٣- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية (٢) .

(١) المادة ٣٦ محاماة .

(٢) المادة ٣٩ محاماة .

ويقدم طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ، ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة (المادة ٤٠ محاماة) .

وللمحامي المقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يحضر ويترافع أمام جميع المحاكم ، وله إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها .

الباب الثاني

نظرية الاختصاص والإحالة

وفيه ستة فصول:

- الفصل الأول : الاختصاص الولائي .
- الفصل الثاني : الاختصاص النوعي .
- الفصل الثالث : الاختصاص القيمي .
- الفصل الرابع : الاختصاص المحلي .
- الفصل الخامس : مدي تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
- الفصل السادس : الإحالة .

الباب الثاني نظرية الاختصاص والإحالة

تمهيد وتقسيم :

الاختصاص في القضاء هو " مقدار ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعاً لمقرها أو نوع القضية ، وهو نوعي إذا اختص بالموضوع ومحلّي إذا اختص بالمكان " (١).

وتأسيساً على هذا: يتضح لنا أن مقصود الاختصاص القضائي يعني : السلطة القضائية التي يتمتع بها قاض أو جهة قضائية ، ويخول لها القانون حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها (٢) .

وهذا يبنى على أن الاختصاص القضائي ينتج عنه الانفراد بولاية القضاء إما عموماً في جميع الأمكنة والحوادث والأزمنة ، وإما خصوصاً في زمن معين أو مكان معين ، أو حادثة معينة ، بناء على تقليد صاحب الولاية العامة ، الذي يملك الحق في الإطلاق أو التقييد وذلك وفقاً للأصول الشرعية أو القانونية (٣) . ولقد حدد شرّاح القانون الاختصاص في كونه توزيعاً للعمل بين المحاكم وجهات القضاء المختلفة (٤) .

وبهذا فإن منشأ الاختصاص القضائي هو تعدد المحاكم والجهات القضائية داخل الدولة الواحدة (٥) ، الأمر الذي يستلزم توزيع العمل القضائي بين هذه المحاكم ، وتلك الجهات إقراراً لمبدأ العدالة بين القضاة في نظر الدعاوى والخصومات (٦) .

(١) المعجم الوسيط ١ / ٢٤٦ ، المعجم الوجيز . ص ١٩٨ .

(٢) التنظيم القضائي . لأستاذنا الدكتور / حامد محمد أبو طالب . ص ١١٣ . ط / مطبعة السعادة . القاهرة ط . الثانية . ط . ١٤٠٢ هـ .

(٣) الأحكام السلطانية للماوردي . ص ٧٠ ، كشف القناع للبهوتي ٦ / ٣١١ .

(٤) نظرية الاختصاص د / عبد الباسط جميعي . ص ٣ .

(٥) المبسّط في قانون المرافعات . لأستاذنا الدكتور / عبد الحكم أحمد شرف - رحمه الله - ص ١٠٤ .

(٦) أصول المرافعات . د / أحمد مسلم . بند ١٧٩ . ص ١٩٢ .

التفرقة بين الاختصاص والولاية القضائية :

الولاية أعم من الاختصاص ، فالولاية تعنى سلطة الحكم المقررة بمقتضى القانون ، والتي تمنح لكافة محاكم الدولة^(١) .

بينما الاختصاص القضائي معناه نصيب كل محكمة من هذه الولاية ؛ نتيجة لتعدد المحاكم^(٢) .

وتبدو أهمية هذه التفرقة في مجال العمل القضائي ، فالقاضى صاحب الولاية القضائية المقررة بمقتضى القواعد الإجرائية له سلطة إصدار الأحكام فى نطاق ولايته في الجهة القضائية التي يتبعها ، فإذا جاوز حدود هذه الولاية بأن أصدر حكماً خارجاً عن حد اختصاصه - المحلى أو النوعى أو القيمى - ولكنه يدخل فى نطاق ولايته القضائية ؛ فإن حكمه هذا يصدق عليه أنه صادر من قاض ذى ولاية ، ومن ثم يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى أمام محاكم هذه الجهة^(٣) .

بيد أن هذا الحكم يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص^(٤) ، ويوصف بكونه غير صحيح ، ومن ثم فيكون محلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف المقرر قانوناً ، وفى الوقت المحدد لرفع الطعن ، فإذا لم يطعن عليه خلال تلك المدة المحددة صار الحكم نهائياً وصحيحاً^(٥) .

بينما إذا صدر الحكم من قاض ليست له ولاية قضائية ، فالحكم فى هذه الحالة يكون منعماً لا وجود له فى الواقع ، ومن ثم فلا يتمتع بأية قيمة قانونية^(٦) ، كما لو أصدر القاضي حكماً فى عمل من أعمال السيادة^(٧) ، فهذا الحكم معدوم الوجود والأثر ؛ لصدوره عن قاض لا ولاية له على هذه الأعمال .

(١) اختصاص المحاكم الدولية والولائى . د/أحمد مليجي . بند ١ ص ٣ ط/دار النهضة .

(٢) أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . بند ٢٦٦ ص ٥٤١ .

(٣) الوجيز . د/عبد المنعم الشرقاوى . بند ١٨٦ ص ٢٥٢ .

(٤) النظرية العامة للعمل القضائي . د/وجدى راغب ص ٦٠٠ .

(٥) نظرية الاختصاص . د/عبد الباسط جميعى . ص ٩ ، ص ١١ . أصول علم القضاء . د/عبد الرحمن عياد . ص ٢٤٦ .

(٦) الوجيز . د/ عبد الفتاح السيد بك . بند ٨٤٥ ص ٧٣٦ .

(٧) أصول المرافعات . د/ أحمد مسلم . بند ١٦٧ ص ١٧٣ .

التفرقة بين الاختصاص والتوزيع الداخلي للعمل القضائي في محكمة واحدة:

لا يعد التوزيع الداخلي للعمل القضائي في المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة تحديداً للاختصاص ، وإنما هو تنظيم إداري لعمل قضائي^(١) ، وإقرار لمبدأ العدالة القضائية بين قضاة المحاكم^(٢) .

وتأسيساً على هذا :

لا يتم التوزيع الداخلي للعمل القضائي بمقتضى نص قانوني ، كما هو شأن تحديد الاختصاص القضائي ، وإنما يتم ذلك بموجب قرار إداري يصدر عن الجمعية العمومية للمحكمة ، يتضمن تحديداً للدوائر داخل المحكمة ، وتقسيماً للعمل القضائي ، وذلك بتوزيعه على هذه الدوائر^(٣) ، كما هو الشأن في تحديد دائرة بعينها لنظر مسائل الأحوال الشخصية ، وأخرى لنظر المواد المدنية والتجارية ، وثالثة لنظر المسائل الجنائية ، وهكذا .

وأخيراً :

يتنوع الاختصاص القضائي بحسب تنوع قواعده القانونية فالاختصاص القضائي يكون ولائياً ، إذا تعلق بالولاية القضائية ، ويكون نوعياً إذا تعلق بنوع الدعوى أو الخصومة ، ويكون قيمياً إذا تعلق بقيمة الدعوى ، ويكون محلياً إذا تعلق بمكان الدعوى أو محلها ، ويكون زمانياً إذا تعلق بزمان مخصوص يقضى فيه القاضى دون غيره^(٤) .

وبناءً على هذا فإن مخالفة أي من هذه القواعد تثير مسألة الدفع بعدم الاختصاص.

(١) أصول المرافعات . د / أحمد ماهر زغلول . بند ٢٦٦ .

(٢) ضوابط الاختصاص . د/عبد الحكم فودة . بند ٢ . ص ١٢ .

(٣) أصول المرافعات . د / أحمد مسلم . بند ٧٣ . ص ٦٥ ، ٦٦ ، بند ١٧٩ . ص ١٩٢ .

(٢) انظر: الاختصاص القضائي . د / الغامدى . ص ٣٤٤ .

محاضرات في قانون المرافعات مقارنة بالفقه الإسلامي

وسوف أتناول الحديث في هذا الباب عن بيان أهم أنواع الاختصاص القضائي

وذلك من خلال الفصول الستة التالية :

الفصل الأول : الاختصاص الولائي .

الفصل الثاني : الاختصاص النوعي .

الفصل الثالث : الاختصاص القيمي .

الفصل الرابع : الاختصاص المحلي .

الفصل الخامس : مدي تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام.

الفصل السادس : الإحالة .

الفصل الأول الاختصاص الولائي

ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : مفهوم الاختصاص الولائي وأهميته.

المبحث الثاني : موقف أعمال السيادة .

المبحث الثالث : أنواع الاختصاص الولائي

المبحث الأول مفهوم الاختصاص الولائي وأهميته

الاختصاص الولائي هو :

الاختصاص الذى يتم بمقتضاه توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء المختلفة داخل الدولة ، ويتحدد على أساسه نوع العمل القضائي الذى تستقل به كل جهة ، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى النحو الذى يقرره القانون^(١).

أهمية الاختصاص الولائي :

يعد الاختصاص الولائي أهم أنواع الاختصاص القضائي؛ حيث تنتزع على أساسه الولاية القضائية بين جهات القضاء المختلفة داخل الدولة الواحدة ، وفقاً للمعايير الشرعية التى يحددها ولى الأمر وتلك التى يضعها المقنن.

ويعرف هذا النوع من الاختصاص فى الفقه الإجرائى بالاختصاص الوظيفي^(٢) أو الاختصاص الولائي؛ حيث تستقل ولاية جهة قضاء معينة بالنظر فى منازعات محددة ، تخرج بحسب طبيعتها من ولاية جهة قضاء أخرى، ومن ثم فهو اختصاص متعلق بالولاية القضائية .

وبهذا يمثل الاختصاص الوظيفي نوعاً من الاختصاص النوعى بمعناه العام ؛ لأنه يستند إلى نوع الخصومة ، ومن ثم فيتأثر باختلافه ، ويأخذ حكمه من جهة تعلقه بالنظام العام .

بيد أن الاختصاص الولائي يختلف عن الاختصاص النوعى بكون الحكم الذى يصدر من محكمة لا ولاية لها على المنازعة ليس له قيمة قانونية ، فهو لا يحوز قوة الشئ المقضى به ، ولا يحتج به أمام جهة قضائية أخرى ، ولا أثر له فى حقوق الخصوم ، لأن تجاوز المحكمة لحدود ولايتها القضائية يعنى سقوط كل قوة

(١) أصول المرافعات. د/أحمد مسلم . بند ٧١ . ص ١٧٩ .

(٢) انظر : قانون القضاء المدنى د / محمود هاشم . بند ٢٤٨ . ص ٣٨٧ .

للقرار الذي تصدره في الخصومة على اعتبار أن حكمها في هذه الحالة لا وجود له ، ومن ثم تتعدم حجيتها^(١) .

بيد أن هذا الحكم وإن لم يكن له حجية أمام المحاكم التابعة لجهة قضائية أخرى إلا أنه يتمتع بالحجية القانونية الكاملة أمام محاكم جهة القضاء التي أصدرته^(٢) .

المبحث الثاني موقف أعمال السيادة

خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء في القانون الوضعي

لم يضع المقنن تعريفاً محدداً لأعمال السيادة ؛ لذا يجتهد الفقه والقضاء في بيان المقصود منها ، وقد جاء عنهما أن المقصود بأعمال السيادة : هي تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها المهيمنة على مصالح الدولة العليا ، وتتصل بالسيادة العليا للدولة^(٣) .

أو هي الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية — الحكومة — باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة^(٤) .

هذا ويعد من الأعمال التي ينطبق عليها الوصف بأنها أعمال سيادية الأعمال التالية :

ما تقوم به السلطة التنفيذية من إبرام المعاهدات ، وإعلان الحرب ، وإبعاد بعض الأجانب عن إقليم الدولة — لسبب قام لديها يقتضى ذلك — ودعوة المجلس للانعقاد أو فض دورته البرلمانية ، والعفو الشامل^(٥) .

(١) المرافعات د/محمد حامد فهمي. بند ٢٩٥. ص ٣٢٣ .

(٢) المرافعات. د/محمد حامد فهمي. بند ٢٩٦. ص ٣٢٤ .

(٣) أعمال السيادة في القانون المصري المقارن . د / حافظ هريدي . بند ١٣٣ . ص ٩٥ .

(٤) نظرية أعمال السيادة . د / عبد الفتاح ساير .

(٥) المرافعات. د/أحمد أبو الوفا. بند ٢٣٢ . ص ٢٦٦ .

هذا ويلاحظ أن المقنن قرر أيضاً انتفاء ولاية القضاء المصري عن الدعاوى المقامة ضد الدول الأجنبية ، أو رؤسائها ، أو ممثليها ، أو الهيئات والمنظمات الدولية وممثليها السياسيين ممن يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية^(١) .

عدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بنظر أعمال السيادة:

لقد عمد المقنن إلى إخراج أعمال السيادة عن ولاية القضاء بجهاته المختلفة ، وقد نص على ذلك صراحة في قانون السلطة القضائية الذي جاء فيه أنه : " ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة"^(٢)

كما نص أيضاً على هذا المنع في قانون مجلس الدولة حيث أورد فيه النص التالي : " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في المسائل المتعلقة بأعمال السيادة"^(٣) .

وبناءً على هذه التشريعات المتعاقبة أخرج المقنن أعمال السيادة من رقابة القضاء عموماً ، — العادى منها والإدارى — فلا يجوز للمحاكم المدنية أو الإدارية أن تنتظر عملاً سيادياً بعد تحقق وصفه ، وإلا عد هذا خروجاً عن حدود اختصاصها الولاى ، ومن ثم لا تحوز أحكامها التي تصدر بشأن الأعمال السيادية أية حجية قانونية ، لانعدام ولايتها القضائية^(٤) .

بل يتعين عليها قانوناً إذا رفعت إليها دعوى تتعلق بعمل من الأعمال السيادية أن تقضى فيها بعدم الاختصاص ، ولا تأمر بالإحالة على أى من الجهات القضائية الأخرى ، حيث إن أعمال السيادة لا تخضع لرقابة أية جهة قضائية أياً كان نوعها ، ومن ثم فلا مجال لأمر الإحالة عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الأعمال

(١) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا بند ٢٣٥ . ص ٢٦٧ .

(٢) المادة " ١٧ " من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م .

(٣) المادة رقم " ١١ " من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ م .

(٤) المرافعات . د/أحمد أبو الوفا . بند ٢٣٢

السيادية ، وهذا يعد مخالفة واضحة ويمثل انتهاكاً صريحاً لنص دستوري تعاقب وروده في دساتير مصر المتعاقبة (١).

وبناءً على ما تقدم :

لا تملك أية محكمة — أياً كانت درجتها — أن تنتظر في دعوى تتعلق بطلب إلغاء عمل سيادي ، أو أمر يتوافر فيه هذا الوصف ، أو دعوى بطلب إيقاف تنفيذه أو تعويض الضرر الناشئ عنه ، وذلك لانعدام ولاية المحاكم عموماً في نظر تلك الأعمال (٢) .

فإذا التزمت هذه المحاكم بنص القانون قضت في الدعاوى المتعلقة بالأعمال السيادية بعدم الاختصاص ، وهذا القضاء لا يتوقف على طلب صاحب المصلحة بل تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يطلب منها ذلك ؛ لتعلقه بالنظام العام (٣) .

(١) المادة " ٦٨ " من دستور ١٩٧١م ، وقد نصت علي أن : " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين ، وسرعة الفصل في القضايا ، ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " ، والمادة " ٧٥ " من دستور ٢٠١٢م ، وقد نصت علي أن : " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل = في القضايا ويحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة " ، والمادة " ٩٧ " من دستور يناير ٢٠١٤م " ، وقد نصت علي أن : " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة " .

(٢) نظرية الاختصاص. د/عبد الباسط جميعي. ص ١١٩ ، الوسيط . د/عاشور مبروك . بند ٢٣٣ ص ٢٦٤ .

(٣) المرافعات . د / محمد حامد فهمي. بند ٢٩٥. ص ٣٢١ ، ٣٢٢ .

وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فيجوز التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولا يسقط الحق في إبداء الدفع بالنزول عنه ، أو التصالح عليه^(١)

هذا ويلاحظ أن المقنن عندما نص على منع جهات القضاء المختلفة من نظر الأعمال السيادية لم يرد حرمان القضاء مطلقاً من البحث في هذه الأعمال ، وإنما جعل هذا المنع مقصوراً على ذات العمل السيادية بعد تحقق وصفه .
أما البحث في أعمال السيادة لمعرفة ما إذا كان العمل المعروض على القضاء عملاً سيادياً أم لا ينطبق عليه هذا الوصف ، فهذا مما أخضعه المقنن لرقابة القضاء^(٢) .

سلطة القضاء على أعمال السيادة في النظام القضائي الإسلامي.

النظام القضائي في الإسلام لا يعترف بفكرة السيادة التي سادت في ظل النظم الوضعية المعاصرة^(٣) .

فكرة السيادة فكرة حديثة من صنع الفقه الفرنسي ، ترجع في نشأتها إلى القرن الخامس عشر تقريباً ، وقد انتقلت من الغرب إلى ديار الإسلام بانتقال القوانين الوضعية إليها بعد سقوط الخلافة العثمانية^(٤) .

وبناءً على هذا يعد مصطلح السيادة من المصطلحات الغريبة على الفقه الإسلامي ، فالفقهاء الأجلاء لم يبحثوا في هذه المسألة ، ولم تلق اهتمامهم ، لعلمهم بأن الإسلام لا يعترف بسيادة لأحد كائناً من كان ، وأنه لا سيادة في الإسلام إلا

(١) الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ١٨١ . ص ٢٦٢ .

(٢) نظرية الاختصاص . د / عبد الباسط جميعي . ص ١١٩ — الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ١٨١ . ص ١٦٢ .

(٣) منع القضاء من نظر أعمال السيادة . لأستاذنا الدكتور حامد محمد أبو طالب . ص ١٠٤ ، ١٠٧ ، الوسيط . د / عاشور مبروك . بند ٢٣٤ . ص ٢٦٥ .

(٤) السيادة في الإسلام . د / عارف أبو عيد . ص ٢٤ .

لشرع الله ﷻ ، فلا صوت يعلو صوت الحق ، ولا عمل يصدر عن أحد ويكون في منأى عن حدود الشرع وأصوله ، فالكل أمام الشرع سواء^(١) ، لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم ، ولا سيد ومسود ، وهذا هو العدل الإلهي الذي قامت عليه شريعة الإسلام ، ولن ترقى إليه شريعة ولا نظم ولا دساتير إلى يوم القيامة بالغة ما بلغت .

من أجل ذلك كان رؤساء الدول في الشريعة الإسلامية أشخاصاً لا قداسة لهم ولا يتميزون عن غيرهم ، وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب الفرد العادي^(٢) .

فالنظام الإسلامي لا يستثنى أحداً من أحكام الشرع ، رئيساً كان أو مرئوساً ، وزيراً كان أو أميراً ، بل يعمل بأحكامه المتفردة على نشر المساواة الحقبة بين أفراد الأمة والناس أجمعين تلك المساواة التي جسدها رسول الله ﷺ^(٣) في أفعاله وأقواله ، وقد جاء منها قوله ﷺ في الحديث المشهور : (إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)^(٤) .

وليس هذا فحسب بل إن أصحابه ﷺ ضربوا للبشرية جمعاء أروع الأمثلة التي لا تكرر لها مادامت الأرض والسماء فهذا خليفة رسول الله ﷺ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتلو لنا منشور خطابه قائلاً :

-
- (١) السيادة في الإسلام . د / عارف أبو عيد . ص ٢٤ ، ص ١٩٧ ، ص ١٩٨ ، منع القضاء من نظر أعمال السيادة . لأستاذنا الدكتور حامد محمد أبو طالب . ص ١٠٥ .
- (٢) التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي . تأليف عبد القادر عوده . ج ١ بند ٢٣٧ . ص ٣١٧ ط / مؤسسة الرسالة . بيروت . ط / السادسة . ط / ١٤٠٥ هـ — ١٩٨٥ م .
- (٣) السلطات الثلاث . د / سليمان الطماوي . ص ٤١٠ .
- (٤) رواه البخاري . كتاب المغازي . باب من شهد الفتح ٤ / ١٥٦٦ ، حديث رقم ٤٠٥٣ ، ومسلم في كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ٣ / ١٣١٥ . حديث رقم ١٦٨٨ .

(أيها الناس : قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن ضعفت فقوموني ، وإن أحسنت فأعينوني ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، الضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم)^(١) .

المبحث الثالث

أنواع الاختصاص الولائي

الولاية القضائية فى النظام القضائي المصري موزعة على جهتين كبيرتين^(٢) هما:

١- جهة القضاء العادي - وتمثلها المحاكم - وهذه الجهة هى صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات، إلا ما أخرجها المقتن عن ولايتها بنص خاص^(٣) .

٢- جهة القضاء الإدارى - وتمثلها محاكم مجلس الدولة - وهى الجهة ذات الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات الإدارية دون غيرها من المنازعات الأخرى^(٤) .

وفي الدستور المصري الحالي، الصادر في ٢٠١٤م زاد المشرع الدستوري علي هاتين الجهتين جهتين أخرتين، هما جهة القضاء الدستوري - حيث جعل المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها-، وجهة القضاء العسكري - حيث جعل القضاء العسكري أيضا جهة قضائية مستقلة- ، هذا فضلاً عن الجهات القضائية المخصصة التى سبق وأن خصها المقتن - نظراً لمواجهة ظروف معينة - بنوع من الولاية القضائية المحدودة ، بحيث تتولى هذه الجهات

(١) مصنف عبد الرزاق ، كتاب الجامع ، للإمام معمر بن راشد ، رواية الإمام عبد الرزاق ، باب لاطاعة في معصية ٣٦٦/١١ ، حديث رقم ٢٠٧٠٢ ، الكامل في التاريخ لابن الأثير ٦٠/٢ .

(٢) راجع : الدستور المصري الحالي، الصادر في ٢٠١٤م.

(٣) نظرية الاختصاص د/عبد الباسط جميعي ص ٦ .

(٤) قانون القضاء المدني د / محمود هاشم. بند ٨٩. ص ١٦٣ .

الفصل في قضايا محددة على سبيل الحصر، ولا يتعدى نظرها إلى ما عداها، وهذه الجهات المخصصة ليست جهات قضائية بالمعنى الفني الدقيق، وإنما هي أشبه بالكيانات القانونية المخصصة بمواجهة ظروف معينة ومنازعات محددة، وإطلاق اسم الجهة عليها إنما هو من قبيل الاستعمال المجازي دون الحقيقي. **ويطلق على هذه الجهات:** القضاء الاستثنائي أو جهات التقاضي ذات الولاية المحدودة.

وأتناول الحديث عن جهات القضاء الأصيلة في النظام القضائي المصري وجهات القضاء الأخرى ذات الولاية المحدودة والاستثنائية، وذلك بشيء من التفصيل من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول

جهة القضاء العادي (المحاكم)

القضاء العادي والولاية العامة.

النص الدستوري :

نصت المادة " ١٨٨ " من الدستور المصري الحالي ، الصادر في ٢٠١٤م علي أن : " يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شؤونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته " .

وبناء عليه :

يتسم القضاء العادي بأنه الجهة القضائية التي تتمتع بالولاية العامة على كافة المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية ، ولا يخرج عن ولايتها إلا ما استثناه المقتن بنص خاص ، كما هو الشأن في إخراج المنازعات الإدارية عن ولاية المحاكم العادية^(١)، وقد نص المقتن على ذلك في المادة رقم ١٥ من

(١) أصول وقواعد المرافعات. د / أحمد ماهر زغلول بند ٢٦٦ . ص ٥٤١ .

قانون السلطة القضائية ، وقد جاء فيها أن المحاكم تختص بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص^(١) .

ولما كانت المنازعات التى يعقد الاختصاص فيها لجهة القضاء العادى تتنوع وتختلف من حيث القيمة والأهمية ، تدخل المقنن فعند إلى تقسيم القضاء العادى إلى طبقات من المحاكم وقام بتوزيع الولاية القضائية على هذه الطبقات المتعددة على أساس نوع الدعوى أو قيمتها، محدداً بذلك نصيب كل طبقة من هذه الطبقات، فيقال مثلاً أن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الجزئية ، وتلك من اختصاص المحاكم الابتدائية ، وهو ما عرف فى النظام القضائى بالاختصاص النوعى أو القيمى^(٢) .

ونظراً لانتشار المحاكم فى كافة أنحاء الجمهورية فقد رسم المقنن لكل محكمة دائرة اختصاص إقليمى ، وجعل محكمة الإقليم تختص محلياً بما يثار فى دائرتها من منازعات وهذا ما عرف بالاختصاص المحلى^(٣) .

إذن فالمحاكم الجزئية المنتشرة فى كل مركز من مراكز الجمهورية تختص إقليمياً بنظر المنازعات التى تقع فى دائرة اختصاصها الإقليمى ما لم ينص القانون على غير ذلك ، مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعى والقيمى .

هذا، ويضاف إلى طبقات المحاكم المدنية - الجزئية والابتدائية - محاكم الاستئناف التى يعقد لها الاختصاص بكافة الطعون عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ؛ وذلك باعتبارها محكمة أول درجة^(٤) .

هذا والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قد عمد مؤخراً على زيادة المحاكم الابتدائية وقد وسّع من اختصاصها المحلى بحسبان موقعها الإقليمى ، نظراً لحاجة الناس إلى ذلك ومواجهة تكاثر الدعاوى، وقد عالج ذلك بمقتضى القرار

(١) قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م .

(٢) الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ١٨٠ . ص ٢٥٩ .

(٣) الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ١٨٠ . ص ٢٥٩ .

(٤) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٢٧٥ . ص ٣١٧ .

بقانون " ٩٣ " لسنة ٢٠١٥ م ، بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية ^(١).

هذا، فضلاً عن وجود محكمة النقض بمقر العاصمة — القاهرة — وهي ليست درجة من درجات التقاضي وإنما ينعقد لها الاختصاص بالإشراف على تطبيق صحيح القانون ، كما ينعقد لها الاختصاص بنظر الطعون في الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في الحالات التي ينص عليها القانون م٢٤٨ / مرافعات.

وبهذا يتضح أن القضاء العادي، ممثلاً في طبقاته المختلفة هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى من ذلك بنص صريح .

المطلب الثاني

جهة القضاء الإداري (محاكم مجلس الدولة)

النص الدستوري:

نصت المادة " ١٩٠ " من الدستور المصري الحالي، الصادر في ٢٠١٤ م علي أن: " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في دعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " .

وعلي هذا : فيمكن القول بأن اختلاف طبيعة المنازعات الإدارية يعد الأصل القانوني الذي استند إليه المشرع في منح القضاء الإداري — وتمثله محاكم مجلس الدولة بطبقاتها المختلفة — الولاية القضائية لنظر كافة المنازعات الإدارية.

(١) راجع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم " ٩٣ " لسنة ٢٠١٥ م ، بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية ، الصادر بالجريدة الرسمية ، العدد " ٣٣ " تابع " ب " في ١٣ أغسطس ، ٢٠١٥ م ، وقد جاء هذا القانون في سبع عشرة مادة .

وبناءً على هذا : عمد المقتن بما له من سلطة مستمدة من الدستور إلى عقد الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الإدارية للقضاء الإداري^(١) ، وقد نص على ذلك في المادة رقم ١٥ من قانون السلطة القضائية.

ومع مراعاة ما نصت عليه المادة ١٩٠ من دستور ٢٠١٤م سألقة الذكر وما أضافته من اختصاص جديد لمجلس الدولة، كما هو شأن اختصاصه دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى ، نجد المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م، وتؤكد على بقية اختصاص مجلس الدولة، وقد جاء فيها:

(تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :

أولاً : الطعون الانتخابية .

ثانياً : منازعات مرتبات ومعاشات ومكافآت الموظفين .

ثالثاً : الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو بمنع العلاوات .

رابعاً : طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي .

خامساً : طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية .

سادساً : طعون منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون .

سابعاً : دعاوى الجنسية .

ثامناً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات الاختصاص القضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .

تاسعاً : طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

(١) الوسيط. د/أحمد السيد صاوي. بند ١٨٠ . ص ٢٥٩ .

عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أم
تبعية

حادى عشر: منازعات عقود الالتزام، والأشغال العامة أو التوريدات أو أى عقد
إدارى آخر

ثانى عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون .

ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين فى القطاع العام فى
الحدود المقررة قانوناً .

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

وبهذا يتضح أن طبقات محاكم مجلس الدولة، المتمثلة فى كل من المحكمة
الإدارية العليا- والتي يخول إليها سلطة التعقيب النهائى على جميع الأحكام
الصادرة من محاكم مجلس الدولة-، ومحكمة القضاء الإدارى ، والمحاكم الإدارية
، والمحاكم التأديبية، هي التى تختص دون غيرها بالفصل فى سائر المنازعات
الإدارية.

وبناءً على ما تقدم: يعد مجلس الدولة – فى غير هذه الحالات – هو
صاحب الولاية العامة على كافة المنازعات الإدارية .

المطلب الثالث

جهات القضاء ذات الولاية المحدودة

قد يرى المقنن ضرورة لإسناد الاختصاص القضائي في نظر منازعات معينة — ذات طبيعة خاصة، أو لكونها تتعلق بفئة محددة من الأشخاص — إلى جهات أخرى، ويمنحها ولاية قضائية جزئية، بحيث تستقل بنظر تلك المنازعات دون غيرها من جهات القضاء العادي أو الإداري، ويتبع أمامها إجراءات معينة تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة أمام القضاء صاحب الولاية العامة، وتكون أحكامها الصادرة في حدود ولايتها المخصصة ذات الطبيعة الخاصة.

هذا، ويستند المقنن في إنشاء جهات القضاء ذات الولاية المحدودة إلى ضرورة قيامه بواجبه في تحقيق المصالح العامة، ومواجهة الظروف الطارئة، واستعمالاً لحقه المكفول في ذلك بموجب الدستور، حيث نص الدستور المصري على أنه: " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم " .

وبناءً على هذا :

فقد عمل المقنن على وجود جهات أخرى للقضاء إلى جانب جهتي القضاء العادي والإداري، وقد منحها الولاية القضائية المحدودة بأشخاص معينين، أو محدودة بحسبان طبيعة منازعة محل التقاضي، وبذلك أستطيع القول بأن جهات القضاء ذات الولاية المحدودة في النظام القضائي المصري، طبقاً لدستور ٢٠١٤م تتمثل فيما يلي:

١- جهة القضاء الدستوري :

حيث أصبحت المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها بموجب الدستور المصري الحالي، الصادر في ٢٠١٤م .

النص الدستوري :

نصت المادة " ١٩١ " من دستور ٢٠١٤م علي أن : " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة

الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة .

كما نصت المادة " ١٩٢ " من ذات الدستور علي اختصاصات هذه المحكمة بقولها : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

هذا، وقد سبق الحديث عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا وطبيعة الأحكام والقرارات التي تصدر منها، ومدي إلزاميتها للكافة، وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول، عند الحديث عن (ترتيب المحاكم وتشكيلها)، ومن ثم فلا حاجة لنا هنا لتكرار ذلك.

٢- جهة القضاء العسكري :

النص الدستوري :

لقد نصت المادة " ٢٠٤ " من دستور ٢٠١٤م علي أن :

" القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو

مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

وبناء على هذا فإن جهة القضاء العسكري تمثلها المحاكم العسكرية^(١)،
ويقصد بها : المحاكم التي ينعقد لها الاختصاص ولائياً بالفصل في كافة المنازعات والجرائم التي تقع ممن يخضعون لقانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦م^(٢)، والذي أنشئت بمقتضاه المحاكم العسكرية، وتحدد بمقتضاه ولايتها القضائية المحدودة بحسان الأشخاص الذين يخضعون لأحكامه أصلاً أو حكماً، أو بحسبان طبيعة المنازعة محل التقاضي.

فيخضع لأحكام القضاء العسكري، العسكريون، وقادة الجيش وضباط الشرطة ، والأمناء ، والمساعدون ، وضباط الصف والجنود والخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم^(٣).

(١) فالمشرع الدستوري قد جعل القضاء العسكري وما يتبعه من محاكم جهة قضائية مستقلة، وذلك بموجب الدستور المصري الحالي، الصادر عام ٢٠١٤ م .

(٢) الصادر في ٧ / ٦ / ١٩٦٦ م ، والمعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ م ، والمعدل حديثاً بمقتضى القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ ، الصادر في ٢٣ أبريل ، الجريدة الرسمية، العدد ١٦ مكرر "أ" في ٢٣ أبريل ٢٠٠٧ م وقد نص القانون الجديد في مادته الأولى على أن "تستبدل عبارة" قانون القضاء العسكري " بعبارة " قانون الأحكام العسكرية" أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ م ، أو في أي قانون آخر".

(٣) حيث نصت المادة رقم ٩٩ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ م في شأن هيئة الشرطة ، على أنه : " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون القضاء العسكري ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ، ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون القضاء العسكري ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية ، التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون

فهؤلاء جميعاً يخضعون بحسب الأصل لأحكام قانون القضاء العسكري، وذلك عما ارتكبه من مخالفات أو جرائم عسكرية ، إذا لم يكن معهم شريك أو مساهم ممن لا يخضعون لأحكام هذا القانون.

كما يدخل في اختصاص جهة القضاء العسكري ولائياً كل اعتداء علي منشآت أو مقرات أو معدات عسكرية وأشباه ذلك مما يتصل بهذا الشأن .
هذا، وقد سبق وأنشأ المقتن أيضاً قبل ذلك : كيانات قضائية، وحدد هيئات ولجان استثنائية، ومنحها الولاية القضائية علي سبيل الاستثناء من الأصل العام، وقد أطلق على هذا النوع من القضاء " القضاء الاستثنائي " ، ومن أهم أمثلة هذا النوع ما يلي :

١- محاكم أمن الدولة :

ويقصد بها : المحاكم التي تحمي مصالح خاصة ذات وصف محدد ، وتتعلق بفئة معينة من الأشخاص^(١).

ينظم هذه المحاكم القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ م ، ومن ثم يحدد اختصاصها ، وكيفية تشكيلها ، والإجراءات التي تتبع أمامها^(٢) ، هذا وتتسم الأحكام التي تصدر عن محاكم أمن الدولة العليا^(٣) بأنها أحكام نهائية لا تقبل الطعن إلا بطريق النقض وإعادة النظر^(٤) ، أما الأحكام التي تصدر عن محاكم أمن الدولة الجزئية^(٥) فهي

المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " . معدلة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧م
(١) قانون القضاء المدني د / فتحي والي . بند ١٦٧ ص ٣٩٤ ، قانون القضاء المدني . د / عزمي عبد الفتاح . ص ٣٢٥ .

(٢) وقد صدر هذا القانون في ٢٠ مايو سنة ١٩٨٠م ، ونشر بالجريدة الرسمية في العدد "٢٢" ، مكرر في ٣١ مايو ١٩٨٠ .

(٣) حيث تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف المنصوص عليها قانوناً محكمة أمن دولة عليا أو أكثر .

(٤) قانون القضاء المدني . د / محمود هاشم . بند ١١٧ . ص ٢٠٥ .

(٥) حيث تنشأ في مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر .

تقبل الطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ، والتي يطعن فى أحكامها بالنقض وإعادة النظر (١) .

٢- هيئات ولجان إدارية ذات اختصاص قضائي.

تتعدد الهيئات واللجان الإدارية التي منحها المقنن الولاية القضائية المحدودة بمنازعات معينة، تختص بالفصل فيها دون غيرها من الجهات القضائية الأخرى، وذلك وطبقاً للقواعد الدستورية والقانونية المعتبرة في هذا الشأن (٢).

وذلك نظراً لطبيعة هذه المنازعات، وما يستلزمه الفصل فيها من توافر خبرات فنية، قد لا تتوفر في قضاة الجهات القضائية الأصلية (٣)، فضلاً عن الحاجة إلى سرعة الفصل في هذه المنازعات، على نحو تتحقق بمقتضاه المرونة الحقة في العمل القضائي، وتُبَسَّط معه الإجراءات، وتقل فيه النفقات (٤).

ومن أمثلة هذه الهيئات واللجان :

- أ- هيئات التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام أو بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام.
 - ب- لجان فض المنازعات.
 - ج- لجان الفصل في المنازعات الزراعية.
 - د- لجان شئون الضباط.
 - هـ- اللجنة المختصة بتقدير أتعاب المحامي.
- وغير ذلك من اللجان الأخرى، التي ينشئها المقنن، ويمنحها سلطة الحكم القضائي بقواعد وشروط مخصوصة.

(١) قانون القضاء المدني . د / محمود هاشم . بند ١١٧ . ص ٢٠٥ .

(٢) الدفع بعدم الاختصاص أ/علي حسن عوض . ص ٢٤ .

(٣) تحديد نطاق الولاية القضائية . د/أحمد مليجي . ص ٥١٤ .

(٤) قانون القضاء المدني . د / عزمي عبد الفتاح ص ٣٢٥ .

الفصل الثاني الاختصاص النوعي

ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الاختصاص النوعي وأهميته ومعاييره .

المبحث الثاني : القضاء المستعجل .

المبحث الأول الاختصاص النوعي أهميته ومعايره

يعد الاختصاص النوعي الأساس القانوني الذي يتم بمقتضاه توزيع الولاية القضائية بين طبقات المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة .
وبناءً عليه :

يمكن القول بأن الاختصاص النوعي يقصد به لدى شرّاح القانون الإجرائي: " نصيب كل محكمة من الدعاوى التي يحددها القانون وفقاً لنوع الدعوى وطبيعتها ، ويخول لها سلطة الفصل فيها دون غيرها من الدعاوى الأخرى " (١) .
وبهذا يتضح أن المعتبر قانوناً في تحديد اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم المختلفة هو نوع الدعوى دون اعتبار لقيمتها أو مكانها.

وبناءً على هذا: يتحدد اختصاص القاضي نوعياً ، فيقال مثلاً اختصاص القاضي بنظر الدعاوى المدنية أو التجارية أو الجنائية ، أو الأسرة (٢) ، أو الدعاوى المستعجلة ، أو اختصاصه بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة بعينها ، أو اختصاصه بالمنازعات العمالية ، أو التنفيذية – المتعلقة بالتنفيذ الجبري – أو اختصاصه بالإشراف على تطبيق صحيح القانون والمنع من مخالفته – كما هو شأن محكمة النقض – حيث يعد هذا تحديداً للاختصاص القضائي ، وفقاً لنوع الدعوى ، وذلك في كل طبقة من طبقات المحاكم المختلفة.

أهمية الاختصاص النوعي :

يحقق الاختصاص النوعي العديد من المزايا التي تؤكد أهميته في النظام القضائي ، حيث يترتب عليه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ، مما يؤدي إلى تسهيل

(١) الوسيط د/ نبيل إسماعيل عمر . بند ٢٤ ص ٩٩ ط . دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية ط . ١٩٩٩ م ، مبادئ القضاء المدني د / وحدى راغب ص ٢٨٢ ، ط . دار النهضة العربية بالقاهرة ط . الثالثة ٢٠٠١ م ، الموسوعة الذهبية في الدفوع أ / عبد العزيز سليم ص ١٢٨ ، ١٢٩ .
(٢) قانون القضاء المدني د/محمود هاشم . بند ٢٣١ ص ٣٦٠ .

أعمال القضاة وإجراءات التقاضي ، ويحقق سرعة الفصل في الدعاوى ، ويؤكد على مبدأ احترام قواعد الاختصاص والعمل على عدم مخالفتها^(١) ، حتى لا يقع التضارب في الأحكام ، مما يطول معه التخاصم بين المتنازعين لدى القضاة والحكام .

معايير تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم :

لقد حدد المقنن الاختصاص القضائي لمحاكم القضاء المدني وفقاً لنوع الدعوى أو أهميتها ، كما أنه أخذ بمعيار طلب الحماية الوقتية بالنسبة للدعاوى المستعجلة ، باعتباره الأساس القانوني الذي يتحدد بمقتضاه اختصاص القضاء المستعجل ، وبناء على هذين المعيارين فقد وزع المقنن ولاية القضاء على مختلف محاكم القضاء المدني – طبقات المحاكم – بما في ذلك التشكيلات القضائية المتخصصة التي تتبع جهة القضاء المدني^(٢) .

وتأسيساً على هذا يتحدد الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء المدني

المعيارين التاليين :

١- معيار أهمية موضوع الدعوى .

لقد اتخذ المقنن من أهمية موضوع الدعوى معياراً قانونياً قسم على أساسه ولاية القضاء المدني بين طبقات المحاكم المختلفة ، لذا فقد فرق وهو بصدد تحديد الاختصاص النوعي لكل طبقة من طبقات المحاكم بين الدعاوى ذات الأهمية والأخرى قليلة الأهمية ، فخص المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى كبيرة الأهمية دون غيرها ، في حين جعل اختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى قليلة الأهمية^(٣)

(١) المرافعات د/أحمد أبو الوفا بند ٣٥٧ ص ٤٠٤ .

(٢) قانون القضاء المدني د / محمود هاشم بند ١٣١ ص ٣٦٠ .

(٣) أصول وقواعد المرافعات. د/أحمد ماهر زغلول بند ٢٦٦ ، ص ٥٤٢ .

ولما كان النظام القضائي المصري يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين فسوف أقصر دراسة الاختصاص النوعي على درجتى القضاء المدني ، وذلك على النحو التالي :

الاختصاص النوعي لقضاء الدرجة الأولى ، ويتمثل فيما يلي :

١ - المحاكم الجزئية :

تعد المحاكم الجزئية المنتشرة في جميع مراكز الجمهورية محاكم درجة أولى دائماً^(١) ، وهى تختص نوعياً بالفصل فى الدعاوى قليلة الأهمية التى جعلها المقنن من اختصاصها دون غيرها من المحاكم الأخرى ، ويعد اختصاص هذه المحاكم بنظر تلك الدعاوى اختصاصاً أصلياً ، وهو يتحدد وفقاً لنوع الدعوى بغض النظر عن قيمتها المالية^(٢) .

هذا وقد قرر المقنن الاختصاص النوعي للأصلى للمحاكم الجزئية بمقتضى المادة " ٤٢ " من قانون المرافعات ، حيث نصت على أن : " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تتجاوز قيمتها أربعون ألف جنيه ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه .. " ^(٣) .

والجدير بالذكر أن هذه المادة تؤكد علي أن المقنن جعل الولاية القضائية للمحاكم الجزئية ولاية أصيلة محدودة بنوع الدعوى - وهى كونها مدنية أو تجارية

(١) قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم. بند ٢٣٢ . ص ٣٦١ .

(٢) مبادئ القضاء المدني د / وجدى راغب ، ص ٣٠١ .

(٣) وفقاً لآخر التعديلات ؛ حيث عدلت هذه المادة بمقتضى قوانين متعاقبة ، وقد كان آخرها القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧م الجريدة الرسمية ، العدد ٢٢ مكرر الصادر فى ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤٢٨ هـ الموافق ٦ يونية ٢٠٠٧م ، والمعمول به اعتباراً من ١/١٠/٢٠٠٧م ، وقد نص فى مادته الأولى على أن : " تستبدل عبارة أربعين ألف جنيه بعبارة عشرة آلاف جنيه ، وعبارة خمسة آلاف جنيه بعبارة ألفى جنيه أينما وردت أى منهما فى المواد ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٧ ، ٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية " .

-، ومن ثم فلا اعتبار لقيمتها المالية، لأن القيمة هنا إنما تفيد لمعرفة كون الحكم ابتدائياً أو انتهائياً، وحديثنا هنا إنما هو عن النوع دون القيمة.

وإذا كان المقنن قد حدد الاختصاص الأصلي النوعي لمحاكم المواد الجزئية فقد منحها أيضاً اختصاصاً نوعياً استثنائياً في نظر بعض الدعاوى، وهذا الاختصاص لا يتقرر لهذه المحاكم إلا بنص خاص^(١)، ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

وبناءً على هذا فقد نص المقنن في المادة ٤٣ على أن: " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى، وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه^(٢) فيما يلي :

- ١- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
- ٢- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
- ٣- دعاوى قسمة المال الشائع .
- ٤- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديد^(٣)ها .
- ٥- دعاوى صحة التوقيع أيأ كانت قيمتها .
- ٦- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر

(١) أصول وقواعد المرافعات . د / أحمد ماهر زغلول . بند ٢٦٨ ، ص ٥٤٤ ، القانون القضائي الخاص د/إبراهيم نجيب سعد . بند ١٧٦ ص ٤٢٨ .

(٢) معدلة بمقتضى القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م ، انظر المادة الأولى من هذا القانون .

(٣) بند " ٤ " من المادة " ٤٣ " مضاف بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ م ، الجريدة الرسمية ، العدد ٢٢ مكرر في ١ / ٦ / ١٩٩٢ م .

نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى^(١) .

هذا وترجع الحكمة من إسناد الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحاكم الجزئية — على سبيل الاستثناء — أياً كانت قيمتها المالية إلى بساطة هذه الدعاوى وشيوعها ، وظهور وجه الحق فيها ، وعدم إثارتها للمشاكل القانونية ، أو حاجتها إلى مزيد من الخبرات الفنية ، فضلاً عن قربها من مواطن الخصوم^(٢) .

التعليق على البند السادس من المادة (٤٣) مرافعات

كان من الأولى بالمقنن إسناد الاختصاص بنظر دعاوى تسليم العقارات للمحكمة الابتدائية التي يقع العقار المراد تسليمه في دائرتها ، وذلك نظراً لأهمية هذه الدعاوى والآثار المترتبة عليها ، فلا يعقل إسناد الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لقاضٍ فرد في المحكمة الجزئية .

وبعد هذا البيان الموجز لاختصاص المحاكم الجزئية النوعي بشقيه الأصلي والاستثنائي .

يمكن القول بأنه يعد من قبيل الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية أيضاً اختصاص محكمة القاهرة الجزئية التجارية ، ومحكمة الإسكندرية الجزئية التجارية^(٣) ، وكذلك اختصاص محاكم العمال الجزئية^(٤) والتي عقد لها

(١) البندان رقما " ٥ " ، " ٦ " من المادة " ٤٣ " بندان جديان مضافان بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م . حيث نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن : " يضاف إلى المادة " ٤٣ " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بندان جديان برقمي " ٥ " ، " ٦ " .

(٢) قانون القضاء المدني. د/محمود هاشم. بند ٢٣٢. ص ٣٦١.

(٣) المادة ١٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م ، وإعمالاً لهذا فقد صدر قرار وزير العدل في سنة ١٩٤٠ م بإنشاء هاتين المحكمتين .

(٤) وقد كان إنشاء هذه المحاكم تنفيذاً لقرار وزير العدل الصادر في سنة ١٩٥٣ م .

الاختصاص بنظر المنازعات العمالية بدوائر المحاكم الابتدائية بالقاهرة وبنها والإسكندرية وبور سعيد^(١) .

٢ - المحاكم الابتدائية : " بوصفها محكمة درجة أولى " :

تعد المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، وبهذا فهي تختص نوعياً بنظر الدعاوى التي جعلها المقنن من اختصاصها ، أو بمعنى أوضح يتحدد الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما أخرجها المقنن بنص خاص ، وجعل الاختصاص به منعقداً لغيرها من المحاكم الجزئية^(٢) .

وبناءً على هذا تختص المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة درجة أولى اختصاصاً أصلياً وفقاً لنوع الدعوى بالحكم ابتدائياً في جمع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه^(٣) م " ٤٧ " من قانون المرافعات^(٣) .

هذا وقد جعل المقنن لهذه المحاكم اختصاصاً نوعياً بنظر بعض الدعاوى أيضاً كانت قيمتها المالية ولو كانت أقل من نصابها ، وذلك على سبيل الاستثناء ، لما رآه المقنن من أهمية لهذه الدعاوى ، ودقة ما تثيره من مشاكل قانونية تستلزم ضرورة نظرها أمام قضاة متعددين ، وأصحاب خبرة أكثر لذا فقد عقد الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحاكم الابتدائية.

واختصاص هذه المحاكم بنظر تلك الدعاوى هو اختصاص نوعي — يتحدد وفقاً لنوع الدعوى — استثنائي لا يتقرر إلا بنص صريح من القانون .

(١) قواعد المرافعات. أ/محمد العشماوي، د/عبد الوهاب العشماوي. جـ ١. بند ٣٠١. ص ٣٨٣

هامش رقم " ٢ " ، الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ١٩٦ . ص ٢٧٤ .

(٢) القانون القضائي الخاص. د / إبراهيم نجيب سعد . بند ١٧٥ . ص ٤٢٨ ، المرافعات . د /

أحمد أبو الوفا. بند ٢٧٦ . ص ٣١٨ ، الوسيط . د/أحمد السيد صاوي . بند ١٩٩ . ص ٢٧٧ .

(٣) معدلة بمقتضى القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م .

وهذا ما أكدته المقنن بمقتضى نص المادة ٤٢ / ٢ من قانون المرافعات التى نصت على : " .. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى ، وغير ذلك مما نص عليه القانون " (١) .

وبناءً عليه تختص المحاكم الابتدائية دون غيرها بالفصل فى دعاوى الإعسار المدنى ، وغير ذلك مما ينص عليه القانون صراحة.

الاختصاص النوعى لقضاء الدرجة الثانية :

يشتمل هذا القضاء على المحاكم التى تنظر الطعن فى الأحكام وهى :

أ- **المحاكم الابتدائية : " بوصفها محكمة استئنافية " :**

تختص المحاكم الابتدائية نوعياً بالمنعقدة بهيئة استئنافية (٢) بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من محاكم المواد الجزئية فى حدود نصابها الإبتدائي ، وكذلك الأحكام الصادرة عن قاضى الأمور المستعجلة (٣) .

(١) عدلت هذه المادة فى فقرتها الأولى فيما يتعلق بنصاب المحكمة الجزئية بمقتضى القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م . انظر المادة الأولى من هذا القانون .

(٢) أصول وقواعد المرافعات. د/ أحمد ماهر زغلول . بند ٢٦٩ . ص ٥٤٤ ، وبهذا يتضح أن المحكمة الابتدائية لها اختصاصان : أحدهما باعتبارها محكمة أول درجة تنظر النزاع لأول مرة ، والآخر باعتبارها محكمة ثاني درجة تنظر النزاع لثاني مرة ، وتسمى فى هذه الحالة بالمحكمة الابتدائية الإستئنافية ، وتشكيل المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة لا يختلف عن تشكيلها كمحكمة ثاني درجة ، ففي تلك الحاليتين تتشكل من ثلاثة أعضاء " م ٩ / ٤ من قانون السلطة القضائية " ، ويوزع العمل فى المحكمة على دوائر ابتدائية ، ودوائر استئنافية ، انظر : الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . ص ٢٧٧ . هامش رقم " ٢ " .

(٣) وهذا ما قرره المقنن فى المادة " ٤٧ / ٢ " من قانون المرافعات عندما بين اختصاص المحكمة الابتدائية كمحكمة درجة أولى ذكر اختصاصها كمحكمة ثاني درجة فقال : " وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الإستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة " . انظر تعديل هذه المادة بمقتضى القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م . المادة الأولى من هذا القانون .

ب - محاكم الاستئناف العليا :

تعد محاكم الاستئناف العليا محاكم درجة ثانية دائماً^(١) ، حيث تختص بنظر الطعون المقدمة إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية — بوصفها محكمة درجة أولى — في حدود نصابها الابتدائي المقرر قانوناً ، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات متى رفعت بصفة أصلية^(٢) .

٢- معيار طبيعة المنازعة أو الطلب

لقد عمد المقتن في النظام القضائي المصري على تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم المدنية وفقاً لطبيعة المنازعة أو الطلب محل الدعوى ، ويتضح هذا من خلال المنهج الذي سار عليه المقتن في تخصيص قضاء درجتى المحاكم الجزئية والابتدائية ، ومن أمثلة التخصيص النوعي لهذه المحاكم ما يلي :

١ - اختصاص إدارة التنفيذ التي تنشأ بمقرر كل محكمة ابتدائية ، أو أحد

فروعها التي تنشأ لها بمقتضى قرار وزير العدل بدائرة محكمة جزئية

بالإشراف على التنفيذ

وبهذا يتضح أن اختصاص إدارة التنفيذ بالإشراف على مسائل التنفيذ هو اختصاص نوعي محدد وفقاً للقانون طبقاً لمعيار طبيعة المنازعة . وكذلك اختصاص قاضى التنفيذ نوعياً دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية ، والوقتية أياً كانت قيمتها.

(١) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٢٧٨ . ص ٣١٩ ، الوسيط . د / نبيل إسماعيل عمر . بند ١٤٤ . ص ٨٤ .

(٢) المادة " ٤٨ " من قانون المرافعات ، وقد نصت على أن : " تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية ، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة ٤٣ من هذا القانون " ، وهذه المادة مستبدلة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م .

وكذلك اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بالفصل في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها^(١).

وكذلك اختصاص قاضي الأمور المستعجلة نوعياً دون غيره بنظر الدعاوى المستعجلة " القضاء المستعجل "؛ لأن المقرر قانوناً أن الاختصاص بنظر الدعاوى المستعجلة ينعقد نوعياً لقاضي الأمور المستعجلة^(٢).

(١) المادة " ٢٧٧ " وهي مستبدلة بقانون المرافعات الجديد ، رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م ، وقد نصت وفقاً لهذا القانون على أن : " تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية " ، وقد كانت تنص قبل صدور هذا القانون على أن : " تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك ، وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية " . وبناء على هذا فقد حذف المقتن هذا النص الأخير واستبدله بالنص الذي سبق ذكره وفقاً لقانون المرافعات الجديد المشار إليه ، وبهذا فقد جعل الاختصاص بنظر قضايا الاستئناف التي ترفع عن أحكام قاضي التنفيذ المتعلقة بالتنفيذ ، سواء أكانت منازعات وقتية أم موضوعية للمحكمة الابتدائية — وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي — دون غيرها أيًا كانت قيمة المنازعة ، وهذا مما يؤيد فكرة تحديد الاختصاص النوعي طبقاً لمعيار طبيعة المنازعة .

(٢) قاضي الأمور المستعجلة قد يكون محكمة الأمور المستعجلة التي توجد بالمدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية، متى رفعت الدعوى بصفة أصلية ، وهو أحد قضاة المحكمة الابتدائية يندب؛ ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة ، وذلك أيًا كانت قيمة الدعوى ، وأيًا كانت قيمة الحق الموضوعي محل الدعوى المستعجلة ، وقد يكون قاضي الأمور المستعجلة قاض يندب في المحكمة الجزئية — وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي — ، وذلك بالنسبة للدعاوى التي ترفع خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية ، وقد يكون قاضي الأمور المستعجلة هو قاضي التنفيذ وذلك بالنسبة للمنازعات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ ، حيث ينعقد له الاختصاص دون غيره بنظر المنازعات الوقتية والموضوعية المتعلقة بالتنفيذ ولو كان داخل المدينة التي بها محكمة ابتدائية، وقد أجاز المقتن لمحكمة الموضوع أن تفصل في الطلبات الوقتية أو المستعجلة التي ترفع إليها تبعاً للدعوى الموضوعية بصرف النظر عن قيمة الطلب المستعجل ، ومحكمة الموضوع قد تكون محكمة جزئية ، وقد تكون محكمة ابتدائية . انظر : أصول المرافعات . د/أحمد مسلم . بند ٢٢٨ . ص ٢٤٨ ، قانون القضاء المدني . د/فتحي والي . بند ٢١١ . ص ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، قانون القضاء المدني د / محمود هاشم . بند ٢٣٧ . ص ٣٦٨ ، ٣٦٩ .

ويقوم هذا الاختصاص على أساس توافر شرطى الاستعجال ، وطلب الحماية الوقتية بصفة مستعجلة^(١) ، فالمعيار هنا ليس هو رغبة الخصوم فى الحصول على حماية وقتية عاجلة ، وإنما هو معيار الوصف القانونى للدعوى ، ومن ثم إذا تخلف هذا الوصف "الاستعجال والوقتية" ، تعين على المحكمة القضاء بعدم الاختصاص^(٢).

هذا، ولما كان القضاء المستعجل علي درجة من الأهمية ، وهو قضاء نوعي يدخل ضمن ولاية القضاء العادي ويتعلق بنوع وطبيعة الدعوي محل التقاضي ، ومن ثم فهو ليس قضاء مستقلا، وإنما هو من قبيل ولاية القضاء العادي، بيد أنه نظراً لأهميته وفاعليته في النظر العلمي والواقع العملي، فقد آثرنا إفراده بالحديث في فرع مستقل، نتناوله الآن بشيئ من التفصيل فى هذا الموضع.

وانظر المادة " ٤٥ " من قانون المرافعات ؛ حيث نصت على أن : " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة ، التي يخشى عليها من فوات الوقت ، أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية ، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذ رفعت بطريق التبعية " .

وبهذا يتضح أن الاختصاص بنظر المسائل المستعجلة هو اختصاص نوعي مقرر للقضاء الجزئي متى رفعت بشأنها دعوى بصفة أصلية .

(١) المرافعات د/أبو هيف . بند ١٠٥٣ . ص ٧٤٢ — أصول المرافعات د/أحمد مسلم . بند ٢٢٨ . ص ٢٤٨ .

(٢) قانون القضاء المدني . د/فتحي والي . بند ٢١١ . ص ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، نظرات في الإحالة لعدم الاختصاص القضائي . د/محمود مصطفى يونس . بند ١٣ . ص ٣٢ . ط . دار النهضة العربية . ط . الأولى ١٩٩٨ م .

المبحث الثاني القضاء المستعجل

النص القانوني :

نصت المادة م(٤٥) مرافعات على أن: " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها؛ ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".

فالمنازعة التي تكون في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية يكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. ويفهم من هذا النص أن المحاكم الجزئية تختص بالدعوى المستعجلة ولكن هذا الاختصاص لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها تبعاً للدعوى الموضوعية.

ماهية القضاء المستعجل، وبيان ضرورته:

لقد اجتهد الفقه الإجرائي في رسم حدود القضاء المستعجل وبيان حقيقته، ومن ثم فقد عرفه بعض الفقه^(١) بأنه : " الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة، أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين".

ذلك أن صاحب الحق قد يتأخر بعض الوقت في رفع دعواه الموضوعية حتى يستعد لها تمام الاستعداد، وحتى بعد رفعه الدعوى فإن الأمر قد يتطلب منح الخصوم آجالاً للحضور والاستعداد للدفاع، كما يستوجب على المحكمة التروى والتأني في فحص الدعوى، وتحقيق وقائعها، وفحص أدلتها، وإصدار الحكم فيها، وقد يطول أمد التقاضي، سواء أكان ذلك بحسن نية أم بسوءها، وفي هذه الأثناء قد

(١) استاذنا الدكتور عبد الباسط جميعي - يرحمه الله - في مبادئ المرافعات، ص ١٢٩.

تتعرض أدلة الدعوى للزوال، كأن يكون الشاهد مريضاً يخشى موته أو مسافراً يخشى غيابه، أو يزول أثر الاعتداء على الحق بمضى الوقت، كجفاف الأرض التي أغرقت بالمياه ونحو ذلك.

وهكذا فهذه الأمور وأشباهها تستدعي تدخل القضاء بإجراءات وقتية لفرض حماية مؤقتة وسريعة للمحافظة على الحقوق الظاهرة، لحين الفصل نهائياً في موضوع النزاع الأصيل، حتى لا تضار مصالح الخصوم من طول إجراءات التقاضي؛ لذلك: جعل المقتن بجانب القضاء الموضوعي قضاءً مستعجلاً، يمنح صاحب الشأن حماية مؤقتة وعاجلة وفقاً لظاهر الحال كما يبدو من الأوراق إلى أن تحكم المحكمة في الموضوع الأصيل دون أن تنقيد بما صدر من المحكمة بشأن قضائها المستعجل.^(١)

المحاكم المختصة بالدعوى المستعجلة:

أولاً: الاختصاص النوعي:

لما كان نص المادة (٤٥) مرافعات يفيد أنه: يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية، فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

وبناء على هذا النص : فإن الدعوى المستعجلة إذا رفعت مستقلة عن الدعوى الموضوعية فإنها ترفع إلى محكمة الأمور المستعجلة، ويختلف الوضع في المدن التي بها مقر المحكمة الابتدائية عن المدن الأخرى على النحو الآتي:

في المدن التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية (عواصم المحافظات) يختص بنظر الدعوى المستعجلة قاض من قضاة المحكمة الابتدائية، يندب في مقر

(١) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٣٥٢، ٣٥٣.

المحكمة؛ ليحكم دون غيره في الدعاوى المستعجلة الخاصة بالمدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية، ومع ذلك فهي محكمة جزئية وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية (استئناف كلي).

وعلى ذلك ففي عاصمة كل محافظة توجد محكمة للأمور المستعجلة، تختص بنظر المنازعات المستعجلة، التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية في هذه المدينة، أما في غير المدن التي توجد بها مقر المحكمة الابتدائية، فإن الاختصاص بالدعاوى المستعجلة ينعقد للمحكمة الجزئية بالمركز.

وهذا، إذا رفعت الدعوى المستعجلة مستقلة عن الدعوى الموضوعية.

أما إذا رفعت الدعوى المستعجلة تبعاً للدعوى الموضوعية، فالمحكمة التي تختص بالموضوع تختص بنظر الطلب المستعجل، سواء أكانت محكمة جزئية أم كلية، وسواء أكانت محكمة أول درجة أم محكمة ثاني درجة.

كما يستوى أن يرفع الطلب المستعجل في صحيفة الدعوى، أو يقدم كطلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصلية.^(١)

وبناء عمكن القول أن محكمة الأمور المستعجلة لا تستقل بهذا الاختصاص، وإنما تشاركها محكمة الموضوع.

والخيار هنا لصاحب الشأن، الذي يريد أن يقدم طلباً مستعجلاً، كما هو شأن من يرفع دعوى ملكية مزرعة دواجن، وأثناء سير الدعوى أراد أن يقدم طلباً بوضع المزرعة تحت الحراسة، فهنا يجوز له أن يقدم هذا الطلب للمحكمة التي تنظر الموضوع، كما يجوز له أيضاً أن يقدم هذا الطلب مستقلاً لمحكمة الأمور المستعجلة.

ثانياً: الاختصاص المحلي:

وفقاً لنص المادة (٥٩) مرافعات إذا كانت الدعوى بطلب إجراء وقتي كالحراسة أو إثبات الحالة ينعقد الاختصاص للمحكمة المستعجلة، التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

(١) الوسيط، د. أحمد السيد صاوي، ص ٣٦٩ وما بعدها.

أما إذا كانت الدعوى عبارة عن منازعة وقتية من منازعات التنفيذ، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها.

التفرقة بين الدعوى المستعجلة والدعوى الموضوعية التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال:

هنا يجب عدم الخلط بين الدعاوى المستعجلة والدعاوى الموضوعية التي قد يوجب القانون نظرها على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال.

ذلك أن المقنن قد ينص أحياناً على نظر الدعوى "على وجه السرعة"، أو "على وجه الاستعجال"، تقديراً منه لظروف وطبيعة هذه الدعاوى.

كما هو شأن ما نصت عليه المادة (٢٥٠) مدني: "يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنتظر الدعوى على وجه السرعة".

وأيضاً: ما نصت عليه المادة (٣/٨٩٠) مدني في شأن نظر دعوى المنازعة في صحة الجرد وأنه "تقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال".

وما نصت عليه المادة (٩٤٣) مدني: "ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتفيد بالجدول، ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة".

ففي هذه الحالات وأمثالها يوجه المقنن قاضي الموضوع أن يفصل في هذا النزاع على وجه السرعة؛ نظراً لطبيعته.

ولكن هذا لا يغيّر من طبيعة الدعوى في أنها دعوى موضوعية، وتسرى عليها أحكام الدعوى الموضوعية، من حيث طريقة رفعها ونظرها وحجية الحكم الصادر فيها، ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام الدعوى المستعجلة "التي تخضع لإجراءات

ومواعيد خاصة، ويحوز الحكم الصادر فيها حجية مؤقتة، تزول بزوال دواعيه، أو بصدر حكم في موضع النزاع".^(١)

شروط اختصاص القضاء المستعجل:

قد ينص القانون على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر منازعات معينة، من ذلك مثلاً دعوى سماع شاهد، (المادة ٩٦ من قانون الإثبات)^(٢)، ودعوى إثبات الحالة، (المادة ١٣٣ من قانون الإثبات)^(٣)، ودعوى الترخيص بإيداع المعروض من غير النقود بالمكان الذي يعينه القاضي (المادة ٤٨٨ مرافعات).^(٤)

(١) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٣٥٥، ٣٥٦، الوسيط، أ.د. فتحي والي، ص ١٢٨.

(٢) ونصها "يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود".

(٣) وتتص على أنه "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة".

(٤) ونصها: "إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة".

ففي هذه الحالات وأمثالها تكون الدعوى مستعجلة بنص القانون.
وإلى جانب هذه الحالات وأشباهها جعل المقنن القضاء المستعجل مختصاً بنظر المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت.

وبمعنى آخر لا يتحدد اختصاص القضاء المستعجل بحسبان رغبة المدعى وحدة أو الخصوم جميعاً في الوصول إلى حكم سريع، وإنما يتحدد الاختصاص بحسب المنازعة، وكونها من المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، كأن يخشى مثلاً أن تضيع معالم الواقعة محل النزاع، أو أن يهلك محل الحق المتنازع عليه، أو أن تفوت فرصة الانتفاع بالحق، أو أن يقع اعتداء يهدد الحق إلى غير ذلك من صور الاستعجال الموضوعي، والذي لا يرجع فيه لمجرد رغبة الخصوم في الحصول على حكم عاجل، وإنما بحسبان ظروف وطبيعة المنازعة محل التقاضي.

فإذا أغرق شخص مثلاً أرض جاره المزروعة أو المعدة للزراعة، أو توقف مقاول عن إتمام بناء تعهد بإتمامه في وقت معين، أو كان النزاع على ملكية عين تحت يد أحد الخصوم، ويخشى أن يبدها نكاية في خصمه، أو رفض مستأجر رد العين المستأجرة رغم انتهاء الإجارة، أو شرع شخص في إقامة جدار على أرضه بقصد حرمان جاره من حق مطلق له عليها، ففي كل هذه الأحوال تعتبر المنازعة مستعجلة، لأن مضي الوقت يضر بصاحب الحق^(١)، وحتى يكون القضاء المستعجل مختصاً بالمنازعة يلزم توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: توافر الاستعجال:

وفقاً لنص المادة (٤٥) فإن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق بالمسائل المستعجلة، التي يخشى عليها من فوات الوقت، وعلى ذلك فتوافر الاستعجال شرط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

(١) أصول المرافعات، أ.د. أحمد مسلم، ص ٢٤٩.

ويعرف بعض الفقهاء^(١) الاستعجال بأنه: "الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح، التي يراد المحافظة عليها"، ويتوافر الاستعجال عندما توجد حالة يترتب على فوات الوقت فيها حصول ضرر منها يتعذر تداركه أو إصلاحه.

وللخشية من فوات الوقت مظهرات:

أولهما: الخشية من زوال المعالم، كأن يقوم جار بإغراق أرض جاره بالمياه، وفوات الوقت هنا يؤدي إلى جفاف الأرض وزوال معالم الواقعة، التي سيستند إليها صاحب الأرض في دعوى التعويض، ومن ثم يرفع دعوى إثبات الحالة.

ثانيهما: الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق، كأن يتلف المستأجر العين المؤجرة عند تركها بحيث لا تصلح للاستعمال، فمضي الوقت هنا لا يذهب المعالم، ولكن يترتب عليه تقويت حق المؤجر في الانتفاع بالعين أو تأخير الانتفاع بها.

والاستعجال هنا يرجع لطبيعة الدعوى ولا يرجع لرغبة الخصوم؛ لأن اتفاقهم باطل لمخالفته للنظام العام، هذا ويجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يتحقق من توافر شرط الاستعجال فإن لم يكن متوفرا حكم بعدم اختصاصه وأحال المنازعة لقاضي الموضوع إن كان لذلك محل.

والعبرة بتوافر الاستعجال وقت رفع الدعوى، ولكن إذا زال الاستعجال أثناء نظر الدعوى، فالراجح أن ذلك يزيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ومن ثم يلزم توافر شرط الاستعجال في الدعوى لحين الحكم فيها.^(٢) هذا ويلاحظ أن هناك بعض الحالات^(٣) قد افترض فيها المقنن توافر شرط الاستعجال ومن ثم

(١) أستاذنا الدكتور عبد الباسط جميهي - يرحمه الله - في مبادئ المرافعات، ص ١٢٩.

(٢) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٣٥٩.

(٣) قواعد المرافعات لمحمد العشماوي، د. عبد الوهاب العشماوي ص ٢٥٣ وما بعدها، مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميهي - يرحمه الله - ص ١٢٩ وما

يعتبر شرط الاستعجال متوفراً، وليس للقاضي سلطة تقدير تحققه، ومن ذلك إشكالات التنفيذ المنصوص عليها بالمادة (٢/٢٧٥) مرافعات، وحالة طلب تقدير مبلغ يودعه الطالب خزانة المحكمة، ويخصص للوفاء بمطلوب الحاجز المنصوص عليها بالمادة (٣٠٣) مرافعات^(١)، ودعوى قصر الحجز المنصوص عليها بالمادة (٣٠٤) مرافعات^(٢)، وحالة إجراء الترميمات العاجلة المنصوص عليها بالمادة (٨٥٩) مدني^(٣).

الشرط الثاني: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً أو تحفظياً لا يمس أصل الحق:
وفقاً لنص المادة (٤٥) يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة أن يكون المطلوب في الدعوى إجراءً وقتياً أو تحفظياً، وقد عبرت المادة عن ذلك بقولها " ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق".

وعلى ذلك فالقاضي المستعجل لا يطلب منه إلا إجراءً وقتياً أو تحفظياً، مثل طلب تعيين حارس على العين المتنازع عليها لحين صدور حكم في موضوع النزاع الأصلي، وكطلب نفقة وقتية لحين صدور حكم يقرر النفقة الموضوعية المتنازع عليها، وكطلب السماح لطالب بأداء الأمتحان مؤقتاً لحين الفصل في النزاع الموضوعي، وهو يدور حول مدى أحقية الطالب في الالتحاق بالكلية، وكطلب وقف قرار فصل طالب لحين الفصل في الموضوع الأصلي، وهو ثبوت

بعدها، قانون المرافعات، د. أحمد هندي، ص ٣٢٥ وما بعدها، الوجيز في المرافعات، د. محمد محمود إبراهيم، ص ٣٧١ وما بعدها.
(١) ونصها: "يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفه مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز...".

(٢) "إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال...".

(٣) ونصها " (١) على صاحب السفل أن يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. (٢) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل، ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة".

واقعة الغش مثلاً، وكطلب وقف التنفيذ على أموال المدين مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى الموضوعية ببطلان التنفيذ؛ لأن الأموال المحجوز عليها لا يجوز الحجز عليها،... وهكذا.

أما إذا تضمنت الدعوى التي وصفت بأنها مستعجلة طلباً موضوعياً، كالحكم بالمدونية، أو الملكية، أو الحيازة، أو الصحة، أو البطلان، أو الفسخ، أو سقوط الحق بالتقادم، أو المقاصة أو غير ذلك، فإن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بنظر مثل هذه الطلبات الموضوعية.

وإذا كان قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بنظر الطلبات التي تمس أصل الحق، وهو ممنوع من التعرض له، ومن ثم فليس له أن يتعمق في بحث المستندات أو أن يقطع في شأنها برأى حاسم أو أن يفسرها، سواء أكانت عقوداً أم أحكاماً، وإنما يتحسس المستندات، ويبحثها بحثاً عرضياً، ويحكم بحسبان ما يبدو له لأول وهلة أو لأول نظرة، بحيث يستقي منها وجه الأمر في هذا الشأن دون تعمق أو إخلال .

كما أنه ليس للقاضي المستعجل أن يبنى حكمه على ثبوت الحق أو نفيه، أو على أى اعتبارات تتصل بأصل الحق، ويجب أن يقتصر على ترجيح الاحتمالات دون أن يجزم برأى في أصل الحق.

الفصل الثالث الاختصاص القيمي

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : الاختصاص القيمي وأهميته .

المبحث الثاني : قيمة الدعوى وأثره في تحديد المحكمة المختصة.

المبحث الأول الاختصاص القيمي وأهميته

الاختصاص القيمي .

يقصد به : تقييد اختصاص المحكمة بالدعوى التى لا تتجاوز قيمتها نصاباً معيناً من المال^(١) ، ويطلق الفقه الفرنسى على هذا النوع من الاختصاص اصطلاح "comp'etence principal" أى الاختصاص الأساسى ، وهذا يعنى أن الاختصاص القضائى النوعى يتوزع بين طبقات محاكم الجهة الواحدة وفقاً لمعيار قيمة الدعوى ، ومن ثم فإن تحديد قيمة الدعوى أو تقدير هذه القيمة هو الأساس القانونى الذى يتم بمقتضاه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

أهمية الاختصاص القيمي .

يعد الاختصاص القيمي نوعاً من الاختصاص النوعى يتحدد وفقاً لقيمة الدعوى، حيث تنقيد سلطة المحكمة فى نظر الدعوى بالنصاب المعين فى كل دعوى^(٢) ، ومن ثم فتفصل فى الدعوى التى تدخل فى نصابها القيمى المحدد لها قانوناً دون غيرها^(٣)، وبهذا يتضح أن الاختصاص القيمي ، وإن عد من الاختصاص النوعى ، إلا أن المعتبر فيه هو قيمة الدعوى وليس نوعها — مدنية أو تجارية أو شخصية — أو طبيعتها — موضوعية أو مستعجلة —

تتضح أهمية هذا التحديد فى معرفة ما إذا كان الحكم الصادر من محكمة ما قد صدر فى حدود نصابها الانتهاى ومن ثم لا يجوز الطعن فيه ، أم صدر فى حدود نصابها الابتدائى ، فيطعن فيه بطرق الطعن المقررة، وما إذا كانت صحيفة الطعن تحتاج إلى توقيع من محام أم لا تحتاج إلى ذلك^(٤).

(١) مبادئ المرافعات. د/عبد الباسط جمعى . ص ١٠٥ ، ١٠٦ ، قانون القضاء المدنى د/محمود

هاشم . بند ٢١٧ . وانظر فى هذا المعنى : الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٧ ، ٧٣ .

(٢) المرافعات د / محمد حامد فهمى . بند ١٥٧ ، ص ١٥٧ .

(٣) مبادئ القضاء المدنى د/وجدى راغب ص ٢٨١ .

(٤) أصول قانون المرافعات د/أحمد هندى . بند ٧٤ ص ١٩٥ .

والملاحظ أن تحديد الاختصاص المنصوص عليه طبقاً لقيمة الدعوى ، لا يكون إلا بالنسبة للدعوى التي تدخل في اختصاص المحكمة النوعي أو القيمي ، أما الدعوى التي ترفع إليها على سبيل الخطأ دون أن تنتبه المحكمة لعدم اختصاصها نوعياً أو قيمياً ، فإن الحكم الذي يصدر فيها يكون قابلاً للاستئناف ، ولو صدر في حدود النصاب الانتهائي لهذه المحكمة ، وذلك حرصاً على عدم تقويت درجة على الخصم من درجات التقاضي^(١) . كما تظهر أهمية تحديد قيمة الدعوى في معرفة قدر الرسوم القضائية المستحقة عن كل دعوى حيث يختلف هذا القدر باختلاف درجة التقاضي ، فضلاً عن اختلافه باختلاف قيمة الدعوى .

هذا ولقد عرف الفقه الإسلامي هذا النوع من الاختصاص ، وقد نص على جوازه بناءً على قاعدة تخصيص القضاء بالمكان والزمان والحادث والنصاب المقدر من المال.

وبناءً على هذه القاعدة يمكن لى القول بجواز الاختصاص القيمي شرعاً فى مجال العمل القضائي ، ومن ثم فيصح تقليد القاضي عليه ، لأن قضاءه استنباطية عن الإمام فصح عموماً وخصوصاً كالوكالة^(٢).

ولقد ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لأحد قضااته : (رد الناس عنى فى درهم والدرهمين)^(٣).

كما جاء عنه أيضاً قوله لأحد القضاة : " اكفى بعض الأمور يعنى صغارها)^(٤) .

(١) قانون القضاء المدني د / محمود هاشم ، بند ٢١٧ ص ٣٣٩ .

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧٢ ، درر الحكام أ / على حيدر ٤ / ٥٩٨ .

(٣) سبق تخريجه والحكم عليه ، ص : ٢٦٤ .

(٤) تهذيب التهذيب : لابن حجر ١١ / ٢٨٩ . ط دار الفكر . بيروت . ط الأولى . ط ١٤٠٤ هـ .

وهذا يدل على اعتبار قيمة الدعوى كمعيار يتم بمقتضاه تخصيص قضاء القاضى ، وقصر ولايته على ما خصص له دون غيره ، ويستفاد هذا التخصيص من خطاب التولية الذى يصدر له من الإمام المولى (١).

المبحث الثانى

تحديد قيمة الدعوى وأثره فى تحديد المحكمة المختصة

لقد اتخذ المقتن من القيمة الاقتصادية للدعوى أساساً قانونياً لتوزيع الاختصاص النوعى — المقدّر — بين محاكم الدرجة الأولى (٢) ، الأمر الذى استلزم تقرير قواعد عامة نص على ضرورة الالتزام بأحكامها عند تحديد قيمة الدعوى ، وذلك لبيان ما يدخل من طلبات الخصم عند تقدير قيمة الدعوى وما يخرج منها ، وهذه القواعد تختلف بداهة بحسب ما إذا كانت الدعوى تتضمن طلباً واحداً أم طلبات متعددة (٣) وقواعد أخرى خاصة جعلها تحكم كيفية تقدير قيمة الدعوى ؛ لما يترتب على هذا التقدير من تحديد للمحكمة المختصة قانوناً بنظرها ، ومعرفة مدى قابلية الحكم الذى يصدر منها للاستئناف أو عدم قابليته لذلك (٤) .

وأتناول الحديث عن هذه القواعد بشئ من التفصيل من خلال المطالب التالية
المطلب الأول: القواعد العامة لتحديد قيمة الدعوى وأثر ذلك فى تحديد الاختصاص
المطلب الثانى : القواعد الخاصة بكيفية تقدير الدعوى .

(١) المغنى ومعه الشرح الكبير لابن قدامة ٣٨٢/١١ ، القضاء فى الإسلام د / محمد سلام مذكور . ص ٢٦ .

(٢) المرافعات . د/ عبد الحميد أبو هيف . بند ٥٦٤ . ص ٤٢١ ، نقض مدني . طعن رقم ٨٧ لسنة ٣٤ ق جلسة ٢٩ / ٦ / ١٩٦٧ م ، مجموعة المكتب الفني ص ١٤١٠ مجلة هيئة قضايا الدولة الإلكترونية ، العدد الأول السنة الأولى ، يناير ٢٠٠٧ م ، وجاء فيه " متى كانت الدعوى بحكم الأساس الذى رفعت به والطلبات المطروحة فيها ما يدخل فى اختصاص المحاكم فإنه لا يخرج الدعوى من هذا الاختصاص أن يكون الادعاء فيها غير صحيح قانوناً لأن ما يترتب على عدم صحته هو رفض الدعوى لا الحكم بعدم الاختصاص " .

(٣) قانون القضاء المدنى . د / محمود هاشم . بند ٢١٨ . ص ٣٤٠ .

(٤) أصول وقواعد المرافعات. د/ أحمد ماهر زغلول. بند ٢٧١. ص ٥٥٢.

المطلب الأول **القواعد العامة في تحديد قيمة الدعوى** **وأثر ذلك في تحديد الاختصاص**

تختلف القواعد العامة التي وضعها المقنن لتحديد قيمة الدعوى بحسب ما إذا كانت دعوى المدعى تتضمن طلباً واحداً أم تتضمن طلبات متعددة ، وأوضح هاتين الحالتين بشيء من التفصيل في الفرعين التاليين :

الفرع الأول: قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلب الواحد .

الفرع الثاني : قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلبات المتعددة .

الفرع الأول

قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلب الواحد

إذا تضمنت دعوى المدعى طلباً واحداً ، فإن المقنن قد اعتمد في هذه الحالة على مجموعة من القواعد القانونية يتم بمقتضاها تحديد قيمة الدعوى ، وتتمثل هذه القواعد فيما يلي:

القاعدة الأولى : العبرة بقيمة الشيء المطلوب الحكم به .

من الواجب القانوني أن تكون الدعوى معلومة القيمة قبل رفعها إلى القضاء ، حتى يتمكن الخصم من رفع دعواه أمام المحكمة التي تختص قانوناً بنظرها، ومن ثم فإن معلومية قيمة الدعوى قبل رفعها هي التي تحدد المحكمة التي ترفع إليها ، وهنا يجب النظر إلى مطلوب المدعى ، الذي يبغى الحكم به ، فما يطلبه المدعى هو المعتبر قانوناً في تحديد قيمة الدعوى بغض النظر عما يحكم به القاضي^(١) .

وبناءً على هذا فإن القيمة التي يحكم بها القاضي ليست معتبرة في تحديد قيمة دعوى المدعى، وإنما المعتبر في تحديد قيمتها ما يطلبه المدعى — قل ذلك أو أكثر — ، وهذا يستلزم القول بأن مطلوب المدعى في دعواه هو الأساس القانوني

(١) المرافعات د / محمد حامد فهمي. بند ١٥٧. ص ١٦٦ ، المرافعات د/أحمد أبو الوفا . بند ٣٠٧

. ص ٣٤٦ ، الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ٢٠٨ . ص ٢٨٩ .

لمعرفة المحكمة المختصة ، ومن ثم فإن هذا الطلب هو الذى يحدد طبيعة الحكم الذى يصدر فيها من حيث قابليته للطعن أو عدمه^(١) .

هذا ولقد أحسن المقنن عندما قرر هذه القاعدة وجعلها أساساً لتحديد قيمة الدعوى ، لأنه ليس من السائع قانوناً أن تتوقف قواعد تحديد الاختصاص ، أو قابلية الحكم للاستئناف على إرادة القاضى فى حكمه ، فقد يبين له من ظروف الدعوى ما يحمله على عدم الحكم بشيء مما يطلبه المدعى^(٢) ، أو يحكم له بشيء أقل مما يطلبه ، وهذا يؤدى إلى اضطراب الدعوى وعدم استقرارها ، فضلاً عن أن مسألة الاختصاص يجب أن تكون سابقة على الحكم فى موضوع الدعوى^(٣)

لذا فقد حالف المقنن التوفيق عندما جعل قيمة ما يطلبه المدعى أساساً لتحديد قيمة الدعوى ، ومن ثم ينتج ذلك أثره فى تحديد المحكمة المختصة وفى معرفة قابلية الحكم للاستئناف أو عدمه ، فضلاً عن استقرار الدعوى من وقت رفعها وعدم تقيدها بإرادة القاضى فى حكمه ، وإلا أثر ذلك على قواعد الاختصاص القضائى .

وبناءً على هذا فإن دعوى التعويض الناتجة عن فسخ عقد من العقود تقدر قانوناً وفقاً لمبلغ التعويض الذى يطلبه المدعى ، بصرف النظر عن القدر المالى الذى تحكم به المحكمة ، أو قيمة الشيء محل التعاقد ، ولو بلغت قيمته ما يزيد عن مطلوب الخصم^(٤) .

(١) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٠٧ . ص ٣٤٦ ، قانون القضاء المدنى د/ محمود هاشم بند ٢١٨ ص ٣٤٠ .

(٢) الوسيط . د / أحمد السيد صاوى . بند ٢٠٨ . ص ٢٨٩ .

(٣) مبادئ القضاء المدنى . د / وجدى راغب . ص ٢٨٦ .

(٤) القانون القضائى الخاص . د/ إبراهيم نجيب سعد . ج ١ . بند ١٨٤ . ص ٤٥٢ ، قانون القضاء المدنى . د/ فتحي والى . بند ١٩٨ . ص ٤٥٦ .

القاعدة الثانية : العبرة بقيمة المطلوب وقت رفع الدعوى .

لتحديد قيمة الدعوى قانوناً يجب النظر إلى ما يطلبه المدعى وقت رفع الدعوى^(١)، دون غيره ، وبهذا فإن قيمة الدعوى تتحدد وقت رفعها إلى القضاء ، سواء أكانت الدعوى مدنية أم تجارية، وأما دعاوى الأحوال الشخصية فتختص بها نوعياً محكمة الأسرة أيّاً كانت قيمتها^(٢) .

ويرجع اعتبار المقنن لوقت رفع الدعوى إلى استقرار الدعوى ، وعدم تأثر قيمتها بالتغيرات والتقلبات التي تطرأ على الأسعار وقيم الأشياء ، وبذلك فقد تجنب المقنن تأثير هذه المتغيرات على قواعد الاختصاص ؛ نظراً لما يترتب على هذه المتغيرات من تأخير الفصل في الدعاوى^(٣) .

وبناءً على هذا : إذا كانت قيمة الطلب وقت رفع الدعوى ثلاثون ألف جنيه اعتبر هذا القدر قيمة لها ، ومن ثم تكون قيمتها مقدرة بهذا المبلغ ، ويترتب على هذا التحديد إختصاص المحكمة الجزئية بنظرها ، لدخولها في حدود اختصاصها

(١) قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم . بند ٢١٨ . ص ٣٤١ ، الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى . بند ٢٠٧ ص ٢٨٩ .

(٢) أصول المرافعات . د/ أحمد مسلم . بند ٣٠٠ . ص ٢٨٩ ، أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . ص ٥٥٣ هامش " ٢ " وقد نص المقنن على اختصاص محكمة الأسرة في المادة رقم ٣ من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ م المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ تابع " أ " الصادر في ١٨ مارس سنة ٢٠٠٤ م وجاء فيها : " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والورثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند نزاع جدى فى شأنها . كما يختص دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وذلك بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة " .

(٣) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى . بند ٢٠٧ . ص ٢٨٩ ، قانون القضاء المدني . د / فتحي والى ص ٢٦٨ ، الوسيط . د / نبيل إسماعيل عمر . بند ٣٣ . ص ٩٣ .

القيمي ، ويكون حكمها قابلاً للاستئناف ؛ لدخوله في النصاب الابتدائي لهذه المحكمة .

ووفقاً لهذا تظل المحكمة الجزئية مختصة بنظر الدعوى ولو أن قيمة ما يطلبه المدعى قد زادت بعد رفعها ، عملاً بما قرره المقتن من أن العبرة في قيمة الدعوى بوقت رفعها إلى القضاء^(١) ، وليس بما يطرأ على هذه القيمة من تغيير بالزيادة أو النقصان ويطبق هذا المبدأ أمام المحكمة الابتدائية ، فلو فرض أن قيمة ما يطلبه المدعى وقت رفع الدعوى خمسون ألف جنيه ، فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة قانوناً بنظر هذه الدعوى ؛ لدخولها في حد نصابها الابتدائي ، ومن ثم إذا ما حدث هبوط في الأسعار وفي قيم الأشياء أدى إلى هبوط في قيمة الطلب المقدم من المدعى ، بأن قلت قيمته لتصل مثلاً إلى أربعين ألف جنيه ، فلا يقال في هذه الحالة بسلب الاختصاص من القاضي الابتدائي إلى القاضي الجزئي ، لخروج الدعوى من اختصاص الأول القيمي ودخولها في اختصاص الثاني ، فهذا القول لا يقبل قانوناً ، لأن المقرر أن العبرة في تحديد قيمة الدعوى بوقت رفعها ومن ثم فلا أثر لتغيير الأسعار وقيم الأشياء على قواعد الاختصاص المقررة . وعليه تظل المحكمة الابتدائية صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى ؛ لدخولها في حد اختصاصها القيمي وقت رفعها .

القاعدة الثالثة: العبرة بقيمة الطلب المتنازع فيه :

المعتبر قانوناً عند تحديد قيمة الدعوى هو قيمة الشيء المتنازع فيه ، ومن ثم فلا يدخل في قيمتها ما يطلبه الخصم دون أن يكون محلاً للمنازعة^(٢)

ولقد نص المقتن على ذلك صراحة في المادة ٤٠ مرافعات : " إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء وحده ، إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ، ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه ، فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله" وبالنظر إلى هذا النص يتضح جلياً أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى

(١) الوسيط. د/نبيل إسماعيل عمر. بند ٣٣. ص ٩٣

(٢) مبادئ القضاء المدني . د/ وجدى راغب. ص ٢٨٦ .

إنما هي بقيمة الشيء المتنازع فيه ، فإن كان التنازع واقعاً في جزء من الحق كانت قيمة الدعوى محددة بحسب قيمة هذا الجزء فحسب ولو أن المدعى عليه أثار النزاع في الحق بأكمله^(١).

أما إذا كانت المنازعة في الحق بأكمله حددت قيمة الدعوى بحسب قيمة الحق المتنازع فيه بأكمله ، بيد أن التنازع إذا وقع في الحق بأكمله فيشترط لتقدير قيمة الدعوى بقيمة الحق بأكمله الشرطان التاليان :

الأول : أن يكون المدعى — صاحب الطلب — خصماً في الدعوى ، أي ذا صفة في النزاع الذي يثيره المدعى عليه في كامل الحق فإن لم يكن المدعى كذلك إلا بالنسبة للجزء المطالب به في الدعوى قدرت القيمة في هذه الحالة بقيمة هذا الجزء فقط ، حيث لا يتصور التمسك بحجية الحكم الذي يصدر في الحق بأكمله تجاه شخص لم يكن طرفاً في الدعوى.

ومثال ذلك : أن يحيل الدائن جزءاً من دينه إلى آخر ، فيرفع المحال إليه بالدين دعوى على المدين لمطالبته بالجزء المحال ، فينازعه المدين في أصل الدين كله دون أن يدخل في الدعوى الدائن الأصلي ، فالدعوى في هذه الحالة بين المحال إليه بالدين والمدين لا تقدر إلا بقيمة الجزء المحال من الدين ، لأن الحكم في هذه الدعوى لا يكون له حجية الشيء المحكوم به إلا بالنسبة للجزء المطلوب فقط ، ولا صفة للمدعى في الخصومة التي يثيرها المدعى عليه إلا في ذلك الجزء^(٢).

الثاني : ألا يكون الجزء المطلوب — محل الدعوى — هو الجزء الأخير من الحق ، فإن كان كذلك فالدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء وحده ، ولو أثار المدعى عليه المنازعة في الحق بأكمله^(٣)؛ حيث لا أهمية لتلك المنازعة بالنسبة لقيمة الدعوى^(٤).

(١) المرافعات . د/ عبد الحميد أبو هيف . بند ٥٦٧ . ص ٤٢٣ ، ص ٤٢٤ .

(٢) المرافعات . د/ أحمد أبو الوفا . بند ٣١٣ . ص ٣٥٦ .

(٣) المرافعات . د/ عبد الحميد أبو هيف . بند ٥٦٧ . ص ٤٢٤ .

(٤) قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم . بند ٢١٨ . ص ٣٤٢ .

والحكمة من ذلك تكمن في الرغبة في التقويت على المدعى فرصة التحايل على قواعد الاختصاص ، فإذا كانت الدعوى بحسب قيمتها من اختصاص المحكمة الابتدائية ، فإنه يحال

القاعدة الرابعة : العبرة بالطلب الختامي للمدعى :

تقدر قيمة الدعوى على أساس الطلب الختامي للمدعى^(١) ، وذلك إعمالاً لما قرره المقنن في المادة ٣٦ / ٣ مرافعات .

حيث نصت على أنه: " ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم " ، وما قرره أيضاً في المادة ٢٢٥ مرافعات ، حيث نص فيها على أنه :
" يكون التقدير بمراعاة القواعد العامة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى " .

وبناءً على هذا يتضح أن المعتبر قانوناً من الطلبات عند تقدير قيمة الدعوى هو الطلب الختامي المقدم من المدعى دون غيره .

فإذا رفعت دعوى أمام محكمة جزئية تدخل بحسب قيمتها في نصاب تلك المحكمة ، ثم أعقب ذلك المدعى بطلب ختامي من شأنه تعديل الطلب الأصلي بزيادة قيمته عن القيمة التي رفع بها عند اتصال الدعوى بالمحكمة الجزئية ، فالزيادة هنا تستوجب على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وتأمّر بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ، لدخولها في النصاب المالي المقدر لها^(٢).

دون المدعى بموجب القاعدة المتقدمة دون التحايل على الاختصاص ، بأن يقسم دعواه إلى دعاوى صغيرة يرفعها مستقلة عن بعضها أمام المحاكم الجزئية ، وكذلك إذا كانت الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية وتدخل في نصاب الاستئناف ، فإنه لا يجوز تقسيمها كما تقدم ؛ حتى لا تكون الأحكام الصادرة فيها انتهائية ، وهو ما يؤدي إلى تفويت درجات التقاضي على المدعى عليه — أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . ص ٥٦٨ . هامش " ٣ " المرافعات . أحمد أبو الوفا . بند ٣١٣ . ص ٣٥٧ .

(١) أصول قانون المرافعات . د/ أحمد هندی بند ٧٦ ص ١٩٧ ، ويقصد بالطلب الختامي : هو الذي يقدم قبل حجز القضية للحكم وإفقال باب المرافعة فيها ، أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . بند ٢٧٩ . ص ٥٧١ . ولمزيد من التفصيل حول هذه المسألة راجع :
الطلبات الختامية ، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي . د/ رمضان إبراهيم عبد الكريم موسى . ص ٧ وما بعدها . بحث منشور في مجلة هيئة قضايا الدولة . العدد الثاني . السنة الحادية والخمسون . إبريل — يونيو ٢٠٠٧ م .

(٢) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى . بند ٢٠٩ . ص ٢٩٠ ، أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . بند ٢٧٩ . ص ٥٧٣ ، الوسيط . د/ نبيل إسماعيل عمر . بند ٣٦ . ص ٩٥ .

أما إذا حدث بمقتضى الطلب الختامي العكس بأن تضمن تعديل الطلب الأصلي بنقص قيمته إلى نصاب المحكمة الجزئية ، وكانت الدعوى قد رفعت بداية إلى المحكمة الابتدائية ؛ لدخولها وفقاً للطلب الأصلي – المعدل – فى نصاب تلك المحكمة ، فهل تظل المحكمة الابتدائية مختصة بنظر الدعوى أو تحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ؛ لدخولها فى نصابها وفقاً للطلب الختامي ؟

فى الواقع هذه المسألة مثار خلاف بين الفقه الإجرائى فقد ذهب معظم شراح القانون – وأرى تأييد هذا المذهب – إلى القول بأن على المحكمة الابتدائية أن تتوقف عن نظر الدعوى وتحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية التى صارت وفقاً للطلب الختامي مختصة بنظرها ، وذلك لصريح نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ، الذي يقضى بأن على المحكمة إذا بان لها عدم الاختصاص بنظر الدعوى ، فإنها تقضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة (١).

فى حين ذهب بعض الفقه إلى القول بأن المحكمة الابتدائية تستمر فى نظر الدعوى ، ولا أثر لتعديل الطلب الأصلي بالطلب الختامي ، وذلك لاعتبار هذا الطلب وجهاً من وجوه الطلبات العارضة التى أشارت إليها المادة ١٢٤ مرافعات، والتى ينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمتها طبقاً للمادة ٣/٤٧ مرافعات ، فضلاً عن كون المحكمة الابتدائية هى صاحبة الاختصاص

(١) المرافعات. د/ أحمد أبو الوفا . بند ٣٠٩ ص ٢٤٩ ، ص ٣٥٠ ، نظرية الاختصاص. د/ عبد الباسط جميعى ص ٥٠ ، القانون القضائى الخاص . د/ إبراهيم نجيب سعد . بند ١٨٤ . ٤٥٦ قانون القضاء المدنى . د/محمود هاشم . بند ٢١٩ ص ٣٤٣ ، مبادئ القضاء المدنى . د/ وجدى راغب . ص ٢٨٦ ، ص ٢٨٧ ، ولا يقال فى هذه الحالة أن المحكمة الابتدائية هى صاحبة الاختصاص العام والشامل ؛ حيث إن هذا يتقيد بالطلبات العارضة التى تطرأ على الدعوى الأصلية ، ونحن والحالة هذه لسنا بصدد طلب عارض ، وإنما بصدد طلب أصلى حدث وأن أنقص صاحبه قيمته ، ومن ثم فيجب على المحكمة الابتدائية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية ؛ احتراماً لنص القانون، مبادئ المرافعات د/ عبد الباسط جميعى . ص ٥٥ ، ص ٥٦ ، الوسيط . د/ نبيل إسماعيل عمر . بند ٣٦ . ص ٩٥ .

العام والشامل في مجال الاختصاص القضائي ، وإعمالاً للمبدأ الذي يقرر أن من يملك الأقل يملك الأكثر (١) .

بيد أنه لا يجوز في هذه الحالة استئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى ؛ لدخوله في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية (٢).

هذا ويشترط لاعتبار الطلب - المعدل - طلباً ختامياً الشروط التالية :

١- أن يكون طلباً معدلاً في الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان ، فإن لم يكن كذلك بأن كان طلباً جديداً اعتبر طلباً عارضاً، ومن ثم يسرى عليه الأحكام المتعلقة بالطلبات العارضة (٣)

٢- ألا يكون الطلب - المعدل - قد قصد به التحايل على قواعد الاختصاص المقررة أو على نهائية الحكم (٤).

(١) المرافعات. د/ محمد حامد فهمي. بند ١٥٧. ص ١٦٦ ، ص ١٦٧ . قواعد المرافعات . أ/ محمد العشماوي د/عبد الوهاب العشماوي. بند ٢٤٢. ص ٤٤٠، الوسيط. د/ أحمد السيد صاوي. بند ٢٠٩. ص ٢٩٠ ، ٢٩١.

ويذهب رأي آخر في الفقه الاجرائي إلى التفرقة بين التغيير الإرادي - من قبل الخصم - في قيمة الطلب الأصلي ، والتغيير غير الإرادي - نتيجة تغير القيمة الإقتصادية - فالأول هو الذي يعتد به دون الثاني . انظر هذا الرأي : - أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . بند ٢٧٩ ص ٥٧٦ .

ويتضح من هذا الرأي أن التغيير الإرادي من قبل الخصوم هو الذي تتأثر به قواعد الاختصاص ، ومن ثم فإن تغير الطلب الأصلي زيادة أو نقصاناً يكون له أثره في تحديد المحكمة المختصة إيدائية كانت أو جزئية وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المقررة ، وأما التغيير غير الإرادي فلا أثر له على تحديد قيمة الدعوى ، ومن ثم فلا أثر له على قواعد الاختصاص ، حيث لا اعتداد به في واقع القانون .

(٢) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوي . بند ٢٠٩ . ص ٢٩١ .

(٣) القانون القضائي الخاص . د/ إبراهيم نجيب سعد . بند ١٨٤ . ص ٤٥٥ .

(٤) قانون القضاء المدني . د/محمود هاشم . بند ٢١٨ . ص ٣٤٣ .

٣- ألا يكون الطلب مندمجاً في الطلب الأصلي — أى أن الطلب الأصلي يتضمنه — فإن كان كذلك فلا أثر له في تقدير قيمة الدعوى^(١) ، ولا يدخل هذا الطلب في التقدير ؛ لأن الحكم في الطلب الأصلي يتضمنه؛ حيث لا يجوز أن يكون للطلب المندمج كيانٌ مستقلٌ ، كما هو الشأن في شطب الرهن في دعوى براءة الذمة^(٢) .

ويلاحظ أن الطلب المندمج الذي لا يؤثر في تقدير قيمة الدعوى يشترط فيه ألا يثار بشأنه النزاع فإن أثر فيه نزاعٌ وجب تقدير الطلب المندمج تقديرًا مستقلًا عن الطلب الأصلي^(٣) .

القاعدة الخامسة: العبرة بما يكون مستحقاً يوم رفع الدعوى ملحقات الطلب الأصلي^(٤) .

تقتضى هذه القاعدة بأن يراعى عند تحديد قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من فوائد وتعويضات ومصاريف وغير ذلك من ملحقات الطلب الأصلي . وقد نص المقتن على تقرير هذه القاعدة في المادة ٣٦ مرافعات حيث نصت على أن : " تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ، ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها ، وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته....." . وبناءً على ما تقدم فقد اعتبر المقتن قيمة ملحقات الطلب الأصلي وتوابعه عند تقدير قيمة الدعوى .

(١) أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . بند ٢٧٧ . ص ٥٦٤

(٢) قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم . بند ٢١٨ . ص ٣٤٣

(٣) ويرى بعض الفقه الاجرائي أن الطلب المندمج طلباً غير قابل للتقدير ، وهو ملحق بالطلب الأصلي، ومن ثم فلا تحسب قيمته عند تقدير قيمة الدعوى. انظر الوسيط. د/ فتحي والي. ص ٢٧٤

(٤) **يقصد بالطلب الملحق** : هو الذي يتبع طلباً أصلياً فيصير في اعتبار القانون — أياً كانت قيمته لو أنه نظر إليه مستقلاً عن الطلب الأصلي — كأنه جزء منه فلا يضيف شيئاً إلى قيمة الدعوى ولا يحسب في تقديرها . المرافعات . د/ محمد حامد فهمي . بند ١٧١ . ص ١٧٥ .

ويشترط لإدخال ملحقات الطلب الأصلي في تقدير قيمة الدعوى الشروط التالية:

- ١- أن يطلب ذلك المدعى ، فلا يجوز للمحكمة إدخال هذه الملحقات في قيمة الدعوى من تلقاء نفسها ، دون أن يطلبه الخصم (١) .
 - ٢- أن تكون هذه الملحقات مقدرة القيمة — أى قابلة للتقدير — فإذا لم تكن كذلك فلا تدخل في تقدير قيمة الدعوى ، وإنما تتحدد قيمتها في هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلي وحده ، بيد أنه يستثنى من ذلك حالة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته (٢) .
 - ٣- أن تكون هذه الملحقات مستحقة الأداء وقت رفع الدعوى (٣) .
- ويستثنى من ذلك طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها؛ وذلك على اعتبار أن ما يستجد من الأجرة — ويكون في ذمة المستأجر — يعد جزءاً من الطلب الأصلي (٤) .

الفرع الثاني

قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلبات المتعددة

التعدد في الدعوى قد يكون نتيجة لتعدد موضوع الدعوى أو نتيجة لتعدد أطرافها .

أولاً : التعدد الموضوعي ، وهو قد يكون تعدداً بسيطاً وقد يكون تعدداً موصوفاً ، فالتعدد البسيط يقصد به : تعدد الطلبات الأصلية في الدعوى المقدمة من المدعى في مواجهة المدعى عليه (٥) . وقد أطلق بعض الفقه الإجماعي على هذا النوع التعدد الاستقلالي (٦) ، وهو يعني استقلال كل طلب من الطلبات الأصلية المتعددة في الدعوى من حيث السبب الذي نشأ عنه .

(١) قانون القضاء المدني. د/محمود هاشم. بند ٢١٨. ص ٣٤٤.

(٢) أصول قانون المرافعات . د/ أحمد هندی بند ٧٧ . ص ٢٠٣ .

(٣) أصول المرافعات . د/ أحمد مسلم . بند ٢٠٠ . ص ٢١١ .

(٤) الوسيط. د/نبيل إسماعيل عمر بند ٣٧ ص ٩٥ ، ٩٦

(٥) مبادئ المرافعات. د/عبد الباسط جميعي ص ٦٢

(٦) أصول المرافعات . د/ أحمد مسلم . بند ٢٠٨ . ص ٢١٥ .

والضابط القانوني لتقدير الدعوى متعددة الطلبات تعددًا موضوعيًا على النحو السابق بيانه هو السبب القانوني الذي تستند إليه هذه الطلبات ، فإذا كان السبب واحداً ، فالدعوى تقدر قيمتها بقيمة الطلبات كلها ، أما إذا كان السبب متعددًا فالتقدير يكون باعتبار كل منها على حدة^(١) .

عملاً بالمادة ٣٨ / ١ مرافعات والتي نصت على أنه : " إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار كل منها على حدة " .

مثال الدعوى متعددة الطلبات المستندة إلى سبب قانوني واحد ، دعوى المطالبة بعدة أقساط من الأجرة ، فالدعوى تقدر في هذه الحالة بقيمة مجموع الأقساط — المطالب بها — كلها ، نظراً لوحدة السبب القانوني وهو عقد الإيجار^(٢) .

مثال الدعوى متعددة الطلبات المستندة إلى عدة أسباب مختلفة دعوى الشخص بدفع أجرة الشئ المؤجر وبدفع ثمن ما باعه من منقولات ، فالدعوى هنا تقدر بقيمة كل طلب على حدة ، وذلك نظراً لاختلاف السبب في كل من الطرفين^(٣) .

بيد أنه يلاحظ أن وحدة السبب أو تعدده كأساس لتقدير قيمة الدعوى لا يكون إلا بالنسبة لطلبات المدعى وحده ، فلا تجمع فيها طلبات المدعى عليه^(٤) .

وأما التعدد الموصوف ، فقد يكون تعددًا احتياطيًا وقد يكون تعددًا اختياريًا ، **فالتعدد الاحتياطي** كما لو طالب المدعى المدعى عليه بطلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي فبأى الطرفين يكون تقدير الدعوى ؟ .

لقد ترك المقتن الإجابة عن هذا التساؤل لجهود الفقه والقضاء ، وجعل هذه المسألة تقديرية للمحكمة ، بيد أن الرأي الغالب يميل نحو تقدير قيمة الدعوى على

(١) الوسيط. د/ نبيل إسماعيل عمر. بند ٣٨. ص ٩٦ ، ٩٧ .

(٢) مبادئ المرافعات . د/ عبد الباسط جميعي . ص ٦٢ .

(٣) تقنين المرافعات. أ/ محمد كمال عبد العزيز ص ١٥١ — ١٥٣ .

(٤) الوسيط. د/نبيل إسماعيل عمر. بند ٣٨. ص ٩٦ ، ٩٧ .

أساس أكبر الطلبين قيمة ، ويشترط كذلك أن يكون الطلبان في مواجهة شخص واحد^(١) .

فإذا كانا في مواجهة شخصين أو أكثر اعتبرت الدعوى في هذه الحالة دعوى منطوية على تعدد في الخصوم ، ومن ثم فيطبق بشأنها وحدة السبب أو تعدده^(٢) .

عملاً بالمادة ٢٩ مرافعات والتي نصت على أنه :

" إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه " .

ويرى بعض الفقه أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي دون الطلب الاحتياطي^(٣) .

وأما التعدد الاختياري فهو يتحقق عندما تتعلق الدعوى بحق تخييري .

والخيار هنا إما أن يكون للمدعى أو للمدعي عليه فإن كان الخيار للمدعي كما لو كان موضوع الدعوى عدداً من الأموال تبرأ ذمة المدين بوفاء أحدها ، وهنا تقدر الدعوى بحسب قيمة الشيء الذي يختاره المدعى محلاً للوفاء .

وأما إذا كان الخيار للمدعى عليه فإن المدعى يطالب المدعى عليه بأى من الأشياء التي تبرأ بها ذمته ، وهنا لا مناص من تقدير قيمة الدعوى بأكبر الأشياء قيمة^(٤) ، ومن ثم تتحدد على أساسها المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

ثانياً : تعدد أطراف الخصومة : إذا تعدد أطراف الدعوى فإن القاعدة التي تحكم قيمة الدعوى هي ذات القاعدة التي تتبع في حالة تعدد الطلبات ، ومن ثم يطبق بشأنها القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٩ مرافعات.

(١) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣١٤ ص ٢٥٧ .

(٢) الوسيط . د / أحمد السيد صاوى . بند ٢١٤ . ص ٢٩٦ .

(٣) قواعد المرافعات / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٣٤٣ ص ٤٤٢ .

(٤) قانون القضاء المدني . د / محمود هاشم بند ٢٢١ . ص ٣٥٠ .

ويستوى في هذا أن يكون التعدد في جانب المدعى أو في جانب المدعى عليه **وبهذا يتضح** أن العبرة بوحدة السبب أو تعدده ، فالدعوى تقدر بقيمة المطلوب فيها — ولو تعدد فيها الخصوم ما دام السبب واحداً — وبنصيب كل خصم إذا تعددت أسبابها .

كما لو رفع دائن دعوى على مجموعة ورثة وطالب كلاً منهم بقدر نصيبه في الدين ، فهنا تقدر الدعوى بقيمة الدين كله نظراً لوحدة السبب القانوني (١) .

المطلب الثاني

كيفية تقدير قيمة الدعوى

لا شك أن تقدير قيمة الدعوى له أهميته في تحديد المحكمة المختصة ، ومعرفة قابلية الحكم الذي يصدر منها للاستئناف أو عدم قابليته لذلك كما تقدم (٢) وحرصاً من المقنن على تحقيق هذه الأهمية في العمل القضائي فقد عمد بعد أن فرغ من بيان القواعد التي تحكم تحديد قيمة الدعوى إلى بيان كيفية تقدير هذه القيمة ، وذلك في كافة الدعاوى المختلفة .

وهذه الدعاوى قد يكون محلها مبلغاً من النقود وهنا الأمر لا يحتاج إلى عناء أو مشقة في تقدير قيمة الدعوى ، حيث تقدر قيمتها بقيمة مبلغ المال النقدي المطلوب فيها (٣) .

وقد يكون محلها طلباً آخر غير نقدي ، وهنا وضع المقنن بعد جهد كبير وعناء شديد عشرة قواعد قانونية يتم بمقتضاها تقدير قيم الدعوى ، وقد نص عليها في المادة ٣٧ مرافعات ، وأوضح — بإيجاز — فيما يلي هذه القواعد ، وذلك على النحو التالي :

القاعدة الأولى : الدعوى العقارية :

" الدعوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار

(١) قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم . بند ٢٢٢ . ص ٣٥٠ ، ٣٥١ .

(٢) الوسيط . د/ نبيل إسماعيل عمر . بند ٣٠ . ص ٨٩ .

(٣) قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم . بند ٢٢٣ ص ٣٥٣

محاضرات في قانون المرافعات مقارنة بالفقه الإسلامي

مبنياً ، فإن كان من الأراضي غير المبنية أو الزراعية يكون التقدير باعتبار أربعمئة مثل قيمة الضريبة الأصلية^(١) ، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته " م ٣٧ / ١ مرافعات .

وبهذا يتضح أن المقنن جعل للمحكمة سلطة تقدير قيمة الدعاوى العقارية التي لم تربط عليها ضريبة ، وللمحكمة في سبيل ذلك أن تستعين بما يقدمه الخصوم من مستندات أو بتقارير الخبراء الذين تندبهم لذلك ، أو بمثل المثل^(٢) .

كما يلاحظ أن المعتبر في التقدير هو الضريبة الأصلية دون الضريبة الإضافية^(٣) .

القاعدة الثانية : الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار.

" الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار ، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق ، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار " م ٣٧ / ٢ مرافعات .

وبناء على هذه القاعدة جعل المقنن قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار هي قيمة العقار المتنازع على ملكيته ، فتقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار ثبوتاً أو نفياً

(١) لقد سبق تعديل هذه المادة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢م ، الجريدة الرسمية . العدد ٢٢ مكرر ، في ١٩٩٢/٦/١م ثم عدلت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩م ، الجريدة الرسمية . العدد ١٩ مكرر في ١٧ مايو ١٩٩٩ م ، وذلك باستبدال عبارة " خمسمئة مثل " بعبارة " ثلثمائة مثل " وعبارة " أربعمئة مثل " بعبارة " مائتي مثل "

(٢) الوسيط . د/ فتحي والي . بند ص ٢٨٠ .

(٣) الاختصاص القيمي ومواعيد الإعلانات والتنفيذ في ضوء القانون ١٨ لسنة ١٩٩٩م . د/ رمضان جمال كامل بند ٥ . ص ١١ . ط/ المركز القومي للإصدارات القانونية .

بقيمة العقار ذاته ، ولو لم تكن الدعوى من الدعاوى العينية العقارية كدعوى الشفعة مثلاً ، وغيرها من الدعاوى التي تتصل بالملكية^(١) .

كذلك تقدر قيمة الدعوى على النحو المتقدم بالنسبة للمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على بالعقار في حالة ما إذا ورد التنفيذ على حق الملكية ، أما إذا ورد على حق آخر قدرت قيمة الدعوى على أساس هذا الحق^(٢) ، بيد أن المقنن قد أسند الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقائية لقاضي التنفيذ م ٢٧٥^(٣) ومن ثم فلا أهمية لتقدير قيمة المنازعات بالنسبة لتحديد المحكمة المختصة ، حيث تدخل في الاختصاص النوعى لقاضى التنفيذ ، ولكن تبقى أهمية التقدير فى معرفة نصاب الاستئناف^(٤) .

وإذا تعلقت الدعوى بتقرير حق انتفاع أو نفيه أو ملكية الرقبة أو نفيها قدرت قيمة الدعوى بنصف قيمة العقار ، وبربع قيمة العقار — المقرر عليه الحق — إذا تعلقت الدعوى بحق ارتفاق أو نفيه^(٥) .

القاعدة الثالثة : الدعاوى المتعلقة بالحكر.

" إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة الحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين " .

تقرر هذه القاعدة أن دعوى الحكر إذا تعلقت بطلب تقدير قيمة معينة له قدرت الدعوى بعشرين مثل القيمة السنوية ، وإذا تعلقت بزيادة قيمة له قدرت الدعوى بعشرين مثل الزيادة المطلوبة^(٦) ، ويلاحظ أن الضابط في اتباع هذا التقدير هو انصباب الدعوى على أصل الحكر أو زيادة قيمته ، ومن ثم لا تتبع هذه القاعدة إذا

(١) أصول وقواعد المرافعات. د/ أحمد ماهر زغلول . بند ٢٩٣ . ص ٦٠٦ ، ٦٠٧ .

(٢) القانون القضائى الخاص . د/ إبراهيم نجيب سعد بند ص ٤٦٦ .

(٣) معدلة القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م .

(٤) الوسيط د / نيل إسماعيل عمر . بند ٤٠ ص ١٠٣ .

(٥) نظرية الاختصاص . د/ عبد الباسط جمبوعى . ص ٤٧ .

(٦) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى . بند ٢٢٢ . ص ٣٠٤ ، الوجيز د/ محمد إبراهيم . ص ٤٧٢ .

كان النزاع مثلاً خاصاً بمبلغ الحكر ، حيث يكون التقدير في هذه الحالة بحسب قيمة المبلغ المطلوب^(١) .

القاعدة الرابعة : الدعاوى المتعلقة بالحياسة .

" دعاوى الحياسة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحياسة " م ٣٧ / ٤ مرافعات .

وذلك لأن النزاع في هذه الدعاوى وإن لم يتعلق بالحق الموضوعي الذي ترد عليه الحياسة إلا أنه يدور حول المكنت التي يخولها هذا الحق ، فضلاً عن كونها دليلاً على الملكية، وسبباً من أسباب كسبها^(٢) .

القاعدة الخامسة : الدعاوى المتعلقة بالإيراد المرتب .

" إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً ، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة " م ٣٧ / ٥ مرافعات .

ويكون الإيراد مؤبداً إذا كان لا ينتهي بوفاة أحد ، ومن ثم فينتقل إلى ورثة المستحق بعد الوفاة ، ويكون لمدى الحياة إذا كان مرتباً دورياً لشخص طول حياته ، أو حياة شخص آخر^(٣) .

القاعدة السادسة : الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل .

" الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة " م ٣٧ / ٦ مرافعات .

وتطبق هذه القاعدة على الغلال وغيرها من المحاصيل الزراعية دون سائر المنقولات ، لسهولة الوقوف على أسعارها في أسواقها العامة ، هذا والمعتبر في تقدير قيمة الدعوى هو سعر المحاصيل وقت رفع الدعوى دون غيره .

(١) قواعد المرافعات أ / محمد العشماوي ، د/ عبد الوهاب العشماوي . بند ٣٥٧ . ص ٤٦٥ .

(٢) تقنين المرافعات أ / محمد كمال عبد العزيز . ص ١٤٩ .

(٣) قانون القضاء المدني د/محمود هاشم. بند ٢٢٧ . ص ٣٥٦ . مبادئ المرافعات. د/عبد الباسط

أما إذا تعلقت الدعوى بمنقولات من غير المحاصيل الزراعية فأرى تأييداً لما ذهب إليه بعض الفقه أن المحكمة تستقل بتقدير قيمة هذه الدعاوى قياساً على استقلالها بتقدير قيمة العقار الذي لم تربط عليه ضريبة^(١). وذلك لعدم النص على تقدير مثل هذه الدعاوى .

القاعدة السابعة : الدعاوى المتعلقة بعقود غير مستمرة .

" إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة التعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البذل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة" م ٧/٣٧ مرافعات ويستوى في إعمال هذه القاعدة أن يكون محل التعاقد عقاراً أو منقولاً ، بيد أنه يراعى عند تقدير قيمة الشيء محل العقد قواعد التقدير المتبعة في كل منهما^(٢) .

القاعدة الثامنة : الدعاوى المتعلقة بعقود مستمرة .

" إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله ، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها ، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على إمتداد العقد إليها " م ٨/٣٧ مرافعات .

وبهذا يتضح: أن المقابل النقدي في دعاوى العقود المستمرة معتبر قانوناً كأساس يتم بمقتضاه تقدير قيم الدعاوى^(٣) ، ومن ثم تتحدد بمقتضاه المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى محل النزاع .

القاعدة التاسعة : الدعاوى المتعلقة بالحجز والتأمينات العينية .

" إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله ، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن

(١) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى . بند ٢١٧ . ٢٩٩ . ويرى بعض الفقه أن هذا النص وإن ورد بشأن المحاصيل إلا أنه يطبق أيضاً بالنسبة لجميع المنقولات . نظرية الاختصاص . د / عبد الباسط جميعي . ص ٤٧ .

(٢) الوسيط. د/ نبيل إسماعيل عمر . بند ٤٠ ص ١٠٤ .

(٣) قانون القضاء المدني. د/محمود هاشم. بند ٢٢٨ ص ٣٥٧

رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر بقيمة الدين المضمون ، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال " م ٣٧ / ٩ مرافعات .

وبناء على هذه القاعدة يتضح أنه لا شأن لقيمة المال ذاته المحجوز عليه أو محل التأمين العيني في تقدير قيمة الدعوى ، إذا كانت بين الدائن الحاجز والمدين (١) .

أما إذا كانت الدعوى مقامة من الغير بطلب استحقاقه للأموال المحجوزة أو التأمين ، فإن التقدير في هذه الحالة يكون باعتبار قيمة هذا المال عقاراً كان أو منقولاً (٢) ؛ لأن الدعوى هنا بمثابة دعوى ملكية (٣) .

القاعدة العاشرة : الدعاوى المتعلقة بصحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية

" دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها " (٤) م ١٠/٣٧ مرافعات .

وذلك تأسيساً على أن الدعوى وإن تعلقت بصحة التوقيع أو التزوير إلا أنها تتصل بالحق الثابت في الورقة المدعى بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها (٥) .

(١) قانون القضاء المدني د/محمود هاشم بند ٣٥٦ .

(٢) تقنين المرافعات. أ/محمد كمال عبد العزيز ص ١٥٠

(٣) المرافعات ، د/أحمد أبو الوفا. بند ٣٢٤ . ص ٤٤٢ .

(٤) يلاحظ أن المقتن عقد الاختصاص بنظر دعوى صحة التوقيع للمحكمة الجزئية أيًا كانت قيمة

هذه الدعوى م ٤٣ / ٥ مرافعات والتي أضافها بمقتضى القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، وانظر المادة الثالثة من هذا القانون وبناء على هذا : فإن معرفة قيمة هذه الدعوى لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى لم تعد لها أهمية عملية بعد عقد المقتن الاختصاص بنظر تلك الدعوى للمحكمة الجزئية أيًا كانت قيمتها .

بيد أن معرفة قيمة الدعوى تبدو أهميتها في معرفة قابلية الحكم الصادر فيها للاستئناف أو عدم قابليته لذلك .

(٥) قانون القضاء المدني قانون القضاء المدني د/فتحي والى. بند ٢٠١ ص ٤٨٠ .

أما الدعاوى غير القابلة للتقدير: فقد نص عليها المقنن بقاعدة مستقلة عن القواعد المتقدمة ، وهي القاعدة التي قررها في المادة ٤١ مرافعات ؛ حيث نص فيها على أنه : " إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه " (١) .

وبناء على هذه القاعدة يفترض في الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير أن قيمتها تزيد عن النصاب الابتدائي للمحكمة الجزئية ، ومن ثم فينעד الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحكمة الابتدائية ، ويكون حكمها الصادر في هذه الدعاوى قابلاً للاستئناف (٢) .

كما هو الحال في دعاوى الطرد والإخلاء وتسليم الصغير لمن يستحق حضانتها (٣) ، هذا ويلاحظ أن الأحكام المتقدمة لا تطبق بالنسبة للدعاوى التي نص المقنن صراحة على عقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية أيا كانت قيمتها ، ولو أنها كانت غير مقدرة القيمة.

(١) معدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م ، وذلك باستبدال عبارة " أربعين ألف جنيه " بعبارة " عشرة آلاف جنيه " انظر المادة الأولى من ذات القانون .

(٢) قانون القضاء المدني د/محمود هاشم. بند ٢٣٠ ص ٣٥٩ ، الوسيط، د/أحمد السيد صاوى. بند ٢٢٤ ص ٣٠٢

(٣) الوسيط . د / نبيل إسماعيل عمر . بند ٣٥ ص ٩٥ .

الفصل الرابع الاختصاص المحلي

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : مقصود الاختصاص المحلي وأهميته تحديده .

المبحث الثاني : قواعد الاختصاص المحلي .

المبحث الأول

مقصد الاختصاص المحلي وأهميته تحديده

لقد عمد المقتن إلى تقسيم الولاية القضائية محلياً على مجموع المحاكم ذات الطبقة الواحدة في المناطق التي يشملها إقليم الدولة ؛ وذلك بتخصيص محكمة أو أكثر — مشكلة من قاضٍ أو أكثر — في كل منطقة إقليمية تتولى نظر الخصومات التي تقع في هذه المنطقة ، وتكون وحدها دون غيرها المختصة بالفصل فيها ، ما لم ينص المقتن على غير ذلك^(١) .

هذا ويعد الاختصاص المحلي نوعاً من الاختصاص القضائي ، تنقسم عليه ولاية القضاء مع غيره من أنواع الاختصاص الأخرى ، بيد أن المعتبر فيه المكان ، حيث تتوزع على أساسه الولاية القضائية على مختلف المحاكم من ذات الطبقة بقصد تيسير التقاضي على المتقاضين^(٢) .

كما أخذ المقتن الإجرائي من فكرة قضاء القاضي في داره أو مسجده المخصوص بالحكم فيه أو غير ذلك من الأمكنة التي يحددها ولي الأمر في عقد التولية ، والتي عنى الفقه الإسلامي ببحثها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها لتنظيم أمر القضاء، أساساً لإنشاء المحاكم المختلفة ، ونشرها في كافة أنحاء الدولة. لذا فقد جعل في كل محلة أو مدينة محكمة أو أكثر تختص محلياً دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي، ولا يجوز لها أن تفصل في دعاوى خارجة عن حدود اختصاصها المقرر.

وقد صور بعض شراح القانون الإجرائي المحكمة على أنها أداة للقضاء ، فهي تعد النواة التي يصدر عنها ويرد إليها كل التنظيم القضائي في مختلف صورته^(٣) .

(١) نظرية الاختصاص د / عبد الباسط جميعي ص ١٠٣ .

(٢) نظرية الاختصاص د/ عبد الباسط جميعي ص ١٠٣ ، ١٠٤ ، القانون القضائي الخاص د /

إبراهيم نجيب سعد ج ١ بند : ١٨٨ ، ص ٤٧٢ .

(٣) أصول المرافعات د / أحمد مسلم بند ٥٥ ، ص ٥٢ .

وقرر بأن " لفظ " المحكمة ليس مرادفاً للفظ القاضى أو القضاة ، ولكنه يفيد معنى جامعاً لأداة القضاء سواء أكانت قاضياً فرداً أم كانت هيئة مشكلة من عدد من القضاة ، ولمجلس القضاء الذى يفيد بها مكاناً محدداً لا مطلق مكان يوجد فيه القاضى أو يجتمع فيه القضاة .. ثم إن للفظ " محكمة " فضلاً عن ذلك مدلولاً إدارياً باعتبارها " مصلحة " حكومية ، تضم طوائف من الموظفين ، وإن كان اعتبارها مصلحة لا ينبغي أن يؤدى إلى الخلط بينها وبين سائر مصالح الدولة الإدارية بالمعنى الصحيح ، وابتكار لفظ " محكمة " للتعبير عن كل هذه المعانى حديث فى عالم القانون ، فقديماً كان السائد لفظ " القاضى " وهو أقصر من أن يمكن اجتماع كل تلك المعانى حوله ، ولا تقتصر أهمية لفظ محكمة على مجرد الاصطلاح ، ولكن التوفيق إليه كان ذا أثر موضوعى محقق ، بما بثه فى التنظيم القضائى مادة ولغة من وضوح واستقرار " (١) .

هذا وقد عرّف الفقه الإجرائى الاختصاص المحلى بأنه :

" قدر ما لمحكمة معينة من محاكم الطبقة الواحدة من اختصاص بنظر المنازعات فى دائرة إقليم معين أو حدود مكانية معينة " (٢) .

وعليه : فإن الاختصاص المحلى لمحكمة ما يتحدد بالدائرة الإقليمية التى تشملها بحسب حدودها الجغرافية.

فالمحكمة الابتدائية لمدينة سوهاج — مثلاً — تختص محلياً بكافة الدعاوى التى تقع فى جميع مراكز وقرى محافظة سوهاج ، متى كانت هذه الدعاوى تدخل بحسب قواعد الاختصاص فى حدود اختصاصها النوعى والقيمى (٣) .

(١) أصول المرافعات . د / أحمد مسلم . بند ٥٥ ص ٥٢ .

(٢) قواعد المرافعات . أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى جـ ٢ بند ٣٧٢ ص ٤٨٢

(٣) المرافعات د / محمد حامد فهمى ص ٣٣٣ .

كذلك فإن محكمة جرجا الجزئية تختص محلياً بكل الدعاوى التي تقع في مركز جرجا بما يشملها هذا المركز من قرى وأحياء .

الملاحظ في هذه الحالة أن لقواعد الاختصاص المحلي أثرها القانوني في عقد الاختصاص المحلي لمحكمة معينة أو سلبه منها بعقده إلى محكمة أخرى.

وفي الفقه الإسلامي : لما كان ولي الأمر هو القائم على أمر الرعية في تدبير شئونها ، والساهر على ما يصلح أحوالها ويحفظ حقوقها وأموالها ، كان هو المسئول الأول الذي يقوم على تنظيم شئون القضاء إطلاقاً وتقييداً أو تعميماً وتخصيصاً ، لذا فقد بات لازماً على الولي أن يخصص قاضياً لكل محلة أو مدينة^(١) ، يوليه عموم النظر في الدعاوى التي تقع في هذه المحلة أو المدينة بين أفرادها المقيمين بها ، أو الطارئین عليها من غير أفرادها ، لأن الطارئ كالمقيم ، إلا إذا خصه بالمقيمين دون الطارئین ، فيكون حكمه مقصوراً على ما خصه به ولا يتعدى إلى غيره.

المبحث الثاني

قواعد الاختصاص المحلي

إن التنظيم القضائي الرشيد يستلزم عدم جمع المحاكم في مكان واحد ، وإنما يجب أن تثبت في أرجاء الدولة كلها ، فيجعل لكل محكمة نصيباً محدداً من ولاية القضاء ، وفقاً لمكانها الإقليمي أو المحلي ، وذلك بالنسبة للمحاكم ذات الطبقة الواحدة ، بحيث تقسم ولاية القضاء محلياً على جملة المحاكم المتمثلة في طبقتها أو نوعها ، ويسمى الاختصاص القضائي المحلي لكل محكمة من المحاكم بدائرة اختصاص المحكمة.

وقد نص على ذلك في المادة ١/٤٩ مرافعات : " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .

(١) الذخيرة للقرافي ١٠ / ١١٨ ، المهذب للشيرازي ٢ / ٣٧٢ ، مدى حق ولي الأمر في تنظيم القضاء وتقييده د / عبد الرحمن القاسم ص ٥٢٤ .

وبالنظر إلى هذه المادة يتضح أن المقنن قد جعل القاعدة العامة في الاختصاص المحلي هي موطن المدعى عليه ، ولا يجوز لأطراف الخصومة الخروج عن أحكام هذه القاعدة إلا بنص صريح .

وفيما يلي أوضح القاعدة العامة في الاختصاص المحلي والاستثناءات الواردة عليها ، وذلك على النحو التالي :

أولاً : القاعدة العامة : اختصاص محكمة موطن المدعى عليه :

تختص محكمة موطن المدعى عليه بنظر الدعاوى التي ترفع عليه^(١) ، متى كانت من الدعاوى الشخصية أو المنقولة ويستوى في هذا أن تكون الدعوى مدنية أو تجارية^(٢) ، رفعت أمام القضاء العادى أو الاستثنائى^(٣) ، أما الدعاوى العقارية فينعتد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها على النحو الذى يرد بيانه فيما بعد .

ويقصد بموطن المدعى عليه، المحل الذى يقيم فيه عادة ، ويتخذ منه موطناً له على سبيل الاستقرار فيه فيكون موطنه في استيفاء ما له وإيفاء ما عليه ، ولا يجهل ما يحدث فيه ، ولو غاب عنه أحياناً كان في نيته الرجوع إليه . وهذا ما يعرف بالموطن الأصلى أو الحقيقى.

وبناءً على هذا : لا ترفع الدعوى على المدعى عليه إلا في موطنه الأصلى فإن لم يكن له موطن أصلي جاز رفع الدعوى عليه في محله المختار^(٤) .

والمحل المختار : هو المكان الذى يختاره الخصم المتقاضى محلاً لإقامته ، لتسليم إعلان الأوراق القضائية إليه في هذا المحل دون غيره ، وقد يكون المحل

(١) التعليق على قانون المرافعات أ / عز الدين الدناصورى ، أ / حامد عكاز ص ٢٧٨ .

(٢) قانون المرافعات أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى ، بند ٣٧٥ ص ٤٨٥ .

(٣) قانون القضاء المدنى د / فتحى والى بند ٢٨٣ ص ٥٠٠ .

(٤) المرافعات د / محمد حامد فهمى ، بند ٣٠٧ ص ٣٣٤ .

المختار محلاً يتفق الخصوم على تعيينه لتنفيذ عمل قانوني معين ، غالباً ما يكون مكتباً للمحاماة.

فإذا تعدد المحل المختار جاز رفع الدعوى فى إحدى المحاكم التى يقع فى دائرتها أى منها.

فإذا لم يكن للمدعى عليه محلاً مختاراً، ولم يستدل على مكانه جاز للمدعى أن يرفع دعواه أمام المحكمة التى وجد بدائرتها وقت رفع الدعوى.

والعبرة فى تحديد محل الإقامة بوقت رفع الدعوى لا بوقت قيام سببها ؛ إذ لا أثر لتغير محل الإقامة على اختصاص المحكمة بعد رفع الدعوى.

فإذا فرض وأن كان المدعى عليه ليس له موطن أصلي ولا محل مختار ولم يستدل على مكان وجوده ، ففي هذه الحالة ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته^(١) ، فإذا لم يكن للمدعى موطناً ولا محلاً معيناً فينعتد الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية .

ولما كانت القاهرة تشتمل على محكمتين إحدهما محكمة جنوب ، والأخرى

محكمة شمال فإن للمدعى الخيار فى رفع دعواه أمام أى من هاتين المحكمتين .
وإذا كانت الدعوى جزئية فالخيار للمدعى أيضاً فله الحرية فى رفع دعواه أمام أى من المحاكم الجزئية شريطة أن تكون المحكمة المختارة داخل مدينة القاهرة^(٢) ، بيد أنه إذا رفع إلى محكمة بعينها من محاكم مدينة القاهرة ، لا يجوز له الرفع أمام محكمة أخرى بذات المدينة ؛ لأن الرفع إلى إحدى المحاكم ينزع الاختصاص من غيرها .

الموطن الحكمي :

يلاحظ أن موطن الشخص الأصلي قد لا يكون هو المكان الذى يقيم فيه عادة ، كما هو شأن عديم الأهلية أو ناقصها ، فموطنه الأصلي حكماً هو موطن وليه أو وصيه أو القيم عليه.

(١) المرافعات د/أحمد أبو الوفا بند ٣٣٣ ص ٤٨٠ .

(٢) أصول المرافعات/ أحمد مسلم بند: ٢٤٥ ص ٢٦٨ .

كذلك يعد موطناً أصلياً الموطن الذي يقع فيه مركز الإدارة الرئيسى لشخص معنوى — شركة كان أو مؤسسة — ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعاوى التى تقام عليه للمحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارته الرئيسى فإذا لم يكن له مركز إدارة فالدعوى تقام عليه في المحكمة التى يقع بدائرتها موطن النائب عنه^(١)

تعدد المدعى عليهم فى دعوى واحدة :

لقد قرر المقتن أنه فى حالة تعدد المدعى عليهم فى دعوى واحدة ترفع الدعوى من المدعى على المدعى عليهم جميعاً أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن أحدهم^(٢)، وهذا يعنى أن قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه لا تزال قائمة ، فلا يعتبر هذا خروجاً عن قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه، فالمقتن وإن كان قد منح الخيار للمدعى فى اختيار المحكمة التى يرفع أمامها دعواه ، فقد قيده بوجوب رفعها أمام محكمة موطن أحد المدعى عليهم^(٣) ؛ نظراً لاتحاد موضوع الدعوى^(٤) .

ويشترط لاستفادة المدعى بالخيار الممنوح له قانوناً فى حالة تعدد المدعى عليهم :

١- أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً ، ويكون التعدد حقيقياً إذا كانت طلبات المدعى فى الدعوى موجهة إليهم جميعاً^(٥) ، ومن ثم لا يكفى لقيام حالة التعدد بين المدعى عليهم مجرد اختصاصهم للمثول فى الدعوى ، أو مجرد اختصاصهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم.

(١) المرافعات د / أحمد أبو الوفا. بند ٣٣٢ ص ٣٧٨ .

(٢) المرافعات د / محمد حامد فهمى بند ٣٠٨ ص ٣٣٤ .

(٣) قواعد المرافعات / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى بند ٣٨٠ ص ٤٩٠ .

(٤) أصول المرافعات د/أحمد مسلم بند ٢٤٤ ، ص ٢٦٧ .

(٥) المرافعات د / أحمد مسلم ، بند ٢٤٤ ص ٢٦٧ .

وهذا يعنى أن حالة التعدد تكون قائمة إذا كان المدعى عليهم جميعاً خصوماً أصليين فى تلك الدعوى ، أو على الأقل ملتزمين فيها بالتزام لا يقبل التجزئة ويستوى فى ذلك أن يكون المدعى عليهم متضامنين – كالدعوى التى ترفع على الشركاء فى المسؤولية عن فعل واحد ضار – أم غير متضامنين ، استوت مراكزهم القانونية أم تفاوتت.

أما إذا كان التعدد بين المدعى عليهم تعدداً صورياً^(١) لا حقيقة له فى واقع القانون ، فلا يستفيد المدعى من هذا الخيار ، كما لو اختصم فى دعواه خصمين ، واختار موطن أحدهما لرفع دعواه. ولما بدأت الخصومة فى محكمة الخصم – المختار موطنه – تنازل عنه أو لم يتنازل ولم يأخذ منه شئ أو دفع المدعى عليهم أنه ليس معهم وأثبت ذلك ، ففى هذه الحالة يقرر القانون للخصم الآخر الحق فى الدفع بعدم الاختصاص ، وطلب الإحالة إلى محكمة موطنه^(٢).

٢- أن يعلن المدعى عليهم جميعاً فى مواطنهم بالمحكمة التى رفعت إليها الدعوى^(٣) ، حتى يتمكن الجميع من معرفة المحكمة التى رفعت إليها الدعوى ، ومن ثم يواصلون السير فيها .

فإذا لم يتم إعلان المدعى عليهم كان لهم حق التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى .

٣- أن تكون هناك مصلحة ظاهرة تتحقق من وراء الجمع وتبدو هذه المصلحة ظاهرة فى حالة وحدة موضوع الدعوى كوحدة الدين ونحوه.

الأسباب القانونية التى تبرر اختصاص محكمة موطن المدعى عليه كقاعدة عامة.

يستند شراح القانون فى تبرير قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه

بنظر الدعوى دون غيرها من المحاكم إلى عدة أسباب أهمها :

(١) أصول المرافعات د / أحمد مسلم بند ٢٤٤ ص ٢٦٧ .

(٢) المرافعات د/ محمد حامد فهمى بند ٢٣٩ ص ٣٣٤ .

(٣) المرافعات د / عبد الحميد أبو هيف . بند ٦١١ ، ص ٤٤٦ .

- أن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته مما يشغلها حتى يثبت العكس، فكان هو الأولى بالرعاية^(١).
- أن المدعى هو الطالب للحق وعليه أن يسعى إلى طلبه ، فيلاحق المدعى عليه في أقرب المحاكم إليه^(٢) سعياً منه وراء طلبه ، وليس من المعقول حمل المدعى عليه إلى محكمة أخرى في دعوى شخصية أو منقولة لمجرد دعوى من المدعى غالباً ما يثبت عدم صحتها^(٣) ، وفي معظم الأحيان لا يراد منها إلا الكيد.

لذا : فإن المدعى يكلف بإثبات دعواه ، فيلاحق المدعى عليه في موطنه ، دون أن يكلفه مشقة الانتقال من موطنه إلى موطن آخر، مما يؤدي إلى تحمله نفقات عالية قد تفوق طاقته المالية .

- أن الديون مطلوبة وليست محمولة، فعلى المدعى مطالبة المدعى عليه في موطنه

- المدعى هو الذى بدأ بالخصومة واختار الوقت المناسب لرفعها ، وأعد من الأدلة ما يؤيد دعواه ، فكان من العدل أن يطلب التقاضى في المحكمة التى بدأرتها موطن المدعى عليه ، فيفاجئه بالدعوى في موطنه.

ثانياً : القواعد الخاصة في الاختصاص المحلى :

بعد أن نص المقتن على القاعدة العامة في الاختصاص المحلى فى المادة ٤٩ من قانون المرافعات ، أورد بعد ذلك عدة قواعد خاصة ، يتحدد على أساسها الاختصاص المحلى، وذلك لحماية مصلحة عامة ، أو مصلحة خاصة يستلزمها حسن التقاضى ، وتتحقق بمقتضاها العدالة القضائية ، فضلاً عن تفادى الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

(١) المرافعات د . / محمد حامد فهمى . بند ٣٠٦ ص ٣٣٣.

(٢) المرافعات د / محمد حامد فهمى بند ٣٠٦ ص ٣٣٣.

(٣) أصول المرافعات د / أحمد مسلم ، بند ٢٤٣ ، ص ٢٦٦ .

وبناءً على هذا فإن المقنن قد يعقد الاختصاص المحلى أحياناً لمحكمة غير محكمة موطن المدعى عليه ، وأخرى يجعل الاختصاص مشتركاً بينها وبين محكمة أو محاكم أخرى، وذلك وفقاً لما يحقق مصالح الخصوم ، ويقتضيه حسن سير الدعاوى داخل النظام القضائي .

ويمكن إجمال الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص المحلى لمحكمة غير محكمة موطن المدعى عليه ، أو يكون الاختصاص مشتركاً بينها وبين محكمة أو محاكم أخرى في الحالات التالية :

١ - المحكمة المختصة بالدعاوى العينية العقارية :

- لقد عقد المقنن الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى العينية العقارية للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار^(١) .

وقد نص على ذلك في المادة ٥٠ / ١ من قانون المرافعات " في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة " .

والدعاوى العينية العقارية : هي التي يكون محلها عقاراً ، كدعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الحيازة ، ودعاوى الشفعة ، فهذه الدعاوى وأمثالها ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع العقار المتنازع فيه بدائرتها^(٢) .

وذلك لأنها هي المحكمة الأقرب للعقار ، والأجدر على فصل النزاع المتعلق به ، فهي التي تتمكن دون غيرها من معرفة حدوده ومعالمه ، فضلاً عن إمكانها معاينته وقت الحاجة إليها^(٣) ، فدعوى طلب الحراسة مثلاً على عقار معين الأولى أن تنظر فيه المحكمة التي بدائرتها العقار المطلوب حراسته ، وهكذا جميع الدعاوى العينية العقارية.

(١) المرافعات د / عبد الحميد أبو هيف بند ٥٨٩ ص ٤٣٤ .

(٢) قانون المرافعات د / محمد عبد الخالق عمر . ص ١٧٦ .

(٣) مبادئ القضاء المدني د / وجدى راغب ص ٣١٩ .

وإذا تعددت أجزاء العقار بين دوائر محاكم مختلفة كان الخيار للمدعى في رفع دعواه أمام أى من هذه المحاكم التى يقع فى دائرتها أحد أجزاء العقار ، صغر هذا الجزء أم كبر، وذلك تحقيقاً للعدالة خلافاً لما كان سائداً من قبل .

حيث كان الاختصاص المحلى فى دعوى العقار الذى تعددت أجزاؤه فى دوائر محاكم مختلفة ينعقد قانوناً للمحكمة التى يقع فى دائرتها أكبر الأجزاء ، وهذا يستلزم إطالة النظر فى الدعوى ؛ نظراً لما يترتب على ذلك من ندب خبير أو أكثر لمعرفة الجزء الأكبر أو الأعلى قيمة^(١) .

لذا فقد حالف المقنن الصواب عندما عقد الاختصاص المحلى لأية محكمة يقع فى دائرتها أحد أجزاء العقار المتنازع فيه .

ودعوى العقار على النحو المتقدم يشترط لنظرها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه أن تتعلق بذات العقار أو أى حق عينى يرد عليه ، ومن ثم يستبعد من ذلك الدعاوى المتعلقة بحق شخصى على العقار ، كدعوى المطالبة بأجرة العقار أو بطلان أو فسخ عقد الإيجار ، أو بإلزام المؤجر بتسليم المستأجر العقار المؤجر لأن هذه الدعاوى من الدعاوى الشخصية العقارية وليست دعاوى عينية عقارية^(٢) .

٢ - المحكمة المختصة بالدعاوى الشخصية العقارية :

الدعاوى الشخصية العقارية هى التى تتضمن التزاماً شخصياً وارداً على عقار ، كما هو شأن الدعوى التى يطلب فيها مشتري عقار بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة ونفاذ عقد البيع ، أو دعوى البائع بفسخ البيع ورد العقار إليه^(٣) .

(١) التعليق على قانون المرافعات أ / الدناصورى ، أ / عكاز ص ٢٨٢ .

(٢) قانون القضاء المدنى المصرى ، د/ عزمى عبد الفتاح . ص ٣٨٦ .

(٣) قواعد المرافعات أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٣٨٥ ص ٤٩٥ .

فهذه الدعاوى شخصية من حيث التزام شخص المدعى عليه ، وعقارية من حيث كونها ترد على عقار^(١) .

لذا فقد عقد المقنن الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه . أو المحكمة التي يقع بدائرتها العقار محل المنازعة، وقد نص على ذلك في المادة ٥٠ / ٢ مرافعات : " في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه " . وبذلك يكون للمدعى الخيار بين رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو محكمة موقع العقار^(٢) .

أما إذا تعلق النزاع بثمن هذا العقار الذي حررت به كمبيالة مثلاً ، وحولها البائع إلى الغير وكان النزاع من هذا الوجه فلا تختص محكمة العقار في هذه الحالة ، وإنما يجب تطبيق القواعد العامة في الاختصاص المحلي.

٣- المحكمة المختصة بدعاوى تسليم العقار :

لقد قرر المقنن - حديثاً - عقد الاختصاص بنظر دعاوى تسليم العقار للمحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها العقار ، وقد نص على ذلك في المادة ٥٠ / ٣ من قانون المرافعات وجاء فيها : " واستثناءً من حكم المادة ١٠٨ من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات "^(٣) وبناءً على هذا تختص المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار بنظر الدعاوى المتعلقة بتسليمه اختصاصاً محلياً يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القاعدة .

(١) قانون القضاء المدني د / فتحي والى . بند : ٢٢٠ ص ٥١٨ ، ولا يجوز مخالفة هذه القاعدة

حماية للطرف الضعيف . نقض مدني طعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦١ ق ، جلسة ٢٥/٣/٢٠٠٦ م .

(٢) لأن اختصاص محكمة موطن المدعى عليه هو الأصل . نقض مدني طعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦١ ق ، جلسة ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٦ م .

(٣) أضيفت هذه الفقرة إلى المادة ٥٠ من قانون المرافعات بمقتضى القانون الجديد رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، انظر المادة الثالثة من هذا القانون .

وتعد هذه القاعدة قيداً أورده المقتن على حكم المادة ١٠٨ مرافعات ، والذي يفيد سقوط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المحلى بالتكلم في موضوع الدعوى لعدم تعلقه بالنظام العام .

٤- المحكمة المختصة بالدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة :

يقرر المقتن أن الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو المؤسسات العامة ، ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية التي يكون بدائرتها مقر المحافظة م ٥١ مرافعات^(١) .

وذلك تيسيراً على إدارة قضايا الحكومة لمتابعة القضايا التي ترفع على الحكومة أو هيئاتها في محكمة واحدة^(٢) ، ويشترط لذلك ما يلي :

- أن تكون الدعوى التي رفعت على الحكومة أو إحدى الهيئات العامة دعوى جزئية ، ومن ثم لا تطبق هذه القاعدة إذا كانت الدعوى ابتدائية .
- أن تكون الحكومة أو الشخص العام مدعي عليه بصفة أصلية ، فإذا كانت الحكومة خصماً تدخل في الدعوى بصفة تبعية ، كما لو كانت الدعوى من دعاوى الضمان أو كانت دعوى فرعية ، ففي هذه الحالة يجب اتباع القواعد العامة في الاختصاص المحلى .
- أن تكون الدعوى من الدعاوى الشخصية أو المنقولة ، فإذا كانت من الدعاوى العينية العقارية، فيسري عليها قاعدة اختصاص محكمة موقع العقار .

٥- المحكمة المختصة بدعاوى الشركات والجمعيات أو المؤسسات الخاصة

(١) المادة ٥١ مرافعات ، وقد نصت على أنه : " في الدعاوى الجزئية التي توقع على الحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الهيئات العامة ، أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة . "

(٢) التعليق على قانون المرافعات أ / الدناصورى ، أ/عكاز ص ٢٨٣ ، القانون القضائي الخاص د/ إبراهيم نجيب سعد . بند ١٩٤ ص ٤٨٢ .

يعقد المقتن الاختصاص المحلى بنظر دعاوى الشركات ، أو الجمعيات ، أو المؤسسات الخاصة للمحكمة التى يقع بدائرتها مركز الإدارة الرئيسى للشركة أو الجمعية ، أو المؤسسة^(١) والسبب فى ذلك :

أن محكمة مركز الإدارة الرئيسى هى أقدر المحاكم على فحص أوراق الشركة ودفاترها ، ومن ثم تكون هذه الأوراق والدفاتر أساساً لحسم النزاع الذى يطرح على هذه المحكمة^(٢) فقرب المحكمة من مركز الإدارة الرئيسى يعتبر قانوناً فى تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر المنازعة المتعلقة بعمل من أعمال الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة .

وإذا كانت الشركة متعددة الفروع فيجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة متى كان النزاع المطروح يتعلق بهذا الفرع.

٦ - المحكمة المختصة بدعاوى التركات :

ينص المقتن فى المادة ٥٣ مرافعات على أن : " الدعوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن ، أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع بدائرتها آخر موطن للمتوفى " (٣) .

(١) المادة ٥٢ / ١ من قانون المرافعات وجاء فيها : " فى الدعوى المتعلقة بالشركات ، أو

الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية ، أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك على آخر "

(٢) قواعد المرافعات . أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٣٨٦ . ص ٤٩٧ .

(٣) المرافعات . د / محمد حامد فهمى . بند ٣١٢ ص ٣٣٧ ، أصول المرافعات . د / أحمد مسلم بند ٢٥٠ ص ٢٧٢ ، المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٤٠ . ص ٣٨٥ ، فإذا لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة . م ١٥ من قانون الأحوال الشخصية رقم " ١ " لسنة ٢٠٠٠م ، الجريدة الرسمية ، العدد ٤ مكرر الصادر فى ٢٩ يناير سنة ٢٠٠٠م .

ويتضح من هذا النص أن المقنن جعل الاختصاص المحلى بنظر دعاوى التركات التى ترفع قبل القسمة منعقدا للمحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن كان للمتوفى ، فيكون هذا الموطن محلاً لافتتاح التركة ، ويستوى فى ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من الدائن على المورث — كما هو شأن المطالبة بدين أو نحوه أو من بعض الورثة على البعض الآخر— كما هو شأن المطالبة بالنصيب الموروث — ، بيد أنه يشترط لإعمال هذه القاعدة أن تكون الدعوى من الدعاوى المتعلقة بأموال التركة ، كما يشترط أيضاً أن تكون الدعوى — أياً كان المدعى فيها — قد رفعت قبل القسمة لا بعدها، ويستوى فى ذلك أن تكون الدعوى شخصية أو عينية منقولة كانت أو عقارية.

٧ - المحكمة المختصة بدعاوى الإفلاس .

إذا توقف تاجر عن دفع ديونه كلها أو بعضها وطلب الحكم بشهر إفلاسه فالمحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى شهر إفلاس التاجر هى المحكمة الاقتصادية المختصة محلياً التى يقع بدائرتها محل التاجر المفلس ، وذلك طبقاً لما قرره المقنن فى القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ م^(١).

وذلك باعتبارها أقدر المحاكم على الفصل فى الدعوى ، وأكثر المحاكم إحاطة بظروف المدين المفلس^(٢) .

٨ - المحكمة المختصة بالدعاوى التجارية :

تنص المادة ٥٥ من قانون المرافعات على أنه : " فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه ، أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها ، أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها " .

ويتضح من هذا النص أن المقنن قد جعل الخيار للمدعى — تيسيراً له — فى رفع دعواه المتعلقة بعمل من الأعمال التجارية أمام إحدى المحاكم الثلاث التالية :

(١) انظر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

(٢) المرافعات. د/عبد الحميد أبو هيف بند ٦٠٤ . ص ٤٤٣.

الأولى : محكمة موطن المدعى عليه ؛ وذلك باعتبارها القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى.

الثانية : المحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها ، بمعنى : أن يكون الاتفاق والتنفيذ الكلى أو الجزئى قد تم فى دائرة محكمة واحدة ، فإن تم أحدهما فى دائرة محكمة تختلف عن دائرة المحكمة التى تم فيها الآخر ، فلا اختصاص لأى من المحكمتين^(١) .

الثالثة : المحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق بحكم العقد أو بقوة القانون فى دائرتها ، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق قد نفذ أو لم ينفذ^(٢) .

وإذا اتفق على تنفيذ الاتفاق فى أكثر من مكان ، كما لو اتفق بشأن عقد بيع مثلاً على أن يتم التسليم فى مكان ودفع الثمن فى مكان آخر ، فالاختصاص ينعقد للمحكمة التى يقع فى دائرتها كل من المكانين ؛ لأن كلا من المكانين محل للتنفيذ فيه^(٣) .

ويلاحظ أن تمام التنفيذ ليس شرطاً ، وإنما يكفى أن يكون التنفيذ واجباً فى دائرة المحكمة ولو لم يتم بالفعل ، كما لا يشترط أن يكون المدعى عليه تاجراً بل يشترط أن يكون العمل محل الاتفاق عملاً تجارياً .

٩ - المحكمة المختصة بدعاوى التوريدات ، والمقاولات ، وأجرة المساكن ، وأجور العمال ، والصناع ، والأجراء .

— لقد عقد المقتن الاختصاص المحلى بنظر هذه الدعاوى لمحكمة موطن المدعى عليه ، أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها ، بيد أنه يشترط فى هذه الحالة الأخيرة أن تكون محكمة الاتفاق أو التنفيذ يقع بدائرتها موطن المدعى م٥٦ مرافعات.

(١) قانون القضاء المدنى . د / فتحى والى . بند ٢٢١ . ص ٥١٨ ، ص ٥١٩ .

(٢) المرافعات د / محمد حامد فهمى . بند ٣١٥ . ص ٣٣٨ .

(٣) الوسيط . د / رمزى سيف . ص ٣٠٣ .

والمقصود بهذه الدعاوى تلك التى تنشأ بين المستهلكين والموردين ، كالدعوى التى يرفعها البقال أو الجزار للمطالبة بثمن ما ورده من بضاعة، وبهذا يكون الخيار للمدعى فى رفع الدعوى فى أي من هاتين المحكمتين ، فله أن يرفع دعواه فى محكمة موطن المدعى عليه ؛ عملاً بالقاعدة العامة فى الاختصاص المحلى، أو يرفعها فى المحكمة التى تم الاتفاق فى دائرتها أو نفذ فى جزء منه وذلك تيسيراً على المدعى ؛ نظراً لضآلة المبلغ الذى ترفع به الدعوى^(١) .

وهذا الاستثناء يرد عليه قيدان .

الأول : أن تكون التوريدات أو المقاولات فردية وليست عامة .

الثانى : إذا اختار المدعى رفع الدعوى أمام محكمة الاتفاق أو التنفيذ فلا بد أن يكون هو من دائرة هذه المحكمة^(٢) .

١٠ - المحكمة المختصة بدعاوى النفقات

تنص المادة ٥٧ مرافعات على أنه : " فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى " وبناء على هذا النص يكون الخيار للمدعى إذا تعلقت دعواه بطلب النفقة وما يتصل بها فى رفع الدعوى أمام محكمة المدعى عليه طبقاً للقاعدة العامة ، أو أمام محكمته هو التى يقع بدائرتها موطنه، وذلك رغبة من المقنن فى التيسير على طالب النفقة، ودعاوى النفقة تشمل كافة الدعاوى المتعلقة بالنفقات ، والتى ترفع من مستحق النفقة على من تجب عليه ، سواء أكان طالب النفقة يطلب تقريرها أم يطلب زيادتها ، بناء على أن طلب زيادة النفقة يعد صورة من صور المطالبة بالنفقات.

بيد أن هذه القاعدة لا تطبق إذا كانت دعوى النفقة تتضمن طلب إسقاطها أو نقصها؛ حيث يجب فى هذه الحالة تطبيق القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى ، ومن ثم لا يسرى عليها الحكم المتقدم.

(١) الوسيط . د / أحمد السيد صاوى . بند ٢٣٦ . ص ٣١٢ .

(٢) أصول المرافعات . د/ أحمد مسلم . بند ٢٥٣ . ص ٢٧٧ .

ويلاحظ أن دعاوى النفقات تشمل النفقات المقررة قانوناً ، كنفقة الآباء على الأبناء والزوج على زوجه ، ونفقة الأقارب ، كذلك تشمل النفقات المؤقتة ، كالنفقة التي يطلبها الدائن من المدين الذي حجز على كل أمواله إلى أن يفصل في أصل الحق.

١١ - المحكمة المختصة بدعاوى المطالبة بقيمة التأمين .

- إذا كانت الدعوى تتضمن المطالبة بقيمة التأمين فقد عقد المقنن الاختصاص المحلي بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد - غالباً ما يكون هو المدعى - أو مكان المال المؤمن عليه م ٥٨ مرافعات.

وبناء على هذا يكون الخيار للمدعى في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها إذا كان هو المستفيد ، أو رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المال المؤمن عليه^(١) ، عقاراً كان أو منقولاً^(٢) .

ويقتصر تطبيق هذه القاعدة على الدعاوى التي تتضمن المطالبة بقيمة التأمين سواء رفعت من المستفيد أو من ورثته ، أو من المؤمن نفسه ، أما الدعاوى الأخرى التي تتعلق بطلب إبطال العقد أو فسخه ، أو الدعاوى التي ترفع من الشركة للمطالبة بقيمة الأقساط ، فيتبع بشأنها القواعد العامة في الاختصاص المحلي^(٣) .

١٢ - المحكمة المختصة بالدعاوى المستعجلة.

إذا كانت الدعوى محل المنازعة تتضمن طلباً بإجراء وقتي فالمحكمة المختصة محلياً بنظرها هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ؛ عملاً

(١) المرافعات. د/أحمد أبو الوفا. بند ٣٤٤ . ص ٣٨٩ .

(٢) مبادئ القضاء المدني . د / وجدى راغب ص ٣٢٥ .

(٣) قانون القضاء المدني . د / محمود هاشم . بند ٢٦٢ . ص ٤٠٧ ، ص ٤٠٨ .

بالقاعدة العامة ، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ، باعتبارها الأقرب والأجدر على معرفة الدعوى وظروفها م ١/٥٩ من قانون المرافعات (١) .
أما إذا كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ فيقرر المقتن عقد الاختصاص المحلى بنظرها إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها م ٢/٥٩ من قانون المرافعات (٢) .

١٣ - المحكمة المختصة بالطلبات العارضة أو المرتبطة .

ينعقد الاختصاص بنظر الطلبات العارضة أو المرتبطة وكذلك الدفوع للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى بصفة أصلية ، بغض النظر عن مكانها الإقليمي ، وذلك تحقيقاً للعدالة القضائية وحسن سير الدعوى م ٦٠ من قانون المرافعات (٣) .
وبناء على هذا : فإن الشخص الذى يتدخل فى الدعوى الأصلية ؛ ليتقاضى الحكم الذى يصدر فيها ، يمثل أمام تلك المحكمة التى رفعت إليها الدعوى الأصلية مرافعة أو مدافعة ، ولو لم تكن فى الأصل محكمته التى يقع فى دائرتها موطنه (٤)
غير أن المقتن خرج - استثناء - عن تلك القاعدة وأجاز للمدعى عليه فى دعوى الضمان الفرعية أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة ، إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة (٥) .

(١) حيث نصت على أنه : " فى الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقضى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها " .

(٢) **وقد جاء فيها :** " وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ " .

(٣) **حيث نصت على أن :** " تختص المحكمة التى تنتظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة ، على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة ، إذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة " .

(٤) المرافعات . د/عبد الحميد أبو هيف . بند ٦٠٣ . ص ٤٤٣ ، قانون القضاء المدنى . د / فتحي والى بند ٢٢٧ . ص ٥٣٨ .

(٥) قواعد المرافعات . أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٣٨٩ . ص ٤٩٠ ، مبادئ القضاء المدنى . د / وجدى راغب . ص ٣٣٦ .

ودعوى الضمان هي : الدعوى الناشئة عن دعوى أصلية أخرى ، ويقرر شراح القانون الإجرائي أن دعاوى الضمان على قسمين:

الأول : دعوى الضمان الأصلية هي التي ترفع ابتداءً ويتبع في رفعها القواعد العامة المعتادة لرفع الدعوى ، وفقا لقواعد الاختصاص المقررة قانونا.

الثاني : دعوى الضمان الفرعية وهي المقصودة في المادة ٦٠ / ٢ من قانون المرافعات ، حيث إنها ناشئة عن دعوى أصلية أو متفرعة عنها ، ومن ثم فإن المحكمة المختصة محليا بنظرها هي المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى الأصلية ولو لم تكن هذه المحكمة هي محكمة موطن المدعى عليه بحسب القواعد العامة^(١) ويستوى في دعوى الضمان الفرعية أن تكون الدعوى الأصلية شخصية أو عينية عقارية أو منقولة ، كما يستوى أيضا أن يكون طالب الضمان - صاحب الطلب العارض - هو المدعى في الدعوى الأصلية أو المدعى عليه.

وعلى هذا فطالب الضمان يمكنه إحضار الضامن أمام محكمة الدعوى الأصلية ، بما في ذلك الحكومة متى كانت ضامنة في الدعوى ، ولو لم تكن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية من محاكمها المختصة للنظر في قضاياها^(٢) .

وحرصا من المقتن على حماية الضامن من تلاعب طالب الضمان بقاعدة الاختصاص المقررة في المادة ٦٠ / ١ من قانون المرافعات .

(١) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٤٦ ، ص ٣٩١ ، دعوى الضمان الفرعية د / أحمد ماهر زغلول . بند ١٤٣ . ص ١٤٧ ط / المطبعة التجارية الحديثة . القاهرة . ط / بدون تاريخ .

(٢) ويقرر بعض الفقه الإجرائي أن الحكومة في دعوى الضمان الفرعية تلاحق الدعوى أينما وجدت ، لأن الدعوى الفرعية حتما تابعة لدعوى أصلية والضامن يلاحق دعوى ضامنة في أي محكمة رفعت إليها ، المرافعات د/عبد الحميد أبو هيف. ص ٤٤١ هامش رقم " ٢ " قواعد المرافعات أ/محمد العشماوى ، د/عبد الوهاب العشماوى . بند ٣٨٩ . ص ٤٩٠ .

لذا فقد أوجب المقنن على المحكمة إجابة الضامن إلى طلبه بعد توافر شرطه ومن ثم يجب عليها أن تقضى في الدعوى بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة موطن الضامن^(١).

مثال دعوى الضمان الفرعية :

أن يرفع المشتري دعوى بفسخ البيع على السمسار — الذي توسط لعقد الصفه — أمام محكمة السمسار فيدخل السمسار البائع ضامناً في الدعوى. فللبائع هنا — الذي أدخل بصفته ضامناً — أن ينازع في اختصاص محكمة السمسار ، ويطلب التقاضي إلى محكمته هو ، حيث إن علاقته بالمشتري هي الأصل وليست الفرع ، وذلك متى أثبت — البائع — تحايل طالب الضمان على قواعد الاختصاص وجلبه البائع للتقاضي أمام محكمة غير مختصة^(٢).

١٤ - المحكمة المختصة طبقاً لاتفاق الخصوم

— حرص المقنن على رعاية مصلحة الخصوم عند التقاضي ، فأجاز بنص صريح الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي ، وقد نص على ذلك في المادة ٦٢ / ١ من قانون المرافعات وجاء فيها:

" إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة ، أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه " .

١٥ - المحكمة المختصة بدعاوى تفسير الأحكام القضائية :

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بتفسيره ، حيث إنها الأولى دون غيرها في بيان المقصود من حكمها ، بمالها من ولاية تكميلية على القضية ، ومن ثم فهي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المتعلقة بتفسير حكمها ، بغض النظر عن موقعها المحلي ، أو مواطن أطراف الدعوى^(٣) ، ويسرى هذا الحكم أيضاً على طلب المعارضة والتماس إعادة النظر ؛ حيث يتعين رفع الطعن إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.

(١) أصول وقواعد المرافعات . د/أحمد ماهر زغلول . بند ٣٧٦ . ص ٧٩٢ .

(٢) مبادئ القضاء المدني د / وجدى راغب . ص ٣٣٦ .

(٣) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٦٠ . ص ٤٠٩ بند ٣٩٥ . ص ٤١٨ .

الفصل الخامس

مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام والآثار المترتبة عليه

ويشتمل علي مبحثين :

المبحث الأول : مدى تعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام والآثار المترتبة علي ذلك

المبحث الثاني : مدى تعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام وآثاره.

المبحث الأول

مدى تعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام والآثار المترتبة علي ذلك

يمكن القول بأن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من القواعد التي تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن الدفع الذي يثار بشأنه دفع يتصل بالنظام العام ويترتب علي ذلك جملة من الآثار أهمها :

١ - يجب علي المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص ولو من تلقاء نفسها :

لقد أوجب المقتن علي المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من تلقاء نفسها ، متى استندت في ذلك على أساس من القانون ، بأن رأت أن الدعوى التي عرضت عليها لا تدخل في اختصاصها الولائي أو النوعي أو القيمي ، ومن ثم فتقضى المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى أو نوعياً أو قيمياً ، وتأمراً بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص ، وذلك من تلقاء نفسها دون أن يتوقف قضاؤها على طلب الخصوم^(١) ، وهذا لا يعد حكماً بما لم يطلبه الخصوم ، وإنما هو إعمال لمبدأ احترام قواعد القانون الآمرة ، والتي راعى المقتن عند تقريرها فكرة توزيع الولاية القضائية وسلطة القضاء بين جهاته ومحاكمه المختلفة^(٢).

٢ - منح الخصوم حقاً إجرائياً في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة تكون عليها الدعوى :

ينشأ عن تجاوز حدود الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي الحق الإجرائي للخصوم في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ومن ثم فيجوز التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف ولو لأول مرة ، كما يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً

(١) أصول وقواعد المرافعات . د / أحمد ماهر زغلول بند ٣٨٦ . ص ٨١٩ .

(٢) قواعد المرافعات أ / محمد العشماوي ، د / عبد الوهاب العشماوي ٢٣٥/٢ .

عن عدم سقوط الحق في إبداء الدفع بالتكلم في موضوع الدعوى أو إبداء دفاع فيها^(١) .

وترتيباً على هذا لا يسقط الحق في التمسك بهذا الدفع ، إذا لم تقض به المحكمة من تلقاء نفسها.

وكما يتقرر الحق في التمسك بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي للخصوم أطراف الدعوى يتقرر أيضاً لكل ذي مصلحة في إيدائه ، بما في ذلك النيابة العامة إذا كانت طرفاً منضماً في الدعوى — حيث ينصرف إليها أثر الحكم — محل الدفع ، والحكم الذي يصدر في الدفع له حجتيه في مواجهة جميع الخصوم سواء أكانوا خصوماً أصليين أم متدخلين^(٢) .

٣- عدم الاعتداد باتفاق الخصوم على مخالفة قواعد الاختصاص .

لا أثر لاتفاق الخصوم على ما يخالف القواعد القانونية المنظمة للاختصاص الولائي والنوعي والقيمي ، فمثل هذا الاتفاق يقع باطلاً لمخالفته صريح نص القانون ، سواء تم هذا الاتفاق قبل رفع الدعوى أو أثناء النظر فيها من محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً بنظرها^(٣).

ومن ثم فلا تنقيد بذلك المحكمة بل يتعين عليها القضاء بعدم الاختصاص والإحالة طبقاً للمادة "١١٠ مرافعات" ، كما لا يتقيد به أى من طرفي الدعوى ؛ بل يجوز له التمسك به أمام المحكمة ولو سبق تنازله عنه أو تصالحه عليه .

(١) أصول المرافعات . د / أحمد مسلم . بند ٢٦ . ص ٢٩٣ ، ٢٩٤ .

(٢) نقض مدنى . طعون أرقام ٣١٥ ، ٦٣٢ ، ٧٠٢ لسنة ٥٩ق . جلسة ١٩٩٢/٧/٣٠م ، وجاء فيها: "... التدخل في أثره ، صيرورة المتدخل سواء للإختصاص أو الانضمام طرفاً في الدعوى ، الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ..." مجموعة المكتب الفنى . السنة الثالثة والأربعون ٢ / ١٠١٧ ، وسوف يأتي الحديث عن ذلك مفصلاً فيما بعد .

(٣) أصول المرافعات . د / أحمد مسلم . بند ٢٦٦ . ص ٢٩٣ ، ٢٩٤ .

٤ - نسبية الحجية القانونية للحكم الصادر من جهة غير مختصة :

المقرر قانوناً لدى الفقه الإجرائي أن الحكم الصادر من جهة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لا يحوز الحجية القانونية أمام الجهة صاحبة الولاية وذلك ؛ للاستقلال القائم بين جهات القضاء ، ومن ثم فإن قضاء الجهة غير المختصة لا يقيد الجهة صاحبة الولاية من نظر الدعوى طبقاً لقواعد الاختصاص^(١).

بيد أن انعدام حجية الحكم الصادر من جهة غير مختصة ليس مطلقاً ، وإنما هو انعدام نسبي ، حيث يحوز هذا الحكم الحجية القانونية أمام المحكمة التي أصدرته ، وكذا أمام المحاكم الأخرى التابعة لذات الجهة ، ومن ثم تتقيد محاكم هذه الجهة بحجية هذا الحكم ، فلا يجوز لها معاودة الفصل في الدعوى مرة أخرى، وبهذا تستنفذ ولايتها على الدعوى إذا رفعت إليها مجددة بنفس الموضوع بين ذات الخصوم^(٢) .

وبناء على هذا:

لا حجية لحكم يصدر من جهة قضائية غير مختصة ولائياً — ولو أنها جهة القضاء العادي — أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية ؛ بل إن حجية هذا الحكم قاصرة على المحاكم التابعة لجهة القضاء التي أصدرته ، ولو كانت المحكمة التي صدر عنها الحكم محكمة عادية ؛ وذلك لإستقلال جهات القضاء فيما بينها ، وهذا هو السائد لدى الفقه الإجرائي.

(١) مبادئ المرافعات. د/عبد الباسط جميعي ص ١٠٤.

(٢) قانون المرافعات . د/ نبيل إسماعيل عمر . بند ٦٢ . ص ٢٠٠ .

المبحث الثاني

مدى تعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام وآثاره

يفرق المقتن الإجرائي بين نوعين من قواعد الاختصاص المحلي ، وذلك على النحو التالي :

الأول : قواعد الاختصاص المحلي التي لا تتعلق بالنظام العام ، وهذه القواعد تعد الأصل في الاختصاص المحلي ؛ حيث تنقرر لمصالح الخصوم للتيسير عليهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم في ظروف طبيعية لا تحملهم على المشقة أو العناء الذي قد يفوق طاقتهم وقدراتهم ^(١) لو أنه فرض عليهم الانتقال بقضاياهم إلى أماكن بعيدة عن مواطن إقامتهم .

لذا فقد رخص المقتن لمن تقرر لمصلحته القاعدة المحلية أن يتنازل عنها بالاتفاق مع خصمه على مخالفة تلك القاعدة ، متى قدر أن ذلك يحقق مصلحته التي قصدها المقتن ^(٢) .

وبناءً على هذا فإن قواعد الاختصاص المحلي المقررة لحماية مصالح خاصة يجوز لأصحاب هذه المصالح الاتفاق على مخالفتها ، فهم أولى الناس بمعرفة ما يحقق مصالحهم ويحمي حقوقهم .

وبهذا يمكن القول بأن قواعد الاختصاص المحلي المقررة لمصلحة الخصوم ليست من النظام العام ، كما هو شأن قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه م ٤٩ مرافعات ، أو القواعد التي تجعل الخيار للمدعى بين محكمة موطن المدعى عليه ومحكمة أخرى قد تكون محكمة موطنه أو غيرها . م ٥٧ ، ٥٨ مرافعات .

وتأسيساً على هذا يرتب القانون الإجرائي على عدم تعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام الآثار القانونية التالية :

(١) نظرية الاختصاص . د / عبد الباسط جميعي . ص ٩١ ، ص ١٠٤ ، قانون القضاء المدني . د/محمود هاشم . بند ٢٦٥ . ص ٤١٣ .

(٢) نظرية الاختصاص . د/جميعي . ص ٩١ ، الوسيط د/أحمد السيد صاوي . بند ٢٢٦ . ص ٣٠٦ .

أولاً : يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى مقدماً على رفع الدعوى أو لاحقاً عليها^(١) ، ويكون هذا الاتفاق ملزماً لأطرافه وللحكمة^(٢) ، ومن ثم لا يجوز للمدعى عليه التمسك بعدم اختصاص المحكمة التى رفعت إليها الدعوى بناء على هذا الاتفاق^(٣) .

ويستوى فى هذا الاتفاق أن يكون صريحاً بالنص عليه فى العقد - أو الواقعة - محل الدعوى ، أو ضمناً مستفاداً من سكوت المدعى عليه بعد إعلانه بالدعوى التى رفعت أمام محكمة أخرى ، دون أن يدفع قبل التكلم فى موضوعها بعدم اختصاصها^(٤) .

كذلك لا يجوز للمدعى الذى رفع دعواه أمام محكمة أخرى على خلاف ما تقرره قواعد الاختصاص المحلى أن يتمسك بعدم اختصاص تلك المحكمة ، حيث إن رفعه الدعوى أمامها إبتداءً دليل على رضاه باختصاصها انتهاءً .

ثانياً : يسقط حق المدعى عليه فى التمسك بعدم الاختصاص المحلى إذا لم يتقدم به فى مبدأ الخصومة ، أى قبل التكلم فى موضوع الدعوى ، كما يسقط حقه إذا أبدى دفاعاً فيها أو دفعاً بعدم القبول^(٥) . م ١٠٨ مرافعات ، ولا يعد حضور المحامى وكيلاً عن المدعى عليه ومثوله فى الدعوى دون الدخول فى موضوعها تكلماً فى الدعوى.

(١) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٥٩ . ص ٤٠٧ .

(٢) أصول المرافعات د/أحمد مسلم . بند ٢٦٧ . ص ٢٩٥ ، قانون القضاء المدنى د/فتحى والى . بند ٢٣٤ ص ٥٥٩ .

(٣) القانون القضائى الخاص . د/ إبراهيم نجيب سعد . بند ٢١٠ . ص ٥١٧ .

(٤) مبادئ المرافعات د/عبد الباسط جميعى . ص ١٠٠ ، نقض مدنى طعن رقم ٣٩٠٨ . لسنة ٧٠ ق جلسة ٩ / ٥ / ٢٠٠١ .

(٥) مبادئ المرافعات د / عبد الباسط جميعى . ص ١٠٠ ، نظرية الدفع . د / أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ . ص ١٨٠ .

ثالثاً : إذا سكت المدعى عليه عن التمسك بهذا الدفع فليس للنيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى باعتبارها طرفاً منضمّاً إلى جانب المدعى عليه حق التمسك به^(١) ، لأن الحق فيه مقرر لمصلحة الخصم ، ولا معنى لحرمان الخصم رغماً عنه من قضاء محكمة قبل هو باختصاصها في حدود الحق المقرر له قانوناً. بيد أنه يجوز للنيابة العامة إذا تدخلت منضمة في دعوى - في تلك الحالات التي يوجب عليها القانون ذلك - معينة لحماية شخص معين ، كما هو شأن عديم الأهلية ، فليس هناك ما يمنع قانوناً من تمسكها بهذا الدفع ، متى رأت في ذلك نفعاً يعود على الشخص الذي تدخلت هي لحمايته ، ولو أنها ليست خصماً حقيقياً في الدعوى.

رابعاً : لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها ما لم يتمسك بذلك أحد الخصوم ، وإلا عدّ ذلك حكماً منها بما لم يطلبه الخصوم ، حيث إنها ليست مجبرة على أن تغرق نفسها في شيء قد وضعه المقنن على عاتق غيرها^(٢) .

ويرى بعض الفقه الإجرائي أن المحكمة إذا تراحت عليها القضايا دون أن تكون بحسب الأصل مختصة بنظرها ، واتفق الخصوم على اختصاصها بنظر دعاويهم جاز لها أن تتخلى عن اختصاصها بنظر تلك الدعاوى ، حتى تنفرغ لنظر الدعاوى التي هي من اختصاصها أصالة^(٣) .

(١) نظرية الاختصاص . د / عبد الباسط جميعي . ص ٩٦ ، قانون القضاء المدني . د / محمود هاشم . بند ٢٦٦ . ص ٤١٥ .

(٢) المرافعات د / أبو هيف ٥٤٥ ، بند ٥٤٦ ، المرافعات أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى ص ٤٨٤ . هامش " ٢ " .

(٣) جارسونيه وجلاسون مشار إليهما في : نظرية الاختصاص . د / عبد الباسط جميعي . ص ١٠٣ ، مبادئ المرافعات د / عبد الباسط جميعي ، المرافعات د / أحمد أبو الوفا . ص ٤٠٨ ، قانون القضاء المدني د / فتحي والي . ص ٥٥٩ هامش " ٣ " - القانون القضائي الخاص . د / إبراهيم نجيب سعد ص ٥١٧ ، ٥١٨ هامش " ٢ " ، ومن هذا الرأي في الفقه الإجرائي المصري . د / أبو هيف . المرافعات . بند ٥٤٥ ص ٤٠٨ هامش " ١ " وانظر نقد هذا الرأي . د / عبد الباسط جميعي المرجعين السابقين بنفس الصفحات .

بيد أن الراجح في الفقه الإجرائي أن المحكمة إذا اتفق على اختصاصها لا يجوز لها أن تقضى بعدم الاختصاص ، ولو أنها ليست مختصة بحسب الأصل بتلك الدعاوى المتفق على اختصاصها بنظرها^(١) .

يستوى في ذلك أن يكون هذا الاتفاق قد تم مقدماً على رفع الدعوى - في الحالات التي يجوز فيها ذلك - أو كان لاحقاً على رفعها .

خامساً : في حالة التنازع بين الخصوم حول حصول الاتفاق على اختصاص محكمة معينة أو عدم حصوله ، فإن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق المدعى عليه^(٢) .

سادساً : إذا تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى محل المنازعة ، وتحققت المحكمة من صحة ما استند إليه ، وجب عليها أن تقضى بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ؛ عملاً بالمادة ١١٠ مرافعات ، ومن ثم تنتهي الدعوى أمامها بغير حكم في موضوعها^(٣) .

سابعاً : إذا كان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه ، وأقام المدعى دعواه أمام محكمة موطن المدعى عليه ، جاز لهذا الأخير التمسك بالدفع بعدم اختصاص محكمته بشرط عدم تكلمه في موضوع الدعوى ، ولا شأن لهذا بما تقرره المادة ٦٢ / ٢ مرافعات^(٤) .

(١) المرافعات . د / محمد حامد فهمي . بند ٣٢٠ ص ٣٤٤ ، ص ٣٤٥ ، المرافعات د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٥٩ ص ٤٠٨ ، القانون القضائي الخاص . د / إبراهيم نجيب سعد . ص ٥١٧ ، ص ٥١٨ ، قانون القضاء المدني . د / فتحي والي . بند ٢٣٤ . ص ٥٥٩ ، الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ٢٤١ ص ٣١٩ .

(٢) قانون القضاء المدني . د / فتحي والي . بند ٢٣٤ . ص ٥٦١ ، نظرية الدفع . د / أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ . ص ١٨٠ .

(٣) أصول المرافعات د / أحمد مسلم . بند ٢٦٣ . ص ٢٩١ ، تقنين المرافعات أ / محمد كمال عبد العزيز . ص ١٨٠ .

(٤) نقض مدني . طعن رقم ٥٣٧ . لسنة ٤٥ ق . جلسة ١٤ / ٥ / ١٩٨٠ م ، وقد نصت المادة ٦٢/٢ من قانون المرافعات الحالي و جاء فيها رد على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تحويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة " ٤٩ " لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص " .

الثاني : قواعد الاختصاص المحلي التي تتعلق بالنظام العام .

من قواعد الاختصاص المحلي القواعد الخاصة التي قررها المقنن على خلاف حكم المادة ٤٩ مرافعات ، وهذه القواعد حظر المقنن على الخصوم الاتفاق على مخالفة أحكامها ، وذلك رعاية لمصلحة عامة رأى المقنن حمايتها واعتبر حماية المصلحة العامة أولى وأجدر بالرعاية من المصلحة الخاصة المتعلقة بالخصوم^(١) تأسيساً على أن رعاية المصالح العامة تتصل مباشرة بالعدالة في أدائها لدورها المقصود ، وتعمل على احترام قواعد القانون من أن تمس ، كما أن اعتبار المقنن للمصلحة العامة لا يعنى انعدام رعايته للمصالح الخاصة ، حيث إن مردود هذه الحماية عائد لا محالة على المصالح الخاصة بالخصوم^(٢) فقيام العدالة بواجبها في احترام القانون لا شك أنه من صميم مصالح الخصوم .

بيد أن المقنن قد رأى نفسه الأجدر أنه في تحقيق ذلك من الخصوم أنفسهم^(٣) لذا فقد رسم لهم طريقاً معيناً عند تقاضيتهم ، ونص على ضرورة التزامهم بهذا الطريق دون غيره ، لذا فقد قرر بطلان الاتفاق الذي يجرى بين الخصوم على نحو يخالف ما قرره من أحكام أمرة.

ومن أمثلة القواعد الخاصة التي نص المقنن على احترامها والتزام أحكامها قاعدة عقد الاختصاص المحلي لمحكمة موقع العقار دون النظر إلي مواطن الخصوم.

كذلك قاعدة عقد الاختصاص المحلي بنظر دعاوى الإفلاس للمحكمة الاقتصادية، التي يقع في دائرتها محل المدين المفلس المطلوب شهر إفلاسه^(٤) .

(١) نظرية الاختصاص . د / عبد الباسط جميعي . ص ١٠٥ - ١٠٧ ، قواعد المرافعات أ /

محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٤٠٥ . ص ٥١٩ .

(٢) مبادئ المرافعات . د / عبد الباسط جميعي ص ٩٨ ، ص ٩٩ .

(٣) مبادئ المرافعات . د / عبد الباسط جميعي . ص ٩٩ .

(٤) نظرية الدفوع . د / أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ . ص ١٨٣ ، ص ١٨٥ .

وكذلك قاعدة عقد الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة للمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة، وعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها العقار المطلوب تسليمه^(١) إلى غير ذلك من القواعد التى نص المقنن على اعتبارها فى تحديد الاختصاص المحلى ، وجعل فيها الاختصاص بنظر الدعاوى محل المنازعة لمحكمة بعينها دون غيرها .

كما هو شأن دعاوى الاستئناف التى أوجب المقنن رفعها إلى محكمة أعلى درجة ، تقع المحكمة المستأنف عليها فى دائرة اختصاصها الإقليمى^(٢) .

وكذا دعاوى التماس إعادة النظر التى أوجب المقنن رفعها إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ؛ متى توافرت لها الشروط المعتمدة قانونا^(٣) .

وأىضا دعاوى المخاصمة والرد^(٤)، ودعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها م ١٩١ ، ١٩٢ مرافعات^(٥) وما شابه ذلك .

فهذه القواعد تعد من قبيل النظام العام فى الاختصاص المحلى ، ومن ثم لا يجوز للخصوم أو غيرهم أو المحكمة مخالفتها ، حيث إنها مقررة بمقتضى قواعد القانون الآمرة ، ويقع باطلا كل أمر يخالف أحكامها^(٦) .

وقد نص المقنن على ذلك فى المادة ٢/٦٢ من قانون المرافعات وجاء فيها :

(١) انظر الفقرة الثالثة من المادة ٥٠ من قانون المرافعات ، وقد أضيفت بالقانون رقم / ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

(٢) مبادئ المرافعات . د / عبد الباسط جميعى . ص ١٠٨ ، نظرية الدفوع . د / أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ ص ١٨٣ .

(٣) المرافعات د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٦٠ . ص ٤٠٩ .

(٤) المسئولية المدنية للقضاة . لأستاذنا الدكتور / السعيد محمد الأزمازى رحمته الله بند ٨٣ ص ٨٥ ط / دار النهضة العربية . ط الأولى ١٩٩٨ م .

(٥) نظرية الدفوع د / أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ - تقنين المرافعات . أ / محمد كمال عبد العزيز ص ٣٧٣ ، ص ٣٧٤ .

(٦) قواعد المرافعات أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٤٠٥ . ص ٥١٩ ، أصول المرافعات . د / أحمد مسلم بند ٢٦٨ . ص ٢٩٦ .

" على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تحويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة " ٤٩ " لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص " .

والذي يتضح لي من هذه الفقرة أن المحظور قانوناً على الخصوم هو إنما هو الاتفاق مقدماً على اختصاص محكمة معينة في الحالات التي ينص فيها على عقد الاختصاص لمحكمة ما على خلاف ما تقرره المادة ٤٩ مرافعات (١) .
أما الاتفاق اللاحق على رفع الدعوى فلا يحظره القانون على الخصوم ، ومن ثم يعتد قانوناً بإرادتهم فيما يتفقون عليه بعد رفع الدعوى على النحو المقرر في المادة ٦٢ / ٢ مرافعات (٢) .

وتأسيساً على هذا : يترتب على تعلق قواعد الاختصاص المحلي - القواعد الخاصة - بالنظام العام ذات الآثار الإجرائية المترتبة علي تعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي ، ومن ثم فلا حاجة للتكرار .

(١) التعليق على قانون المرافعات . أ/الدناصورى ، أ/ عكاز . ص ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، تقنين المرافعات أ / محمد كمال عبد العزيز ص ١٨٠ .

(٢) نظرية الدفع . د / أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ . ص ١٨٠ - ص ١٨٣ ، قانون القضاء المدني . د/فتحى والى . بند ٢٣٤ . ص ٥٦٣ ، وقد نصت المادة ٦٢/٢ من قانون المرافعات الحالى و جاء فيها : " على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تحويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة " ٤٩ " لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص " .

الفصل السادس

الإحالة

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : الإحالة وأحكامها

المبحث الثاني : الآثار الإجرائية المترتبة على الإحالة

المبحث الأول الإحالة وأحكامها

أولاً : مفهوم الإحالة وأنواعها :

هي : نقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى وفقاً للقواعد المقررة قانوناً^(١)

ثانياً : أنواع الإحالة :

قد تكون الإحالة لعدم الاختصاص أو لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى أو أكثر ، أو للارتباط بين موضوع الدعوى المنظورة ودعوى أخرى منظورة أمام محكمة أخرى - ولو لم تكن هناك مخالفة لقواعد الاختصاص المقررة - وقد تكون الإحالة لاتفاق الخصوم علي نقل دعواهم من محكمة إلي أخرى علي النحو الذي يرسمه القانون وتسمى حينئذ بالإحالة الاتفاقية .

وبناءً علي هذا فإن الإحالة تتنوع إلي أربعة أنواع رئيسة هي :

١ - الإحالة لعدم الاختصاص :

والإحالة هنا تعد الوسيلة الفنية الإجرائية التي يتم بمقتضاها تصحيح سير الدعوى في مرحلة اتصالها بالقضاء^(٢) ، وذلك عن طريق نقلها من محكمة غير مختصة إلى جهة مختصة - كما هو الشأن في إحالة الدعوى الإدارية من محكمة عادية إلى جهة القضاء الإداري - ، أو نقلها من محكمة عادية غير مختصة إلى محكمة عادية أخرى مختصة بنظرها بعد ثبوت عدم الاختصاص بنظرها طبقاً للقانون .

هذا وقد قرر المقنن وجوبية الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص ، فنص في المادة " ١١٠ " مرافعات علي أنه :

(١) المرافعات د / عبدالحميد أبو هيف. ص ٨٩٩ ، قانون القضاء المدني د / فتحي والي . بند ٢٣٥ . ص ٥٦٤ ، أصول قانون المرافعات د/أحمد هندی . بند ١٧٩ .

(٢) قانون القضاء المدني د/فتحي والي. بند ٢٣٦. ص ٥٦٨، الجزاء الإجرائي. د / أيمن رمضان . ص ٧٢٣

" على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ..."

وبهذا يتضح أن المقنن قد سوى في الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص بين عدم الاختصاص المتعلق بالولاية وعدم الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى أو قيمتها أو محلها ، فالحكم بعدم الاختصاص أياً كان مبناه يستوجب الإحالة إلى المحكمة المختصة^(١) .

كما أنه سوى في وجوبية الإحالة بين قضاء المحكمة بعدم الاختصاص بناءً على دفع تمسك به أحد الخصوم وقضائها بذلك من تلقاء نفسها إذا كان الاختصاص من النظام العام ، فالإحالة واجبة على كل حال بعد الحكم بعدم الاختصاص^(٢) .

٢ - الإحالة لقيام ذات النزاع :

وهذا الدفع في هذه الحالة يفترض أن هناك دعوى أقيمت لدى محكمة مختصة ، ثم أعيد رفعها أمام محكمة أخرى مختصة أيضاً أو تعاصر رفعهما ، كما لو أقيمت دعوى على جملة أشخاص تابعين لمحاكم مختلفة ، أو كان هناك اتفاق بين المدعى والمدعى عليه على محل معين لتنفيذ العقد منشأ النزاع يختلف عن محل المحكمة التابع لها المدعى عليه .

ففي هذه الحالة يقرر المقنن الإجراءي حق الدفع للمدعى عليه ؛ تجنباً لزيادة المصروفات ، وتوحيداً في نظر الخصومات ، وحفظاً لأحكام القضاة من التناقض^(٣) ، وهذا الدفع يستلزم بطبيعته أن تكون الدعويان متحدتان سبباً وموضوعاً وخصوماً ، فضلاً عن اختصاص كل من المحكمتين ، وتبعيتهما لجهة قضائية واحدة^(٤) .

(١) الوسيط د / أحمد السيد صاوي بند ١٥٢ . ص ٢١٥ .

(٢) قوانين المرافعات. د/ أمينة النمر. بند ٢٨٧ . ص ٦٢٩ ، نقض مدني . طعن رقم ١٨٦٠ لسنة

٦١ ق . جلسة ١٩٩٦/٥/١٥ م المستحدث . ص ٢٢٣ .

(٣) نظرية الدفع . د/أحمد أبو الوفا . بند ١٠٨ ص ٢٢٨ .

(٤) الوجيز د/عبد الفتاح السيد بك. بند ٥٥٣ . ص ٥٠٢ .

٣ - الإحالة للارتباط :

وهنا يفترض أن هناك دعوى أقيمت في محكمة بعينها وارتبطت بدعوى أخرى رفعت لدى محكمة أخرى ، وكان الارتباط بينهما وثيقاً ، الأمر الذي حدا بالمقنن الإجرائي أن يعمل على الجمع بينهما بدلاً من تفريقهما بين المحاكم ، فنص على عقد الاختصاص بنظرهما معاً لدى محكمة واحدة^(١) ، كما لو رفعت دعوى مطالبة بتنفيذ عقد بعينه ، في حين يرفع الطرف الآخر دعوى يطلب فيها بطلان العقد نفسه أو فسخه^(٢) ، وهذا الدفع يشترط له اتحاد الموضوع والسبب دون اتحاد الخصوم^(٣) ، وهذا ما يفارق بينه وبين الدفع في الحالة الأولى ، كما أن الدفع بالإحالة للارتباط لا يتقيد قبوله بالمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً ، بل العبرة بأسبقية الدفع أمام أي منهما^(٤) ، وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام ، منعاً لتناقض الأحكام .

٤ - الإحالة لاتفاق الخصوم :

قد تتم الإحالة استجابة لاتفاق الخصوم ، وبناءً على طلبهم ومحض ارادتهم ، وذلك في الأحوال التي تكون فيها قاعدة الاختصاص مقررة بحسب الأصل لمصلحتهم ، فهنا يخول القانون للخصوم الحق في الاتفاق على نقل دعواهم من محكمة إلى أخرى م " ١١١ " مرافعات ؛ وذلك على نحو يحقق مصالح الخصوم المشروعة في التقاضي ، ولا يخالف بحال قواعد القانون الأمرة في هذا الشأن ، ويؤدي إلى حسن سير العدالة القضائية ، هذا فضلاً عن تحسين الأداء في رسالة القضاء .

هذا ويشترط في الاتفاق على الإحالة أن يكون صريحاً وواضحاً ومجمعاً عليه من قبل الخصوم ، وخالياً من كل عيب يشوب إرادة أحدهم ، فضلاً

(١) نظرية الدفوع . د / أحمد أبو الوفا . بند ١٢٧ ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ .

(٢) الدفوع الشكلية / د/ زياد صبحي ذياب . ص ٤٤ .

(٣) الدفوع الشكلية . د / زياد صبحي ذياب . ص ٤٤ .

(٤) الوجيز . د / عبد الفتاح السيد بك بند ٥٥٤ . ص ٥٠٣ .

عن ضرورة أن تكون المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ابتداءً مختصة فإن لم تكن كذلك فقد وجب علي المحكمة هذه أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة بناءً علي نص المادة " ١١٠ " مرافعات وليس علي أساس نص المادة " ١١١ " مرافعات المتعلقة بالاتفاق فيما بين الخصوم .

هذا وتعد الإحالة بناءً علي اتفاق الخصوم علي فرض توافر شروطه وصحته أمراً جوازياً في حق المحكمة ، حيث يحق لها قانوناً أن تستجيب لطلب الخصوم أو ترفضه متى قام للرفض عندها سبب يقتضيه كما لو كانت المحكمة قد قطعت في الدعوى شوطاً كبيراً ، أو كانت قد أوشكت علي الانتهاء منها أو أن انتقال الدعوى منها إلي غيرها مما يؤثر علي حسن العدالة القضائية .

ثالثاً : أهمية الإحالة :

تعد الإحالة عنواناً لصحة الحكم بعدم الاختصاص — ما لم يطعن فيه — ، ومن ثم فهي الوسيلة القانونية لتصحيح سير الدعوى وقت اتصالها بالقضاء^(١) . كما أن الإحالة هي الأثر الإجرائي المترتب علي الحكم بعدم الاختصاص ، وقد استهدف المقنن من وجوبها بعد الحكم بعدم الاختصاص تبسيط الإجراءات ، وتقليل النفقات ، ورفع المشقات عن المتخاصمين^(٢) عند التقاضي والخصومات . وهذا يتضح من اتجاه المقنن في تقريره نظر الدعوى أمام المحكمة المحالة إليها بحالتها دون حاجة إلي رفعها من جديد م ١١٠ مرافعات ، وفي هذا توفير لوقت القضاء والمتخاصمين ، وتبسيط للإجراءات القضائية .

فالمحكمة المحالة إليها الدعوى تلتزم بنظرها وفقاً للحالة التي كانت عليها أمام المحكمة المحيلة ، ومن ثم فيعند بكل إجراء أو تحقيق اتخذ بشأنها أو حكم صدر

(١) الجزاء الإجرائي . د/ أيمن رمضان . ص ٧٢٣ .

(٢) الوسيط د / أحمد السيد صاوي . بند ١٥٢ . ص ٢١٥ ، قوانين المرافعات د / أمنية النمر . بند ٢٨٧ . ص ٦٢٩ .

فيها وكان سابقاً على الأمر بالإحالة ، وهذا يستلزم القول بأن المحكمة المحالة إليها الدعوى تبدأ بالنظر فيها من حيث انتهت المحكمة المحيلة^(١).

وهذا مما يدل على أهمية الإحالة ، حيث يترتب عليها انعدام المشقة في رفع الدعوى من جديد أو إعادة إجراءاتها مرة أخرى كما يترتب عليها تقليل النفقات ، وتقصير مدد التقاضي ، فضلاً عن سرعة الفصل في الخصومات والدعاوى ؛ حيث لا يقبل عقلاً أن تقضى محكمة بعدم اختصاصها لقيام سببه دون أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي تراها مختصة بنظرها ، ثم يكلف الخصم بإعادة إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة التي يحددها القانون ؛ لتتظر في دعواه من جديد^(٢).

رابعاً : نطاق الإحالة :

حقيقة أرى مع جمهور شراح القانون الإجرائي اتساع نطاق الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص ليشمل الإحالة من محكمة قضائية إلى مثتها ، كما يشمل أيضاً الإحالة من محكمة قضائية إلى غيرها من جهات القضاء الأخرى^(٣)، المنصوص على منحها الولاية القضائية للنظر في دعاوى معينة كالمحاكم الاستثنائية - محاكم أمن الدولة ، والمحاكم العسكرية ومحكمة القيم - واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي المحدد قانوناً - كهيئات التحكيم ، ولجان فض المنازعات - .

(١) الوسيط د / نبيل إسماعيل عمر . ص ٣٥١ ، قانون القضاء المدني د/فتحي والي. بند ٢٣٦ .

ص ٥٦٨ ، ص ٥٦٩ ، نقض مدني طعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق . جلسة ١٥/٥/١٩٩٦م .

(٢) أصول قانون المرافعات د / أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص ٤٩١ ، الاختصاص القضائي أ /

عبد الهادي عباس . بند ١٦٤ . ص ٣٤٥ ، الجزاء الإجرائي د / أيمن رمضان . ص ٧٢٣ .

(٣) قانون القضاء المدني د / فتحي والي . بند ١٨٨ . ص ٢٨٤ ، ص ٢٨٥ ، الوسيط د / أحمد

السيد صاوي . بند ١٥٣ . ص ٢١٤ ، أصول قانون المرافعات د/أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص

٤٩٥ ، قوانين المرافعات د/أمانة النمر . بند ٢٨٧ . ص ٦١٣ ، الدفوع والطلبات العارضة أ /

مجدى هرجة . ص ٤٥ ، بحث في قواعد المرافعات د / عبد العزيز بدوي . ص ٨٩ .

وقضاء انظر : نقض مدني طعن رقم ٦٤٣ لسنة ٤٥ ق . جلسة ٢٤/٣/١٩٧٩ م .

وبناءً على هذا تصح الإحالة من محكمة قضائية إلى محكمة استئنائية أو إلى لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي^(١) ، وذلك بضوابط مخصوصة تضمن سلامة رفع الدعوى وصحة اتصالها بالقضاء.

ومما يبرر قانوناً هذا المذهب الأسباب التالية :

١- أن جهات القضاء الاستئنائية أيّاً كان نوعها — محاكم استئنائية أو لجاناً إدارية ذات اختصاص قضائي — قد منحت الولاية القضائية المحدودة في نظر بعض المنازعات بمقتضى نص القانون^(٢) .

٢- عموم نص المادة ١١٠ مرافعات القاضى بوجوب الإحالة^(٣) بعد الحكم بعدم الاختصاص ؛ حيث لم يرد فيه قيد ولا تخصيص ينم عن قصر الإحالة على المحاكم القضائية بمعناها الفنية الدقيقة . وهذا يستلزم القول بالإبقاء على عموم النص حيث لا مخصص . ومن ثم فإن القول بالقصر قول مجرد عن الدليل .

٣- أن جهات القضاء الاستئنائية عندما تباشر عملها المنوط بها فإنها تباشر عملاً قضائياً يحسم النزاع في الدعاوى المطروحة عليها^(٤) .

(١) ويشترط بعض الفقه الإجرائي في الإحالة من وإلى هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي أن تكون من الهيئات التي ينص المقتن على تطبيق قانون المرافعات أمامها ، كما هو شأن محكمة القيم ، التي ورد النص بشأن إتباعها قواعد قانون المرافعات م ٣٨ من القانون الخاص بها رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ الصادر في ١٥ مايو سنة ١٩٨٠ م .

انظر : قوانين المرافعات د/ أمينة النمر . بند ٢٨٨ . ص ٦٣٤ .

(٢) انظر ص ٢٣٤ وما بعدها من البحث .

(٣) الوسيط د / فتحي والى . بند ١٨٨ . ص ٢٨٤ ، ص ٢٨٥ ، أصول علم القضاء . د / عبد الرحمن عياد . ص ٢٧٨ .

(٤) قانون القضاء المدني د / فتحي والى . بند ٢٣٦ . ص ٥٧٠ ، الدفوع والطلبات العارضة أ / مجدى هرجة ص ٤٣ ، قوانين المرافعات د/ أمينة النمر . بند ٢٨٧ . ص ٦٣١ .

ومن ثم فإن انطواء المحاكم الاستثنائية أو اللجان الإدارية على عناصر غير قضائية ، أو اختلاف الإجراءات المتبعة أمامها عن تلك التي تتبع أمام المحاكم القضائية، لا ينفى عن عملها المنوط بها أنه عمل قضائي تباشره بمقتضى القانون^(١). وبناءً على ما تقدم أرى جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص بين المحاكم القضائية وجهات القضاء الاستثنائية بأنواعها المختلفة ، كجوازها بين المحاكم القضائية ذات التشكيل القضائي الفنى .

ولا أرى قبولاً للقول بتضييق نطاق الإحالة بقصرها على المحاكم القضائية المشكلة تشكيلاً قضائياً ، كما يذهب إليه بعض الفقه الإجراءي^(٢) .

خامساً : تقييد الإحالة في مجال القضاء المستعجل :

يسرى حكم المادة ١١٠ مرافعات على القضاء المستعجل بشرط أن تكون الدعوى التي رفعت إلى قاضى الأمور المستعجلة دعوى موضوعية ، أخطأ المدعى فى رفعها^(٣) ، كدعوى تثبيت الملكية ، ففي هذه الحالة يجب على القاضى المستعجل أن يقضى فى هذه الدعوى بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الموضوع المختصة^(٤) .

أما إذا كانت الدعوى المرفوعة إلى القاضى المستعجل دعوى مستعجلة لم يتوافر بشأنها شرط الاستعجال أو عدم المساس بأصل الحق ، كدعوى طرد المستأجر الذى قام بسداد الأجرة ، فهنا يجب على القاضى المستعجل أن يقضى بعدم الاختصاص فقط ولا يأمر بالإحالة لأن قضاءه بعدم الاختصاص يعنى ضمناً

(١) الدفوع والطلبات العارضة أ / مجدى هرجة . ص ٤٣ ، نقض مدنى . طعن رقم ١٠٢٣ لسنة ٦٢ ق . جلسة ١٩٩٣/٢/١٨ م .

نقض مدنى . طعن رقم ٦٣٤ . لسنة ٤٥ ق . جلسة ١٩٧٩/٣/٢٤ م .

(٢) انظر هذا رأى : نظرية الدفوع د / أحمد أبو الوفا . بند ٢١٥ . ص ٣١١ ، المرافعات د / أحمد أبو الوفا . ص ٢٤٩ ، الوسيط . د / نبيل إسماعيل عمر . ص ٣٥٢ ، الاختصاص القضائي . أ / عبد الهادى عباس . بند ٢٨٢ . ص ٥٤٢ .

(٣) قوانين المرافعات د / أمينة النمر . بند ٢٨٩ . ص ٦٣٩ .

(٤) الدفوع والطلبات العارضة . أ / مجدى هرجة . ص ٤٨ ، الوسيط . د / فتحى والى . بند ١٨٨ ص ٢٨٤ .

الحكم برفض الدعوى وعدم قبولها^(١) ؛ لانتهاء شرطها ولا صحة للأمر بالإحالة ، حيث إنها لا تكون إلا تبعاً للحكم بعدم الاختصاص^(٢) .
والقاضي المستعجل يتحدد اختصاصه بالطلب الوقتي ، فإذا توافر شرطه كان مختصاً بنظره وإلا قضى فيه بعدم القبول ، حيث لم يرق له اختصاص بنظر دعوى تخلف عنها شرطها ، ومن ثم فيقضى بعدم القبول ، وإذا قضى بعدم الاختصاص فهذا يعنى رفضه للدعوى وعدم قبولها ولا يجوز له والدعوى على تلك الحالة أن يأمر بالإحالة لأن الإحالة مقيدة بعدم الاختصاص .
وبهذا يكون حكم عدم الاختصاص من القاضي المستعجل سببه ذات الدعوى دون شخص القاضي .

المبحث الثاني

الآثار الإجرائية المترتبة على الإحالة

إذا ما انتهت المحكمة من بحثها في الدفع بعدم الاختصاص ، وتبين لها أنها هي المختصة بنظر الدعوى حكمت برفض الدفع واستمرت في نظر الدعوى ، وأما إذا قضت بقبول الدفع فالدعوى تزول من أمامها ، وقد أوجب عليها المقنن في هذه الحالة أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة^(٣) عقب حكمها بعدم الاختصاص ، أيّاً كان نوع الاختصاص ، الذي استندت إليه في حكمها .
وبناءً على هذا يترتب على الأمر بالإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص الآثار الإجرائية التالية :

(١) الوسيط. د / فتحي والى. بند ١٨٨. ص ٢٨٣ ، ص ٢٨٤ ، قوانين المرافعات . د/ أمينة النمر . بند ٢٨٩ . ص ٦٤١ .

(٢) وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بعدم الاختصاص لعدم توافر ركن الإستعجال حكم منه للنزاع أثره عدم جواز إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع . نقض مدني . طعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٥١ ق . جلسة ١٩٨٦/١/٢ م .

(٣) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوي. بند ١٥٢ ص ٢١٤ ، قوانين المرافعات د/ أمينة النمر. بند ٢٨٧ . ص ٦٢٩

أولاً : استنفاد المحكمة المحيلة سلطتها على الدعوى .

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً، أو قيمياً، أو نوعياً ، أو محلياً وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بناء على دفع الخصم ، أو من تلقاء نفسها تستنفد بذلك سلطتها القضائية على الدعوى محل الإحالة^(١) .

وبذلك فإن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة ينهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ، وإن لم تتعرض فيه للحق الموضوعي محل الدعوى ، ومن ثم لا يكون لهذه المحكمة سلطة التصدي لهذه الدعوى مرة أخرى ، كما أنه لا يجوز للخصوم إعادة رفع الدعوى من جديد أمام تلك المحكمة ، حيث انتهت الخصومة أمامها بمجرد الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ، ومن ثم فإن الدعوى تعتبر في حق المحكمة المحيلة كأن لم تكن ، وذلك في حدود المسألة التي قضت فيها^(٢) .

ولا سبيل لإعادة سلطة المحكمة المحيلة على الدعوى مرة أخرى سوى الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة ، وإلغاء الحكم المطعون فيه من قبل المحكمة الاستئنافية^(٣) ، والحق في الطعن لا تملكه المحكمة المحيلة ، إذ يتقرر قانوناً للخصوم أطراف الدعوى، ومن ثم فلهم الحق في التمسك به أو النزول عنه فإذا لم يتم الطعن في حكم المحكمة المحيلة ، أو رفع الطعن بعد فوات وقته المحدد له قانوناً أو تنازل الخصم عنه أو سبق اتفاهه على نهائية الحكم الذي يصدر في الدعوى أيّاً كان نوعه ، ففي هذه الحالة لا يجوز للخصوم بأى حال إعادة دعواهم أمام المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص والإحالة ، وإذا رفعت تلك

(١) أصول قانون المرافعات د/ أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص ٤٩٠ ، ص ٤٩١ ، الدفوع والطلبات العارضة . أ / مجدى هرجة . ص ٤٠ ، ص ٤١ .

(٢) المرافعات د/ محمد حامد فهمى . بند ٤٤٢ . ص ٤٨٧ ، بحوث في قواعد المرافعات . د/ عبد العزيز بديوى . ص ٨٥ .

(٣) أصول قانون المرافعات د / أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص ٤٩١ ، الاختصاص القضائي . أ / عبد الهادى عباس . بند ٢٨٣ . ص ٥٤٣ .

الدعوى أمام المحكمة المحيلة مرة أخرى فإنها تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها^(١) .

هذا ويلاحظ أن للمحكمة المحيلة سلطة جوازية في توقيع الغرامة المالية على المدعى الذى أخطأ في رفع دعواه إلى محكمة غير مختصة^(٢) .

وهذه الغرامة تعد جزاءً إجرائياً يوقعه القانون على الخصم عند مخالفته قواعد الاختصاص المقررة ، وهذه الغرامة لا تجاوز قيمتها أربعمئة جنيه ، ويلزم المدعى بأدائها طبقاً للمادة ١١٠ مرافعات^(٣) .

كما يلاحظ أن مجال توقيع هذه الغرامة هو حالة قبول الدفع بعدم الاختصاص ، أما إذا قضت المحكمة برفض الدفع فلا يجوز لها قانوناً توقيع الغرامة ، لأن نص المادة ١١٠ مرافعات يعد استثناءً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه^(٤) .

ويجوز للمحكمة إعفاء المدعى من تلك الغرامة إذا ثبت لديها أن المدعى كان معذوراً في خطئه ، لعدم وضوح الاختصاص.

ثانياً : انتقال الدعوى من المحكمة المحيلة إلى المحكمة المحال إليها أي كان نوعها أو طبقته .

يترتب على الحكم بعدم الاختصاص والأمر بالإحالة انتقال الدعوى من المحكمة المحيلة إلى محكمة أخرى ترى المحكمة المحيلة أنها مختصة قيمياً أو نوعياً أو محلياً بنظر الدعوى ، طبقاً لقواعد الاختصاص^(٥) .

(١) قوانين المرافعات د / أمينة النمر . بند ٢٨٧ . ص ٦٣٣ ، الاختصاص القضائي . أ / عبد

الهادى عباس . بند ٢٨٣ . ص ٥٤٣ .

(٢) قانون القضاء المدنى د/ فتحى والى . بند ٢٣٦ . ص ٥٦٨ .

(٣) تضاعفت قيمة الغرامة الواردة فى المادة ١١٠ من قانون المرافعات بمقتضى القانون رقم ٧٦

لسنة ٢٠٠٧ م ، وذلك من مائتي جنيه الـ أربعمئة جنيه ، انظر المادة الرابعة من هذا القانون .

(٤) أصول قانون المرافعات د / أحمد هندى . بند ١٧٩ . ص ٤٩٥ ، قانون القضاء المدنى . د /

فتحى والى بند ٢٣٦ . ص ٥٦٨ .

(٥) الوسيط. د/أحمد السيد صاوى. بند ١٥٢ . ص ٢١٥ ، الدفوع والطلبات العارضة. أ/مجدى

هرجة ص ٤٦ .

أما إذا كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة سببه انتفاء الولاية فيكفي لصحة الإحالة أن تحدد المحكمة المحيلة الجهة ذات الاختصاص دون تعيين للمحكمة المختصة داخل تلك الجهة^(١) ، كما هو الشأن في قضاء محكمة عادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الإدارية والأمر بإحالتها إلى جهة القضاء الإداري المختصة قانوناً بنظرها ، وكذلك الحال بالنسبة للإحالة من جهة القضاء الإداري إلى جهة القضاء العادي^(٢) ، حيث يكفي لصحة أمر الإحالة أن يكون متضمناً تحديد اختصاص الجهة القضائية دون تعيين المحكمة المختصة التابعة لتلك الجهة وذلك دفعاً لتسلط قضاء محكمة تتبع جهة معينة على تحديد اختصاص محكمة أخرى تابعة لجهة أخرى^(٣) .

وقد هدف المقنن من تحديد الاختصاص بنظر الدعوى إلى احترام حكم المحكمة المحيلة الذي قضى باختصاص جهة أخرى ؛ دفعاً لحالات تنازع الاختصاص السلبي بين جهتي القضاء^(٤) .

أما إذا كانت المحكمة المحيلة والمحكمة المحال إليها تتبعان جهة قضائية واحدة فقد أوجب المقنن على المحكمة المحيلة أن تحدد عند الحكم بعدم الاختصاص المحكمة التي تنتظر الدعوى^(٥) ولا يعد هذا تسلط قضاء محكمة على تحديد اختصاص محكمة أخرى ؛ لأن مصدر التحديد هو القانون — م ١١٠

(١) قانون القضاء المدني د / فتحي والي . بند ٢٣٦ . ص ٥٦٧ ، أصول قانون المرافعات . د / أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص ٤٩١ .

(٢) الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ١٥٢ . ص ٢١٥ ، الوسيط . د / نبيل إسماعيل عمر . ص ٣٥١ .

(٣) قانون القضاء المدني د / فتحي والي . بند ٢٣٦ . ص ٥٦٧ ، ص ٥٧٠ ، الدفوع والطلبات العارضة / أمجدى هرجة . ص ٤٣ .

(٤) الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ١٥٢ . ص ٢١٥ ، ص ٢١٦ .

(٥) أصول قانون المرافعات د / أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص ٤٩١ ، قانون القضاء المدني د / فتحي والي . بند ٢٣٦ . ص ٥٦٧ .

مرافعات — وليس أمر الإحالة ، ومن ثم فيجب احترامه وإعمال أحكامه والعمل بموجبه ومقتضاه .

وبناءً على هذا تنتقل الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة إلى المحكمة المحال إليها ، ويستوى في ذلك أن تكون المحكمة المحال إليها من نفس طبقة المحكمة المحيلة أو من طبقة أعلى أو أدنى منها^(١) ، وذلك لعموم نص المادة ١١٠ مرافعات حيث قضى بوجوب الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص دون تمييز بين طبقات المحاكم أو درجاتها .

وبناءً عليه : تصح الإحالة من محكمة جزئية إلى محكمة جزئية أخرى ومن محكمة جزئية إلى محكمة ابتدائية والعكس ، كذلك تصح الإحالة من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف وهكذا .

هذا وتلتزم المحكمة المحيلة بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها وإخطار الخصوم بموعدها ، حتى يتسنى لهم متابعة سير دعواهم طبقاً للقانون^(٢) .

ثالثاً : التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها على حالتها .

تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها تنفيذاً لحكم الإحالة ، بيد أن هذه المحكمة تتقيد وهي بصدد نظر الدعوى بالحالة التي تكون عليها وقت الحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة من قبل المحكمة المحيلة، ويستوى في ذلك أن تكون

(١) لأن المقرر من قضاء محكمة النقض : أن مفاد المادة ١١٠ من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها " ، نقض مدنى . طعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦ م . ص ٧٩٤ .

(٢) الوسيط. د/فتحى والى. بند ١٨٨. ص ٢٨٣ ، ص ٢٨٤ ، أصول علم القضاء. د/ عبد الرحمن عياد ص ٢٧٨ ، بحوث فى قواعد المرافعات د / عبد العزيز بديوى . ص ٨٩ .

الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المحيلة في صورة دعوى أصلية ، أو في صورة دعوى تبعية ، أو في صورة طلب عارض أو مرتبط^(١) .

وهذا يعني أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى تعتد بكافة الإجراءات ، وأدلة الإثبات والأحكام الفرعية التي اتخذت أو صدرت في الدعوى محل الإحالة ، وذلك عملاً بما تقرره المادة ١١٠ مرافعات من أن الدعوى تحال إلى المحكمة بحالتها التي تكون عليها وقت الحكم بعدم الاختصاص^(٢) .

هذا ويحق للخصوم عند متابعة دعواهم أمام المحكمة المحال إليها التمسك بجميع أوجه الدفع والدفاع التي كانت مقررة لهم أمام المحكمة المحيلة^(٣) ، وهذا يعد تأكيداً على مبدأ أن الدعوى عند الإحالة تحال بحالتها.

رابعاً : حق المحكمة المحال إليها في القضاء بعدم الاختصاص والإحالة .

إذا رأت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها لسبب آخر قام لديها كان لها الحق في القضاء بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، كما لو أحيلت إليها دعوى من محكمة جزئية مثلاً لعدم إختصاصها بنظرها محلياً ، ورأت المحكمة المحال إليها أنها لا تختص بها نوعياً ، فإنها تحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية المختصة^(٤) ، كما يحق أيضاً للمحكمة الأخيرة القضاء بعدم الاختصاص المحلي والإحالة إلى المحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر الدعوى وهكذا .

(١) وإذا كان الاختصاص القضائي يباشر بغير طريق الدعوى فلا تتم الإحالة ، كما لو قدمت عريضة أمر الأداء إلى قاضٍ غير مختص ، رفض الأمر لعدم الاختصاص ، فإنه لا يحيله إلى القاضي المختص . قوانين المرافعات . د / أمينة النمر . بند ٢٨٨ . ص ٦٣٤ ، ص ٦٣٥ .

(٢) الوسيط . د/أحمد السيد صاوى . بند ١٥٣ . ص ٢١٥ ، ص ٢١٦ .

(٣) الوسيط . د / فتحي والي . بند ١٨٨ . ص ٢٨٣ .

(٤) قوانين المرافعات د / أمينة النمر . بند ٢٨٧ . ص ٦٣٠ ، نقض مدني . طعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق . جلسة ١٥/٥/١٩٩٦م .

والسبب في هذا يرجع إلى أن التزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى محدد بالأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة^(١) .
ومن ثم يحق للمحكمة المحال إليها أن تقضى بعدم الاختصاص لسبب آخر تراءى لها ، ويعد هذا تطبيقاً عملياً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً .
كذلك يحق للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تقضى بعدم القبول لسبب يقتضيه كانتفاء المصلحة في رفع الدعوى وشبهها^(٢) .

ومما تجدر ملاحظته في هذا الشأن

أن المحكمة المحال إليها الدعوى إنما تكون قد أدت التزامها المفروض عليها بمقتضى المادة ١١٠ مرافعات إذا قامت بمجرد النظر في الدعوى ، ولو لم تفصل هي في موضوعها^(٣) — كما لو تبين لها عدم الاختصاص بنظر الدعوى لسبب آخر على النحو السابق بيانه —.

وأرى أن المقنن كان موفقاً عندما استخدم في المادة ١١٠ مرافعات عبارة " بنظرها " دون عبارة " الفصل في موضوعها " مما يؤكد على أن المحكمة المحال إليها ليست ملزمة قانوناً بالفصل في موضوع الدعوى تنفيذاً لأمر الإحالة ، وإنما قيامها بالنظر في الدعوى — ولو قضت بعدم الاختصاص لسبب آخر أو قضت فيها بعدم القبول — يعد تنفيذاً منها لأمر الإحالة وأداءً لواجبها المفروض عليها بمقتضى القانون — ، وهذا لا يناقض حق الخصوم في الطعن على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة أياً كانت المحكمة التي أصدرته^(٤) .

(١) نقض مدنى ، طعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق . جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م. المستحدث . ص ٢٢٣

(٢) الدفوع والدفاعات د/عبد الحكم فودة. ص ٣٠ ، قانون القضاء المدنى د/فتحى والى . بند ٢٣٦ . ص ٥٦٨ ، ص ٥٧٠ .

(٣) أصول قانون المرافعات د / أحمد هندى . بند ١٧٩ . ص ٤٩٤ .

(٤) الوسيط . د/رمزى سيف. ص ٣٩١ ، الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى . بند ١٥٢ . ص ٢١٥ ، ص ٢١٦ ، الدفوع والدفاعات د / عبد الحكم فودة . ص ٣٢ .

خامساً : الإبقاء على الإجراءات السابقة على أمر الإحالة .

تحال الدعوى عند الحكم بعدم الاختصاص إلى المحكمة المختصة بكل ما اتخذ فيها من إجراءات ، وما تم فيها من تحقيقات ، وأعمال للخبراء ، وما قدم فيها من أدلة للنفي أو الإثبات ، ومن ثم فهي تنتقل بكافة آثارها المترتبة عليها اعتباراً من يوم رفعها^(١) ، فضلاً عن الإجراءات التي رفعت بمقتضاها أمام القضاء ، بحيث لا يحتاج المدعى إلى تجديد لرفع دعواه أمام المحكمة المحال إليها ، وإنما تبدأ هذه المحكمة بالنظر في الدعوى من حيث انتهت المحكمة المحيلة^(٢) .

وهذا يدل على مدى مرونة القضاء ووحدة عناصره ومحاكمه المختلفة ؛ ليعبر عن قضاء موحد لا تناقض ولا انفصال فيه ، بل هو كل لا يتجزأ .

هذا ويمكن القول بأن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة يعبر في ذاته بطريق ضمنى عن حكم آخر هو اختصاص المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى ، مما يستلزم القول بحجية هذا الحكم أمام جميع المحاكم^(٣)

والفقه الإسلامي يرتب عند إحالة الدعوى من قاض إلى آخر وجوب نظر القاضى الآخر المحال عليه فى الدعوى المحالة إليه ، ومصدر هذا الوجوب هو أصل الولاية وليس أمر الإحالة^(٤) فالقاضى المحيل انتفت عنه ولاية الفصل فى

(١) الوسيط. د/نبيل إسماعيل عمر. ص ٣٥٠ ، الدفوع والدفاعات . د/ عبد الحكم فودة . ص ٣١ . هذا وتعد الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة المحيلة ، بحوث فى قواعد المرافعات . د / عبد العزيز بديوى . ص ٨٩ هامش رقم " ١ " .

(٢) الوسيط . د / رمزى سيف . ص ٣٩١ ، الوسيط . د / فتحي والى . بند ١٨٨ . ص ٢٨٢ .

(٣) أصول قانون المرافعات . د / أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص ٤٩٤ ، الوسيط. د/ أحمد السيد صاوى . بند ١٥٢ . ص ٢١٥ ، ص ٢١٦ ، نقض مدني ، طعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦٥ ق ، جلسة ٧ / ٥ / ١٩٩٦ م . ص ٧٣٦ ، طعن رقم ٣٩٢٩ لسنة ٦١ ق جلسة ٥ / ٤ / ١٩٩٧ م . ص ٦١٣ ، طعن رقم ٢١١٦ لسنة ٦٦ ق جلسة ٢٩ / ٦ / ١٩٩٧ م . ص ١٠٣٤ .

(٤) نظام القضاء فى الإسلام . د / محمد جمال الدين عواد . ص ١٤٣ .

الدعوى ، فى حين أنها ثبتت عليها ولاية نظر القاضى المحالة إليه ، طبقاً لقواعد الاختصاص التى تحدد اختصاص كل قاض وترسم حدود ولايته .

وهذا هو معنى وجوب نظر القاضى فى الدعوى المحالة عليه فالوجوب مصدره ثبوت الولاية له دون أمر الإحالة إليه.

وبناءً على هذا يستنفذ القاضى الأول سلطته على الدعوى ؛ لعدم اختصاصه بها دون القاضى الثانى الذى تدخل الدعوى فى اختصاصه بمقتضى ولايته .

كذلك يرتب الفقه الإسلامى على إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص اعتبار الإجراءات التى رفعت بها الدعوى والاعتداد بما تم فيها من إثبات للحجج الشرعية وشهادة للشهود المعنية ، وأيمان جبرية اعتبرها القاضى الأول^(١) على وجهها الشرعى مخاطباً بها القاضى الثانى المكتوب إليه^(٢) .

وفى هذا تقصير لمدد التقاضى ، ورفع للمشقة عن عاتق القاضى من أن يعيد الثبوت أو إجراءات التقاضى ، هذا فضلاً عن سرعة الفصل فى الدعاوى والخصومات ، وتيسير الأمر على المتقاضين فى حسم المنازعات.

وقد أورد الفقه الإسلامى عدة أمثلة على الإحالة الوجوبية بعد الحكم بعدم الاختصاص أهمها :

١- إذا رفعت دعوى تتعلق بعقار ليس فى بلد القاضى فعلى القاضى الذى رفعت إليه أن يحيلها إلى القاضى الذى يقع العقار فى دائرة اختصاصه^(٣).

يقول ابن فرحون " وفى مختصر الواضحة فى الرجل من أهل المدينة يكون له دار بمكة فيدعيها رجل من أهل مكة قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إنما تكون خصومتها حيث الدار والشئ المدعى فيه "

(١) مواهب الجليل للحطاب ٦ / ١١٠ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٤٠ ، ٤١ .

(٢) المغنى ومعه الشرح الكبير لابن قدامة ١١ / ٤٥٨ وما بعدها .

(٣) فكل دعوى تتعلق بعقار كالأراضى والدور والتركات العقارية وأشباهاها ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضى موقع العقار انظر : جامع الفصولين . لابن قاضى سماونه ١ / ١٦ ، تبصرة الحكام . لابن فرحون ١ / ٦٧ .

بيد أنه يلاحظ أن المدعى في هذه الدعوى بالخيار بين رفع دعواه مباشرة إلى قاضى بلد الدار ، أو رفع دعواه أمام قاضيه لإثبات حجته ثم إحالة دعواه إلى قاضى موقع الدار ، ويكتب القاضى المحيل إلى القاضى المحال إليه ما ثبت عنده من المدعى وما استند إليه من حجج شرعية^(١) .

٢- إذا رفعت دعوى على المدعى عليه في غير موطنه في الوقت الذى تقرر فيه قواعد الاختصاص الشرعية عقد الاختصاص بنظر الدعوى لقاضى موطنه ، فهنا يكون للمدعى عليه الحق فى الدفع بعدم اختصاص القاضى الذى رفعت إليه دعوى المدعى يطلب فيها إحالة الدعوى إلى قاضى موطنه المختص بنظرها شرعاً ، وعلى القاضى الناظر فى الخصومة إجابته إلى طلبه^(٢) .

٤- إذا رفعت دعوى تنفيذية أو مستعجلة إلى قاض قصرت ولايته القضائية على الأنكحة فقط أو النفقات فقط أو المداينات فقط ، فعلى القاضى إحالة الدعوى إلى القاضى المختص بالتنفيذ على المحكوم عليه دون غيره^(٣) .

(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٦٧ ، وجاء فيه : " قال ابن حبيب وخالف مطرف وأصبع قول ابن الماجشون فى ذلك وقالوا إنما تكون الخصومة حيث يكون المدعى عليه ولا يلتفت إلى موضع المدعى ولا موضع المدعى فيه غير أن من حق المدعى إن شاء بدأ بقاضيه يعنى قاضى مكة فرفع إليه أمره وأثبت عنده بينته ثم كتب قاضى مكة بذلك إلى قاضى المدينة " .

(٢) نظرية الدعوى . د / محمد نعيم ياسين . ص ٦٠١ .

(٣) المغنى ومعه الشرح الكبير . لابن قدامة ١١ / ٤٥٨ .

الباب الثالث

نظرية الدعوى والخصومة القضائية

الفصل الأول : الدعوى وطبيعتها القانونية .

الفصل الثاني : شروط قبول الدعوى.

الفصل الثالث : تقسيمات الدعوى.

الفصل الرابع : دعاوى الحيابة .

الفصل الأول

ماهية الدعوى وطبيعتها القانونية

المبحث الأول

ماهية الدعوى

تستعمل كلمة الدعوى في عدة معانٍ (١) ، فقد يقصد بها " المطالبة أمام القضاء ، فيقال : رفع شخص الدعوى ، أي : قدم طلباً إلى القضاء ، وأحياناً أخرى يقصد بلفظ الدعوى : الادعاء ، فيقال : البينة على من ادعى ، وأحياناً تستعمل الدعوى بمعنى الحق في حكم بمضمون معين لصالح المدعي ، كما هو شأن دعوى الاسترداد ودعوى منع التعرض .

وأخيراً : تستعمل الدعوى لتعني مجموعة الإجراءات أمام القضاء ، فيقال : مصاريف الدعوى ، أي المصاريف التي أنفقت بالنسبة لجميع إجراءات الخصومة (٢) .

هذا ويمكن لنا تعريف الدعوى بأنها : الوسيلة الشرعية التي تخول لصاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته .

(١) الدعوى لغة : اسم من الادعاء وهو المصدر ، أي أنها اسم لما يدعي ، وجمعها دعاوى بكسر الواو ، وفتحها (المصباح المنير للفيومي ١ / ٢٣٢) ولها إطلاقات متعددة بعضها حقيقي ، وبعضها مجازي منها ، الطلب والتمني ، كما في قول الله تعالى : (لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون) [الآية : ٥٧ من سورة يس] ، كما تستعمل بمعنى الدعاء ، كما في قول الله تعالى : (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) ، وتستعمل كثيراً بمعنى إضافة الإنسان إلى نفسه شيئاً . انظر : لسان العرب ، مادة : دعو ، المصباح المنير ١ / ٢٣٢ ، نظرية الدعوى د / محمد نعيم عبد السلام ١ / ٩٣

(٢) الوسيط أ.د / فتحي والي ، ص : ٤٣ .

وعلى ذلك فالدعوى وسيلة قانونية تعطي صاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء سواء لجأ لها أم لم يلجأ ، فهي باقية في الحالتين ، وبمقتضى هذه الوسيلة يلجأ صاحب الحق إلى القضاء لصون حقه حماية أو تقريراً ، وهي تختلف عن الوسائل الأخرى التي تحمي الحق ، كحق الدفاع الشرعي ، وحق الحبس ، فهي إن كانت وسائل قانونية ، غير أنها قد يباشرها صاحب الحق بنفسه دون تدخل سلطة أخرى .

هذا ولا يجوز للإنسان بحال أن يقتضى حقه بيده ، حيث تكفلت الدولة دون غيرها بإقامة العدل بين رعاياها وفي إقليمها ، وقد جعلت التقاضي حقاً مصوناً ومكفولاً للناس كافة ، ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، متى وقع اعتداء على حق من حقوقه ، وقد نصت على ذلك في جميع دساتيرها المختلفة . وعليه فإن القضاء في مجتمعنا المعاصر باعتباره مرفقاً عاماً من مرافق الدولة له الدور الهام والفاعل في استقرار مبادئ العدل وبسط المساواة بين أفراد المجتمع .

فالقاضي بعمله النبيل ورسالته الرفيعة يهيء للمجتمع سبل الأمن ليطمئن كل فرد من أفرادها على نفسه وماله وعرضه.(١) ، وهنا تتجلى وظيفة الدولة في أن توزع العدل على مواطنيها من خلال سياساتها المختلفة - الاقتصادية ، الاجتماعية والسياسية - ، ومن خلال تنظيمها لقضاء عادل يضمن الطمأنينة للناس في أموالهم وأرزاقهم وسائر حقوقهم(٢) .

(١) راجع د/ عادل محمد جبر ، حماية القاضي وضمانات نزاهته دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية، رسالة ماجستي، كلية الشريعة والقانون بطنطا ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م ص ٣٧ .

(٢) راجع أ/ عاطف صالح، المساواة في الظلم عدل ، مقال منشور في مجلة المعمل القانوني، الكتاب الخامس (ملف دستور الثورة) صيف ٢٠١٢م، ص ١٣٧، ١٣٨ .

المبحث الثاني

طبيعة الدعوى

يمكن القول بأن طبيعة الدعوى محل خلاف بين الفقه القانوني هل هي الحق ذاته أم هي شيء آخر مختلف عن الحق ، وإذا كانت شيئاً آخر فما هو هذا الشيء ، وما هي العلاقة إذن بين الحق والدعوى .

وهنا نقول بأن الفقه قد أورد في هذا الشأن ثلاث نظريات مختلفة نعرضها بإيجاز على النحو التالي :

الأولى : النظرية التقليدية :

ومفادها : أن الحق والدعوى شيء واحد فالدعوى هي ذات الحق في إحدى ظواهره ، وهي تندمج في الحق ، ومن ثم فهما كلمتان مترادفتان ، ولا فرق بينهما سوى الفرق بين السكوت والحركة ، حيث يكون الحق في حالته العادية في حالة سكون ، فإذا تحرك الحق أطلقنا عليه اسم الدعوى .

وهي الحالة الطبيعية التي يفترض قيامها في كل مجتمع منظم ، ففي حالة سكون الحق تتوارى الدعوى وتكون كامنة ، مع أنها موجودة ، ولكن صاحب الحق يتمتع به في هدوء ، وربما كان وجودها هو سبب استقرار الحق والانتفاع الهادئ به ، حتى إذا ما اعتدى على الحق أو تجاهله الغير اندفع هو بنفسه بحركة رد فعل ضد هذا الاعتداء أو الإنكار ، ويتحول الحق من حالة السكون إلى حالة الحركة ، فتظهر الدعوى عندئذ كمظهر من مظاهر الحق ، بحيث يمكن القول بأن الدعوى هي الحق في حالة الحركة ، ويطلق على هذه النظرية نظرية الوحدة والاندماج .

هذا وقد استند أصحاب هذه النظرية على الأسانيد التالية :

١- أن الحق والدعوى يولدان معاً أو ينشآن معاً وينقضيان معاً ونطاقهما واحد ، ومن ثم لا يتصور نشوء دعوى قبل نشوء الحق الذي تحميه ، أو أن تبقى قائمة بعد انقضائه ، كما لا يتصور نشوء الحق قبل أن توجد الدعوى المقررة لحمايته ، أو قيامه بعد انقضائها ، وكذلك فإن المدى الذي ينبسط عليه الحق والدعوى واحد .

٢- أن الصفات التي يحملها الحق هي نفسها الصفات التي تحملها الدعوى التي تحميه ، كما أنها تكتسب طبيعته ، فإن كان الحق مما يمكن التنازل عنه كانت الدعوى كذلك ، وإذا كان الحق يمكن تجزئته كانت الدعوى كذلك ، وإن كان الحق عينياً كانت عينية ، وإن كان عقارياً فالدعوى عقارية ، وإذا كان الحق شخصياً كانت الدعوى شخصية وهكذا .

٣- أن محل الحق أو موضوعه هو موضوع الدعوى ، فإذا كان الحق ينصب على عقار معين ، فالدعوى لا يمكن أن تنصب إلا على ذلك العقار ، وإن كان محل العقد منقولاً كدفع مبلغ من المال ، فإن موضوع الدعوى التي تحمي هذا الحق الشخصي يكون إلزام المدين بدفع هذا المبلغ (١) .

نقد النظرية التقليدية :

وجهت انتقادات عديدة لهذه النظرية ، أهمها :

١- يختلف حق الدعوى عن الحق الموضوعي من حيث السبب والموضوع والمدى .

أ- من حيث السبب ، سبب الحق يختلف عن سبب الدعوى ، وذلك أن الحق يكون سببه أي مصدره عقداً أو فعلاً ضاراً مثلاً أما الدعوى فسببها المنازعة بين المدعى والمدعى عليه ، وهذا السبب يختلف عن سبب الحق .

ب- من حيث الموضوع " موضوع الدعوى إلزام المدعى عليه باحترام حق المدعي أو بأدائه إليه أو بعدم التعرض له فيه ، فالدعوى تنصب دائماً على طلب الحكم ، أي إلزام المدعى عليه بعمل أو بامتناع ، أما الحق نفسه فإن موضوعه يختلف حسب طبيعته ، فقد يكون حقاً عينياً ، وقد يكون حقاً شخصياً ، فمثلاً: المالك الذي يطلب منع تعرض الغير له في ملكيته يكون موضوع دعواه إلزام هذا الغير بالامتناع عن التعرض في حين أن موضوع حقه هو ملكية العين ، فالحق

(١) نظرية المصلحة في الدعوى ، أ.د / عبد المنعم الشرقاوي ، ص : ٢٤ ، ٢٥ ، مبادئ المرافعات ، د/ عبد الباسط جميعي ، ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ .

عيني ينصب على شيء ، والدعوى تتمخض عن التزام سلبي ولا يمكن أن يقال إن موضوع الحق هو نفسه موضوع الدعوى أو موضوع الحكم الصادر فيها" (١).
ت- من حيث المدى ، يختلف مدى الحق عن مدى الدعوى ، ذلك أن الحق الواحد قد تتولد عنه جملة دعاوى ، كما في حالة حق الملكية ، الذي تتولد عن الاعتداء عليه دعوى بالاستحقاق ودعوى بالتعويض .

٢- قد يوجد الحق ولا توجد له دعوى ، كما في الالتزامات الطبيعية ، فإن الدائن هنا وإن كان لا يملك المطالبة بحقه إلا أن ذلك لا ينفي أن له حقاً —
بدليل أن المدين إذا وفي بالتزامه بالرضا فلا يقال إن المدين تبرع أو إن الدائن تلقى تبرعاً ، وإنما يقال إن المدين وفى الذى عليه والدائن استوفى حقه ، ومن هنا لا يمكن أن يقال إن انتفاء الدعوى يؤدي إلى انتفاء الحق ذاته ، إذ قد يوجد حق بلا دعوى .

٣- قد توجد دعوى بغير حق معين تستند إليه أو تمتزج به أو تندمج فيه مثل دعوى الصورية أو دعوى البطلان أو دعوى الفسخ ، فهذه دعاوى تقوم في عالم القانون ولها كيائها المسلم به ولا سبيل لإنكارها ومع ذلك لا يمكن تحديد الحق الذي تستند إليه هذه الدعاوى أو تمتزج به أو تندمج فيه (٢) .

الثانية : النظرية الحديثة :

وتسمى نظرية الازدواج ، ويقرر القائلون بها أن الدعوى رغم اتصالها بالحق إنما هي شيء مستقل عنه ، وهي وسيلة لحمايته وليست الحق ذاته ، وهي تشكل حقاً متميزاً بذاته ، له شروطه وقواعده الخاصة التي قد تختلف عن شروط الحق الأصلي الذي تقوم لحمايته .

(١) مبادئ المرافعات ، أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميع ، يرحمه الله ، ص : ٣٠٢ .

(٢) انظر : نظرية المصلحة ، أ.د / عبد المنعم الشرقاوي ، ص : ٢١ ، وما بعدها .

وبمقتضى هذه النظرية قد توجد حقوق ولا توجد لها دعاوى لحمايتها ، وقد توجد دعاوى لا يقصد بها حماية حقوق ما ، فالدعوى توجد بوجود المصلحة في رفعها وقبل وجودها لا توجد الدعوى (١)

وقد ساق القائلون بهذه النظرية حججاً يؤيدون بها رأيهم في اختلاف الدعوى عن الحق ، وخلصتها :

١- أن الحق يختلف عن الدعوى في السبب — كما ذكرنا — فسبب الحق الواقعة القانونية سواء كانت عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص القانون ، بينما سبب الدعوى هو الاعتداء على الحق أو المركز القانوني .

٢- الدعوى تختلف عن الحق في الشروط والأثر :

أما اختلافهما في الشروط ، فالدعوى يشترط لها الأهلية ، بينما لا تشترط للحق ، فالقاصر أو عديم الأهلية قد يكتسب حقاً كما لو ورث مالاً أو أوصى له بعقار ، ومع هذا لا يستطيع أن يرفع دعوى للزود عنه ؛ لأن رفع الدعوى يستلزم الأهلية .

وأما اختلافهما في الأثر ، فالدعوى تضيف عنصراً جديداً للحق ، فمثلاً الدائن رغم ثبوت حقه لدى المدين لا يستطيع أن ينفذ على أموال المدين إلا بعد استصدار حكم يلزم المدين بالأداء ، فالدعوى إذن زودت الحق بقوة لم تكن له من قبل .

٣- من المتصور وجود حق لا تحميه دعوى — كما سبق القول — بالنسبة للالتزامات الطبيعية ، فالحقوق التي تقابل الالتزامات الطبيعية ليس لصاحبها أن يطالب بها أمام القضاء .

كما قد توجد دعاوى لا تستند إلى حق موضوعي كدعوى النقابات التي نرفعها دفاعاً عن المهنة المشتركة ، وقد يحمي الحق الواحد أكثر من دعوى ،

(١) نظرية المصلحة ، أ.د / عبد المنعم الشرقاوي ، ص : ٢٧ .

فالمالك الذي اغتصب عقاره يستطيع أن يرفع دعوى ملكية ودعوى حيازة ودعوى تعويض (١) .

الثالثة : النظرية التوفيقية :

حاول بعض الفقهاء (٢) أن يوفق بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة ، فذهب إلى أن الدعوى ليست هي ذات الحق متحرراً ، كما أنها ليس لها كيان مستقل عن الحق الذي تحميه ، وإنما هي عنصر من عناصر الحق ، ذلك أن الحق مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون ، فعنصر الحق هما المصلحة والحماية القانونية ، وصورة الحماية القانونية هي الدعوى ، فالدعوى ليست إلا وسيلة لحماية الحق وهي تدور معه وجوداً وعدمًا .

ومن ثم لا يتصور وجود الحق بغير دعوى أو وجود الدعوى بغير حق ، ولكل حق دعوى واحدة تحميه ، فإذا وقع اعتداء على حق لشخص ونشأت بسبب ذلك عدة دعاوى ، كما إذا اغتصب عقار من مالكه يكون له رفع دعوى ملكية ، ودعوى حيازة ، ودعوى تعويض ، فذلك راجع إلى أن الاعتداء هنا وقع على حقوق عديدة بقدر عدد الدعاوى التي تنشأ ، فدعوى الملكية ؛ لأن اعتداء على ملكيته ، ودعوى الحيازة لأن اعتداء وقع على حيازته ، ودعوى التعويض لأن ضرراً لحق به نتيجة لهذا الاعتداء .

ومن ثم ينتهي أصحاب هذا الرأي إلى أن الدعوى وإن كانت تتصل بالحق اتصالاً وثيقاً وتتأثر ببعض مظاهره ، إلا أنها لا تختلط بالحق ولا تعدو أن تكون الدعوى وسيلة لحماية الحق (٣) .

(١) الوسيط أ.د / أحمد السيد صاوي ، ص : ١٦٧ .

(٢) الدكتور / عبد المنعم الشرقاوي في نظرية المصلحة ، ص : ٣٥ .

(٣) الوسيط أ.د / أحمد السيد صاوي ، ص : ١٦٧ ، ١٦٨ .

المبحث الثالث

التفرقة بين الدعوى وما يشته به

يؤكد شراح القانون على أن الحق في استعمال الدعوى مقرر لكل شخص ، وأن الدعوى باعتبارها وسيلة قانونية لحماية الحق ، أو لضمان احترام القانون (١) كما تستعمل بطريقة المطالبة أصلاً تستعمل أيضاً بطريق الدفع فرعاً ، أى رداً على طلب المدعى — من قبل المدعى عليه — ؛ وذلك لأن الدعوى التى يباشرها المدعى كالدفع الذى يبيده المدعى عليه (٢) ، لذا فقد اشترط فى الدفع عموماً ما اشترط فى الدعوى بصفة عامة ؛ حيث إن كلاهما يصدق عليه أنه وسيلة إجرائية يطلب الشخص بمقتضاها تقرير حق أو حمايته .

وبناء عليه نقول أن الدعوى يقصد بها :

الوسيلة الإجرائية المقررة لكل شخص فى اللجوء للقضاء ، والحصول على الحماية القانونية ؛ لتقرير حق ما أو ضمان احترامه بشروط مخصوصة .
وحق الشخص فى استعمال الدعوى وطلب الحماية القانونية يتأتى من كونه فرداً من أفراد المجتمع ، يطلب احترام نص القانون (٣) ، وبذلك يضمن لنفسه قضاءً عادلاً متوافقاً مع القواعد القانونية المقررة لحماية حقوق المتنازعين .
وعلى هذا فإن لكل ذى مصلحة الحق فى استعمال دعواه متى كان هناك إهداراً لقاعدة قانونية مقررة بنص القانون ، سواء أكانت هذه القاعدة موضوعية أى تحمى حقوقه الموضوعية ، أم إجرائية تضمن عدم المساس بحقوقه الدفاعية .

وأما المطالبة القضائية :

فهى لا تعدو أن تكون مجرد إجراء قضائى يتخذه المطالب أو من يمثله قانوناً لحماية حق أو تقريره (٤) ، يكفى لصحتها وقبولها ، والتزام المحكمة

(١) الوجيز د / عبد المنعم الشرقاوى بند ١٩ . ص ٢٢ .

(٢) نظرية المصلحة فى الدعوى . د/عبد المنعم الشرقاوى . بند ٦ ص ١٤ .

(٣) نظرية الدفع . د / أحمد أبو الوفا . بند ٤٦٠ ص ٧٨٨ ، ٧٨٩ .

(٤) قانون القضاء المدني . د / فتحي والي . بند ٥١ . ص ١٠٦ .

بالقضاء فيها أن يتبع الطالب الإجراءات التي ينص عليها القانون ، كإعلان صحيفة افتتاح الدعوى ، وقيد الدعوى في الميعاد المحدد ، وبمجرد استيفاء هذه الإجراءات تقبل المطالبة وتلتزم المحكمة بنظرها ، دون حاجة إلى اشتراط كون المطالب محقاً في مطالبته أم غير محق (١).

وإذا ما استوفت المطالبة الإجراءات الشكلية السابق بيانها انعقدت بذلك الخصومة (٢).

وأما عن الخصومة :

فهى تعنى مجموعة الإجراءات التى تستمر من وقت المطالبة القضائية للحصول على الحماية القانونية إلى حين الفصل فى موضوعها بحكم ينهى النزاع بشأنها ، أو انقضائها بنحو صلح أو ترك (٣).

وتبدأ الخصومة بإيداع صحيفة الدعوى ، وإعلان الخصم بها ، وتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة .

وفى الفقه الإسلامى :

الدعوى لغة : اسم لما يدعيه المرء ، وهى تعنى إضافة إنسان شيئاً إلى نفسه فى منازعة أو غيرها (٤).

واصطلاحاً : " قول مقبول — عند القاضى — يقصد به طلب حق لنفسه قبل غيره ، أو دفعه عن حق نفسه " (٥).

وأما الدفع فهو وإن كان الوجه الآخر للدعوى ، ويشترك معها فى أركانها وشروطها من حيث وجوب استناده على حق مشروع ، وكونه بين طرفين أحدهما

(١) المرافعات . د / محمد حامد فهمي . بند ٣٢٩ . ص ٣٥٦ .

(٢) نظرية الدفوع . د / أحمد أبو الوفا . بند ٤٦٦ . ص ٧٩٨ .

(٣) نظرية المصلحة . د/عبد المنعم الشرقاوي . بند ٧ . ص ١٥ .

(٤) لسان العرب لابن منظور . مادة " دعا " ١٤ / ٢٥٧ .

(٥) وهو تعريف بعض الحنفية للدعوى انظر : تنوير الأبصار للتمرتاشى ، والدر المختار للحصكفى

٥ / ٥٤١ .

مدعٍ وآخر مدعى عليه ، وصيغة جازمة تعبر عن المقصود منه ، وكونه عند قاض مختص بسماعه وإصدار حكم بشأنه، إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة (١) لصحة كل منها ، إلا أن الدفع ليس هو ذات الدعوى ، وهذا يستفاد من تعريف الدعوى السابق بيانه، حيث ورد فيه التعبير بحرف العطف (أو)، وهو كما يفيد العطف يفيد أيضاً التتويج ، وهذا هو المقصود في التعريف ، فدل ذلك على أن الدعوى غير الدفع ، لأن الدعوى ترفع من المدعى بحسب الأصل ، والدفع يبدى من المدعى عليه في صورة جواب عنها ، وإن كان الجامع بينهما أن كلا منهما يعد دعوى من جانب صاحبه .

وبناءً على هذا يمكن القول بأن الدفع هو الوجه الآخر للدعوى ، وهو : قول مقبول عند القاضى يقصد به دفع طلب خصمه عن حق نفسه .

وأما المطالبة القضائية : فهي تعد مضمون الدعوى الذى يعبر عنه المدعى وهذا يستفاد من تعبير الفقهاء عن معنى الدعوى بأنها (قول ... يقصد به طلب حق لنفسه ...)

وهذا يعنى أن المطالبة القضائية داخلية فى الدعوى ، أو هى جزء الدعوى ، وبهذا لا يتصور دعوى بلا مطالبة قضائية (٢) . فإن وجدت فهى دعوى غير مقبولة شرعاً .

وأما الخصومة : فهى لغة مأخوذة من " الخصم " ، وهو أصل يدل على المنازعة (٣) ثم سمي " المخاصم " " خصما " ، والأصل فى المخاصمة : أن يتعلق أحد الطرفين " بخصم " الآخر أى : جانبه (٤).

(١) بدائع الصنائع للكاظمي ٨ / ٣٩١٦ ط . مطبعة الإمام . القاهرة ، تبصرة الحكام لابن فرحون

١ / ١٠٦ ، الحاوى الكبير للماوردي ٢١ / ٣١٤ ، كشاف القناع للبهوتي ٦ / ٣٨٤ .

(٢) بحوث فى قواعد المرافعات والقضاء الإسلام . د/عبدالعزیز بديوى . ص ٢٠ .

(٣) لسان العرب لابن منظور ٤ / ١١٤ .

(٤) لسان العرب لابن منظور ٤ / ١١٤ .

ومنه قوله سبحانه تعالى ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴾ (١).

" والخصومة " معناها الجدل والمنازعة (٢) كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ (٣).

وفي اصطلاح الفقهاء : هي " اسم لكلام يجرى بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاحنة " (٤) ، أو هي " الدعوى والجواب عنها " (٥).

وبناء على هذا : فالخصومة في الفقه الإسلامي تعني الدعوى الصحيحة أو الجواب عنها بنعم أو لا (٦). فإذا رفعت دعوى دون أن يجاب عنها بإقرار ، أو إنكار ، أو دفع ، فهي دعوى وإذا أجيب عنها من قبل من وجهت إليه سميت خصومة .

وبهذا تختلف الدعوى عن الخصومة ، فالدعوى قد توجد دون أن تتضمن خصومة ، كما هو الشأن في دعاوى الحقوق العامة ، ودعاوى إثبات الحقوق أو حفظها (٧) ، كما أن الدعوى تنشأ بمجرد الإدعاء والطلب من المدعى ، ولكنها لا تسمى خصومة إلا بوجود المدعى عليه أو المطلوب ، الذي تتوجه إليه الدعوى ، إذن فالخصومة أعم من الدعوى ، فكل خصومة دعوى ، وليس كل دعوى خصومة ؛ لأن الدعوى توجد بالمدعى ، والخصومة لا توجد إلا بالمدعى والمدعى عليه ، لأنها منازعة بين خصمين أو أكثر .

(١) سورة " ص " آية (٢١) .

(٢) المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية ١ / ٢٣٩ .

(٣) سورة " ص " آية (٦٤) .

(٤) المبسوط للسرخسي ٦ / ٥٣٢ .

(٥) البحر الرائق لابن نجيم ٧ / ١٤٤ .

(٦) تكملة رد المحتار ٦ / ٢٥٧ .

(٧) دفع الخصومة . د / الغامدي ص ١٥٦ .

المبحث الرابع

خصائص الدعوى وعناصرها

نتناول الحديث عن خصائص الدعوى في مطلب أول، وعن عناصرها في مطلب ثان، وذلك علي النحو التالي .

المطلب الأول

خصائص الدعوى

نظراً لأن الدعوى وسيلة لحماية حق أو مركز قانون آخر ، ومن ثم فهي تتأثر بصفات الحق الذي ترمي لحمايته وترتبط به على التفصيل الآتي :

١ - الدعوى حق وليس واجباً :

إذا اعتدي على حق فلصاحبه أن يستعمل حقه في رفع دعواه للقضاء ، وله أن يترك ذلك ، ولا يجب عليه أن يرفع دعواه حماية لحقه ودفاعاً عن القانون وحماية المجتمع .

وإذا كانت الدعوى حقاً لصاحب الحق المعتدى عليه فلا يجوز له أن يسيء استعمال هذا الحق ، ويستعمله لمجرد الكيد والإضرار بخصمه ، فإن فعل جاز الحكم عليه بتعويض الضرر الذي يترتب على ذلك ، وكذلك المدعى عليه لا يجوز له أن يسيء استعمال حق الدفاع لمجرد الكيد والإضرار بخصمه (١) .

وهو حق مطلق بمعنى أنه لا يجوز الاتفاق مسبقاً على عدم مباشرته ، وإن كان يجوز الاتفاق على تقييده ، كأن يتفق المتعاقدون على عدم رفع الأمر للقضاء إلا بعد عرضه على محكمين .

ومادام لكل حق دعوى تحميه ، فلا يجوز لإنسان أن يقتضي حقه بغير وسيلة اللجوء إلى القضاء — في غير الحالات التي نص عليها القانون.

(١) قواعد المرافعات ، لمحمد العشماوي ، د / عبد الوهاب العشماوي ، ص : ٥٥٤.

٢ - الدعوى حق قابل للتنازل:

إذا تنازل صاحب الحق الموضوعي عن حقه فإنه يترتب على ذلك زوال حقه في الدعوى التي تحمي هذا الحق ، سواء قصد التنازل هذا الأثر أم لم يقصده. ولكن يجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن الدعوى فقط ، وهذا التنازل لا يترتب عليه التنازل عن الحق الموضوعي ، فهنا تنقضي الدعوى ويبقى الحق الموضوعي .

٣ - الدعوى حق يمكن حوالة وانتقاله.

الحق في الدعوى يمكن حوالة وانتقاله إلى الخلف العام أو الخلف الخاص ، وذلك إذا أحيل أو انتقل الحق الوضعي الذي تحميه هذه الدعوى ، ويلاحظ أن " المصلحة التي تحميها الدعوى قد تتعلق بشخص صاحبها ، وعندئذ لا تكون قابلة للانتقال إلى خلفه ، وكذلك الدعوى التي تحمي هذه المصلحة ، وقد يحدث أن تكون الدعوى غير قابلة للانتقال ، ولكنها تصبح قابله له إذا حدثت الخلافة بعد رفعها للقضاء ، من ذلك دعوى التعويض الأدبي " (١) .

٤ - الدعوى حق ينقضي بالتقادم.

الدعوى مدة محددة يجب رفعها خلالها ، فإذا مضت هذه المدة ولم تستعمل الدعوى تقادمت ولم يعد لها وجود .

وإذا كان القانون يتحدث عن تقادم الحق أو تقادم الالتزام ، فإن الذي يتقادم في الحقيقة هو الدعوى وليس الحق أو الالتزام ، بدليل أن مدة التقادم لا تسري إلا من وقت نشوء الحق في الدعوى ، كما أن حساب مدة تقادم الحق يقف بمجرد رفع الدعوى (٢).

(١) الوسيط / د فتحي والي ص : ٥٢ ، ٥٣ .

(٢) قانون المرافعات ، أ.د / أحمد هندي ، ص : ٤٤١ ، وما بعدها.

المطلب الثاني عناصر الدعوى

لكل دعوى ثلاثة عناصر هي أشخاصها ومحلها وسببها
ولتحديد عناصر الدعوى أهمية تتمثل فيما يأتي :

١- تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى واحدة أم بدعويين ، ذلك أنه إذا اتحد طلبان في هذه العناصر نكون بصدد دعوى واحدة ، وإن تعدد رفعها إلى القضاء ، أما إذا اختلف الطلبان في عنصر من هذه العناصر نكون بصدد دعويين وليس دعوى واحدة .

وينبغي على ذلك أمور ، منها :

(أ) لا يجوز أن تقوم خصومتان متعاصرتان بالنسبة لنفس الدعوى ، لما في ذلك من ضياع وقت القضاء ، فضلاً عن مخاطر تناقض الأحكام ، ولذلك إذا بدأت خصومة بالنسبة لدعوى معينة ، ثم بدأت خصومة ثانية بالنسبة لذات الدعوى ، تدفع الثانية بضمها إن كانت أمام نفس المحكمة أو بإحالتها إذا رفعت أمام محكمة أخرى.

(ب) إذا صدر حكم في نفس الدعوى فإنه يحول دون عرض هذه الدعوى مرة ثانية أمام القضاء ، ويتحدد ذلك بعناصر الدعوى .

٢- يتقيد القاضي في حكمه بعناصر الدعوى ، فليس له أن يحكم لشخص ليس طرفاً في الدعوى ، كما لا يجوز له أن يقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

٣- الطعن بالاستئناف يؤدي إلى نقل الدعوى التي فصلت فيها محكمة أول درجة بعناصرها إلى المحكمة الاستئنافية ، وهذا يقتضي تحديد عناصر الدعوى التي فصلت فيها محكمة أول درجة ، حتى لا تتغير موضعاً أو أشخاصاً أمام المحكمة الاستئنافية .

على أن تحديد عناصر دعوى معينة والقول بأن الأمر يتعلق بدعوى واحدة أو بدعويين تعتبر مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع (١) .

هذا ونتناول عناصر الدعوى بشيء من التفصيل على النحو التالي :

أولاً : أشخاص الدعوى :

هما من تكون له الدعوى ، ومن توجد الدعوى في مواجهته والأول هو المدعي والثاني هو المدعى عليه .

والمدعي هو رافع الدعوى ، أو البادئ في المطالبة القضائية وله صفة إيجابية وهي عادة صاحب الحق المدعي ، وقد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، كما قد يكون واحداً أو متعدداً (٢) .

والمدعى عليه هو المشكو منه ابتداء ، المراد الحكم عليه ، وله صفة سلبية هي صفة المدين أو المسئول عن الحق المدعي ، ولا يتغير وصفه في الدعوى الأصلية حتى ولو شكا بدوره من المدعي ، فإن ما قد يطلب الحكم له به على المدعي يسمى دعاوى المدعى عليه ، وقد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، كما قد يكون واحداً أو متعدداً .

وإذا اختلفت دعويان في شخص المدعي أو المدعى عليه ، فالعبرة في تحديد أشخاص الدعوى هي بصفاتهم في الدعوى لا بمباشرتهم إجراءاتها .

فقد يكون المدعي أو المدعى عليه ممثلاً في الإجراءات بواسطة شخص آخر كالقاصر يمثله الولي أو الوصي ، أو كان شخصاً معنوياً كشركة يمثّلها رئيس مجلس الإدارة ، ففي هذه الحالة يظل المدعي أو المدعى عليه هو الأصل وهو القاصر أو الشركة ، وليس الولي أو الوصي أو رئيس مجلس الإدارة ، ومن ثم إذا رفع الولي أو الوصي أو رئيس مجلس الإدارة بعد ذلك دعوى ينسب الحق لنفسه

(١) الوسيط أ.د. / فتحي والي، ص: ٧١ ، قانون المرافعات.

(٢) أصول المرافعات أ.د. / أحمد مسلم ، ص : ٣١٢ .

الذي كان يدعيه القاصر أو الشركة ، فإنها تعد دعوى مختلفة عن الدعوى الأولى من حيث أشخاصها (١).

ثانياً : محل الدعوى :

وهو ما يطلبه المدعي في دعواه ، فقد يطلب تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو يطلب إلزام المدعى عليه بأداء معين أو القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين أو طلب تغيير المركز القانوني ، كالتطبيق أو حل الشركة أو يطلب إجراء وقتي أو تحفظي ، كفرض نفقة مؤقتة أو تعيين حارس على عقار.

ويتكون محل الدعوى من ثلاثة عناصر :

١- نوع الحماية التي يطلبها المدعي ، تقرير أو إلزام أو تغيير ، ويختلف المحل باختلاف نوع الحماية المطلوبة ، ذلك أن دعوى تقرير صحة عقد بيع عقار معين تختلف عن دعوى إلزام البائع بتسليم العقار .

٢- نوع الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته ، ذلك أن دعوى تقرير ملكية أرض تختلف عن دعوى تقرير حق ارتفاق على هذه الأرض ، وأيضاً دعوى إلزام المؤجر بتركيب مصعد تختلف عن دعوى تخفيض الأجرة لعدم تركيب المصعد .

٣- محل الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته ، ذلك أن دعوى تقرير ملكية فدان معين تختلف عن دعوى تقرير ملكية بستان أو فدان آخر أو منقول ، ودعوى المطالبة بقسط من الدين تختلف عن دعوى المطالبة بقسط آخر (٢) .

واختلاف عنصر من عناصر المحل يؤدي إلى اختلاف الدعوى ، ونكون بصدد دعويين لا دعوى واحدة ، ومن باب الأولى إذا اختلف عنصران أو اختلف المحل بجميع عناصره ، وعلى ذلك فإن دعوى تقرير حق الزوج في إيقاع طلاق معين بإرداته المنفردة تختلف عن دعوى تقرير حق الزوج في إيقاع طلاق آخر ، نال الأول بالإرادة المنفردة لاختلاف المحل ، وأيضاً دعوى صحة ونفاذ عقد بيع

(١) مبادئ القضاء المدني أ.د. / وجدي راغب ، ص : ٧٨ ، ٧٩ .

(٢) مبادئ القضاء المدني أ.د. / وجدي راغب ، ص : ٧٩ .

جزء من منزل مملوك على الشيوع تختلف في موضوعها عن دعوى الشفعة المتعلقة بهذا الجزء (١) .

ويراعى أن تحديد ما إذا كان المحل مختلفاً في الدعويين قد يثير بعض الصعوبات ، ولذلك يراعى أنه لا ينفي وحدة محل الدعوى أن يكون المطلوب في دعوى بمجرد نفي المطلوب في دعوى أخرى ، كدعوى صحة عقد ودعوى أخرى ببطلان نفس العقد ، فالمحل واحد في الدعويين ، ومن ثم فالأمر يتعلق بدعوى واحدة لا دعويين ، وكدعوى الإلزام بدين ودعوى براءة الذمة من هذا الدين ، فالمحل واحد في الدعويين ، ومن ثم يتعلق الأمر بدعوى واحدة لا دعويين .

كذلك لا ينفي وحدة الدعوى الاختلاف في تحديد مقدار محلها إذا لم يكن أصلاً معين المقدار ، كالمطالبة بتعويض أو نفقة ، فمحل الدعوى هو تحديد التعويض أو النفقة بصرف النظر عن الرقم الذي يطلبه المدعى ، فهذا الرقم ليس هو محل الدعوى ، وإنما هو الحد الأعلى لسلطة القاضي ، وعلى ذلك إذا طلب المدعي بتعويض أو نفقة مقدارها ألف جنيه ، فله أن يطلب أثناء الخصومة ألفين أو خمسمائة دون أن يعتبر هذا طلباً جديداً ، وليس للمدعي بعد صدور الحكم بمبلغ معين أن يرفع دعوى للمطالبة بمبلغ أكبر ، حيث يتعلق الأمر بذات الدعوى ما لم تكن الدعوى الأولى قد رفعت بطلب مؤقت .

كما يراعى أن الدعوى التي ترفع بطلب شيء معين تختلف عن الدعوى التي ترفع بطلب قيمة هذا الشيء ، ولذلك إذا طالب شخص بسيارة ، فليس للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بقيمة هذه السيارة .

ولكن لأن الحكم بقيمة الشيء لا يتصور بغير ثبوت ملكيته ، فإن نفي الملكية نتيجة رفض الدعوى الأولى يؤدي إلى عدم قبول الدعوى الثانية (٢)

(١) الوسيط أ.د. / فتحي والي ، ص : ٧٣ .

(٢) الوسيط ، د / فتحي والي ، ص : ٧٣ ، ٧٤ .

ثالثاً : سبب الدعوى :

يسهم سبب الدعوى في تحديد معالم الشيء المطلوب القضاء به ، فهذا الشيء لا يتحدد فقط بتحديد المحل ، وإنما أيضاً بتحديد سبب هذه الحماية القضائية ، فإذا اختلف السبب كنا بسبب دعويين لا دعوى واحدة .

لا يقصد بالسبب النص القانوني المجرد أو القاعدة القانونية التي يستند إليها المدعي في دعواه ، وإنما يقصد به الوقائع القانونية المنتجة التي يتمسك بها المدعي كسبب للدعوى بصرف النظر عن التكييف القانوني لهذه الوقائع .

وعلى ذلك إذا استند المدعي إلى وقائع معينة كسبب لدعواه فإن الدعوى تظل واحدة لوحدة السبب ولو غير المدعي تكييفه لهذه الوقائع أو غير القاعدة القانونية التي يستند إليها في دعواه ، فإذا رفع شخص دعوى تعويض استناداً إلى وقائع معينة منسوبة إلى المدعى عليه تعتبر فعلاً ضاراً ، فإن تغيير تكييف هذه الوقائع لتحديد أنه تنطبق عليه قواعد المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية أياً كان نوعها لا يعني أن الأمر يتعلق بأسباب مختلفة ، وبالتالي بدعوى مختلفة ، وإنما يتعلق بتكييف مختلف يؤدي إلى اختلاف القواعد القانونية مع بقاء السبب واحداً ، وعلى العكس إذا اختلفت الوقائع التي يستند إليها المدعي في دعواه عن الوقائع في الدعوى الأولى فإن السبب يكون مختلفاً هذا ولو تشابهت هذه الوقائع أو تماثلت (١) ويجب أن نفرق بين سبب الدعوى وأدلتها ، فإذا رفع شخص دعوى إلزام استناداً إلى عقد بينه وبين المدعي عليه وقدم لإثبات العقد ورقة عرفية ، فإن استناده بعد هذا إلى الشهادة أو الإقرار لا يعتبر تغيير للسبب وإنما للأدلة ، وتظل الدعوى واحدة (٢).

(١) الوسيط أ.د / فتحي والي ، ص : ٧٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص : ٧٦ .

الفصل الثاني

شروط قبول الدعوى

نتناول الحديث عن بيان شروط قبول الدعوى في ثلاثة مباحث ، المبحث الأول ونحدد من خلاله شروط قبول الدعوى ، والمبحث الثاني نوضح فيه شرط المصلحة ، والمبحث الثالث نبين فيه أوصاف المصلحة.

المبحث الأول

تحديد شروط قبول الدعوى

تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه "

وقد اقتصر المقتن على شرط المصلحة كشرط وحيد لقبول الدعوى ، مما فتح الباب واسعاً للخلاف بين الشراح ، ومن هنا فقد اقتصر بعضهم (١) على ذكر هذا الشرط ، بينما يرى بعضهم (٢) أن شروط قبول هي المصلحة والصفة ، ويرى فريق ثالث أن هذه الشروط هي المصلحة والصفة والأهلية (٣) ، ويرى فريق رابع

(١) أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ، نظرية المصلحة في الدعوى ص ٤١ ، أ.د. عبد العزيز عامر ، شرح قانون المرافعات الليبي ص ١١٣ ، أ.د. أحمد السيد صاوي ، الوسيط ص ١٧٣ ، أ.د. نبيل عمر ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ص ٢٧٤ ، أ.د. محمد محمود إبراهيم ، الوجيز في المرافعات ص ٦١٩ .

(٢) أ.د. أحمد هندي ، قانون المرافعات ص ٤٥٣ ، أ.د. وجدي راغب ، أ.د. أحمد ماهر زغلول ، مذكرات في قانون المرافعات المدنية والتجارية ص ١٧٢ ، أ.د. أحمد مسلم ، أصول المرافعات ص ٣٢٩ .

(٣) أ. د عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — في مبادئ المرافعات ص ٣١٠ .

أن شروط قبول الدعوى المصلحة والصفة والأهلية وتوافر وجود الحق الذي تقام الدعوى لحمايته (١) .

ويرى بعض الشراح (٢) أن الشروط هي (أولاً) حق أو مركز قانوني ، (ثانياً) اعتداء على الحق أو المركز القانوني ، (ثالثاً) الصفة ، ويرى أنه إذا توافرت هذه الشروط تنشأ المصلحة في الدعوى ومن ثم فشرط المصلحة لا يضيف جديداً إلى شروط الدعوى .

ونرى مع جمهور الفقه أن الشرط الوحيد لقبول الدعوى هو المصلحة بأوصافها التي سنذكرها ذلك أن هذا الشرط بأوصافه يغطي تماماً الشروط التي ذكرها الفقهاء ، فشرط وجود الحق يحل محله وصف المصلحة بأنها " قانونية " ، وشرط وقوع الاعتداء على الحق يحل محله وصف المصلحة بأنها " قائمة " ، وشرط الصفة يحل محله وصف المصلحة بأنها " شخصية ومباشرة " .

وأما شرط الأهلية فالراجح فقهاً أنه شرط لصحة مباشرة الإجراءات وليس شرطاً لقبول الدعوى بدليل أن الدعوى تظل مقبولة حتى ولو فقد رافعها أهليته أثناء سيرها ، وإنما تنقطع الخصومة إلى أن يستأنف السير فيها من يقوم مقامه (٣)

(١) أ.د. محمد حامد فهمي ، مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية ٥/٢ ، أحمد العشماوي ، د. عبد الوهاب العشماوي ، في قواعد المرافعات ص ٥٦٢ .

(٢) أ.د. فتحي والي ، الوسيط ص ٥٤ وما بعدها .

(٣) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ١٧٤ .

المبحث الثاني المصلحة

يقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على مقدم الطلب أو الدفع .
بمعنى أنه لا بد أن يكون للطلب أو الدفع الذي يبدي أمام القضاء فائدة يهدف إليها مقدمه وإلا كان الطلب أو الدفع غير مقبول حيث لا يجوز اللجوء إلى القضاء عبثاً بدون رغبة في تحقيق منفعة ما
ومعنى كون الفائدة عملية أن المسائل النظرية البحتة لا تصلح لذاتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية.

وعليه فإن المحاكم لا تقبل أي طلب أو دفع ليس لصاحبه فيه مصلحة ، فكل من يلجأ إلى القضاء لا بد أن يكون له غرض جدي يسعى إليه ويستهدفه ، أي أن تكون لديه نية الحصول على نتيجة قانونية مفيدة ، وذلك حتى لا يضيع وقت المحاكم وأموال الدولة في سبيل الحكم في قضايا لا يستفيد منها أحد ؛ ولأنه ليس من وظيفة القضاء الفصل في مسائل نظرية بحتة ، وليس من حسن السياسة تشجيع الناس على رفع الدعاوى الكيدية ، بفتح طريق التقاضي أمامهم بالرغم من انعدام الفائدة من سلوكه (١) .

ولذلك قالوا " إن المصلحة هي مناط الدعوى " وأنه " حيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوى " وأنه لا دعوى حيث لا مصلحة " .

هذا وتختلف المصلحة المقصودة من الدعوى عن الحق ذاته ، ذلك أن المصلحة وهي الفائدة التي تعود من الدعوى تتمحض عن حماية الحق أو اقتضائه ، وهذا أمر مختلف عن الحق ذاته ، فالحق رغم الاعتداء عليه أو رغم التراخي في وفائه قائم قانوناً ولكن الدعوى ترفع لرد العدوان عليه أو لتعجل الوفاء به ،

(١) مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية ، أ.د. محمد حامد فهمي ٦/٢ .

فالهدف منها هو هدف عملي وهو ابتغاء ثمرة الحق والحصول فعلاً على المنفعة المرجوة منه (١) .
والمصلحة شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن من المدعي أو المدعي عليه أو غيرهما (٢) .

المبحث الثالث أوصاف المصلحة

ليس كل مصلحة تكفي لقبول الدعوى ، وإنما هناك أوصاف للمصلحة لابد من توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة ، وهذه الأوصاف هي تتمثل فيما يلي:
الوصف الأول : أن تكون مصلحة قانونية .
الوصف الثاني : أن تكون مصلحة قائمة وحالة .
الوصف الثالث : أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة .
وهو نوضح هذه الأوصاف بشيء من التفصيل على النحو التالي :

المطلب الأول المصلحة القانونية

تنص المادة (٣) مرافعات على أنه " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ... " وبناءً على هذا يلزم أن تكون المصلحة مصلحة قانونية.

وتتحقق المصلحة القانونية إذا كانت الدعوى مستندة إلى حق أو مركز قانوني (٣) ، فلا يعتد بالمصلحة إلا إذا كان للمدعي حق مقرر له في القانون يقيم

(١) مبادئ المرافعات ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣١٣ .

(٢) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ١٧٧ .

(٣) نظرية المصلحة في الدعوى ، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ص ٥٧ .

به الدعوى لينتفع بمزاياه أو ليرد اعتداءً واقعاً عليه أو ليطالب تعويض الضرر الناشيء من هذا الاعتداء (١) .

ولا يعني هذا وجوب أن تكون الدعوى مؤسسة على حق ، وذلك ؛ لأن شرط المصلحة في الدعوى يختلف نطاقه عن الحق .

وترتيباً على هذا إذا توافرت المصلحة ولكنها كانت غير مشروعة فلا تقبل الدعوى ، كالمطالبة بدين القمار ، أو كدعوى التعويض التي ترفعها خليعة على من تسبب في وفاة خليلها .

ومن صور المصلحة غير المشروعة ما نصت عليه المادة (٥) مدني من أنه " يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :

أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .

ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

ج- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة "

ومن ثم فكل دعوى تستند إلى مصلحة من هذا القبيل تكون غير مقبولة (٢) . وكذلك إذا توافرت المصلحة ولكنها كانت اقتصادية محضة فلا تقبل الدعوى؛ لأن المصلحة الاقتصادية المحضة لا تكفي لتبرير قيام الدعوى أو قبولها أمام القضاء كالدعوى التي يرفعها أحد التجار المنافسين لشركة تجارية — شاب تكوينها عيب يبطلها — يطلب الحكم ببطان الشركة .

فلا شك أن لهذا التاجر مصلحة في الحكم ببطان الشركة ، وهي التخلص من منافستها له في السوق ، ولكن هذه المصلحة ليست مصلحة قانونية ، وإنما هي مصلحة اقتصادية محضة ومن ثم لا تكفي لقبول الدعوى .

(١) مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية أ.د. محمد حامد فهمي ٧/٢ .

(٢) قواعد المرافعات ، لمحمد العشماوي ، د. عبد الوهاب العشماوي ص ٥٧٤ ، ٥٧٥ .

بخلاف التاجر الذي يدخل مع هذه الشركة في معاملات ويرتبط معها بعقود ،
فله أن يدعي أما القضاء ببطلان الشركة لكي يبرر عدم تنفيذه لتلك العقود أو
الارتباطات ؛ لأن مصلحته في هذه الحالة مصلحة قانونية تبرر ادعائه ببطلان
الشركة (١) .

وكذلك حالة الشخص الذي يصاب في حادث ويموت ، فلا تقبل دعوى
التعويض التي يرفعها التاجر ضد مرتكب الحادث عن فقد عمليتهم ، مع أن
الحادث أصاب مصالحهم الاقتصادية بالضرر ، ولكن ذلك لا يبيح لهم رفع دعوى
التعويض ؛ لأن مصلحتهم في هذا الشأن ليست مصلحة قانونية ، وإنما هي
مصلحة اقتصادية.

والمصلحة القانونية قد تكون مالية أو مادية وقد تكون أدبية أو معنوية .
وهي تكون مالية أو مادية إذا كان الغرض من الدعوى حماية حق عيني أو
اقتضاء حق شخصي سواء بتنفيذ التزام عقدة المدعي عليه مع المدعي تنفيذاً عينياً
أو بطلب مبلغ من النقود نتيجة تعهد ارتبط به المدعي عليه أو لجبر ضرر نشأ عن
فعل خاطئ ارتكبه المدعي عليه ، أو عن إخلال المدعي عليه بالتزام واقع على
عائقه .

وتكون المصلحة أدبية أو معنوية ، وهي مصلحة تكفي لقبول الدعوى ، كما
في حالة المدعي الذي يطالب بتعويض رمزي عن فعل ضار ارتكبه خصمه في
حقه ، كأن ينشر أحد الصحفيين مقالاً بمس شرف أحد المواطنين أو سمعته ،
فيرفع ذلك المواطن دعوى بطلب إلزام الصحفي بأن يدفع إليه مبلغاً ضئيلاً على
سبيل التعويض الرمزي مع نشر الحكم في الجريدة التي نشر بها ذلك المقال .
فهنا لا يسعى رافع الدعوى إلى فائدة مادية ، وإنما يسعى إلى ترضية أدبية ،
وهي توصف بأنها مصلحة قانونية ، ومن ثم تكون دعواه مقبولة .

(١) مبادئ المرافعات ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣١٦ .

ويراعى أن وصف المصلحة بأنها مادية أو أدبية إنما يبنى على المطلوب في الدعوى ، فإذا طالب المدعي بالتعويض المالي كانت المصلحة مادية ، وإن كان ينشد الترضية المعنوية فقد يكون ضرراً أدبياً ومع هذا يطلب تعويضاً مالياً وقد يقع ضرر مادي ولا يطلب إلا تعويضاً أدبياً .

وعلى كل حال سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية فهي مصلحة قانونية ؛ لأنها تتعلق بحق هو حق المضرور في جبر وإصلاح ما أصابه من ضرر (١) .

المطلب الثاني

المصلحة القائمة الحالة

تنص المادة " الثالثة " من قانون المرافعات على أنه: " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ... ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " .

وعلى ذلك يجب أن تكون المصلحة قائمة بالفعل بمعنى أن يكون الاعتداء قد وقع على الحق المرفوعة به الدعوى أو أن يكون قد حصل فيه نزاع يتطلب فضه بواسطة القضاء ؛ لأن القضاء إنما يفصل في النزاع الذي وقع فعلاً .
ومن قبيل المصلحة القائمة والحالة أن يتمتع المدين عن الوفاء بالدين بعد حلول أجله (٢) .

وترتيباً على هذا إذا كانت المصلحة غير حالة بأن كانت مؤجلة ، أو كانت معلقة على شرط لم يتحقق بعد ، فإن الدعوى في هذه الحالة تكون سابقة لأوانها ، ويحقق للمدعي عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى ؛ لأن المصلحة فيها غير قائمة ، ويسمى هذا الدفع عملاً " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان " مثال ذلك

(١) مبادئ المرافعات ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣١٨ ،

(٢) شرح قانون المرافعات الليبي ، أ.د. عبد العزيز عامر ص ١١٩ .

من يرفع دعوى بدين مؤجل ، أو بدين معلق على شرط لم يتحقق بعد ، ويحكم القاضي بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن المصلحة في الدعوى غير قائمة . ويستلزم هذا الوصف أن تكون المصلحة قائمة أي ألا تكون احتمالية ، فإذا كانت قائمة ينبغي أن تكون حالة ، أي ألا تكون مستقبلية ؛ لأن المصلحة المستقبلية موجودة ، غاية الأمر أنها مؤجلة أو معلقة على شرط . وعلى كل حال — فالأصل — أن المصلحة المحتملة والمستقبلية لا تكفي لقبول الدعوى .

ومع ذلك فقد أوردت المادة (٣) مرافعات استثناء هاماً على هذا الأصل بقولها " ومع هذا تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " . ويرد هذا الاستثناء على وصف المصلحة بأنها قائمة ويجيز قبول الدعوى رغم أن الضرر لم يقع بالفعل ولكن وقوعه محتمل (١) . ووفقاً للنص سالف الذكر تكفي المصلحة المحتملة في قبول نوعين من الدعاوى هما :

- ١- دعاوى القصد منها الاحتياط لدفع ضرر محقق وتسمى هذه الدعاوى (الدعاوى الوقائية)
- ٢- دعاوى القصد منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتسمى هذه الدعاوى (دعاوى الأدلة) .

ونتناول هذين النوعين فيما يأتي :

أولاً : الدعاوى الوقائية :

وهي الدعاوى التي يكون الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محقق ، وترفع هذه الدعاوى قبل قيام النزاع أو قبل وقوع الضرر أو الاعتداء على الحق ويكون الهدف منها منع الضرر لإزالته ، فالشخص الذي يرفع دعوى من هذه الدعاوى لم

(١) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ١٨٩ .

يصب بضرر ولم يعتد أحد على حقه ، وإنما هو يطلب الحماية ؛ لأنه مهدد ويلتمس حمايته من الأذى الذي يوشك أن يلحق به .

وعلة قبول هذه الدعاوى أن لصاحب الحق وإن لم ينازع في حقه لا شك أن له مصلحة في الاستقرار والاطمئنان ، وأن هذه المصلحة قائمة وحالة .

ومن صور الدعاوى الوقائية :

١- دعوى إيقاف الأعمال الجديدة :

وهي دعوى يرفعها الحائز وفقاً لنص المادة (٩٦٢) مدني (١) على من شرع في أعمال جديدة لو تمت لهددت حيازة المدعي ، كالدعوى التي يرفعها جار على جاره الذي شرع في تعلية عقاره على نحو يخالف ارتفاعاً مقررأ بعدم التعلية لصالح عقار المدعي ، وكالدعوى التي يرفعها صاحب مزرعة صحراوية على جاره الذي بدأ في حفر بئر عميقة لم تم حفرها لاستنزفت مياه الآبار المجاورة ، لعدم مراعاته المسافات الواجبة في هذا الشأن .

فهنا لم يعتد الجار على حق جاره ؛ لأنه يبني أو يحفر في أرضه هو ، وليس في أرض المدعي ، كما أن الضرر لم يقع ؛ لأن التعلية قد لا تحرم الجار من حق الارتفاق أو ؛ لأن الماء قد لا يجف في بئر المدعي .

ومع هذا متى كان ظاهراً أن تلك الأعمال لو تمت تؤدي إلى العدوان ، فإن الحق يكون مهدداً ويكون لصاحبه أن يرفع الدعوى لوقف الأعمال التي تهدد حقه .

(١) ونصها " من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ، ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر ... " .

٢- دعوى منع التعرض :

وهي دعوى يرفعها الحائز وفقاً لنص المادة (٩٦١) مدني (١) على من تعرض له في حيازته .

وتختلف دعوى منع التعرض عن دعوى إيقاف الأعمال الجديدة أن التعرض قد وقع ولكن الحيازة لم تسلب ، بل هي باقية للمدعي ؛ لأن الحيازة لو سلبت لكان على المدعي أن يرفع دعوى استرداد الحيازة .

فدعوى منع التعرض في مرتبة وسطى بين دعوى إيقاف الأعمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة ، ذلك أنه في دعوى إيقاف الأعمال الجديدة مجرد شروع في أعمال لو تمت لهددت حيازته ، وفي دعوى منع التعرض وقع التعرض فعلاً ولكنه لم يصل الأمر إلى سلب الحيازة ، وفي دعوى استرداد الحيازة وقع الاعتداء وسلبت الحيازة .

٣- دعوى قطع النزاع :

وتسمى الدعوى التحريضية وصورتها أن يزعم شخص أن له حقاً عند آخر ويشيع هذه المزاعم بصورة علنية وجدية فيخشى المزعوم ضده نتيجة هذا الادعاء ، ويرفع دعوى ضد هذا الشخص يطلب منه أن يثبت ما يدعيه بالدليل ، فإن عجز عن إثبات ما يدعيه حكم بأنه لا حق له فيما يدعيه قبل المدعي ويمتنع عليه المطالبة بذلك في المستقبل .

وقد اختلف الشراح في قبول هذه الدعوى ، حيث ذهب بعضهم إلى أن دعوى قطع النزاع غير مقبولة ؛ لأنها تتضمن إكراه المدعي على الالتجاء إلى القضاء ، والأصل أن المدعي حر يختار الوقت المناسب لرفع دعواه ولا يصح إكراهه على المخاصمة في وقت معين ؛ لأن مباشرة الدعوى حق له يستعمله في

(١) ونصها " من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جار أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض " .

الوقت الذي يراه مناسباً وليس واجباً يجبر على أدائه ، وقد يكون في إكراهه عل المخاصمة قبل أن تنتهياً له أسباب النجاح فيها ضرر عظيم .

ويذهب قول آخر إلى قبول هذه الدعوى ؛ لأن العبرة في القبول وعدمه هنا يتوافر المصلحة ، ومتى توافر هذا الشرط فلا محل للقول بعدم قبولها ، ولا شك أن هذه المزاعم إذا اتخذت شكلاً علنياً وجدياً فإنها تؤثر تأثيراً سيئاً على سمعة ومركز الشخص الموجهة إليه ، ومن ثم تكون مصلحته ظاهرة في المبادرة بوضع حد لها .

ويميل المقنن المصري للأخذ بالرأي الأخير ، فقد جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي ٧٧ لسنة ١٩٤٩ أنه " يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذي يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحصول لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وجرم من رفع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة " .

وعلى ذلك اتجه القضاء إلى قبول هذه الدعوى متى كانت المزاعم جدية ولها أثر ضار يعتد به ولا تكون مجرد تخرصات فارغة لا نتيجة لها .
والتحقق من مدى وجود هذه المصلحة متروك لتقدير القضاء حسب ظروف كل حالة (١) .

ومثال ذلك أن يثير شخص مزاعم ضد تاجر بأنه مدين له بمبلغ كبير أن تثار هذه المزاعم بصورة جدية كأن يتضمنها إنذار موجه إلى التاجر ، أو ترفع بها دعوى أمام محكمة غير مختصة فتحكم بعدم اختصاصها ولا تقضي في موضوعها ، أو أن تذكر هذه المزاعم في شهادة أمام القضاء ، أو أن ترد في محرر كتابي أو في بيان مقدم لجهة رسمية أو في نشرة تزوع على التجار ففي مثل هذه الحالات يجوز للتاجر أن يرفع دعوى قطع النزاع ضد الشخص الذي يثير

(١) قواعد المرافعات ، لمحمد العشماوي ، د. عبد الوهاب العشماوي ص ٥٧٧ .

هذه المزاعم وبطلب منه إثبات المديونية وإلا حكم ببراءة ذمة التاجر من المديونية، ويمتنع على هذا الشخص أن يدعي بذلك في المستقبل .

وتطبيقاً لذلك حكم بعدم قبول الدعوى التي أقامها مجموعة من الورثة ضد مصلحة الضرائب أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، حيث كانت مصلحة الضرائب طلبت منهم كشوفاً عن المنشآت والآلات الزراعية التي آلت إليهم بالميراث ، فردوا عليها بأن هذه المنشآت والآلات لا تخضع لرسم أيلولة خاص غير الرسم المقرر على الأطيان الزراعية التي تعتبر تلك الآلات والمنشآت من ملحقاتها أو جزءاً منها ، ثم قام الورقة برفع دعوى طلبوا فيها الحكم بعدم خضوع تلك الأشياء لرسم أيلولة خاص خلاف رسم الأيلولة المقرر على الأطيان الزراعية. دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فيها ، حيث لا يوجد نزاع بينها وبين المدعين في هذا الشأن .

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وقالت في حيثيات الحكم إنه يجب لقبول دعوى قطع النزاع أن تكون مزاعم المدعي عليه فيها مما يعتبر تعرضاً جدياً للمركز القانوني للمدعي وليست مجرد أقوال أو تصرفات ليس لها أثر واضح ضار يعتد به ، وأن كل ما صدر عن مصلحة الضرائب هو أنها وجهت للمدعين في تلك الدعوى كتاباً طلبت فيه منهما عدة بيانات منها كشوف تفصيلية بالمنشآت والآلات الزراعية الموجودة بالأطيان التي ورثاها وليس في المطالبة بهذا البيان ما يدل على أن مصلحة الضرائب كانت تقصد من ذلك إخضاع هذه المنشآت لرسم أيلولة خاص .. ثم قالت " قد كان يمكن أن تقبل هذه الدعوى بحسبانها دعوى قطع النزاع لو أن مصلحة الضرائب أظهرت نيتها واضحة ثابتة قاطعة في الاتجاه إلى فرض رسم أيلولة خاص على تلك الأشياء فقد كان يحق للمدعين عندئذ الالتجاء إلى القضاء ليقطعاً عليها هذا النزاع " (١) .

(١) انظر : حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر في ١٩٥٠/١٢/٣٠ منشور بمجلة التشريع والقضاء ، السنة الثالثة ، ص ٢١٧ ، أورده أستاذنا الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — في مبادئ المرافعات ص ٣٣٧ ، ٣٣٨ .

ويراعى أنه من المتفق عليه أن للشخص المزعوم ضده أن يطالب بتعويض عن هذه المزاعم ، إذا أثبت فسادها وضررها المادي والأدبي ، ولكن قد لا يكون في المطالبة بالتعويض حماية كافية ، ومن ثم لا تغني دعوى التعويض عن دعوى قطع النزاع التي ترمي إلى وضع حد لهذه المزاعم .

٤- الدعاوى التقريرية :

وهي الدعاوى التي فيها تقرير وجود حق أو مركز قانوني أو عدم وجوده دون إلزام الخصم بأداء معين .

ومن صور الدعاوى التقريرية دعوى براءة الذمة التي يرفعها المدين الذي يختلف مع دائنه حول انقضاء الدين بالوفاء أو التقادم أو غير ذلك من أسباب الانقضاء ، ودعوى نفي حق الارتفاق ، ويقصد بها الحصول على حكم في مواجهة شخص معين بأن العقار الذي يملكه المدعي ليس محملاً بحق ارتفاق لعقار آخر يملكه المدعي عليه ، أو أن الارتفاق الذي كان قائماً على ذلك العقار قد انقضى أو زال (١) ، ودعوى صحة عقد أو بطلانه لم ينازع أحد فيه .

٥- الدعوى الاستفهامية :

هي دعوى يرفعها شخص يتوقف اكتسابه أو فقدته لحق من الحقوق على ما يختاره شخص آخر في مدة حددها القانون .

والقصد من هذه الدعوى تقصير هذه المدة فيطلب المدعي فيها من المدعي عليه بيان موقفه الذي سيختاره ، وإذن فهي لا تثير خلافاً بين طرفيها ويسميها بعض الشراح الدعوى الاستجوابية (٢) .

ومثالها ما نصت عليه المادة (١٤٠) مدني :

(١) شرح قانون المرافعات ، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي - يرحمه الله - ص ٣٩ ، ٤٠ .

(٢) قواعد المرافعات ، لمحمد العشماوي ، د. عبد الوهاب العشماوي ص ٥٧٩ .

١- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .

٢- ويبدأ سريان هذه المدة في حال نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد ."

لصاحب الحق في الإبطال فترة يباشر فيها حقه وتمتد هذه الفترة إلى خمس عشرة سنة ومن مصلحة الشخص الذي يضر به استعمال حق الإبطال أن يباشره صاحبه في الحال حتى تستقر الأمور ، أو ليقدم دفاعه في الوقت المناسب .

فهل يجوز لهذا الشخص أن يرفع دعوى عل صاحب حق الإبطال هنا ليرغمه على أن يقرر في الحال إن كان ينوي مباشرة الحق أم لا .

يكاد يجمع الفقه والقضاء على أن الدعوى الاستفهامية لها طبيعة خاصة تقتضي القول بعدم قبولها ؛ لأنها تحد من جرية الشخص هنا في إبطال العقد أو إجازته ، مع أن القانون حدد في النص صراحة المدد التي يجوز للشخص استعمال حقه في الإبطال ، ومن ثم فلا يقبل من المدعي أن يلغي بإرادته هذه المدة ويطلب من المحكمة إلزام ذلك الشخص أن يختار قبل نهاية الفترة المحددة ، ويحرمه بذلك مما منحه القانون من رخصة (١) .

ثانياً : دعاوى الأدلة :

النوع الثاني من الدعاوى التي تقبل رغم أن المصلحة فيها غير قائمة هي دعاوى الأدلة ، وهي دعاوى يقصد بها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

(١) نظرية المصلحة ، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ص ٢٤٣ .

وأهم هذه الدعاوى :

١ - دعوى إثبات الحالة :

وفقاً لنص المادتين ١٣٣، ١٣٤ من قانون الإثبات " يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة ... " ويجوز للقاضي ... أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله ... " .

وتهدف هذه الدعوى إلى إثبات الحالة قبل أن تتغير معالمها بمضي الوقت ، كأن يقوم شخص بإغراق أرض جاره أو مزروعاته بالماء ، أو أن يترك المستأجر العين المؤجرة بعد إتلافها ، فيعتمد صاحب الأرض أو المؤجر ويرفع دعوى إثبات الحالة ، تمهيداً لإقامة دعوى تعويض فلو انتظر حتى يرفع دعوى التعويض لأدى ذلك إلى جفاف الأرض وتغير معالمها وإلى فوات مصلحة المالك في الاستفادة من العين المؤجرة .

٢ - دعوى سماع الشهود :

وفقاً لنص المادة (٩٦) من قانون الإثبات " يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد .

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود " .

والغرض من هذه الدعوى المحافظة على الدليل ، كما إذا كان الشاهد مريضاً مرضاً خطيراً ، أو أصيب إصابة قد تؤدي إلى وفاته ، أو كان مسافراً إلى بلد بعيد لا يرجى حضوره منه قريباً ، ففي مثل هذه الحالات يجوز رفع دعوى سماع الشاهد ومتى توافرت الشروط يحكم القاضي بسماع الشاهد وينفذ الحكم بسماع

شهادته أمام القاضي بعد حلف اليمين وتثبت شهادته في محضر تحقيق إلى أن يقوم النزاع الموضوعي وعندئذ لا يجوز تسليم صورة من المحضر ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود .

ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته المادة (٩٧) إثبات .

٣- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية :

وفقاً لنص المادة (٤٥) من قانون الإثبات " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر أنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " .

والغرض من هذه الدعوى المحافظة على دليل قائم والاطمئنان إلى عدم إنكار ذلك الدليل عندما يحدث التمسك به في المستقبل .

فهذه الدعوى قائمة على أساس احتمالي ، فقد لا يحتاج صاحب الشأن إلى التمسك بهذه الورقة فقد لا يقوم النزاع نهائياً ، وحتى إذا قام قد لا ينكر الخصم توقيعه أو خطه .

غير أن للمدعي في هذه الدعوى مصلحة قائمة وحالة في أن يستقر على أمر بشأن هذا الدليل ، فهي من دعاوى الاستيثاق للحق ويجوز رفعها طبقاً للمادة (٣) مرافعات(١) .

٤-دعوى التزوير الأصلية :

وفقاً لنص المادة (٥٩) من قانون الإثبات " يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة ... " .

(١) مبادئ المرافعات ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣٢٥ .

والغرض من هذه الدعوى هدم دليل قائم في الواقع ومدعي ببطلانه نظراً لتزويره.

وسميت دعوى التزوير الأصلية ، تمييزاً لها عن دعوى التزوير الفرعية ، ذلك أن الأصل في الطعن بالتزوير يحدث عندما يتمسك شخص بمحرر في دعوى فيطعن المنسوب إليه المحرر بأنه مزور ، ويعتبر ذلك بمثابة رفع دعوى فرعية من جانبه ؛ لأن الطعن بالتزوير معناه الادعاء به ، ومن ثم فإنه يعتبر طلباً عارضاً في دعوى أصلية ، ولذلك يطلق عليه دعوى التزوير الفرعية .

ويترتب عليها وقف السير في القضية الأصلية إلى أن تفرغ المحكمة من تحقيق الادعاء بالتزوير أو بتنازل مقدم المحرر المطعون عليه عن التمسك به . وواضح أن هذه الدعوى تقوم على أساس احتمالي ، فقد لا يكون الدليل موجوداً ، وحتى إذا كان موجوداً فقد لا يقوم نزاع أصلاً ، وحتى إذا نشب نزاع فقد لا يحتج به من بيده المحرر .

إلا أن للمدعي مصلحة قائمة وحالة تتمثل في اطمئنانه من أن هذا الدليل لن يستعمل ضده في أي وقت فهي من دعاوى الاستيثاق والتي أجازت رفعها المادة (٣) مرافعات .

المصلحة المستقبلية :

ذكرنا فيما سبق أن وصف المصلحة بأنها قائمة وحالة يعني ألا تكون المصلحة احتمالية أو مستقبلية ، وأن الأصل أن المصلحة المحتملة والمستقبلية لا تكفي لقبول الدعوى.

ومع هذا فقد أوردت المادة (٣) مرافعات استثناءً بحالات تكفي فيها المصلحة المحتملة .

والآن نبحث فيما إذا كانت المصلحة مؤكدة لكنها مستقبلية أي مؤجلة أو معلقة على شرط فهل يمكن قبول الدعوى .

أولاً : المطالبة بحقوق مؤجلة :

إذا كان لشخص على آخر دين ثابت لا شك فيه ولكنه مؤجل ، فيرفع الدائن دعوى يطالب بدينه قبل حلول الأجل .

لا شك أن المصلحة هنا ليست احتمالية بل هي محققة ولكنها رغم تحققها غير حالة ومن ثم لا تقبل الدعوى ؛ لأن من المسلم به أن الدائن بدين لم يحل أجله ليس له أن يرفع دعوى المطالبة به قبل حلول الأجل ، ومثل هذه الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .

على أن القضاء المصري أجاز قبول الدعوى إذا حل الأجل بعد رفع الدعوى؛ لأنه لا يكون للمدعي عليه مصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى . ومن العبث الحكم بعدم قبول دعوى يمكن إعادة رفعها في نفس يوم الحكم بعدم القبول وتكون مقبولة .

غير أن المدين إذا وفى بالدين بمجرد حلول الأجل كانت مصاريف الدعوى على الدائن الذي تعجل في رفعها (١) .

ورأي البعض — بحق — أن يرفق بين حالتين :

الأولى : إذا تمسك المدعي عليه بعدم قبول الدعوى قبل حلول الأجل ، فيحكم حينئذ بعدم القبول ، حتى ولو حل الأجل بعد ذلك ؛ لأنه تعلق للمدعي عليه حق بالدفع الذي تمسك به من يوم تمسكه .

والثانية : إذا تمسك المدعي عليه بعدم القبول بعد حلول الأجل فلا يقبل دفعه كما جرى القضاء المصري على قبول الدعاوى التي ترفع بطلب أقساط حالة وأخرى لم تحل بعد كما في حالة المستأجر الذي تأخر في دفع الأجرة فيرفع المؤجر دعوى يطالبه بالأجرة المتأخرة وما يستجد ، وذلك على أساس أن تأخر المدين في دفع الأقساط السابقة يعتبر قرينة على مسلكه في المستقبل مما يجعل حق الدائن بالنسبة للأقساط المستقبلية مهدداً بخطر محقق ويجعل له مصلحة في طلبها .

(١) أصول المرافعات ، أ.د. أحمد مسلم ص ٣٣٤ .

وعلى ذلك تحكم المحكمة بأداء الأقساط التي ثبت تأخر المدين في أدائها وما حل من الأقساط الأخرى ، وذلك تأسيساً على أن حلول الأجل أثناء سير الدعوى يجعل دفع المدين بعدم القبول دفعاً غير منتج وتكون مصلحته فيه منعدمة .
ثانياً : الديون المعلقة على شرط :

لصاحب الحق المعلق على شرط فاسخ أن يرفع الدعوى يطالب بحقه ، فإذا اقتضاه وتحقيق الشرط الفاسخ جاز لخصمه أن يرفع الدعوى بطلب رد الحال إلى ما كانت عليه .

بخلاف الشرط الواقف ، حيث يتوقف نشوء الحق على تحقق الشرط ، فلا يجوز رفع الدعوى قبل تحقق الشرط ؛ لأن المصلحة هنا مصلحة احتمالية ولا تكفي لقبول الدعوى.

المطلب الثالث **المصلحة الشخصية المباشرة**

قلنا فيما سبق أنه يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة وأن تكون هذه المصلحة قانونية ، قائمة وحالة ، وشخصية ومباشرة .
ويقصد بكون المصلحة شخصية ومباشرة بأن يكون المدعي هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه كالوصي والوكيل .
وعلى ذلك لا تقبل دعوى شخص يطالب بحق لأبيه أو لأخيه أو ابنه مالم تكن له الولاية على صاحب الحق كأن يكون وصياً عليه أو قيمياً أو ولياً شرعياً .
كذلك لا تقبل دعوى التعويض التي يرفعها مصاب ويطالب التعويض لجميع المصابين .

ولا تقبل الدعوى إذا كانت لرافعها مصلحة شخصية غير مباشرة ، كمن يرفع طعناً يقصد به استقامة قضاء يرى في انحرافه عن مبادئ القانون السليمة ضرراً بحق له ، يخشى أن يكون هذا القضاء سابقة ضارة به (١) .

(١) قواعد المرافعات ، لمحمد العشماوي ، د. عبد الوهاب العشماوي ص ٥٧٣ .

ويرى بعض الشراح أن وصف المصلحة بكونها شخصية ومباشرة هو شرط الصفة ، بمعنى أن الصفة المطلوبة في التقاضي ليست إلا المصلحة الشخصية المباشرة .

وينبغي التمييز بين حالتين :

الأولى : حالة ما إذا كان رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه وهنا تختلط الصفة بالمصلحة الشخصية المباشرة .

الثانية : حالة ما إذا كان رافع الدعوى شخصاً آخر غير صاحب الحق ، كالولي والوصي والقيم ومدير الشركة فهنا تتميز الصفة عن المصلحة الشخصية المباشرة فيجب على المدعي أن يثبت صفته في تمثيل ذلك الغير الذي ترفع الدعوى باسمه .

وأياً ما كان الحال لا تقبل الدعوى إلا ممن له مصلحة شخصية ومباشرة أو من نائبه .

وترد على هذه القاعدة الاستثناءات الآتية :

١ - الدعوى غير المباشرة :

يجوز وفقاً لنص المادة (٢٣٥) مدني " لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ... "

وعلى ذلك أجاز القانون للدائن أن يستعمل حقوق مدينه ومنها رفع الدعوى على مدين المدين للمطالبة بدين للمدين ويعتبر رافع الدعوى وهو دائن المدين نائباً عن المدين في مقاضاته مدينه ومصدر النيابة هو القانون .

ولا يقبل استعمال الدائن لحقوق مدينه إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق ، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار ، ولا يشترط إضرار المدين لاستعمال حقه ، ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى (١) .

(١) المادة ٢/٢٣٥ مدني .

٢- دعاوى النقابات والجمعيات :

لكل من النقابة والجمعية شخصية معنوية ولها ذمة مالية مستقلة ومن ثم فلها أن ترفع الدعاوى تطالب بحقوقها ، كالدعوى التي ترفعها على مقاول لتنفيذ ما اتفق عليه في العقد ، وكالدعوى التي ترفعها تطالب بثمن أشياء باعتها للأعضاء أو غيرهم .

ويجوز " للمنظمات النقابية التي تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد وذلك لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك " .

ويجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة منها ، كما يجوز له رفع هذه الدعاوى مستقلاً عنها .

كما يجوز للنقابة أن ترفع دعاوى للدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة التي أنشئت النقابة لحمايتها ، وسواء كان الانضمام لها إجبارياً على كل المشتغلين بالمهنة أم كان اختيارياً^(١) .

وتقبل الدعوى التي ترفعها نقابة المحامين أو الأطباء أو المأذونين لوقف عرض الفيلم الذي يسخر من هذه المهنة وممن ينتمي إليها ، كذلك تقبل الدعوى التي ترفعها نقابة ضد شخص يمارس المهنة دون أن تتوافر فيه شروط ذلك .

ويتشدد القضاء في قبول الدعاوى التي ترفعها الجمعيات دفاعاً عن الغرض الذي أنشئت من أجله على أساس أن الجمعية تدافع عن مصالح عامة والاعتراف لها بالصفة في ذلك يمس سلطة النيابة العامة .

وينتقد الفقه — بحق — هذا الاتجاه ، ويرى أنه ينبغي الاعتراف للجمعيات بالصفة في رفع الدعاوى التي ترفعها دفاعاً عن المصالح المشتركة لأعضائها والأغراض التي أنشئت لأجلها^(٢) .

(١) مبادئ القضاء المدني ، أ.د. وجدي راغب ص ١٢٨ .

(٢) المرجع السابق ص ١٢٩ ؟

" وقد أيد القضاء المصري هذا الرأي ، فقضت محكمة القضاء الإداري بأن الاتحاد النسائي جمعية تقوم على الدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية ، فإذا كان القرار المطعون فيه قد استند في ترك تعيين المدعية في الوظائف الفنية لمجلس الدولة على عدم ملائمة الوظيفة لأنوثتها ، فإن للاتحاد النسائي الحق في التدخل دفاعاً عن مبادئه وقيماً على أداء رسالته "(١).

٣- دعاوى الحسبة :

يمكن القول بأن الحسبة هي : " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس "(٢) .

ولقد أخذ القضاء المصري بهذه المعاني في شأن الحسبة ، حيث قضت محكمة النقض بأن الحسبة هي : " في اصطلاح الفقهاء أمر بمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن منكر إذا ظهر فعله ، وهي من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية أصلية أو مستمدة أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه ، وطلب منه القيام بها، وذلك بالنقد إلى القاضي بالدعوى أو باستعداد إلى المحتسب أو إلى المظالم ، ودعوى الحسبة تكون فيما هو حق لله ، أو فيما كان حق الله فيه غالباً ، كالدعوى بإثبات الطلاق البائن ، أو بالتفريق بين زوجين في زواج ظهر فسادُه"(٣).

وأرى أن الحسبة هي :

عمل يقوم عليه ولي الأمر أو من يفوضه في ذلك صراحة للأمر بالمعروف إذا أظهر الناس تركه ، والنهي عن المنكر إذا أظهر الناس فعله ؛ وذلك حماية لقيم

(١) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ١٨٨ .

(٢) الماوردي ، الأحكام السلطانية ص ٢٤٠ ، عبد الرحمن بن نصر الشري ، كتاب نهاية

الرتبة في طلب الحسبة ، ص ٦ ، د / عطية مشرفة ، القضاء في الإسلام . ص ١٧٨ .

(٣) - الطعن رقم ٢٠ لسنة ٣٤ ق ، أحوال شخصية ، جلسة ١٩٦٦/٣/٣٠ م ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٧ ، ص ٧٨٢ ، الطعن رقم ٢٤ لسنة ٥٠ ق ، أحوال شخصية ، جلسة ١٩٨١/١٢/١٠ م ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٢ ق ، ص ٢٥٢ .

المجتمع من العبث والفوضى ، وصيانة للدين من الضياع ، وحفظاً لمصالح الناس
المعتبرة في أمور الدين والدين.

وبهذا يتضح أن الحسبة تحمي النظام العام في المجتمع وتحفظ قيمه الرئيسية
وتصون آدابه العامة ، ولقد كثر الخلاف حول مدى الإبقاء على نظام الحسبة أو
إلغائها ، سيما في الآونة الأخيرة ، بيد أننا نؤيد جماهير الفقه القانوني فيما ذهب
إليه من ضرورة بقاء الحسبة والتأكيد على أهميتها ؛ نظراً لحاجة الناس إليها بل
وإلى تعميمها وإقرارها حقاً للناس كافة على نحو ينظمه المقنن دون إفراط أو
تقريط ، وذلك صوناً للأديان من عبث العابثين ، وحماية للأخلاق من الحمقى
والمهرجين واستبقاءً لأنظمة المجتمع وأدبه العام^(١).

وأساسها الشرعي قوله تعالى

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

ويسمى القائم على أمرها بالمحتسب أو والي الحسبة ، وقد كان النبي ﷺ
أولى الناس بذلك ، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ (مرّاً على صُبرة
طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلاءً ، فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال :
أصابته السماء يا رسول الله — فقال رسول الله ﷺ : أفلا جعلته فوق الطعام كي
يراه الناس ؟ من غش فليس مني) (٣) .

(١) - ومن الفقه القانوني المؤيد لدعوى الحسبة : د / أحمد السيد صاوي ، الوسيط في قانون
المرافعات، ط ١٩٩٠، ص ١٧١، د. فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، ط ١٩٩٣، ٦٣،
د. وجدي راغب، المبادئ، ص ١٣٠، وقارن د / نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون
المرافعات، ط ١٩٩٩م.

(٢) سورة آل عمران الآية رقم " ١٠٤ " .

(٣) رواه مسلم ، كتاب الإيمان . باب قول النبي ﷺ " من غشنا فليس منا " ١ / ٩٩ ، حديث رقم " ١٠٢ "

وقد ثبت عنه عليه السلام أنه استعمل سعيد بن العاص بن أمية رضي الله عنه بعد فتح مكة على سوقها^(١).

وقد استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إحدى النساء وكانت تسمى الشفاء على سوق المدينة ، فكان أول من وضع نظاماً للحسبة هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد عرفت الحسبة بهذه التسمية في عهد المهدي العباسي [١٥٨ - ١٦٩ هـ]^(٢).

ولأن من واجبات ولي الأمر حفظ الدين على أصوله المستقرة ، وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبيّن له الصواب ، وأخذ بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروساً من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل.

ومن واجبات ولي الأمر أيضاً إقامة العقوبات لتُصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتُحفظ حقوق العباد من إتلاف واستهلاك ، وليس بخافٍ عن أحد أن مما جرت عليه أمور الناس ، واستمرت عليه عادات الأمم أنه لم تكن مملكة إلا كان أسها ديانة من الديانات ، وأصلها ملة من الملل ، عليها بُنيت شرائطها وفروعها وجرت أحكامها وحدودها.

والرجل حقاً مَنْ قام بأمر الدين والدنيا معاً ونظر إلى آخرته ، والسعيد مَنْ وقى الدين بملكه ولم يوق الملك بدينه ، وأحى السنة بعدله ولم يمتها بجوره ، وحرس الرعية بتدبيره ولم يضعها بتدميره ؛ ليكون لقواعد ملكه موطئاً ولأساس دولته مشيداً ولأمر الله في بلاده ممتثلًا^(٣)

(١) ابن عبد البر، الاستيعاب ٢ / ٦٢١ ، د / محمد سلام مذكور، القضاء في الإسلام ص ١٤٧ ، ص ١٤٨

(٢) د / عطية مشرفة ، القضاء في الإسلام ص ١٨٦ ، د / نصر فريد واصل، السلطة القضائية. ص ١٠١ .

(٣) - <http://www.alukah.net/sharia/٠/٦٦٦٣٣/#ixzz٣VmElidfO> -

ودعوى الحسبة من الدعاوى المقبولة أمام القضاء يرفعها العبد دفاعاً عن حق من حقوق الله سبحانه وتعالى كالدعوى التي يرفعها شخص بالتفريق بين زوجين تحرم معيشتهم معاً ، كالمرأة التي تجمع بين زوجين ، وكالمسلمة إذا تزوجت غير مسلم ، كالمرأة المطلقة ثلاثاً ، وكالمرأة المتزوجة بمحرم ، وكالدعوى بطلب ثبوت نسب صغير ، وكطلب الحجر على شخص ، أو طلب تعيين قيم .

ولا تتوافر في دعاوى الحسبة المصلحة الشخصية المباشرة ؛ لأن المدعي في هذه الدعاوى لا يطلب لنفسه شيئاً فيها ، وحديثاً أصبحت النيابة العامة هي المختصة دون غيرها برفع دعوى الحسبة باعتبارها الهيئة المكلفة بطلب الحماية القضائية للمصالح العامة في المجتمع (١).

وهذا وقد حكمت محكمة الجيزة الابتدائية في شهر مارس ١٩٩٤ بعدم قبول دعوى الحسبة التي أقامها عدد من الأشخاص للتفريق بين الدكتور نصر أبو زيد وزوجته الدكتور ابتهاج يونس — على أساس أنه ارتد عن الإسلام في بعض مؤلفاته التي تعد في نظرهم خروجاً عن الدين الإسلامي بعد أن رفضت اللجنة العلمية المختصة ترفيقه — وهي القضية التي شغلت المجتمع المصري فترة طويلة — وقد استندوا في دعواهم إلى أن دعوى الحسبة هي دعوى يجوز لأي شخص أن يرفعها بصرف النظر عما إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة فيها ؛ ولأن المادة (٢٨٠) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تحيل إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد به نص ، والمذهب الحنفي يجيز رفع دعوى الحسبة ، كما استندوا إلى قضاء النقض في ١٩٦٦/٣/٣٠ بقبول دعوى الحسبة .

وقالت محكمة الجيزة في حكمها أن هذا القضاء يجب العدول عنه بعد صدور قانون المرافعات الحالي ١٣ لسنة ١٩٦٨ وصدور الدستور المصري سنة ١٩٧١

(١) - راجع في تفصيل القول حول دعوى الحسبة وما يتعلق بها : د/ أحمد خليفة شرقاوي ، قضاء الحسبة وحصانة الأديان ، ط/ دار النهضة العربية ، ط/ الأولى سنة ٢٠١٦ م .

فقانون المرافعات نص صراحة في المادة الثالثة على أنه " لا دعوى بلا مصلحة " وهذا القانون هو الواجب التطبيق على منازعات الأحوال الشخصية بعد إلغاء المحاكم الشرعية فضلاً عن أن الدستور المصري عندما نص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فإن هذا الخطاب ليس موجهاً إلى القاضي ليحكم به مباشرة وإنما هو موجه للمشرع ليصوغ تشريعاته وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ، أما القاضي فهو ملزم بتطبيق التشريع دون نظر ما إذا كان مستمداً من الشريعة أم لا (١) .

ومع هذا فإننا نرى مع مجموعة من الفقهاء (٢) أنه من الضروري قبول دعاوى الحسبة فكما خول المقنن النيابة العامة حق تحريك الدعوى الجنائية وحق رفع الدعوى والتدخل في بعض المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية فما أوجبنا اليوم إلى أن يعمم المقنن " دعوى الحسبة ويقرها حقاً للكافة ، حماية لقيم المجتمع ومثله وحماية للنظام العام والآداب لما يتسم به دور النيابة العامة في هذا المجال من قصور نظر لعبئها الشديد في العمل ، فضلاً عن أنها لا تستطيع أن تمد سمعها وبصرها على كل ما يخل بالنظام العام والآداب فما أكثر ما يقع وما أقل ما يصل إلى علم النيابة العامة .

كما لا يخفى ما ينطوي عليه إعطاء المواطن حق الدفاع عن قيم المجتمع الذي يعيش فيه من الاستفادة بتكاتف الجهود للمحافظة على نظام المجتمع وأمنه وتركيزه لروح احترام القانون في نفوس الأفراد الأمر الذي أحست بضرورته

(١) انظر : قانون المرافعات ، أ.د. أحمد هندي ص ٥٠٧ .

(٢) أ.د. أحمد هندي في المرجع السابق ، والصفحة نفسها ، أ.د. أحمد السيد صاوي ،

الوسيط ص ١٨٤ ، ١٨٥ ، أ.د. حسن الليدي ، دعاوى الحسبة .

المجتمعات منذ أن بدأت تعرف أسباب الحضارة فنظم القانون الروماني الدعاوى الشعبية وأباح رفعها من الكافة حماية للمصلحة العامة " (١) .

٤ - الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة :

للنيابة العامة رفع الدعاوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق " (٢) .

وقد نص القانون على أن للنيابة العامة رفع الدعاوى بطلب شهر إفلاس التاجر ، كما لها رفع الدعاوى بحل جمعية من الجمعيات .

كما أن القانون أوجب على النيابة العامة أو أجاز لها أن تتدخل في بعض الدعاوى المدنية حماية للمصلحة العامة وحفاظاً على النظام العام والآداب .

ولا تتوافر للنيابة العامة المصلحة الشخصية المباشرة في هذه الدعاوى أو تلك ، إذ لا فائدة تعود عليها ولا ضرر .

وإنما تقبل هذه الدعاوى استثناء من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، ولكن لا يمكن القول بأنها مرفوعة من غير ذي صفة ؛ لأن الصفة متوافرة بحكم القانون (٣) .

(١) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ١٨٤ ، ١٨٥ ، راجع : : د/ أحمد خليفة شرقاوي ، قضاء الحسبة وحصانة الأديان ، مرجع سابق .

(٢) المادة (٨٧) مرافعات .

(٣) أصول المرافعات ، أ.د. أحمد مسلم ص ٣٣١ .

الفصل الثالث

تقسيمات الدعاوى

تنقسم الدعاوى تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، ونوجز القول في ذلك من خلال المبحثين التاليين :

المبحث الأول

تقسيم الدعاوى باعتبار طبيعة الحقوق التي تحميها

تنقسم الدعاوى باعتبار طبيعة الحقوق التي تحميها إلى دعاوى شخصية ودعاوى عينية.

والدعوى الشخصية هي : التي تستند إلى حق شخصي ، ناشئ عن دين أو التزام شخصي أيا ما كان مصدره أي سواء نشأ عن عقد أو فعل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص في القانون كالدعوى التي يرفعها الدائن يطالب مدينه بالدين ، وكالدعوى التي يرفعها البائع على المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن ، أو التي يرفعها المشتري على البائع بتنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة ، أو الدعوى التي يرفعها المؤجر على المستأجر بدفع الأجرة .

ونظراً ؛ لأن الأفراد يستطيعون بإرادتهم أن ينشئوا التزامات شخصية لا حصر لها ، كذلك فإن الدعاوى الشخصية لا يمكن حصرها أو إحصاؤها .

والدعوى العينية هي التي تستند إلى حق عيني ، والغرض منها تقرير هذا الحق في مواجهة من يعتدي عليه أو ينازع فيه (١) ، كدعوى المطالبة بالملكية أو الحيازة أو بأن لعقاره حق ارتفاق على عقار مجار ، أو بنفي تحمل عقاره بحق ارتفاق للعقار المجاور ، أو بحق انتفاع ، وكدعوى الدائن المرتهن ضد من ينازعه في الرهن .

ونظراً ؛ لأن الحقوق العينية الأصلية والتبعية واردة في القانون على وجه الحصر وليس للأفراد أن ينشئوا من الحقوق العينية مالم يرد به نص فإن الدعاوى

(١) مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية ، أ.د. محمد حامد فهمي ص ١٦ .

العينية محدودة بعدد هذه الحقوق (١) .

الدعوى المختلطة :

قلنا إن الدعوى إذا استندت إلى حق شخصي فهي دعوى شخصية ، وإذا استندت إلى حق عيني فهي دعوى عينية .

وقد تستند الدعوى إلى الحقين معاً الحق العيني والحق الشخصي ، وقد جرى الفقه على تسمية هذه الدعوى بالمختلطة .

ومثالها الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بعقد مسجل ضد البائع يطلب فيها تسليم العقار المبيع فهذه الدعوى شخصية ؛ لأنها تستند إلى حق شخصي للمشتري في مواجهة البائع يلزمه بتسليم العقار المبيع يستمده المشتري من عقد البيع ، وهي أيضاً عينية ؛ لأنها تستند إلى حق عيني وهو حق الملكية الناتج عن التسجيل والذي يتعين احترامه من الكافة بما فيهم البائع .

أهمية هذا التقسيم :

تظهر أهمية هذا التقسيم في تحديد من توجه إليه الدعوى .

ذلك أن الدعوى الشخصية تقام على الملتزم نفسه أو من يحل محله من ورثته ولو كان الشيء الملزم به في يد غير المدين به ، نظراً ؛ لأن الحق الشخصي علاقة بين شخصين .

أما الدعوى العينية فترفع ضد الشخص الذي يدعي حقاً له على العين ، أو ضد الشخص الذي توجد العين في حيازته ، نظراً ؛ لأن الحق العيني مقرر على عين بذاتها يتبعها في يد أي إنسان تؤول إليه حيازتها .

فمثلاً إذا أجر شخص عيناً لآخر أصبح ملتزماً بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإن باعها المؤجر أو أجرها لشخص آخر وسلمها إليه ، فلا يكون للمستأجر الأول إلا دعوى شخصية يقيمها على المؤجر يطلب فيها تسليم

(١) شرح قانون المرافعات الجديد ، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٦٣ ، ٦٤ .

العين المؤجرة ، أو تعويض الضرر الناشئ عن عدم الوفاء بالالتزام أما المشتري أو المستأجر الثاني فلا يمكن أن توجه إليه الدعوى ؛ لأنه ليس مدينًا للمستأجر الأول بأي التزام شخصي ؛ ولأن حق المستأجر ليس حقاً عينياً يتبع به العين تحت يد الحائز لها .

وإذا بيع عقار وانتقلت ملكيته بالتسجيل ، كان للمشتري حق عيني على العقار ، وله أن يرفع بناءً عليه دعوى دينية تتبع العقار في أي يد يكون ، حتى ولو كانت حيازة العقار قد انتقلت إلى مشتر ثان من نفس البائع الأول.

المبحث الثاني

تقسيم الدعاوى باعتبار طبيعة الشيء المطلوب بها

نقسم الدعاوى باعتبار طبيعة الشيء المطلوب بها إلى دعاوى عقارية ، ودعاوى منقولة (١) .

الدعوى العقارية هي : الدعوى التي يكون المطلوب بها عقاراً .

والدعوى المنقولة هي : الدعوى التي يكون المطلوب بها منقولاً (٢) .

وتنص المادة (٨٣) مدني على أنه " يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية " .

وجاء في المذكرة الإيضاحية " وقد قسم المشروع الأموال إلى عقار ومنقول أيضاً ، فجعل كل حق عيني يقع على شيء ثابت عقاراً سواء كان ذلك الحق حق

(١) تنص المادة (٨٢) مدني على أنه " كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .

ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رسداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله " .

(٢) مذكرات في قانون المرافعات ، أ.د. محمد حامد فهمي ص ١٧ .

ملكية أو حق انتفاع أو ارتفاق أو رهن أو اختصاص ... الخ ، وكذلك كل دعوى عينية تتعلق بعقار .

واعتبر المشروع مالا منقولاً كل ما ليس مالا عقارياً .. وعلى هذا النحو يعتبر مالا منقولاً جميع الحقوق والدعاوى العينية والشخصية المتعلقة بشيء منقول بما في ذلك حق ملكية المنقول والحقوق الشخصية المتعلقة بعقار والحقوق المتعلقة بشيء غير مادي أي حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية وما شابهها " (١) .

أهمية تقسيم الدعاوى إلى عقارية ومنقولة :

تظهر أهمية هذا التقسيم فيما يتعلق بالاختصاص ذلك أن الدعوى العقارية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار . أما الدعوى المنقولة فترفع أمام محكمة موطن المدعي عليه — كقاعدة — وهناك حالات مستثناة .

تداخل التقسيمين السابقين :

يتداخل التقسيمان السابقان : فقد تكون الدعوى الشخصية منقولة أو عقارية ، وقد تكون الدعوى العينية منقولة أو عقارية .

ويتولد من التقسيمين السابقين أربعة أنواع من الدعاوى هي :

١- الدعوى الشخصية المنقولة ، وهي الدعوى التي تستند إلى حق شخص ويطلب بها مال منقول ، كدعوى الدائن ضد المدين بمبلغ من النقود ، كالدعوى التي ترفع بتسليم سيارة ، وكالدعوى التي يرفعها المستأجر على مؤجر العقار بتسليم العقار للانتفاع به .

٢- الدعوى الشخصية العقارية ، وهي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها الحصول على ملكية عقار أو على حق عيني على عقار ، كالدعوى التي يرفعها مشتري العقار بعقد غير مسجل ضد بائع العقار بطلب صحة التعاقد ، حتى إذا ما سجل الحكم انتقلت ملكية العقار

(١) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ١/٤٧٠ ، ٤٧١ .

للمشتري، فهذه الدعوى تعد شخصية ؛ لأن المشتري لا يستند فيها إلى حق عيني لعدم التسجيل ولكنه يستند إلى حق شخصي ناشئ عن عقد البيع بنقل ملكية العقار .

وهي في نفس الوقت عقارية ؛ لأنها ترمي إلى الحصول على ملكية العقار .
٣- الدعوى العينية المنقولة ، وهي الدعوى التي تستند إلى حق عيني على منقول ، كدعوى مالك المنقول ضد شخص ينازعه فيه ، وكدعوى استرداد المنقولات المحجوزة ، وكدعوى مرتهن المنقول بطلب تقرير حق الرهن في وجه من ينازعه فيه ، فهذه الدعاوى عينية لاستنادها على حق عيني أصلي أو تباعي وهي منقولة ؛ لأنها تتعلق بمال منقول .

٤- الدعوى العينية العقارية ، وهي الدعوى التي تستند إلى حق عيني على عقار ، كالدعوى التي يرفعها مالك العقار بعقد مسجل ضد من ينازعه في ملكيته وكالدعوى التي ترفع بتقرير حق ارتفاق أو انتفاع على عقار أو الدعوى التي يرفعها مالك العقار بنفي وجود حق ارتفاق أو انتفاع على العقار ، وكالدعوى التي يرفعها المرتهن لعقار أو صاحب حق الاختصاص أو الامتياز ضد من ينازعه حقه على العقار ، فهذه الدعاوى عينية لاستنادها على حق عيني أصلي أو تباعي وعقارية ؛ لأن رافع الدعوى يطلب تقرير أو نفي وجود حق عيني على عقار .

أهمية هذه التقسيمات :

تظهر أهمية هذه التقسيمات في تحديد المحكمة المختصة محلياً ، ذلك أن المادة ١/٤٩ مرافعات نصت على أن " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه مالم ينص القانون على غير ذلك " .
ونصت المادة (٥٠) مرافعات على أنه " في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة .

وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه " .

دعاوى خارجة عن التقسيم السابق :

هناك دعاوى لا تدخل تحت التقسيم السابق ، وذلك ؛ لأن هذا التقسيم يعتمد على الحقوق المالية ، ومن ثم تخرج عنه الدعاوى التي لا تتعلق بالأموال ، كالدعاوى التي تتعلق بحالة الإنسان ، كدعوى النسب ، ودعوى الزوجية ، ودعوى الحجر فهذه الدعاوى لا توصف بأنها شخصية أو عينية ولا منقولة أو عقارية . وأياً ما كان الحال فإن هذه الدعاوى تختص بها محلياً المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه طبقاً للقاعدة مالم ينص القانون على غير ذلك . كما أن هناك دعاوى تستند إلى حقوق لا يمكن تحديد طبيعتها ، كدعاوى الفسخ ، والبطلان ، ودعوى إثبات الحالة ، ودعوى تحقيق الخطوط الأصلية ، ودعوى التزوير الأصلية .

وقد اختلف في تحديد طبيعة الحقوق التي تعتمد عليها هذه الدعاوى ، وإن كان لا أثر لهذا الخلاف من الناحية العملية ؛ لأنه من المسلم به أن هذه الدعاوى تعتبر شخصية منقولة أو تعتبر ملحقه بها وتسري عليها جميع أحكامها ؛ لأن الدعاوى العينية محددة في القانون ولها قواعد خاصة بها .

وما عداها يعتبر دعاوى شخصية ، و " لذلك عرف بعض الشراح الدعوى الشخصية تعريفاً واسعاً فقالوا إنها كل دعوى غير عينية ، وعرفوا الدعوى المنقولة كذلك بأنها كل دعوى غير عقارية ، وبهذين التعريفين الواسعين تدخل الدعاوى التي ذكرناها ضمن الدعاوى الشخصية المنقولة " (١) .

(١) مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية ، أ.د. محمد حاد فهمي ٢٣/٢ ، ٢٤ ، شرح قانون المرافعات الجديد ، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جمعي - يرحمه الله - ص ٧٠ .

ثالثاً : دعاوى الحق ودعاوى الحيازة :

تنقسم الدعاوى العينية العقارية إلى دعاوى الحق ، ودعاوى الحيازة .
ودعاوى الحق هي التي تحمي حقاً عينياً أصلياً على عقار كدعوى استحقاق العقار وتنشيت الملكية ، ودعوى تقرير حق الارتفاق أو الانتفاع ، ودعوى نفيهما .
أما دعاوى الحيازة فهي التي تحمي مجرد حيازة تلك الحقوق ، فهي دعاوى تحمي المركز الواقعي وهو السيطرة الفعلية على عقار ، بصرف النظر عن كون الحائز مالكاً للعقار الذي يدعي حيازته أم لا .
وتهدف دعوى الحق إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقه مباشرة والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته ولمن من الخصوم هو في الواقع .
أما دعوى الحيازة فلا يقصد منها إلا حماية الحيازة في ذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها (١) .
وتخضع دعاوى الحق للقواعد العامة في الدعاوى أما دعاوى الحيازة ؛
فالأنها تحمي مجرد مركز قانوني ، ولخضوعها لقواعد خاصة بها ، فإنها تتفرد بدراسة خاصة ، وهو ما تخصص له الفصل الرابع .

(١) نقض مدني جلسة ١٩٣٢/٣/١٧ طعن رقم ٤ لسنة ٢ ق .

الفصل الرابع دعاوى الحيازة

تمهيد وتقسيم:

نظم المقنن دعاوى لحماية الحيازة في حد ذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالكاً أو صاحب حق أم أنه ليس كذلك .

ويرجع اهتمام المقنن بأمر الحيازة وحمايتها إلى أن حماية الحيازة تعد حماية للملكية أو الحق بطريق غير مباشر ، ذلك أن الأصل أن الملكية تكون للحائز ، وقد نصت المادة (٩٥٤) مدني على أن " من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس " وعلى ذلك فحماية الحيازة حماية للملك أو الحق .

والتجاء المالك أو صاحب الحق إلى دعاوى الحيازة أسهل له من الالتجاء إلى دعوى الملك أو الحق ؛ لأن طريق هذه الدعوى طويل وشاق يستغرق وقتاً ومالاً ، بخلاف دعاوى الحيازة فهي سهلة ؛ لأن رافعها عليه أن يثبت مجرد وضع يده وهو أمر يسير ولا يكلف بإثبات الملكية أو الحق ، وعندما يثبت حيازته فإنه يصبح مدافعاً بالنسبة للحق وعلى من ينازعه فيه عبء الإثبات .

وحتى إذا لم يكن الحائز مالكاً أو صاحب الحق فحمايته واجبة إلى أن يثبت خصمه أن الحائز غير مالك ، والقول بغير ذلك يعني السماح لمن يدعي الملكية بالاعتداء على الحائز ونزع الحيازة بالقوة مما يؤدي إل الفوضى وتعرض النظام للخطر .

لذلك وضع المقنن المصري ثلاث دعاوى لحماية الحيازة هي دعوى استرداد الحيازة ، دعوى منع التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة (المواد من ٩٥٨ - ٩٦٢ مدني).

ونتناول فيما يلي هذه الدعاوى في مباحث متتالية ثم نتحدث في قاعدة " عدم الجمع بين الحيابة والحق " في مبحث وفي الحماية الوقتية للحيابة في مبحث على النحو التالي :

المبحث الأول: دعوى منع التعرض .

المبحث الثاني : دعوى وقف الأعمال الجديدة .

المبحث الثالث : دعوى استرداد الحيابة .

المبحث الرابع : قاعدة عدم الجمع بين الحيابة والحق .

المبحث الخامس : الحماية الوقتية للحيابة .

المبحث الأول

دعوى منع التعرض

تعريفها :

يقصد بدعوى منع التعرض ، الدعوى التي يرفعها حائز العقار يدفع بها إجراءً مادياً أو قانونياً موجهاً إليه بما يتعارض مع حقه في الحيابة .
ذلك أن محكمة النقض عرفت التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض بأنه " الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد " (١) .
وعلى ذلك فـ " إن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب ... " (٢) .

(١) نقض مدني جلسة ١٦/٤/١٩٧٩م طعن رقم ٧١١ لسنة ٤٦ ق .

(٢) نقض مدني جلسة ٦/١١/١٩٥٢م طعن رقم ٨٢ لسنة ٢٠ ق .

ويشترط لقبول دعوى منع التعرض الشروط الآتية :

الشرط الأول : أن يكون المدعي حائزاً حيازة قانونية .

والحيازة القانونية هي سلطة فعلية يستعملها شخص على شيء باعتباره مالكاً له أو صاحب حق عيني عليه ، ولا يهم أن يكون هذا الشخص مالكاً بالفعل أو صاحب حق عيني أو لا يكون .

ومن التعريف يبدو أن للحيازة ركنين ، ركن مادي ، وركن معنوي ، ولا توجد الحيازة القانونية إلا إذا توافر الركنان .

١- ويتكون الركن المادي من مجموعة الأعمال المادية التي يقوم بها حائز ، وهي الأعمال التي تصدر عادة من مالك الشيء أو صاحب حق عيني عليه ، ويكون هذا بالاستئثار مادياً بالشيء أو بالقيام بالأفعال المادية التي يكون بها استعمال الشيء أو استغلاله أو التغيير فيه وفقاً لما تسمح به طبيعته ، فقد تكون الحيازة للأرض الزراعية بزراعتها ، وللعمارة بإجارتها ، أو لمنزل بسكنائه وللحديقة بجني ثمارها ، أو قلع بعض ما بها من أشجار .

ويجب أن تكون الأعمال التي يقوم بها الحائز كافية للدلالة على حيازة الشيء .

ولكن لا يلزم استمرار الأعمال المادية فقد يكفي الاستعمال المتقطع لقيام الركن المادي للحيازة ما دامت طبيعة الشيء أن يستعمل استعمالاً متقطعاً ، كما في أراضي المراعي ، والمباني التي تقام بالمصايف والمشاتي .

كما لا يلزم أن يقوم الحائز بالأعمال المادية بنفسه ويكفي أن يباشرها بواسطة تابعيه من العمال والخدم ونحوه .

ولكن يجب أن تكون الأعمال المادية التي يأتيها الحائز على جانب من الأهمية فـ " لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح " (١) .

(١) المادة ١/٩٤٩ مدني .

وتطبيقاً لذلك فإن مجرد وضع سيارة في أرض فضاء أو مجرد المرور في أرض الجار ، أو مجرد وضع أسمدة ومحاصيل في أرض فضاء ، أو مجرد وضع أتربة ناتجة عن حفر قطعة أرض مجاورة لأرض فضاء كل هذه الأعمال لا تظهر فاعلها بمظهر الحائز ؛ لأن هذه الأعمال يتحملها الملاك المتجاورون على سبيل التسامح بينهم فلا تكسب من يقوم بها حقاً قبل الآخر مهما طال الزمن .

٢- أما الركن المعنوي فهو قصد الحائز استعمال الحق العيني الذي تدل عليه الأعمال المادية التي يقوم بها ، وهو بهذا يحوز لحساب نفسه فيظهر بمظهر مالك الشيء أو صاحب الحق العيني عليه .

أما إذا لم يكن الشخص يحوز بقصد التملك أو استعمال حق عيني عليه فإن الركن المعنوي لا يكون موجوداً ، وتكون الحيازة مادية أو عرضية وليست قانونية، كحيازة المستأجر والمستعير والمودع لديه ، والحارس المرتهن حيازياً ، وحيازتهم لا تكفي لقبول دعوى منع التعرض ، ما عدا المستأجر وهو حائز عرضي فله أن يرفع جميع دعاوى وضع اليد بناءً على المادة ١/٥٧٥ مدني (١) . وعلى ذلك " يجب توافر نية التملك لمن يبتغي حماية يدع بدعوى منع التعرض ... فلا تكفي حيازة عرضية ... أما ما أباحه القانون المدني ... للمستأجر وهو حائز عرضي من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء استثناء من الأصل لا تطبيقاً لمبدأ عام وذلك لما لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس والمرتهن حيازياً والمودع لديه" (٢) .

(١) ونصها " لا يضمن المؤجر المستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من حق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد " .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٦٢/١٢/٦ طعن رقم ٢٣٣ لسنة ٢٧ ق ، جلسة ١٩٥٦/٤/١٢ طعن رقم ٣٥٧ لسنة ٢٢ ق ، جلسة ١٩٤٥/١/١٨ طعن رقم ٤٩ لسنة ٤١ ق .

و " لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وقضاؤها في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ، ما دامت هذه العناصر مدونة في حكمها ، وتفيد عقلاً النتيجة التي استفادتها " (١) .

الشرط الثاني : أن تكون الحيازة خالية من العيوب .

تنص المادة ٢/٩٤٩ مدني على أن الحيازة " إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عليه الحيازة أو التمس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب " .

وعلى ذلك فيجب أن تكون الحيازة خالية من الإكراه والخفاء واللبس (الغموض) وهذه العيوب لا تعد الحيازة ما دام قد توافر لها ركنها المادي والمعنوي ، فالحيازة المعيبة غير الحيازة العرضية ، فالأولى حيازة قانونية ، والثانية ليست كذلك ، ولهذا تنتج الحيازة المعيبة آثارها ضد جميع الناس عدا من تعيبت في مواجهته .

(أ) الإكراه :

إذا أخذت الحيازة بالقوة تكون معيبة بعيب الإكراه يستوي في ذلك الإكراه المادي والمعنوي ، ولكن لا يكفي الإكراه البسيط .

وتعتبر الحيازة التي بدلت بالإكراه غير هادئة وتظل كذلك ما دام الإكراه موجوداً ، فإذا زالت القوة ، ولم يعد الحائز محتاجاً إليها للاحتفاظ بحيازته فإن الحيازة تبرأ من هذا الوقت من عيب الإكراه .

و " إذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك " (٢) .

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧٣/٣/٢٣ طعن رقم ١٣٧ لسنة ٣٧ ق .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٥٩/٦/٢٥ طعن رقم ١١٨ لسنة ٢٥ ق .

(ب) الخفاء :

يجب أن تكون الحيابة ظاهرة ، ومن ثم إذا كانت خفية فلا تنتج آثارها ولا يحميها القانون ، ذلك أن المالك أو صاحب الحق لا يعتمد إخفاء حيابته فليس هذا شأن المالك أو صاحب الحق .

ومثال الخفاء في حيابة العقار أن يستمد شخص المياة من إحدى المساقي عن طريق أنابيب ينشئها تحت أرض الجار ، أو أن يحفر نفقاً للمرور منه إلى العقار . وعلى ذلك يجب أن تكون الحيابة ظاهرة غير خفية .

(ت) اللبس أو الغموض :

هو الشك الذي يحيط بالحيابة فلا يعرف ما إذا كان الحائز يحوز الشيء باعتباره مالكاً أو صاحب حق عيني عليه ، أم يحوزه لحساب غيره ، فإذا قام هذا الشك وكانت أفعال الحيابة تحتل أحد هذين الفرضين فإنها تكون معيبة بعب اللبس أو الغموض ، مثال ذلك أن يحوز مالك العقار الذي يملك فيه جزءاً على الشيوع ، فإن حيابته تحتل أنه يحوز كل المال لحساب نفسه أو أنه يحوزه بناءً على حقه كمالك على الشيوع بالنيابة عن الشركاء ، فهذه الحيابة حيابة معيبة بعب اللبس أو الغموض .

وعلى ذلك يجب أن تكون الحيابة واضحة ، ومن هنا فإنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن تتوافر الحيابة الهادئة الظاهرة الواضحة (١) .
و " لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيابة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة " (٢) .

(١) نقض مدني رقم ١٠٨ لسنة ١٣١٣ ق جلسة ١٩٤٤/٥/٤ .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/١١/١٦ طعن رقم ٩٣٧ لسنة ٤٥ ق .

الشرط الثالث : أن ترد الحيازة على عقار أو حق يجوز تملكه بمضي المدة (١) .

وعلى ذلك لا تقبل دعوى منع التعرض وسائر دعاوى الحيازة إلا من حائز العقار ، فلا ترفع لحماية منقولات ؛ لأن الحيازة في المنقول تختلط بالملكية ، ذلك أن الحيازة في المنقول سند الملكية ولحائز المنقول استرداده بدعوى الملكية ويكفي لإثباتها إقامة الدليل على الحيازة بحسن نية .

ولكن إذا أصبح المنقول عقاراً بالتخصيص تجرى عليه جميع الأحكام المتعلقة بالعقار ، ويكون موضوعاً لحماية دعوى الحيازة طالما أن له صفة العقار (٢) .

كما لا تقبل دعاوى الحيازة ممن يحوز عقاراً أو حقاً لا يجوز تملكه بالتقادم، كمن يحوز عقاراً من الأملاك العامة للدولة (٣) ، أو من الأملاك المخصصة للمنفعة العامة (٤).

الشرط الرابع : أن تستمر حيازة الحائز هادئة ظاهرة واضحة لمدة لا تقل عن عام قبل وقوع التعرض.

وقد قدر المقنن أن من يستمر حائزاً لمدة سنة كاملة حيازة هادئة ظاهرة واضحة فهو يحوز حيازة جديرة بالحماية القانونية .

ويجب أن تكون السنة مستمرة وكفي في ذلك أن يثبت الحائز بشهادة الشهود أو بالمستندات الدالة على حيازته أنه كان حائزاً في بداية السنة وفي نهايتها فيفهم من ذلك أن الفترة التي تتخلل ما بين التاريخين هي فترة حيازة متصلة .

(١) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ٢١٥ .

(٢) شرح قانون المرافعات ، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٨١ .

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٥٦/٤/١٢ طعن رقم ٢٥٧ لسنة ٢٢ ق .

(٤) نقض مدني جلسة ١٩٤٤/٣/٩ طعن رقم ٦٥ لسنة ١٣ ق .

ويجوز للخلف أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفة ليكمل مدة السنة ، بشرط قيام رابطة قانونية بين الحيازتين (١) .

الشرط الخامس : أن يكون المدعي عليه قد تعرض للمدعي في حيازته

والتعرض قد يقع بفعل مادي يحرم الحائز من حيازته أو يعطل انتفاعه بها ، كما قد يقع بإجراء قانوني ينطوي على ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز .

ومن أمثلة التعرض المادي أن ينزع شخص حيازة عقار في يد غيره ، أو يقوم بالبناء في الأرض أو يقوم بزراعتها ، أو يحفر فيها مسقى ، أو يغرس فيها أشجاراً ، أو يرعي فيها أغناماً ، أو أن يفتح نافذة في جدار تطل على ملك الجار أو أن يردم مسقى في أرضه تمتد إلى أرض الجار ، أو يهدم ممراً في أرضه يمتد إلى أرض الجار ؛ لأن الردم والهدم يتضمنان إنكار حق الارتفاق الذي تنتفع به أرض الجار ويعتبر حائزاً له .

ومن أمثلة التعرض بإجراء قانوني ، أن يرسل شخص إنذاراً للحائز بعدم البناء مثلاً في الأرض ، أو يرسل شخص إنذاراً إلى المستأجر من الحائز بعدم دفع الأجرة للحائز وأن يدفعها للمنذر ، أو أن يقيم شخص دعوى ضد المستأجر من الحائز طالباً طرده من العين المؤجرة باعتباره غاصباً وإلزامه بالتعويض عن حيازتها بغير حق .

أما إذا رفعت دعوى الملكية ، فلا تعتبر تعرضاً للحائز في حيازته ؛ لأن ادعاء الملكية لا يتضمن المنازعة في الحيازة ، بل يتضمن التسليم للمدعي عليه بالحيازة .

فضلاً عن أنه لو جاز منع دعوى الملكية واعتبرت تعرضاً للحائز ، لكان معنى ذلك عدم وجود سبيل لتقرير حقه الذي يدعيه (٢) .

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧١/١٢/٢٣ طعن رقم ٧٥ لسنة ٣٧ ق .

(٢) مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية ، أ.د. محمد حامد فهمي ص ٣٢ ، ٣٣ .

الشرط السادس :أن ترفع دعوى منع التعرض في خلال سنة من وقوع التعرض ، وإلا سقط حق الحائز في رفعها ، ولم يبق له إلا دعوى الملكية يرفعها بطلب أصل الحق على العين .

و " إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم وتحتسب مدة السنة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى ... فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت عن شخص واحد فإنها تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يحقق اعتداءً على الحيازة " (١) .

وتعتبر مدة السنة المشترط عدم مضيها على الفعل الصادر من المدعي عليه مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الانقضاء التي تسري على التقادم المسقط العادي (٢) .

المبحث الثاني

دعوى وقف الأعمال الجديدة

تعريفها :

هي دعوى يرفعها حائز العقار أو الحق العيني على من بدأ في عمل من شأن تمامه أن يحدث ضرراً لحيازته .

وتهدف هذه الدعوى إلى إيقاف العمل الجديد قبل أن يتم ويصبح تعرضاً كأن يبدأ شخص بوضع مضخة ميكانيكية في مزرعته من شأن تشغيلها سحب المياه وحرمان المزارع المجاورة من المياه، فيرفع صاحب مزرعة مجاورة دعوى وقف وضع المضخة ، نظراً ؛ لأن وضعها يتسبب في منع المياه لعدم مراعاة المسافة

(١) نقض مدني جلسة ١٦/٤/١٩٧٩ الطعن رقم ٧١١ لسنة ٤٦ ق .

(٢) نقض مدني جلسة ١٣/١٢/١٩٤٥ طعن رقم ٢٥ لسنة ١٥ ق .

بين المضخات ، أو كأن يبدأ شخص في بناء جداراً لو تم لأدى إلى سد مطل قانوني لجاره ، فيرفع الجار دعوى وقف الأعمال الجديدة ؛ لأن من شأن تملّكها أن تصبح تعرضاً للحائز في حيازته لحق الارتفاق .

شروطها :

تنص المادة ١/٩٦٢ مدني على أن " من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر " . وعلى ذلك يشترط لدعوى وقف الأعمال الجديدة الحيازة القانونية الهادئة الظاهرة الواضحة ، وأن ترد على عقار أو حق عيني يجوز تملكه بالتقادم ، وأن تستمر هذه الحيازة لمدة سنة قبل بدء الأعمال الجديدة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من بدء العمل الذي من شأنه تمامه أن يحدث الضرر . وتتفق هذه الشروط مع الشروط التي سبق ذكرها في دعوى منع التعرض فنحيل إلى ما سبق ذكره بشأنها .

ولكن دعوى وقف الأعمال الجديدة يشترط فيها شرط خاص وهو : ألا يكون العمل قد تم ، فوفقاً لنص المادة ٢/٩٦٢ مدني يشترط أن ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة قبل تمام العمل ؛ لأن العمل إذا تم تصبح أمام تعرض للحيازة ومن ثم يدفع هذا التعرض بدعوى منع التعرض التي يجوز رفعها في هذه الحالة خلال عام من تاريخ انتهاء العمل الذي يمثل التعرض .

وتتميز دعوى وقف الأعمال الجديدة عن غيرها من دعاوى الحيازة في سلطة القاضي التقديرية عند نظر الدعوى فله " أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها ، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف العمل ضماناً لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو

بعضها إصلاحاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته " (١) .

ويبدو مما تقدم أن دعوى وقف الأعمال الجديدة تنتهي بحكم وقتي وتعقبها دعوى موضوعية لتقرير الحق فشأنها في ذلك شأن الدعوى المستعجلة .

المبحث الثالث

دعوى استرداد الحيازة

تعريفها :

هي الدعوى التي يطلب بها الحائز رد العقار المغصوب ممن حازه بالإكراه.

شروطها :

الشرط الأول : الحيازة :

نظراً لأن دعوى استرداد الحيازة وضعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، بصرف النظر عن الحيازة ومن ثم لا يشترط فيها توفر نية التملك عند الحائز ، كما لا يشترط فيها وضع اليد لمدة سنة على الأقل سابقة على التعرض ، ويجوز رفعها ممن ينوب عن غيره في الحيازة ، ويكفي في قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة واضحة (٢) .

الشرط الثاني : أن يقع سلب للحيازة .

والمقصود بسلب الحيازة زوال حيازة المدعي بصفة كاملة ، وذلك بإخراجه من العقار واستيلاء شخص آخر عليه .

وليس معنى زوال حيازة المدعي بصفة كاملة أن تزول حيازة العقار كله ، وإنما معنى ذلك أن يكون زوال الحيازة كاملاً حتى ولو كان عن جزء من العقار ، وذلك تمييزاً لسلب الحيازة عن التعرض فهو قد يزيل حيازة الحائز في فترة

(١) المادة ٢/٩٦٢ مدني .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٦/٥/٥ طعن رقم ٧١١ لسنة ٤٢ ق ، جلسة ١٩٦٤/١/٩ طعن رقم ٥٨ لسنة ٢٩ ق .

التعرض ، وعلى ذلك فزوال الحيازة بصفة متقطعة ولفترات مؤقتة يعتبر تعرضاً ولا يكون سلباً للحيازة.

و" لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره ... " (١) وإن كانت " دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوة مادية وتكون قد سلبت حيازة مادية أيضاً " (٢) .

وقد يتم سلب الحيازة بالقوة والإكراه ، أو بالغش والخديعة، ويتم سلب الحيازة بالقوة والإكراه باستخدام وسائل مادية لا يستطيع الحائز أو نائبه أن يدفعها. وقد يكون الإكراه معنوياً ، كما لو تمكن شخص من استصدار أمر من النيابة العامة بتسليم العقار إليه ، فيضطر الحائز مكرهاً إلى التخلي عن حيازته وتسليم العقار لمن صدر أمر النيابة لصالحه (٣) .

ويتم سلب الحيازة بالغش والخديعة وذلك باستعمال أساليب احتيالية تؤدي إلى الاستيلاء على العقار رغماً عن إرادة الحائز ، ومثال ذلك تنفيذ حكم قضائي بتسليم العقار في مواجهة الحائز الذي لم يكن طرفاً في الحكم .

الشرط الثالث : أن ترفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة .

أو من زوال حالة الإكراه ، إذا كانت أعمال العنف قد استغرقت فترة من الزمن ، كما لو دارت معركة استمرت عشرة أيام فلا تحسب مدة السنة إلا من اليوم الأخير لانتهاء المعركة .

أو تحسب السنة من وقت اكتشاف زوال الحيازة ، إذا تم زوالها خفية . ويراعى أنه لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة استمرار حيازة المسترد عاماً كاملاً قبل سلبها .

(١) نقض مدني جلسة ١٩٥٥/١٠/٢٠ طعن رقم ١٩١ لسنة ٢٢ ق .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٣٦/١٠/٢٢ طعن رقم ٤٠ لسنة ٦ ق .

(٣) مبادئ المرافعات ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٢٥٥ .

ولكن إذا كانت حيازته مستمرة لمدة أطول من عام قبل سلب الحيازة ، فيجوز للحائز رفع دعوى استرداد الحيازة ولو كان سلبها قد تم بدون استعمال القوة أو أساليب الغش والاحتتيال .

أما إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة قبل سلبها فنفرق بين سلب الحيازة بالقوة أو الغش وسلبها بغير ذلك .

فإن سلبت بالقوة أو الغش فللحائز أن يسترد حيازته .

أما إذا سلبت بغير عنف ولا غش " فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني .

فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ " (١) .

المبحث الرابع

قاعدة عدم الجمع بين الحيازة والحق

قصد المقتن حماية الحيازة في حد ذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالكاً أو صاحب حق ، ويتصور انفصال الحيازة عن الملكية ، بمعنى أن الحائز قد يكون شخصاً آخر غير المالك ومع هذا فهو جدير بالحماية باعتباره صاحب مركز واقعي .

واستكمالاً لحماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق (٢) منع القانون الجمع بين الحيازة والحق ويسري المنع على المدعي والمدعي عليه والقاضي ومعنى ذلك عدم جواز رفع الدعويين في وقت واحد ، وبناءً على ذلك فإنه إذا رفعت دعوى الحيازة فلا يجوز للخصوم عرض أصل الحق للنزاع ، إلا إذا انتهت الخصومة على الحيازة ، أو تنازل عنها رافعها .

(١) المادة ١/٩٥٩ مدني .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٤/١١/٥ طعن رقم ٤٦٢ لسنة ٣٨ ق .

كما لا يجوز لقاضي الحيازة أن يقضي لمصلحة الحائز أو في غير مصلحته مستنداً إلى أساس الحق ، وإنما يجب أن يكون مستنداً إلى واقعة الحيازة في ذاتها (١).

وقد نصت المادة (٤٤) مرافعات على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة . ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .

وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه "

المقصود بالحق :

يقصد بالحق الذي لا يجوز الجمع بين المطالبة به وبين دعوى الحيازة ، والذي لا يجوز دفع دعوى الحيازة استناداً إليه ، والذي لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوته أو نفيه ، هو حق الملكية أو أي حق عيني آخر ، كحق الارتفاق أو حق الانتفاع (٢) .

تطبيق القاعدة بالنسبة للمدعي في دعوى الحيازة :

" لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ، يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ... ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي في الادعاء بالحيازة " (٣) تأسيساً على أن المدعي تنازل عن دعوى الحيازة ذلك ؛ لأن المقنن أعطاه الخيار بين طريقين

(١) قواعد المرافعات ، لمحمد العشماوي ، د. عبد الوهاب العشماوي ص ٦٥٠ .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٥٦/٤/١٢ طعن رقم ٢٥٧ لسنة ٢٢ ق .

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٧٤/١١/٥ طعن رقم ٤٦٢ لسنة ٣٨ ق ، نقض مدني جلسة ١٩٥٥/٦/١٦ طعن رقم ٢٧ لسنة ٢٢ ق .

أحدهما سهل وهو طريق دعوى الحيازة والآخر صعب وهو طريق دعوى الملكية فإذا اختار الطريق الصعب يعتبر متنازلاً عن الطريق السهل الميسور .
وتسقط دعوى الحيازة لرفع دعوى الحق سواء رفعت أمام المحكمة التي تنتظر دعوى الحيازة أم أمام محكمة أخرى .
وإذا بادر المدعي ورفع دعوى الملك فلا يجوز له أن يرفع دعوى الحيازة (١) .

ومن باب الأولى " إذا رفعت دعوى الملك أولاً وفصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ؛ لأن القضاء في الملك يكون شاملاً لها " (٢) .
ولكن إذا رفع المدعي دعوى الحق ثم حصل اعتداء على حيازته فيجوز له في هذه الحالة أن يرفع دعوى حيازة وتكون مقبولة وتستمر الدعويان أمام القضاء (٣) ، والقول بتطبيق قاعدة عدم الجمع في هذه الحالة يؤدي إلى سلب الحماية عن الحيازة لمن يرفع دعوى الملك إذ يباح للمدعي عليه أن يعتدي على حيازة المدعي ولا يملك المدعي أن يرفع دعوى لحماية حيازته بمجرد أنه رفع دعوى الحق .

تطبيق القاعدة بالنسبة للمدعي عليه في دعوى الحيازة :

لا يجوز للمدعي عليه في دعوى الحيازة أن يدفع الدعوى بالاستناد إلى الحق ذلك أنه حتى ولو كان مالكاً فلا يعني هذا أنه حائز ؛ لأن الحيازة قد تنفصل عن الملك ، ويكون الحائز غير المالك .

(١) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد ثاوي ص ٢٢٧ .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٤٤/٢/٢٤ طعن رقم ٦٠ لسنة ١٣٣ ق .

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٤٠/٥/٩ طعن رقم ١٠ لسنة ١٠ ق .

والدفع هنا دفع غير منتج ؛ لأنه ليس كل مالك حائزاً ، فضلاً عن أن الملك لا يجيز لصاحبه أن يتعرض للحائز أو يسلب حيازته بالقوة ، لما في ذلك من إخلال بالأمن ومخالفة لقاعدة " لا يجوز لإنسان أن يقتضي حقه بيده " (١) .

ولا يجوز للمدعي عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الحق إلا بعد الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها ، أو أن يتخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .

وعلى ذلك إذا أراد المدعي عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الحق ، فعليه أن يتخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه ، أو أن ينتظر حتى يفصل في دعوى الحيازة ، وينفذ الحكم الصادر فيها ، ثم يرفع دعواه بعد ذلك .

أما إذا تعجل ورفع المدعي عليه في دعوى الحيازة دعوى الملك قبل أن يتخلى عن الحيازة وقبل أن يصدر الحكم فيها وينفذ فلا تقبل دعواه بصريح نص المادة ٢/٤٤ مرافعات .

تطبيق القاعدة بالنسبة للقاضي في دعوى الحيازة :

لا يجوز للقاضي في دعوى الحيازة أن يحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

وترتيباً على ذلك لا يجوز للقاضي في دعوى الحيازة أن يحكم بها بناءً على ثبوت الملك ، أو أن يحكم بعدم الحيازة على أساس عدم الملك ؛ لأن العلاقة منفكة بين الحيازة والملك ولا تلازم بينهما ، ومن ثم إذا استند إلى ثبوت الحق أو نفيه لإثبات الحيازة أو نفيها يكون قد استند إلى أسباب غير منتجة .

ويجب على القاضي أن يبني حكمه في دعوى الحيازة على توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها لا على ثبوت الحق أو عدم ثبوته (٢) .

(١) مبادئ المرافعات ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٢٦٦ .

(٢) تطبيقاً لذلك حكمت محكمة النقض بـ " إن المادة ... من قانون المرافعات إذ تنهي عن الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق تلزم القاضي إلزامها الخصوم بالنزول على

وما دام القاضي ممنوعاً من الحكم بالحيازة على أساس الملكية فلا محل في دعوى الحيازة لبحث الملكية ومستنداتها إلا على سبيل الاستئناس للتحقق من صفة وضع اليد ، لا لتأسيس الحكم عليها (١) وينبغي أن يكون ذلك بالقدر الذي تقتضيه دعوى الحيازة دون التعرض إلى أمر الملكية بأي حال .

وتطبيقاً لذلك قالت محكمة النقض " إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية ولا محل فيها لبحث الملكية ولا مستنداتها إلا على سبيل الاستئناس بها في شأن وضع اليد وبالقدر الذي تقتضيه دعوى اليد دون التعرض لأمر الملكية بأي حال ، فعلى المحكمة أن تقيم حكمها في هذه الدعاوى على الحيازة المادية بشروطها فتقضي بقبولها أو برفضها بناءً على توافر تلك الشروط أو عدم توافرها أما إذا هي أسست قضاءها فيها على الملكية ومستنداتها فإنها بذلك تكون قد أقحمت دعوى الملك على دعوى اليد وأغفلت أمر وضع اليد وخالفت المادة ... من قانون المرافعات " (٢) .

حكمها ، فيتعين على القاضي أن يقيم حكمه في دعوى اليد على توافر وضع اليد بشروطه القانونية أو عدم توافره لا على ثبوت الحق أو عدم ثبوته ، فإذا كان الحكم في دعوى وضع اليد قد اتخذ من ثبوت حق الارتفاق الأساس الوحيد لقضائه بإعادة الطريق محل النزاع إلى حالته الأولى فإنه يكون مخالفاً للقانون " (نقض مدني جلسة ١٩٤٨/٤/٤ طعن رقم ١٣ لسنة ١٧ ق) .

(١) نقض مدني جلسة ١٩٥٢/١/١٠ طعن رقم ٣ لسنة ٢٠ ق .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٤٦/١/١٧ طعن رقم ٣٥ لسنة ١٥ ق .

المبحث الخامس الحماية الوقتية للحيازة

تمهيد :

" يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة وكانت هذه المنازعات تعرض على النيابة العامة وتصدر فيها قرارات وقتية بمنح الحيازة لأحد المتنازعين أو ترك الأمر على ما هو عليه وعلى الطرف المتضرر من قرارها أن يلج سبل التقاضي أمام المحاكم للتظلم منه ، وقد ثار الخلاف في شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة في هذا الشأن استتباعاً للجدل حول تحديد ماهية هذا القرار ، وهل هو قرار إداري فيختص بنظر التظلم منه جهة القضاء الإداري أم هو قرار قضائي يندرج تحت ولاية جهة القضاء العادي . وقد أخذت بعض المحاكم بالرأي الأول ، وأخذ البعض الآخر بالرأي الثاني ، واتجه رأي ثالث إلى أن قرار النيابة الوقتي المتعلق بالحيازة إذا كان صادراً في شأن منازعة تشكل جريمة من جرائم انتهاك ملك الغير فهو قرار قضائي لا تختص جهة القضاء الإداري بنظر التظلم المرفوع عنه ، أما إذا كان قرار النيابة الوقتي سالف الذكر صادراً في شأن منازعة لا تشكل جريمة فإنه يعتبر من قبيل القرارات الإدارية مما يختص معه مجلس الدولة دون القضاء العادي بنظر التظلم منه ، وإزاء هذه الآراء المتعددة في شأن تحديد الجهة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة العامة في شأن الحيازة " (١) أصدر المقتن القانون ٢٩ لسنة ١٩٨٢م استحدث به المادة (٣٧٣) عقوبات ، وبمقتضاها أصبح للنياية العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه .

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢م .

وواضح أن النص لم يعالج إلا جانباً واحداً يتعلق بحالة جدية الاتهام بجريمة، وحجب النيابة العامة عن إصدار قرارات وقتية في شأن منازعات الحيازة المدنية (التي لا تثير شبهة جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير) مع أن منازعات الحيازة المدنية قد تؤدي في كثير من الأحيان بأطرافها إلى الوقوع في الجريمة(١).

لذلك أصدر المقتن القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٢ وعالج فيما عالج مسألة الحماية الوقتية للحيازة ، وأضاف مادة جديدة إلى قانون المرافعات برقم (٤٤) مكرر ونص فيها على أنه " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم " .

المقصود بمنازعات الحيازة :

" يقصد بمنازعات الحيازة المشاكل القانونية أو المادية التي تتضمن إزعاج الحائز وتكدير صفو حيازته "(٢) .

كما يقصد بالحيازة مطلق الحيازة فتشمل الحيازة القانونية والحيازة المادية ، ذلك أن الهدف حماية الحيازة في حد ذاتها .

(١) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ٢٣٣ ، ٢٣٤ .

(٢) قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أ.د. نبيل إسماعيل عمر ص ٢٤٠ .

اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة :

وفقاً لنص المادة (٤٤) مكرر أصبحت النيابة العامة مختصة بنظر ما يعرض عليها من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ، أي سواء كانت المنازعة مدنية بحتة أي لم تقترن بأفعال تشكل جريمة ، أم كانت مقترنة بما يشكل جريمة ، وقبل هذا التعديل لم تكن مختصة بالمنازعة إلا إذا شكلت جريمة .

ويراعى أن المادة (٤٤) مكرر لم تسلب المحاكم اختصاصها بدعوى الحيازة، فاختصاص المحاكم المدنية بمنازعات باق كما هو ، والحائز حر في اختيار الطريق الذي يحقق مصلحته ، ولا مانع يمنع من الجمع بين الطريقين النيابة العامة ، والقضاء ، فيجوز لمن سلبت حيازته أن يرفع الأمر للقضاء ، ويبلغ النيابة بذلك ، ويمكن للمحكمة أن توقف الدعوى المدنية لحين صدور قرار النيابة .

نظر المنازعة وإصدار القرار :

أوجبت المادة ١/٤٤ مكرر مرافعات على النيابة العامة إذا عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن يعرض النزاع على عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، حتى يكون على قدر كبير من الخبرة والدراية اللازمة . كما أوجبت على عضو النيابة أن يسمع أقوال أطراف النزاع وأن يجري التحقيقات اللازمة ثم يصدر قراراً مسبباً واجب التنفيذ فوراً ، وسواء كانت المنازعة مدنية بحتة ، أو جنائية .

ولا يمنع صدور هذا القرار النيابة العامة من المبادرة إلى رفع الدعوى الجنائية إذا شكلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم .

إعلان القرار لذوي الشأن :

أوجبت الفقرة الثانية من المادة (٤٤) مكرر مرافعات على النيابة العامة أن تعلن القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . ويراعى أن هذا الميعاد ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته سقوط أو بطلان أو جزاء مالي ، وإن كان قد يترتب جزاء إدارياً على المتسبب في تأخير جعل غيبة كثير من الموجهة إليهم الإعلانات أو الذين يجري التنفيذ في حقهم عن

مواطنهم لفترة متأخرة من النهار أمراً شائعاً" (١) ، ولذلك عدل المقنن النص وأجاز إجراء الإعلان أو القيام بالتنفيذ حتى الساعة الثامنة مساءً . ويجوز إتمام الإعلان في غير الأوقات المسموح بها ، إذا كانت هناك ضرورة لذلك ، وبناءً على أمر من قاضي الأمور الوقفية .

التظلم من قرار النيابة في منازعات الحيابة :

لكل ذي شأن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه .

وسواء كان القرار صادراً في شأن منازعة جنائية أم في شأن منازعة غير جنائية، وبذلك حسم المقنن النقاش الذي دار بين جهتي القضاء وجعل التظلم من اختصاص جهة القضاء العادي سواء كان قرار الحيابة الصادر من النيابة العامة مدنياً أو جنائياً (٢) .

وإذا لم يرفع التظلم خلال المدة سالفة الذكر سقط الحق فيه وأصبح قرار النيابة نهائياً ، بمعنى أنه ينفذ قرار النيابة ويبقى الوضع كذلك إلى أن يفصل في النزاع من الناحية الموضوعية من المحكمة المختصة بأصل الحق .

وإذا رفع التظلم في الميعاد فإن قاضي الأمور المستعجلة يحكم فيه بعد سماع أقوال الخصوم بحكم وقتي إما بتأييد قرار النيابة أو بتعديله أو بإلغائه .

والحكم الصادر يقبل الطعن فيه وفقاً للقواعد العامة، ولقاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ قرار النيابة المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم (٣) .

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ .

(٢) المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ م .

(٣) انظر : قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أ.د. نبيل إسماعيل عمر ص ٢٣٩ وما بعدها ، الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ٢٣١ وما بعدها ، قانون المرافعات ، أ.د. أحمد هندي ص ٥٢٧ وما بعدها .

الباب الرابع

إجراءات التقاضي

تمهيد وتقسيم :

بعد أن تحدثنا في نظام القضاء، وفي توزيع ولاية القضاء وفي الدعوى وأنواعها وشروط قبولها وجب أن نعرف كيف ترفع الدعوى أمام القضاء وكيف تسير إلى أن تنتهي الخصومة بحكم أو بغير حكم ثم ما قد يعقب صدور الحكم من طعن فيه .

والأصل أن يحصل اللجوء إلى القضاء بوسيلة الدعوى ، وقد يحصل بوسيلة العريضة .

ولذلك نقسم الحديث في هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو الآتي :

- الفصل الأول : التقاضي بوسيلة الدعوى .
- الفصل الثاني : التقاضي بوسيلة العريضة .
- الفصل الثالث : طرق الطعن في الأحكام .

الفصل الأول

التقاضي بوسيلة الدعوى

تمهيد وتقسيم :

يتلخص التقاضي بهذه الوسيلة في أن المدعي يعد صحيفة بدعواه ، ويقدمها لقلم كتاب المحكمة المختصة لقيدها وتحديد جلسة لنظرها ، ثم تعلن هذه الصحيفة للمدعي عليه ، وفي الميعاد المحدد قد يحضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة أو لا يحضران ، أو يحضر أحدهما دون الآخر ، ثم تنتظر المحكمة الدعوى ، وقد تقدم طلبات أخرى أو لا تقدم ، ويبيد المدعي عليه دفعه ، وقد يحدث عارض من العوارض قد يؤدي إلى انتهاء الخصومة بغير حكم ، والغالب أن تنتهي بحكم .

وعلى ذلك سوف نقسم الحديث في هذا الفصل إلى المباحث الآتية :

المبحث الأول : رفع الدعوى وإعلانها .

المبحث الثاني : حضور الخصوم وغيابهم .

المبحث الثالث : إجراءات الجلسات ونظامها .

المبحث الرابع : الطلبات والدفع .

المبحث الخامس : عوارض الخصومة .

المبحث السادس : الأحكام القضائية .

المبحث الأول

رفع الدعوى وإعلانها

وأوراق ومواعيد المرافعات

نتحدث في هذا الموضوع في رفع الدعوى وقيدتها ، وإعلانها ونظراً لارتباط الموضوع بمواعيد المرافعات فإننا نخصص المطلب الأول للحديث في رفع الدعوى وقيدتها ، والمطلب الثاني للإعلان ، والمطلب الثالث لمواعيد المرافعات .

المطلب الأول

رفع الدعوى وقيدتها

إعداد صحيفة الدعوى وبياناتها

يعد المدعي صحيفة الدعوى بنفسه أو يستعين على ذلك بغيره ، وتسمى هذه الصحيفة بصحيفة افتتاح الدعوى ، أو عريضة الدعوى ، أو ورقة التكليف بالحضور " ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :

- ١- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته.
 - ٢- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فأخر موطن كان له .
 - ٣- تاريخ تقديم الصحيفة .
 - ٤- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
 - ٥- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
 - ٦- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها " (١) .
- وتحرر صحيفة الدعوى من أصل وعدد من الصور بقدر عدد المدعي عليهم، فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب .

(١) المادة (٦٣) مرافعات .

ويجب أن يوقع محام على صحيفة الدعوى إلا إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمسين جنيهاً (١) .

قيد الصحيفة :

وفقاً لنص المادة (٦٥) مرافعات معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ يقوم قلم كتاب المحكمة التي تقدم إليها الصحيفة بقيدها إذا كانت مصحوبة بما يأتي :

- ١- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً ، أو ما يفيد إعفاء المدعي منها .
 - ٢- صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب .
 - ٣- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسؤولية المدعي وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
 - ٤- مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتغال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من هذه المذكرات أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم .
- وعلى قلم الكتاب أن يثبت تاريخ القيد في جميع الأحوال .

(١) وقد نصت المادة (٥٨) من قانون المحاماة على أنه " لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقيدين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير .

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقيدين أمامها .

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقيدين أمامها على الأقل .

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً ، ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة " .

وعلى ذلك إذا لم ترفق الأوراق سالفة الذكر بصحيفة الدعوى امتنع قلم كتاب المحكمة عن قيدها لعدم استيفاء المستندات والأوراق .

وقد كانت المادة (٦٥) مرافعات قبل تعديلها تنص على إلزام المدعي أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة .

" إلا أنه إزاء عدم تقرير جزاء على مخالفة ما أوجبه النص فقد غلب التراخي عل تنفيذ هذا الالتزام ، وكان هذا التراخي سبباً في تعطيل الفصل في كثير من القضايا حتى أنه بات مألوفاً أن المدعي هو الذي يطالب بالأجل تلو الأجل ومن أجل تقديم مستندات أوجب القانون تقديمها منذ اللحظة الأولى لرفعه لدعواه" (١) .

لذلك عدل المقنن هذه المادة وخول قلم الكتاب سلطة الامتناع عن قيد صحيفة الدعوى مالم يكن مرفقاً بها الأوراق سالفة الذكر .

ولكن إذا رأى قلم الكتاب عدم قيد الصحيفة ، لعدم استيفاء المستندات والأوراق المذكورة ، قام بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقفية ليفصل فيه فوراً ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب .

فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضي اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، ويرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام خطاباً مسجلاً بعلم الوصول مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى وصورة من المذكرة الشارحة أو الإقرار يخبره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى ، وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .

ولا شك أن إرسال خطاب من قلم الكتاب للمدعي عليه على النحو سالف الذكر يوفر ضمانه للتقاضي من شأنها أن تؤثر تأثيراً فعالاً على مسار كثير من الخصومات ، ذلك أنه كان يترتب عل عدم تحقق الإعلان الفعلي على يد المحضر

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ .

أن يفاجأ المدعي عليه بصدور حكم لم يعلم شيئاً عن الدعوى التي صدر فيها ، مما يحتم عليه أن يطعن في الحكم ويستشكل في تنفيذه ، مع قيام كل الاحتمالات لضياع حقوق لو علم صاحب الشأن بأي طريق أن هناك دعوى تتعلق بها لما ضاعت ؛ لأنه كان في استطاعته الدفاع عنها (١) .

ويجب على المدعي عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها ، أو يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صوراً منها تحت مسؤوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا اشتهرت صحيفتها (٢) .

وإذا كانت صحيفة الدعوى مصحوبة بالمستندات والأوراق المنصوص عليها في المادة ١/٦٥ مرافعات أو أمر قاضي الأمور الوقفية بالمحكمة بقيدها فإن قلم الكتاب يقيّد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك (٣) بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .

(١) راجع المذكرة الإيضاحية للقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ .

(٢) المادة (٦٥) مرافعات معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ .

(٣) بمعنى أن يعطي للدعوى رقماً مسلسلاً بالجدول العام للقضايا ويفرد لها ملفاً بالمحكمة ، ويثبت في السجل المخصص لهذا الغرض بالمحكمة ملخص للبيانات التي تتضمنها الدعوى من حيث أطرافها وموضوعها مع بيان تاريخ الجلسة ، وتقيّد هذه البيانات في السجل المذكور أمام الرقم المعطى للقضية والذي يعتبر رقماً ثابتاً لها يستدل به عليها في أي وقت فإن تغير وجب أن يثبت في السجل تغييره مع الإحالة إلى الرقم الجديد . (شرح قانون المرافعات ، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٤٣١) .

محاضرات في قانون المرافعات مقارنةً بالفقه الإسلامي

وفي تحديد ميعاد الجلسة يراعي قلم الكتاب المواعيد القانونية وظروف العمل بالمحكمة .

وميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ويجوز عند الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة .

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقفية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .

ويجب أن يضاف إلى ميعاد الحضور سواء كان ميعاداً عادياً أم مقصراً ميعاد مسافة (١) .

(١) تنص المادة (١٦) مرافعات على أنه " إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه ، والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما تزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزداد له يوم على الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود " . كما تنص المادة (١٧) مرافعات على أن " ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً .

ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقفية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها ، وما يجوز لقاضي الأمور الوقفية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج " .

بعد أن يثبت قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى في أصل الصحيفة وصورها ، ويقوم بقيدها في السجل المعد لذلك ، يقوم في اليوم التالي على الأكثر بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.

ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها للمدعي ، إذا طلب ذلك ، ليتولى بنفسه تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب .

وقد استثنى المقنن دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ من ذلك وجعل عبء تسليم صحف هاتين الدعويتين إلى قلم المحضرين على عاتق قلم الكتاب ، نظراً لأهمية هاتين الدعويتين .

المطلب الثاني

إعلان صحيفة الدعوى

إعلان الصحيفة :

يقوم قلم المحضرين " بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .

وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلاً لأي طعن .

ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه مالم يحضر بالجلسة " (١) .

وإذا لم يتم إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً فلا يترتب على ذلك بطلان إعلانها ، كما لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور ، ولكن هذا لا يخل بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد (١) .

ولكن إذا لم يتم إعلان الصحيفة بعد أن تم قيدها في قلم الكتاب ، وحتى لا يهمل المدعي دعواه بعد أن أنتجت أثرها في قطع التقادم وسريان الفوائد من وقت تقديمها لقلم الكتاب (٢) نصت المادة (٧٠) مرافعات على أنه " يجوز بناءً على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي " .

المقصود بالإعلان وأهميته :

الإعلان القضائي هو الوسيلة الرسمية لإعلام الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات (٣) .

وترجع أهمية الإعلان إلى أن كل إجراء يتخذه أحد الخصوم يجب أن يكون في مواجهة الطرف الآخر ، ويجب إخبار كل خصم بما يجريه الخصم الآخر ، حتى يتمكن من الرد على خصمه حماية لمصلحته ، ولا يؤخذ خصم على غرة وهو أمام القضاء .

والإعلان القضائي هو الوسيلة الرسمية لإعلام الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات ، فهو يحقق مبدأ " حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم " .

ومن هنا اهتم المقتن بإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه ؛ لأن الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان الصحيح .

(١) المادة (٦٩) مرافعات .

(٢) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ٥٣٧ .

(٣) انظر : تعريفات أخرى للإعلان ، في " نظرات في طرق تسليم الإعلان " د. عاشور السيد مبروك ص ٩ وما بعدها .

أحكام عامة في الإعلانات :

أولاً : أسند المقتن عملية إعلان الأوراق القضائية إلي المحضرين؛ حيث تنص المادة (٦) مرافعات على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناءً على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا مالم ينص القانون على غير ذلك، ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم " .

وعلى ذلك لا ينتج الإعلان أثره إلا إذا تم على يد محضر — كقاعدة — وفي حالات استثنائية يجوز أن يحصل الإعلان بخطاب مسجل بعلم الوصول ، كما هو الحال في المادة (٢٠٢) مرافعات (١) .

ثانياً : " لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقفية " (المادة (٧) مرافعات معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩) وقد كان النص قبل تعديله يمنع إجراء الإعلان أو القيام بالتنفيذ بعد الساعة الخامسة مساءً ، وكان ذلك يؤدي إلى عرقلة تسليم الإعلان أو القيام بالتنفيذ ، نظراً " لما لحق الحياة العملية والاجتماعية من تطور إجراءاته .

ونظراً ؛ لأن النص لم يحدد وسيلة إعلان القرار فقد ذهب بعض الشراح إلى وجوب إعمال المادة السادسة من قانون المرافعات " كل إعلان أو تنفيذ يكون

(١) ونطها: " على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك مالم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف " .

بواسطة المحضرين بناءً على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ... " ومن ثم يجب أن يكون إعلان قرار النيابة عن طريق إعلان على يد محضر " . فضلاً عن أن الإعلان على يد محضر يوفر ضماناً هامة للمعلن إليه لا يوفرها الطريق الإداري وهو الإعلان عن طريق النيابة .

ويرى بعض الشراح — بحق — أن الإعلان عن طريق قلم المحضرين وإن كان يوفر ضماناً للمعلن إليه إلا أنه يعترضه الكثير من القصور والتلاعب وكثيراً ما ينتهي بتسليم الإعلان لجهة الإدارة ، فضلاً عن أنه لا يحقق تيسير وتبسيط إجراءات إعلان قرارات النيابة ، ومن ثم يجب إعلان قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة بالطريق الإداري (١) .

ثالثاً : الأصل أن المحضر ملزم بإجراء الإعلان ، ومع هذا يجوز له أن يتمتع عن القيام به إذا تراءى له وجه للامتناع ، كما لو كان الإعلان خالياً من البيانات أو كان الإعلان يخرج عن نطاق اختصاصه المكاني أو اشتمل الإعلان على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو شاب البيانات غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إجراء الإعلان .

وفي هذه الحالات وأمثالها يجب على المحضر أن يعرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقفية ، ليأمر بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير بالحذف أو بالإضافة ، وللطالب أن يتظلم من الأمر الذي أصدره قاضي الأمور الوقفية ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع المحضر والطالب (٢) .

رابعاً : " يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية :

(١) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ٢٣٥ .

(٢) المادة (٨) مرافعات معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ .

- ١ - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
- ٢ - اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره .
- ٣ - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
- ٤ - اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوماً وقت الإعلان فأخر موطن كان له .
- ٥ - اسم وصفة من سلمت إليه الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام .
- ٦ - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة " (١) .

خامساً : قد يوجب القانون عل الخصم أن يعين موطناً مختاراً له في
البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها ، ويفيد هذا الموطن المختار في تسليم الأوراق التي تعلن لهذا الشخص كما في المادتين (٦٣ ، ٢٠٣) مرافعات .
فإن لم يعين الخصم موطناً مختاراً له على النحو الذي تطلبه القانون أو كانت بياناته ناقصة أو غير صحيحة جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة .

تسليم الإعلان :

نظم القانون أحكام تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في المواد (١٠ - ١٤) من قانون المرافعات عل النحو الآتي :

أولاً : تسليم الإعلان إلى المعلن شخصياً :

الأصل أن يتم تسليم الإعلان إلى الشخص الموجه إليه الإعلان بنفسه ، ومن ثم إذا قابل المحضر المعلن إليه في المحكمة أو في الطريق وكان يعرفه وسلمه

الإعلان ، فإن الإعلان ينتج أثره ولا يجوز للمعلن إليه أن يدفع ببطلان الإعلان تأسيساً على أنه لم يتسلمه في موطنه .

وإذا كان المحضر لا يعرف المعلن إليه ، أو يعرفه وقابله في الطريق وامتنع عن الاستلام ، فيجب على المحضر الانتقال إلى موطن المعلن إليه ليعلنه في موطنه ، ويثبت في ورقة الإعلان ما يفيد انتقاله إلى موطن المعلن إليه .

وإذا كان المعلن إليه حاضراً وجب تسليم صورة الإعلان إليه شخصياً فلا يجوز تسليم صورة الإعلان لغير المعلن إليه إلا إذا كان غائباً ويبطل الإعلان إذا سلمت صورته إلى قريب أو خادم مع وجود المعلن إليه (١) .

وإذا كان المعلن إليه حاضراً وامتنع عن الاستلام فإن المحضر يثبت امتناع المعلن إليه عن الاستلام وسبب هذا الامتناع فإن رفض المعلن إليه إبداء الأسباب أثبت المحضر ذلك ، ولا " يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل ؛ لأن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول هذا الامتناع ، بل يجب على المحضر أياً كان سبب الامتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة (١١) من قانون المرافعات ، وعليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة على النحو الذي سيرد ذكره .

ثانياً : تسليم الإعلان في الموطن المختار :

يعتبر مكتب المحامي الموكل عن الخصم محلاً مختاراً له في درجة التقاضي الموكل فيها ، و " بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها " (٢) .

(١) شرح قانون المرافعات ، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جمعي — يرحه الله — ص ٤٣٣ ، ٤٣٤ .

(٢) المادة ١/٧٤ مرافعات ، وانظر : نقض مدني جلسة ١٠/٥/١٩٧٧ ، الطعن رقم ٧٢٤ لسنة ٤٢ ق .

ثالثاً : تسليم الإعلان في الموطن الأصل للمعلن إليه :

إذا توجه المحضر إلى موطن المعلن إليه فلم يجده ، وجب على المحضر أن يثبت غياب المعلن إليه ، ثم يسلم صورة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار . ويجوز تسليم الصورة لمن يقرر أنه وكيل المعلن إليه أو يعمل في خدمته ولو لم يكن ساكناً معه ؛ لأن علاقة التبعية فيها ضمان كاف لوصول الورقة إلى المعلن إليه ، بخلاف الأزواج والأقارب والأصهار حيث يشترط أن يكون من الساكنين مع المعلن إليه ؛ لأن الإقامة هي الضمان لوصول صورة الإعلان للمعلن إليه .

ولا يلزم أن تكون " إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية ومستمرة بل يكفي أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان وأن يكون ظاهر الحال الذي يشاهده المحضر في هذا الوقت دالاً على ذلك " (١) .

ويقصد بمن " يعمل في خدمة الشخص تابعه الذي يعمل لحسابه بأجر أياً كان نوع العمل الذي يؤديه إذ العبرة بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والمعلن إليه لا بنوع الخدمة التي يؤديها التابع " (٢) .

وعلى ذلك فلا يجوز تسليم أوراق المحضرين إلى الأقارب غير الساكنين مع المعلن إليه ، كما لا يجوز تسليمها إلى الساكنين معه من غير أقاربه ، ولا يجوز تسليمها للجيران من باب الأول .

والمحضر ، وعلى ما جر به قضاء محكمة النقض (٣) ، غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ، فليس عليه " أن يتحقق من صفة من يتقدم إليه في

(١) نقض مدني جلسة ١٩٦٨/٢/١ طعن رقم ٢٨٢ لسنة ٣٤ ق .

(٢) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات .

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/١/١٤ ، طعن رقم ٢٧٠ لسنة ٤٢ ق ، جلسة ١٩٧٧/٢/٩ ، طعن رقم ٧١٦ لسنة ٤٢ ق ، جلسة ١٩٧٧/١/١٢ ، طعن رقم ٣٨ لسنة ٤٥ ق .

موطن المعلن إليه لتسليم الورقة ، ومقتضى ذلك أن الإعلان يصح لوكيل الشخص ولو تعلقت الورقة بموضوع يجاوز نطاق الوكالة " (١) .
ومع هذا فمن الأفضل أن يتحقق المحضر من صفة من يخاطبه ومدى جواز تسليم الورقة إليه .

رابعاً : تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة :

وفقاً لنص المادة (١١) مرافعات معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ ، إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المعلن إليه أو وجد شخصاً لا يصح تسليم الإعلان إليه طبقاً لأحكام المادة (١٠) مرافعات ، أو امتنع من يصح استلامه عن الاستلام أو التوقيع على الأصل بالاستلام ، وجب على المحضر أن يسلم الورقة في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، وذلك بعد توقيع من سلم إليه الإعلان من هؤلاء بالاستلام .
" وقصد بالنص على تسليم الورقة لجهة الإدارة في ذات اليوم ألا تتراخى إجراءات الإعلان وآثاره لسبب لا دخل لطالب الإعلان فيه ، ويعد من قبيل الامتناع الذي يوجب على المحضر تسليم الورقة لجهة الإدارة امتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه من ذكر اسمه أو صفته (٢) التي تجيز له تسلم الصورة ؛ لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذي رسمه القانون " (٣) .

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة ، ويخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة .

(١) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بصدد المادة ١١ منه .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٩/٥/٣١ طعن رقم ٩٣٤ لسنة ٤٦ ق .

(٣) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بصدد المادة (١١) .

ويجب على المحضر أن يثبت في أصل الإعلان وصورتيه أنه توجه إلى موطن المعلن إليه ولم يجد أحداً أو وجد من لا يصح تسليمه أو من امتنع عن الاستلام أو التوقيع وأنه توجه إلى جهة الإدارة القسم أو المركز أو مقر العمدة أو موطن شيخ البلد وسلمه الورقة حسب الأحوال وأنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه وأرفق به صورة الإعلان (١) .

و " من المقرر أن ما يثبتته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير " (٢) .

وقد حسمت المادة ٣/١١ مرافعات الخلاف حول الوقت الذي ينتج فيه الإعلان آثاره ، حيث نصت على أن " يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً " لا من يوم وصول الكتاب المسجل إلى المعلن إليه ، ولا من يوم تسلمه الإعلان من جهة الإدارة ، ولا عبرة بتاريخ قيد الإعلان بدفانتر القسم (٣) .

ويراعى أنه لا يجوز تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة إلا بعد التحقق من عدم وجود الشخص المراد إعلانه هو وغيره ممن يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو امتنع من وجده عن الاستلام ، ولذلك أوجبت المادة (٣/١١) على المحضر أن يبين في أصل ورقة الإعلان وصورتها بالتفصيل في حينه كل ما يتخذ من خطوات سابقة على تسليم الصورة إلى جهة الإدارة ويترتب على إغفال تلك الإجراءات بطلان الإعلان (٤) .

(١) نقض دني جلسة ١٩٧١/٤/١٥ طعن رقم ٤٤٣ لسنة ٤٣٦ ق .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/٥/٢٩ طعن رقم ٩٤٦ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ١٩٧٨/٣/٢٠ طعن رقم ٤٩٦ لسنة ٤٤٤ ق .

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٧٩/٣/٢٩ طعن رقم ٩٨٢ لسنة ٤٦ ق .

(٤) نقض مدني جلسة ١٩٦١/٥/١٨ طعن رقم ٥٢١ لسنة ٢٦ ق ، جلسة ١٩٦٢/١١/٢٢ طعن رقم ٢٠ لسنة ٢٧ ق .

خامساً : تسليم الأوراق للنيابة العامة :

تسلم الأوراق إلى النيابة العامة في الحالات الآتية :

١- إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج.

يجرى إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج بتسليم الأوراق للنيابة العامة وتتولى النيابة العامة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضاً في هذه الحالة — وبشرط المعاملة بالمثل — تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه .

و ضمناً لوصول خبر الإعلان إلى المعلن إليه ، أوجب القانون على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتاباً موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى، ويخبره بأن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة (١) ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة ، أو التوقيع على أصلها بالاستلام (٢) . ويراعى أن المادة ٩/١٣ مرافعات إنما تنظم قاعدة إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج وليس لهم موطن في مصر .

أما " من يكون مقيماً خارج القطر إذا أعلن ... في محله الأصلي كان إعلاناً صحيحاً ، فالإعلان الحاصل له في المحل الذي له فيه أملاك ومقر عمل ووكيل يقوم على أعماله ويمثله في دعاويه ينتج آثاره القانونية، ولو كان محله في الخارج

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧٢/٥/٩ طعن رقم ٣٢٣ لسنة ٣٧ ق ، جلسة ١٩٧١/١١/٣٠

طعن رقم ٤٧٥ لسنة ٣٦ ق .

(٢) المادة ٩/١٣ مرافعات .

معلوماً، وهذا الإعلان يتم بتسليم صورته لوكيله شخصياً، أو لمن يتسلمها وفقاً للقانون في حالة غيابه أو لشيخ الناحية أو للقسم إذا لم يوجد من هؤلاء من تسلم إليه " (١) .

٢- إعلان الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم.

وفقاً لنص المادة ١٠/١٣ مرافعات ، إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم ، وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنياية

وعلى ذلك يعلن الأشخاص الذين ليس لهم موطن أصلي ، أو موطن مختار ، أو موطن خاص في مصر أو في الخارج بتسليم صورة الإعلان للنياية العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته .

وقد أجاز القانون ذلك على " سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم لكل باحث مُجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي .

إلا أن تقدير كفاية التحريات التي تسيق الإعلان للنياية أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدها ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقبه عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة" (٢) .

(١) نقض مدني جلسة ١٩٣٧/٤/١٥ طعن رقم ٥٤ لسنة ٥٦ ق .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٣/٦/١٢ الطعن رقم ٢٩ ، ٣١ لسنة ٣٨ ق ، جلسة

١٩٧٣/١١/٢٩ طعن رقم ٣٦٢ لسنة ٣٨ ق ، جلسة ١٩٧٩/١٢/٢٤ طعن رقم ٤٧٠

لسنة ٤٨ ق ، جلسة ١٩٧٠/٦/٣٠ طعن رقم ٣١٦ لسنة ٤٠ ق ، جلسة ١٩٧٠/٤/٣٠

طعن رقم ٢٦ لسنة ٣٦ ق .

و" يتعين أن تشتمل ورقة الإعلان في مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج ، حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه وتسليمه الصورة ، ولتراقب المحكمة مدى ما استنفذ من جهد في سبيل التحري عن موطنه وذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين في مصر وأولئك الذين غادروها للخارج" (١) .

ويجري العمل على أن يقوم المحضر بتسليم الإعلان إلى النيابة العامة الواقع في دائرتها آخر موطن معلوم للمعلن إليه ، ومع هذا يجوز تسليمها لأي نيابة غيرها طبقاً لعموم النص .

وينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه للنيابة العامة حتى ولو لم تهتد النيابة إلى معرفة موطن المراد إعلانه (٢) .

٣- إعلان أفراد القوات المسلحة :

في " ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة " (٣) .

المقصود بأفراد القوات المسلحة الضباط العاملون والاحتياط ، والجنود الدائمون والمؤقتون ، وجميع العاملين بوزارة الدفاع ، وهؤلاء يعلنون عن طريق النيابة العامة ، حيث يقوم المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة وهي تتولى بدورها تسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، وهي تقوم بتسليم الصورة إلى المعلن إليه .

وعلى ذلك فـ " إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين يكون باستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة صورة الإعلان ، ويكون تسليم هذه

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧٠/٢/١٠ طعن رقم ٥٢٦ لسنة ٣٥ ق .

(٢) إعلان الأوراق القضائية ، المستشار محمد أحمد عابدين ص ١٤٣ ، ١٤٤ .

(٣) المادة ٦/١٣ مرافعات .

الصورة لها بواسطة النيابة العامة التي تعتبر في هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً " (١) .

ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان ولكن بشرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم العسكرية وإلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة (٢) .

ولذلك حكمت محكمة النقض بأنه " لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن بطلان إعلانه بالاستئناف بوصفه ضابطاً بالقوات المسلحة ورد عليه بأسباب لا خطأ فيها قانوناً بقوله [أما القول بأنه نقيب احتياطي بالقوات المسلحة فهي صفة لم تذكر في أية ورقة من أوراق الدعوى فكان كل من المستأنفين يجهل هذه الصفة ، وهو لم يذكر صفته في دعواه المدنية التي رفعها ...] لما كان ذلك فإن الحكم إذا اعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعي " (٣) .

والعبرة بصفة المعلن إليه وقت الإعلان (٤) ومن ثم إذا زالت صفته العسكرية أعلن وفقاً للقواعد .

وينتج الإعلان أثره القانوني باستلام الإدارة القضائية المختصة صورة الإعلان (٥) .

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧٧/٢/٢٤ طعن رقم ٢٥ لسنة ٤١ ق .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/٢/١٥ طعن رقم ٨٦٧ لسنة ٤٤ ق .

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٧٢/٦/١٢ الطعن رقم ٢٩ ، ٣١ لسنة ٣٨ ق .

(٤) نقض مدني جلسة ١٩٨٤/٢/٩ الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٤٩ ق ، ذكره المستشار محمد أحمد عابدين في إعلان الأوراق القضائية ص ١٢٥ .

(٥) نقض مدني جلسة ١٩٧٧/٢/٢٤ الطعن رقم ٢٥ لسنة ٤١ ق .

٤- حالات أخرى :

نصت الفقرة الأخيرة من المادة (١٣) مرافعات على أنه " وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة " .
والمقصود بجميع الحالات حالات الإعلانات إلى الشخص الاعتباري ،
وأفراد القوات المسلحة ، والمسجونين والعاملين بالسفن التجارية .
فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه الورقة أو امتنع عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام أثبت المحضر ذلك على أصل الإعلان وصورته وقام بتسليم الصورة للنيابة العامة، وينتج الإعلان أثره القانوني من وقت تسليمه للنيابة .

سادساً : إعلان السجناء :

فيما يتعلق بالمسجونين يسلم الإعلان لمأمور السجن ، وبناءً على هذا يقوم المحضر بتسليم الإعلان الموجه لشخص السجين لمأمور السجن.
وينتج الإعلان أثره من وقت تسليم الصورة لمأمور السجن حتى ولو لم يسلمها للسجين .

وإذا لم يجد المحضر المأمور أو امتنع المأمور عن الاستلام أو التوقيع به أثبت المحضر ذلك وسلم الصورة للنيابة على النحو سالف الذكر.

سابعاً : إعلان بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها :

في " ما يتعلق ببجارة السفن التجارية أو العاملين فيها يسلم للربان " (١) .
وبناءً على ذلك يسلم المحضر صورة الإعلان الموجه لأحد بحارة السفينة التجارية أو العاملين فيها لربان السفينة ويسري هذا على السفن الراسية بالمواني المصرية سواء كانت سفناً مصرية أم أجنبية (٢) .

(١) المادة ٨/١٣ مرافعات .

(٢) الوسيط ، أ.د. فتحي والي ص ٣٨٩ .

أما إذا كانت السفينة تجوب البحار فيتم تسليم الإعلان إلى الوكيل الملاحي للسفينة في مصر باعتباره موطناً لمالك السفينة (١) .
والحكمة في ذلك ، أن هؤلاء البحارة يقضون أكثر وقتهم في السفن ، ولا يتواجدون في مواطنهم إلا قليلاً ، ومن ثم فلا جدوى من إعلانهم في مواطنهم .
ولكن لا يسري هذا النص على العسكريين العاملين بالأسطول البحري ، وإنما تسلم إعلاناتهم كما تسلم الإعلانات لسائر أفراد القوات المسلحة .
وينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه لربان السفينة حتى ولو لم يسلم صورته للشخص المطلوب إعلانة .

إعلان الشخص الاعتباري :

هذا، ويتم تسليم صحف الدعاوى الطعون والأحكام القضائية إلى هيئة قضايا الدولة، أو إلى فروعها بالأقاليم، وذلك وفقاً للاختصاص المحلي، في حالة إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة.
ولا يعتد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام لهؤلاء الأشخاص إلا لهيئة قضايا الدولة، أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها (٢).
وإذا تم تسليم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام لغير هيئة قضايا الدولة، فإنها تقع باطلة وفقاً لنص المادة (١٩) مرافعات (٣) .
وينتج الإعلان أثره القانوني بمجرد تسليمه إلى إدارة هيئة قضايا الدولة المختصة ، دون ما حاجة إلى إخطار الوزارة أو المصلحة المقصود إعلانها (٤) .

(١) إعلان الأوراق القضائية أ/ محمد أحمد عابدين ص ١٧٦ .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٥٩/٦/٢٥ طعن رقم ٢١٥ لسنة ٢٥ ق .

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٧٥/١٢/٤ طعن رقم ٣١٩ لسنة ٢٥ ق .

(٤) نقض مدني جلسة ١٩٧٥/١٢/٤ طعن رقم ٧٤٣ لسنة ٤١ ق .

أما الأوراق الأخرى، كالإنذار أو التبليغ فإن صورة الإعلان يتم تسليمها للوزراء أو المحافظين أو رؤساء المدن أو القرى أو مديري المصالح المختصة أو لمن يقوم مقامهم ، ويتم التسليم في مقر عملهم .

و " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة " (١) .

٢- الهيئات العامة :

وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها .

وتسلم لرئيس مجلس الإدارة المختص أو من يقوم مقامه (٢) والعبرة بمقر مركز إدارة الهيئة أو المؤسسة الرئيسي ولا عبرة بمركز الإدارة القانونية لها (٣) . وعلى ذلك فلا يجوز تسليم صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العامة إلى هيئة قضايا الدولة ، إلا إذا أحالت الهيئة العامة منازعات معينة إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر ، فإنه يجوز تسليم الإعلان لهيئة قضايا الدولة في هذه الحالة باعتبارها موطناً مختاراً للهيئة العامة (٤) .

وإذا امتنع رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو من يقوم مقامه عن الاستلام يتم التسليم للنيابة العامة على ما سبق ذكره .

(١) الفقرة الأخيرة من المادة (١٣) مرافعات .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/١١/٢٨ طعن رقم ٩٢٢ لسنة ٤٥ ق .

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٧٧/٢/١٥ طعن رقم ٦١ لسنة ٤٢ ق .

(٤) إعلان الأوراق القضائية ، أ/ محمد أحمد عابدين ص ١٥١ ، ١٥٢ .

الأشخاص المعنوية الخاصة :

نفرق هنا بين ثلاث حالات :

(أ) الشركات التجارية :

في " ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه " .
وعلى ذلك إذا كان للشركة التجارية مركز إدارة تسلم صورة الورقة في مركز الإدارة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة ، أو للمدير أو لمن ينوب عنهم .

أما إذا لم يكن للشركة التجارية مركز تسلم صورة الورقة لواحد من المذكورين لشخصه أو في موطنه، وعند تسليم الصورة في موطن واحد من هؤلاء يجوز تسليمها عند غيابه لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، ولا يلزم المحضر بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ما دام موجوداً في مركز إدارة الشركة (١) .

(ب) الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر

الأشخاص الاعتبارية

في " ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه ، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه " (٢) .

(١) نقض مدني جلسة ١٧/٢/١٩٦٦ طعن رقم ٣١٩ لسنة ٣٠ ق .

(٢) المادة ٤/١٣ مرافعات .

وبناءً على ذلك إذا كان للشركة المدنية ومن في حكمها مركز إدارة تسلم صورة الورقة في هذا المركز لمن ينوب عن الشركة أو الجمعية أو ما في حكمها وفقاً لعقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه.

أما إذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عن الشركة المدنية أو الجمعية لشخصه أو في موطنه وإذا لم يكن موجوداً سلمت الورقة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٠) مرافعات .

(ج) الشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل بمصر .

بالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في مصر تسلم صورة الورقة إلى مدير الفرع أو الوكيل (١) حيث يعتبر مقر الفرع أو الوكيل موطناً لهذه الشركة " إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل ، أما إذا كان الإعلان موجهاً من الوكيل إلى الشركة الأجنبية فإنه يتعين إعلانها في موطنها الأصلي احتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التي تعد من أهم تطبيقات احترام حقوق الدفاع ... " (٢) .

على أن تسليم صورة الإعلان إلى فرع أو وكيل الشركة الأجنبية في مصر " لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج ، وإنما قصد به مجرد التيسير عليه في إتمام الإعلان والتعجيل بإجرائه .. " (٣) .

" وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة " (٤) .

(١) المادة ٥/١٣ مرافعات .

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٨١/٦/٢٢ طعن رقم ١٥٨ لسنة ٤٨ ق ، أورده المستشار محمد أحمد عابدين في إعلان الأوراق القضائية ص ١٦٨ .

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٧٠/١٢/١٠ طعن رقم ١٤٥ لسنة ٣٦ ق .

(٤) الفقرة الأخيرة من المادة (١٣) مرافعات .

المطلب الثالث

مواعيد المرافعات

المقصود بمواعيد المرافعات :

يقصد بمواعيد المرافعات الآجال والمدد التي يحددها قانون المرافعات لاتخاذ الإجراءات المقررة فيها ، ذلك أن قانون المرافعات يحدد آجالاً معينة يتخذ فيها الإجراء حتى ينتج أثره ، وحتى يكون أطراف النزاع على علم مسبق بهذه المواعيد ، ومن ثم يراعونها عند اتخاذ الإجراءات ؛ محافظة على حقوقهم .

أنواع المواعيد :

تتنوع مواعيد المرافعات على النحو الآتي :

(أ) الميعاد الكامل :

ويقصد به الميعاد الذي يجب أن ينقضي بتمامه ثم يتخذ الإجراء بعد انقضائه، ومن أمثلته مواعيد الحضور وهي خمسة عشر يوماً للحضور أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية ، وثمانية أيام للحضور أمام المحكمة الجزئية ، وأربع وعشرين ساعة للحضور أمام المحاكم المستعجلة ، بمعنى أنه لا يجوز تحديد جلسة أمام محكمة من هذه المحاكم إلا بعد انقضاء هذه المواعيد بتمامها ، ويحسب الميعاد من اليوم التالي لحصول الإعلان ، فإذا تم الإعلان يوم ١٠/١٠/١٩٩٩ م فلا تحدد الجلسة قبل يوم ١٩/١٠/١٩٩٩ م إذا كانت الدعوى جزئية ، فلا بد من مضي مدة ثمانية أيام كاملة ثم يتخذ الإجراء بعد ذلك وهكذا.

(ب) الميعاد الناقص :

ويقصد به الميعاد الذي يجب أن يتخذ الإجراء خلاله وإذا انقضى الميعاد سقط الحق في اتخاذ الإجراء ، ومن أمثلته المواعيد التي يحددها القانون للطعن في الأحكام أو للنظم من الأوامر ، فإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً في العادة من تاريخ صدور الحكم ، فيجب أن يرفع الاستئناف قبل مضي اليوم الأخير ، وهذا معنى كون الميعاد ناقصاً ؛ لأنه إذا تم الميعاد ولم يرفع الاستئناف أصبح الحكم نهائياً ولا يجوز استئنافه في اليوم الواحد والأربعين .

(ث) الميعاد المرتد :

ويقصد به الميعاد الذي يجب أن يتخذ الإجراء قبله ، ومن أمثلته الاعتراض على قائمة شروط البيع يجب أن يتم قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام ، فيتعين أن نعرف ميعاد الجلسة ولنفرض أنه ١٩٩٩/٩/٢٥ م، ثم نرجع إلى الوراء ثلاثة أيام كاملة وهي ٢٤، ٢٣، ٢٢ ويكون آخر ميعاد لتقديم الاعتراضات هو يوم ١٩٩٩/٩/٢١ م .

كيفية حساب المواعيد :

تنص المادة (١٥) مرافعات عل أنه: " إذا عيّن القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء .

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم .

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي مالم ينص القانون على غير ذلك " .

وبناءً على ذلك يبدأ حساب الميعاد من اليوم التالي ، ولا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد(١) ، مثلاً ميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثمانية أيام من تاريخ حصول الإعلان وحصل الإعلان يوم ١٩٩٩/٣/١ فيبدأ حساب مدة الثمانية أيام من اليوم التالي لحصول الإعلان ولا

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/٦/٢٨ طعن رقم ٢٢٣ لسنة ٤٥ ق .

يحسب من المدة اليوم الذي حصل فيه الإعلان ، فيحسب الميعاد هنا من يوم ٩٩٩/٣/٢ ويجوز تحديد الجلسة هنا اعتباراً من يوم ٩٩٩/٣/١٠ .

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات فإنه يحسب ابتداءً من الساعة التالية ، ولا تحسب الساعة التي حصل فيها الإعلان ، مثلاً لو كانت الدعوى مستعجلة وأنقص الميعاد فيها إلى ساعة واحدة ، وحصل الإعلان في الساعة الواحد والربع فلا يحدد ميعاد الجلسة قبل الساعة الثالثة .

وإذا " كان الأجل محدداً بالشهور أو السنين فيبدأ حساب المدة من اليوم التالي لاتخاذ الإجراء على أن يتم الشهر أو السنة في اليوم المقابل من الشهر التالي أو السنة التالية ، فإذا كانت الدعوى قد أوقفت لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الحكم الذي صدر في ٩٩٩/٣/١ فيحسب هذا الأجل اعتباراً من يوم ٩٩٩/٣/٢ وينتهي يوم ٩٩٩/٦/٢ .

ولا عبرة بكون الشهر ثلاثين يوماً أو أكثر أو أقل ولا بكون السنة بسيطة أو كبيسة وتحسب بالتقويم الشمسي مالم ينص القانون على غير ذلك .

امتداد المواعيد :

تمتد مواعيد المرافعات إذا توافرت حالة مما يأتي :

١- إذا كان مقر المحكمة التي يتخذ الإجراء أمامها بعيداً عن موطن الشخص المطلوب اتخاذ الإجراء منه أو ضده .

وفي هذه الحالة تضاف إلى المواعيد العادية مدة تقابل المسافة بين المحكمة وبين إقامة الشخص ، فلو كان شخص يقيم بمدينة سوهاج وأراد أن يطعن بالنقض في حكم صدر ضده ، فيضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض مدة تقابل المسافة بين سوهاج والقاهرة مقر محكمة النقض، وتحسب هذه المدة بالطريقة المبينة في المادتين (١٦ ، ١٧) مرافعات .

وعلى ذلك إذا كان ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً ، فإن هذا الميعاد يزداد مقابل المسافة بما يعادل يوماً لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه ، وما تزيد من الكسور

على الثلاثين كيلو متراً يزداد له يوم على الميعاد ، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ، ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً لمن يقع موطنه في مناطق الحدود نظراً لصعوبة المواصلات وقتلتها .

ويكون ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في خارج مصر ستين يوماً .

وتطبيقاً لذلك فإن من يقيم بسوهاج مثلاً وهي تبعد عن القاهرة بمقدار ٤٧٥ كيلو متراً تقريباً تزداد له أربعة أيام ميعاد مسافة للطعن بالنقض ولمن يقيم في حلايب وشلاتين (على حدود مصر الجنوبية) يزداد له خمسة عشر يوماً ميعاد مسافة للطعن بالنقض ، ولمن يقيم في إيطاليا يزداد له ستين يوماً ميعاد مسافة .

ولكن " يجوز بأمر من قاضي الأمور الوقفية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها ، إنما يجوز لقاضي الأمور الوقفية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمدّ المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج " (١) .

٢- إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية وودلك إعمالاً لنص المادة (١٨) مرافعات التي نصت على أنه : " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها " .

وعلى ذلك تمتد مواعيد المرافعات إذا صادف آخرها يوم عطلة وتمتد هذه المواعيد إلى أول يوم عمل ، وإذا استغرقت العطلة عشرة أيام امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ولمدة يوم واحد بخلاف ما إذا وقعت العطلة في أول الميعاد أو خلاله فلا يمتد الميعاد بسببها مهما طال ما دامت تنتهي العطلة قبل انتهاء الميعاد ، لكن إذا انتهى الميعاد أثناء العطلة امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .

ويسري امتداد الميعاد إذا صادف آخره يوم عطلة سواء كان مقدراً بالأيام أم بالشهور أم بالسنين أم بالساعات ، فلو كان الميعاد محدداً بالساعات وينتهي الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة — وهو يوم عطلة — امتد الميعاد إلى الساعة العاشرة من يوم السبت (١) .

وسواء كان الميعاد كاملاً أم ناقصاً ، أما إذا كان الميعاد مرتداً أي يجب اتخاذ الإجراء قبله ، فلا يمتد بسبب العطلة الرسمية ؛ لأن الامتداد يكون في نهاية الميعاد ، وإذا قلنا بامتداد هذا الميعاد فهو يمتد من بدايته ؛ لأن نهايته محددة سلفاً ، فلو كانت الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات محددة يوم ٩٩/٢/٢٦ وتقدم الاعتراضات إلى ما قبل الجلسة بثلاثة أيام فنعود إلى الوراء ٢٥ ، ٢٤ ، ٢٣ ولو صادف يوم ٢٢ هو آخر يوم لتقديم الاعتراضات عطلة لا يمتد الميعاد ويقدم الاعتراض يوم ٢٣ ؛ لأنه يؤدي إلى اقتطاع يوم من الأيام الثلاثة التي يجب أن تسبق جلسة نظر الاعتراضات ويتبقى يومان فقط ويؤدي ذلك إلى الاصطدام بما قرره المادة (١/٤٢٢) مرافعات من أنه يجب إبداء الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة نظر الاعتراضات بثلاثة أيام .

ولا يقال إن الميعاد يرتد هنا بالرجوع إلى الوراء " أي أن الميعاد يمتد إلى اليوم الذي قبله " (٢) ، ففي المثال المذكور يمتد الميعاد إلى الوراء أي إلى يوم ٢١ ومعنى هذا أن الميعاد لم يمتد وإنما انحسر وضاق (٣) .

(١) الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ٤٨٤ .

(٢) شرح قانون المرافعات الجديد ، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٤٩٧ .

(٣) انظر : الوسيط ، أ.د. فتحي والي ص ٣٦٦ هـ — ٣ ، الوسيط ، أ.د. أحمد السيد صاوي ص ٤٨٤ ، وانظر : عكس هذا في مبادئ القضاء المدني ، أ.د. وجدي راغب ص ٣٢٥ هـ ٦٠ ، مبادئ المرافعات ، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٤٨٣ .

سلطة القضاء في تعديل المواعيد : الأصل أنه لا يجوز للقاضي أن يعدّل في المواعيد زيادة أو نقصاً مراعاة لحقوق الخصوم .
ومع هذا أجاز القانون للقاضي في حالات معينة منصوص عليها أن يعدّل في المواعيد على النحو التالي :

١ - إنقاص المواعيد :

أجاز القانون للقاضي أن ينقص بعض المواعيد من ذلك ما ذكرته المادة (١٧) مرافعات من أن " ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً ، ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقفية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة " .

وما نصت عليه المادة (٦٦) مرافعات من أن " ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ، وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالي .

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقفية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى " .

٢ - مدّ المواعيد :

يجوز لقاضي الأمور الوقفية أو للمحكمة عند نظر الدعوى المقامة على شخص موطنه بالخارج وأعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها ، نظراً ؛ لأن هذا الشخص لن يتمتع بميعاد المسافة لمن موطنه بالخارج ، أن يأمر بمدّ المواعيد العادية ، أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج (١) .

(١) المادة ٣/١٧ مرافعات .

المبحث الثاني

حضور الخصوم وغيابهم

نتحدث عن حضور الخصوم في المطلب الأول وعن غيابهم في المطلب الثاني .

المطلب الأول

حضور الخصوم

بعد أن يعلن المدعي صحيفة الدعوى للمدعي عليه يجب على الخصوم أن يحضروا في اليوم والساعة المحددين بالصحيفة ليبيدي المدعي طلباته ، ويبيدي المدعي عليه ما لديه من دفوع .

ومع هذا فإن الخصوم لا يجبرون على الحضور في القضاء المدني إلا إذا أمرت المحكمة بحضور الخصم لاستجوابه ، سواء أمرت بذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب خصمه ، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار (١) .

والأصل أن يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى ، ويجوز أن يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة (٢) .

ولكن " لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ، ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً " (٣) .

(١) المادة (١٠٦) من قانون الإثبات .

(٢) المادة (٧٢) مرافعات .

(٣) المادة ١/٨١ مرافعات .

والحكمة في ذلك أن يظل القضاة وأعوانهم بعيدين عن معترك الخصومات ، ولا يتدخلوا فيها ضماناً لاستقلال القضاء ، وحيدة القضاة وأعوانهم ، وإغلاقاً لمظنة التهمة .

ومع هذا يجوز لهم الحضور والمرافعة نيابة عن ممثلين قانوناً ، وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية (١) .

وإذا حضر عن أحد الخصوم وكيل فيجب عليه " أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر " (٢) .

وإذا وكل أحد الخصوم وكيلاً عنه فإن موطن الوكيل يكون معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها . ويجب على الخصم الذي ليس له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه .

و " التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف ، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيها القانون تفويضاً خاصاً .

وكل قيد يرد في سند الوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر " (٣) .

(١) المادة ٢/١ مرافعات .

(٢) المادة (٧٣) مرافعات .

(٣) المادة (٧٥) مرافعات .

و " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردّها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون تفويض خاصاً " (١) .

ويجوز تعدد الوكلاء في قضية واحدة ، و " إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية مالم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل " (٢) .
و " يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي ، وذلك تحت مسؤوليته ودون توكيل خاص ، مالم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل " (٣) .
و " كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة " (٤) .

ولا يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة في وقت غير لائق ، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بالتنازل عن التوكيل ، وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح موكله ، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر (٥) .

(١) المادة (٧٦) مرافعات .

(٢) المادة (٧٧) مرافعات .

(٣) المادة (٧٨) مرافعات ، المادة (٥٦) من قانون المحاماة .

(٤) المادة (٧٩) مرافعات .

(٥) المادة (٩٢) من قانون المحاماة .

ولكن لا يمنع اعتزال الوكيل أو عزله سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه (١) .

المطلب الثاني

غياب الخصوم

غياب الخصم عن مجلس القضاء.

أ- غياب المدعى والمدعى عليه.

في هذه الحالة تحكم المحكمة في الدعوى بشرط أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها، وإلا قررت المحكمة شطبها ؛ وذلك عملاً بما نص عليه المقنن الإجرائي في المادة " ٨٢ " مرافعات؛ حيث نص على أنه : " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت المحكمة شطبها ، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه " (٢).

والملاحظ أن المقنن في المادة ٨٢ من قانون المرافعات الحالي قد أفاد بأن الشطب كجزاء على تخلف المدعى والمدعى عليه عن الحضور لا يكون إلا في الحالات التي تكون فيها الدعوى غير صالحة للحكم فيها ومن ثم فقد أوجب على المحكمة أن تتحقق قبل الحكم بالشطب من صلاحية الدعوى للحكم فيها من عدمه عند تخلف الخصوم عن الحضور، فإذا تبين للمحكمة أن الدعوى غير صالحة للحكم فيها فإنها تقضى بشطبها من تلقاء نفسها، وهذا يستلزم توافر شرطين :

١- تخلف المدعى والمدعى عليه معاً عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء أكانت الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية، ولهذا فإن حضور

(١) المادة (٨٠) مرافعات .

(٢) الفقرة الثالثة أضيفت بمقتضى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ م .

أحدهما يحول دون الحكم بالشطب كأن يحضر المدعى عليه ويتخلف المدعى عن الحضور لأن الحكم بالشطب عندئذ قد يكون ضاراً بمصلحته، ولا يجوز حرمانه من استخدام حقه في الدفاع وتمكينه من تقديم ما لديه من أقوال وحجج لتقنين دعوى خصمه، ما لم يقرر الانسحاب وترك الدعوى للشطب كجزاء على تخلف المدعى، وفي هذه الحالة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالحكم بالشطب إذا رأت أن الدعوى صالحة للحكم فيها ويتعين عليها تنبيه المدعى عليه إلى ذلك حتى لا ينسحب معولاً على شطب الدعوى.

٢- ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها، وتكون كذلك إذا لم يكن الخصوم قد أبدوا دفاعهم بشكل يمكن المحكمة من تكوين عقيدتها في الدعوى، فإذا حكمت في الدعوى رغم ذلك كان حكمها باطلاً لإخلاله بحق الدفاع. وكان قانون المرافعات السابق يمنع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى إذا تغيب الخصمان في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية، وكان يتعين عليها أن تقضى حتماً بالشطب لأن القانون قصر سلطتها على ذلك، ولا يجوز لها أن تتصل بالدعوى أو بموضوعها، وإذا أخطأت المحكمة وسارت في إجراءات الدعوى رغم تغيب طرفيها أو أصدرت حكماً فيها كانت الإجراءات التي اتخذتها والحكم الذي أصدرته باطلاً، لأن القانون لم يعط المحكمة سلطة السير بل منعها من نظرها وحتم عليها أن تقضى بشطبها^(١).

وبتوافر هذين الشرطين لا يكون للمحكمة سلطة الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها باطلاً، كذلك لا يكون للمحكمة سلطة شطب الدعوى إلا مرة واحدة فلا يجوز شطب الدعوى أكثر من مرة، فإذا شطب الدعوى وتم تعجيلها وعاودت الخصومة سيرها ثم تخلف الخصوم بعد ذلك، فلا يكون للمحكمة والحالة هذه أن

(١) - راجع: د / إبراهيم النفاوي، الإخلال بالواجب الإجرائي، ص ١٦ وما بعدها، راجع الأمانة الإجرائية للخصم في التقاضي، د/ أحمد خليفة شرقاوي، مرجع سابق ص ٥٣ وما بعدها.

تقضى بالشطب ثانية وإنما تقضى باعتبار الخصومة كأن لم تكن ، وهو جزاء إجرائي يرتبه المقنن على إهمال الخصم أو تقصيره في متابعة الدعوى أو مباشرتها .

ب- غياب المدعي.

إذا تغّب المدعي عن الحضور في الجلسة تقرر المحكمة شطب الدعوى ما لم يحضر المدعي عليه ويطلب استمرار النظر في الدعوى فإذا طلب المدعي عليه ذلك اعتبرت الخصومة حضورية في حقه.

لذا نص المقنن في المادة " ٨٣ " مرافعات على أنه " إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .

ولا يجوز للمدعي أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم بطلب ما "

ج- غياب المدعي عليه .

لا أثر لتغيب المدعي عليه عن مجلس القضاء ، فإذا كانت أول جلسة وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى ، فإذا لم يكن المدعي عليه قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية لجلسة تالية لإعادة إعلانه ويعتبر الحكم في الحالتين حضورياً، أما إذا تعدد المدعي عليهم وأعلن بعضهم لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيب الجميع ، أو تغيب من لم يعلن لشخصه أجلت المحكمة نظر الدعوى وجوباً لإعلان من لم يعلن لشخصه من الخصوم الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعي عليهم جميعاً م ٨٤ مرافعات.

وقطعاً لسبل التلاعب بين الخصوم وتأكيداً لتقرير الأمانة الإجرائية عند التقاضي يقرر المقنن الإجرائي في المادة " ٨٥ " مرافعات بأنه : " إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل

القضية لجلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه ، فإذا كان البطلان راجعاً إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنية "

وبعد هذا العرض يتبين لنا أن المقنن قد جابه الفساد الإجرائي في شأن التخلف عن حضور الجلسات القضائية^(١)؛ حيث رتب جزاء الشطب في حالة عدم حضور المدعى بينما رتب في حالة تخلف المدعى عليه وجوب إعلانه لشخصه وإلا فقد وجب إعادة إعلانه ، كما قرر تغريم المدعى بغرامة مالية يقدرها القاضي لا تقل عن خمسين جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية متى كان البطلان الواقع في الإعلان راجعاً إلى فعله.

وهذه الجزاءات الإجرائية التي يفرضها المقنن إنما يواجه بها الفساد الإجرائي الذي يتسبب في وقوعه الخصوم ، مما يؤثر على حسن سير التقاضي ، وينال من قيمة الأمانة الإجرائية التي يجب أن يكون عليها الخصم عند التقاضي . هذا وقد أجاز المقنن مؤخرا الحكم في الدعوى عند تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى بشرط أن تكون صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً ضرورياً (م ٨٤ مرافعات).

ومع ذلك، فقد جعل من تخلف الخصم عن الحضور في عدد من الحالات سبباً للحكم لغير صالحه كجزاء على تخلفه أو الحكم بجزاء آخر، لأن إظهار وجه الحق في الدعوى يتوقف على نشاط الخصم وخاصة واقعة الحضور بشخصه.

(١) راجع في ذلك تفصيلاً : العدالة الإجرائية في التقاضي دراسة تحليلية ، د / أحمد خليفة شرقاوي ، ص ٣٣، ط/ شركة ناس ط/ الأولى سنة ٢٠١٥ م، راجع أيضاً : الأمانة الإجرائية للخصم في التقاضي، د/ أحمد خليفة شرقاوي ، مرجع سابق ص ٥٥ وما بعدها.

تغيب الخصم عن مجلس القضاء في الفقه الإسلامي.

من الواجب الإجرائي في حق الخصم أنه إذا دعي إلى مجلس القضاء حضر إليه، فإذا طلبه القاضي فقد وجبت عليه إجابته ما لم يكن في ذلك ضرراً يلحق به، فإذا تبين أن الخصم تغيب عن مجلس القضاء بغير عذر لئلاً وظلماً لخصمه فإن للقاضي الحق في أن يتخذ الإجراءات المناسبة لإحضاره إلى مجلس القضاء.

لأن تغيب الخصم عن الحضور أو امتناعه عنه دون عذر مقبول يعد نوعاً من إساءة الأدب عند التقاضي، ومن ثم فيجوز للقاضي أن يعزره بما يراه تعزيزاً وتأديباً له «لاستهانته بدعوة القاضي»^(١).

حتى إنهم قالوا بتغريمه أجره الرسول الذي يدعوه لمجلس القضاء، قال ابن فرحون نقلاً عن معين الحكام وغيره: «وإذا تبين أن المطلوب ألد بالمدعي، ودعاه الطالب إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجره الرسول إليه، ولا يكون على الطالب من ذلك شيء»^(٢).

فإن طال أمر تغيبه لئلاً ومطلاً بُحث عنه بكل طريقة يتوصل إليه بها، وقد رأى بعض الفقه أن الخصم المطلوب إذا اعتكف للعبادة لئلاً وظلماً، يريد بذلك الفرار والهرب، من إعطاء الحقوق لأصحابها فإنه يُخرج من المسجد^(٣).

(١) ابن عابدين ، حاشية ٤١٥/٥ ، ٤١٦ ، ابن فرحون ، تبصرة الحكام ٣٧١/١ .

(٢) ابن فرحون ، تبصرة الحكام ٣٧١/١ ، الخطاب ، مواهب الجليل ١١٣/٦ .

(٣) الخطاب ، مواهب الجليل ١١٣/٦ ، راجع : الأمانة الإجرائية للخصم في التقاضي، د/ أحمد خليفة شرقاوي ، مرجع سابق ص ٥٥ وما بعدها .

المبحث الثالث

إجراءات الجلسات ونظامها

أولاً : المقصود بالجلسة :

يقصد بالجلسة الفترة الزمنية التي تجلسها هيئة المحكمة في المكان الذي يخصص لهذه الدائرة (١) ، وقد تكون هيئة المحكمة قاض واحد أو قضاة ، بمساعدة كاتب في مواجهة الخصوم ووكلائهم لنظر القضايا .

مبادئ عامة تراعى بالجلسة : نص قانون المرافعات في المادتين (١٠١) ، (١٠٢) على مبدئين هامين يجب مراعاتهما بالجلسة .

الأول : علانية الجلسات.

يمكن القول بأن الأصل أن " تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة " (٢) .

الثاني : حرية الدفاع والمناقشة .

وقد سبق القول أيضاً بأنه " يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعي عليه آخر من يتكلم " (٣) ، ونحيل بشأن هذين المبدئين إلى ما سبق ذكره آنفاً .

ثانياً : ضبط الجلسة وإدارتها :

يرأس الجلسة القاضي أو رئيس هيئة المحكمة ومن ثم يناط به ضبط الجلسة وإدارتها والإشراف عليها وله في سبيل ذلك سلطات ، فـ " للمحكمة ولو من تلقاء

(١) انظر : الوسيط ، أ.د. فتحي والي ص ٤٦٥ ، مبادئ قانون القضاء المدني ، أ.د. وجدي راغب ص ٥٣٤ .

(٢) المادة (١٠١) مرافعات .

(٣) المادة (١٠٢) مرافعات .

نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات " (١) .

كما أن للقاضي سلطة إخراج من يخل بنظام الجلسة من القاعة ، وفإن لم يمثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيه ويكون حكمها بذلك نهائياً .

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كالكتاب والحاجب كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرتين السابقتين (٢) .

" ... يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها ، فإذا كانت الجريمة التي وقعت جنائية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه " (٣) .

و " ... للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة . وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور .

ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه " (٤) . واستثناء من الأحكام التي قررتها المواد (١٠٤ ، ١٠٦ ، ١٠٧) سألقة الذكر " ... إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام

(١) المادة (١٠٥) مرافعات .

(٢) المادة (١٠٤) مستبدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ .

(٣) المادة (١٠٦) مرافعات .

(٤) المادة (١٠٧) مرافعات .

الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك" (١).

و " في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العاملين الأول .

ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها " (٢) .

ثالثاً : محضر الجلسة :

لكل جلسة من جلسات المحاكم محضر يحرره كاتب الجلسة حيث " يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً " (٣) ، ويدون الكاتب في المحضر ساعة افتتاح الجلسة وتاريخها وساعة اختتامها وأسماء القضاة والكاتب وبيان الدعاوى التي طلبت وأسماء الخصوم والمحامين فيها ويثبت في المحضر جميع ما دار في الجلسة وما حدث من وقائع .

ويعتبر محضر الجلسة ورقة رسمية له حجية الأوراق الرسمية في الإثبات ولا يجوز دحض ما جاء فيه إلا بالادعاء بالتزوير (٤) .

وإذا اتفق الخصوم على الصلح فلهم " ... أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر

(١) المادة ٢/٤٩ من قانون المحاماة .

(٢) المادة (٥٠) من قانون المحاماة .

(٣) المادة (٢٥) مرافعات .

(٤) الوسيط ، أ.د. فتحي والي ص ٤٧٠ .

الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام .
ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما انفقوا عليه — كتابة أو شفاهة — بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق" (١).

المبحث الرابع الطلبات والدفع

تباشر الدعوى أمام المحاكم بطريقتين:

الأولى الطلب ، والثاني الدفع.

فالطلب معناه : الإجراء القانوني الذي يعرض بمقتضاه الشخص على

القضاء ما يدعيه طالبا الحكم له به.

وأما الدفع : فهو الوسيلة التي يجيب بها الخصم على المدعي

بقصد منع الحكم له بمطلوبه.

هذا ونتناول الحديث بشيء من التفصيل عن كل من الطلبات والدفع وذلك

على النحو التالي :

المطلب الأول الطلبات

أنواع الطلبات:

قد يكون الطلب أصلياً وهو المفتتح للخصومة، ويعبر عنه أيضاً بالطلب الأصلي، وتنشأ عنه خصومة لم تكن موجودة من قبل، ويرفع للقضاء بورقة من أوراق المحضرين هي صحيفة افتتاح الدعوى، أو ورقة التكليف بالحضور، ويجب أن يقدم إلى محكمة مختصة بنظره من جميع الوجوه.

(١) المادة (١٠٣) مرافعات معدلة بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ .

وقد يكون الطلب عارضاً، وهو طلب يُبدى أثناء سير الدعوى، ويقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا يلزم أن تكون مختصة به من جميع الوجوه^(١).

وقد يقدم الطلب العارض من المدعى أو من المدعى عليه، أو من شخص ذي مصلحة في التدخل في الدعوى وقد يكون اختصاصاً للغير.

آثار الطلب:

تترتب على الطلب سواء كان أصلياً أم عارضاً آثار قانونية بالنسبة للمحكمة وبالنسبة للخصوم.

(أ) بالنسبة للمحكمة:

١-تلتزم المحكمة بتحقيق الطلب والفصل فيه، وإذا امتنع القاضي عن ذلك اعتبر مرتكباً لجريمة إنكار العدالة.

وتتحدد سلطة المحكمة بالفصل فيما يقدم إليها من طلبات وليس لها أن تحكم فيما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإن قضت بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، كان الحكم خاطئاً وجاز الطعن فيه.

٢- متى قُدم الطلب إلى محكمة مختصة نزع اختصاص بقية المحاكم بالفصل فيه حتى ولو كانت مختصة وفقاً للقواعد، كحالة تعدد المدعى عليهم في أماكن مختلفة.

فإذا حدث ورفعت الدعوى ذاتها إلى محكمة أخرى مختصة جاز الدفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي رُفعت إليها أولاً للارتباط.

(ب) بالنسبة للخصوم:

١- قطع التقادم الساري لمصلحة المدعى عليه في مواجهة المدعى وفقاً لنص المادة (٣٨٣) مدني^(٢) ولو رُفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.

(١) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٢٣٩.

(٢) ونصها «ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة..».

- ٢- سريان الفوائد التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى، وفقاً لنص المادة (٢٢٦) مدني «إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وتأخر المدين في الوفاء، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد... وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخ آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره».
- ٣- «... يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى» (المادة ١٨٥/٣) مدني.

- ٤- التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء (المادة ١/٢٢٢) مدني.
- وعلى ذلك إذا قدم الدائن طلب التعويض عن الضرر الأدبي أمام القضاء ثم توفى بعد المطالبة انتقل الحق في التعويض إلى الورثة، بخلاف ما إذا توفى قبل تقديم الطلب فلا ينتقل هذا الحق إلى الورثة.
- ٥- تنظر المحكمة الدعوى بالحالة التي كانت عليها يوم رفعها، وتصرف نظرها عما يطرأ بعد رفعها، فلا يتأثر الاختصاص بها إذا غير المدعى عليه موطنه. ومع ذلك إذا كانت الدعوى لم تستوف شروط قبولها وقت رفعها واستوفتها بعد ذلك وقبل الحكم فيها جاز قبولها، لتفادي رفع الدعوى مرة ثانية بنفس النزاع^(١).

أنواع الطلبات العارضة:

تتعدد أنواع الطلبات العارضة، فقد تبدى هذه الطلبات من المدعى وتسمى حينئذ بالطلبات الإضافية، أو الطلبات العارضة من المدعى. وقد تبدى من المدعى عليه، وتسمى حينئذ طلبات المدعى عليه العارضة أو دعاوى المدعى عليه، وقد تبدى من شخص ذي مصلحة بقصد التدخل في الدعوى وتسمى حينئذ بالتدخل في الدعوى وقد تبدى من الخصوم لإدخال شخص في الخصومة، وتسمى حينئذ باختصاص الغير.

(١) الوجيز في المرافعات، أ.د./ محمد محمود إبراهيم، ص ٧٢٤.

وقد نصت المادة (١٢٣) مرافعات على أن «تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة».

ونتناول فيما يلي هذه الأنواع بشيء من التفصيل:

أولاً: الطلبات العارضة من المدعى (الطلبات الإضافية)

وفقاً لنص المادة ١٢٤ مرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما

يلي:

١- «ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبين بعد رفع الدعوى»^(١)، كأن يطلب المدعى منع التعرض بدلاً عن وقف الأعمال الجديدة، إذا كان العمل قد تم، أو كأن يطلب استرداد الحيازة بدلاً عن منع التعرض إذا كان قد تم سلبها بعد رفع الدعوى، أو أن يطالب بقيمة العقار بدلاً من المطالبة بملكيته، أو أن يطالب بخمسين ألف جنيه بدلاً عن ثلاثين أو العكس، وهكذا ما دام الطلبان مستنديين إلى نفس السبب وبين الخصوم أنفسهم.

٢- «ما يكون مكماً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة»^(٢) كأن يكون الطلب الأصلي بتقديم حساب فيطالب بنتيجة الحساب بطلب عارض، أو كأن يطلب الدين بالطلب الأصلي ثم يطلب الفوائد في طلب عارض، أو يطالب بتسليم السيارة ثم الريع بطلب عارض.

٣- «ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله»^(٣) كأن يطلب الحكم بملكية عقار بناء على عقد، ثم يعدل الطلب إلى التقادم المكسب أو الميراث.

(١) المادة ١٢٤/١.

(٢) المادة ١٢٤/٢.

(٣) المادة ١٢٤/٣.

٤- «طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي»^(١) كأن يكون الطلب الأصلي الحكم بملكية مصنع، ثم يقدم طلباً عارضاً بتعين حارس قضائي على المصنع، أو أن يقدم طلباً عارضاً بتحديد نفقة مؤقتة لحين الفصل في الموضوع.

٥- «ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي»^(٢) ويشترط لقبول هذا النوع من الطلبات الإضافية شرطان، الأول: أن تأذن المحكمة بتقديم الطلب، الثاني: أن الطلب العارض مرتبطاً بالطلب الأصلي، وذلك حتى لا يتخذ المدعى من تقديم الطلبات الإضافية وسيلة لإعنات خصمه أو تعطيل الفصل في الدعوى.

ثانياً: الطلبات العارضة من المدعى عليه (دعاوى المدعى عليه):

وفقاً لنص المادة (١٢٥) مرافعات للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

١- «طلب المقاصة القضائية، وهي التي ينقصها شرط من شروط المقاصة القانونية، ذلك أن للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقود أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء»^(٣).

فإذا اختلف شرط من شروط المقاصة القانونية بأن كان أحد الدينين متنازعا في وجوده أو في مقداره جاز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة أن تحكم له بدينه بعد حسم النزاع على وجوده أو مقداره ليصبح صالحاً لإجراء المقاصة القضائية بين الدينين.

٢- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. للمدعى عليه أن يقدم طلباً عارضاً للمحكمة التي تنتظر الدعوى

(١) المادة ١٢٤/٤.

(٢) المادة ١٢٤/٥.

(٣) المادة ٣٦٢/١ مدني.

الأصلية ويطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو أي إجراء فيها، ذلك أن هذه المحكمة تعد أقدر المحاكم على تقدير الضرر الذي أصاب المدعى عليه من الدعوى أو من إجراء فيها»^(١).

٣- «أي طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يُحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه»^(٢) كأن يطلب المدعى تنفيذ العقد، فيطلب المدعى عليه فسخ العقد. أو أن يطلب المدعى الحكم له بملكية عقار فيطلب المدعى عليه تقرير حق ارتفاق عليه لعقار له. أو كأن يطلب المدعى الحكم له بملكية الأرض فيطلب المدعى عليه دفع تكاليف البناء المقام على الأرض.

٤- «أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة»^(٣) كأن يطلب المدعى الحكم له بملكية عقار فيطلب المدعى عليه الحكم بملكيته له هو.

٥- «ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية»^(٤) فيجوز للمدعى عليه أن يُقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية وبشرط أن تأذن المحكمة بتقديمه، كأن يطلب الموكل من الوكيل في الدعوى الأصلية تقديم حساب عن الوكالة فيطلب المدعى عليه الحكم له بأتعابه ومصاريفه، أو كأن يطلب المدعى تسليم العين المباعة فيطلب المدعى عليه الثمن أو بقيمته.

ثالثاً: الطلبات العارضة من شخص خارج عن الخصومة (التدخل في

الدعوى):

تنص المادة ١/١٢٦ مرافعات على أنه «يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى». وعلى ذلك يجوز أن يتدخل في الدعوى شخص غريب تأييداً لأحد الخصوم في الدعوى، أو بطلب حق لنفسه. ومن ثم فالتدخل نوعان:

(١) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٢٤٧.

(٢) المادة ٢/١٢٥.

(٣) المادة ٣/١٢٥.

(٤) المادة ٤/١٢٥.

(أ) التدخل الانضمامي، أو التبعية، أو التحفظي، ويقصد منه تقوية مركز أحد الخصوم، إذا كان للمتدخل مصلحة في ذلك، كتدخل الدائن في دعوى ضد مدينه حتى لا يخسر المدين الدعوى ويؤدي هذا إلى فقد ضمانه العام المقرر لدائن على أموال مدينه^(١)، وتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة ضد المشتري، حتى لا يرجع عليه إذا خسر الدعوى.

(ب) التدخل الاختصامي أو الأصلي أو الهجومي، ويقصد به المتدخل طلب حق لنفسه، يستوى أن يكون هو ذات الحق موضوع الدعوى أو أن يكون متعلقاً به، كأن يتدخل طالباً الحكم له بملكية عين متنازع عليها في خصومة قائمة.

شروط التدخل:

وفقاً لنص المادة ١٢٦ مرافعات يُشترط لقبول التدخل بنوعيه توافر شروط المصلحة وهو تطبيق للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة ١/٣ «لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون».

كما يُشترط فضلاً عن ذلك في التدخل الاختصامي أن يكون هناك ارتباط بين الدعوى الأصلية والطلب الذي يُبديه المتدخل. ذلك أن المتدخل الاختصامي يدعي لنفسه حقاً، وكان الأصل أن يطلبه بدعوى مستقلة إلا أن المقنن أجاز طلبه بطلب عارض في خصومة قائمة نظر للارتباط بين الدعوى الأصلية والطلب العارض.

آثار التدخل:

يترتب على التدخل بنوعيه أن يصير المتدخل طرفاً في الخصومة ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، كما يكون له حق الطعن في هذا الحكم.

كما تترتب عدة آثار تختلف بحسب نوع التدخل على النحو الآتي:

(١) تنص المادة ٢٣٤ مدني على أن «١- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. ٢- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون».

١- ليس للمتدخل الانضمامي إبداء طلبات مغايرة للطلبات التي طلبها الخصم الأصلي الذي انضم لجانبه، لأن دوره يقتصر على الدفاع فله أن يُبدى ما يشاء من أوجه الدفاع.

بخلاف المتدخل الاختصاصي فهو في مركز المدعى حيث يطلب حقاً لنفسه، ومن ثم له أن يُبدى من الطلبات والدفع ما يراه.

٢- ليس للمتدخل الاختصاصي أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي، لأنه يأخذ حكم المدعى وتدخله يُعد قبولاً للاختصاص ويسقط حقه في الدفع به.

بخلاف المتدخل الانضمامي، إذا كان منضمّاً للمدعى فليس له أيضاً أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي، لأنه ليس للمدعى أن يتمسك بهذا الدفع. أما إذا كان منضمّاً للمدعى عليه فله أن يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي، ما لم يكن حق المدعى عليه في التمسك بالدفع الشككية قد سقط بالحديث في الموضوع أو ما شابه ذلك.

٣- التدخل الانضمامي يتبع الدعوى الأصلية ومن ثم يزول بزوالها لأي سبب من الأسباب إرادية أو غير إرادية، فإذا انقضت الخصومة بالترك أو التنازل أو بالصلح أو حكم بعدم القبول أو بعدم الاختصاص فينقضي بذلك التدخل أيضاً.

بخلاف التدخل الاختصاصي فإن كان سبب الزوال إرادياً كالصلح، فإن ذلك لا يؤثر على التدخل بل يبقى قائماً في مواجهة الخصوم وتنتظره المحكمة كما لو كان طلباً أصلياً، وإن كان سبب الزوال غير إرادي كالحكم بعدم القبول أو بعدم الاختصاص فيزول التدخل تبعاً لزوال الخصومة ما لم يكن التدخل قد رفع بالإجراءات العادية لرفع الدعوى وكانت المحكمة مختصة به من جميع الوجوه فلا يزول في هذه الحالة وتنتظره المحكمة كطلب أصلي.

٤- المتدخل الانضمامي يتحمل مصاريف تدخله، أيّاً كان الحكم (أي حتى ولو صدر الحكم لصالح من انضم إليه) لأن المحكوم عليه لم يُنازعه في حق من حقوقه حتى يمكن تحميله بمصروفاته.

أما المتدخل الهجومي فتسرى عليه قاعدة المدعى أي أنه يتحمل المصروفات إذا خسر الدعوى.

رابعاً: الطلبات العارضة لإدخال شخص في الخصومة (اختصام الغير):

يُقصد باختصام الغير، إدخال شخص في خصومة لم يكون طرفاً فيها بطلب عارض من خصم فيها أو بأمر المحكمة التي تنتظرها.

وعلى ذلك فاختصام الغير قد يكون بطلب من واحد من طرفي الخصومة، بهدف أن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، أو أن يُحكم عليه بطلبات معينة، أو بهدف الدفاع عن الخصم الذي طلب اختصامه^(١).

وقد يكون اختصام الغير بناء على أمر المحكمة التي تنتظر الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

وقد لقي اختصام الغير انتقادات عديدة منها: أنه يجبر هذا الشخص على الدخول في خصومة في وقت قد يكون غير مناسب بالنسبة له، لأنه قد لا يكون مستعداً لها، كما أنه قد يؤدي إلى نظر الدعوى عليه أمام محكمة غير مختصة وفقاً للقواعد العامة، كما أن اختصام الغير بأمر المحكمة يُخل بمبدأ حياد القاضي، فلا يصح أن يكون القاضي مدعياً، كما يخل بحق الخصوم في تسيير الدعوى واختصام من يرون اختصامه فيها^(٢).

ولكن هذه الانتقادات لم تقوى على الحيلولة دون تقرير هذا النظام نظراً لفوائده العملية، حيث يؤدي إلى فض نزاعين أو أكثر في قضية واحدة، أو على الأقل يجعل الحكم الصادر في الدعوى حجة على المختصم مما يحول بينه وبين تجديد النزاع وتكرار دعاوى وتناقض الأحكام^(٣).

كما أن إدخال الغير قد يُسهم في تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة.

(١) قانون المرافعات المدنية والتجارية، أ.د/ نبيل إسماعيل عمر، ص ٣٣٤.

(٢) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٢٥٢.

(٣) أصول المرافعات، أ.د/ أحمد مسلم، ص ٥٨٥.

(أ) اختصام الغير بطلب أحد الخصوم:

تنص المادة ١١٧ مرافعات على أن « للخصم أن يُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها... ».

لم يُحدد المقتنن أحوال اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم على سبيل التحديد، وإنما أورد في النص سالف الذكر ضابطاً لذلك حيث أجاز للخصم إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها.

ومع أن كلمة « للخصم » تنصرف للمدعى والمدعى عليه، إلا أن عبارة « من كان يصح اختصامه عند رفعها » قد يتبادر منها من كان يصح رفع الدعوى عليه إلى جانب المدعى عليه، إلا أن الواقع أن للمدعى عليه كما للمدعى اختصام أشخاص في الدعوى، ما دامت تربط من يراد اختصامه بالدعوى صلة محققة، كانت تبرر وجوده ضمن أشخاصها من أول أمرها^(١).

ويشترط لاختصام الغير، أن يكون هناك ارتباط بين الدعوى الأصلية وموضوع الإدخال، لأن الخصومة مشتركة وواحدة.

ويتم اختصام الغير بطلب عارض يقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها بالمادة ٦٦ مرافعات، لأن اختصام الغير يعتبر دعوى قائمة بذاتها، ومن ثم لا يُقدم هذا الطلب شفاهاً في الجلسة.

من التطبيقات الهامة لاختصام الغير دعوى الضمان الفرعية.

ذلك أنه وفقاً لأحكام القانون المدني « يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعهد البيع إذا كان هذا الحق قد

(١) المرجع السابق، والصفحة نفسها.

آل إليه من البائع نفسه»^(١)، وعلى ذلك فإن البائع مُلزم بالضمان إذا استحق المبيع كله أو بعضه وتوافرت الشروط لذلك.

ويرجع المشتري (صاحب الضمان) على البائع (الضامن) بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب استحقاق المبيع^(٢) وله أن يرجع عليه بإحدى طريقتين هما دعوى الضمان الأصلية، ودعوى الضمان الفرعية.

ودعوى الضمان الأصلية تستدعي أن ينتظر المشتري انتهاء الدعوى الأولى التي يرفعها مُستحق العين المبيعة وإذا حُكم للمُستحق بها كان للمشتري أن يرفع دعوى على البائع (الضامن) بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة، طالباً التعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

أما دعوى الضمان الفرعية فعندما تُرفع على المشتري دعوى باستحقاق العين المبيعة فلا ينتظر حتى تنتهي هذه الدعوى، وإنما يُبادر بتقديم طلب عارضٍ بإدخال بائع العين (الضامن) في الدعوى، حتى إذا ما فشل المشتري ومعه البائع في الدفاع وحُكم باستحقاق العين المبيعة كان الحكم حجة على البائع ويُحكم عليه بالتعويض لاستحقاق المبيع.

و«يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم على طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها، إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة.

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيًا ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى»^(٣).

(١) المادة ٤٣٩ مدني.

(٢) راجع المادتين ٤٤٣، ٤٤٤ مدني.

(٣) المادة ١١٩ مرافعات.

و«يُقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية»^(١).
و«إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجَه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي»^(٢).

وأما «إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية»^(٣).

(ب) اختصاص الغير بناء على أمر المحكمة:

تنص المادة (١١٨) مرافعات على أن «للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخال لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.
وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى».
وقد كانت المادة (١٤٤) من قانون المرافعات ٧٧ لسنة ١٩٤٩ الملغى تحدد الحالات التي يجوز للمحكمة فيها أن تأمر باختصاص الغير بالآتي:
«(أ) من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة.
(ب) من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة.
(ج) الوارث مع المدعى أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.
(د) من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.

(١) المادة ١٢٠ مرافعات.

(٢) المادة ١٢١ مرافعات.

(٣) المادة ١٢٢ مرافعات.

ولم يشأ المقتن أن يحدد سلطة القاضي في الأمر بإدخال خصم بالحالات سالفة الذكر. وإنما ترك له السلطة في ذلك بمقتضى قاعدة تشمل الحالات السابقة وغيرها. وبمقتضاها يكون للقاضي سلطة الأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

ولا تقوم المحكمة بإدخال من ترى إدخاله، ولكنها تحدد ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون تكليفه بالحضور بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ويراعى أن الإدخال بأمر المحكمة مقصور على محكمة أول درجة حتى لا يفوت على الخصم المدخل حقه في التقاضي على درجتين بخلاف ما إذا كان الإدخال بمثابة إجراء تحقيق ولن يترتب عليه تقويت درجة من درجات التقاضي.

تقديم الطلبات العارضة والفصل فيها:

تقدم الطلبات العارضة بطريق من طريقتين:

الأول : بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أي بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها بالمادة (٦٦) مرافعات.

الثاني : بإبدائها شفاهاً في الجلسة في حضور الخصوم وإثباتها في محضر الجلسة، وإذا كان الخصم غائباً تؤجل الدعوى لجلسة قادمة لإعلان الخصم بالطلبات، وإذا كان حاضراً فله أن يطلب التأجيل للرد على طلبات خصمه.

ويقتصر إبداء الطلبات شفاهاً في الجلسة على الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى والمدعى عليه والمتدخل، أما اختصاص الغير فيكون بالإجراءات المعتادة، لأن الأصل أن هذا الشخص غير حاضر بالجلسة.

و«لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة

رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه»^(١). ويجوز تقديم الطلبات العارضة أمام محكمة أول درجة ما لم يقلل باب المرافعة (المادتان ١٢٣، ١٢٦/٢). ويعتبر باب المرافعة مفتوحاً إذا كانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم مع السماح بتقديم مذكرات خلال مدة معينة فيجوز للخصوم التقدم بطلبات عارضة خلال هذه المدة، بشرط إطلاع الخصم الآخر عليها. ويجوز للخصوم إذا أقفل باب المرافعة أن يطلبوا من المحكمة فتحه لتقديم طلبات عارضة إذا كان هناك ما يبرر ذلك، وللمحكمة سلطة تقديرية في إجابة الخصوم لطلبهم أو عدم إجابتهم^(٢). وتحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو بالتدخل. ولكن لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها. وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإذا لم يمكن تحكم في الدعوى الأصلية، وتستبقى الطلب العارض أو طلب التدخل لتحكم فيه بعد تحقيقه.

المطلب الثاني

الدفع

أولاً : ماهية الدفع :

هي الوسائل التي يرد بها المدعى عليه على طلبات المدعى حتى لا يحكم عليه بها.

وتختلف الدفع فيما بينها بحسب موضوع كل منها، والغرض المقصود به، والنتيجة التي يؤدي إليها الحكم بقبوله^(٣).

(١) المادة ١٢٦ مكرر مرافعات.

(٢) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٢٦٠.

(٣) مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية، أ.د/ محمد حامد فهمي ٥١/٢.

ذلك أن المدعى عليه قد يدفع الدعوى بإنكار أصل الحق الذي يدعيه المدعي، كأن ينكر الواقعة التي بنيت عليها الدعوى، أو ينازع في انطباق القاعدة القانونية المطلوب تطبيقها، وقد لا ينكر سند الحق، ولكنه يدعى بطلانه، أو يُقر بنشوء الحق وينازع في بقاءه كأن يدعى انقضاءه بالوفاء أو المقاصة أو بالتقادم ويسمى هذا النوع بالدفع الموضوعية.

وقد لا يدخل المدعى عليه في الموضوع، ولكن يدفع الدعوى بإنكار حق المدعى في رفعها، كأن يدفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان نظراً لأن الحق مؤجل، أو يدفع دعوى الحيابة لرفعها بعد مضي سنة من وقوع التعرض، أو يدفع دعوى النفقة التي ترفعها الزوجة لعدم وجود وثيقة بالزواج، ويسمى هذا النوع بالدفع بعدم القبول.

وقد لا يتعرض المدعى عليه للمنازعة في أصل الحق، ولا في حق المدعى في رفع الدعوى، ولكنه يدفعها بالطعن في صحة الخصومة، كأن يدفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بأن صحيفة الدعوى باطلة لتخلف بيانات جوهرية. ويسمى هذا النوع بالدفع الشكلية.

ثانياً : أنواع الدفع وأحكامها :

١ - الدفع الموضوعية:

وهي التي توجه إلى موضوع الدعوى وينازع بها المدعى عليه في الحق المدعي.

والدفع الموضوعية لا تقع تحت حصر، ويجوز للمدعى عليه إبداءها في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى يُقفل باب المرافعة فيها.

كما يجوز إبداءها في أي مرحلة من مراحل التقاضي فإذا فات المدعي عليه دفع أمام محكمة أول درجة جاز له أن يبديه أمام محكمة ثاني درجة إذا استؤنف الحكم بمعني أن السكوت عن دفع موضوعي أمام محكمة الدرجة الأولى لا يُسقط الحق في إبدائه أمام محكمة الدرجة الثانية.

ولا يلزم المدعى عليه باتباع ترتيب معين في إبدائها أو أن يبيدها معاً في جلسة واحدة، بل يجوز أن تبدى متفرقة على جلسات.

ومن أمثلة الدفوع الموضوعية، إنكار وجود موضوع الدعوى، أو الدفع بانقضاء الحق بالمقاصة، أو بالوفاء أو بالتقادم، ومنها إنكار توافر أركان المسؤولية في دعوى التعويض، ومنها الدفع بعدم سريان قاعدة قانونية معينة على موضوع الدعوى، أو بتفسير القاعدة تفسيراً معيناً.

٢- الدفوع بعدم القبول:

يقصد بها، ما ينازع به المدعى عليه في أن للمدعى حقاً في رفع دعواه أو في توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى^(١).

هذا النوع من الدفوع لا يوجه إلى صحة إجراءات الخصومة، ولا إلى موضوع الدعوى، وإنما يوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى. «فالذي يدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليه، إنما يطلب من القضاء الامتناع عن «سماع هذه الدعوى» لا لأنها رفعت بإجراءات غير صحيحة، ولا إلى محكمة غير مختصة، ولا لأن المدعي ليس صاحب حق كما يزعم، وإنما يكتفي المدعى عليه بطلب عدم سماع الدعوى من خصمه لأنه لا حق له في رفعها، لتخلف شرط المصلحة، أو الصفة فيها أو لعدم توافر شروطهما، أو لأن القانون منع سماعها أو لأن الميعاد المحدد لرفعها قد انقضى»^(٢).

وقد اعتبر المقتن المصري الدفع بعدم القبول نوعاً مستقلاً من الدفوع. ونظراً لأن تحديد طبيعة هذا النوع من الدفوع أثار حيرة الفقهاء فألحقه بعضهم بالدفوع الموضوعية، وقال بعض آخر بأنه أشبه أن يكون من الدفوع الشكلية وقال غيرهم بأنه يجب أن يكون نوعاً مستقلاً من الدفوع لا هو بالشكلي،

(١) انظر تعريفات أخرى، في الوسيط، أ.د./فتحي والي، ص ٤٩١، شرح قانون المرافعات الجديد، أ.د./عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ١٢١.

(٢) أصول المرافعات، أ.د./أحمد مسلم ص ٥٧٣.

لأنه لا يتعلق بالإجراءات ولا هو بالموضوعي، لأنه لا يتصل بالحق المدعي به، فهو إذن صورة خاصة ونوع خاص من الدفوع، كما حاول بعض الفقهاء توزيع الدفوع بعدم القبول ما بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية وأوردوا لذلك تقسيمات للدفوع بعدم القبول^(١)، ولذلك فقد أورد أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ضابطاً لتكييف الدفع حيث قال «والواقع أننا في تكييف هذا النوع من الدفوع يجب أن نشير إلى ثمة ثلاث مراحل يجب أن يمر بها الذهن حتى يتصور وجود الدعوى، فالمرحلة الأولى هي مرحلة الحق الذي ترفع به الدعوى، وليكن مثلاً مبلغ ١٠٠ جنيه، والمرحلة الثانية هي مرحلة الحق في رفع الدعوى، فقد يكون حق الدائن في المبلغ ثابتاً ولكن لا يكون له الحق في رفع الدعوى به، كما لو كان قاصراً فتكون الدعوى المرفوعة منه غير مقبولة رغم ثبوت حقه في الدين بينما تكون الدعوى مقبولة لو رفعها الوصي أو القيم أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الإجراءات التي تتبع في رفع الدعوى، أي تقديم الدعوى إلى القضاء بإيداعها في قلم الكتاب وإعلانها للخصوم بإعلان صحيح... إلخ. فإذا تعلق الدفع بالمرحلة الأولى كان موضوعياً، وإذا تعلق بالمرحلة الأخيرة كان شكلياً وإذا تعلق بالمرحلة الثانية أو الوسطي أي مرحلة الحق في رفع الدعوى — كان دفعاً بعدم القبول»^(٢).

أحكام الدفع بعدم القبول:

(١) أجاز المقنن إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى حيث نصت المادة ١/١١٥ على أن «الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إيدأؤه في أية حالة تكون عليها» ومن ثم فالدفع بعدم القبول لا يسقط بالكلام في الموضوع، ولا يجب إبداء الدفوع بعدم القبول معاً، ولا يسقط الحق فيما لم يبد منها^(٣).

(١) مبادئ المرافعات، أستاذي د/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — مذكرات في المرافعات المدنية والتجارية، أ.د/ محمد حامد فهمي ٥٧/٢، شرح قانون المرافعات الجديد، أ.د/ عبد المنعم الشرفاوي، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ١٢١.
(٢) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣٥٤.
(٣) الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٤٩١.

(٢) تختلف سلطة المحكمة في القضاء بعدم القبول من تلقاء نفسها بحسب سبب عدم القبول. فإن كان عدم القبول يرجع إلى عدم وجود قاعدة قانونية تحمي مصلحة من النوع الذي يتمسك به المدعى، كما في عدم قبول الدعوى بطلب دين قمار، أو عدم قبول الدعوى لحماية مصلحة اقتصادية بحتة، فإن على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها.

أما إذا كان عدم القبول يرجع إلى أحد الأسباب الأخرى، كانهدام صفة المدعى، أو لرفع الدعوى قبل أو بعد الميعاد المعين في القانون، أو لسبق صدور الحكم في موضوع الدعوى، فإن كان الأمر يتعلق بالنظام العام قضت به المحكمة من تلقاء نفسها وإلا فلا^(١).

(٣) لا تلزم المحكمة بأن تحكم في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع، أو أن تقرر ضمها إلى الموضوع، كما هو الحال في الدفع الشكالية، وإنما يجوز للمحكمة أن تحكم في الدفع بعدم القبول وحده، كما يجوز لها أن تفصل فيه وفي موضوع الدعوى معاً، دون أن تقرر ضمه للموضوع^(٢).

(٤) جرى القضاء المصري على أن المحكمة إذا قبلت الدفع بعدم القبول، فإنها تستنفذ ولايتها على موضوع الدعوى، ومن ثم إذا استؤنف الحكم كان الموضوع كله معروضاً على المحكمة الاستئنافية، وإذا ألغت الحكم فلا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، فقد استنفدت ولايتها، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى موضوعياً. مع أن هذا الموضوع لم ينظر أمام محكمة الدرجة الأولى!! وهذا يعنى أن القضاء المصري قارب بين الدفع بعدم القبول وبين الدفع الموضوعية^(٣).

(١) المرجع السابق والصفحة نفسها.

(٢) المرجع السابق والصفحة نفسها.

(٣) مبادئ المرافعات أستاذ الدكتور عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣٥٦، أصول المرافعات، أ.د/ أحمد مسلم، ص ٥٧٤، الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٤٩٤، وانظر نقد هذا الاتجاه في مبادئ القضاء المدني، أ.د/ وجدي راغب، ص ٤٢٦.

(٥) الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول نظر الدعوى يحوز حجية الأمر المقضى أو لا يحوزها حسب الأحوال فأحياناً يترتب على قبول الدفع بعدم قبول الدعوى عدم جواز تجديدها، كما إذا حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى الحيازة لرفعها بعد مضي سنة من وقوع الاعتداء، أو حكمت بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد. أو حكمت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها فهذه الأحكام تحوز حجية الأمر المقضى، ولا يستطيع المدعى رفع الدعوى من جديد.

وأحياناً لا يترتب على قبول الدفع بعدم قبول الدعوى عدم جواز تجديدها، كما إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، أو بعدم قبول دعوى الحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة، أو بعدم قبول الدعوى من الدائن على الكفيل إذا لم يكن قد رجع على المدين، فهذه الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضى، ويجوز للمدعى أن يعود ويرفع ذات الدعوى مرة ثانية عند حلول الأجل في المثال الأول، أو بعد تنازل المدعى عليه عن الحيازة لخصمه يجوز له رفع دعوى الملكية في المثال الثاني، أو بعد أن يرجع الدائن على المدين في المثال الثالث يجوز له أن يرفع الدعوى على الكفيل^(١).

٣- الدفع الشكلي:

المراد بالدفع الشكلي: دفع يرمي «إلى الطعن في صحة شكل الدعوى إما بإنكار اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، وإما بإنكار صحة الإجراءات التي رفعت بها أو التي تسير فيها»^(٢).

وهذا النوع من الدفع لا يمس موضوع الدعوى، وإنما يقتصر على الدليل على خطأ الإجراءات، ويهدف «إلى تعطيل نظر موضوع القضية أو منعه لسبب يتعلق باختصاص المحكمة أو بإجراءات الخصومة»^(٣).

(١) الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٤٩٥، شرح قانون المرافعات الجديد، أ.د/ عبد المنعم الشرقاوي، أستاذ الدكتور عبد الباسط جميعي - يرحمه الله - ص ١٢٦.

(٢) أصول المرافعات، أ.د/ أحمد مسلم، ص ٥٦٧.

(٣) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي - يرحمه الله - ص ٣٥١، الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٢٨٢.

أحكام الدفوع الشكلية:

للدفع الشكلي أحكام خاصة به هي:

- ١— أوجب المقنن إبداء الدفع الشكلي قبل إبداء أي طلب، أو دفاع موضوعي أو دفع بعدم القبول^(١)، وإلا سقط الحق في الدفع الشكلي.
 - ٢— أوجب المقنن إبداء الدفوع الشكلية معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها^(٢)، وعند إبدائها معاً تتساوى، ومن ثم فلا يلزم تقديم بعضها على بعض، كما لا يلزم اتباع ترتيب معين بينها^(٣).
 - ٣— أوجب المقنن إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها الدفع الشكلي معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد من هذه الوجوه^(٤).
 - ٤— أوجب المقنن إبداء الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن وإلا سقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
- وهذه القاعدة مستقلة عن قاعدة وجوب إبداء الدفع الشكلي قبل إبداء طلب أو دفاع موضوعي، ولهذا فإن الحق في الدفع الشكلي يسقط بعدم إبدائه في صحيفة الطعن، ولو فرض وكان الطاعن لم يتكلم في هذه الصحيفة في الموضوع^(٥).
- وتسرى القواعد الأربع السابقة على جميع الدفوع الشكلية أو الأوجه التي تبني عليها، ما لم يكن الحق فيها قد نشأ بعد الكلام في الموضوع، أو ما لم تكن هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، ومثل هذه الأنواع من الدفوع لا يسقط الحق فيه بالكلام في الموضوع، بل يجوز إيدؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف نظراً لتعلقها بالنظام العام^(٦).

(١) المادة ١٠٨ مرافعات.

(٢) المادة ١٠٨ مرافعات.

(٣) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣٥٣.

(٤) المادة ٣/١٠٨ مرافعات.

(٥) الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٤٨٦.

(٦) أصول المرافعات، أ.د/ أحمد مسلم، ص ٥٦٨، الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٢٨٧.

٥- تحكم المحكمة في الدفوع الشكلية قبل نظر الموضوع فقد يغنيها ذلك عن نظر الموضوع والحكم فيه، كما لو قضت ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم اختصاصها بالدعوى^(١) ومع هذا يجوز للمحكمة أن تأمر بضم الدفوع الشكلية إلى الموضوع وتفصل فيهما معاً، وعلى كل حال يجب أن تفصل المحكمة في الدفوع الشكلية صراحة سواء ابتداء أم عند الحكم في الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة^(٢).

٦- الحكم في الدفع الشكلي لا يمس موضوع الدعوى ولا يعتبر فصلاً فيها، ولا يحوز حجية الأمر المقضى، ومن ثم إذا قررت المحكمة قبول دفع شكلي فحكمت بعدم الاختصاص، وترتب على ذلك انتهاء الخصومة، فللمدعى أن يبدأ خصومة جديدة ويرفع ذات الدعوى مراعيًا قواعد الاختصاص.

٧- استئناف الحكم الصادر في الدفع الشكلي يقتصر عليه وحده، وتفصل محكمة الدرجة الثانية فيه وحده، دون موضوع الدعوى فلا يعد معروضاً عليها، ويرجع على محكمة الدرجة الأولى بشأنه عند الاقتضاء، فإذا استؤنف الحكم بعدم الاختصاص وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم، فإنها لا تتعرض لموضوع الدعوى وإنما تعيده لمحكمة أول درجة لتتظر فيه إذ لم يسبق لها نظره، فنظر محكمة الاستئناف للموضوع حينئذ يخالف مبدأ التقاضي على درجتين^(٣).

الدفع بعدم الاختصاص:

يقصد بالدفع بعدم الاختصاص «الدفع الذي يطلب به ألا تفصل المحكمة في الدعوى المنظورة أمامها لأنها ليست داخلية في حدود ولايتها تبعاً لقواعد الاختصاص»^(٤).

والدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي تسرى عليه أحكام الدفوع الشكلية.

(١) الوسيط، أ.د./ فتحي والي، ص ٢٨٧.

(٢) أصول المرافعات، أ.د./ أحمد مسلم، ص ٥٦٨.

(٣) الوسيط، أ.د./ فتحي والي، ص ٤٨٩، الوجيز في المرافعات، أ.د./ محمد محمود إبراهيم، ص ٧٥٠، أصول المرافعات، أ.د./ أحمد مسلم، ص ٥٦٩.

(٤) الدكتور عبد العزيز عامر، شرح قانون المرافعات الليبي ف ١٣٥.

أهم الفروق بين الدفع بعدم القبول والدفع بعدم الاختصاص:

يتضح مما سبق وجود فرق بين الدفع بعدم القبول والدفع بعدم الاختصاص باعتباره دفعاً شكلياً وهذه الفروق هي:

(١) الدفع بعدم الاختصاص يقصد به منع المحكمة من نظر الدعوى المرفوعة إليها بسبب أن ولايتها لا تمتد إلى الفصل في موضوع الدعوى. بينما الدفع بعدم القبول يقصد به منع المحكمة من نظر الدعوى المرفوعة إليها بسبب أن المدعى ليس له حق رفع الدعوى.

(٢) الدفع بعدم الاختصاص — كغيره من الدفوع الشكلية — يجب إيدأؤه قبل إيدأء أي طلب أو دفاع موضوعي أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام. بخلاف الدفع بعدم القبول، حيث يجوز إيدأؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.

(٣) الدفع بعدم الاختصاص إذا تعدد يجب إيدأؤها معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها — ما لم تكن متعلق بالنظام العام — بخلاف الدفع بعدم القبول إذا تعدد فلا يجب إيدأؤها معاً ولا يسقط الحق فيما لم يبد منها.

(٤) الدفع بعدم الاختصاص كدفع شكلي — إذا لم يتعلق بالنظام العام — وتعددت الوجوه التي يبني عليها يجب إيدأء جميع هذه الوجوه معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. بخلاف الدفع بعدم القبول إذا تعددت الوجوه التي يبني عليها، فلا يلزم إيدأؤها معاً، ولا يسقط الحق فيما لم يبد منها.

(٥) الدفع بعدم الاختصاص يجب إيدأؤه في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيه، ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام — بخلاف الدفع بعدم القبول فلا يجب إيدأؤه في الصحيفة ولا يسقط الحق فيه إذا لم يبد.

(٦) الدفع بعدم الاختصاص تحكم فيه المحكمة قبل الحكم في الموضوع، إلا إذا أمرت بضمه إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منهما على حدة. بخلاف الدفع بعدم القبول، فيجوز للمحكمة أن تحكم فيه وحده،

ويجوز لها أن تفصل فيه وفي موضوع الدعوى معاً، دون أن تقرر ضمه للموضوع.

(٧) الحكم في الدفع بعدم الاختصاص لا يمس موضوع الدعوى ولا يعتبر فصلاً فيها ولا يحوز حجية الأمر المقضى، والحكم الصادر في الدفع بعدم القبول يحوز حجية الأمر المقضى أو لا يحوزها حسب الأحوال. على التفصيل السابق ذكره.

(٨) الحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص، لا ينهي سلطة محكمة الدرجة الأولى على موضوع النزاع فإذا استؤنف الحكم بعدم الاختصاص وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم، فإنها لا تتعرض لموضوع الدعوى، وإنما تعيده لمحكمة أول درجة لتتظر فيه حيث لم تستنفذ ولايتها على الموضوع، بخلاف الدفع بعدم القبول، فإن المحكمة إذا قبلت الدفع فإنها تستنفذ ولايتها على موضوع الدعوى، فإذا استؤنف الحكم وألغته محكمة الاستئناف، فلا تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع حيث قد استنفدت ولايتها^(١).

المبحث الخامس

عوارض الخصومة

كثيراً ما تعترض الخصومة أثناء سيرها عوارض تؤثر على سير الخصومة وهو ما يطلق عليه الشراح عوارض الخصومة أو طوارئ الخصومة. وأياً ما كان الحال، فمن هذه العوارض ما يؤدي إلى عدم سير الخصومة. ومنها ما يؤدي إلى انقضاء الخصومة بغير حكم. ونتناول العوارض التي تؤدي إلى عدم سير الخصومة في المطلب الأول ثم العوارض التي تؤدي إلى انقضاء الخصومة في المطلب الثاني.

(١) د. عبد المنعم الشرقاوي، تعليق على حكم مجلس الدولة رقم ٢٠٧ في ١٠/٢/١٩٤٨م منشور بمجلة التشريع والقضاء السنة الأولى قسم القضاء ص ٢٩٣.

المطلب الأول

العوارض التي تؤدي إلى عدم سير الخصومة

العوارض التي تعترض الخصومة وتؤدي إلى عدم سيرها هي وقف الخصومة وانقطاع الخصومة.

ونتناول وقف الخصومة في الفرع الأول وانقطاع الخصومة في الفرع الثاني.

الفرع الأول

وقف الخصومة

يقصد بوقف الخصومة عدم السير فيها مدة محددة، وقد يكون وقف الخصومة بقوة القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم.

(أ) وقف الخصومة بقوة القانون:

يحصل هذا النوع من الوقف بمجرد توفر سببه القانوني، بدون حاجة إلى حكم به، ولكن في العمل تقرره المحكمة بمجرد قيام سببه، ولا يعدو عملها هذا أن يكون تقريراً لأمر واقع بحكم القانون، وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا المجال، ومن ثم تعتبر الدعوى موقوفة من تاريخ قيام سبب الوقف لا من تاريخ الحكم به^(١).

ومن أمثلة وقف الخصومة بحكم القانون ما نصت عليه المادة ١٦٢ مرافعات من أنه «يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طُلب رده»، وكذلك في حالة تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي «يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى ... ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه»^(٢).

(١) الوجيز في المرافعات، أ.د./ محمد محمود إبراهيم، ص ٧٨٦.

(٢) المادة ٣١ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.

(ب) وقف الخصومة بحكم المحكمة:

يحصل هذا النوع من الوقف بحكم المحكمة وليس بقوة القانون ولذلك يجب أن يصدر بالوقف حكم من المحكمة، ولا تبدأ آثاره إلا من تاريخ صدور الحكم، وليس للمحكمة أن تحكم بالوقف في غير الحالات التي يخولها القانون هذه السلطة^(١).

ويتنوع الوقف بحكم المحكمة إلى نوعين:

١- الوقف الجزائي .

٢- الوقف التعليقي.

هذا، ونتناول بيان هذين النوعين بشيء من التفصيل علي النحو التالي:

١- الوقف الجزائي:

هو عقوبة توقعها المحكمة وفقاً للمادة (٩٩) على المدعي إذا تأخر في تقديم المستندات في المواعيد التي تحددها له المحكمة أو إذا تخلف عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، كما لو كلفته بإدخال خصم جديد، أو بإعادة إعلان أحد الخصوم فيها فلم يستجب لذلك في الميعاد الذي حددته له المحكمة.

في هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن توقع على المدعي جزاء مالياً فتحكم عليه بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيهاً.

«ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه»^(٢).

وعلى ذلك فمدة الوقف الجزائي شهر وقد كانت قبل ذلك ستة أشهر ثم خفضت إلى ثلاثة أشهر ثم على شهر واحد بقصد عدم إطالة مدة التقاضي. ومدة الشهر هي الحد الأقصى للوقف ومن ثم يجوز للقاضي أن يحكم بالوقف مدة أدنى من ذلك.

(١) الوسيط، أ.د./ فتحي والي، ص ٥٨١.

(٢) المادة ٢/٩٩ مرافعات، معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢، ثم بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩، ثم بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

ويختلف الوقف الجزائي عن التأجيل، ذلك أن الوقف هنا جزاء وله بهذه الصفة آثار تختلف عن آثار التأجيل فقد يكون غرض المحكمة من الوقف تنبيه المدعي لما سيتعرض له من جزاءات أخرى.

كما يستلزم الوقف أن يقوم المدعي بطلب السير في دعواه (أي يعجل الدعوى) في خلال الخمسة عشر يوماً^(١) التالية لانتهاء مدة الوقف، وإذا مضت مدة الوقف ولم يُعجل المدعي دعواه، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

بخلاف التأجيل فإن القضية تؤجل إلى جلسة محددة في قرار التأجيل ذاته ولا يحتاج الأمر إلى إعلان الخصم بها^(٢).

والغالب أن تتدرج المحكمة في توقيع الجزاءات، فتبدأ بالغرامة، فإن امتثل المدعي وأبدى عذراً وقبلته المحكمة جاز لها أن تُقلل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها.

أما إذا لم يمتثل فإن المحكمة توقع عليه عقوبة الوقف، وإذا ظل معانداً وقعت عليه جزاء أشد وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ويجوز للمحكمة أن تبدأ بالوقف فليس ثمة ما يلزمها بأن تبدأ بالغرامة ثم تنتهي بالوقف، فإن التدرج في توقيع الجزاءات أمر متروك لتقدير المحكمة^(٣).

ويراعى أن الوقف جزاء لإهمال المدعي ومن ثم لا يوقع إذا كان المهمل هو المدعي عليه، ولذلك فإن الجزاء الوحيد الذي يطبق في حالة عدم تنفيذ المدعي عليه لما تأمره به المحكمة هو الحكم عليه بالغرامة. وتحكم في الدعوى بحالتها، وتستطيع أن تستخلص من تخلف المدعي عليه عن القيام بما أمرته به ضعف مركزه وأن تقضى على هذا النحو بما يترجح لديها أنه الحق.

(١) المادة ٣/٩٩ مرافعات وقد كانت ثلاثين يوماً قبل تعديل النص بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٢) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور عبد الباسط الجميعي — يرحمه الله — ص ٣١٠.

(٣) المرجع السابق، والصفحة نفسها.

ونظراً لأن توقيع الوقف الجزائي قد يضر بمصلحة المدعى عليه فينبغي للمحكمة أن تسمع أقوال المدعى عليه في وقف الدعوى، لاحتتمال أن يكون الوقف ضاراً به. وللمحكمة أن تأمر بالوقف رغم اعتراض المدعى عليه. وفي خلال مدة الوقف يمتنع على الخصوم اتخاذ أي إجراء أو تعجيل للدعوى قبل مضي مدة الوقف.

ومتى انتهت المدة يجوز للمدعى عليه تعجيل الدعوى أي تحديد جلسة لها وإعلان الخصم بها.

ولكن إذا لم تعجل الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن — كما سبق القول —.

٢- الوقف التعليقي.

تنص المادة (١٢٩) مرافعات على أنه «في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى وعلى ذلك يحصل الوقف التعليقي بحكم المحكمة، ولا تنشأ حالة الوقف إلا بهذا الحكم.

وللمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم، ويجب تصفيتيها أولاً، لأن الحكم في القضية الأصلية متوقف على الحكم في هذه المسألة.

مثال ذلك أن ترفع دعوى قسمة أمام المحكمة الجزئية، ثم يدعى واحد من الشركاء أو من غيرهم بملكية عين معينة من الأموال المراد قسمتها ويقدم من الأدلة ما يوحي بجديته فإذا كانت قيمة العين المتنازع عليها تدخل في اختصاص القاضي الجزئي فإن المحكمة تنتظر الدعوى وتفصل في المسألة الأولية (وهي ملكية العين المتنازع عليها) باعتبارها وسيلة دفاع يدخل تحقيقها والفصل فيها في إجراءات الخصومة نفسها ولا يحتاج الأمر على وقف الدعوى.

بخلاف ما إذا كانت قيمة العين المتنازع عليها لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ورأت المحكمة أن الفصل في دعوى القسمة يتوقف على الفصل في ملكية العين المتنازع عليها فإن المحكمة تحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في ملكية العين المتنازع عليها.

ومن أمثلة الوقف التعليقي أيضاً أن تُرفع دعوى مدنية بطلب التعويض، ويتوقف الفصل فيها على الفصل في دعوى جنائية منظورة، فهنا تقضى المحكمة المدنية بوقف الدعوى حتى يُفصل في الدعوى الجنائية^(١).

ويشترط للوقف التعليقي أن تكون المحكمة التي تنتظر الدعوى غير مختصة بنظر المسألة الأولية والفصل فيها، وأن ترى المحكمة أن الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى. وتقدير ذلك متروك للمحكمة، ولها ألا تُوقف الدعوى إذا رأت لأسباب سائغة أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على الحكم في المسألة الأولية^(٢). وتظل الخصومة واقفة حتى يزول سبب الوقف، وليس للوقف التعليقي مدة محددة، بل يمتد على أن يُفصل في المسألة الأولية بحكم نهائي. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.

وقد نصت المادة (١٦) من قانون السلطة القضائية على أنه «إذا دُفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها».

(١) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/١/١١ الطعن رقم ٣٥ لسنة ٤٥ق، نقض مدني جلسة ١٩٧٧/١٢/٢٦ الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٤٤ق.

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/٣/١٤ طعن رقم ٤٦٤ لسنة ٤٤ق.

وعلى ذلك إذا مضت المدة ولم تنزل سبب الوقف بسبب تقصير المكلف باستصدار حكم في المسألة الأولية، بأن لم يرفع الدعوى بها، أو رفعها وترك الخصومة فيها، كان للخصم أن يُعجل الدعوى ويطلب الحكم فيها بحالتها^(١).

(ج) الوقف الاتفاقي:

رخص المقنن للخصوم أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أيًا كان سببه فنص في المادة (١٢٨) مرافعات^(٢) على أنه «يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه».

والحكمة من تقرير هذا الوقف أن الخصوم قد يرون أن المصلحة تتحقق بالصلح أو بالتحكيم أو بأي طريق آخر وقد لا يُجيبهم القاضي إلى تأجيل الدعوى المدة التي يريدونها، في حين أن مفاوضات الصلح أو جلسات التحكيم تستغرق مدة أطول ومن ثم رخص لهم المقنن الاتفاق على وقف الخصومة مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وليس للمحكمة أمام هذا الاتفاق إلا أن تجيب الخصوم إليه، لأن الدعوى لا تزال ملكاً لأطرافها على كل حال. ويكفي من تدخل الدولة في هذا الشأن تحديد المدة القصوى التي يجوز الاتفاق على وقف الخصوم خلالها^(٣).

ويجوز للخصوم الاتفاق على وقف الخصومة في أي مرحلة من مراحل

التقاضي.

(١) الوسيط، أ.د./ فتحي والي، ص ٥٨٦.

(٢) معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٣) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي — برحمه الله — ص ٣٠٧، ٣٠٨. وانظر الوسيط للدكتور/ فتحي والي، ص ٥٨٧ حيث يري أن المحكمة سلطة تقديرية في إقرار هذا الاتفاق.

شروط الوقف الاتفاقي:

يشترط للوقف الاتفاقي ما يأتي:

١- اتفاق جميع الخصوم على الوقف سواء كانوا خصوماً أصليين أم متدخلين وأياً كان نوع التدخل^(١).

٢- ألا تزيد مدة الوقف المتفق عليها عن ثلاثة أشهر وهذا هو الحد الأقصى، وقد كانت المدة ستة أشهر فأنقصت إلى ثلاثة أشهر^(٢) رغبة من المقنن في تقصير مدد التقاضي، وواضح أنه يجوز الاتفاق على الوقف مدة أقل من ثلاثة أشهر وإذا اتفق الخصوم على مدة أطول من ذلك لا تقرر المحكمة الاتفاق إلا في حدود الثلاثة أشهر.

ولا مانع يمنع من الاتفاق على وقف الخصومة مدة أخرى ولكن بعد تعجيلها حيث يشترط ألا تتصل مدد الوقف الاتفاقي.

آثار الوقف:

١- الخصومة الواقعة خصومة قائمة، ولذلك تظل المطالبة القضائية منتجة لآثارها، كما تظل كافة الإجراءات التي اتخذت في الخصومة قبل وقفها، وإذا انتهى الوقف عادت الخصومة للسير من النقطة التي وقفت عندها، ومن ثم رُفعت نفس الدعوى مرة أخرى، جاز دفعها بالإحالة إلى المحكمة الأولى.

٢- تعتبر الخصومة راکدة ويمتنع اتخاذ أي إجراء فيها خلال مدة الوقف، وإذا تم شيء من ذلك فإنه يعتبر باطلاً، وإذا كانت هناك مواعيد إجرائية لم تبدأ فإنها لا تبدأ أثناء الوقف، وإذا كان الميعاد قد بدأ قبل الوقف ولم ينته فإنه يقف ويستأنف سريانه بعد انتهاء الوقف.

على أن أثر الوقف بالنسبة للمواعيد لا يترتب بالنسبة للوقف الاتفاقي، فقد نصت المادة ١٢٨ مرافعات على أنه :

(١) الوسيط، أ.د./ فتحي والي، ص ٥٨٦، ٦٨٧.

(٢) بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩.

«... لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما...»^(١).

تعجيل الدعوى:

وإذا انتهت مدة الوقف الاتفاقية فيجب تعجيل الدعوى خلال ثمانية الأيام التالية لنهاية مدة الوقف وإلا اعتبر المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه^(٢)، بمعنى أن الخصومة تنتهي فتزول المطالبة القضائية وما يترتب عليها من آثار، كما تزول أعمال الخصومة التي تمت قبل الوقف.

الفرع الثاني انقطاع الخصومة

يُقصد بانقطاع الخصومة وقف السير فيها بقوة القانون لوفاة أحد الخصوم، أو لفقده أهلية الخصومة أو لزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين. ومن هنا يُفهم أن انقطاع الخصومة هو وقف لها بقوة القانون وله أسباب معينة.

أسباب انقطاع الخصومة:

حصرت المادة ١/١٣٠ مرافعات أسباب انقطاع الخصومة حيث نصت على أنه «ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها».

وعلى ذلك فأسباب انقطاع الخصومة هي (١) الوفاة (٢) فقد الأهلية (٣) زوال الصفة.

(١) الوسيط، أ.د./فتحي والي، ص ٥٨٨.

(٢) المادة ٢/١٢٨ معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ وانظر نقض مدني جلسة ١٩٧٨/٥/٩ طعن رقم ٢٥٧ لسنة ٤٦ق، نقض مدني جلسة ١٩٦٦/٥/٤ طعن رقم ١٨١ لسنة ٣١ق.

١- وفاة أحد الخصوم، إذا انعقدت الخصومة بين أحياء ثم توفي واحد منهم أو توفوا جميعاً انقطع سير الخصومة لأن الخصومة لا تكون إلا بين أحياء ضمناً لتطبيق مبدأ اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم.

ويستوي أن يكون المتوفى المدعى أو المدعى عليه حيث تنقطع الخصومة بوفاة أي خصم متدخلاً أو مدخلاً أو مختصماً لمجرد صدور الحكم في مواجهته. وزوال الشخصية الاعتبارية يأخذ حكم وفاة الشخص الطبيعي، فإذا كانت إحدى الجمعيات أو الشركات خصماً في دعوى ثم حُلَّت الجمعية أو صفيت الشركة أو اندمجت في شركة أخرى وترتب على ذلك زوال الشخصية المعنوية فإن الخصومة تنقطع كما لو تُوفى الشخص الطبيعي^(١).

٢- فقد أهلية الخصومة، كأن يُحجر على أحد أطراف الخصومة لجنون أو عته أو سفه أو غفلة، وكأن يُحكم بشهر إفلاس تاجر فإنه يغل يده يأخذ حكم من يفقد أهلية الخصومة بالنسبة لأمواله في التفليسة^(٢).

٣- زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائين كأن يرفع شخص دعوى بصفته ولي أو وصي على القاصر ثم تزول هذه الولاية أو الوصاية بعزله أو ببلوغ القاصر سن الرشد فيؤدي زوال صفة هذا الشخص إلى انقطاع سير الخصومة، وكذلك السنديك الذي يمثل التفليسة ثم تزول صفته. فإن زوالها يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة.

ويرى بعض الشراح أن وفاة الشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري أو تركه منصبه بعد سير الخصومة يؤدي إلى انقطاعها بناء على هذا السبب^(٣) بينما يرى بعض الشراح - وهو ما نؤيده - أن الخصومة لا تنقطع بتغيير ممثل

(١) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي - يرحمه الله - ص ٣١٦.

(٢) مبادئ قانون القضاء المدني، أ.د/ وجدي راغب، ص ٥٥٤.

(٣) أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي - يرحمه الله - في مبادئ المرافعات ص ٣١٧.

الشخص الاعتباري، لأنه لا يعد نائباً وإنما مجرد عضو للشخص الاعتباري والنص قاصر على صفة النائب^(١).

ولكن لا تنقطع الخصومة إذا توفى وكيل الدعوى (المحامي) لأنه ليس طرفاً في الخصومة، وإنما هو عوين من أعوان القضاء، ولذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة ١٣٠ على أنه «ولا تنقطع الخصومة ب وفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتتحي أو بالعزل...» لأننا لو اعتبرنا ذلك سبباً لانقطاع الخصومة لأمكن الخصوم سيء النية من قطع الخصومة كلما سارت وذلك بعزل الوكيل.

ومع هذا إذا توفى وكيل الدعوى أو زالت وكالته لأي سبب فللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته، إذا بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى، حتى يتمكن الوكيل الجديد من دراسة القضية وتجهيز دفاعه.

وإذا تحقق سبب من هذه الأسباب انقطعت الخصومة إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. ذلك أن وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة، أو زوال صفة من كان يمثل من النائبين، بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم لن يؤثر على حق الخصم في إبداء دفاعه.

«وتعتبر الدعوى مهياًة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة»^(٢).

وعلى ذلك إذا حجزت المحكمة القضية للحكم مع تبادل مذكرات في خلال مدة معينة، ثم تحقق سبب الانقطاع بعد انتهاء هذه المدة فللمحكمة أن تحكم في الدعوى لأنها تكون مهياًة للحكم فيها سواء قدمت مذكرات أم لم تقدم.

(١) أ.د./وجدي راغب، مبادئ قانون القضاء المدني، ص ٥٥٤ ، ٥٥٥، أ.د./فتحي والي،

الوسيط، ص ٥٩١ هـ-٣.

(٢) المادة ١٣١ مرافعات.

بخلاف ما إذا تحقق سبب الانقطاع قبل انتهاء مدة تبادل المذكرات، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى، لأنها لا تكون مهياًة للحكم في موضوعها حتى ولو قدم الخصوم مذكرات لأن الميعاد لم ينته والمرافعة لم تنته ويجوز أن تقدم مذكرات تكميلية^(١).

وإذا تحقق سبب من هذه الأسباب انقطعت الخصومة بقوة القانون « ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع وجب على المحكمة — قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة — أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإن لم يقم به خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه»^(٢).

آثار انقطاع الخصومة:

«يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع»^(٣). ومع هذا تعتبر الخصومة المنقطة خصومة قائمة وتظل المطالبة القضائية منتجة لآثارها، كما تظل الإجراءات التي اتخذت قبل تحقيق سبب الانقطاع قائمة ومن ثم عند تعجيل الدعوى (أي معاودة السير فيها) تعود للسير من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد بكل الإجراءات السابقة^(٤).

كما تبطل جميع الإجراءات التي تحصل أثناء فترة الانقطاع ومن ثم لا يجوز اتخاذ أي إجراء في الخصومة أثناء فترة الانقطاع، كما يبطل الحكم الصادر خلالها ولو أصدرته المحكمة دون علم به طالما كانت الدعوى غير مهياًة للحكم فيها.

(١) شرح قانون المرافعات الليبي، أ.د/ عبد العزيز عامر، ص ٣٢٥.

(٢) المادة ٢/١٣٠ مرافعات مستبدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٣) المادة ١٣٢ مرافعات.

(٤) مبادئ قانون القضاء المدني، أ.د/ وجدي راغب، ص ٥٥٧.

ولكن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام، فهو مقرر للمصلحة الخاصة، ومن ثم لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجب أن يتمسك به من يقوم مقام الخصم الذي قام به سبب الانقطاع. ويجوز له أن يتنازل عن التمسك به صراحة أو ضمناً، ولكن ليس للخصم الآخر أن يتمسك به^(١).

استئناف الدعوى سيرها:

الوسيلة الأولى: تعجيل الخصومة وذلك بإعلان صحيفة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر.

أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب من قام مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

الوسيلة الثانية: حضور من قام مقام من توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته الجلسة التي كانت محددة لنظر الدعوى.

وعلى ذلك إذا حدث سبب الانقطاع ولكن عند حلول ميعاد الجلسة حضر فيها وارث المتوفى^(٢)، أو حضر القيم عن حُجر عليه، أو حضر الشخص الذي كان مشمولاً بالولاية أو الوصاية وبلغ سن الرشد، بدلاً عن زالت صفته فإن الخصومة تستأنف سيرها.

المطلب الثاني

العوارض التي تؤدي إلى انقضاء الخصومة بغير حكم

من العوارض التي تعترض الخصومة وتؤدي إلى انقضائها بغير حكم في موضوعها سقوط الخصومة، وانقضاؤها بمضى المدة، وترك الخصومة. ونتناول هذه العوارض مخصصين فرعاً لكل عارض.

(١) المرجع السابق، ص ٥٥٨ وانظر نقض مدني جلسة ١٩٧٨/٥/٢٥ طعن رقم ٦٥٤ لسنة ٤٥ ق، جلسة ١٩٧٠/٤/٩ طعن رقم ٢٢ لسنة ٣٦ ق.

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/٥/٢٥ طعن رقم ٦٥٤ لسنة ٤٥ ق.

الفرع الأول سقوط الخصومة

المقصود بسقوط الخصومة:

يُقصد به زوال الخصومة وإلغاء إجراءاتها، بسبب عدم السير فيها بفعل المدعى أو امتناعه مدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها. فهو جزاء يوقع بسبب إهمال المدعى متابعة السير في دعواه، متى استمر هذا الإهمال مدة معينة سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة، وفي مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها^(١)، وقد نصت المادة ١٣٤ معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ على أنه «لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي».

شروط الحكم بسقوط الخصومة:

يشترط للحكم بسقوط الخصومة توافر الشرطين الآتيين:

- ١- عدم السير في الدعوى بفعل المدعى ومن في حكمه كالمستأنف أو امتناعه، فيلزم أن تكون الخصومة واقفة، كما لو حكم بإيقافها تطبيقاً للمادة ٢/٩٩ مرافعات ولم يعجل السير فيها وظلت واقفة لمدة ستة أشهر أو لقيام سبب من أسباب انقطاع الخصومة. ويلزم أن يكون الوقف بفعل المدعى أو امتناعه أما إذا لم يكن الوقف راجعاً على فعل المدعى أو امتناعه^(٢) فلا تسقط الخصومة، كأن يرجع وقف الخصومة إلى فعل المدعى عليه، أو تقف الخصومة لحين الفصل في مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها الحكم في الدعوى.

(١) الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٥٩٥.

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٦/٦/٢٢ طعن رقم ٥٢٥ لسنة ٤٢ق

٢- أن تظل الخصومة واقفة لمدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي سواء اتخذ من المدعى أم من المدعى عليه أم من خصم متدخل في الدعوى أم كان حكماً صادراً في الدعوى.

وإذا كان الأصل أن تبدأ مدة الستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فإنه يستثنى من ذلك حالة انقطاع الخصومة حيث «لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي»^(١). وعلى ذلك في حالة الانقطاع نفرق بين ما إذا كان سبب الانقطاع قد تحقق في شأن المدعى أو في شأن المدعى عليه.

(أ) إذا تحقق سبب الانقطاع في شأن المدعى أو المستأنف كأن يكون قد توفى أو فقد أهليته أو زالت صفة من يمثله فلا تبدأ مدة الستة أشهر إلا من تاريخ اليوم الذي يقوم فيه المدعى عليه بإعلان ورثة المدعى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو من قام مقام من زالت صفته بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي (المدعى)، وإن لم يقم المدعى عليه بهذا الإعلان فإن الخصومة لا تسقط.

(ب) إذا تحقق سبب الانقطاع في شأن المدعى عليه أو المستأنف عليه بأن يكون قد توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفة من يمثله فيجب على المدعى أو المستأنف أن يعجل الخصومة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم بانقطاعها. وليس للمدعى أن يتعلل بأنه كان ينتظر إخطاراً من خصومه بوجود هذه الخصومة لأنه هو صاحبها ولا يحتاج إلى تنبيه من أحد^(٢).

وعلى ذلك تبدأ مدة الستة أشهر هنا من تاريخ الحكم بانقطاعها.

(١) المادة ١٣٥ مرافعات.

(٢) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي - يرحمه الله - ص ٣١٩، ٣٢٠، وانظر نقض مدني جلسة ١٩٧٠/١/٢٠ طعن رقم ٤٤٥ لسنة ٣٥ ق.

كما أن حساب بداية مدة الستة أشهر يثير بعض الصعوبات في حالات وقف الخصومة على النحو التالي:

(أ) **الوقف الاتفاقي**، لا مجال للسقوط فيه، لأنه إذا لم تُعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل الذي اتفق الخصوم على وقف الخصومة فيه، اعتبر المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

(ب) **الوقف الجزائي**: لا تبدأ مدة الستة أشهر إلا من تاريخ انتهاء مدة الوقف التي قضت بها المحكمة، ذلك لأن المدعى ممنوع من اتخاذ أي إجراء في فترة الوقف ومن ثم لا ينسب إليه تقصير أو إهمال فيلزم للسقوط أن تمضي ستة أشهر خلاف مدة الوقف دون أن تعجل الدعوى حتى يُحكم بالسقوط.

ويراعى أن الجزاء الذي يوقع على المدعى إذا أهمل في دعواه ولم يطلب السير فيها بعد انقضاء مدة الوقف الجزائي في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ولكن إذا لم يتمسك المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن فليس للمحكمة أن تقضى بهذا الجزاء من تلقاء نفسها ومن ثم تظل الخصومة في حالة ركود، فإذا مضت مدة الستة أشهر سقطت الخصومة بقوة القانون^(١).

(ج) **الوقف التعليقي**، لا تبدأ مدة الستة أشهر إلا من تاريخ الحكم النهائي في المسألة الأولية التي يتوقف على الفصل فيها الحكم في الدعوى الأصلية لأنه لا يمكن أن ننسب إهمالاً للمدعى قبل صدور حكم في المسألة الأولية.

كيف يتم إسقاط الخصومة:

يتم إسقاط الخصومة بطريق من طريقتين:

الأول: رفع دعوى سقوط الخصومة أمام المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. حتى ولو كانت من محاكم الدرجة الثانية، فلو كان الأمر يتعلق باستئناف منظور أمام محكمة من

(١) قانون المرافعات المدنية والتجارية، أ.د/ أحمد هنيدي، ٣٠٧/٢.

محاكم الدرجة الثانية، فإن دعوى إسقاط الخصومة ترفع أمام هذه المحكمة مع أن الدعوى مبتدأة، وهذه من الصور التي يجوز فيها رفع دعوى مبتدأة أمام محكمة من محاكم الدرجة الثانية، ويترتب على ذلك أن الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يكون إنتهائياً^(١).

الثاني: التمسك بسقوط الخصومة عن طريق الدفع، وذلك إذا عجل المدعى دعواه بعد مضي الستة أشهر جاز للمدعى عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة عن طريق الدفع ونظراً لأن سقوط الخصومة مقرر لمصلحة المدعى عليه فإنه يجب أن يتمسك به قبل الكلام في الموضوع.

وإذا تمسك المدعى عليه أو من في حكمه بسقوط الخصومة عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع فيجب أن يكون التمسك به في مواجهة جميع المدعين أو المستأنفين، وإلا كان الطلب أو الدفع غير مقبول، لأنه لا يجوز تجزئه السقوط، واعتبار الدعوى ساقطة بالنسبة لبعض المدعين ويعتبر المتدخل في حكم المدعى إذا كان تدخله هجومياً أو كان منضماً للمدعى.

أما بالنسبة للمدعى عليهم فيكفي أن يتمسك واحد منهم بسقوط الخصومة، في صورة دعوى أو دفع، فيؤدي ذلك إلى سقوط الخصومة بالنسبة للجميع، ويعتبر المتدخل تدخلاً انضمامياً لمساندة المدعى عليه أو لمساندة أحد المدعى عليهم في حكم المدعى عليه.

آثار الحكم بسقوط الخصومة:

لا تسقط الخصومة إلا بحكم يصدر بناء على تمسك المدعى عليه بسقوط الخصومة في صورة دعوى أو في صورة دفع — كما سبق القول —. وقد نصت المادة ١٣٧ مرافعات على أنه «يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات. وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى، ولا

(١) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣٢٦.

في الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها.

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها».

وعلى ذلك يترتب على الحكم بسقوط الخصومة زوالها من تاريخ رفعها وإلغاء جميع إجراءاتها، فتزول صحيفة افتتاح الدعوى وما ترتب عليها من آثار، كما تزول جميع الإجراءات التي اتخذت في الدعوى. وتسقط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات ولكن لا يسقط أصل الحق ما دام قائماً، ويجوز رفع دعوى جديدة به.

كما لا تسقط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام.

كما لا تسقط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها.

وكذلك لا تسقط بسقوط الخصومة إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت قبل سقوطها، ويجوز للخصوم أن يتمسكوا بها في خصومة جديدة ما لم تكن باطلة في ذاتها.

ولا تسقط بسقوط الخصومة الإجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، كالأعذار السابق على رفع الدعوى التي قُضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره^(١).

و«متى حُكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال.

(١) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٥٩٠.

ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول التماس سقط طلب التماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول التماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال»^(١).

الفرع الثاني

انقضاء الخصومة بمضى المدة (بالتقادم)

تنص المادة ١٤٠ مرافعات على أنه «في جميع الأحوال تنتقضي الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.

ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض». وقد قصد بهذا النص وضع حد لتراكم القضايا المعلقة أمام المحاكم، بحيث تنتقضي الخصومة فيها على كل حال أيًا كان سبب وقفها أو انقطاعها، وأيًا كان المتسبب في الوقف، فلا يشترط هنا أن ينسب الإهمال إلى المدعى. ومن ثم تنتقضي الخصومة بمضى هذه المدة في جميع الأحوال. كما لو كانت الخصومة منقطعة لوفاء المدعى ولم يقم المدعى عليه بإخطار ورثة المدعى بوجود الدعوى، فإنه تنتقضي على كل حال بمضى سنتين.

وهذا نوع من التقادم الحتمي لا يلحقه وقف ولا انقطاع، ولا يشترط له أكثر من مضي المدة^(٢) التي حددها المقتن بسنتين، وقد كانت قبل صدور القانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ ثلاث سنوات خفضت إلى سنتين عملاً على تقصير مدة التقاضي وحثاً للخصوم على موالاة الإجراءات.

ويبدأ سريان هذه المدة من آخر إجراء صحيح وقد ذهبت محكمة النقض إلى تفسير عبارة «في جميع الأحوال» تفسيراً يخالف ما درجت عليه دوائرها المدنية ومؤداه انصراف هذه العبارة إلى الحالات التي يكون فيها عدم موالاة السير في الخصومة راجعاً على مطلق إرادة الخصوم أو قلم كتاب المحكمة، وعلى ذلك لا يسرى هذا التقادم إذا قام مانع مادي يُعد من قبيل القوة القاهرة كحالة الحرب مثلاً

(١) المادة ١٣٨ مرافعات.

(٢) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣٢١.

بحيث يستحيل على الخصم مولاة السير في الدعوى، وكذلك إذا قام مانع قانوني يحول دون السير في إجراءات الخصومة، كوقف السير في الدعوى المدنية لحين الحكم في الدعوى الجنائية^(١).

التمسك بانقضاء الخصومة بمضى المدة:

تتقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ويحصل الانقضاء بقوة القانون، ولكن لا يجوز للمحكمة أن تقضى بانقضاء الخصومة بالتقادم من تلقاء نفسها، وإنما يجب على صاحب الشأن – المدعى أو المدعى عليه ومن في حكمهم، أن يتمسك بانقضاء الخصومة بمضى المدة. ويتم التمسك بذلك إما عن طريق دعوى أصلية بالطريق المعتاد أمام المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب انقضاء الخصومة فيها. وإما عن طريق دفع يُبدى عندما تُعجل الخصومة بعد مضي المدة.

آثار الحكم بانقضاء الخصومة بالتقادم:

يترتب على الحكم بانقضاء الخصومة بالتقادم، زوالها وزوال جميع آثارها ولكن لا يؤدي إلي انقضاء أصل الحق وما دام باقياً فإنه يجوز رفع دعوى مبتدأ به.

ولا يؤدي الحكم بانقضاء الخصومة بالتقادم على زوال الأحكام القطعية التي صدرت في الدعوى وكذلك الإجراءات السابقة على هذه الأحكام. كما لا تسقط بانقضاء الخصومة بالتقادم الإقرارات الصادرة من الخصوم ولا الإيمان التي حلفوها.

وكذلك لا تسقط إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت في الخصومة المنقضية ويجوز للخصوم أن يتمسكوا بها في خصومة جديدة ما لم تكن باطلة في ذاتها.

(١) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوى، ص ٥٩٢.

الفرع الثالث ترك الخصومة أو التنازل عنها

يقصد بترك الخصومة تنازل المدعى عنها مع احتفاظه بالحق الموضوعي^(١).

والأصل أنه يجوز للمدعى أن يتنازل عن دعواه كما يشاء، لأن الدعوى ملك لصاحبها.

وغالباً ما يلجأ المدعى إلي ترك الخصومة إذا رأى ضعف مركزه، أو أنه تسرع في رفع الدعوى قبل أن يستعد لها تماماً ويجهز أدلته، أو ليفسح مجالاً للصالح أو للتحكيم.

ومع هذا فنظراً لأن ترك الخصومة لا يحول دون رفع الدعوى من جديد بالحق ذاته ما دام باقياً. وقد يكون المدعى عليه قد تكلف الجهد والمال في تحضير دفاعه، ومن ثم تتحقق مصلحته في الفصل في الدعوى حتى يتخلص منها نهائياً. ولذلك نصت المادة (١٤٢) مرافعات على أنه «لا يتم التنازل بعد إيداع المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية على محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى».

وعلى ذلك فإذا كان للمدعى أن يترك خصومته بإرادته إلا أن هذا التنازل لا يتم إذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته إلا بقبوله، فهنا يكون للمدعى عليه حق تعلق بالخصومة ويوجب الفصل فيها، ومن ثم لا يجوز للمدعى أن يتركها بإرادته المنفردة.

(١) انظر، مبادئ قانون القضاء المدني، أ.د./ وجدي راغب، ص ٥٧٤، الوسيط، أ.د./ أحمد السيد صاوي، ص ٥٩٣، مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣٣٢.

والمقصود بطلبات المدعى عليه الطلبات الموضوعية التي تجعل حقه متعلقاً بالخصومة وبوجوب الفصل فيها. ويكفي في ذلك أن يكون المدعى عليه قد طلب رفض الدعوى، لأن هذا طلب موضوعي^(١).

أما إذا كان المدعى عليه قد تغيب عن الجلسات، أو حضر ولم يبد أي طلبات، أو طلب التأجيل للاستعداد أو أبدى طلبات يقصد منها منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى، كما لو طلب الحكم فيها بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو ببطالان الصحيفة. فيجوز للمدعى في هذه الحالات أن يترك الخصومة بإرادته المنفردة، لأن الطلبات التي أبداهها المدعى عليه لم يقصد منها أن تتظر المحكمة الدعوى وتفصل فيها، وإنما يقصد منها منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

وإذا أبدى المدعى عليه طلباً من هذا القبيل ولم يبد طلبات موضوعية، ومع هذا رفض قبول ترك الخصومة واعترض عليه، فلا يلتفت إلى اعتراضه على الترك وعدم قبوله له، لأن هذه الطلبات في واقع الأمر تسليم من المدعى عليه بطلب المدعى ترك الخصومة، وتحقيق من جانبه للغرض الذي يرمي إليه وهو التخلص من الخصومة بغير حكم في موضوعها مما مفاده أن المادة ١٤٢ تضع قاعدة عامة مقتضاها عدم الاعتداد باعتراض المدعى عليه على ترك الخصومة طالما لم يكن له مصلحة مشروعة في الإبقاء عليها^(٢).

ويجوز رجوع الخصم عن ترك الخصومة صراحة أو ضمناً ما دام خصمه لم يقبل الترك أو يحكم القاضي باعتماده^(٣).

(١) شرح قانون المرافعات الجديد، أ.د/ عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٤٦٩، ٤٧٠.

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٩/٣/٧ طعن رقم ٧١٤ لسنة ٤٨ ق.

(٣) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/٥/١١ طعن رقم ٨٥٤ لسنة ٤٥ ق.

كيفية ترك الخصومة:

وفقاً لنص المادة ١٤١ مرافعات يتم ترك الخصومة بطريق من الطرق الآتية:

- ١- إعلان على يد محضر يوجهه التارك لخصمه، يُقرر فيه ترك الخصومة.
- ٢- بيان صريح في مذكرة يقدمها التارك أو وكيله للمحكمة مع إطلاع خصمه عليها، ويجب أن تكون المذكرة موقعة من التارك أو من وكيله بشرط أن يكون توكيله يُجيز له ترك الخصومة لأن ذلك يحتاج على توكيل خاص بذلك ولا يكفي في هذا الشأن التوكيل العام.
- ٣- إبداء ترك الخصومة شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر. ويراعي أن يكون التارك للخصومة متمتعاً بالأهلية اللازمة لذلك.

الترك الجزئي للخصومة:

قد يكون ترك الخصومة كلياً أو جزئياً، وتركها كلياً يعني التنازل عن الخصومة جملة.

أما الترك الجزئي فهو تنازل عن بعض الخصومة، كما لو كانت الدعوى مرفوعة بعدة طلبات وقرر المدعى أن يتنازل عن بعضها وتستمر الدعوى بالباقي، وكما لو كانت الدعوى ضد عدة أشخاص، وتنازل عن اختصام بعضهم. ويجوز التنازل عن إجراء من إجراءات الخصومة أو عن ورقة من أوراق المرافعات، وفي هذه الحالة يعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، ويجوز أن يتم هذا التنازل صراحة أو ضمناً^(١) ومن ثم لا يلزم أن يتم بإحدى الطرق السابق ذكرها. كما لا يشترط موافقة الخصم الآخر على ذلك التنازل^(٢).

(١) المادة ١٤٤ مرافعات.

(٢) نقض مدني جلسة ١٩٧٨/٥/١١ طعن رقم ٨٥٤ لسنة ٤٥.

آثار ترك الخصومة:

يترتب على الترك الكلي إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى^(١)، ويُحكم على التارك بالمصاريف.

ولكن ترك الخصومة (التنازل عنها) لا يعنى التنازل عن الحق، بل ويجوز لمن ترك الخصومة أن يُقيم دعوى جديدة بذات الحق إذا كان باقياً.

و«إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن» (المادة ١٤٤). ووفقاً لنص المادة (١٤٥) فإن «النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به» وعلى ذلك إذا تنازل شخص عن الحكم الصادر له في دعوى معينة فإن ذلك يستتبع النزول عن الحق الثابت في الحكم ما لم يتحفظ المتنازل ويقرر أنه يتنازل عن الحكم دون الحق الثابت فيه^(٢).

المبحث السادس الأحكام القضائية

تمهيد:

الأصل أن تنتهى الخصومة بحكم يصدر في موضوعها، ذلك أن صدور حكم في الموضوع هو الغاية التي يقصدها المدعى من دعواه، ولكن كثيراً ما تصدر المحكمة أحكاماً قبل الفصل في الموضوع، كالأحكام الصادرة بعدم القبول، أو بعدم الاختصاص، أو بالإحالة، أو بانقضاء الخصومة بالنقادم، وقد تصدر المحكمة قرارات بمقتضى سلطتها الولائية.

وللأحكام عموماً آثار تترتب عليها. ولذلك نتحدث فيما يلي في الأحكام وتقسيماتها وآثارها.

(١) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٥٩٧.

(٢) شرح قانون المرافعات، أ.د/ عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي —
يرحمه الله — ص ٤٧١.

المقصود بالحكم:

يقصد بالحكم القرار الصادر من محكمة بموجب سلطتها القضائية في خصومه رفعت إليها وفقاً لقانون المرافعات.

وعلى ذلك فلكي يعتبر القرار حكماً يجب أن يكون صادراً من محكمة ونقصد بالمحكمة الهيئة التي لها ولاية فصل الخصومات وفقاً للقانون، وأما إذا كان القرار صادراً عن غير محكمة فلا يكون حكماً.

ويجب أن يكون القرار الصادر من المحكمة استعمالاً لسلطتها القضائية، أما إذا كان القرار صادراً عن المحكمة بموجب سلطتها الولائية فيطلق عليه اصطلاح «أمر»^(١) كما يجب لاعتبار القرار حكماً أن يكون صادراً في خصومة، أما إذا كان القرار صادراً في غير خصومة فلا يُعد حكماً وإنما قد يُعد أمراً أو قراراً إدارياً، ذلك أن الحكم يفترض وجود نزاع يفصل فيه، فالمنازعة ورفعها هو المبرر الأصلي لتدخل القضاء، أما القرار الإداري فقد تصدره المحكمة لتسيير أمور إدارية لا يلزم لها خصومة، وفضلاً عن ذلك يجب لاعتبار القرار المذكور حكماً أن يصدر وفقاً للأوضاع والإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات والتي سنتناولها فيها بعد.

تقسيمات الأحكام:

تنقسم الأحكام تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة أهمها ما يأتي:

١- الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية:

تنقسم الأحكام باعتبار مدى حرية المحكمة في الرجوع في مسألة فصلت فيها إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية.

الحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في مسألة فصلاً لا يجوز الرجوع فيه^(٢) ومثال ذلك الحكم الذي يقضى بملكية عين لشخص معين، أو الحكم بإجابة طلبات

(١) وهناك ما يصدر عن المحكمة استعمالاً لسلطتها الولائية ويطلق عليه «حكم» مثل حكم إيقاع البيع. وهناك ما يصدر عن المحكمة استعمالاً لسلطتها القضائية ويطلق عليه «أمر» مثل أوامر الأداء (انظر: الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٦١٢، هـ ٢ من الصفحة نفسها).

(٢) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣٤.

المدعى أو برفضها، أو الحكم بعدم اختصاص المحكمة أو برفض الدفع بعدم الاختصاص أو الحكم بقبول الدعوى أو بعدم قبولها.

الحكم غير القطعي هو الحكم الذي يفصل في مسألة على نحو يجوز للمحكمة أن تراجع فتعده أو تلغيه^(١). كالأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، مثل الحكم بنفقة وقتية، وكالأحكام التي تتعلق بتنظيم إجراءات السير في الخصومة أو تحقيقها، مثل الحكم بضم دعويين، أو مثل الحكم بندب خبير.

وتظهر أهمية التفرقة بين الحكم القطعي وغير القطعي في أمرين:

الأول: أن الحكم القطعي لا يجوز للمحكمة التي أصدرته أن ترجع فيه (يجوز حجية الشيء المحكوم فيه) أما الحكم غير القطعي فإنه يجوز للمحكمة أن تعدل عنه، كما يجوز لها ألا تأخذ بنتيجته، وإذا كان وقتياً فله حجية قاصرة ومؤقتة.

الثاني: الحكم القطعي لا يسقط بسقوط الخصومة أو بانقضائها بالتقادم، بخلاف الحكم غير القطعي فيزول بسقوط الخصومة أو بانقضائها بالتقادم^(٢).

وقد يشتمل الحكم الواحد على قرارين أحدهما قطعي والثاني غير قطعي، كالحكم الذي يقرر مسؤولية المدعي عليه (قطعي) ويحيل مسألة تحديد التعويض على خبير (غير قطعي)^(٣).

٢- الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الصادر قبل الفصل فيه :

الحكم الفاصل في الموضوع هو الذي يفصل في الطلب أو الدفع الموضوعي^(٤)؛ كالحكم بالملكية في دعوى المطالبة بها، أو كالحكم بصحة العقد أو بطلانه في دعوى صحة العقد.

(١) المرجع السابق والصفحة نفسها.

(٢) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٦٥٥.

(٣) الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٦١٣.

(٤) مبادئ قانون القضائي المدني، أ.د/ وجدي راغب ص ٥٨٢.

أما الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع كالحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص، أو كالحكم الصادر في بطلان صحيفة الدعوى أو صحتها. فهي أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع.

وهذه الأحكام منها ما يؤدي إلى إنهاء الخصومة ومنها ما لا يؤدي إلى إنهاء الخصومة، مثلاً الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة يؤدي إلى إنهاء الخصومة، وإن كان صادراً برفض الدفع بعدم الاختصاص لا يؤدي إلى إنهاء الخصومة وكذلك الحكم بعدم قبول الدعوى يؤدي إلى إنهاء الخصومة والحكم برفض الدفع بعدم القبول لا يؤدي إلى إنهائها.

وتظهر أهمية هذا التقسيم في أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم في الموضوع بخلاف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وتنتهي الخصومة يجوز الطعن فيها فور صدورها متى كانت قابلة للطعن^(١).

٣- الأحكام الابتدائية والنهائية والباتية:

تنقسم الأحكام باعتبار مدى قابليتها للطعن فيها أمام محكمة أعلى إلى أحكام ابتدائية، وأحكام انتهائية، وأحكام باتية.

الحكم الابتدائي هو الحكم الذي تصدره محكمة أول درجة سواء كانت محكمة جزئية أو ابتدائية، ويكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف.

أما الحكم النهائي فهو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف ويشمل الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية في حدود النصاب النهائي لكل منهما، والأحكام التي يقرر المقنن عدم قابليتها للاستئناف، والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية باعتبارها محكمة ثاني درجة، والأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.

(١) أصول المرافعات، أ.د/ أحمد مسلم، ص ٦٧١.

أما الحكم البات فهو الحكم الذي لا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية أو غير العادية. كالأحكام الاستثنائية التي لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض سواء كانت صادرة من محاكم الاستئناف العالی أم من المحاكم الكلية مثال ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية باعتبارها محاكم ثاني درجة فهذه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، فهي أحكام باتة.

وكذلك الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر ومضى ميعاد الطعن فتصبح أحكاماً باتة، وأيضاً أحكام النقض نفسها تعتبر باتة. أما الحكم النهائي القابل للطعن بالنقض فلا يعتبر باتاً رغم أنه حائز لقوة الأمر المقضى.

وتظهر أهمية التفرقة بين الأحكام الابتدائية والانتهازية والباتة في أمرين: الأول: في تحديد طرق الطعن، ذلك أن الأحكام الابتدائية تقبل الطعن بالاستئناف، أما الأحكام النهائية فلا تقبل الطعن إلا بطريق من طرق الطعن غير العادية (النقض والتماس إعادة النظر).

الثاني: في بيان مدى قابلية الحكم للتنفيذ الجبري، ذلك أن القاعدة أن الأحكام الانتهازية تقبل التنفيذ الجبري أما الأحكام الابتدائية فلا تقبل التنفيذ الجبري^(١) — كقاعدة —.

٤- الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية:

تنقسم الأحكام باعتبار حضور الخصوم أو غيابهم إلى أحكام حضورية وأخرى غيابية.

الحكم الحضورى هو الحكم الذي يصدر في مواجهة خصم حاضر حقيقة أو حكماً، ذلك أن الحكم يعتبر حضورياً إذا حضر الخصم جلسة من الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه في الدعوى أو غاب في أول جلسة ثم أعلن وأعذر بأنه إن لم يحضر يكون الحكم حضورياً، لأنه وإن كان الحكم صادراً في غياب المدعى عليه

(١) قانون المرافعات، أ.د/ أحمد هندی، ٤٣٨/٢.

إلا أنه يكون حكماً حضورياً اعتبارياً، أي أنه ليس حضورياً حقيقة ولكنه حضورى حكماً.

أما الحكم الغيابي فهو الذي يصدر في غياب الخصم.

وتظهر أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية والغيابية في أن الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة بينما لا يجوز ذلك بالنسبة للحكم الحضورى. وقد تضاعلت أهمية هذه التفرقة، بعد أن توسع قانون المرافعات الجديد في معنى الحكم الحضورى على النحو سالف الذكر، ولم يعد من المتصور صدور حكم غيابى في المسائل المدنية والتجارية يقبل الطعن بالمعارضة إلا في الأحوال التي أجاز فيها القانون ذلك. كما هو الحال في الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية^(١).

ويلاحظ أن الخصم الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وإن كان الحكم يعتبر حضورياً إذا تم إعداره إلا أن ميعاد الاستئناف لا يسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم (٢/٢١٣ مرافعات).

وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

وأيضاً إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ففي هذه الحالات لا يسرى ميعاد الطعن في الحكم الصادر ضده إلا من تاريخ إعلانه به^(٢).

(١) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٦٥٧.

(٢) المادة ٣/٢١٣ وانظر مبادئ المرافعات، أستاذى الدكتور عبد الباسط جمعى — يرحمه الله — ص ٣٩٧.

آثار الأحكام :

تترتب على صدور الأحكام آثار هامة، من وقت النطق بها في الجلسة، نجملها فيما يأتي:

١- خروج النزاع من ولاية المحكمة، إذا أصدرت المحكمة حكماً في الموضوع فإنها تكون قد أدت مهمتها واستنفدت ولايتها، ولا يجوز لها سحب الحكم الذي أصدرته ولا إحداث أي تغيير فيه أو إضافة إليه، فلا يجوز لها مثلاً أن تعود وتمنح المدين مهلة للوفاء بعد الحكم عليه بالدين، أو أن تقضى للمحكوم له بشمول حكمها السابق بالنفاذ المعجل^(١).

ويستثنى من ذلك ما يأتي:

(أ) جواز إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عن طريق الطعن فيه بالمعارضة أو بالتماس إعادة النظر فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تُعيد النظر في حكمها متى طعن فيه بالمعارضة — إذا كانت جائزة — أو بالتماس إعادة النظر^(٢).

(ب) تصحيح الحكم أو تفسيره أو استكمالها، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تعيد النظر فيما فصلت فيه بقصد تصحيح ما وقع في الحكم من أخطاء مادية أو حسابية، كأن تخطئ المحكمة في بيان اسم أحد الخصوم أو في عملية حسابية وقد نصت المادة (١٩١) مرافعات على أن «تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة».

(١) المرافعات المدنية والتجارية، أ.د/ محمد حامد فهمي ٢١٨/٢ هـ-٢.

(٢) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٧٠٥.

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال».

كما «يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم بتفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام. ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية»^(١).

و«إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه»^(٢) وهذا هو ما يسمى بالاستكمال أي استيفاء الحكم في الطلبات وفي الدعوى^(٣).

ويراعى أنه لا يجوز للمحكمة إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة في جوهر حكمها بحجة أنها تصحح أخطاءه المادية أو تفسر عباراته المبهمة، بل يجب أن يكون عملها قاصراً على محض التصحيح المادي أو التفسير.

وتفقد المحكمة حقها في تصحيح أحكامها أو تفسيرها متى طعن فيها بالاستئناف، إذ تصبح محكمة الدرجة الثانية هي المختصة دون سواها بمراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها^(٤).

٢ - تقرير الحقوق وإنشاؤها:

الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها، لأن المحكمة إذا قضت بملكية عين مثلاً لأحد الخصوم فإنما تقرر أنه مالك له من قبل دون خصمه

(١) المادة ١٩٢ مرافعات.

(٢) المادة ١٩٣ مرافعات.

(٣) مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي - يرحمه الله - ص ٣٩٩.

(٤) المرافعات المدنية والتجارية، أ.د/ محمد حامد فهمي، ٢/ ٢١٨.

ويبقى حق المحكوم له مستمداً من سند الملكية الذي تمسك به أمام المحكمة واعتمدت عليه في قضائها.

ولكن في بعض الأحوال تكون الأحكام منشئة لحق أو مركز قانوني لم يكن موجوداً من قبل، كالحكم بالإفلاس، أو بالتطبيق أو بالانفصال الجسماني، أو بتعيين حارس أو برسو المزداد.

وسواء كانت الأحكام مقررة أم منشئة فإن الحكم عموماً يعد سنداً قوياً للمحكوم له وقد يكون هو السند الوحيد إذا كان الحكم منشئاً، وقد يكون سنداً إضافياً إذا كان الحكم مقررراً^(١).

٣ - حجية الشيء المحكوم فيه:

الأثر الهام للحكم هو فضؤه الحاسم للنزاع، بحيث لا يجوز للمحكمة التي أصدرته، ولا لمحكمة غيرها أن تنتظر فيما قضى به مرة أخرى. وإنما يجوز الطعن في الحكم وإعادة طرح النزاع على ذات المحكمة أو محكمة أعلى إذا كان القانون يجيز ذلك.

وتتضمن حجية الأحكام قرينتين:

الأولى: قرينة الحقيقة، حيث يعد الحكم عنواناً للحقيقة فيما قضى به، بحيث لا يجوز إهدار هذه الحقيقة في أي مجال ولدى أي سلطة قانونية في الدولة. على أنها حقيقة نسبية فلا يحتج بها إلا بين الخصوم الذين كانوا طرفاً في الدعوى التي انتهت بالحكم ما لم تقض طبيعة الأشياء بغير ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام المنشئة حيث إن حقيقتها مطلقة.

الثانية: قرينة الصحة، بمعنى أن الحكم يفترض صدوره بناء على إجراءات صحيحة، وأنه متى صار له مظهر الحكم وكيانه لا يجوز الادعاء ببطلانه بدعوى أصلية^(٢)، والحكمة من تقرير هذه الحجية للأحكام ضرورة وضع حد للمنازعات تنتهي عنده ويمتنع تجديدها بعده، وحتى لا تتضارب الأحكام.

(١) أصول المرافعات، أ.د/ أحمد مسلم، ص ٦٧٧.

(٢) المرجع السابق ص ٦٧٧، ٦٧٨.

ولا ينفى عن الحكم حجيته كونه قابلاً للطعن فيه بطريق من طرق الطعن القانونية، فهو يكتسب الحجية فور صدوره ولو كان ابتدائياً. وتظهر الأهمية العملية للحجية عندما تعاد نفس المنازعة — في غير حالات الطعن — أمام المحكمة ذاتها أو أمام محكمة أخرى، فيكون للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ويعتبر الدفع بالحجية من النظام العام، لأن المقتن لم يقرر هذه الحجية لصالح الخصوم، وإنما قررها للصالح العام الذي يدعو إلى استقرار الحماية القضائية^(١).

الفرق بين حجية الشيء المحكوم فيه وبين قوة الشيء المحكوم فيه:

يجب عدم الخلط بين مصطلح حجية الشيء المحكوم فيه، ومصطلح قوة الشيء المحكوم فيه. ذلك أن الحكم إذا كان لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) ويوصف بأنه حكم نهائي، فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويصبح واجب التنفيذ أما حجية الشيء المحكوم فيه فهي تثبت للحكم حتى ولو كان ابتدائياً.

(١) قانون المرافعات، أ.د/ أحمد هندي، ٥٤٩/٢.

الفصل الثاني التقاضي بوسيلة العريضة

تمهيد وتقسيم:

يحصل اللجوء إلى القضاء بوسيلة من وسيلتين الأولى بدعوى ترفع إلى القضاء وتعلن إلى الخصم، والثانية بعريضة تقدم على القاضي. وتختلف وسيلة الدعوى عن وسيلة العريضة اختلافاً كبيراً.

ذلك أنه في وسيلة الدعوى يطلب المدعى من المدعى عليه الحضور أمام محكمة معينة في ميعاد معين. بينما في وسيلة العريضة تُقدم العريضة إلى القاضي دون أن يُطلب حضور أحد أمامه.

أيضاً في وسيلة الدعوى تسمع المحكمة طلبات المدعى ودفع المدعى عليه وتحقق فيهما بينما في وسيلة العريضة ينظر القاضي العريضة دون سماع أحد ودون تحقيق ما.

كذلك في وسيلة الدعوى يُقصد بها استصدار حكم فاصل في النزاع، بينما في وسيلة العريضة يُقصد بها استصدار أمر عليها^(١).

أما وقد تحدثنا في التقاضي بوسيلة الدعوى في الفصل الأول فإننا نتحدث في التقاضي بوسيلة العريضة في الفصل الثاني.

على أن المقنن فرض نظاماً جديداً للمطالبة القضائية وسماه «أوامر الأداء» وأوجب اتباع هذا النظام إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره. وأمر الأداء يشبه الأمر على عريضة في إجراءات استصداره.

ولذلك نص المقنن على الأوامر على العرائض في الباب العاشر من الكتاب الأول (التداعي أمام المحاكم) ثم نص على أوامر الأداء في الباب الحادي عشر.

ومن هنا فإننا نتحدث في الأوامر على العرائض في المبحث الأول، ثم في أوامر الأداء في المبحث الثاني.

(١) أصول المرافعات، أ.د/ أحمد مسلم، ص ٣٨٣.

المبحث الأول الأوامر على العرائض

تعريفها:

قرارات يصدرها القضاة على طلبات مكتوبة يقدمها أصحاب الشأن دون مواجهة بين الخصوم.

كالأمر بإجراء إعلان أو تنفيذ في غير المواعيد المنصوص عليها بالمادة (٧) مرافعات. وكالأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج (المادة ١٧) وكالأمر بإنقاص مواعيد الحضور المنصوص عليها بالمادة (٦٦) مرافعات وكالأمر بتوقيع الحجز التحفظي في الحالات التي يشترط فيها إذن القاضى بتوقيع الحجز التحفظي (المادة ٣١٩) وكالأمر بتقدير أجر حارس المنقولات المحجوزة (المادة ٣٦٧).

مجالاتها:

قبل تعديل المادة (١٩٤) مرافعات بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ كانت تنص على أنه «في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر...» ولذلك «ذهب رأي ... على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت في التشريع على سبيل الحصر في حين ذهب الرأي السائد قضاء وفقهاً إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح إصدار الأمر في كل حالة يرى القاضى أنها تحتاج إلى الحماية الوقائية بالإجراء الذي يراه مناسباً لهذه الحماية...»^(١).

أما بعد التعديل فأصبحت المادة (١٩٤) تنص على أنه «في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر...» ومن ثم قيدت سلطة القاضى في إصدار الأمر على عريضة، بحيث لا يكون له أن يصدر أمراً على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصدار هذا الأمر.

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

سلطة القضاة في إصدار الأوامر على العرائض:

الأصل أن وظيفة المحاكم هي فصل الخصومات فصلاً قضائياً حاسماً للنزاع، وهذا هو عملها الأصلي العادي الذي أنشئت من أجله وهي تباشر هذه الوظيفة بما يُسمى سلطتها القضائية.

وفي ممارسة القضاة لهذه الوظيفة يُصدرون أوامر للأفراد في الحالات التي يُجيز لهم القانون ذلك على النحو سالف الذكر. ويصدرون هذه الأوامر بمقتضى ما لهم من سلطة ولائية.

وعلى ذلك فللقاضي سلطة قضائية بمقتضاها يكشف عن الحق وينسبه لصاحبه ويوفر له الحماية بتوقيع الجزاء على من يعتدى على هذا الحق.

كما أن له سلطة ولائية بمقتضاها يُصدر الأوامر في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر. ذلك أن القاضي أحد ولاة الأمور ومن حقه إصدار الأوامر للأفراد باعتباره حاكماً أو والياً تجب على الرعية طاعته وتنفيذ أوامره.

ولهذا أعطى المقنن القضاة اختصاصاً بإصدار الأوامر إلى جانب اختصاصهم بإصدار الأحكام ويقرر الفقه في هذا الشأن أن القاضي حين يحكم فإنه يباشر سلطة القضائية أما حين يأمر فإنه يمارس سلطته الولائية^(١).

القاضي المختص بإصدار الأوامر على العرائض:

تنص المادة ١٩٤ مرافعات^(٢) على أنه «في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه على قاضى «الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنتظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين

(١) شرح قانون المرافعات، أ.د/ عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي —

يرحمه الله — ص ٣٩١.

(٢) معدل بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها».

وقد نصت المادة ٢٧٤ مرافعات معدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أنه «... ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ...».

وعلى هذا، إذا كان الأمر على عريضة يتعلق بالتنفيذ كالأمر بجني الثمار أو حصاد المحاصيل المحجوزة (المادة ٣٧٠ مرافعات) فيختص مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها بإصداره ما لم ينص القانون على ذلك^(١).

وإذا كان الأمر على عريضة يتعلق بدعوى منظورة أمام القضاء، يكون للطالب الخيار بين تقديم العريضة إلى قاضي الأمور الوقفية أو إلى رئيس الهيئة التي تنتظر الدعوى أما إذا كان الأمر على عريضة لا يتعلق بالتنفيذ ولا يتعلق بدعوى منظورة أمام القضاء فيختص به قاضي الأمور الوقفية وحده.

و«قاضي الأمور الوقفية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضياها».

وتقدم العريضة على المحكمة الجزئية أو الكلية حسب نصاب كل منهما، على أنه قد يوجد نص يقرر اختصاص قاضي الأمور الوقفية بالمحكمة الابتدائية بإصدار الأمر بصرف النظر عن قيمة النزاع^(٢).

كما يجب مراعاة الاختصاص المحلي، فإذا كان الأمر يتعلق باتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها، أما إذا كان الأمر يتعلق بالتنفيذ

(١) كاستصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي إذا كان حق الدائن يسرى عليه نظام أوامر الأداء (المادة ٢١٠).

(٢) كما هو الشأن في نص المادة (١/١٠٨٩) مدني والتي تقرر أنه «على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها».

فيختص به مدير إدارة التنفيذ التي يقع المال محل التنفيذ في دائرتها أو من يعاونه من قضاتها^(١).

إجراءات استصدار الأمر على عريضة:

تقدم عريضة إلى القاضى المختص وتكون محررة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وعلى أسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة، وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب.

ولا يلزم توقيع محامٍ على العريضة مهما بلغت قيمة الطلب. ويسدد طالب الأمر الرسوم اللازمة على العريضة حتى يمكن عرضها على القاضى^(٢).

ويطلع القاضى على العريضة وما يرفق بها من مستندات دون حضور الخصوم ودون مرافعة — كقاعدة —^(٣) و«يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لقديمها على الأكثر»^(٤) وهذا ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان.

وللقاضى سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه أو إجابة بعض الطلبات دون بعض حسب ما يرى القاضى بناء على أسباب الطلب ومستنداته.

«ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً»^(٥).

(١) مبادئ القضاء المدني، أ.د./ وجدي راغب، ص ٧٠٥؛ شرح قانون المرافعات، أ.د./ عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٣٩٩، ٤٠٠.

(٢) انظر المرجعين السابقين.

(٣) نصت المادة ٣١٩ في شأن توقيع الحجز التحفظي على أن «... وللقاضى قبل إصدار أمره أن يُجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب...».

(٤) المادة ١/١٩٥ مرافعات.

(٥) المادة ٢/١٩٥ مرافعات.

و«يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر»^(١) وهذا ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط.

سقوط الأمر على عريضة:

يفترض المقنن أن طالب الأمر يواجه خطراً ولجأ إلى القضاء لدفع هذا الخطر بأمر على عريضة ومن ثم يجب أن يُقدم هذا الأمر للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً، وإلا انتفت الحكمة من إصدار الأمر، ولذلك نص المقنن على أن «يسقط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد»^(٢).

التظلم من الأمر على عريضة:

يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر يستوى في ذلك طالب الأمر أو المأمور ضده أو غيرهما إذا أضر بهما الأمر الصادر.

ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز تقديم التظلم إلى المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي تختص بموضوع النزاع الذي يتصل به الأمر والتابع لها القاضي الذي أصدره^(٣).

كما «يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حال تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة»^(٤).

ويكون «لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة»^(٥).

(١) المادة ١٩٦ مرافعات.

(٢) المادة ٢٠٠ مرافعات.

(٣) الوسيط، أ.د./ أحمد السيد صاوي، ص ٧١٤.

(٤) المادة ١٩٨ مرافعات.

(٥) المادة ١/١٩٩.

ويجب رفع التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال^(١).

«وفي حالة قبول التظلم من أمر الرفض فإن المحكمة التي تنتظر التظلم تصدر الأمر المطلوب اختصاراً للإجراءات»^(٢).

وعلى ذلك فإن المحكمة تحكم في التظلم بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام.

ويراعى أن الحكم الصادر في التظلم حكم وقتي ومن ثم فهو لا يُقيد محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر، وأيضاً فهو يقبل الطعن فيه بالاستئناف مهما كانت قيمة الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر.

كما يراعى أن الحكم الصادر من قاضى الأمور الوقتية في التظلم المرفوع إليه يعتبر صادراً من المحكمة التي يتبعها هذا القاضى، وعلى ذلك إذا كان الحكم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية فإنه يستأنف أمام المحكمة الكلية، أما إذا كان صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية فإنه يستأنف أمام محكمة الاستئناف^(٣).

المبحث الثاني أوامر الأداء

تمهيد:

رأى المقنن أن هناك بعض الديون لا يحتاج تحقيقها إلى مواجهة بين الخصوم، نظراً لثبوتها بالكتاب ومن ثم يبعد أن تكون محل نزاع جدي، ولذلك وضع لها نظاماً مبسطاً ومختصراً لاقتضاها، ونص عليه لأول مرة في الباب

(١) المادة ٢/١٩٧ معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٢) المذكرة الإيضاحية للقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٣) الوسيط، أ.د/ فتحي والي، ص ٨٥٣، مبادئ قانون القضاء المدني، أ.د/ وجدي راغب، ص ٧٠٩.

الخامس من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٩ بعنوان «في استيفاء الديون الصغيرة الثابتة بالكتابة» وقد أخذ به المقنن «بحذر وفي حدود ضيقة ذلك أنه رغم مزاياه لم يكن نظاماً مألوفاً للتقاضي ولهذا جعل ولُوجَه جوازياً وقصره على الديون النقدية الصغيرة، وعندما بدأ العمل يَألف هذا النظام وتبين فوائده تدخل المشرع بالقانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٥٣، القانون رقم ٤٨٥ لسنة ١٩٥٣ على التوالي ليُجعله نظاماً وجوبياً وليعممه على كافة ديون النقود متى توافرت الشروط التي بينها القانون، وقد أدى هذا الوجوب والتعميم إلى نجاح كبير لهذا النظام فقد دلت الإحصائيات أن الغالبية العظمى من طلبات أوامر الأداء قد قُبِلت وأنه لم يُعَارَض في أوامر الأداء إلا بنسبة ضئيلة وأن معظم هذه المعارضة قد رفض، وبهذا أدى النظام إلى عدم تكس الجلسات بقضايا لم تكون هناك ضرورة تستوجب عرضها على المحاكم لوضوحها وخلوها من النزاع الجدى هذا فضلاً عن حصول الغالبية الكبرى من الدائنين بديون النقود الثابتة بالكتابة على حقوقهم في وقت قصير»^(١).

وقد حدا هذا النجاح بالمقنن إلى التوسع في نظام أوامر الأداء ولم يقصره على ديون النقود بل جعله شاملاً الدين الثابت بالكتابة الذي يكون محله تسليم منقول بنوعه ومقداره.

ولما صدر القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ توسع «في الحالات التي يتبع فيها نظام أوامر الأداء بحيث تشمل بجانب الديون التي يكون محلها مبالغ نقدية أو تسليم المنقول المعين بنوعه (المثلّيات) طلب تسليم المنقول المعين بذاته أيضاً متى توافرت فيه شروط إصدار الأمر...»^(٢).

شروط الحق الذي يجب اتباع نظام أوامر الأداء في المطالبة به:

يجب اتباع طريق أوامر الأداء إذا توافرت في الحق المطلوب الشروط

الآتية:

(١) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ١٣ لسنة ١٩٦٨.

(٢) المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

أولاً: أن يكون محل الحق المطلوب مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه.

وقد نصت المادة ١/٢٠١ مرافعات على أن «استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن... وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود... أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره». أما إذا كان المطلوب عقاراً أو منقولاً غير معين فترفع الدعوى بالطريق العادي، ذلك أن نظام أوامر الأداء استثناء من القواعد العامة، والاستثناء لا يُقاس عليه ولا يُتوسع فيه.

وما دام محل الحق مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بذاته كالسيارة رقم كذا أو معيناً بنوعه مثل كمية من القطن أو الأرز فلا أهمية بعد ذلك لطبيعته فيستوى أن يكون ديناً تجارياً أو مدنياً ولا أهمية أيضاً لمقداره صغيراً أو كبيراً ما دام المقدار محدداً^(١).

وإذا كان محل الحق المطلوب نقوداً وعقاراً أو عقاراً ومنقولاً أو منقولاً معيناً بذاته وآخر غير معين فإذا لم يكن بينهما ارتباط وجب على الدائن أن يتبع طريق أوامر الأداء لاقتضاء ما تتوافر فيه الشروط واتباع الطريق العادي لاقتضاء ما لا تتوافر فيه الشروط.

وأما إذا كان بينهما ارتباط فإنه يتعين اتباع الطريق العادي.

ثانياً: أن يكون حق الدائن ثابتاً بالكتابة، حتى ولو كانت قيمته ضئيلة، يستوى أن يكون ثابتاً في محرر رسمي أو محرر عرفي عليه توقيع المدين أو ختمه أو بصمة أصبعه.

وعلى ذلك إذا كان حق الدائن ثابتاً بوسيلة أخرى غير الكتابة كشهادة الشهود مثلاً وجب عليه أن يسلك الطريق العادي للمطالبة بهذا الحق.

(١) شرح قانون المرافعات، أ.د/ عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط الجميعي — يرحمه الله — ص ٤١٢، ٤١٣.

وإذا كان الدين ثابتاً بورقة تجارية فيجب اتباع طريق أوامر الأداء عند الرجوع على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضمان الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد حامل الورقة التجارية مطالبة واحد من غير هؤلاء كأن يطالب أحد المظهرين للورقة وجب على صاحب الحق اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى^(١) وكذا إذا أراد الرجوع على واحد من هؤلاء وواحد من غيرهم. **ثالثاً:** أن يكون محل الحق معين المقدار، بأن يكون مبلغاً معيناً من النقود، أو منقولاً معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة كالسيارة رقم كذا، أو منقولاً معيناً بنوعه تعييناً كافياً كخمسين أردباً من القمح الهندي.

وذلك حتى يمكن إصدار الأمر بالإلزام المدين بأداء قدر محدد من النقود أو منقول معين، أما إذا كان محل الحق غير معين المقدار وجب سلوك الطريق العادي لتحديد مقداره واستصدار حكم بالإلزام المدين بالمقدار الذي يحدده القاضي. ويعتبر محل الحق معين المقدار إذا كان لا يحتاج تعيينه إلا لعملية حسابية بسيطة^(٢).

رابعاً: أن يكون الحق حال الأداء، فلا يمكن استصدار أمر أداء بحق مؤجل، أو معلق على شرط، ذلك أن المطالبة القضائية لا تجوز بحق غير حال الأداء وطلب أمر الأداء هو مطالبة قضائية، وفضلاً عن ذلك فإن القانون ينص على وجوب تكليف المدين بوفاء الدين قبل استصدار الأمر، والتكليف بالوفاء لا يكون إلا عن دين حال.

خامساً: أن تكون المطالبة مبتدأة. يجب اتباع طريق أوامر الأداء للمطالبة بالحق الذي تتوافر فيه الشروط سالفة الذكر إذا كانت المطالبة مبتدأة، أما إذا قدمت المطالبة في صورة طلب عارض في دعوى أصلية، فإن ذلك يجوز ولا يجبر الدائن على سلوك طريق أوامر الأداء رغم توافر الشروط. كما لو رفع المشتري دعوى يطالب البائع بتسليم العقار مثلاً فيطالبه المدعى عليه بدفع خمسين ألف جنيه

(١) المادة ٢/٢٠١، ٣.

(٢) الوسيط، أ.د./ فتحي والي، ص ٨٥٦.

باقي الثمن الثابت بالكتابة. فهذا الطلب يقبل من المدعى عليه وإن لم يقدم بطريق أوامر الأداء، بل ويجوز أن يُقدم هذا الطلب شفاهة في الجلسة إذا كان الخصم حاضراً، كما يجوز أن يُبدى بصحيفة تعلن إلى المدعى على يد محضر قبل الجلسة المحددة وتحدد لها نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى الأصلية ولا يقال أن هذا الطلب قدم بغير الطريق القانوني وهو طريق أوامر الأداء، ذلك أن الدائن يجبر على سلوك هذا الطريق إذا كانت المطالبة مبتدأة^(١).

جزاء عدم اتباع نظام أوامر الأداء:

إذا توافرت الشروط سالفة الذكر وجب على صاحب الحق أن يسلك طريق نظام أوامر الأداء للمطالبة به، ذلك أن سلوك هذا الطريق إلزامي وليس اختيارياً، ومن ثم فإن سلوك الطريق الآخر يعد مخالفاً للقانون.

وعلى ذلك إذا رُفعت دعوى عادية للمطالبة بحق تتوافر فيه الشروط سالفة الذكر فإن المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً وهو طريق أوامر الأداء.

وهذا الجزاء يتعلق بالنظام العام فللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصم أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الإجراءات^(٢).

القاضي المختص بإصدار أمر الأداء:

وفقاً لنص المادة ٢٠٢ يستصدر الدائن أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع.

وعلى ذلك فالاختصاص النوعي بإصدار أمر الأداء يكون لقاضي المحكمة الجزئية أو رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية وفقاً للقواعد العامة.

(١) شرح قانون المرافعات، أ.د./ عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي —

يرحمه الله — ص ٤١٤، ٤١٥.

(٢) مبادئ قانون القضاء المدني، أ.د./ وجدي راغب، ص ٧١٣.

وتطبيقاً على ذلك، إذا كانت قيمة الطلب أربعين ألف جنيه فما دونها فإنه يقدم على قاضى المحكمة الجزئية، أما إذا زادت قيمته عن ذلك فإنه يقدم إلى رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية.

أما الاختصاص المحلي فينעד للمحكمة الجزئية أو الابتدائية التابع لها موطن المدين ما لم يقبل اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع.

إجراءات استصدار أوامر الأداء:

يلزم لاستصدار أمر الأداء اتباع الخطوات الآتية:

أولاً: تكليف المدين بالوفاء:

يجب «على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل... ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف».

وعلى ذلك فيجب على الدائن قبل أن يتقدم بطلب أمر الأداء أن يكلف مدينه الوفاء، فقد يبادر المدين بذلك، ويجنب نفسه والدائن مشقة القضاء.

وفي هذا التكليف اكتفى المقنن بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى المدين، ولم يشترط أن يكون التكليف بإعلان على يد محضر، تيسيراً على الدائن واختصاراً للإجراءات، ولكن لا مانع يمنع من أن يتم التكليف بالوفاء بإعلان على يد محضر، ويقوم بروتستو عدم الدفع في الأوراق التجارية مقام هذا التكليف.

ويجب على الدائن أن يمهل المدين فرصة كافية من الوقت ليتدبر أمره أو يدبر دينه، حتى يتفادى صدور الأمر، وقد حدد المقنن هذه المهلة بخمسة أيام لا بد أن تمضى بتمامها فهذا هو الحد الأدنى، ولا يجوز تقديم العريضة قبل انقضائها.

ثانياً: تحرير العريضة وتقديمها:

«يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختار له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان

مقيماً خارج هذه الدائرة تعين اتخاذ موطن يختار في البلدة التي بها مقر المحكمة»^(١).

ويُقدم الدائن أو وكيله العريضة على قلم كتاب المحكمة، ويُرفق بها السند المكتوب بالدين، وما يثبت حصول تكليف المدين بالوفاء، وهو إيصال علم وصول الخطاب، أو أصل الإعلان على يد محضر، أو بروتستو عدم دفع الورقة التجارية، كما يرفق أية مستندات أخرى يراها الدائن تؤيد طلبه.

ولا تقدم العريضة إلا بعد مضي خمسة أيام على استلام المدين للخطاب أو الإنذار المتضمن تكليفه بالوفاء، وإلا فإنه يتعين على القاضي أن يرفض غصدار الأمر.

ثالثاً: إجراءات إصدار أمر الأداء:

ينظر القاضي العريضة بدون جلسة، فلا يحضر طالب الأمر أو من يُطلب الأمر ضده أو الكاتب، ولا تتدخل النيابة حتى ولو توافرت حالة من حالات التدخل.

ويجب على القاضي أن يتخذ قراراً خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم العريضة، ولكن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط. وينحصر قرار القاضي في أحد أمرين.

الأول: إصدار أمر الأداء:

إذا رأى القاضي أن يجيب الطالب إلى كل طلباته فإنه يُصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة ويتضمن إلزام المدين بالدين ويبين المبلغ الواجب أدائه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، وكذا المصاريف. ولا يلزم القاضي بتسبيب الأمر.

الثاني: الامتناع عن إصدار الأمر:

«إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يُحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب

(١) المادة ٢/٢٠٣.

بإعلان خصمه إليها»^(١) وبذلك تتحول المطالبة القضائية على دعوى عادية. وإذا لم يحدد القاضى جلسة لنظر الدعوى فللدائن أن يطالبه بذلك لاستدراك ما فاتته.

وإذا اشتملت العريضة على جملة طلبات فلا يملك القاضى أن يجيب الطالب إلى بعضها دون بعض، فإما أن يجيب جميع الطلبات وإما أن يمتنع عن إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الموضوع. ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاز المعجل رفضاً لبعض الطلبات، ومن ثم يجوز للقاضى أن يرفض شمول الأمر بالنفاز المعجل ويصدر أمر الأداء بباقي الطلبات.

إعلان المدين بأمر الأداء:

بعد أن يُصدر القاضى أمر الأداء يقوم الدائن بسحب صورة تنفيذية من الأمر، وتحفظ النسخة الأصلية من العريضة بالمحكمة، بينما تسلم النسخة الثانية منها للدائن مؤشراً عليها بالأمر، مع توقيعها وختمها بخاتم المحكمة. ولا يجوز سحب المستندات التي أرفقت بالعريضة، بل تبقى لحين انتهاء ميعاد التظلم من أمر الأداء وذلك منعاً من التلاعب والعبث^(٢). ويجب على الدائن أن يُعلن المدين شخصياً أو في موطنه بصورة العريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر، وإلا تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن^(٣) فتزول العريضة وما ترتب عليها من آثار وأهمها قطع التقادم. وللدائن إذا أراد أن يطلب أمر أداء جديد برسم جديد إذا كان حقه الأصلي لا زال باقياً.

(١) المادة ١/٢٠٤.

(٢) شرح قانون المرافعات، أ.د/ عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور/ عبد الباسط جميعي — يرحمه الله — ص ٤١٨.

(٣) المادة ٢٠٥.

الطعن في أمر الأداء

للطعن في أمر الأداء طريقان:

الطريق الأول: التظلم من أمر الأداء:

يجوز للمدين أن يتظلم من أمر الأداء الصادر ضده خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه.

ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية وفقاً للقواعد العامة.

ويستطيع المدين أن يعلن الدائن بالتظلم في الموطن المختار الذي حدده الدائن في طلب أمر الأداء فإن لم يكن قد حدد موطناً مختاراً جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.

و«يعتبر المتظلم في حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن»^(١).

وتفصل المحكمة في التظلم بحكم يخضع للقواعد العامة للأحكام من حيث جواز الطعن فيه^(٢).

الطريق الثاني: استئناف أمر الأداء

يجوز الطعن في أمر الأداء بالاستئناف مباشرة، ويستأنف أمر الأداء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام المحكمة الاستئنافية وفقاً للقواعد العامة.

كما تسرى القواعد العامة في الاستئناف على استئناف أمر الأداء من حيث نصاب الاستئناف وإجراءاته وميعاده.

(١) المادة ٢٠٧.

(٢) مبادئ قانون القضاء المدني، أ.د./ وجدي راغب، ص ٧١٦.

ويبدأ ميعاد الاستئناف المباشر لأمر الأداء من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم أو الحكم في التظلم باعتباره كأن لم يكن. وفرض المسألة هنا أن الدائن يعلن أمر الأداء إلى المدين فلا يتظلم منه وإنما يستأنفه مباشرة ومن ثم يعتبر استئنافه لأمر الأداء تنازلاً عنه عن التظلم. ومن الممكن أن يستأنف المدين أمر الأداء من اليوم التالي لإعلانه ولكن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً إلى ما بعد انتهاء ميعاد التظلم وفوات الموعد المقرر قانوناً.

ونظراً لأن ميعاد التظلم عشرة أيام من تاريخ إعلان أمر الأداء وميعاد الاستئناف أربعون يوماً فيكون الحد الأقصى لاستئناف أمر الأداء خمسين يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان أمر الأداء للمدين. أما إذا كان المدين قد تظلم وحكم باعتباره التظلم كأن لم يكن فإن ميعاد الاستئناف وهو أربعون يوماً يبدأ من تاريخ هذا الحكم^(١).

(١) شرح قانون المرافعات، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي -
يرحمه الله - ص ٤٢٢.

الفصل الثالث

طرق الطعن في الأحكام

تمهيد وتقسيم:

قلنا فيما سبق إن للحكم القضائي حجية، بحيث يتمتع عرض النزاع مرة ثانية أمام القضاء، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية ومنعاً من تضارب الأحكام، وتقوم هذه الحجية على افتراض مؤداه أن الحكم عنوان الحقيقة.

وبالرغم من ذلك فإن الأحكام - في الواقع - عرضة لوقوع بعض الأخطاء فيها ومن العدل تصحيح هذه الأحكام.

وللعمل على استقرار المراكز القانونية قرر القانون أنه لا يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل عنه أو تغيره، وكذلك لا يجوز للخصوم رفع دعوى أصلية ببطالان الحكم.

واستجابة لضرورة تصحيح الأحكام رسم المقتن طرقاً يسلكها الخصوم للطعن في الأحكام وحدد لذلك مواعيد محددة وإذا انقضت دون أن يطعن في الحكم، أو طعن فيه واستنفدت طرق الطعن المقررة قانوناً أصبح هذا الحكم باتاً لا يجوز المساس به إطلاقاً.

تقسيم طرق الطعن:

تنقسم طرق الطعن إلى قسمين:

(أ) طرق طعن عادية.

(ب) طرق طعن غير عادية.

وطرق الطعن العادية هي المعارضة والاستئناف.

والمعارضة طريق عادي للطعن في الحالات التي ينص القانون على جواز

الطعن فيها بالمعارضة.

وأما طرق الطعن غير العادية فهي التماس إعادة النظر، والنقض.

وأساس هذا التقسيم أن القانون لا يحدد أسباباً معينة للطعن العادي بل يجوز

للمحكوم عليه أن يستأنف الحكم لأي سبب من الأسباب سواء كان متعلقاً بالوقائع أم

متعلقاً بالقانون ومن ثم لا يلزم الطاعن بإثبات حقه في الطعن، لأن الأصل جوازه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وتهدف طرق الطعن العادية إلى طرح النزاع الذي فصل فيه الحكم مرة أخرى على القضاء، وذلك سواء كان الحكم الطعون فيه معيباً أم غير معيب^(١).

بخلاف طرق الطعن غير العادية فقد حدد القانون الحالات التي يجوز فيها ولوج كل طريق منهما، ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر أو النقض إلا إذا توفر سبب من الأسباب التي حددها القانون.

ويجب على الطاعن أن يقيم الدليل على جواز حقه في الطعن. ويهدف الطعن بإحدى الطرق غير العادية إلى إصلاح عيب محدد في الحكم^(٢).

وللتفرقة بين طرق الطعن العادية وغير العادية نتائج عديدة أهمها ما يأتي:

- ١- طرق الطعن العادية تسبق طرق الطعن غير العادية، ومن ثم فلا يجوز الطعن بطرق الطعن غير العادية إلا في الأحكام النهائية (أي التي لا يجوز الطعن فيها بطريق من طرق الطعن العادية).
- وترتيباً على ذلك إذا كان الحكم ابتدائياً وأراد المحكوم عليه أن يطعن فيه فعليه أن يستأنفه ولا يجوز له أن يطعن فيه مباشرة بالتماس إعادة النظر أو النقض وإذا فوت ميعاد الاستئناف دون أن يستأنفه سقط حقه في طرق الطعن غير العادية.
- وذلك لأن طرق الطعن العادية أعم وأشمل من طرق الطعن غير العادية من حيث معالجتها لعيوب الأحكام ومن ثم لا يجوز اللجوء إلى الطرق غير العادية وهي طرق استثنائية إلا إذا كان الطريق العادي غير ممكن^(٣).

(١) الوسيط، أ.د. فتحي والي، ص ٦٦٥.

(٢) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٧٤٧.

(٣) مبادئ قانون القضاء المدني، أ.د. وجدي راغب، ص ٦١٠، ٦١١.

٢- طريق الطعن العادي يطرح النزاع من جديد أمام المحكمة التي تنتظر الطعن ومن ثم تكون لها سلطة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتنتظر النزاع من جميع جوانبه. بخلاف طريق الطعن غير العادي فهو لا يهدف إلا إلى معالجة عيوب محددة ومن ثم تقتصر سلطة المحكمة التي تنتظر الطعن على التحقق من هذه العيوب وإزالتها.

٣- إذا كان الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية أو طعن فيه بالفعل فلا يجوز تنفيذه جبراً إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو بأمر المحكمة.

وبالعكس إذا كان الحكم نهائياً (لا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية) فإنه يقبل التنفيذ الجبري - كقاعدة - ولا يمنع من تنفيذه قابليته للطعن فيه بطريق من طرق الطعن غير العادية أو الطعن فيه فعلاً بطريق من هذه الطرق ما لم تأمر المحكمة التي تنتظر الطعن بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.

ويراعى أن الطعن بالمعارضة والتماس إعادة النظر تنتظرهما المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أما الطعن بالاستئناف والنقض فتنتظرهما محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم.

ونتناول الحديث عن طرق الطعن في الأحكام - بالقدر المتاح - من خلال أربعة مباحث .

المبحث الأول: القواعد العامة في الطعن.

المبحث الثاني : الاستئناف.

المبحث الثالث: التماس إعادة النظر.

المبحث الرابع: النقض.

المبحث الأول

القواعد العامة في الطعن

نتحدث في هذا المبحث عن أشخاص الخصومة في الطعن وعن الأحكام التي يجوز الطعن فسخها وعن ميعاد الطعن ونخصص مطلباً لكل موضوع.

المطلب الأول

أشخاص الخصومة في الطعن

أشخاص الخصومة في الطعن هما الطاعن والمطعون ضده وقد يتعددون.

(أ) الطاعن:

تنص المادة (٢١١) علي أنه «لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم، أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون علي غير ذلك».

وعلى ذلك يشترط في الطاعن ما يأتي:

١- أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء كان مدعياً أم مدعاً عليه، وسواء أدخل في الدعوى أم تدخل فيها. ويجوز أن يكون خافاً عاماً أو خاصاً لخصم من الخصوم^(١). ومن ثم لا يقبل الطعن ممن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه، ووسيلته للدفاع عن مصلحته هي الاحتجاج بنسبية الشيء المقضي بمعنى أن الأحكام لا تقيد ولا تضر من لم يكن طرفاً فيها.

٢- أن تكون له مصلحة في الطعن، بأن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر برفض طلباته كلها أو بعضها أو ألزمه بشيء، أما إذا كان قد قضى له بكل طلباته فلا يقبل طعنه، بخلاف ما إذا صدر الحكم في شق منه في صالحه والآخر في غير مصلحته فإن طعنه يكون مقبولاً.

(١) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٧٤٩.

٣- ألا يكون قد قبل الحكم، فلا يجوز الطعن إذا كان الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً. فإذا أعلن المحكوم عليه صراحة قبوله الحكم أو تنازله عن حق الطعن فيه فلا يجوز له الطعن.

وكذلك إذا قبل الحكم ضمناً ويستفاد القبول الضمني من أي تصرف من المحكوم عليه يدل على قبوله للحكم، كأن يقوم بتنفيذ الحكم باختياره دون أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري بخلاف ما إذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري فتنفيذه لا يعد قبولاً للحكم.

وعموماً يجب أن يكون القبول واضحاً لا شك فيه لأن التنازل لا يفترض.

(ب) المطعون ضده:

يشترط في المطعون ضده أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن يكون الحكم قد صدر لصالحه ولو في جزء منه^(١).

(ج) تعدد الطاعنين والمطعون عليهم:

إذا تعدد المحكوم عليهم فمن المتصور أن يطعن بعضهم في الحكم ويفوت الآخرون ميعاد الطعن فيسقط حقهم فيه.

وإذا تعدد المحكوم لهم فقد يطعن المحكوم عليه في الحكم ضد بعضهم دون بعض عمداً أو إهمالاً، أو قد يرفع الطعن على بعضهم في الميعاد، ويفوت الميعاد بالنسبة للباقيين فيصبحون في مأمن من توجيه الطعن إليهم^(٢).

وقد نصت المادة ١/٢١٨ على أنه «فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه».

(١) شرح قانون المرافعات، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي - يرحمه الله - ص ٥٤١.

(٢) أصول المرافعات، أ.د. أحمد مسلم، ص ٦٨٨.

وقد أرست هذه الفقرة القاعدة العامة في ذلك وهي تطبيق لمبدأ نسبية أثر الإجراءات وعلى ذلك فلا يستفيد من الطعن إلا لمن رفعه ولا يحتج به إلا على من رفعه عليه.

ثم أوردت المادة ٢/٢١٨، ٣ استثناءين بحالات معينة وقررت عدم تجزئة موضوع الحكم بين الخصوم مما يعنى ضرورة بقاء الحكم أو تعديله أو إلغائه عن طريق الطعن بالنسبة لجميع الخصوم على السواء حتى لا تتعارض الأحكام على النحو الآتي:

الاستثناء الأول:

- ١- إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته مثل الحكم الصادر في دعوى قسمة بين شركاء.
 - ٢- إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن، كما إذا كان المدينون متضامنين وطعن في الحكم بعضهم.
 - ٣- إذا كان الحكم صادراً في دعوى يوجب القانون فيها اختصاص أشخاص معينين مثل دعوى استرداد المنقولات المحجوزة حيث «يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين...»^(١).
- ومثل الدعوى غير المباشرة، حيث يجب رفع الدعوى على المدين ومدين المدين (المادة ٢/٢٣٥ مدني) ومثل دعوى الشفعة حيث يجب رفع الدعوى على البائع والمشتري (المادة ٩٤٣ مدني) وموضوع هذه الدعاوى يكون غير قابل للتجزئة بحكم القانون.

فإذا تعدد المحكوم عليهم وطعن بعضهم في الحكم وفوت الآخرون ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم «جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه

(١) المادة ٣٩٤ مرافعات.

منضمّاً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن.

وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم^(١).

الاستثناء الثاني:

إذا طعن في الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية من الضامن أو طالب الضمان، فإنه يجوز لمن لم يطعن منهما أن يفيد من طعن زميله إذا كان دفاعهما واحداً في الدعوى الأصلية.

أما إذا كان الحكم قد صدر لصالحهما وطعن على أحدهما في الميعاد، جاز اختصام الآخر ولو بعد فوات الميعاد^(٢).

ويراعى أن انضمام من لم يطعن في الحكم إلي زميله أو اختصام من لم يوجه إليه الطعن هنا مسألة جوازية فتعدد الخصوم هنا ليس تعدداً إجبارياً على عكس الاستثناء الأول^(٣).

المطلب الثاني

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

نصت المادة ٢١٢ مرافعات^(٤) على أنه «لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها...»

ووفقاً لهذا النص فإن:

القاعدة العامة:

هي أنه لا يقبل الطعن إلا إذا كان الحكم منهيّاً للخصومة كلها.

(١) المادة ٢/٢١٨.

(٢) المادة ٣/٢١٨.

(٣) الوسيط أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٧٦٩.

(٤) معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

ويقصد بالحكم المنهي للخصومة الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى برمتها أو ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها، كالحكم الصادر في أصل الحق المدعى به، أو الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى، أو بسقوط الخصومة، أو بتركها.

أما إذا كان الحكم غير منه للخصومة كالحكم الصادر برفض الدفع لعدم الاختصاص، أو برفض الدفع بعدم القبول، أو برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو كالأحكام المتعلقة بالإثبات أو بالسير في الدعوى فهذه لا يجوز الطعن فيها فور صدورها. وإنما يطعن فيها مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. والحكمة من هذه القاعدة هي منع تجزئة الدعوى الواحدة، وتمزيق أوصالها مما قد ينتج عنه بسبب ذلك نوع تعارض في الأحكام، وتأخير الفصل في الدعاوى وإطالة أمد التقاضي وزيادة النفقات وتشعب الأمور وتعقيدها، فضلاً عن أن الحكم في أصل الحق قد يصدر لمصلحة من خسر المسألة الفرعية فيوفر عليه ذلك عناء الطعن في الحكم غير المنهي للخصومة.

هذه هي القاعدة العامة وقد نصت المادة ٢١٢ على الاستثناءات الآتية:
الاستثناءات التي يجوز فيها الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها.

أجاز المقتن الطعن في بعض الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فور صدورها دون انتظار لصدور الحكم في الموضوع وهي:

١- **الأحكام الوقتية والمستعجلة:** نظراً لأن لهذه الأحكام وضعها المستقل فإن بقاءها أو إلغائها في الطعن لا يؤثر على الموضوع، ومن ثم تنتفي الحكمة من منع الطعن به على الاستقلال.

٢- **الأحكام الصادرة بوقف الدعوى،** ذلك أن الطعن في هذه الأحكام لا يعطل الخصومة ولا يربكها بل إنه قد يؤدي إلي تعجيل السير فيها، ومن ناحية ثانية فلا محل للطعن فيها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة لانعدام

المصلحة عندئذ، ومن ثم فإن عدم جواز الطعن المباشر فيها يؤدي إلى نتيجة غير مقصودة للمقنن وهي عدم جواز الطعن فيها إطلاقاً^(١).

٣- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ويقصد بها أحكام الإلزام التي تصدر في شق من الموضوع إذا كانت نهائية أو مشمولة بالنفذ المعجل، ذلك أن قابلية الحكم للتنفيذ الجبري تجعل للمحكوم عليه مصلحة ملحة في الطعن علي استقلال دون انتظار الحكم المنهي للخصومة حتى يمكن للمحكوم عليه أن يتوقى التنفيذ الجبري.

٤- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة تطبيقاً للمادة ١١٠ مرافعات، فالأصل أنه لا يجوز الطعن في هذا الحكم فور صدوره، لأن الخصومة وإن انتهت به أمام المحكمة التي أصدرته غير أن الخصومة قائمة أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

وقد استثنى المقنن هذه الحالة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وأجاز بمقتضاها الطعن فيها فور صدورها، ونظراً لما قد يترتب على الطعن من إلغاء للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بينما تكون المحكمة المحالة إليها الدعوى قد قطعت شوطاً كبيراً فيها أو قد تكون فصلت فيها مما قد يؤدي إلى تضارب الأحكام. ولذلك أوجبت المادة ٢١٢ مرافعات على المحكمة المحالة إليها الدعوى في حالة الطعن في حكم عدم الاختصاص والإحالة أن توقف الدعوى حتى يفصل في الطعن.

وغنى عن البيان أن الدعوى لا تقف أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى إذا لم يطعن في الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لعدم وجود مبرر لوقفها.

(١) مبادئ قانون القضاء المدني، أ.د. وجدي راغب، ص ٦١٤.

ولكن لا يجوز الطعن في هذا الحكم بعد ذلك مع الحكم المنهي للخصومة كلها لسبق سقوط حق الطعن فيه^(١).

المطلب الثالث

ميعاد الطعن في الأحكام

يقصد بميعاد الطعن المدة الزمنية التي يجب أن يتم الطعن خلالها وإلا يسقط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها^(٢).

بدء الميعاد: نصت المادة ٢١٣ مرافعات على القاعدة في بدء الميعاد وعلى استثناءاتها على النحو الآتي:

القاعدة العامة:

«يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك...»

الاستثناءات:

(أ) نصت المادة ٢١٣ مرافعات^(٣) على حالات يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره وهذه الحالات هي:

١- إذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة

لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.

٢- إذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة

ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير

فيها لأي سبب من الأسباب.

٣- إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصاص

من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

(١) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٧٧٨، ٧٧٩.

(٢) المادة ٢١٥.

(٣) معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩.

هذا وقد أوجبت المادة ٢١٣ مرافعات أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك ضماناً لوصول خبر الحكم إليه، ومن ثم لا يجوز إعلان المحكوم عليه بالحكم في الموطن المختار في الخصومة التي انتهت بالحكم.

وتتص الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٣ على أن يجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم، بمعنى أن الميعاد يسرى في حق من أعلن إليه الحكم وفي حق من أعلنه، فإذا كان المحكوم عليه لا يسرى الحكم في مواجهته إلا من تاريخ إعلانه إليه لتوفر حالة من الحالات سالفة الذكر في حقه، وكان قد قام هو بإعلان الحكم للخصم نظراً للحكم له ببعض الطلبات في ذات الحكم. ولذلك فإن الميعاد يسرى في حقه من تاريخ إعلانه الحكم على أساس أنه قد أقام الدليل على علمه بالحكم.

(ب) حالات يبدأ فيها ميعاد الطعن من وقت آخر غير تاريخ صدور الحكم أو تاريخ إعلانه.

هناك حالات ينص فيها القانون على سريان ميعاد الطعن من وقت آخر غير تاريخ صدور الحكم أو تاريخ إعلانه وأهم هذه الحالات ما نصت عليه المادتان ٢٢٨، ٢٤٢ مرافعات من أنه «إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوتيه والذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهر فيه الورقة التي احتجزت»^(١).

وقف سريان الميعاد:

ميعاد الطعن في الأحكام من مواعيد السقوط، فلا تسرى عليها أسباب الوقف أو الانقطاع التي تسرى بالنسبة لمواعيد التقادم.

(١) المادة ٢٢٨ مرافعات وانظر الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٧٨٥

ولكن ميعاد الطعن يقف إذا قامت قوة قاهرة منعت المحكوم عليه من الطعن^(١).

وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، وذلك حتى لا ينقضي ميعاد الطعن في البحث عن أسماء الورثة ومواطنهم.

ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على النحو سالف الذكر وجب إعادة الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم، ويعلنون لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، قبل الجلية المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

وكذلك إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفى وزالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك^(٢).

إعلان الطعن:

نصت المادة ١/٢١٤ مرافعات على أنه «يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم». وعلى ذلك يجب أن يتم الإعلان لشخص المطعون ضده أو في موطنه الأصلي ولا يجوز — كقاعدة — إعلانه في موطنه المختار في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه، لاحتمال انقطاع صلته بهذا الموطن بعد صدور الحكم في الخصومة.

(١) شرح قانون المرافعات، أ.د. عبد المنعم الشرقاوي، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي -

يرحمه الله - ص ٥٤٤.

(٢) المادة ٢١٧ مرافعات.

ويجوز أن يتم إعلان الطعن في الموطن المختار في حالتين هما:

١- إذا كان المطعون ضده قد أعلن الحكم واتخذ لنفسه في ورقة إعلان الحكم موطناً مختاراً، لقيام قرينة قانونية على قبوله إعلانه بالطعن في هذا الموطن ولو لم يصرح بذلك.

٢- «وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة»^(١).

المبحث الثاني الاستئناف

الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام يترتب عليه طرح النزاع من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم. وقد سبق القول^(٢) بأن طرق الطعن العادية هي المعارضة والاستئناف، ويكاد يكون الاستئناف هو الطريق العادي الوحيد للطعن بعد إلغاء المعارضة فيما عدا حالات قليلة أقيمت فيها المعارضة كطريق للطعن.

والاستئناف هو تطبيق للمبدأ الهام «التقاضى على درجتين» نظراً لأن الأحكام القضائية عرضه لوقوع أخطاء بها لصدورها عن القضاة وهم بشر غير معصومين، ومن ثمَّ وجب إعادة النظر فيها — بناء على طلب الخصوم — أمام محكمة أعلى درجة لتصحيحه إن لم يكن صحيحاً، ولذلك فالاستئناف ضمانات هامة من ضمانات العدالة.

ونتحدث فيما يلي عن الأحكام التي يجوز استئنافها، ونصاب الاستئناف ، وتقدير قيمة الدعوي فيما يتعلق بنصاب الاستئناف، والأحكام التي يجوز استئنافها استثناءً، وتلك التي لا يجوز استئنافها استثناءً، وذلك علي النحو التالي:

(١) المادة ٢١٤/٢.

(٢) انظر «تقسيم طرق الطعن» في بداية الفصل الثالث.

أولاً : الأحكام التي يجوز استئنافها :

القاعدة هي جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى سواء كانت صادرة من المحكمة الجزئية أم من المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة.

ولكن المقنن قدر أن الدعاوى ضئيلة القيمة لا تستحق أن تنتظر على درجتين نظراً لصغر قيمتها توفيراً للنفقات وتجنباً لكيد الخصوم في مثل هذه الدعاوى صغيرة القيمة. ولذلك حدد نصاباً للأحكام التي يجوز استئنافها ومع ذلك فقد استثنى أحكاماً وأجاز استئنافها بالرغم من أنها دون النصاب، كما حدد أحكاماً أخرى ومنع استئنافها مع أنها داخلية في النصاب على النحو الآتي:

ثانياً : نصاب الاستئناف:

حدد المقنن نصاباً معيناً لمحاكم الدرجة الأولى وجعل الأحكام فيما دون ذلك أحكاماً نهائية لا تقبل الاستئناف.

وبالنسبة للمحاكم الجزئية يكون حكمها انتهاياً (لا يقبل الاستئناف) إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يستوى في ذلك الدعاوى التي تختص بها المحاكم الجزئية على أساس قيمة الدعوى أو على أساس نوعها. وبالنسبة للمحاكم الابتدائية يكون حكمها انتهاياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز أربعين ألف جنيه.

وعلى ذلك فالقاعدة أن الأحكام التي تقبل الاستئناف هي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في حدود اختصاصها الابتدائي، وهي الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه، والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه.

وقد نصت المادة ٢١٩ مرافعات على هذه القاعدة «للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي».

ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً».

ثالثاً : تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف:

«تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من ٣٦ — ٤١»^(١) ومع هذا أضاف المقنن بعض قواعد خاصة بنصاب الاستئناف وهي:

١- لا تحتسب في تقدير قيمة الدعوى الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. وعلى هذا إذا قدم المدعى عدة طلبات فأقر له المدعى عليه ببعضها ونازع في الباقي فتحتسب قيمة الدعوى على أساس الجزء المتنازع فيه، كما لو طلب تسليم السيارة وقيمتها ستين ألف جنيه والتعويض وقيمته عشرين ألف جنيه فأقر له المدعى بالسيارة ونازع في التعويض فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يقبل الاستئناف لأن قيمة الجزء المتنازع عليه عشرين ألف جنيه.

وكذلك لا تدخل في التقدير المبالغ المعروضة عرضاً حقيقياً كأن يطلب المدعى ستين ألف جنيه تعويضاً فيعرض المدعى عليه مبلغ أربعين ألف جنيه عرضاً حقيقياً.

٢- إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً في مواجهة طلب المدعي الأصلي كان تقدير قيمة الدعوى على أساس قيمة أكبر الطلبين الأصلي أو العارض^(٢). وعلى هذا إذا طالب المدعي بمبلغ يزيد عن ٤٠٠٠٠ أربعين جنيه، ثم تقدم المدعى عليه بطلب عارض عشرين ألف جنيه، فتقدر قيمة الدعوى بأربعين ألف جنيه.

(١) المادة ٢٢٣ مرافعات.

(٢) المادة ١/٢٢٤.

وقد استثنى المقتن من الحكم السابق حالة ما إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده^(١) حتى لا يتخذ المدعى عليه من طلب التعويض وسيلة لجعل الحكم قابلاً للاستئناف^(٢).

٣- «يكون التقدير ... على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى»^(٣) فلا عبرة بما يحكم به القاضي، فإذا طلب المدعى مبلغ عشرين ألف جنيه ولكن القاضي حكم بأربعة آلاف جنيه فإن الحكم يقبل الاستئناف.

٤- «جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى»^(٤) فالحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص يقبل الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن خمسة آلاف جنيه أما إذا كانت أقل من ذلك كان الحكم بعدم الاختصاص نهائياً لا يقبل الاستئناف.

رابعاً : الأحكام التي يجوز استئنافها استثناءً:

قلنا أن المقتن قد استثنى أحكاماً وجعلها قابلة للاستئناف أيّاً ما كانت قيمة الدعوى، أي ولو قلت قيمتها عن نصاب الاستئناف وهذه الأحكام هي:

١- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة.

«يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها»^(٥) أي سواء كانت صادرة من قاضى الأمور المستعجلة في دعوى مستقلة رفعت إليه، أو كانت صادرة من قاضى الموضوع في دعوى مستعجلة رفعت إليه على سبيل التبع للدعوى الموضوعية، أو كانت صادرة من قاضى التنفيذ في منازعة وقتية متعلقة بالتنفيذ.

(١) المادة ٢/٢٢٤.

(٢) مبادئ قانون القضاء المدني، أ.د/ وجدي راغب، ص ٦٢٨.

(٣) المادة ٢٢٥.

(٤) المادة ٢٢٦.

(٥) المادة ٢٢٠ مرافعات.

والحكمة في ذلك أن الأحكام المستعملة تصدر عادة بعد إطلاع سريع وسطحي على الأوراق، مع ما قد يترتب على هذه الأحكام من خطورة.

٢- الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم^(١).

وعلى ذلك يجوز استئناف الحكم النهائي إذا صدر من محكمة غير مختصة به ولائياً أو نوعياً، لأن الحكم إذا صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، لا يسوغ التحدى بنهائيته والقول بعدم استئنافه فشرط نهائيته عدم مخالفته لتلك القواعد^(٢).

وكذلك إذا وقع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لأن مثل هذا الحكم غير جدير بالبقاء ويكون الحكم باطلاً إذا شاب أحد عناصره عيب يبطله كما لو صدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً، أو صدر في جلسة سرية، أو صدر بدون توقيع القاضي.

كما يكون الحكم باطلاً إذا بُنيَّ على إجراءات باطلة كما لو كانت المطالبة القضائية باطلة، أو استند الحكم إلى إجراء باطل من إجراءات الإثبات^(٣).

و ضمناً لجدية الاستئناف أوجب القانون «... على المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.

(١) المادة ١/٢٢١.

(٢) الوسيط، أ.د/ أحمد السيد صاوي، ص ٨١١.

(٣) مبادئ قانون القضاء المدني، أ. د/ وجدي راغب، ص ٦٢٩.

ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حُكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان»^(١).

٣- الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.

إذا صدر من محكمة أول درجة حكم في حدود نصابها الانتهائي مخالفاً لحكم آخر سبق صدوره في الدعوى نفسها، وكان الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي عند صدور الحكم الجديد، فإنه يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الجديد لرفع التناقض بينه وبين الحكم السابق وفي هذه الحالة يُعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون.

أما إذا كان الحكم السابق قد صدر نهائياً عند رفع دعوى الاستئناف، فإنه لا يطرح أمام محكمة الاستئناف.

خامساً : الأحكام التي لا يجوز استئنافها استثناءً:

أورد المقتن حالات معينة ونص على عدم قابلية الحكم للاستئناف حتى ولو كانت قيمته تجاوز النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى. ومن ذلك، الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة الطلب الأصلي المقدم إليها مع الطلب العارض أو المرتبط إذا كان الطلب العارض أو المرتبط لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية (المادة ٤٦ مرافعات) وكذلك الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في دعوى المنازعة في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع (المادة ٢٩٥ مرافعات).

وكذلك يجوز للخصوم وفقاً لنص المادة ٢/٢١٩ أن يتفقوا، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً ويصدر الحكم في هذه الحالة نهائياً إذا اتفق جميع الخصوم.

(١) المادة ٢/٢٢١، معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢، بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩، والقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٥	المقدمة
٧	تمهيد
١١	أهمية قانون المرافعات
١١	طبيعة قانون المرافعات
١٣	التسميات المختلفة لقانون المرافعات
١٥	علاقة قانون المرافعات بقوانين الإجراءات الأخرى
١٦	خصائص قانون المرافعات
٢٣	الفصل الأول : المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء
٢٣	المبحث الأول : استقلال القضاء
٢٦	المبحث الثاني : مجانية القضاء
٢٧	مجانية القضاء في النظام القضائي الإسلامي
٢٨	المبحث الثالث : تعدد القضاة والقاضي الفرد
٢٩	موقف المقتن المصري من تعدد القضاة والقاضي الفرد
٣١	المبحث الرابع : المساواة أمام القضاء
٣١	المساواة أمام القضاء في النظام القضائي الإسلامي
٣٣	المبحث الخامس : علانية الجلسات
٣٩	المبحث السادس : حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم
٤١	المبحث السابع : حرية الدفاع والمناقشة
٤٢	حرية الدفاع والمناقشة في النظام القضائي الإسلامي
٤٣	المبحث الثامن : التقاضي على درجتين
٤٩	الفصل الثاني : ترتيب المحاكم وتشكيلها
٤٩	المبحث الأول : درجات المحاكم (طبقاتها)

الصفحة	الموضوع
٥٣	محكمة النقض
٥٥	المحكمة الدستورية العليا
٥٧	المبحث الثاني : تشكيل المحاكم
٦٢	الفصل الثالث : العاملون بالقضاء
٦٢	المبحث الأول : القضاة
٦٣	المطلب الأول : اختيار القاضي وشروطه
٦٣	الفرع الأول : اختيار القاضي
٦٥	الفرع الثاني : شروط تعيين القاضي
٦٨	المطلب الثاني : ضمانات القاضي
٦٩	الفرع الأول : ضمانات حماية القاضي من الحكومة
٧٧	الفرع الثاني : ضمانات حماية القاضي من الخصوم
٨٤	الفرع الثالث : ضمانات حماية القاضي من نفسه
٨٥	أولاً : منع القاضي من القيام ببعض الأعمال والتصرفات
٨٦	ثانياً : اعتبار القاضي غير صالح لنظر الدعوى
١٠٥	حماية القاضي من نفسه في النظام القضائي الإسلامي
١٠٦	المبحث الثاني : أعضاء النيابة العامة
١٠٩	وظيفة النيابة العامة أمام القضاء المدني
١١٢	حالات تدخل النيابة العامة
١١٥	المبحث الثالث : أعوان القضاء
١١٥	المطلب الأول : الكتاب وأمناء السر

الصفحة	الموضوع
١١٧	المطلب الثاني : المحضرون
١١٩	المطلب الثالث : المترجمان (المترجم)
١٢٠	المطلب الرابع : الخبراء
١٢٢	المطلب الخامس : المحامون
١٣٧	الباب الثاني : نظرية الاختصاص والإحالة
١٤٣	الفصل الأول : الاختصاص الولائي
١٤٤	المبحث الأول : مفهوم الاختصاص الولائي وأهميته
١٤٥	المبحث الثاني : موقف أعمال السيادة
١٤٨	سلطة القضاء على أعمال السيادة في النظام القضائي الإسلامي
١٥٠	المبحث الثالث : أنواع الاختصاص الولائي
١٥١	المطلب الأول : جهة القضاء العادي (المحاكم)
١٦٢	المطلب الثاني : جهة القضاء الإداري (محاكم مجلس الدولة)
١٦٥	المطلب الثالث : جهات القضاء ذات ولاية المحدودة (القضاء الاستثنائي)
١٧٠	الفصل الثاني : الاختصاص النوعي
١٧١	المبحث الأول : الاختصاص النوعي أهميته ومعايير
١٧٢	المبحث الثاني : القضاء المستعجل
١٨١	الفصل الثالث : الاختصاص القيمي
١٨٢	المبحث الأول : الاختصاص القيمي وأهميته

الصفحة	الموضوع
١٨٤	المبحث الثاني : تحديد قيمة الدعوى وأثره في تحديد المحكمة المختصة
١٨٥	المطلب الأول : القواعد العامة في تحديد قيمة الدعوى وأثر ذلك في تحديد الاختصاص
١٨٥	الفرع الأول : قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلب الواحد
١٨٥	القاعدة الأولى : العبرة بقيمة الشيء المطلوب الحكم به .
١٨٧	القاعدة الثانية : العبرة بقيمة المطلوب وقت رفع الدعوى .
١٨٨	القاعدة الثالثة: العبرة بقيمة الطلب المتنازع فيه
١٩٠	القاعدة الرابعة : العبرة بالطلب الختامي للمدعى
١٩٣	القاعدة الخامسة: العبرة بما يكون مستحقاً يوم رفع الدعوى
١٩٤	الفرع الثاني : قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلبات المتعددة
١٩٧	المطلب الثاني : كيفية تقدير قيمة الدعوى
١٩٧	القاعدة الأولى : الدعاوى العقارية
١٩٨	القاعدة الثانية : الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار .
١٩٩	القاعدة الثالثة : الدعاوى المتعلقة بالحكر .
٢٠٠	القاعدة الرابعة : الدعاوى المتعلقة بالحيازة .
٢٠٠	القاعدة الخامسة : الدعاوى المتعلقة بالإيراد المرتب
٢٠٠	القاعدة السادسة : الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل .

الصفحة	الموضوع
٢٠١	القاعدة السابعة : الدعاوى المتعلقة بعقود غير مستمرة .
٢٠١	القاعدة الثامنة : الدعاوى المتعلقة بعقود مستمرة .
٢٠١	القاعدة التاسعة : الدعاوى المتعلقة بالحجز والتأمينات العينية .
٢٠٢	القاعدة العاشرة : الدعاوى المتعلقة بصحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية
٢٠٤	الفصل الرابع : الاختصاص المحلى
٢٠٥	المبحث الأول : مقصود الاختصاص المحلى وأهميته تحديده
٢٠٧	المبحث الثانى : قواعد الاختصاص المحلى
٢٠٨	أولاً: القاعدة العامة: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه
٢١١	الأسباب القانونية التى تبرر اختصاص محكمة موطن المدعى عليه كقاعدة عامة.
٢١٢	ثانياً : القواعد الخاصة فى الاختصاص المحلى
٢٢٥	الفصل الخامس : مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام والآثار المترتبة عليه
٢٢٦	المبحث الأول : مدى تعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام والآثار المترتبة على ذلك
٢٢٩	المبحث الثانى : مدى تعلق قواعد الاختصاص المحلى بالنظام العام وآثاره
٢٣٦	الفصل السادس : الإحالة
٢٣٧	المبحث الأول : الإحالة وأحكامها
٢٤٤	المبحث الثانى : الآثار الإجرائية المترتبة على الإحالة
٢٥٥	الباب الثالث : نظرية الدعوى والخصومة القضائية

الصفحة	الموضوع
٢٥٦	الفصل الأول : ماهية الدعوى وطبيعتها القانونية
٢٥٦	المبحث الأول : ماهية الدعوى
٢٥٨	المبحث الثاني : طبيعة الدعوى
٢٦٣	المبحث الثالث : التفرقة بين الدعوى وما يشتبه بها
٢٦٧	المبحث الرابع : خصائص الدعوى وعناصرها
٢٦٧	المطلب الأول : خصائص الدعوى
٢٦٩	المطلب الثاني : عناصر الدعوى
٢٧٤	الفصل الثاني : شروط قبول الدعوى
٢٧٤	المبحث الأول : تحديد شروط قبول الدعوى
٢٧٦	المبحث الثاني : المصلحة
٢٧٧	المبحث الثالث : أوصاف المصلحة
٢٧٧	المطلب الأول : المصلحة القانونية
٢٨٠	المطلب الثاني : المصلحة القائمة الحالة
٢٩٢	المطلب الثالث : المصلحة الشخصية المباشرة
٣٠١	الفصل الثالث : تقسيمات الدعاوى
٣٠١	المبحث الأول : تقسيم الدعاوى باعتبار الحقوق التي تحميها
٣٠٣	المبحث الثاني : تقسيم الدعاوى باعتبار طبيعة الشيء المطلوب بها
٣٠٨	الفصل الرابع : دعاوى الحيابة

الصفحة	الموضوع
٣٠٩	المبحث الأول : دعوى منع التعرض
٣١٠	الشرط الأول : أن يكون المدعي حائزاً حيازة قانونية .
٣١٢	الشرط الثاني : أن تكون الحيازة خالية من العيوب
٣١٤	الشرط الثالث : أن ترد الحيازة على عقار أو حق يجوز تملكه بمضي المدة
٣١٤	الشرط الرابع : أن تستمر حيازة الحائز هادئة ظاهرة واضحة لمدة لا تقل عن عام قبل وقوع التعرض .
٣١٥	الشرط الخامس : أن يكون المدعي عليه قد تعرض للمدعي في حيازته
٣١٦	الشرط السادس : أن ترفع دعوى منع التعرض في خلال سنة من وقوع التعرض ، وإلا سقط حق الحائز في رفعها ولم يبق له إلا دعوى الملكية يرفعها بطلب أصل الحق على العين .
٣١٦	المبحث الثاني : دعوى وقف الأعمال الجديدة
٣١٨	المبحث الثالث : دعوى استرداد الحيازة
٣١٨	الشرط الأول : الحيازة
٣١٨	الشرط الثاني : أن يقع سلب للحيازة .
٣١٩	الشرط الثالث : أن ترفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة
٣٢٠	المبحث الرابع : قاعدة عدم الجمع بين الحيازة والحق
٣٢٥	المبحث الخامس : الحماية الوقتية للحيازة
٣٢٩	الباب الرابع : إجراءات التقاضي
٣٣٠	الفصل الأول : التقاضي بوسيلة الدعوى
٣٣١	المبحث الأول : رفع الدعوى وإعلانها وأوراق ومواعيد المرافعات

الصفحة	الموضوع
٣٣١	المطلب الأول : رفع الدعوى وقيدتها
٣٣٦	المطلب الثاني : إعلان صحيفة الدعوى
٣٣٧	المقصود بالإعلان وأهميته
٣٣٨	أحكام عامة في الإعلانات
٣٣٨	التظلم من قرار النيابة في منازعات الحيابة
٣٤٠	تسليم الإعلان
٣٤٠	أولاً : تسليم الإعلان إلى المعلن شخصياً
٣٤١	ثانياً : تسليم الإعلان في الموطن المختار
٣٤٢	ثالثاً : تسليم الإعلان في الموطن الأصل للمعلن إليه
٣٤٣	رابعاً : تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة
٣٤٥	خامساً : تسليم الأوراق للنيابة العامة
٣٤٩	سادساً : إعلان السجناء
٣٤٩	سابعاً : إعلان بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها
٣٥٢	الأشخاص المعنوية الخاصة
٣٥٢	الشركات التجارية
٣٥٢	الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية
٣٥٣	(ح) الشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل بمصر .
٣٥٤	المطلب الثالث : مواعيد المرافعات

الصفحة	الموضوع
٣٦٠	المبحث الثاني : حضور الخصوم وغيابهم
٣٦٠	المطلب الأول : حضور الخصوم
٣٦٣	المطلب الثاني : غياب الخصوم
٣٦٨	المبحث الثالث : إجراءات الجلسات ونظامها
٣٧١	المبحث الرابع : الطلبات والدفع
٣٧١	المطلب الأول : الطلبات
٣٧٣	أنواع الطلبات العارضة
٣٧٤	أولاً: الطلبات العارضة من المدعى (الطلبات الإضافية)
٣٧٥	ثانياً: الطلبات العارضة من المدعى عليه (دعوى المدعى عليه)
٣٧٦	ثالثاً: الطلبات العارضة من شخص خارج عن الخصومة (التدخل في الدعوى)
٣٧٩	رابعاً: الطلبات العارضة لإدخال شخص في الخصومة (اختصاص الغير)
٣٨٤	المطلب الثاني : الدفع
٣٨٤	أولاً: الدفع الموضوعية
٣٨٥	ثانياً: الدفع بعدم القبول
٣٩٢	أهم الفروق بين الدفع بعدم القبول والدفع بعدم الاختصاص
٣٩٣	المبحث الخامس : عوارض الخصومة
٣٩٤	المطلب الأول : العوارض التي تؤدي إلى عدم سير الخصومة

الصفحة	الموضوع
٣٩٤	الفرع الأول : وقف الخصومة
٤٠١	الفرع الثاني : انقطاع الخصومة
٤٠٥	المطلب الثاني: العوارض التي تؤدي إلى انقضاء الخصومة بغير حكم
٤٠٦	الفرع الأول : سقوط الخصومة
٤٠٦	شروط الحكم بسقوط الخصومة
٤٠٨	كيف يتم إسقاط الخصومة
٤٠٩	آثار الحكم بسقوط الخصومة
٤١١	الفرع الثاني : انقضاء الخصومة بمضى المدة (بالتقادم)
٤١٢	التمسك بانقضاء الخصومة بمضى المدة
٤١٣	الفرع الثالث : ترك الخصومة أو التنازل عنها
٤١٦	المبحث السادس : الأحكام القضائية
٤١٧	تقسيمات الأحكام
٤١٧	١- الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية
٤١٨	٢- الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الصادر قبله
٤١٩	٣- الأحكام الابتدائية والنهائية والباطة
٤٢٠	٤- الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية
٤٢٦	الفصل الثاني : التقاضي بوسيلة العريضة

الصفحة	الموضوع
٤٢٧	المبحث الأول : الأوامر على العرائض
٤٣٢	المبحث الثاني : أوامر الأداء
٤٤٠	الطعن في أمر الأداء
٤٤٢	الفصل الثالث : طرق الطعن في الأحكام
٤٤٥	المبحث الأول : القواعد العامة في الطعن
٤٤٥	المطلب الأول : أشخاص الخصومة في الطعن
٤٤٨	المطلب الثاني : الأحكام التي يجوز الطعن فيها
٤٥١	المطلب الثالث : ميعاد الطعن في الأحكام
٤٥٤	المبحث الثاني : الاستئناف
٤٥٥	الأحكام التي يجوز استئنافها
٤٥٧	الأحكام التي يجوز استئنافها استثناءً
٤٥٩	الأحكام التي لا يجوز استئنافها استثناءً
٤٦١	فهرس الموضوعات

تم بحمد الله ،،،